

29ª EDIÇÃO
2025

Pedro Lenza

DIREITO CONSTITUCIONAL

Inclui MATERIAL
SUPLEMENTAR



COLEÇÃO
**ESQUE
MATI
ZADO®**



LIVRO VIVO®

saraiva **jur**

SUMÁRIO

Folha de rosto

Estudo interativo

Uma Homenagem Especial

Mais uma Homenagem Especial

Uma Nova Homenagem Especial

Mais uma Nova Homenagem Especial

Agradecimentos

Nota do Autor à 28.^a Edição

Apresentação à 1.^a edição

1 – (Neo)Constitucionalismo

1.1. Alocação do Direito Constitucional

1.1.1. A classificação em “ramos do direito”

1.1.2. A superação da dicotomia “público-privado” —
constitucionalização do direito privado

1.2. Constitucionalismo

1.2.1. Conceito

1.2.2. Evolução histórica

1.2.2.1. Constitucionalismo durante a Antiguidade

1.2.2.2. Constitucionalismo durante a Idade Média

1.2.2.3. Constitucionalismo durante a Idade Moderna

1.2.2.4. Constitucionalismo norte-americano

- 1.2.2.5. Constitucionalismo moderno (durante a Idade Contemporânea)
- 1.2.2.6. Constitucionalismo contemporâneo (durante a Idade Contemporânea) “atenado” com a ideia de “constitucionalismo globalizado”
- 1.2.2.7. Constitucionalismo do futuro: o que podemos esperar?
- 1.2.3. Esquematização do constitucionalismo
- 1.3. Neoconstitucionalismo
 - 1.3.1. Aspectos iniciais
 - 1.3.2. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo
 - 1.3.3. Marcos fundamentais para se chegar a um “novo direito constitucional” (neoconstitucionalismo)
- 1.4. O novo constitucionalismo democrático latino-americano. Constitucionalismo pluralista (andino ou indígena). Estado plurinacional e intercultural
- 1.5. Constitucionalismo e soberania popular
 - 1.5.1. Aspectos gerais
- 1.6. Constitucionalismo popular (Tushnet) — “Judicial Review” — “Teorias do diálogo constitucional” (Bateup) e “Os papéis das Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais nas Democracias Contemporâneas” (Barroso)
 - 1.6.1. Constitucionalismo popular: perspectivas
 - 1.6.2. Supremacia judicial “versus” soberania judicial: a nossa posição no sentido do diálogo constitucional
 - 1.6.3. Reversão (superação) legislativa da jurisprudência da Corte: possibilidade de mutação constitucional pela via legislativa

- 1.6.4. “Os papéis das Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais nas democracias contemporâneas” (Luís Roberto Barroso)
- 1.7. Constitucionalismo democrático e “backlash” (reação social em razão de decisão da Corte)
- 1.8. “Constitucionalismo Abusivo” (David Landau): um alerta que preocupa E NÃO SE CONFUNDE COM O DENOMINADO “CONSTITUCIONALISMO AUTORITÁRIO” (MARK TUSHNET)
- 1.9. Material digital exclusivo

2 – Constituição: Conceito, Constitucionalização Simbólica, Classificações, Elementos e Histórico

- 2.1. Conceito
 - 2.1.1. Sentido sociológico
 - 2.1.2. Sentido político
 - 2.1.3. Sentido material e formal
 - 2.1.4. Sentido jurídico
 - 2.1.5. Sentido culturalista
 - 2.1.6. Constituição aberta
 - 2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país?
 - 2.1.7.1. Constituição-lei
 - 2.1.7.2. Constituição-fundamento (Constituição-total)
 - 2.1.7.3. Constituição-moldura
 - 2.1.7.4. Constituição dúctil (Constituição maleável, suave) (“Costituzione mite” — Gustavo Zagrebelsky)

- 2.2. “Crowdsourced constitution”: o legado da experiência pioneira da Islândia (2011)
- 2.3. Constitucionalização simbólica
 - 2.3.1. Aspectos iniciais
 - 2.3.2. Legislação simbólica
 - 2.3.2.1. Confirmação de valores sociais
 - 2.3.2.2. Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à solução dos problemas sociais (legislação-álibi)
 - 2.3.2.3. Adiamento da solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios
 - 2.3.2.4. Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica
 - 2.3.3. Constitucionalização simbólica
 - 2.3.4. Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico
 - 2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das normas constitucionais
- 2.4. Classificação (tipologia)
 - 2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”
 - 2.4.2. Quanto à forma
 - 2.4.3. Quanto à extensão
 - 2.4.4. Quanto ao conteúdo
 - 2.4.5. Quanto ao modo de elaboração
 - 2.4.6. Quanto à alterabilidade
 - 2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)
 - 2.4.8. Quanto à dogmática
 - 2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência)

- 2.4.10. Quanto ao sistema
- 2.4.11. Quanto à função
- 2.4.12. Quanto à origem de sua decretação: heterônomas (heteroconstituições) x autônomas (“autoconstituições” ou “homoconstituições”)
- 2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves Ferreira Filho)
- 2.4.14. Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) — conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)
- 2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)
- 2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988

2.5. Elementos das Constituições

2.6. Histórico das Constituições Brasileiras

- 2.6.1. Constituição de 1824
- 2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da República
- 2.6.3. Constituição de 1891
- 2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República
- 2.6.5. Constituição de 1934
- 2.6.6. Constituição de 1937
- 2.6.7. Constituição de 1946
- 2.6.8. Golpe Militar de 1964
- 2.6.9. Constituição de 1967
- 2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969
- 2.6.11. Constituição de 1988

2.7. Material digital exclusivo

3 – Hermenêutica: Muta  o X reforma. Regras x princ  pios. “derrotabilidade”. Postulados Normativos. Cria  o judicial do direito. Estrutura da Constitui  o

3.1. Muta  es constitucionais “versus” reformas constitucionais

3.2. Regras e princ  pios

3.3. Derrotabilidade (“defeasibility”)

3.4. Normas de segundo grau: postulados normativos

3.5. M  todos de interpreta  o

3.5.1. M  todo jur  dico ou hermen  utico cl  ssico

3.5.2. M  todo t  pico-problem  tico (ou m  todo da t  pica)

3.5.3. M  todo hermen  utico-concretizador

3.5.4. M  todo cient  fico-espiritual

3.5.5. M  todo normativo-estruturante

3.5.6. M  todo da compara  o constitucional

3.6. princ  pios da interpreta  o constitucional

3.6.1. Princ  pio da unidade da Constitui  o

3.6.2. Princ  pio do efeito integrador

3.6.3. Princ  pio da m  xima efetividade

3.6.4. Princ  pio da justeza ou da conformidade (exatid  o ou corre  o) funcional

3.6.5. Princ  pio da concord  ncia pr  tica ou harmoniza  o

3.6.6. Princ  pio da for  a normativa

3.6.7. Princ  pio da interpreta  o conforme a Constitui  o

- 3.6.8. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade
- 3.7. limites da interpretação constitucional
 - 3.7.1. Decisões interpretativas em sentido estrito
 - 3.7.1.1. Sentença interpretativa de rechaço (repelir/contrapor)
 - 3.7.1.2. Sentença interpretativa de aceitação
 - 3.7.2. Decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)
 - 3.7.2.1. Sentenças aditivas (ou sentenças manipulativas de efeito aditivo). Declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo
 - 3.7.2.2. Sentenças substitutivas (declaração de inconstitucionalidade com efeito substitutivo)
 - 3.7.3. Lacuna constitucional e o “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF
 - 3.7.4. Críticas ao “pamprincipiologismo” (Lenio Streck) e a realidade de uma inegável “Supremocracia” (Oscar Vilhena Vieira)
 - 3.7.5. Desacordo moral razoável
- 3.8. teoria dos poderes implícitos
- 3.9. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição
- 3.10. Estrutura da constituição
 - 3.10.1. Preâmbulo
 - 3.10.1.1. Esquematização
 - 3.10.1.2. Qual a natureza jurídica do preâmbulo? Tem ele relevância jurídica?

3.10.1.3. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios? Referida previsão enfraquece a laicidade do Estado brasileiro?

3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)

3.10.2.1. Apontamentos gerais sobre o ADCT

3.10.2.2. Finalidade do ADCT

3.10.2.3. Classificação das disposições do ADCT

3.10.2.4. O natural exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento

3.10.2.5. Qual a natureza jurídica das disposições do ADCT?

3.10.2.6. As disposições do ADCT estão imunes ao poder de reforma?

3.11. Material digital exclusivo

4 – Poder Constituinte

4.1. Esquema geral

4.2. Conceito e titularidade

4.3. Hiato constitucional (revolução — mutação — reforma — hiato autoritário)

4.4. Poder constituinte originário (genuíno ou de 1.º grau)

4.4.1. Conceito

4.4.2. Uma subdivisão

4.4.3. Características

4.4.4. Poder constituinte originário formal e material

- 4.4.5. Formas de expressão
- 4.4.6. A proposta de convocação de uma “assembleia nacional constituinte exclusiva e específica” para a reforma política: aberração jurídica; violência ao sistema
- 4.4.7. “Lipoaspiração constitucional” e a proposta de realização de plebiscito para a elaboração de uma nova Constituição
- 4.5. Poder constituinte derivado (instituído, constituído, secundário, de 2.º grau ou remanescente)
 - 4.5.1. Conceito e espécies
 - 4.5.2. Poder constituinte derivado reformador
 - 4.5.3. Poder constituinte derivado decorrente
 - 4.5.3.1. Estados-Membros
 - 4.5.3.2. Distrito Federal
 - 4.5.3.3. Municípios: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?
 - 4.5.3.4. Territórios Federais: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?
 - 4.5.4. Poder constituinte derivado revisor
- 4.6. Poder Constituinte Difuso
- 4.7. Poder Constituinte Supranacional
- 4.8. Nova Constituição e ordem jurídica anterior
 - 4.8.1. Recepção
 - 4.8.1.1. Inconstitucionalidade superveniente?
 - 4.8.1.2. Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de

controle de constitucionalidade, poderá ser recebida pela nova Constituição se com ela for compatível?

- 4.8.1.3. Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção
- 4.8.2. Repristinação
- 4.8.3. Desconstitucionalização
- 4.8.4. Recepção material de normas constitucionais
- 4.9. poder constituinte e direito adquirido. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL: máximo, médio ou mínimo?
- 4.10. Material digital exclusivo

5 – Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

- 5.1. Eficácia jurídica e eficácia social
- 5.2. Normas constitucionais de eficácia plena
- 5.3. Normas constitucionais de eficácia contida
- 5.4. Normas constitucionais de eficácia limitada
- 5.5. A classificação de “Maria Helena Diniz”
- 5.6. A classificação de “Celso Ribeiro Bastos” e “Carlos Ayres Britto”
- 5.7. Normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada
- 5.8. Normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais e o gradualismo eficaz das normas constitucionais

5.9. Eficácia e aplicabilidade na jurisprudência do STF

5.10. Material digital exclusivo

6 – Controle de Constitucionalidade

6.1. Controle de Constitucionalidade: direito comparado e sistema brasileiro

6.1.1. Noções preliminares

6.1.2. A inconstitucionalidade das leis e a regra geral da “teoria da nulidade”. Sistema austríaco (Kelsen) “versus” Sistema norte-americano (Marshall). Anulabilidade “versus” nulidade

6.1.3. Flexibilização das teorias da “nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional” e da “anulabilidade da norma inconstitucional” no direito estrangeiro (brevíssima noção)

6.1.3.1. Áustria

6.1.3.2. Estados Unidos

6.1.3.3. Espanha

6.1.3.4. Portugal

6.1.3.5. Alemanha

6.1.4. Flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro

6.1.4.1. A mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado — art. 27 da Lei n. 9.868/99 e art. 11 da Lei n. 9.882/99

6.1.4.2. A mitigação do princípio da nulidade no controle difuso

6.1.5. Constitucionalidade e inconstitucionalidade superveniente?

6.2. Breve análise evolutiva do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade

6.2.1. Constituição de 1824

- 6.2.2. Constituição de 1891
- 6.2.3. Constituição de 1934
- 6.2.4. Constituição de 1937
- 6.2.5. Constituição de 1946
- 6.2.6. Constituição de 1967 e EC n. 1/69
- 6.2.7. Constituição de 1988

6.3. Espécies de inconstitucionalidade e o “estado de coisas inconstitucional”

- 6.3.1. Inconstitucionalidade por ação e por omissão (quadro esquemático)
- 6.3.2. Vício formal (inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato)
 - 6.3.2.1. Inconstitucionalidade formal orgânica
 - 6.3.2.2. Inconstitucionalidade formal propriamente dita
 - 6.3.2.3. Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo
- 6.3.3. Vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário)
- 6.3.4. Vício de decoro parlamentar (?)
- 6.3.5. “Estado de coisas inconstitucional” (ECI)

6.4. Momentos de controle

- 6.4.1. Controle prévio ou preventivo
 - 6.4.1.1. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Legislativo
 - 6.4.1.2. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Executivo
 - 6.4.1.3. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Judiciário
 - 6.4.1.4. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Judiciário e a perspectiva das “normas constitucionais

interpostas” (Zagrebelsky)

6.4.2. Controle posterior ou repressivo

6.4.2.1. Controle político

6.4.2.2. Controle jurisdicional

6.4.2.3. Controle híbrido

6.4.2.4. Exceções à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo

6.4.2.4.1. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo

6.4.2.4.2. Controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo

6.4.2.4.3. “Órgãos administrativos autônomos de controle” (TCU, CNJ e CNMP) exercem controle de constitucionalidade?

6.5. Sistemas e vias de controle judicial

6.6. Controle difuso

6.6.1. Origem histórica: Marbury “versus” Madison, Sessão de fev. de 1803 (I, repertório de Cranch, 137-180)

6.6.2. Noções gerais

6.6.3. Controle difuso nos tribunais e a cláusula de reserva de plenário (“full bench”). Art. 97, CF/88

6.6.3.1. Regras gerais

6.6.3.2. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas do STF no julgamento de RE?

6.6.3.3. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais?

6.6.3.4. A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira instância?

6.6.4. Efeitos da decisão

- 6.6.4.1. Para as partes
- 6.6.4.2. Para terceiros (art. 52, X): visão clássica e tradicional do papel do Senado Federal no controle difuso considerando que não houve mutação constitucional
 - 6.6.4.2.1. Procedimento (art. 52, X) (visão clássica)
 - 6.6.4.2.2. Amplitude do art. 52, X (visão clássica)
 - 6.6.4.2.3. A expressão “no todo ou em parte” (art. 52, X) (visão clássica)
 - 6.6.4.2.4. Efeitos propriamente ditos (art. 52, X) (visão clássica)
 - 6.6.4.2.5. O Senado é obrigado a suspender os efeitos? (art. 52, X) (visão clássica)
- 6.6.5. Para terceiros (art. 52, X): mutação constitucional do papel do Senado Federal no controle difuso. Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso: análise crítica — abstrativização do controle difuso — tendência para uma maior expansividade das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais. Perspectivas do controle incidental em controle concentrado. Limitação do cabimento da reclamação
 - 6.6.5.1. Abstrativização do controle difuso: aspectos doutrinários
 - 6.6.5.2. Rcl 4.335: por 8 x 2 o STF não aceitou a tese da mutação constitucional do art. 52, X — decisão proferida na vigência do revogado CPC/73
 - 6.6.5.3. Valorização dos precedentes: a necessidade de se criar uma nova cultura
 - 6.6.5.4. Controle incidental em controle concentrado abstrato e o seu efeito “erga omnes” — eficácia da decisão do STF — ADI 4.029, j. 08.03.2012 — perspectivas para a mutação constitucional do art. 52, X, apesar de proferida incidentalmente em controle concentrado

- 6.6.5.5. ADIs 3.406 e 3.470, j. 29.11.2017, “DJE” de 1.º.02.2019 — mutação constitucional do art. 52, X (7 x 2) .
Entendimento reiterado no julgamento dos embargos de declaração (j. 23.02.2023, “DJE” de 02.05.2023)
- 6.6.5.6. Eficácia expansiva das decisões. Objetivação (“dessubjetivação”) do recurso extraordinário. Limites à reclamação constitucional. Inconstitucionalidades no CPC/2015?
- 6.6.5.7. REs 955.227 e 949.297 (j. 08.02.2023): a consagração do efeito “erga omnes” e vinculante nas decisões proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral — mutação constitucional do art. 52, X, CF/88
- 6.6.6. Controle difuso em sede de ação civil pública
- 6.7. Controle concentrado
 - 6.7.1. ADI genérica
 - 6.7.1.1. Conceito (ADI genérica)
 - 6.7.1.2. Objeto (ADI genérica)
 - 6.7.1.2.1. Leis
 - 6.7.1.2.2. Atos normativos
 - 6.7.1.2.3. Súmulas?
 - 6.7.1.2.4. Emendas constitucionais?
 - 6.7.1.2.5. Medidas provisórias?
 - 6.7.1.2.6. Regulamentos subordinados ou de execução e decretos?
Inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua
 - 6.7.1.2.7. Tratados internacionais
 - 6.7.1.2.8. Normas constitucionais originárias
 - 6.7.1.2.9. O fenômeno da recepção
 - 6.7.1.2.10. Atos estatais de efeitos concretos e atos estatais de efeitos concretos editados sob a forma de lei

(exclusivamente formal)

- 6.7.1.2.11. Ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida
- 6.7.1.2.12. Lei revogada ou que tenha perdido a sua vigência após a propositura da ADI — regra geral da prejudicialidade. O caso particular da fraude processual. Novas perspectivas: singularidades do caso (não prejudicialidade)
- 6.7.1.2.13. Alteração do parâmetro constitucional invocado. Novo precedente na linha de não ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria na hipótese de inadmitida constitucionalidade superveniente
- 6.7.1.2.14. Divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo
- 6.7.1.2.15. Respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral
- 6.7.1.2.16. Leis orçamentárias?
- 6.7.1.2.17. Resoluções do CNJ e do CNMP
- 6.7.1.2.18. Ato administrativo normativo genérico (ADI 3.202 — agravo regimental em processo administrativo)
- 6.7.1.3. Elementos essenciais do controle de constitucionalidade:
 - a) elemento conceitual (o conceito de “bloco de constitucionalidade”); b) elemento temporal
- 6.7.1.4. Teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes?) (“Ratio decidendi” — “holding” versus “obiter dictum” — “dictum”)
Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou
- 6.7.1.5. “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou inconstitucionalidade consequencial, ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”

- 6.7.1.6. Lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade”
 - 6.7.1.6.1. A instituição da Defensoria Pública pela CF/88 e a sua potencialização pela EC n. 80/2014
 - 6.7.1.6.1.1. A questão do “prazo em dobro” para a Defensoria Pública no processo penal — rejeição de inconstitucionalidade “rebus sic stantibus”
 - 6.7.1.6.1.2. Ação civil “ex delicto” ajuizada pelo MP — art. 68, CPP (lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção)
 - 6.7.1.6.2. Procedimento de aprovação das medidas provisórias: apreciação pela comissão mista nos termos do art. 62, § 9.º, CF/88. Arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput”, e §§ 1.º e 2.º, Res. n. 1/2002-CN
- 6.7.1.7. “Inconstitucionalidade circunstancial”
- 6.7.1.8. O efeito vinculante para o Legislativo e o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição”. Possibilidade de reversão legislativa da jurisprudência da Corte. A denominada “mutação constitucional pela via legislativa”
- 6.7.1.9. Criação do Município de Luís Eduardo Magalhães — ADI 2.240/BA — análise do voto do Min. Eros Grau. Contraponto: voto do Min. Gilmar Mendes — Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Efeito prospectivo. Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Dogma da nulidade da lei e garantia da segurança jurídica
- 6.7.1.10. Proibição do “atalhamento constitucional” e do “desvio de poder constituinte” (utilização de meio aparentemente legal buscando atingir finalidade ilícita)

- 6.7.1.11. Inconstitucionalidade “chapada”, “enlouquecida”, “desvairada”
- 6.7.1.12. Início da eficácia da decisão que reconhece a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei em processo objetivo de controle abstrato
- 6.7.1.13. Competência (ADI genérica)
 - 6.7.1.13.1. Lei ou ato normativo federal ou estadual em face da CF (art. 102, I, “a”)
 - 6.7.1.13.2. Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da CE (art. 125, § 2.º)
 - 6.7.1.13.3. Lei ou ato normativo municipal em face da CF
 - 6.7.1.13.4. Lei ou ato normativo distrital em face da CF/88
 - 6.7.1.13.5. Lei ou ato normativo distrital em face da Lei Orgânica Distrital
 - 6.7.1.13.6. Lei municipal em face da lei orgânica do Município
- 6.7.1.14. Legitimidade (ADI genérica)
- 6.7.1.15. Procedimento e características marcantes do processo objetivo (ADI genérica)
- 6.7.1.16. “Amicus curiae” (ADI e demais ações) e audiências públicas (“sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” — Peter Häberle)
 - 6.7.1.16.1. “Amicus curiae” — regras gerais
 - 6.7.1.16.2. É possível a admissão do “amicus curiae” na ADC?
 - 6.7.1.16.3. Cabe “amicus curiae” na ADPF?
 - 6.7.1.16.4. Cabe “amicus curiae” na ADO?
 - 6.7.1.16.5. Cabe “amicus curiae” na IF (representação interventiva)?
 - 6.7.1.16.6. Outras hipóteses de cabimento do “amicus curiae”

- 6.7.1.16.7. Parlamentar pode ser admitido no processo como “amicus curiae”? (Novidade mais ampla introduzida pelo CPC/2015 — Lei n. 13.105/2015)
- 6.7.1.16.8. Natureza jurídica do “amicus curiae”
- 6.7.1.16.9. “Amicus curiae” pode interpor recurso?
- 6.7.1.16.10. Audiências públicas
- 6.7.1.17. Efeitos da decisão (ADI genérica)
 - 6.7.1.17.1. Princípio da parcelaridade
 - 6.7.1.17.2. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto
 - 6.7.1.17.3. Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Necessidade de impugnação de todo o “complexo normativo”
 - 6.7.1.17.4. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade
 - 6.7.1.17.4.1. Coisa julgada “inconstitucional”. S. 343/STF. Rescisória (art. 966, V, CPC/2015)
 - 6.7.1.17.4.2. Explicitação da amplitude da S. 343/STF. “Leading case”: RE 590.809 (j. 22.10.2014). Revogado CPC/73 e Novo CPC/2015
 - 6.7.1.17.4.3. Arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do revogado CPC/73: “embargos rescisórios”. Como ficou no CPC/2015 (arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º)?
 - 6.7.1.17.4.4. Aspectos conclusivos: efeito da decisão no plano normativo (“Normebene”) e no plano do ato singular (“Einzelaktebene”) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão (interessante tendência apontada pelo Min. Gilmar Mendes). Perspectiva introduzida pelo CPC/2015
- 6.7.1.17.5. Pedido de cautelar (ADI genérica)

- Reclamação para a garantia da autoridade da decisão do
- 6.7.1.18. STF: paradigma de ordem objetiva (ADI genérica e súmula vinculante)
 - 6.7.1.18.1. Regras gerais
 - 6.7.1.18.2. Natureza jurídica do instituto da reclamação
- 6.7.2. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)
 - 6.7.2.1. Conceito (ADC)
 - 6.7.2.2. Objeto (ADC)
 - 6.7.2.3. Competência (ADC)
 - 6.7.2.4. Legitimidade (ADC)
 - 6.7.2.5. Procedimento (ADC)
 - 6.7.2.6. Efeitos da decisão (ADC)
 - 6.7.2.7. Medida cautelar (ADC)
- 6.7.3. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
 - 6.7.3.1. Localização (ADPF)
 - 6.7.3.2. Objeto — hipóteses de cabimento (ADPF)
 - 6.7.3.3. Preceito fundamental — conceito (ADPF)
 - 6.7.3.4. Competência (ADPF)
 - 6.7.3.5. Legitimidade (ADPF)
 - 6.7.3.6. Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade
 - 6.7.3.7. Efeitos da decisão (ADPF)
 - 6.7.3.8. O parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99 é constitucional (arguição incidental)?
 - 6.7.3.9. Pedido de medida liminar (ADPF)
 - 6.7.3.10. ADPF pode ser conhecida como ADI? Se sim, o princípio da fungibilidade teria natureza ambivalente? Ou seja, ADI poderia ser conhecida como ADPF?

6.7.4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

- 6.7.4.1. Conceito (ADO)
- 6.7.4.2. Espécies de omissão
- 6.7.4.3. Objeto (ADO)
- 6.7.4.4. Competência (ADO)
- 6.7.4.5. Legitimidade (ADO)
- 6.7.4.6. Natureza jurídica dos legitimados (ADO)
- 6.7.4.7. Procedimento (ADO)
- 6.7.4.8. Medida cautelar (ADO)
- 6.7.4.9. Efeitos da decisão (ADO)
 - 6.7.4.9.1. Regras gerais
 - 6.7.4.9.2. Novas perspectivas: ADOs 20, 24, 25, 26, 27 e 38 — um passo adiante nas decisões meramente recomendatórias
- 6.7.4.10. A atual jurisprudência do STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO?

6.7.5. Representação Interventiva (IF)

- 6.7.5.1. Conceito (IF)
- 6.7.5.2. Representação interventiva federal (ADI interventiva federal)
 - 6.7.5.2.1. Objeto (IF)
 - 6.7.5.2.2. Princípios sensíveis
 - 6.7.5.2.3. Competência (IF)
 - 6.7.5.2.4. Legitimidade (IF)
 - 6.7.5.2.5. Procedimento (IF)
 - 6.7.5.2.6. Medida liminar (IF)
 - 6.7.5.2.7. Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal
- 6.7.5.3. Representação interventiva estadual (ADI interventiva estadual)

- 6.8. Controle abstrato de Constitucionalidade nos estados-membros
 - 6.8.1. Regras gerais
 - 6.8.2. Objeto
 - 6.8.3. Competência
 - 6.8.4. Legitimados
 - 6.8.5. Parâmetro de controle (pauta de referência ou paradigma de confronto)
 - 6.8.5.1. Regras gerais: literalidade do art. 125, § 2.º, CF/88
 - 6.8.5.2. Normas de reprodução obrigatória ou compulsória e normas de mera imitação (da CF na CE)
 - 6.8.5.3. A utilização do recurso extraordinário no controle concentrado e em abstrato estadual
 - 6.8.6. “Simultaneus processus”
- 6.9. Quadro comparativo do sistema jurisdicional misto de controle posterior ou repressivo de Constitucionalidade no Brasil
- 6.10. Material digital exclusivo

7 – Divisão Espacial do Poder — Organização do Estado

- 7.1. Noções preliminares
 - 7.1.1. Elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado
 - 7.1.2. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado
- 7.2. Formas de estado
- 7.3. Federação
 - 7.3.1. Histórico
 - 7.3.2. Tipologias do Federalismo

- 7.3.2.1. Federalismo por agregação ou por desagregação (segregação)
- 7.3.2.2. Federalismo dual ou cooperativo
- 7.3.2.3. Federalismo simétrico ou assimétrico
- 7.3.2.4. Federalismo orgânico
- 7.3.2.5. Federalismo de integração
- 7.3.2.6. Federalismo equilíbrio
- 7.3.2.7. Federalismo de segundo grau
- 7.3.3. Características da Federação
- 7.3.4. Federação brasileira
 - 7.3.4.1. Breve histórico
 - 7.3.4.2. Federação na CF/88 e princípios fundamentais
 - 7.3.4.2.1. Composição e sistematização conceitual
 - 7.3.4.2.2. Fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.º, CF/88)
 - 7.3.4.2.3. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3.º, CF/88)
 - 7.3.4.2.4. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais (art. 4.º, CF/88)
 - 7.3.4.2.5. Idioma oficial da República Federativa do Brasil (art. 13, “caput”, CF/88)
 - 7.3.4.2.6. Símbolos da República Federativa do Brasil (art. 13, §§ 1.º e 2.º, CF/88)
 - 7.3.4.2.7. Vedações constitucionais impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
- 7.4. União Federal
 - 7.4.1. Capital Federal
 - 7.4.2. Bens da União

7.4.3. Competências da União Federal

- 7.4.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)
- 7.4.3.2. Competência legislativa
- 7.4.3.3. Competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação — discussão em relação à EC n. 85/2015
- 7.4.3.4. Legislação sobre o meio ambiente e controle da poluição: competência municipal. O caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224) e o da aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitem fumaça acima de padrões considerados aceitáveis (RE 194.704)

7.4.4. Regiões administrativas ou de desenvolvimento

7.5. Estados-Membros

7.5.1. Formação dos Estados-Membros

- 7.5.1.1. Regra geral
- 7.5.1.2. Aspectos específicos e procedimentais
- 7.5.1.3. E qual deve ser o procedimento no caso de criação de um novo Estado?
- 7.5.1.4. Fusão
- 7.5.1.5. Cisão
- 7.5.1.6. Desmembramento

7.5.2. Bens dos Estados-Membros

7.5.3. Competências dos Estados-Membros

- 7.5.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)
- 7.5.3.2. Competência legislativa

7.5.4. Exploração dos serviços locais de gás canalizado

7.5.5. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

7.5.5.1. Aspectos gerais

7.5.5.2. Conceito

7.5.5.3. O que aconteceu com as regiões metropolitanas instituídas antes da nova Constituição de 1988?

7.5.5.4. Caráter compulsório da participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

7.5.5.5. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal que deverá ser preservada. Não se admite a simples transferência de competências exclusivamente para o Estado-Membro. A gestão deverá ser compartilhada

7.5.5.6. “Estatuto da Metrópole” — Lei n. 13.089/2015

7.5.5.7. Qual a natureza jurídica das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões criadas por lei complementar estadual?

7.6. Municípios

7.6.1. Formação dos Municípios

7.6.2. Competências dos Municípios

7.6.2.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)

7.6.2.2. Competências legislativas

7.6.2.3. Competência municipal para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição

7.7. Distrito Federal

7.7.1. Histórico

- 7.7.2. Distrito Federal como unidade federada
- 7.7.3. Outras características importantes
- 7.7.4. Competências do Distrito Federal
 - 7.7.4.1. Competências não legislativas (administrativas ou materiais)
 - 7.7.4.2. Competências legislativas
- 7.8. Territórios Federais
 - 7.8.1. Histórico
 - 7.8.2. Natureza jurídica
 - 7.8.3. Ainda existem territórios no Brasil?
 - 7.8.4. Mas, afinal de contas, o que é Fernando de Noronha?
 - 7.8.5. Apesar de não existirem, podem vir a ser criados novos territórios?
 - 7.8.6. Outras características importantes sobre Territórios Federais
- 7.9. Modelos de repartição de competências
 - 7.9.1. Modelo clássico e modelo moderno
 - 7.9.1.1. Modelo clássico
 - 7.9.1.2. Modelo moderno
 - 7.9.2. Modelo horizontal e modelo vertical
 - 7.9.2.1. Modelo horizontal
 - 7.9.2.2. Modelo vertical
- 7.10. Quadro ilustrativo da competência legislativa constitucional — alguns precedentes do STF
- 7.11. Amianto, tabaco e Covid-19 (pandemia)
 - 7.11.1. Amianto
 - 7.11.2. Tabaco

- 7.11.3. Covid-19 — medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia e as perspectivas trazidas pelas ECs ns. 109/2021 e 119/2022

7.12. Intervenção

7.12.1. Intervenção federal

- 7.12.1.1. Hipóteses de intervenção federal
- 7.12.1.2. Espécies de intervenção federal
- 7.12.1.3. Decretação e execução da intervenção federal e a oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional
- 7.12.1.4. Controle político exercido pelo Congresso Nacional
 - 7.12.1.4.1. Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado
- 7.12.1.5. Afastamento das autoridades envolvidas
- 7.12.1.6. A intervenção federal na vigência da Constituição Federal de 1988: os casos particulares do Distrito Federal e do Espírito Santo e a efetiva decretação da intervenção federal nos Estados do Rio de Janeiro e de Roraima e no Distrito Federal
- 7.12.1.7. A intervenção federal: necessidade de preservação dos direitos fundamentais

7.12.2. Intervenção estadual

- 7.12.2.1. Hipóteses de intervenção estadual e intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais
- 7.12.2.2. Decretação e execução da intervenção estadual
- 7.12.2.3. Controle exercido pelo Legislativo
 - 7.12.2.3.1. Hipóteses em que o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado
- 7.12.2.4. Afastamento das autoridades envolvidas
- 7.12.2.5. Súmula 637 do STF

7.13. Material digital exclusivo

8 – Separação de “Poderes”— Teoria Geral

8.1. Noções introdutórias

8.1.1. Aristóteles: identificação das funções do Estado

8.1.2. Montesquieu: correspondência entre a divisão funcional e a divisão orgânica

8.1.3. E qual seria a finalidade da separação dos poderes?

8.2. funções típicas e atípicas

8.3. Impropriedade da expressão “tripartição de Poderes”

8.4. A independência dos Poderes e a indelegabilidade de atribuições

8.5. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

9 – Poder Legislativo

9.1. Estrutura do poder legislativo

9.1.1. Estrutura do Poder Legislativo federal

9.1.2. Estrutura do Poder Legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais

9.1.2.1. Estrutura do Poder Legislativo estadual

9.1.2.2. Estrutura do Poder Legislativo municipal

9.1.2.3. Estrutura do Poder Legislativo distrital

9.1.2.4. Estrutura do Poder Legislativo dos Territórios Federais

9.2. Atribuições do Congresso Nacional

9.3. Câmara dos Deputados

- 9.3.1. Aspectos fundamentais
- 9.3.2. Requisitos para a candidatura dos Deputados Federais
- 9.3.3. Competências privativas da Câmara dos Deputados
- 9.4. Senado Federal
 - 9.4.1. Aspectos fundamentais
 - 9.4.2. Requisitos para a candidatura dos Senadores
 - 9.4.3. Competências privativas do Senado Federal
- 9.5. Quadro comparativo e deliberações
- 9.6. Remuneração dos parlamentares
 - 9.6.1. Subsídio mensal
 - 9.6.2. Verba indenizatória: dever de transparência
- 9.7. Das reuniões
 - 9.7.1. Sessão legislativa ordinária
 - 9.7.2. Hipóteses de convocação extraordinária
 - 9.7.3. Reunião em sessão conjunta
 - 9.7.4. Sessão preparatória e Mesas Diretoras
- 9.8. Das comissões parlamentares
 - 9.8.1. Comissão temática ou em razão da matéria (permanentes)
 - 9.8.2. Comissão especial ou temporária
 - 9.8.3. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
 - 9.8.3.1. Regras gerais
 - 9.8.3.2. Criação
 - 9.8.3.3. Direito público subjetivo das minorias
 - 9.8.3.4. Objeto
 - 9.8.3.5. Prazo

- 9.8.3.6. Poderes
- 9.8.3.7. O princípio da separação de “poderes” e a impossibilidade de a CPI investigar atos de conteúdo jurisdicional
- 9.8.3.8. Postulado de reserva constitucional de jurisdição
- 9.8.3.9. Postulado da colegialidade
- 9.8.3.10. Motivação
- 9.8.3.11. Conclusões: encaminhamento para as autoridades responsáveis para que promovam as eventuais responsabilizações dos infratores
- 9.8.3.12. Competência originária do STF
- 9.8.3.13. A regra da prejudicialidade
- 9.8.3.14. A questão específica da quebra do sigilo bancário
- 9.8.3.15. Sigilo bancário e CPIs estaduais
- 9.8.3.16. Sigilo bancário e as CPIs distritais
- 9.8.3.17. Sigilo bancário e as CPIs municipais
- 9.8.4. Comissão mista
- 9.8.5. Comissão representativa
- 9.9. Imunidades parlamentares
 - 9.9.1. Aspectos introdutórios
 - 9.9.2. Imunidade parlamentar federal
 - 9.9.2.1. Imunidade material ou inviolabilidade parlamentar (art. 53, “caput”)
 - 9.9.2.2. Imunidade formal ou processual
 - 9.9.2.2.1. Imunidade formal ou processual para a prisão (art. 53, § 2.º). Perspectivas em razão do julgamento da AP 470 — “mensalão”
 - 9.9.2.2.2. Prisão preventiva de parlamentar? Precedente da 2.^a Turma do STF. Dúvida manifestada pela 1.^a Turma do

STF. Inexistência de apreciação do Pleno.

Inafiançabilidade legal em razão de excepcionalidade de caso concreto decorrente de “absoluta anomalia institucional, jurídica e ética”. “Derrotabilidade da regra” contida no art. 53, § 2.º, CF/88. Perspectivas para o julgamento da Pet 9.218 (pendente)

- 9.9.2.2.3. Outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e a necessidade de controle político (aplicação analógica do art. 53, § 2.º, CF/88) — ADI 5.526
- 9.9.2.2.4. Imunidade formal ou processual para o processo (art. 53, §§ 3.º a 5.º)
- 9.9.2.3. Prerrogativa de foro (“foro privilegiado”) (art. 53, § 1.º)
 - 9.9.2.3.1. Cancelamento da S. 394/STF
 - 9.9.2.3.2. Caso “Gulliver”. “Ciranda dos processos”. “Valsa processual”. AP 333 (j. 05.12.2007)
 - 9.9.2.3.3. Renúncia ao mandato. Manutenção da competência do STF. Abuso de direito. Fraude processual inaceitável: AP 396 (j. 28.10.2010)
 - 9.9.2.3.4. Nova tentativa de fixação de tese de julgamento sobre a prerrogativa de foro. Inexistência de fraude processual e abuso de direito. Afastamento do risco de prescrição da pena em abstrato: AP 536 (j. 27.03.2014)
 - 9.9.2.3.5. Viragem jurisprudencial. Novo entendimento da Corte. Mutação constitucional: AP 937 QO (j. 03.05.2018)
- 9.9.2.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento
- 9.9.2.5. Outras garantias
- 9.9.2.6. As imunidades parlamentares podem ser renunciadas?
- 9.9.2.7. As imunidades parlamentares estendem-se aos suplentes?

9.9.3. Parlamentares estaduais e do DF

9.9.4. Parlamentares municipais

9.10. Incompatibilidades e impedimentos dos parlamentares federais

9.11. Perda do mandato do Deputado ou Senador

9.11.1. Hipóteses de perda do mandato e suas peculiaridades

9.11.2. Cassação

9.11.3. Votação aberta na hipótese de cassação do mandato: aprovação da “PEC do voto aberto” (EC n. 76/2013). Avanço democrático

9.11.4. A perda do mandato parlamentar em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado e a interpretação fixada pelo STF no julgamento da AP 470 (“mensalão”), bem como da AP 565 (art. 15, III, x art. 55, §§ 2.º e 3.º). O caso concreto da AP 396.

9.11.5. É possível a renúncia do cargo por parlamentar submetido a processo que vise ou possa levá-lo à perda do mandato?

9.11.6. Perda do mandato nas hipóteses de infidelidade partidária

9.11.7. Suspensão do exercício do mandato de parlamentar eleito (AC 4.070)

9.12. Hipóteses em que não haverá a perda do mandato do Deputado
OU SENADOR E OUTRAS REGRAS

9.13. Processo legislativo

9.13.1. Considerações introdutórias

9.13.2. Esquema do processo legislativo das leis ordinárias e complementares

9.13.3. Fase de iniciativa

9.13.3.1. Regra geral para a iniciativa

- 9.13.3.2. Iniciativa concorrente
- 9.13.3.3. Iniciativa “privativa” (reservada ou exclusiva)
 - 9.13.3.3.1. Iniciativa reservada ao Presidente da República
 - 9.13.3.3.2. Iniciativa reservada aos Governadores dos Estados e do DF e aos Prefeitos — simetria com o modelo federal
 - 9.13.3.3.3. Iniciativa reservada do Judiciário
 - 9.13.3.3.4. Iniciativa reservada aos Tribunais de Contas
 - 9.13.3.3.5. Assuntos exclusivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
 - 9.13.3.3.6. Podemos falar em iniciativa reservada de matéria tributária?
 - 9.13.3.3.7. Iniciativa do processo legislativo de matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais
 - 9.13.3.3.8. Pode o legitimado exclusivo ser compelido a deflagrar processo legislativo?
 - 9.13.3.3.9. Cabe emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada?
 - 9.13.3.3.10. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas em relação às normas fruto da manifestação do poder constituinte derivado decorrente?
 - 9.13.3.3.11. As regras de iniciativa reservada previstas na CF/88 devem ser observadas, enquanto limites, pelo poder constituinte derivado reformador (PEC)?
 - 9.13.3.3.12. Sanção presidencial convalida vício de iniciativa?
- 9.13.3.4. Iniciativa popular
 - 9.13.3.4.1. Aspectos gerais
 - 9.13.3.4.2. Existe algum exemplo de lei fruto de iniciativa popular?
 - 9.13.3.4.3. Conclusões iniciais

- 9.13.3.4.4. Iniciativa popular de “PEC”?
- 9.13.3.4.5. Cabe iniciativa popular de matérias reservadas à iniciativa exclusiva de outros titulares?
- 9.13.3.4.6. Iniciativa popular e as espécies normativas: esquematização
- 9.13.3.4.7. Iniciativa popular em âmbito estadual e municipal
- 9.13.3.5. Iniciativa conjunta: ainda persiste, tendo em vista a Reforma da Previdência (EC n. 41/2003)?
- 9.13.3.6. Iniciativa para fixação do subsídio dos Ministros do STF — teto do funcionalismo — art. 48, XV, c/c o art. 96, II, “b”
- 9.13.3.7. Algumas peculiaridades a serem observadas
 - 9.13.3.7.1. Organização do Ministério Público
 - 9.13.3.7.2. Proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67 — regra da irrepetibilidade)
 - 9.13.3.7.3. Iniciativa parlamentar ou extraparlamentar
- 9.13.4. Fase constitutiva
 - 9.13.4.1. Deliberação parlamentar — discussão e votação
 - 9.13.4.1.1. O projeto começa na Câmara ou no Senado?
 - 9.13.4.1.2. Apreciação pelas Comissões
 - 9.13.4.1.3. Processos de votação
 - 9.13.4.1.4. A Casa revisora
 - 9.13.4.1.5. Espécies de emendas
 - 9.13.4.1.6. Algumas outras regras fundamentais
 - 9.13.4.2. Deliberação executiva — sanção e veto
 - 9.13.4.2.1. Sanção
 - 9.13.4.2.2. Regras gerais sobre o veto

- 9.13.4.2.3. Os vetos devem ser apreciados na ordem cronológica de sua comunicação ao Congresso Nacional? (MS 31.816 — “royalties” do pré-sal)
- 9.13.4.2.4. Procedimento de apreciação dos vetos presidenciais (Res. n. 1/2015-CN)
- 9.13.4.2.5. Regras específicas sobre o veto
- 9.13.5. Fase complementar — promulgação e publicação
 - 9.13.5.1. Promulgação
 - 9.13.5.2. Publicação
- 9.14. Espécies normativas
 - 9.14.1. Emenda constitucional
 - 9.14.1.1. Limitações formais ou procedimentais (art. 60, I, II, III, e §§ 2.º, 3.º e 5.º)
 - 9.14.1.2. Limitações circunstanciais (art. 60, § 1.º)
 - 9.14.1.3. Limitações materiais (art. 60, § 4.º)
 - 9.14.1.4. Limitações temporais?
 - 9.14.1.5. Limitações implícitas
 - 9.14.1.6. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e a sua equivalência com as emendas constitucionais — EC n. 45/2004
 - 9.14.2. Lei complementar e lei ordinária
 - 9.14.2.1. Semelhanças
 - 9.14.2.2. Diferenças
 - 9.14.2.2.1. Aspecto material
 - 9.14.2.2.2. Aspecto formal
 - 9.14.2.3. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária?
 - 9.14.2.4. É possível a ampliação das hipóteses de reserva de lei complementar no âmbito dos demais entes federativos

para além daquelas previstas expressamente na CF/88 e de reprodução obrigatória?

9.14.3. Lei delegada

9.14.4. Medida provisória

9.14.4.1. Aspectos iniciais

9.14.4.2. O processo de criação das medidas provisórias de acordo com a EC n. 32/2001

9.14.4.3. Parecer prévio pela comissão mista e a inconstitucionalidade dos arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput” e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN. As novas regras sobre a tramitação das medidas provisórias durante a vigência da Emergência em Saúde Pública e do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19

9.14.4.4. Medidas a serem adotadas pelo Congresso Nacional

9.14.4.4.1. Aprovação sem alteração

9.14.4.4.2. Aprovação com alteração

9.14.4.4.3. Não apreciação (rejeição tácita)

9.14.4.4.4. Rejeição expressa

9.14.4.5. Impacto da medida provisória sobre o ordenamento jurídico

9.14.4.6. Pode o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória já editada?

9.14.4.7. Pode o Presidente do Congresso Nacional devolver MP liminarmente e de ofício, sem iniciar o procedimento previsto na Constituição?

9.14.4.8. Limitação material à edição de medidas provisórias, de acordo com a EC n. 32/2001

9.14.4.9. O que acontecerá com as medidas provisórias editadas em data anterior à EC n. 32/2001?

9.14.5. Decreto legislativo

9.14.5.1. Aspectos gerais

9.14.5.2. Breves notas sobre o processo de formação dos tratados internacionais e a novidade trazida pela EC n. 45/2004

9.14.5.2.1. Tratados e convenções internacionais gerais

9.14.5.2.2. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (EC n. 45/2004)

9.14.5.2.3. A “supralegalidade” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos

9.14.6. Resolução

9.14.7. Quadro comparativo das espécies normativas

9.15. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e o Tribunal de Contas

9.15.1. Tribunal de Contas da União

9.15.1.1. Composição e características

9.15.1.2. Atribuições constitucionais do TCU

9.15.1.3. “Apreciar as contas” x “julgar as contas” (art. 71, I e II)

9.15.1.4. Recursos repassados pela União: remessa necessária de recursos x recursos repassados pela União (art. 71, VI)

9.15.1.5. O Tribunal de Contas tem atribuição para exercer controle de constitucionalidade?

9.15.1.6. Sustação de “atos” e “contratos” administrativos pelo Tribunal de Contas

9.15.1.7. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas?

9.15.1.8. É necessária a observância do devido processo legal em processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas?

- O Tribunal de Contas pode exigir, por si, a quebra de
- 9.15.1.9. sigilo bancário?
 - 9.15.1.10. Teoria dos poderes implícitos e as atribuições do Tribunal de Contas — possibilidade de concessão de medidas cautelares para assegurar o exercício de suas atribuições
 - 9.15.1.11. Situação jurídica acobertada pela autoridade da coisa julgada pode ser desconstituída por decisão ou ato do Tribunal de Contas?
 - 9.15.1.12. Decisões do Tribunal de Contas com eficácia de título executivo
 - 9.15.1.13. Ao decidir, cabe ao Tribunal de Contas manter o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia? (a nova orientação trazida pela Lei n. 13.866/2019)
 - 9.15.1.14. Ministros do Tribunal de Contas da União
- 9.15.2. Distinção entre a atuação do TCU e da CGU: inexistência de invasão de atribuições. Auxílio no controle externo (TCU) “x” controle interno (CGU) — perfeita convivência
 - 9.15.3. Tribunais de Contas Estaduais e Tribunal de Contas do Distrito Federal
 - 9.15.4. Tribunais de Contas Municipais
 - 9.15.5. Ministério Público Especial (art. 130)
- 9.16. Material digital exclusivo

10 –Poder Executivo

- 10.1. Notas introdutórias
- 10.2. Presidencialismo “versus” parlamentarismo
- 10.3. Executivo monocrático, colegial, diretorial e dual — conceito

10.4. O poder executivo na CF/88

10.4.1. O exercício do Poder Executivo no Brasil

10.4.1.1. Âmbito federal

10.4.1.2. Âmbito estadual

10.4.1.3. Âmbito distrital

10.4.1.4. Âmbito municipal

10.4.1.5. Âmbito dos Territórios Federais

10.4.2. Atribuições conferidas ao Presidente da República

10.4.2.1. Regras gerais do art. 84, CF/88

10.4.2.2. Regras específicas decorrentes do art. 84, CF/88

10.4.2.3. O poder regulamentar e a realidade dos denominados “decretos autônomos”

10.4.3. Condições de elegibilidade

10.4.4. Processo eleitoral e equipe de transição

10.4.5. Posse e mandato

10.4.6. Impedimento e vacância dos cargos

10.4.6.1. Vice-Presidente da República: sucessor e substituto natural do Presidente da República

10.4.6.2. Substitutos eventuais ou legais

10.4.6.3. Mandato-tampão: eleição direta e indireta (art. 81)

10.4.6.4. Ausência do País do Presidente e do Vice-Presidente da República e licença do Congresso Nacional (norma de reprodução obrigatória)

10.4.7. Ministros de Estado

10.4.7.1. Características gerais e requisitos de investidura no cargo. Poderá haver controle judicial? A questão específica do desvio de finalidade

10.4.7.2. Atribuições dos Ministros de Estado

- 10.4.7.3. Poderão os Ministros de Estado receber delegação para exercer matéria de competência privativa do Presidente da República?
- 10.4.7.4. Responsabilidade e juízo competente para processar e julgar os Ministros de Estado. A análise do controle político pela Câmara dos Deputados (art. 51, I)
- 10.4.8. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional
 - 10.4.8.1. Conselho da República
 - 10.4.8.2. Conselho de Defesa Nacional
- 10.4.9. Crimes de responsabilidade
 - 10.4.9.1. Notas introdutórias e natureza jurídica
 - 10.4.9.2. Procedimento
 - 10.4.9.2.1. Câmara dos Deputados
 - 10.4.9.2.2. Senado Federal
 - 10.4.9.2.3. Caso Dilma Rousseff: inovação constitucional. Fatiamiento da votação e das penas
 - 10.4.9.3. Crime de responsabilidade: admite-se o controle judicial?
- 10.4.10. Crimes comuns
 - 10.4.10.1. Conceito e procedimento
 - 10.4.10.2. Imunidade presidencial (irresponsabilidade penal relativa)
- 10.4.11. Prisão
- 10.4.12. A imunidade formal em relação à prisão (art. 86, § 3.º) e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa (art. 86, § 4.º) podem ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo por atos normativos dos respectivos entes federativos?
- 10.4.13. Outras regras importantes sobre os demais Chefes do Poder Executivo
 - 10.4.13.1. Os demais entes federativos podem dispor sobre crime de responsabilidade definindo o órgão julgador por ato

legislativo próprio?

- 10.4.13.2. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia pelo Legislativo local para o julgamento dos Chefes do Executivo?
- 10.4.14. Sistematização da competência para julgamento das autoridades pela prática de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade
 - 10.4.14.1. Prefeitos Municipais
 - 10.4.14.2. Vereadores Municipais
 - 10.4.14.3. A inconstitucionalidade das regras trazidas pela Lei n. 10.628/2002 em relação à “perpetuatio jurisdictionis” e ao “inusitado foro cível por prerrogativa de função em lei processual penal”
 - 10.4.14.4. Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento
 - 10.4.14.5. Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF — Pet 3.240 — o reconhecimento do duplo regime sancionatório para os agentes políticos (exceto o Presidente da República). Perspectivas trazidas pela “nova” Lei de Improbidade — Lei n. 14.230/2021

10.5. Material digital exclusivo

11 –Poder Judiciário

- 11.1. Funções do poder judiciário
- 11.2. Algumas características da jurisdição
- 11.3. Reforma do Poder Judiciário — EC n. 45/2004

- 11.3.1. Histórico de sua tramitação
- 11.3.2. Principais alterações
- 11.4. Estatuto da Magistratura
 - 11.4.1. Disposições gerais
 - 11.4.2. A EC n. 88/2015 (fruto da “PEC da Bengala”), a EC n. 103/2019 (“Reforma da Previdência”), a EC n. 122/2022 e as ADIs 5.316, 5.430 (Magistratura) e 5.490 (Ministério Público)
- 11.5. Garantias do Judiciário
 - 11.5.1. Garantias institucionais do Judiciário
 - 11.5.1.1. Garantias de autonomia orgânico-administrativa
 - 11.5.1.2. Garantias de autonomia financeira
 - 11.5.2. Garantias funcionais do Judiciário (ou de órgãos)
 - 11.5.2.1. Garantias de independência dos órgãos judiciários
 - 11.5.2.1.1. Vitaliciedade
 - 11.5.2.1.2. Inamovibilidade
 - 11.5.2.1.3. Irredutibilidade de subsídios
 - 11.5.2.2. Garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários
 - 11.5.3. Prerrogativa de foro: o magistrado aposentado tem direito a foro especial por prerrogativa de função?
- 11.6. Estrutura do Judiciário
 - 11.6.1. Órgãos de convergência e órgãos de superposição
 - 11.6.2. Justiças: comum e especial
 - 11.6.3. Competência penal “versus” competência civil
 - 11.6.4. Juizados Especiais: algumas particularidades
 - 11.6.4.1. Não cabimento de Recurso Especial para o STJ e o cabimento de Rcl
 - 11.6.4.2. Cabimento de RE para o STF

- 11.6.4.3. Cabimento de HC e MS contra ato de juizado especial — superação da S. 690/STF
- 11.6.4.4. Ação de indenização em razão do fumo: incompetência dos Juizados — complexidade da causa
- 11.6.4.5. Juizados e a Lei Maria da Penha
- 11.6.5. Organograma do Poder Judiciário

11.7. A regra do “Quinto constitucional”

11.8. Características gerais dos órgãos do Poder Judiciário

- 11.8.1. Supremo Tribunal Federal (STF)
 - 11.8.1.1. STF — aspectos históricos
 - 11.8.1.2. STF — regras gerais
 - 11.8.1.3. STF — destaques às novidades trazidas pela EC n. 45/2004 (“Reforma do Judiciário”)
 - 11.8.1.4. STF — procedimento para deliberação e encaminhamento de solicitações de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR)
- 11.8.2. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
 - 11.8.2.1. STJ — regras gerais
 - 11.8.2.2. Requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional — “filtro de relevância” (EC n. 125/2022)
- 11.8.3. Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Juízes Federais
- 11.8.4. Tribunais e Juízes do Trabalho
 - 11.8.4.1. Tribunal Superior do Trabalho (TST)
 - 11.8.4.2. Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)
 - 11.8.4.3. Juízes do trabalho — Varas do Trabalho
 - 11.8.4.4. Competências da Justiça do Trabalho

11.8.4.5. O que aconteceu com os mandatos dos classistas em face da EC n. 24/99?

11.8.5. Tribunais e Juízes Eleitorais

11.8.5.1. Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

11.8.5.2. Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

11.8.5.3. Juízes Eleitorais

11.8.5.4. Juntas Eleitorais

11.8.5.5. Competências e atribuições da Justiça Eleitoral

11.8.6. Tribunais e Juízes Militares

11.8.6.1. Superior Tribunal Militar (STM)

11.8.6.2. Justiça Militar da União

11.8.6.2.1. Regras gerais e Circunscrições Judiciárias Militares

11.8.6.2.2. Conselhos de Justiça (julgamento colegiado e por escabinato) e os Juízes Federais da Justiça Militar da União (julgamento monocrático)

11.8.6.2.3. Hierarquia militar (postos e graduações)

11.8.6.2.4. Ministério Público Militar e Defensoria Pública da União

11.8.6.2.5. A Justiça Militar da União julga civil?

11.8.6.2.6. E os crimes dolosos contra a vida? Justiça Militar da União: modificações introduzidas pela Lei n. 13.491/2017

11.8.6.2.7. A Lei n. 9.099/95 (que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) se aplica no âmbito da Justiça Militar?

11.8.6.2.8. A Justiça Militar da União e a Reforma do Judiciário

11.8.6.3. Justiça Militar dos Estados

11.8.6.3.1. Atribuições

11.8.6.3.2. Composição e competência

- 11.8.6.3.3. Aplicação da pena de perda do posto e da patente (oficiais) e da graduação (praças): atribuição
- 11.8.6.3.4. Hierarquia militar estadual (postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar) — Lei n. 14.751/2023
- 11.8.6.3.5. Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual (Justiça Militar Estadual)
- 11.8.6.4. Justiça Militar do Distrito Federal
- 11.8.7. Tribunais e Juízes dos Estados
- 11.8.8. Varas Agrárias e os conflitos fundiários
- 11.8.9. Justiça Estadual é competente para julgar crimes comuns entre silvícolas
- 11.8.10. Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios
- 11.9. Princípio do juiz natural e convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão julgador de tribunal
- 11.10. Magistratura — teto de subsídio “x” teto de remuneração — PODER JUDICIÁRIO — caráter nacional E UNITÁRIO
- 11.11. Da Justiça de Paz (art. 98, II)
 - 11.11.1. Regras gerais
 - 11.11.2. Os juízes de paz integram o Poder Judiciário?
- 11.12. Dos precatórios
 - 11.12.1. Regras gerais
- 11.13. Conselho Nacional de Justiça
 - 11.13.1. Aspectos gerais e composição do CNJ
 - 11.13.2. Aperfeiçoamento do CNJ: EC n. 61/2009

- 11.13.3. Inexistência de regulamentação (critérios objetivos) para a indicação dos membros do CNJ
- 11.13.4. O CNJ é constitucional?
- 11.13.5. Atribuições do CNJ e o controle de suas decisões pelo STF (limites?)
 - 11.13.5.1. Regras gerais
 - 11.13.5.2. O CNJ não exerce função jurisdicional
 - 11.13.5.3. O CNJ tem atribuição para exercer o controle de constitucionalidade?
 - 11.13.5.4. STF: órgão de cúpula jurisdicional e órgão de cúpula administrativa, financeira e disciplinar (amplitude)
 - 11.13.5.5. A competência do STF para processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ (e contra o CNMP) no exercício de suas atividades-fim
- 11.13.6. O CNJ tem controle da função jurisdicional do Judiciário?
- 11.13.7. Corregedoria Nacional de Justiça e Ministro-Corregedor do CNJ
- 11.13.8. O CNJ, no exercício de suas atribuições correccionais, atua originariamente (primariamente) e concorrentemente com as Corregedorias dos tribunais
- 11.13.9. Prerrogativa de foro
- 11.13.10. Outras regras sobre o CNJ

11.14. Súmula vinculante

- 11.14.1. Duas realidades: a morosidade da Justiça e as teses jurídicas repetitivas
- 11.14.2. As “famílias” do direito
- 11.14.3. Influência do “stare decisis” da família da “common law”
- 11.14.4. Influência da Alemanha e da Áustria

- 11.14.5. A influência do direito português
- 11.14.6. A evolução do “direito sumular” no Brasil (fase colonial — influência do direito português)
- 11.14.7. A evolução do “direito sumular” no Brasil (após a independência)
- 11.14.8. Prenúncios da súmula vinculante em âmbito constitucional
- 11.14.9. Prenúncios da súmula vinculante no âmbito do direito processual civil
- 11.14.10. Os contornos da súmula vinculante na EC n. 45/2004
- 11.14.11. As regras trazidas pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006 — súmula vinculante
 - 11.14.11.1. Competência
 - 11.14.11.2. Objeto
 - 11.14.11.3. Requisitos para a edição
 - 11.14.11.4. Legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante
 - 11.14.11.5. Procedimento
 - 11.14.11.6. Efeitos da súmula
 - 11.14.11.7. Modulação dos efeitos
 - 11.14.11.8. Revogação ou modificação da lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante
 - 11.14.11.9. Da reclamação
 - 11.14.11.10. Responsabilidade do administrador público
 - 11.14.11.11. Responsabilidade dos magistrados?
- 11.14.12. As súmulas vinculantes (a de número 30 com a publicação suspensa) editadas pelo STF
- 11.14.13. Aspectos conclusivos
- 11.15. Extinção dos Tribunais de Alçada

- 11.15.1. Histórico nas Constituições
- 11.15.2. O surgimento dos Tribunais de Alçada nos Estados
- 11.15.3. A EC n. 45/2004

11.16. material digital exclusivo

12 –Funções Essenciais à Justiça

12.1. Noções introdutórias

12.2. Ministério Público

12.2.1. Histórico

- 12.2.1.1. Origens remotas
- 12.2.1.2. Constituição de 1824
- 12.2.1.3. Constituição de 1891
- 12.2.1.4. Constituição de 1934
- 12.2.1.5. Constituição de 1937
- 12.2.1.6. Constituição de 1946
- 12.2.1.7. Constituição de 1967
- 12.2.1.8. Emenda Constitucional n. 1/69
- 12.2.1.9. Constituição de 1988

12.2.2. Definição e investidura (“quarentena de entrada”)

12.2.3. Organização do Ministério Público na CF/88 — art. 128, I e II, e MP Eleitoral

- 12.2.3.1. Organização do Ministério Público da União e Estadual
- 12.2.3.2. MP Eleitoral

12.2.4. Chefe do Ministério Público

- 12.2.4.1. Procurador-Geral da República
- 12.2.4.2. Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios

- 12.2.4.3. Procurador-Geral do Trabalho
- 12.2.4.4. Procurador-Geral da Justiça Militar
- 12.2.4.5. Procurador-Geral Eleitoral
- 12.2.4.6. Procurador Regional Eleitoral
- 12.2.4.7. Novas perspectivas em relação à nomeação do PGR
- 12.2.4.8. PGR e conflito negativo de atribuição entre órgãos do Ministério Público
- 12.2.5. Princípios institucionais
 - 12.2.5.1. Regras gerais
 - 12.2.5.2. O Ministério Público estadual pode postular autonomamente perante o STF, assim como apresentar sustentação oral, sem que se exija a ratificação pelo PGR?
- 12.2.6. Princípio do promotor natural
- 12.2.7. Garantias do Ministério Público
 - 12.2.7.1. Garantias institucionais
 - 12.2.7.1.1. Autonomia funcional
 - 12.2.7.1.2. Autonomia administrativa
 - 12.2.7.1.3. Autonomia financeira
 - 12.2.7.2. Garantias dos membros do Ministério Público
 - 12.2.7.2.1. Vitaliciedade
 - 12.2.7.2.2. Inamovibilidade
 - 12.2.7.2.3. Irredutibilidade de subsídios
 - 12.2.7.3. Impedimentos imputados aos membros do Ministério Público (vedações)
 - 12.2.7.4. Abrangência das garantias e impedimentos
- 12.2.8. Funções institucionais do Ministério Público
- 12.2.9. A teoria dos “poderes implícitos” e o poder de investigação criminal pelo MP. A investigação criminal não é exclusividade da polícia (devendo ser observados alguns parâmetros).

Procedimento investigatório criminal (PIC) a cargo do Ministério Público. A constitucionalidade dos GAECOs

12.2.10. Posicionamento do MP ao lado dos Juízes nas salas de audiência (ADI 4.768) e a Lei n. 14.508/2022 (Advocacia)

12.2.11. Conselho Nacional do Ministério Público

12.2.11.1. Regras gerais e composição

12.2.11.2. Escolha dos membros do Ministério Público da União

12.2.11.3. Escolha dos 3 membros do Ministério Público dos Estados

12.2.11.4. A sabatina no Senado Federal e a falta de critérios para a indicação dos demais membros do Conselho que não os oriundos da carreira do Ministério Público

12.2.11.5. Esquematização gráfica sobre a indicação dos membros do CNMP

12.2.11.6. Corregedor Nacional

12.2.11.7. Atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

12.2.11.8. Pode o CNMP fixar novo teto remuneratório dos membros e servidores do Ministério Público diferente do estabelecido na CF/88?

12.2.11.9. O CNMP tem competência para realizar controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições?

12.2.11.10. Outras regras

12.2.12. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas — Ministério Público Especial (art. 130)

12.3. Advocacia pública

12.3.1. A distorção corrigida pela EC n. 19/98

12.3.2. Atribuições e prerrogativas dos ocupantes dos cargos das carreiras jurídicas da advocacia pública (regras gerais)

- 12.3.3. O advogado público pode exercer a advocacia fora das atribuições do respectivo cargo?
- 12.3.4. Assessoramento, amplitude vinculativa dos pareceres jurídicos e a responsabilização dos advogados públicos
- 12.3.5. “Contempt of Court”: a multa do art. 14, parágrafo único, CPC/73, e os advogados públicos — ADI 2.652. CPC/2015 — avanço na linha da decisão do STF
- 12.3.6. Pareceres e Súmula da Advocacia-Geral da União
- 12.3.7. Advocacia-Geral da União
 - 12.3.7.1. Regras gerais
 - 12.3.7.2. Órgãos da Advocacia-Geral da União
 - 12.3.7.3. Advogado-Geral da União
 - 12.3.7.4. O caso particular do “direito de manifestação” do AGU no controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, § 3.º)
 - 12.3.7.5. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 - 12.3.7.6. Procuradoria-Geral Federal
 - 12.3.7.7. Procuradoria-Geral do Banco Central
 - 12.3.7.8. A prerrogativa da intimação pessoal dos advogados públicos e a regra no CPC/2015
 - 12.3.7.9. A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n. 10.910/2004, aplica-se ao rito dos Juizados Especiais Federais?
 - 12.3.7.10. Advogados públicos no âmbito da Administração Federal gozam de 30 ou de 60 dias de férias?
- 12.3.8. Procuradoria-Geral dos Estados e do Distrito Federal
 - 12.3.8.1. Estrutura unitária (unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal)

- 12.3.8.2. Nomeação e destituição do Procurador-Geral do Estado pelo Governador: as regras poderão ser definidas com autonomia nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do DF (novo entendimento — ADI 2.820)
- 12.3.8.3. Garantias e impedimentos dos Procuradores do Estado e do DF
- 12.3.9. Procuradoria-Geral dos Municípios
- 12.3.10. Advocacia pública e os honorários de sucumbência no CPC/2015
- 12.3.11. Aplicabilidade das regras do Estatuto da Advocacia a advogados empregados públicos? — ADI 3.396
- 12.4. Advocacia
 - 12.4.1. A advocacia à luz da jurisprudência do STF
 - 12.4.1.1. ADIs 1.105 e 1.127
 - 12.4.1.1.1. A exegese fixada pelo STF
 - 12.4.1.1.2. Quadro-resumo
 - 12.4.1.1.3. Sala de Estado-Maior
 - 12.4.1.2. ADIs 1.194, 2.522, 3.168, 3.541 e 7.227
 - 12.4.1.3. OAB — “serviço público independente”— ADI 3.026
 - 12.4.1.4. Competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que a OAB figure na relação processual (RE 595.332)
 - 12.4.1.5. Constitucionalidade do Exame de Ordem: vitória para os bacharéis em direito e conquista da sociedade (RE 603.583)
 - 12.4.1.6. Súmula Vinculante 5/STF x Súmula 343/STJ (cancelada) e a Lei n. 14.365/2022
 - 12.4.1.7. Súmula Vinculante 47/2015

12.5. Defensoria Pública

- 12.5.1. “Ondas renovatórias”. “Global Access to Justice Project”
- 12.5.2. Assistência jurídica integral e gratuita — aspectos gerais e evolução constitucional. Acesso à justiça como elemento instrumental de concretização do mínimo existencial (Barcellos)
- 12.5.3. Regras gerais e abrangência da Defensoria Pública
- 12.5.4. O fortalecimento da Defensoria Pública pela EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário), bem como pelas ECs ns. 69/2012 e 74/2013: autonomia funcional, administrativa e financeira
- 12.5.5. Autonomia da Defensoria Pública da União — DPU. Constitucionalidade da EC n. 74/2013. A pretensão formulada na ADI 5.296 (10.04.2015) mostra-se totalmente infundada. Equiparação da Defensoria Pública ao Ministério Público
- 12.5.6. As profundas alterações introduzidas pela EC n. 80/2014
 - 12.5.6.1. Visão topológica
 - 12.5.6.2. Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado
 - 12.5.6.3. Princípios institucionais da Defensoria Pública
 - 12.5.6.4. Número de defensores públicos na unidade jurisdicional
 - 12.5.6.5. O Defensor Público deve estar inscrito nos quadros da OAB para desempenhar as suas funções institucionais?
- 12.5.7. A Defensoria Pública como cláusula pétrea
- 12.5.8. Princípio do defensor público natural
- 12.5.9. Garantias dos membros da Defensoria Pública
- 12.5.10. É possível o reconhecimento da garantia da vitaliciedade para os membros da Defensoria Pública?
- 12.5.11. A Defensoria Pública como “custos vulnerabilis” (Maurilio Casas Maia): origem histórica. Atuação da Defensoria Pública

além das situações de vulnerabilidade meramente econômico-financeira. Perspectiva de contraponto à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Paridade de armas entre acusação pública e defesa pública. Importante decisão proferida pelo Min. Barroso na ADPF 709 (16.10.2023)

- 12.5.11.1. O defensor integral do vulnerável (assistência qualificada) e o microssistema de defesa dos vulneráveis. Função processual distinta do “custos vulnerabilis” e da curadoria especial. Defensor da mulher, das crianças, das vítimas de racismo
- 12.5.12. Expressa previsão de notificação da Defensoria Pública da União nas hipóteses de retirada compulsória do migrante ou do visitante (Lei de Migração — Lei n. 13.445/2017)
- 12.5.13. Algumas questões já decididas pela jurisprudência do STF e do STJ
 - 12.5.13.1. A indispensabilidade do concurso público para ingresso na carreira
 - 12.5.13.2. Servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no “exercício regular” de suas funções tem direito à “assistência judiciária” do Estado? Essa atribuição pode ser destinada à Defensoria Pública Estadual?
 - 12.5.13.3. Prazo em dobro e intimação pessoal: prerrogativas da Defensoria Pública. A questão da regra do prazo em dobro para o processo penal. “Lei ainda constitucional”
 - 12.5.13.4. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para Procuradores do Estado no exercício da assistência judiciária, como foi o caso de São Paulo?
 - 12.5.13.5. As prerrogativas do prazo em dobro e da intimação pessoal valem para os advogados dativos?

- 12.5.13.6. As prerrogativas do prazo em dobro e intimação pessoal para a Defensoria Pública aplicam-se ao rito especial dos Juizados?
- 12.5.13.7. Como ficou a prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal no CPC/2015? Houve previsão explícita para os escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e para as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública?
- 12.5.13.8. Defensor público pode exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais?
- 12.5.13.9. Inconstitucionalidade progressiva — art. 68 do CPP — “lei ainda constitucional”
- 12.5.13.10. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública?
- 12.5.13.11. É possível a atuação da Defensoria Pública em medidas de contracautela?
- 12.5.13.12. O Defensor Público pode receber honorários advocatícios? Como ficou no CPC/2015? Perspectiva de superação da S. 471/STJ – julgamento do RE 1.140.005
- 12.5.13.13. O Defensor Público tem poder de requisição?
- 12.5.13.14. Defensores Públicos têm prerrogativa de foro por eventual crime praticado?
- 12.5.13.15. A Defensoria Pública Estadual e a Distrital podem atuar nos Tribunais Superiores?
- 12.5.13.16. É constitucional a imposição por ato normativo da obrigatoriedade de convênio a ser firmado entre a Defensoria Pública e a OAB, para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita?
- 12.5.13.17. A Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que preencham os requisitos

constitucionais?

12.6. Material digital exclusivo

13 –Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

13.1. Sistema constitucional das crises

13.1.1. Noções introdutórias

13.1.2. Constitucionalismo brasileiro: quadro descritivo

13.1.3. Controle judicial

13.2. Estado de defesa (CF/88)

13.2.1. Hipóteses de decretação do estado de defesa

13.2.2. Procedimento e regras gerais

13.2.3. Controle exercido sobre a decretação do estado de defesa ou sua prorrogação

13.3. Estado de sítio (CF/88)

13.3.1. Hipóteses de decretação do estado de sítio

13.3.2. Procedimento e abrangência

13.3.3. Medidas coercitivas

13.3.4. Controle exercido sobre a decretação do estado de sítio

13.4. Disposições comuns aos estados de defesa e de sítio

13.5. quadro comparativo entre o estado de defesa e o estado de sítio (CF/88)

13.6. Forças Armadas

13.6.1. Regras gerais

13.6.2. Emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). As Forças Armadas não assumem o papel de

poder moderador na hipótese de conflito entre poderes. As Forças Armadas são instituições de Estado e, portanto, não são elas órgãos de governo

- 13.6.3. Acumulação de cargos (ECs ns. 77/2014 e 101/2019)
- 13.6.4. “Habeas corpus” e punições disciplinares militares
- 13.6.5. Serviço militar obrigatório
- 13.6.6. Leis de iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1.º, I e II, “f”)
- 13.6.7. As praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber abaixo do salário mínimo?
- 13.6.8. Editais de concurso podem estabelecer limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas?
- 13.6.9. “Princípio da insignificância” e crimes militares: o caso concreto de posse de reduzida quantidade de substância entorpecente. Princípio da especialidade. Afastamento da Lei de Drogas
- 13.6.10. A criminalização da “pederastia” ainda se justifica no Código Penal Militar? ADPF 291 e a nova redação dada ao art. 235, CPM, pela Lei n. 14.688/2023
- 13.6.11. Criação do Ministério da Defesa pela EC n. 23/99
- 13.7. Segurança Pública
 - 13.7.1. Aspectos gerais
 - 13.7.2. Cooperação entre a União e os Estados-Membros e o DF e a Força Nacional de Segurança Pública
 - 13.7.3. BEPE — Batalhão Especial de Pronto Emprego
 - 13.7.4. UPPs — Unidades de Polícia Pacificadora (RJ)
 - 13.7.5. Polícias da União
 - 13.7.5.1. Polícia Federal (PF)
 - 13.7.5.2. Polícia Rodoviária Federal (PRF)

- 13.7.5.3. Polícia Ferroviária Federal (PFF)
- 13.7.5.4. Polícia Penal Federal (PPF)
- 13.7.6. Polícias dos Estados
 - 13.7.6.1. Polícia civil estadual
 - 13.7.6.2. Nos Municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia poderá ser realizado por subtenente ou sargento da polícia militar?
 - 13.7.6.3. Polícia judiciária dos Estados — discussão sobre a escolha do diretor-geral da Polícia Civil. Superação do entendimento firmado na ADI 132? Reconstrução jurisdicional da própria teoria do federalismo (ADI 3.062). Análise da ADI 3.038 e da ADI 3.077 (resgate da tese firmada na ADI 132). Finalmente, a Lei n. 14.735/2023 exige que o diretor-geral seja delegado de polícia em atividade e de classe mais elevada
 - 13.7.6.4. Polícia ostensiva ou preventiva dos Estados — PM e Corpo de Bombeiros Militares
 - 13.7.6.5. Polícia penal estadual (EC N. 104/2019)
- 13.7.7. Polícias do Distrito Federal
- 13.7.8. Polícias dos Territórios
- 13.7.9. Policiais civis e militares: direito de greve (?) e anistia (?)
 - 13.7.9.1. Direito de greve?
 - 13.7.9.2. Lei poderá conceder anistia a policiais civis ou militares (PM e Corpo de Bombeiros) em relação a eventuais crimes praticados e infrações disciplinares conexas decorrentes de participação em movimentos reivindicatórios?

- 13.7.10. A extinção da pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal pela Lei Federal n. 13.967/2019 — ADI 6.595 (STF) — inconstitucionalidade formal e material. A reintrodução pela Lei n. 14.751/2023
- 13.7.11. Polícias penais federal, estadual e distrital (EC n. 104/2019)

13.8. Guardas municipais

13.9. Exercício da advocacia?

13.10. Segurança viária. Carreira dos agentes de trânsito. EC n. 82/2014

13.10.1. Tramitação da EC n. 82/2014

13.10.2. A segurança viária é questão de saúde pública

13.10.3. Tripé da segurança viária

13.10.4. Segurança viária: questão a ser tratada de forma indissociável da segurança pública

13.10.5. A carreira específica de agentes de trânsito

13.11. Material digital exclusivo

14 –Direitos e Garantias Fundamentais

14.1. Localização

14.2. Evolução dos direitos fundamentais (“gerações” ou “dimensões” de direitos)

14.2.1. Direitos fundamentais da 1.^a dimensão

14.2.2. Direitos fundamentais da 2.^a dimensão

14.2.3. Direitos fundamentais da 3.^a dimensão

14.2.4. Direitos fundamentais da 4.^a dimensão

- 14.2.5. Direitos fundamentais da 5.^a dimensão
- 14.3. Diferenciação entre direitos e garantias fundamentais
- 14.4. Características dos direitos e garantias fundamentais
- 14.5. Abrangência (Titularidade) dos direitos e garantias fundamentais
- 14.6. A aplicabilidade das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
- 14.7. A teoria dos quatro “status” de jellinek
- 14.8. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais
 - 14.8.1. Aspectos gerais
 - 14.8.2. Teorias da eficácia indireta (mediata) ou direta (imediata)
 - 14.8.3. Eficácia “irradiante” dos direitos fundamentais
 - 14.8.4. Alguns precedentes
 - 14.8.5. Brevíssima conclusão
- 14.9. Deveres fundamentais
- 14.10. Direitos individuais e coletivos
 - 14.10.1. Direito à vida (art. 5.^o, “caput”)
 - 14.10.1.1. Aspectos gerais
 - 14.10.1.2. Células-tronco embrionárias
 - 14.10.1.3. Interrupção da gravidez nos casos de gestação de feto anencéfalo
 - 14.10.1.4. Interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre (STF, 1.^a T., HC 124.306 e ADPF 442 — pendente)
 - 14.10.1.5. Distanásia, eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia
 - 14.10.2. Princípio da igualdade (art. 5.^o, “caput”, I)

- 14.10.2.1. Aspectos gerais
- 14.10.2.2. “Separate but equal” e “Treatment as an equal” (Brown v. Board of Education)
- 14.10.2.3. Ações afirmativas — três importantes precedentes da Suprema Corte
- 14.10.2.4. Ações afirmativas — indicação de Ministros para o STF
- 14.10.2.5. Congeneridade
- 14.10.2.6. Foro da residência da mulher no revogado CPC/73. Novas regras trazidas pelo CPC/2015 (foro de domicílio do guardião de filho incapaz) e pela Lei n. 13.894/2019 (foro do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha)
- 14.10.2.7. Art. 384 da CLT: obrigatoriedade de intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de hora extra. Revogação expressa pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
- 14.10.3. Princípio da legalidade (art. 5.º, II)
- 14.10.4. Proibição da tortura (art. 5.º, III)
 - 14.10.4.1. Algemas
 - 14.10.4.2. Lei da Anistia
- 14.10.5. Liberdade da manifestação de pensamento (art. 5.º, IV e V)
 - 14.10.5.1. Liberdade de expressão e a problemática do “hate speech”. “Posição de preferência” da liberdade de expressão
 - 14.10.5.2. Ainda a problemática do “hate speech” (discursos de incitação ao ódio). Liberdade de expressão e a prática do crime de racismo: precedente histórico na jurisprudência do STF — HC 82.424. A liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto
 - 14.10.5.3. Delação anônima
 - 14.10.5.4. “Marcha da maconha”

- 14.10.5.5. Liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, pigmentações de carácter permanente (tatuagem) e o concurso público
- 14.10.6. Liberdade de consciência, crença e culto (art. 5.º, VI a VIII)
 - 14.10.6.1. Regras gerais
 - 14.10.6.2. Ensino religioso nas escolas e a inconstitucionalidade de se obrigar a manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em escolas e bibliotecas públicas
 - 14.10.6.3. Feriados religiosos
 - 14.10.6.4. Casamento perante autoridades religiosas
 - 14.10.6.5. Transusão de sangue nas Testemunhas de Jeová
 - 14.10.6.6. Curandeirismo
 - 14.10.6.7. Crucifixos em repartições públicas
 - 14.10.6.8. Imunidade religiosa
 - 14.10.6.9. Guarda sabática
 - 14.10.6.10. A expressão “Deus seja louvado” nas cédulas de real
 - 14.10.6.11. Sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana
 - 14.10.6.12. Aspectos conclusivos
- 14.10.7. Liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Indenização em caso de dano (art. 5.º, IX e X)
- 14.10.8. Inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5.º, X)
 - 14.10.8.1. Sigilo bancário
 - 14.10.8.2. Proibição da revista íntima (Lei n. 13.271/2016)
 - 14.10.8.3. Gravação clandestina x interceptação telefônica: análise à luz de alguns aspectos trazidos pela Lei n. 13.432/2017 (detetive particular) e das novidades do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019)

- 14.10.9. Inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI)
 - 14.10.9.1. Regras constitucionais
 - 14.10.9.2. O caso específico da “Lei do Mosquito”
- 14.10.10. Sigilo de correspondência e comunicações (art. 5.º, XII)
- 14.10.11. Liberdade de profissão (art. 5.º, XIII)
- 14.10.12. Liberdade de informação (art. 5.º, XIV e XXXIII)
- 14.10.13. Liberdade de locomoção (art. 5.º, XV)
- 14.10.14. Direito de reunião (art. 5.º, XVI)
- 14.10.15. Direito de associação (art. 5.º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI)
- 14.10.16. Direito de propriedade (art. 5.º, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI)
- 14.10.17. Direito de herança e estatuto sucessório (art. 5.º, XXX e XXXI)
- 14.10.18. Propriedade intelectual (art. 5.º, XXVII, XXVIII e XXIX)
- 14.10.19. Defesa do consumidor (art. 5.º, XXXII)
- 14.10.20. Direito de petição e obtenção de certidões (art. 5.º, XXXIV)
- 14.10.21. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV)
- 14.10.22. Limites à retroatividade da lei (art. 5.º, XXXVI)
- 14.10.23. Princípio do promotor natural (art. 5.º, LIII)
- 14.10.24. Princípio do juiz natural ou legal (art. 5.º, XXXVII e LIII)
- 14.10.25. Tribunal Penal Internacional — “TPI” (art. 5.º, § 4.º — EC n. 45/2004)
- 14.10.26. Federalização dos crimes contra direitos humanos (art. 109, V-A e § 5.º — EC n. 45/2004) — Incidente de deslocamento de competência — IDC
- 14.10.27. Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII)
- 14.10.28. Segurança jurídica em matéria criminal (art. 5.º, XXXIX a LXVII) e a teoria dos mandados expressos de criminalização à luz dos direitos fundamentais

- 14.10.28.1. Legalidade e anterioridade da lei penal incriminadora.
Irretroatividade da lei penal “in pejus” (art. 5.º, XXXIX e XL)
- 14.10.28.2. Práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5.º, XLI a XLIV)
- 14.10.28.3. Regras constitucionais sobre as penas (art. 5.º, XLV a XLVIII)
- 14.10.28.4. Direitos assegurados aos presos (art. 5.º, XLIX, L, LXII, LXIII e LXIV)
- 14.10.28.5. Regras sobre extradição (art. 5.º, LI e LII)
- 14.10.28.6. Presunção de inocência (não culpabilidade) (art. 5.º, LVII).
Análise da execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário
- 14.10.28.7. Regras sobre a prisão (art. 5.º, LXI, LXV, LXVI, LXVII)
- 14.10.28.8. Audiências de custódia ou de apresentação
- 14.10.28.9. Identificação criminal (art. 5.º, LVIII)
- 14.10.28.10. Ação penal privada subsidiária da pública (art. 5.º, LIX)
- 14.10.29. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV)
 - 14.10.29.1. Aspectos gerais
 - 14.10.29.2. Interrogatório por videoconferência (on-line)
 - 14.10.29.3. A investigação criminal defensiva e as perspectivas trazidas pela Lei n. 13.432/2017 à luz do contraditório e da ampla defesa
Transferência e inclusão de presos em estabelecimentos
 - 14.10.29.4. penais federais de segurança máxima

- 14.10.29.5. Art. 98 do antigo Regimento Interno do CNJ: necessidade de intimação pessoal de terceiros que demonstrem interesse jurídico nos procedimentos de controle administrativo (PCAs). Correção no novo RI
- 14.10.29.6. Ordem de apresentação das alegações finais — direito fundamental do contraditório e ampla defesa
- 14.10.30. Devido processo legal substantivo ou material (arts. 5.º, LV, e 3.º, I)
- 14.10.31. Provas ilícitas (art. 5.º, LVI)
- 14.10.32. Publicidade dos atos processuais e dever de motivação das decisões judiciais (arts. 5.º, LX, e 93, IX). Perspectivas do CPC/2015
- 14.10.33. Assistência jurídica integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV)
- 14.10.34. Erro judiciário (art. 5.º, LXXV)
- 14.10.35. Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito (art. 5.º, LXXVI)
- 14.10.36. Gratuidade nas ações de “habeas corpus” e “habeas data” (art. 5.º, LXXVII)
- 14.10.37. Celeridade processual (art. 5.º, LXXVIII)
 - 14.10.37.1. Aspectos gerais
 - 14.10.37.2. Victor, RAFA 2030 e VitorIA (STF)
 - 14.10.37.3. Sistema de justiça multiportas (“The Multi-Door Courthouse” — Frank E. A. Sander)
- 14.10.38. Direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais (art. 5.º, LXXIX)
- 14.11. Remédios constitucionais
 - 14.11.1. Os remédios constitucionais nas Constituições brasileiras — quadro esquematizado
 - 14.11.2. “Habeas corpus” (art. 5.º, LXVIII)

- 14.11.2.1. Regras gerais
- 14.11.2.2. Esquematização da evolução histórica do “HC” no constitucionalismo brasileiro
- 14.11.2.3. Competência
- 14.11.2.4. Espécies
- 14.11.2.5. Punições disciplinares militares
- 14.11.2.6. “Habeas corpus” impetrado em face de ato da “Turma Recursal” — competência do TJ — superada a S. 690/STF
- 14.11.2.7. “Habeas corpus” e trancamento do processo de “impeachment”?
- 14.11.2.8. “Habeas corpus” coletivo: perspectivas lançadas a partir do julgamento do HC 143.641 (20.02.2018)
- 14.11.3. Mandado de segurança (art. 5.º, LXIX)
 - 14.11.3.1. Introdução
 - 14.11.3.2. Esquematização da evolução histórica do “MS” no constitucionalismo brasileiro
 - 14.11.3.3. Abrangência
 - 14.11.3.4. Direito líquido e certo
 - 14.11.3.5. Ilegalidade ou abuso de poder
 - 14.11.3.6. Legitimidade ativa e passiva
 - 14.11.3.7. Competência
 - 14.11.3.8. Algumas outras observações
- 14.11.4. Mandado de segurança coletivo (art. 5.º, LXX)
 - 14.11.4.1. Regras gerais
 - 14.11.4.2. Objeto, legitimidade ativa e objetivos
 - 14.11.4.2.1. Objeto
 - 14.11.4.2.2. Legitimidade ativa
 - 14.11.4.2.2.1. Partidos políticos

14.11.4.2.2.2. Organizações sindicais, entidades de classe e associações

14.11.4.2.3. Objetivos

14.11.5. Mandado de injunção (art. 5.º, LXXI)

14.11.5.1. Aspectos gerais

14.11.5.2. Omissão total ou parcial

14.11.5.3. Legitimidade ativa

14.11.5.4. Legitimidade passiva

14.11.5.5. Competência

14.11.5.6. Procedimento

14.11.5.7. Efeitos da decisão

14.11.5.8. Especificidades do MI coletivo

14.11.6. “Habeas data” (art. 5.º, LXXII)

14.11.6.1. Aspectos gerais

14.11.6.2. Legitimidade ativa e passiva

14.11.6.3. Procedimento

14.11.6.4. Competência

14.11.7. Ação popular (art. 5.º, LXXIII)

14.11.7.1. Aspectos gerais

14.11.7.2. Esquematização da evolução histórica da “ação popular”
no constitucionalismo brasileiro

14.11.7.3. Requisitos

14.11.7.4. Legitimidade ativa e passiva

14.11.7.5. Competência

14.11.7.5.1. Regra geral — juízo de primeiro grau

14.11.7.5.2. SEBRAE — competência da Justiça comum

14.11.7.5.3. Ação popular contra o CNMP — incompetência do STF

14.11.7.5.4. Incompetência originária do STF e indicação do órgão
competente

14.11.7.6. Outras regras

14.12. Material digital exclusivo

15 –Direitos Sociais

15.1. Aspectos gerais

15.2. Breves comentários aos direitos sociais

15.2.1. Direito à educação

15.2.2. Direito à saúde

15.2.3. Direito à alimentação

15.2.4. Direito ao trabalho

15.2.5. Direito à moradia

15.2.6. Direito ao transporte

15.2.7. Direito ao lazer

15.2.8. Direito à segurança

15.2.9. Direito à previdência social

15.2.10. Proteção à maternidade e à infância

15.2.10.1. Regras gerais

15.2.10.2. Licença adotante x licença gestante

15.2.11. Assistência aos desamparados

15.3. “Busca da felicidade”

15.4. Direitos relativos aos trabalhadores

15.4.1. Direitos sociais individuais dos trabalhadores

15.4.2. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores (arts. 8.º a 11)

15.4.2.1. Direito de associação profissional ou sindical

15.4.2.2. Direito de greve

15.4.2.3. Direito de substituição processual

- 15.4.2.4. Direito de participação
- 15.4.2.5. Direito de representação classista
- 15.5. “Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática dos direitos sociais, culturais e econômicos (canotilho)
 - 15.5.1. Princípio do não retrocesso social ou da proibição da evolução reacionária
 - 15.5.2. “Judicialização da saúde”: fornecimento de medicamentos
 - 15.5.3. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço
- 15.6. Material digital exclusivo

16 –Nacionalidade

- 16.1. Conceito
 - 16.1.1. Definições correlatas
- 16.2. Espécies de nacionalidade e critérios para a sua aquisição
- 16.3. Brasileiro nato
- 16.4. Brasileiro naturalizado
 - 16.4.1. Noções introdutórias: procedimento
 - 16.4.2. Naturalização ordinária constitucional em relação aos originários de países de língua portuguesa
 - 16.4.3. Naturalização ordinária legal
 - 16.4.4. Naturalização especial
 - 16.4.5. Naturalização provisória
 - 16.4.6. Naturalização extraordinária ou quinquenal

Conclusão de curso superior: ainda subsiste com a revogação
16.4.7. do Estatuto do Estrangeiro?

16.5. Quase nacionalidade — portugueses — Art. 12, § 1.º —
reciprocidade

16.6. A lei poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e
naturalizados?

16.6.1. Regra geral

16.6.2. Hipóteses taxativas de exceção à regra geral

16.6.2.1. Extradicação

16.6.2.1.1. Extradicação ativa

16.6.2.1.2. Extradicação passiva: brasileiro nato x brasileiro
naturalizado (art. 5.º, LI)

16.6.2.1.3. Extradicação passiva: regras procedimentais

16.6.2.1.4. Extradicação passiva: necessidade de prisão do
extraditando?

16.6.2.1.5. Extradicação passiva: vedações legais

16.6.2.1.6. Extradicação passiva: vedações legais em relação à entrega
do extraditando

16.6.2.1.7. Extradicação passiva: e se o extraditando for casado ou
viver em união estável com pessoa de nacionalidade
brasileira ou tiver filho brasileiro? Haverá óbice, por
esse motivo, ao pedido de extradicação?

16.6.2.1.8. Extradicação passiva: entendendo o STF pela procedência
do pedido de extradicação, o Presidente da República será
obrigado a extraditar o requisitado?

16.6.2.2. Cargos privativos de brasileiros natos (art. 12, § 3.º)

16.6.2.3. Perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado: fraude
relacionada ao processo de naturalização ou de atentado

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 12, § 4.º, I, na redação dada pela EC n. 131/2023)

16.6.2.4. Conselho da República (art. 89, VII)

16.6.2.5. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222)

16.7. Medidas de retirada compulsória: repatriação, deportação e expulsão

16.7.1. Repatriação

16.7.2. Deportação

16.7.3. Expulsão

16.7.4. Banimento: existe expulsão ou banimento de brasileiros?

16.8. Asilo político e refúgio (direito de permanecer no Brasil)

16.9. Perda da nacionalidade

16.9.1. Hipóteses de perda da nacionalidade

16.9.1.1. Cancelamento da naturalização: a regra anterior e o reforço da necessidade de sentença judicial transitada em julgado

16.9.1.2. Aquisição de outra nacionalidade: como ficou a regra constitucional diante da reforma introduzida pela EC n. 131/2023?

16.10. Reaquisição da nacionalidade brasileira perdida

16.11. Material digital exclusivo

17 –Direitos Políticos

17.1. Noções introdutórias

- 17.1.1. Democracia semidireta ou participativa
- 17.1.2. Plebiscito “versus” referendo: experiências na história brasileira
 - 17.1.2.1. Referendo para manutenção ou não do regime parlamentarista (1963)
 - 17.1.2.2. Plebiscito para a escolha entre a forma (república ou monarquia constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) (1993)
 - 17.1.2.3. Referendo para a manifestação do eleitorado sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional (2005)
 - 17.1.2.4. Referendo no Estado do Acre para decidir sobre o fuso horário (2010)
 - 17.1.2.5. Plebiscitos no Estado do Pará para decidir sobre a formação dos Estados do Carajás e do Tapajós (2011)
- 17.1.3. O resultado do plebiscito ou do referendo pode ser modificado por lei ou emenda à Constituição?
- 17.1.4. Quadro comparativo: plebiscito “versus” referendo
- 17.1.5. EC n. 111, de 28.09.2021
- 17.1.6. Outros institutos de democracia semidireta ou participativa: “recall” e veto popular
- 17.1.7. Democracia contemporânea: novas perspectivas (Luís Roberto Barroso)
- 17.2. Soberania popular, nacionalidade, cidadania, sufrágio, voto e escrutínio
- 17.3. Direito político positivo (direito de sufrágio)
 - 17.3.1. Capacidade eleitoral ativa

17.3.2. Capacidade eleitoral passiva

17.3.2.1. Condições de elegibilidade

17.4. Direitos políticos negativos

17.4.1. Inelegibilidades

17.4.1.1. Inelegibilidades absolutas

17.4.1.2. Inelegibilidades relativas

17.4.1.2.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida
(por motivos funcionais)

17.4.1.2.1.1. Inelegibilidade relativa em razão da função exercida
para um terceiro mandato sucessivo

17.4.1.2.1.2. A figura do denominado “prefeito itinerante” ou
“prefeito profissional”

17.4.1.2.1.3. Inelegibilidade relativa em razão da função para
concorrer a outros cargos

17.4.1.2.2. Inelegibilidade relativa em razão do parentesco

17.4.1.2.3. Militares

17.4.1.2.4. Inelegibilidades previstas em lei complementar

17.4.2. Candidatos com “ficha suja”: inelegibilidade?

17.4.3. Privação dos direitos políticos — perda e suspensão

17.4.3.1. Perda dos direitos políticos (arts. 15, I e IV, e 12, § 4.º, II,
CF/88)

17.4.3.2. Suspensão dos direitos políticos (arts. 15, II, III e V, e 55,
II, e § 1.º, CF/88; art. 17.3, Dec. n. 3.927/2001 c/c o art.
1.º, I, “b”, LC n. 64/90)

17.4.4. Reaquisição dos direitos políticos perdidos ou suspensos

17.5. Servidor público e exercício do mandato eletivo

17.6. Material digital exclusivo

18 –Partidos Políticos

- 18.1. Conceito
- 18.2. Regras constitucionais
- 18.3. Fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão — direito de antena (EC n. 97/2017)
- 18.4. Coligações partidárias: evolução jurisprudencial e reformas constitucionais (ECS ns. 52/2006 e 97/2017)
 - 18.4.1. Regras gerais
 - 18.4.2. Primeiro momento — a consagração da regra da verticalização das coligações partidárias pelo TSE
 - 18.4.3. Ataques à regra da verticalização das coligações partidárias fixada pelo TSE e o destaque para o art. 16, CF/88 (cláusula constitucional da anualidade)
 - 18.4.4. Ataques à regra da EC n. 52/2006, que expressamente acabou com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Mantida a verticalização para as eleições de 2006 (anualidade eleitoral — art. 16, CF). A EC n. 52/2006 entrou em vigor na data de sua publicação, mas somente pôde ser aplicada às eleições que ocorreram até um ano da data de sua vigência
 - 18.4.5. EC n. 97/2017: alteração da Constituição Federal para se vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, admitindo-as apenas, como faculdade, para as eleições majoritárias
 - 18.4.6. Federações partidárias e a ADI 7.021 (STF)
- 18.5. fidelidade partidária

- 18.5.1. Sistema proporcional
- 18.5.2. Sistema majoritário
- 18.5.3. Resolução do TSE x Minirreforma Eleitoral (Lei n. 13.165/2015). Aspectos sobre a justa causa para desfiliação partidária e o caso específico do sistema majoritário
- 18.5.4. EC n. 91/2016 (“Janela Partidária Constitucional”) e Minirreforma Eleitoral (“Janela Partidária Legal”)
- 18.5.5. EC n. 97/2017 (nova “Janela Partidária Constitucional”)
- 18.5.6. EC n. 111/2021 (nova “Minirreforma” Eleitoral)
- 18.6. a vaga decorrente do licenciamento de titulares de mandato parlamentar deve ser ocupada pelos suplentes das coligações OU dos partidos?
- 18.7. Financiamento das campanhas eleitorais — ADI 4.650, ADI 5.394 (aspectos da minirreforma eleitoral de 2015 — Lei n. 13.165) e ADI 5.494 (perspectivas a partir da minirreforma eleitoral de 2017 — Lei n. 13.488)
- 18.8. EC n. 111/2021 — Ação afirmativa 1
- 18.9. EC n. 117/2022 — Ação afirmativa 2
- 18.10. Material digital exclusivo

19 –Ordem Social

- 19.1. Aspectos gerais
 - 19.1.1. Valores da ordem social: base e objetivo
 - 19.1.2. Conteúdo da ordem social
- 19.2. Seguridade social

19.2.1. Princípios orientadores da organização da seguridade social

19.2.2. Financiamento da seguridade social

19.3. Educação

19.3.1. “Homeschooling” (RE 888.815)

19.3.2. FUNDEB — Aspectos gerais — ECs ns. 53/2006 e 108/2020

19.3.3. Quadro esquematizado da educação escolar

19.4. Cultura

19.4.1. Plano Nacional de Cultura (EC n. 48/2005)

19.4.2. Sistema Nacional de Cultura (EC n. 71/2012)

19.5. Desporto

19.5.1. Desporto em sentido amplo

19.5.2. Modalidades de desporto

19.5.3. Papel do Estado e das entidades dirigentes e associações na promoção do desporto

19.5.4. Destinação dos recursos públicos para o desporto

19.5.5. Manifestações desportivas de “criação nacional”

19.5.6. Justiça Desportiva

19.5.6.1. Regras gerais, natureza jurídica e composição

19.5.6.2. Instância administrativa de curso forçado: exceção ao princípio do acesso incondicionado ao Poder Judiciário. Necessidade de esgotamento das vias administrativas

19.5.6.3. Questões trabalhistas: competência da Justiça do Trabalho

19.5.6.4. Vedação do exercício de funções na Justiça Desportiva por integrantes do Poder Judiciário

19.5.7. Bingos e a questão específica das loterias como serviço público (competência administrativa)

19.6. Ciência, tecnologia e inovação (EC n. 85/2015)

- 19.6.1. Perspectivas introduzidas pela EC n. 85/2015
- 19.6.2. O papel do Estado
- 19.6.3. Modalidades de pesquisa e o tratamento prioritário do Estado
- 19.6.4. Apoio e incentivo do Estado
- 19.6.5. Estado Social de Direito: concepção social do mercado
- 19.6.6. O destaque para a biotecnologia

19.7. Comunicação social

- 19.7.1. Princípios orientadores da comunicação social
- 19.7.2. Princípios a orientar a produção e a programação das emissoras de rádio e TV
- 19.7.3. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens
- 19.7.4. Serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (TV)
 - 19.7.4.1. Diferenciação entre os serviços de telecomunicação e de radiodifusão (EC n. 8/95)
 - 19.7.4.2. Concessão, permissão e autorização
 - 19.7.4.3. Prazo da concessão ou permissão e da autorização
 - 19.7.4.4. Outorga e renovação (da concessão ou permissão e da autorização)
 - 19.7.4.5. Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T): consignação de mais um canal de radiofrequência às concessionárias e “autorizadas” dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens, sem apreciação do Congresso Nacional
- 19.7.5. Conselho de Comunicação Social: órgão auxiliar do CN
- 19.7.6. Direito de antena e a EC n. 97/2017

- 19.7.7. Lei de Imprensa — ADPF 130
- 19.7.8. “Lei Eleitoral sobre o Humor”, Res. 23.714/2022 do TSE (Eleições 2022) e a problemática das “fake news”

19.8. Meio ambiente

- 19.8.1. Conceito de meio ambiente
- 19.8.2. Aspectos do meio ambiente
- 19.8.3. Direitos humanos, direito ao desenvolvimento e direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações
 - 19.8.3.1. A problemática
 - 19.8.3.2. Sustentabilidade: solução para a problemática
- 19.8.4. A proteção ambiental no constitucionalismo brasileiro
- 19.8.5. Natureza jurídica do meio ambiente e a justiça distributiva entre as presentes e futuras gerações
- 19.8.6. Incumbência do Poder Público
- 19.8.7. Crueldade contra animais?
 - 19.8.7.1. Farra do boi
 - 19.8.7.2. Rinhas ou brigas de galo
 - 19.8.7.3. Rodeios de animais
 - 19.8.7.4. O julgamento específico da vaquejada — ADI 4.983 (j. 06.10.2016) e a EC n. 96/2017
 - 19.8.7.5. Animais em circo
 - 19.8.7.5.1. A origem do circo — breve nota
 - 19.8.7.5.2. O adestramento de animais em circos
 - 19.8.7.5.3. O fim dos animais em circos significaria o fim da cultura circense?
- 19.8.8. Importação de pneus usados — ADPF 101
- 19.8.9. Exploração de recursos minerais

- 19.8.10. Responsabilidade por danos ambientais
- 19.8.11. Ecossistemas especialmente protegidos e erigidos à categoria de patrimônio nacional
- 19.8.12. Os “Soldados da Borracha” e a EC n. 78/2014
- 19.8.13. Terras devolutas
 - 19.8.13.1. Classificação dos bens públicos: as terras devolutas enquanto bens dominicais
 - 19.8.13.2. Titularidade
 - 19.8.13.3. Terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado necessárias à proteção dos ecossistemas naturais — indisponibilidade
- 19.8.14. Localização das usinas nucleares: necessidade de lei federal
- 19.9. Família, criança, adolescente, jovem e pessoa idosa
 - 19.9.1. Família: conceito de entidade familiar
 - 19.9.2. União homoafetiva (união estável entre pessoas do mesmo sexo)
 - 19.9.3. Impossibilidade de reconhecimento de união estável e de relação homoafetiva concomitantes para fins de rateio de pensão por morte — RE 1.045.273
 - 19.9.4. Transexualidade: transgêneros e o direito de alteração no registro civil
 - 19.9.5. O enquadramento da homofobia e da transfobia como crimes de racismo pelo STF (ADO 26 e MI 4.733)
 - 19.9.6. A união estável pode ser reconhecida em relação a uma menor de 14 anos estuprada que veio a se casar com o agressor, para efeitos de extinção de punibilidade quando era admitida (antes da revogação do art. 107, VII, CP)?
 - 19.9.7. Família: assistência e proteção contra a violência doméstica. As particularidades da denominada Lei Maria da Penha (ADC 19 e ADI 4.424)

- 19.9.7.1. Lei Maria da Penha: instrumento de proteção efetiva dos direitos fundamentais
- 19.9.7.2. Não aplicação da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)
- 19.9.7.3. Constitucionalidade das regras até que sejam estruturados os “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
- 19.9.7.4. Crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher: ação penal pública incondicionada
- 19.9.8. Casamento: regras gerais; gratuidade da celebração; efeito civil; liberdade de crença (centro espírita, candomblé, umbanda etc.)
- 19.9.9. Divórcio: forma de dissolução do casamento civil à luz da EC n. 66/2010 e do CPC/2015. A posição do STF no RE 1.167.478 (j. 08.11.2023)
- 19.9.10. Liberdade para o planejamento familiar: dignidade da pessoa humana e paternidade responsável
- 19.9.11. Criança, adolescente e jovem (EC n. 65/2010)
- 19.9.12. Criança, adolescente e jovem: proteção especial. Avanços trazidos pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
- 19.9.13. Alienação parental
- 19.9.14. Adoção
 - 19.9.14.1. Regras gerais sobre adoção
 - 19.9.14.2. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6.º. Posição do STF na AR 1.811
 - 19.9.14.3. Adoção internacional

- 19.9.14.4. Adoção por casal homoafetivo ou transexual
- 19.9.15. Direito de ação de investigação de paternidade: a problemática da submissão coercitiva ao exame de DNA
- 19.9.16. Portadores de deficiência
 - 19.9.16.1. Proteção constitucional
 - 19.9.16.2. Convenções internacionais sobre direitos humanos com “status” constitucional
 - 19.9.16.3. Outras proteções infraconstitucionais
- 19.9.17. Inimputabilidade penal
- 19.9.18. Dever de reciprocidade entre pais e filhos
- 19.9.19. Pessoa idosa
 - 19.9.19.1. Princípios da solidariedade e proteção à luz da “reserva do possível”
 - 19.9.19.2. Pessoa idosa e transporte público: “constitucionalismo fraternal” ou “altruístico” — “ações distributivistas e solidárias” — “direito fraternal”
 - 19.9.19.3. Celeridade do processo e crimes praticados contra a pessoa idosa
 - 19.9.19.4. Estelionato contra a pessoa idosa
 - 19.9.19.5. Casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos (ARE 1.309.642)
- 19.10. Indígenas
 - 19.10.1. Os indígenas no constitucionalismo brasileiro e a questão terminológica
 - 19.10.2. Proteção das “minorias nacionais” e a importância da “terra”
 - 19.10.3. Terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas
 - 19.10.3.1. Bens da União. Terras destinadas à posse permanente dos indígenas: bens públicos de uso especial

- Terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas: marco
 - 19.10.3.2. temporal ou tradicionalidade?
 - 19.10.3.3. Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas: conceito
 - 19.10.3.4. Nulidade e extinção dos atos que atentem contra as “terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas”
 - 19.10.4. Indigenato: fonte para o direito dos indígenas sobre as suas terras
 - 19.10.5. Usufruto exclusivo dos indígenas e a mineração em terras indígenas
 - 19.10.6. Regras constitucionais para a remoção dos grupos indígenas
 - 19.10.7. Demarcação das terras indígenas
 - 19.10.7.1. Aspectos gerais
 - 19.10.8. Defesa judicial dos direitos e interesses dos indígenas
 - 19.10.8.1. Legitimidade ativa: indígenas, comunidades, organizações e o MP (Federal ou Estadual)
 - 19.10.8.2. Competência: Justiça Federal x Justiça Estadual
 - 19.10.9. Educação nas comunidades indígenas
 - 19.10.10. Infanticídio indígena
- 19.11. Material digital exclusivo

20 –Ordem econômica e financeira

- 20.1 Material digital exclusivo

21 –Princípios fundamentais

- 21.1. justificativas iniciais
- 21.2. República

- 21.3. federação
- 21.4. estado democrático de direito
 - 21.4.1. Aspectos gerais
 - 21.4.2. A Lei da Anistia, a ADPF 153 e a decisão da “Corte Interamericana de Direitos Humanos” (ADPF 320)
- 21.5. Separação de “poderes”
- 21.6. Fundamentos da República Federativa do Brasil
- 21.7. objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
- 21.8. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais
 - 21.8.1. Art. 4.º, CF/88
- 21.9. Material digital exclusivo

Referências



UMA HOMENAGEM ESPECIAL

Gostaria de pedir licença ao meu ilustre leitor e fazer um agradecimento que, apesar de particular, é muito especial...

Gostaria de agradecer a você, minha querida Má, por tudo o que representa, não só em minha vida como também para o resultado deste nosso “filho”.

Como muitos devem saber, o “nosso” *Esquematizado* surgiu no ano de 2000, como um sonho e a concretização de um projeto de vida...

Hoje, depois de 24 anos, com milhares de exemplares vendidos, gostaria de confessar que tudo isso — além das muitas pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram, inclusive o meu ilustre leitor, fiel e amigo, que constantemente envia sugestões — tem a mão de uma pessoa chamada Má.

Todos devem presumir a dificuldade que é “lutar”, diária, diuturna e, também, literalmente, durante muitas e muitas noites de estudo, para que o livro continue a cumprir o seu relevante papel na vida de muitas pessoas...

Todos podem imaginar os momentos de dificuldade, de esgotamento... que poderiam se comparar à luta diária dos concurseiros de nosso país, que se “fecham” ao mundo, que se afastam dos entes queridos, que se privam de momentos prazerosos, sempre em busca de um sonho muito nobre, de um projeto de vida, marcado por horas e mais horas isolados: o concurseiro “guerreiro”, os livros, o quarto, a biblioteca e Deus para nos guiar.

Muitas vezes nos perguntamos, eu inclusive, se tudo está valendo a pena, se tanto esforço está valendo a pena, se, pela fragilidade da vida, devemos continuar nessa trajetória.

Então, é nesses momentos de dificuldade que vejo a importância que é ter uma pessoa como a Má: atrás, para me segurar nos momentos difíceis, projetando-me para o sonho; à frente, servindo como força propulsora; e ao

lado, me estimulando, encorajando, incentivando e entusiasmando...

Posso dizer, então, que tudo isso que o *Esquematizado* hoje representa tem a mão da Má, que nunca deixou de sonhar este nosso sonho.

Muitas horas, muitas noites... Assim, depois de tanta coisa que passamos juntos, eu só tenho a lhe agradecer por tudo, Má, especialmente por sua alegria de vida, a contribuir para a realização do sonho de muitos e ilustres “concurseiros” que, honrosamente, acreditaram em “nosso” *Esquematizado*.

Assim, Má, por tudo e para sempre, o meu muito obrigado por ajudar a manter vivo este nosso sonho.

Precisava dividir essa felicidade e berrar para todo mundo que eu te amo muuuuuuito e, de alguma maneira, te dizer o quanto você é importante nisso tudo e na minha vida! Valeu...



MAIS UMA HOMENAGEM ESPECIAL¹

Gostaria de pedir novamente licença ao meu ilustre leitor e fazer mais um agradecimento que, apesar de particular, é, também, muito especial...

Com a graça de Deus (porque ter um filho é uma bênção), eu e a Má esperávamos nossa filha para o dia 20 de julho de 2010. Apressadinha como os pais, no dia 25 de maio de 2010, a pequena (literalmente, porque prematura) Manoela veio ao mundo.

Realmente, como muitos diziam, a minha vida mudou! Tudo é muito estranho e novo. Como é possível que aquele “tesouro” tenha saído da barriga da minha esposa?

Dizem que se parece um pouco comigo, e fico, mais ainda, impressionado. Como é a natureza!

E agora, pela primeira vez, estou vivenciando a emoção de ser pai... Que explosão de sentimentos! Realmente, o mundo fica paralisado quando eu fico olhando nos olhos dela...

Acho que tudo passa a fazer sentido. Tanta luta diária, tantas noites sem dormir (escrevendo, atualizando os livros, em solitário enclausuramento), tantos sonhos sonhados... Agora tudo passa a ter um significado: consigo entender o verdadeiro sentido do *amor incondicional* dos pais pelos filhos...

Realmente, a atualização deste ano exigiu muito. Foram dois meses trabalhando quase 20 horas por dia. A pequena Manoela não entendia o que estava acontecendo. Desde que ela nasceu estávamos grudados. Falava para ela sobre a minha missão e o compromisso que tenho com os meus ilustres “guerreiros” concurseiros. Não sei se ela entendia... Explicava para ela que o *papai* logo voltaria a brincar. Que loucura isso tudo... Que dualidade. Que dificuldade.

Muitas vezes, de madrugada, beijava a Manu e a Má e era como se aquilo me desse mais forças. Quando parecia que não conseguiria mais, eu pensava nas duas... pensava nos meus leitores e no que passam nessa fase tão difícil da vida. Pensava na minha responsabilidade e em cada aluno que vejo renunciando a tantas coisas.

Dizem que todo ser humano tem de *plantar árvores, escrever livros e ter filhos*. De fato, isso tudo já fiz, mas, se soubesse, decididamente, *teria invertido a ordem*!

Escreverei mais livros (essa é a minha missão!) e plantarei mais árvores. Mas, para ser sincero, o que penso mesmo é em ter mais um filho.² E aconselho: não deixem que os projetos (muitos profissionais) sejam a única prioridade da vida. Ao lado de pessoas queridas, continuemos a sonhar os sonhos sonhados e, assim, a realizar os projetos idealizados. Sejam felizes! A vida é curta... Obrigado, Manu, por dar sentido a isso tudo. Obrigado, Má, por ter me “dado” a Manu e por estar ao meu lado, sempre acreditando nesse nosso sonho.



UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL³

Mais uma vez, gostaria de pedir licença ao meu querido leitor para trazer uma nova e justa homenagem especial...

Quando abri o meu coração em homenagem feita à Manoela, que mudou as nossas vidas, escrevi que, depois de plantar árvores, escrever livros e ter um filho, pensava, mesmo, era em ter mais um filho.

Três anos depois, Max vem ao mundo, trazendo muita alegria e emoção para todos nós.

É impressionante como ele (o nosso querido Macão) olha dentro do meu olho e, no olhar, traduz o sentimento do amor...

Tenho dito que o Max ou a Manu serão os atualizadores do NOSSO *Esquematizado*, afinal todos sabem qual é a minha missão de vida (ajudar a realizar sonhos!). Não sei se irão para o mundo do direito... Contudo, tenho certeza de que os dois já têm a absoluta noção do que significa o *Esquematizado* em nossas vidas e nas vidas das pessoas, dos “guerreiros concurseiros” do Brasil.

Mesmo pequeno, com menos de um ano de idade, parecia que o Max entendia o que estava acontecendo. Sempre que eu dava uma parada no processo de atualização, ele, com a sua alegria, vinha me beijar e me incentivar.

Nesse período (foram quase 3 meses, trabalhando em média mais de 10 horas por dia), o mais difícil era ter que pedir para a Má segurar as pontas, buscando minimizar a ausência do papai... Em alguns momentos, desesperado em vê-los em casa, durante o mês de janeiro, todos em férias, cheguei a pedir para a Má viajar com eles à praia. Como era complicada a despedida.

E, para piorar, a Manu, já com 3 anos, perguntava: “papai, você vai junto?”. Em uma das várias vezes que falei que não poderia ir, sentei em frente ao computador e “travei”. Tremia... Não conseguia escrever uma linha. Foi quando, incentivado pelos milhares de seguidores das redes sociais, larguei tudo e fui correndo ver a minha “turminha”. Que emoção! Lembro que paramos na estrada para comer pastel. Como era bom estar com eles, o simples fato de estarmos juntos. Foi mesmo energizante aquele final de semana (aqui agradeço aos amigos do Brasil pela força).

Pois bem, como todos sabem, a primeira edição do *NOSSO Esquematizado* foi publicada no ano 2000. Já são vários anos de constante e pessoal aperfeiçoamento do trabalho. Já são muitas horas de enclausuramento. Percebi que o *Esquematizado*, e não poderia ser de outra maneira, faz parte das nossas vidas. É como se fosse mais um dos nossos “filhos” e, assim, a “turminha” se solidifica: Má, Manu, Max, o *NOSSO Esquematizado* e, agora, para completar, o Puffeiro (o cachorrinho que o Papai Noel trouxe para a Manu no último Natal...) e a Chachinha, uma maltês pela qual a Manu se apaixonou durante esse processo das atualizações (Puffeiro tem dormido no meu cunhado, rs!).

Vivemos o livro e lutamos para que ele continue a servir de ferramenta, ajudando na realização de sonhos... (com certeza, o meu leitor percebe que eu não consigo delegar o trabalho de atualização, por mais dolorido e desgastante que seja...).

E o Max, o que significou nisso tudo? Sem dúvida, a confirmação de que o amor não se divide, mas se soma, se fortalece, se potencializa, enfim se solidifica a cada dia. É impressionante o sentimento que percebo em seu olhar. Macão, você é muito especial e obrigado por ter vindo para somar.

Má, então, novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me “dado” a Manu e o Max e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de todos nós. “Turminha”, AMO vocês...



MAIS UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL⁴

Novamente, gostaria de pedir licença aos meus queridos leitores para trazer *mais uma nova e justa homenagem especial...*

Como muitos perceberam, esta mensagem está sendo escrita para a 19.^a edição, no ano de 2015, mais precisamente, no dia 20.06.2015, data de seu fechamento.

Hoje, o Tommy está fazendo 5 meses de vida. Uma alegria que chegou no meio do trabalho de atualização, tornando este, certamente, mais leve.

Nesses 15 anos de existência do livro, em nenhum momento levei tanto tempo para atualizá-lo. Foram 6 meses. Hoje, neste momento, até me assusto ao ver o Tommy já entendendo tudo com um simples olhar.

Pensando bem, o susto é maior quando vejo que o tempo passou e a vida ao nosso redor não parou. Por isso, sem dúvida, os sentimentos despertados pela chegada da Manu e do Max potencializam-se.

Agora, com 3 filhos e vivendo o livro com eles, tenho certeza de que este compõe as nossas vidas.

Outro dia, nesta reta final, quando disse que tinha acabado o trabalho de revisão, a Manu deu um berro de alegria misturado com alívio: “acabou, Papai?” “Podemos viajar agora?” “Podemos brincar mais?”.

Realmente, é bastante complicado. Mas temos que procurar encontrar um equilíbrio para, juntos, avançarmos neste grandioso projeto de vida, aliás, uma decisão tomada há 15 anos!

Certamente, Manu e Max sabem o valor do *Esquematizado*. Certamente, cada um, do seu modo, sabe que lutamos para ajudar milhares de “guerreiros” do Brasil.

E vou dizer uma coisa: tenho absoluta certeza de que o Tommy, aqui homenageado, também já entendeu tudo. Eu trabalhar em casa, no processo de atualização, faz com que eles se integrem nessa intensa rotina. Muitas

vezes, na correria do dia, Tommy ficava no meu colo, vendo-me escrever. Isso mesmo, escrevia enquanto ele estava no meu colo, pois a Má estava com o Max (de 2 anos completados em maio) e a Manu (de 5, do mesmo mês), que também queriam atenção (e olha que tenho de reconhecer a extraordinária ajuda da Má e, também, da Vovó Tina e da Tia Lili).

Esta, sem dúvida, a realidade de muitos, com ou sem filhos, mas sempre encontrando espaço na vida corrida para nutrir o grande sonho.

Devo também dizer que vocês, meus queridos leitores, merecem todo o meu respeito, a minha admiração e consideração, pois sei o que passam. Assim, não consigo delegar o trabalho, que faço artesanalmente, pessoalmente e, por isso, nesta nova fase da vida (claro, sem contar as inúmeras alterações de atos normativos, jurisprudência, códigos etc.), o motivo de termos levado 6 meses para a atualização.

Chegamos ao final satisfeitos com o resultado. A nova edição está com 109 novas páginas e Tommy com 5 meses, justificando e dando razão para essa nossa opção de vida. E tem algo inexplicável: como ele me olha quando estou por perto. Talvez esse seu olhar suplique para que eu termine logo. Mas, no fundo, a paz que me transmite, sem dúvida, reflete a mensagem de que ele sabe a importância disso tudo, especialmente na vida das pessoas.

É isso. Valeu, amigos do Brasil, por tanto apoio que deram nas redes sociais. Tenham certeza de que vocês também foram essenciais. Espero que gostem do trabalho final.

Finalmente, este texto não poderia terminar de outra forma, senão exatamente como aquele que homenageou o Max, mas, agora, naturalmente, *atualizado*: “Má, novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me ‘dado’ a Manu, o Max e o Tommy e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de todos nós. ‘Turminha’ (agora maior — e acho que levei a sério aquela história de *plantar árvores, escrever livros e ter filhos*), AMO vocês...”.

À minha **mãe**, exemplo de vida, guerreira da vida, inspiração espiritual para os que a cercam, sensibilidade natural, pureza inexplicável como o nascer do sol, o meu muito obrigado por ter sempre apoiado os meus projetos intelectuais e por termos juntos vencido tantos obstáculos...

Ao meu **pai**, que tanto me ensinou, que tanto me orientou, que com certeza também foi o responsável pelas lições da vida, obrigado pela força; saiba que o tenho eternamente em meu coração...

Aos meus **irmãos**, por tudo o que representam e pelo exemplo de garra, perseverança e alegria de vida...

Ao **Felipe**, ao **Rafa**, à **Laurinha** e ao **Miguel**, meus sobrinhos, pela renovação de todos esses sentimentos...

A todos vocês dedico este trabalho.

A vocês, **Má**, **Manu**, **Max** e **Tommy**, por tudo o que significam em minha vida, alegrando-a, energizando-a, abençoando-a; pela pureza, preciosidade, ternura, meiguice e amor; por tanta força e positividade depositadas neste meu projeto de vida; com carinho, o meu eterno agradecimento.



AGRADECIMENTOS

Todos, com certeza, tiveram um papel fundamental para que este trabalho se concretizasse, sendo muitos os nomes que deveriam ser relacionados para não incorrer em injustiças.

Devo, contudo, lembrar algumas pessoas que, com certeza, influenciaram muito o meu desenvolvimento acadêmico.

Ada Pellegrini Grinover, exemplo de jurista, exemplo de doutrinadora, exemplo de cientista do direito, exemplo de pensadora, pessoa a quem devo o eterno agradecimento pela oportunidade de desenvolver os estudos de pós-graduação (**mestrado** e **doutorado**) na Faculdade de Direito da USP e pelo apoio neste trabalho conjuntamente com o projeto de pesquisa, encontrando, ainda, dentre tantos afazeres, o precioso tempo para apresentá-lo à comunidade acadêmica.

Antonio Carlos Marcato, ex-membro do MP, Desembargador aposentado e agora advogado. Sem dúvida, poucos têm essa “tríplice” experiência que o mestre, com generosidade, compartilha, divulgando o seu conhecimento, ensinando e encantando.

Damásio de Jesus, mestre de todos nós, modelo de paixão e devoção pela ciência do direito, ensinando-nos que o aprendizado não tem limites ou fronteiras: seremos eternos estudiosos, pelo resto de nossas vidas.

Leda Pereira Mota, amiga de sempre que, nos bancos acadêmicos, fez nascer em mim a paixão pelo Direito Constitucional quando me convidou para auxiliá-la nas aulas de seminário na PUC/SP, espaço utilizado em conjunto com os alunos, como verdadeiro “laboratório experimental”, discutindo diversas questões sobre a matéria. Você será nossa eterna mestra!

Maria Helena Diniz, pela amizade sincera e por ter mostrado para mim e, creio, para todos os que com ela convivem o exemplo de vida e de ser humano, bem como de grande estudiosa do direito.

Agradeço ao *Damásio Educacional*, pela credibilidade conferida a este estudo e por acreditar nesse grande sonho, alimentando-o diariamente.

Agradeço, também, ao *Marcato Cursos Jurídicos*, por tantas oportunidades e alegrias vividas no passado.

Agradeço ao *ProOrdem — Centro de Estudos Jurídicos*, nas pessoas de *Marco Antônio Clauss*, *Joana D’Arc Alves Trindade* e *Clerice Pires*, pela amizade e pelo apoio que, no início, depositaram neste trabalho.

Sinceros são os meus agradecimentos à *OAB/SP*, que, apoiando o desenvolvimento dos advogados, abriu as portas para que eu pudesse apresentar-me em palestra proferida na *OAB/Pinheiros*. Aproveito este espaço para declarar a minha eterna gratidão a toda a comunidade pinheirense, na pessoa de seu ex-Presidente, o amigo *José Vicente Laino*, exemplo humano de pessoa e profissional.

Gostaria de agradecer o carinho que tenho recebido em todo o Brasil nos cursos e palestras, com os quais muito aprendi.

Aliás, não poderia deixar de expressamente agradecer a dois grandes mestres. Em primeiro lugar (*ladies first...*), à amiga *Noêmia Garcia Porto*, por tudo e por ter-me dado a honra de dialogar sobre grandes temas do direito constitucional. Em segundo, ao grande mestre *Cássio Juvenal Faria*, por tanta credibilidade depositada neste estudo, o que, para mim, é um grande orgulho! Simplesmente, o meu muitíssimo obrigado...

Tio Beto, Tia Christina, Li e Bruno, obrigado por estarem juntos neste meu projeto de vida.

Tio Cláudio, Tia Marly, Vó Olguinha, Cris, Clau, Fábio... obrigado por termos pensado juntos a nova “cara” do livro.

Tia Márcia, Débora, Thaís e família, obrigado por me apoiarem desde o começo.

Ao Igor, meu mais novo comprador... ele só tinha 5 anos e, utilizando o cartão da minha esposa, comprou o livro no *saraiva.com*!

Fau e Guto, Tia Etra, Ailton, Tio Eduardinho, Duca, Tia Jussara, Fabinho, Leny e Nice, pela energia da Bahia, muitíssimo obrigado.

Lembro, ainda, *Armando Casimiro Costa Filho* e todos da *LTr Editora*, que, logo no primeiro contato, acreditaram em mim, viabilizando a realização deste sonho, sendo responsáveis pelas cinco primeiras edições desta obra.

Em igual sentido, os meus profundos agradecimentos a *Vauledir Ribeiro Santos* e a todos da *Editora Método*, que, empenhados na manutenção do grande sonho, deram importante projeção nacional ao trabalho e lutaram ao meu lado da 6.^a até a 11.^a edição.

A partir da 12.^a edição tive a honra e o privilégio de unir forças com a querida **SARAIVA**, que, desde o início, também acreditou neste grande sonho. Em nome de *Jorge Eduardo Saraiva, Ruy Mendes Gonçalves, José Luiz M. A. de Próspero, Antonio Luiz de Toledo Pinto, Nilson Lepera, Luiz Roberto Curia, Jônatas Mello, Lígia Alves, Maria Lúcia Godoy, Clarissa B. Maria, Rubens F. Odagima, Luiz Facchini, Sandra Bensadon, Gisele Guerra, Valéria Zanocco, Henrique H. Garcia, Arlindo Meira, André Pereira*, toda a comprometida e profissional *Equipe de Divulgação*, eu só tenho a agradecer a **todos** que de um modo ou de outro se envolveram neste projeto.

A partir da 18.^a edição tive a alegria e honra de trabalhar ao lado dos antigos e de novos colegas, todos muito empolgados e focados no atual momento do **Esquematizado**. Já maduro e firme no mercado editorial, agora com o sucesso da *Coleção Esquematizado®*, esperamos continuar cumprindo o nosso papel. Assim, obrigado por terem contribuído para o desafio: continuar com a excepcional aceitação nacional (não é fácil manter o livro “vivo”) e, sempre, na busca da confiança de novos e fiéis leitores. Assim, o meu agradecimento para *Jorge Saraiva Neto, Maurício Pereira Fanganiello, Ronyse Avelino Pacheco, Ilaine Cristina de Melo* e, na linha de frente do editorial, *Thaís de Camargo Rodrigues, Deborah Caetano de Freitas Viadana* e *Eveline Gonçalves Denardi*.

A partir do ano de 2016, para a 20.^a edição, começamos a idealizar as novas perspectivas do mercado editorial e estamos pensando, juntos, em como escrever uma marcante história para mais 100 novos anos da

SARAIVA.

Para a edição de 2017, qual seja, a 21.^a, introduzimos importantes novidades, destacando-se o conceito de “livro vivo[®]” e as fantásticas e infundáveis perspectivas de uma plataforma on-line. A partir da 22.^a edição, em 2018, a versão 2 da plataforma foi melhorada, assim como tivemos importante aumento de conteúdo.

A tecnologia, os avanços no mercado de educação, as ferramentas para a educação a distância, enfim, novos instrumentos estão sendo estudados e testados. Por isso, feliz e empolgado com o profissionalismo e a seriedade do novo “time” que passa a fazer parte dessa nossa grande família. Certamente, posso dizer que, todos, respiramos e **SOMOS EDUCAÇÃO**. Então, os meus sinceros agradecimentos para *Eduardo Mufarej, Claudio Lensing, Flávia Alves Bravin, Rafael Augusto Torres Pinto, Mário Santiago de Freitas, Daniela Lopes, Tiago Delgado Ramos, Fillipi Ragonha, André Raymundi, Roberto Navarro, Liana Ganiko Brito, Maria Izabel Barreiros Bitencourt, Bruna Schlindwein Zeni, Eveline Gonçalves Denardi, Clarissa Boraschi Maria, Ana Cristina Garcia, Isabella Sánches de Souza, Fernando Penteado, Felipe Maia do Valle, Thayo Vianna, Mônica Landi Colobone, Tiago Dela Rosa, Marli Rampim*, além de tantos outros que, de um modo ou de outro, contribuem para a realização desse grande sonho.

SARAIVA EDUCAÇÃO, simplesmente **OBRIGADO** por tudo. Estou muito feliz e espero que os meus queridos leitores aproveem a nova fase do *Esquematizado*, casamento novo, parceria de sucesso, juntos na luta pelos grandes sonhos!

Ainda, sou e serei eternamente grato a *Roseli e Rose* e toda a equipe da *Know-how Editorial*, pelo profissionalismo, comprometimento e arte de editar. Vocês realmente “sabem como” produzir um livro de sucesso, inovando o mercado editorial. Obrigado por tudo o que fizeram pelo NOSSO Esquematizado.

Não posso deixar de agradecer aos *amigos, professores, operadores do direito*, vários leitores das áreas jurídicas e não jurídicas, pela divulgação do presente trabalho, por suas sugestões e especialmente pela forte acolhida das edições anteriores!

Por fim, aos *alunos, candidatos aos “concursos da vida”*, minha fonte inspiradora diária para sempre continuar estudando e com eles aprendendo: minha realização como ser humano.

A todos, o meu muito obrigado.

O autor



NOTA DO AUTOR À 28.^a EDIÇÃO

Chegamos à **28.^a edição**, com muito trabalho e constante preocupação com o conteúdo e a precisão das informações. Lá se vão **24 anos** de muito esforço e dedicação, sempre pensando em nossos queridos leitores.

O texto está adequado e ampliado considerando as **132** emendas constitucionais (nem todas impactam diretamente no texto do livro), **6** emendas constitucionais de revisão, **3** tratados ou convenções internacionais que têm força normativa de Constituição em razão da regra contida no art. 5.º, § 3.º, CF/88, **59** súmulas vinculantes (STF), o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) e as principais decisões do STF até a data de fechamento desta edição. Também foram consideradas algumas súmulas e determinados entendimentos firmados pelos demais tribunais superiores: STJ, TST, TSE e STM.

A partir da **21.^a edição**, em razão da necessidade de atualização e aprimoramento da obra e diante da impossibilidade de aumentar o seu número de páginas, decidimos transportar as questões do *modelo tradicional* para a plataforma on-line. O material poderá, inclusive, ser baixado em PDF para o “**treino**” e segue exatamente o mesmo formato das edições anteriores. Na **22.^a edição**, a plataforma foi melhorada e ampliamos a quantidade de materiais e informações. **Nesta edição**, seguimos o mesmo caminho, sem volta, da **plataforma** e do “**livro vivo**®” e, certamente, aumentaremos a nossa aproximação com os nossos queridos leitores.

Nesse contexto de integração entre o livro físico e a plataforma, estamos inserindo os capítulos 20 e 21, assim como as referências e o sumário completo da obra, na plataforma.

Potencializando a pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e já aprovada **metodologia**, aplicada com sucesso desde a 1.^a edição do **NOSSO Esquematizado**, introduzimos duas **poderosas novidades** que passam a

constituir **material digital exclusivo**: **a) vídeos** ao longo dos capítulos; **b)** acesso à **plataforma** on-line. Os **vídeos** servirão de ferramenta para a sedimentação da matéria, destaque dos pontos mais importantes, revisão e, em alguns momentos, introdução de conteúdo complementar novo; o acesso à **plataforma** permitirá a **ampliação do “treino”**.

Nesse particular, no tocante aos vídeos, sinceros são os nossos agradecimentos a Zé, Eli, Ciça, Marcelão, Gabriel, Isa e Giselle, parabenizando pelo trabalho da equipe!

Segue o nosso agradecimento ao extraordinário Thayo Vianna pela versão 2 da plataforma e o consagrado QR Code.

Sem dúvida, os vários *e-mails* que chegam de todo o Brasil e as sugestões recebidas em cursos e palestras têm servido de importante fonte para o enriquecimento deste trabalho. Assim, agradeço aos amigos deste nosso grande país.

Com importantes comentários, ricas sugestões e discussões, novamente e sempre, ao amigo **Leandro Hissa Dahi**, serei eternamente grato.

Li, Bruno, Tia Christina, Tio Barreto e, claro, **Má**, obrigado por terem minimizado o sentimento da Manu, do Max e do Tommy, que não entendiam a minha ausência... De fato, sem vocês me ajudando, eu não teria conseguido implementar essa árdua tarefa que é a atualização do livro.

Outrossim, durante todo esse tempo, os cursos que já ministramos na TV Justiça (“Aula Magna”, “Saber Direito”, “Apostila”) e em alguns tribunais (cursos de capacitação interna — como é rica a experiência de falar para pessoas tão preparadas e que atuam diretamente com as questões do direito) serviram para percebermos as tendências da jurisprudência, que se mostram extremamente importantes àqueles que se preparam para concursos públicos.

Nesse particular, declaradamente, **agradecemos e homenageamos** o extraordinário trabalho do setor de jurisprudência do **STF**, notadamente a equipe responsável pelo **“Notícias”**, pelo **“Informativos”** e pelo notável **“A Constituição e o Supremo”**, compêndio eletrônico lançado pelo STF e

desenvolvido pelas *Secretarias de Documentação e de Informática*, em cumprimento a uma das promessas do Ministro Nelson Jobim na Presidência; no caso, a de facilitar acesso rápido e preciso às informações, verdadeiro dever das fontes.

Esperamos que esta obra, em sua nova edição e com as **novas ferramentas e tecnologias empregadas no livro**, continue ajudando os colegas, e, mais uma vez, **aguardamos as críticas e sugestões**. Devo declarar que imperfeições existirão, motivo pelo qual estarei sempre aberto.

Estamos trabalhando fortemente para o constante aprimoramento do “*NOSSO Esquematizado*”, sempre orando para que todos os ilustres concurseiros, honestos e batalhadores, realizem o seu “sonho dourado”.

Saibam que sempre estarei à procura de elementos para ajudá-los nesta fase difícil de suas vidas. **Nunca desistam!** Sejam sempre fortes! Tenho certeza, e sempre falo para os meus alunos, que todos podem... só depende de vocês. Confio plenamente em cada um. Vocês só precisam acreditar em si e se concentrar ao máximo em seus objetivos, e tenho fé em Deus que sempre conseguirão o que buscam.

No final, quando olharem para trás e disserem que valeu o esforço, que atingiram o que buscavam, essa alegria, tenham certeza, será a minha maior recompensa, e isso bastará para que **eu** olhe para trás e também diga: “Pedro, valeu a pena tanto esforço neste trabalho...”. Continue firme em sua missão de vida: **“ajudar a realizar sonhos”**.

Amigo, amiga, certamente, **2024** será o seu grande ano! Contem comigo! Agora, vamos à luta. *Muito boa sorte neste seu projeto de vida e chamem-me para a posse!*

Eternamente grato...

São Paulo, 08.02.2024.

Pedro Lenza
Mestre e Doutor pela USP
Visiting Scholar na Boston College Law School

 pedrolenza8@gmail.com

 <https://twitter.com/pedrolenza>

 <https://www.instagram.com/pedrolenza>

 <https://www.youtube.com/pedrolenza>

 <https://www.facebook.com/pedrolenza>

 <https://www.editoradodireito.com.br/colecao-esquematizado>

(cupom: VALELENZA)



APRESENTAÇÃO À 1.^a EDIÇÃO

É com grande satisfação que apresento o livro do jovem e promissor mestrando da Faculdade de Direito da USP, *Pedro Lenza*, intitulado “Direito Constitucional Esquematizado”. Escrita numa linguagem clara e direta, a obra destina-se, declaradamente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, sem eximir-se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição.

Da leitura amena surge um livro “fácil”, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais maduros, sobretudo no campo do direito.

Penso, assim, que a obra será de grande valia para a comunidade jurídica. Só resta desejar a seu jovem autor todo o êxito que merece.

São Paulo, 24 de novembro de 1999.

Ada Pellegrini Grinover



(NEO)CONSTITUCIONALISMO

■ 1.1. ALOCAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL

■ 1.1.1. A classificação em “ramos do direito”

Antes de tratarmos do movimento que recebeu o nome de “constitucionalismo”, faremos uma ponderação inicial, lembrando que o *direito constitucional* costuma ser alocado dentro do ramo do direito público, destacando-se por seu objeto e princípios fundamentais orientadores de sua aplicação.

José Afonso da Silva observa que o *direito constitucional* “configura-se como **Direito Público fundamental** por referir-se diretamente à *organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política*”.¹

Apesar de colocarmos o *direito constitucional* dentro do ramo do direito público (fundamental), devemos alertar o leitor que, modernamente, vem sendo dito que o direito é **uno** e **indivisível, indecomponível**. O direito deve ser definido e estudado como um grande **sistema**, em que tudo se harmoniza no conjunto. A divisão em ramos do direito é meramente didática, a fim de facilitar o entendimento da matéria, vale dizer: questão de **conveniência acadêmica**.

Aceitando a classificação dicotômica (público e privado), apenas para fins didáticos, dentro do **direito público** poderemos alocar, também (destacando-se a particularidade **fundamental** do direito constitucional), o direito administrativo, o urbanístico, o ambiental, o tributário, o financeiro, o econômico, o penal, o processual, o internacional etc., ao contrário do direito civil e do comercial, que, historicamente, preencheriam a categoria do **direito privado**.

Referida classificação dicotômica pode ser atribuída a **Jean Domat** (afastando-se daqueles que a imputam ao Direito Romano), que foi quem separou, pela primeira vez, as **leis civis** das **leis públicas** e cuja obra influenciou a elaboração do **Código Napoleão** de 1804, despertando a denominada **“Era da Codificação”**, que conferiu ao Código Civil a natureza de verdadeira **“constituição privada”**, disciplinando as relações particulares, as regras sobre família, a propriedade, o estado civil, a capacidade etc. Surgia então a ideia do **dogma da completude**, ou seja, de que os Códigos continham toda a regulamentação das relações privadas, devendo o juiz simplesmente aplicá-las.²

Essa perspectiva de codificação do direito civil como regulador das relações privadas é fortalecida pela principiologia do **liberalismo clássico**, que enalteceu a ideia de **liberdade meramente formal** perante a lei e de **não intervenção do Estado** (direitos de **primeira “geração”**, ou, mais tecnicamente, de **primeira “dimensão”**) (*absenteísmo estatal*), tema que será retomado no estudo dos direitos fundamentais (cf. *item 14.2* deste trabalho).

Em outro momento, além da classificação dicotômica em ramo de direito público e de direito privado, a evolução do Estado liberal para o **Estado social de direito** faz surgir a necessidade de se reconhecer, ao lado da dicotomia, a categoria dos **direitos sociais**, cujas normas de direito do trabalho e de direito previdenciário expressam a manifestação de um Estado prestacionista, intervencionista e realizador da chamada **justiça distributiva** (esses novos direitos, chamados de **segunda geração** ou **dimensão**, surgem, pela primeira vez, na Constituição brasileira de 1934), tendo como marco a Revolução Industrial.

O texto de 1988, por sua vez, muito embora já tivesse sido insinuado no texto de 1946 e na Carta de 1967, consagra a proteção aos direitos de **terceira geração** ou **dimensão**, marcados pelo lema da **solidariedade** ou **fraternidade**, evidenciando, assim, os direitos transindividuais.³

■ 1.1.2. A superação da dicotomia “público-privado” — constitucionalização do direito privado

Avançando, por outro lado, modernamente, sobretudo em razão da evidenciação de novos direitos e das transformações do Estado (de autoritário/absolutista para liberal e de liberal para social, podendo-se, inclusive, falar em Estado pós-social de direito), cada vez mais se percebe uma forte influência do **direito constitucional** sobre o **direito privado**.

Sob essa perspectiva, especialmente diante do princípio da **dignidade da pessoa humana**, fundamento da República Federativa do Brasil e **princípio-matriz** de todos os direitos fundamentais (art. 1.º, III, CF/88), parece mais adequado, então, falar em um **direito civil-constitucional**, estudando o direito privado à luz das regras constitucionais e podendo, inclusive, em muitos casos, reconhecer a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, tema que será mais bem estudado no *item 14.8* deste trabalho (**eficácia horizontal dos direitos fundamentais**).⁴

Essa situação, qual seja, a superação da rígida dicotomia entre o público e o privado, fica mais evidente diante da tendência de **descodificação** do direito civil, evoluindo da concentração das relações privadas na codificação civil para o surgimento de vários **microssistemas**, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Locações, a Lei de Direito Autoral, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei de Alimentos, a Lei da Separação e do Divórcio etc.

Todos esses microssistemas encontram o seu fundamento na Constituição Federal, norma de validade de todo o **sistema**, passando o direito civil por um processo de **despatrimonialização**.⁵

Portanto, apesar da “suposta” utilidade didática, parece adequado **não mais falarmos em ramos do direito**, e sim em um verdadeiro escalonamento verticalizado e hierárquico das normas, apresentando-se a Constituição como **norma de validade** de todo o sistema, situação essa decorrente do princípio da **unidade do ordenamento** e da **supremacia da Constituição (força normativa da Constituição** — Konrad Hesse).⁶

Fala-se, então, em uma necessária e inevitável **releitura dos institutos**, notadamente os de direito civil (e privado), sob a ótica constitucional, conforme o quadro a seguir:⁷

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (PRINCÍPIO-MATRIZ)	
☐	Direito Civil Constitucional
☐	Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais
☐	Descodificação do Direito Civil
☐	Microssistemas
☐	Despatrimonialização do Direito Civil

■ 1.2. CONSTITUCIONALISMO

■ 1.2.1. Conceito

Canotilho identifica vários constitucionalismos, como o inglês, o americano e o francês, preferindo falar em “**movimentos constitucionais**”. Em seguida, define o constitucionalismo como uma “... teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma *técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos*. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma *teoria normativa da política*, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo”.⁸

Kildare Gonçalves Carvalho, por seu turno, vislumbra tanto uma perspectiva **jurídica** como **sociológica**: “... em termos jurídicos, reporta-se a um sistema normativo, enfeixado na Constituição, e que se encontra acima dos detentores do poder; sociologicamente, representa um movimento social que dá sustentação à limitação do poder, inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer seus interesses e regras na condução do Estado”.⁹

André Ramos Tavares estabelece quatro sentidos para o constitucionalismo:

“... numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, **limitar o poder arbitrário**. Numa segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja cartas constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa terceira acepção possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. Numa vertente mais restrita, o

constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado”.¹⁰

Partindo, então, da ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm regras de **limitação ao poder autoritário** e de **prevalência dos direitos fundamentais**, afastando-se da visão opressora do antigo regime.

■ 1.2.2. Evolução histórica

A História da Europa pode ser dividida, sem muita preocupação teórica, em quatro grandes “eras”: **Idade Antiga** (até o século V — tomada do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros — 476 d.C.); **Idade Média** (século V até o fim do Império Romano do Oriente, com a *queda de Constantinopla* no século XV — 1453 d.C.); **Idade Moderna** (1453-1789 — Revolução Francesa); **Idade Contemporânea** (1789 até os dias atuais).

Sem se preocupar com a análise das referidas “eras”, Canotilho, entre tantas distinções, estabelece, mais simplificadaamente, apenas dois grandes **movimentos constitucionais**: o constitucionalismo **antigo** e o **moderno**, caracterizando-se este último como “... o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de *domínio político*, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma de ordenação e fundamentação do poder político”.¹¹

Isso posto, passemos a analisar, brevemente, a evolução histórica do constitucionalismo.

■ 1.2.2.1. Constitucionalismo durante a Antiguidade

Analisando a **Antiguidade clássica**, Karl Loewenstein identificou, entre os **hebreus**, timidamente, o surgimento do constitucionalismo, estabelecendo-se no Estado teocrático limitações ao poder político ao

assegurar aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos.¹²

Refere o autor, ainda, mais tarde, no século V a.C., a experiência das **Cidades-Estados gregas** como importante exemplo de democracia constitucional, na medida em que a **democracia direta**, particular a elas, consagrava “... o único exemplo conhecido de sistema político com plena identidade entre governantes e governados, no qual o poder político está igualmente distribuído entre todos os cidadãos ativos”.¹³

■ 1.2.2.2. *Constitucionalismo durante a Idade Média*

Durante a **Idade Média**, a **Magna Carta de 1215** representa o grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo, mesmo que formalmente, a proteção a importantes direitos individuais.

■ 1.2.2.3. *Constitucionalismo durante a Idade Moderna*

Na Idade Moderna, destacam-se: o *Petition of Rights*, de 1628; o *Habeas Corpus Act*, de 1679; o *Bill of Rights*, de 1689; e o *Act of Settlement*, de 1701.¹⁴

Nessa linha, além dos **pactos**, há o que a doutrina chamou de **forais** ou **cartas de franquia**, também voltados para a proteção dos direitos individuais. Diferenciam-se dos pactos por admitir a participação dos súditos no governo local (elemento político).

Os **pactos** e **forais** ou **cartas de franquia**, documentos marcantes durante a Idade Média, buscavam resguardar **direitos individuais**. Alerta-se, contudo, que se tratava de direitos direcionados a determinados homens, e não sob a perspectiva da universalidade.

■ 1.2.2.4. *Constitucionalismo norte-americano*

Outro ponto nessa evolução do **constitucionalismo** foram os chamados **contratos de colonização**, marcantes na história das colônias da América do Norte.

Como anota Ferreira Filho, “chegados à América, os peregrinos, mormente puritanos, imbuídos de igualitarismo, não encontrando na nova terra poder estabelecido, fixaram, por *mútuo consenso*, as regras por que haveriam de governar-se. Firma-se, assim, pelos chefes de família a bordo do *Mayflower*, o célebre ‘*Compact*’ (1620); desse modo se estabelecem as *Fundamental Orders of Connecticut* (1639), mais tarde confirmadas pelo rei Carlos II, que as incorporou à Carta outorgada em 1662. Transparece aí a ideia de estabelecimento e organização do governo pelos próprios governados, que é outro dos pilares da ideia de Constituição”.¹⁵

Nesse sentido é que Kildare identifica como indícios do constitucionalismo na América, além dos referidos “contratos de colonização” (*Compact* e as *Fundamental Orders of Connecticut*), a *Declaration of Rights* do Estado de Virgínia, de 1776, seguida pelas Constituições das ex-colônias britânicas da América do Norte, Constituição da Confederação dos Estados Americanos, de 1781.¹⁶

■ 1.2.2.5. **Constitucionalismo moderno (durante a Idade Contemporânea)**

Chegamos, então, ao **constitucionalismo moderno**, em que predominam as **constituições escritas** como instrumentos para conter qualquer arbítrio decorrente do poder.

Dois são os marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno: a **Constituição norte-americana de 1787** e a **francesa de 1791** (que teve como preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789), movimento este deflagrado durante o Iluminismo e concretizado como uma contraposição ao absolutismo reinante, por meio do qual se elegeu o **povo** como o **titular legítimo do poder**.

Podemos destacar, nesse primeiro momento, na concepção do **constitucionalismo liberal**, marcado pelo liberalismo clássico, os seguintes valores: individualismo, absenteísmo estatal, valorização da propriedade privada e proteção do indivíduo. Essa perspectiva, para se ter um exemplo, influenciou profundamente as Constituições brasileiras de 1824 e 1891.

Conforme falamos, a concepção liberal (de valorização do indivíduo e afastamento do Estado) gerará **concentração de renda e exclusão social**, fazendo com que o Estado passe a ser chamado para evitar abusos e limitar o poder econômico.

Evidencia-se, então, aquilo que a doutrina chamou de segunda geração (ou dimensão) de direitos e que teve como documentos marcantes a Constituição do México de 1917 e a de Weimar de 1919, influenciando, profundamente, a Constituição brasileira de 1934 (**Estado Social de Direito**).

■ 1.2.2.6. *Constitucionalismo contemporâneo (durante a Idade Contemporânea) “antenado” com a ideia de “constitucionalismo globalizado”*

O **constitucionalismo contemporâneo** está centrado naquilo que Uadi Lammêgo Bulos chamou de “**totalitarismo constitucional**, consectário da noção de **Constituição programática**”, e que tem como bom exemplo a Constituição brasileira de 1988.¹⁷

Fala-se em “**totalitarismo constitucional**” na medida em que os textos sedimentam um importante **conteúdo social**, estabelecendo normas programáticas (metas a serem atingidas pelo Estado, programas de governo) e realçando o sentido de **Constituição dirigente** defendido por Canotilho.

Contudo, partindo dessa concepção de normas programáticas, André Ramos Tavares, apoiado no pensamento de Dromi (*vide item 1.2.2.7 a seguir*), enaltece o **constitucionalismo da verdade** e, assim, em relação às normas programáticas, identifica duas categorias:

- “normas que jamais passam de programáticas e são praticamente inalcançáveis pela maioria dos Estados”;
- “normas que não são implementadas por simples falta de motivação política dos administradores e governantes responsáveis”.

Consoante alerta Tavares, “as primeiras precisam ser erradicadas dos corpos constitucionais, podendo figurar, no máximo, apenas como objetivos a serem alcançados a longo prazo, e não como declarações de realidades utópicas, como se bastasse a mera declaração jurídica para transformar-se o ferro em ouro. As segundas precisam ser cobradas do Poder Público com mais força, o que envolve, em muitos casos, a participação da sociedade na gestão das verbas públicas e a atuação de organismos de controle e cobrança, como o Ministério Público, na preservação da ordem jurídica e consecução do interesse público vertido nas cláusulas constitucionais”.¹⁸

Essa concepção de dirigismo estatal (de o texto fixar regras para dirigir as ações governamentais) tende a evoluir para uma perspectiva de **dirigismo comunitário**, ideia também vislumbrada por André Ramos Tavares ao falar em uma fase atual do **constitucionalismo globalizado**, que busca difundir a perspectiva de proteção aos direitos humanos e de propagação para todas as nações.¹⁹

Destacamos, ainda, uma concepção de proteção aos direitos de **fraternidade** ou **solidariedade**, que são identificados pela doutrina como direitos de **terceira dimensão** ou **geração**.²⁰

No Brasil, conforme já apontado, essa perspectiva está consagrada no texto de 1988, embora esboçada nos textos de 1946 e 1967 (e EC n. 1/69).

■ 1.2.2.7. ***Constitucionalismo do futuro: o que podemos esperar?***

O **constitucionalismo do futuro** sem dúvida terá de consolidar os chamados *direitos humanos de terceira dimensão*, incorporando à ideia de constitucionalismo **social** os valores do constitucionalismo **fraternal**²¹ e de

solidariedade, avançando e estabelecendo um equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e alguns excessos do contemporâneo.

Por isso, como bem anota **José Roberto Dromi**, o futuro do constitucionalismo “deve estar influenciado até identificar-se com a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a universalidade”.

Trata-se da Constituição do “**por vir**”, com os seguintes valores:²²

■ **verdade (veracidade):** a Constituição não pode mais gerar falsas expectativas; o constituinte só poderá “prometer” o que for viável cumprir, devendo ser transparente e ético;

■ **solidariedade:** trata-se de nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social;

■ **consenso:** a Constituição do futuro deverá ser fruto de consenso democrático;

■ **continuidade:** ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta os avanços já conquistados;

■ **participação:** refere-se à efetiva participação dos “corpos intermediários da sociedade”, consagrando-se a noção de democracia participativa e de Estado de Direito Democrático;

■ **integração:** trata-se da previsão de órgãos supranacionais para a implementação de uma integração espiritual, moral, ética e institucional entre os povos;

■ **universalização:** refere-se à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas Constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira universal e afastando, assim, qualquer forma de desumanização.

■ 1.2.3. Esquematização do constitucionalismo



MOMENTO HISTÓRICO	DOCUMENTOS/CARACTERÍSTICAS MARCANTES
ANTIGUIDADE	■ “Lei do Senhor” — hebreus — limites bíblicos ■ democracia direta — Cidades-Estados gregas
IDADE MÉDIA	■ Magna Carta de 1215
IDADE MODERNA	■ pactos e forais ou cartas de franquia ■ <i>Petition of Rights</i> de 1628 ■ <i>Habeas Corpus Act</i> de 1679 ■ <i>Bill of Rights</i> de 1689 ■ <i>Act of Settlement</i> de 1701
CONSTITUCIONALISMO NORTE-AMERICANO	■ contratos de colonização ■ <i>Compact</i> (1620) ■ <i>Fundamental Orders of Connecticut</i> (1639) ■ Carta outorgada pelo rei Carlos II (1662) ■ <i>Declaration of Rights</i> do Estado de Virgínia (1776) ■ Constituição da Confederação dos Estados Americanos (1781)
CONSTITUCIONALISMO MODERNO	■ Constituição norte-americana de 1787 ■ Constituição francesa de 1791
CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO	■ totalitarismo constitucional ■ dirigismo comunitário ■ constitucionalismo globalizado ■ direitos de segunda dimensão ■ direitos de terceira dimensão (fraternidade e solidariedade)

CONSTITUCIONALISMO DO FUTURO

- consolidação dos direitos de terceira dimensão: fraternidade e solidariedade

- segundo Dromi, a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a universalidade são perspectivas para o constitucionalismo do futuro

■ 1.3. NEOCONSTITUCIONALISMO²³

■ 1.3.1. Aspectos iniciais

A doutrina passa a desenvolver, a partir do início do século XXI, uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, denominada **neoconstitucionalismo**, ou, segundo alguns, **constitucionalismo pós-moderno**, ou, ainda, **pós--positivismo**.²⁴

Visa-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais.

Kildare, de maneira interessante, anota que a perspectiva é de que “ao **constitucionalismo social** seja incorporado o **constitucionalismo fraterno** e de **solidariedade**”,²⁵ valores já destacados por Dromi dentro de um contexto de constitucionalismo do futuro ou do “por vir” (cf. *item 1.2.2.7*).

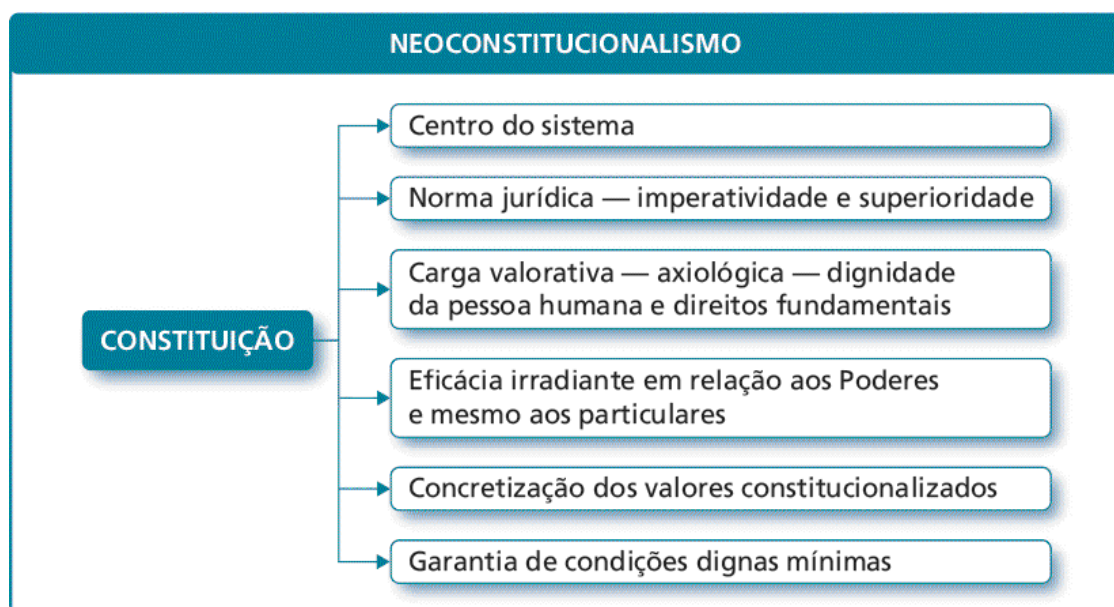
Nas palavras de Walber de Moura Agra, “o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das **prestações materiais prometidas pela sociedade**, servindo como ferramenta para a implantação de um **Estado Democrático Social de Direito**. Ele pode ser considerado como um movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais características podem ser mencionadas: **a)** posituação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais; **b)** onipresença dos princípios e das regras; **c)** inovações hermenêuticas; **d)** densificação da força normativa do Estado; **e)** desenvolvimento da justiça distributiva”.²⁶

E continua: “o seu modelo normativo não é o descritivo ou deontológico, mas o **axiológico**. No constitucionalismo moderno a diferença entre normas constitucionais e infraconstitucionais era apenas de grau, no neoconstitucionalismo a diferença é também axiológica. A

‘**Constituição como valor em si**’. O caráter ideológico do constitucionalismo moderno era apenas o de limitar o poder, o caráter ideológico do neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais”.²⁷

CONSTITUCIONALISMO MODERNO	NEOCONSTITUCIONALISMO
■ hierarquia entre as normas	■ hierarquia entre normas não apenas formal, mas também axiológica — valor
■ limitação do poder	■ concretização dos direitos fundamentais

■ 1.3.2. Pontos marcantes do neoconstitucionalismo



■ **Estado constitucional de direito:** supera-se a ideia de Estado Legislativo de Direito, passando a Constituição a ser o **centro** do sistema, marcada por uma intensa **carga valorativa**. A lei e, de modo geral, os

Poderes Públicos, então, devem não só observar a forma prescrita na Constituição, mas, acima de tudo, estar em consonância com o seu **espírito**, o seu **caráter axiológico** e os seus **valores** destacados. A **Constituição**, assim, adquire, de vez, o caráter de **norma jurídica**, dotada de **imperatividade**, **superioridade** (dentro do sistema) e **centralidade**, vale dizer, tudo deve ser interpretado a partir da Constituição.

■ **Conteúdo axiológico da Constituição:** para Barcellos, do ponto de vista **material**, sobressai o seguinte elemento dentro da noção de constitucionalismo: “(i) a incorporação explícita de **valores** e **opções políticas** nos textos constitucionais, sobretudo no que diz respeito à promoção da **dignidade humana** e dos **direitos fundamentais**”.²⁸

Como importante marca das Constituições contemporâneas, além de realçar seus **valores** (especialmente após a Segunda Guerra Mundial), associados, particularmente, à ideia da dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Barcellos identifica a previsão de **opções políticas gerais** (como a redução de desigualdades sociais — art. 3.º, III) e **específicas** (como a prestação, por parte do Estado, de serviços de educação — arts. 23, V, e 205).

Nesse contexto, a partir do momento que os valores são constitucionalizados, o grande desafio do neoconstitucionalismo passa a ser encontrar mecanismos para sua efetiva **concretização**.

■ **Concretização dos valores constitucionais e garantia de condições dignas mínimas:** de acordo com a lição de Barcellos, completando, do ponto de vista **material**, destaca-se um outro elemento na concepção de constitucionalismo: “(ii) a expansão de conflitos específicos e gerais entre as opções normativas e filosóficas existentes dentro do próprio sistema constitucional”.²⁹

Sem dúvida, os valores constitucionalizados poderão entrar em choque, seja de modo **específico** (por exemplo, a *liberdade de informação e de expressão* e a *intimidade, honra e vida privada*), seja de modo **geral**, no que, conforme afirma, diz respeito “ao próprio papel da Constituição”.

Em uma visão **substancialista** (a Constituição deveria impor “um conjunto de decisões valorativas que se consideram essenciais e consensuais”), ou mesmo designada de **procedimentalismo** (a Constituição deve “garantir o funcionamento adequado do sistema de participação democrático, ficando a cargo da maioria, em cada momento histórico, a definição de seus valores e de suas próprias convicções materiais”), em relação a qualquer das posições que se filie, mesmo no “procedimentalismo” deverão ser resguardadas as **condições de dignidade e dos direitos dentro, ao menos, de patamares mínimos**.³⁰

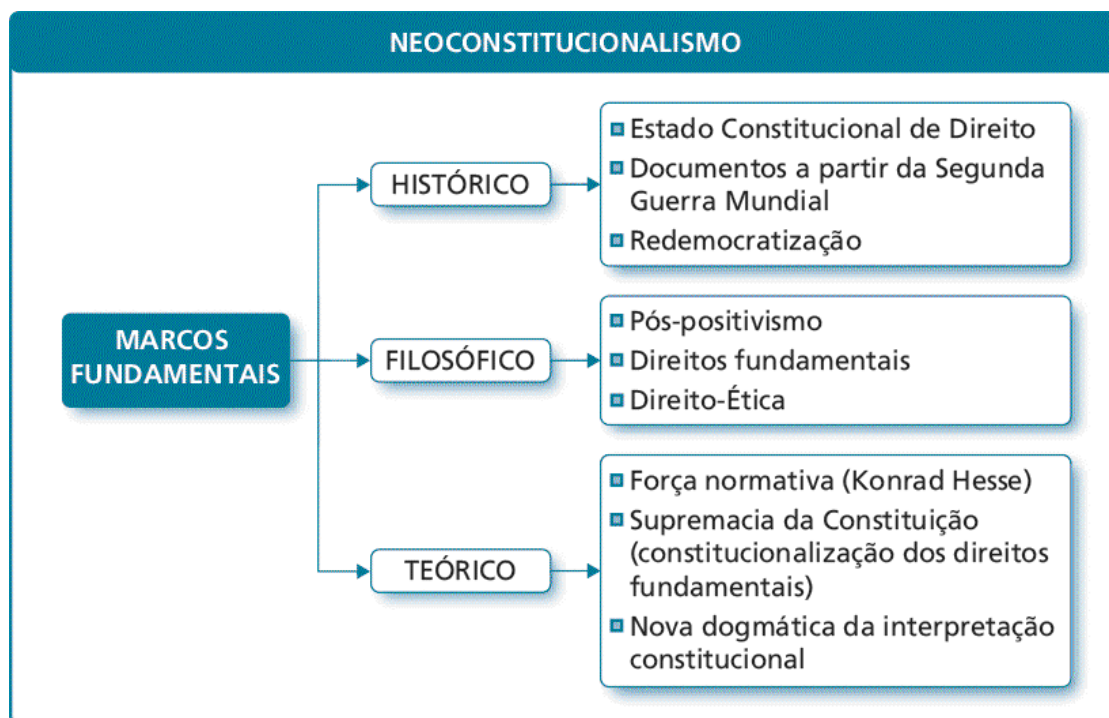
Ainda, segundo Dirley da Cunha Júnior, “... foi marcadamente decisivo para o delineamento desse novo Direito Constitucional, a reaproximação entre o **Direito** e a **Ética**, o **Direito** e a **Moral**, o **Direito** e a **Justiça** e demais **valores substantivos**, a revelar a importância do homem e a sua ascendência a filtro axiológico de todo o sistema político e jurídico, com a consequente proteção dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana (grifamos)”.³¹

■ 1.3.3. Marcos fundamentais para se chegar a um “novo direito constitucional” (neoconstitucionalismo)

Em interessante trabalho, Barroso aponta três **marcos fundamentais** que definem a trajetória do direito constitucional para o atual estágio de “novo”: o **histórico**, o **filosófico** e o **teórico**.

Ao analisar o quadro a seguir, conclui-se que “o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como *marco histórico*, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como *marco filosófico*, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como *marco teórico*, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a

expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito”.³²



Assim, podemos esquematizar:³³

■ **histórico:** evidenciam-se aqui as Constituições do pós-guerra, na Europa, destacando-se a da Alemanha de 1949 (Lei Fundamental de Bonn) e o Tribunal Constitucional Federal (1951); a da Itália de 1947 e a instalação da Corte Constitucional (1956); a de Portugal (1976) e a da Espanha (1978), todas enfocando a perspectiva de **redemocratização** e **Estado Democrático de Direito**. No Brasil, o destaque recai sobre a Constituição de 1988, em importante processo democrático;

■ **filosófico:** o **pós-positivismo** aparece como o marco filosófico do neoconstitucionalismo.

A ideia de **jusnaturalismo moderno** se desenvolve a partir do século XVI, aproximando a **lei** da **razão** e se transformando, assim, na **filosofia natural do Direito**, e vai servir de sustentáculo, “fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos”, para as revoluções liberais, consagrando-se nas Constituições escritas e nas codificações. “Considerado metafísico e anticientífico, o direito natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do **positivismo jurídico**, no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, regimes que **promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade**. Ao fim da 2.^a Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao Direito”.

Nesse contexto surge a noção do **pós-positivismo** como marco filosófico do **neoconstitucionalismo**. “O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Procura empreender uma **leitura moral do Direito**, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a **atribuição de normatividade aos princípios** e a **definição de suas relações com valores e regras**; a reabilitação da **razão prática** e da **argumentação jurídica**; a formação de uma **nova hermenêutica constitucional**; e o desenvolvimento de uma **teoria dos direitos fundamentais** edificada sobre o fundamento da **dignidade humana**. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o **Direito e a filosofia**”;

■ **teórico:** **a)** força normativa da Constituição; **b)** expansão da jurisdição constitucional; **c)** nova dogmática da interpretação constitucional.

Dentro da ideia de **força normativa** (Konrad Hesse), pode-se afirmar que a norma constitucional tem *status* de norma jurídica, sendo dotada de **imperatividade**, com as consequências de seu descumprimento (assim como acontece com as normas jurídicas), permitindo o seu cumprimento forçado.

No contexto de **expansão da jurisdição constitucional**, Barroso observa que, “antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de *supremacia do Poder Legislativo*, na linha da doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral. A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não apenas novas constituições, mas também um **novo modelo**, inspirado pela experiência **americana**: o da **supremacia da Constituição**. A fórmula envolvia a **constitucionalização dos direitos fundamentais**, que ficavam imunizados em relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário. Inúmeros países europeus vieram a adotar um modelo próprio de controle de constitucionalidade, associado à criação de tribunais constitucionais”.

Ao confrontar **regras** (enunciados descritivos, aplicados de acordo com as regras de subsunção, isso quer dizer a aplicação e enquadramento do fato à norma) e **princípios** (normas que consagram valores), Barroso conclui no sentido de uma **nova dogmática da interpretação constitucional**, não mais restrita à denominada interpretação jurídica tradicional.

Assim, “... as especificidades das normas constitucionais (...) levaram a doutrina e a jurisprudência, já de muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Tais princípios, de natureza **instrumental**, e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais. São eles, na ordenação que se afigura mais adequada para as circunstâncias brasileiras: o da **supremacia da Constituição**, o da **presunção de constitucionalidade das normas e atos**

do poder público, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade”.

Enfim, essas são as marcas do “novo direito constitucional” ou neoconstitucionalismo, que se evidencia ao propor a identificação de novas perspectivas, marcando, talvez, o início de um novo período do Direito Constitucional.

■ 1.4. O NOVO CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO-AMERICANO. CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA (ANDINO OU INDÍGENA). ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL

O denominado **novo constitucionalismo latino-americano** (por alguns chamado de *constitucionalismo andino* ou *indígena*) culmina com a promulgação das Constituições do **Ecuador** (2008)³⁴ e da **Bolívia** (2009)³⁵ e sedimenta-se na ideia de **Estado plurinacional**,³⁶ reconhecendo, constitucionalmente, o direito à **diversidade cultural** e à **identidade** e, assim, revendo os conceitos de **legitimidade** e **participação popular**, especialmente de parcela da população historicamente excluída dos processos de decisão, como a população indígena.

Trata-se, inegavelmente, de necessária e real transformação estrutural e, assim, conforme aponta Grijalva, “o constitucionalismo plurinacional só pode ser **profundamente intercultural**, uma vez que a ele corresponde constituir-se no âmbito de relação igual e respeitosa de distintos povos e culturas, a fim de manter as diferenças legítimas, e eliminar — ou, ao menos, diminuir — as ilegítimas, mantendo a **unidade** como garantia da diversidade”.³⁷

Esse modelo de **constitucionalismo pluralista** pressupõe rupturas paradigmáticas, muito bem delimitadas por Raquel Yrigoyen Fajardo, a saber: a) *colonialismo*, b) *constitucionalismo liberal*, c) *constitucionalismo social-integracionista* e d) *constitucionalismo pluralista* (delimitado por 3 ciclos de reformas constitucionais).³⁸

■ **colonialismo**: vigorava a ideologia da “inferioridade natural dos índios”, em um modelo de subordinação;

■ **constitucionalismo liberal (século XIX):** construção do Estado-nação pelo “monismo jurídico”, ou seja, como bem anota Yrigoyen Fajardo, a existência de um único sistema jurídico dentro do Estado, sobressaindo-se um regramento geral para todos. A ideia de pluralismo jurídico, como forma de coexistência de vários sistemas normativos dentro de um mesmo espaço geopolítico... não era admitida pela ideologia do Estado-nação, havendo exclusão dos povos originários, dos afrodescendentes, das mulheres, das maiorias subordinadas, buscando a manutenção da sujeição dos índios;³⁹

■ **constitucionalismo social-integracionista (século XX):** marcado pela Constituição do México de 1917 e a de Weimar (Alemanha) de 1919, há o reconhecimento de direitos sociais e sujeitos coletivos, com a ampliação das bases de cidadania. O Estado define o modelo de integração dos índios com o Estado e o mercado, não havendo, contudo, rompimento da ideia de Estado-nação e monismo jurídico;⁴⁰

■ **constitucionalismo pluralista (séculos XX e XXI):** Yrigoyen Fajardo reconhece 3 ciclos marcantes e que ensejam importantes reformas constitucionais nos países latino-americanos, evidenciando-se novos atores sociais nos processos decisórios: a) *ciclo multicultural* (1982-1988); b) *ciclo pluricultural* (1989-2005) e c) *ciclo plurinacional* (2006-2009).⁴¹ Vejamos a esquematização:⁴²

CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA			
	Ciclo Multicultural	Ciclo Pluricultural	Ciclo Plurinacional
CARACTERÍSTICAS	■ “introdução do direito — individual e coletivo — à identidade cultural, junto com a inclusão de direitos indígenas específicos”	■ “incorpora os direitos contidos no Convênio 169 da OIT. Este ciclo afirma o direito (individual e coletivo) à identidade e diversidade cultural, já introduzido no primeiro ciclo, mas desenvolve mais o conceito de ‘nação	■ “os povos indígenas demandam que sejam reconhecidos não apenas como ‘culturas diversas’, mas como nações originárias ou sujeitos políticos coletivos com direito a participar nos novos pactos do Estado, que se

		multiétnica’ e ‘estado pluricultural’, qualificando a natureza da população e avançando rumo ao caráter do Estado. Também reconhece o pluralismo jurídico, assim como novos direitos indígenas e de afrodescendentes”	configurariam, assim, como Estados plurinacionais. E, além disso, reclamam, ao Estado, direitos sociais e um papel frente às transnacionais e poderes materiais tradicionais”
PAÍSES	■ Canadá — 1982 ■ Guatemala — 1985 ■ Nicarágua — 1987 ■ Brasil — 1988	■ Colômbia — 1991 ■ México — 1992 ■ Paraguai — 1992 ■ Peru — 1993 ■ Bolívia — 1994 ■ Argentina — 1994 ■ Equador — 1996/1998 ■ Venezuela — 1999	■ Equador — 2008 ■ Bolívia — 2009
DOCUMENTOS NORMATIVOS (INTERNACIONAIS)	■ Revisão da Convenção 107/OIT	■ Convenção 169/OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto n. 10.088/2019)	■ Aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas — 2007

■ 1.5. CONSTITUCIONALISMO E SOBERANIA POPULAR

■ 1.5.1. Aspectos gerais

A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição e de que esta deve conter **limitações ao poder autoritário** e regras de **prevalência dos direitos fundamentais** desenvolve-se no sentido da consagração de um **Estado Democrático de Direito** (art. 1.º, *caput*, CF/88) e, portanto, de **soberania popular**.

Assim, de forma expressa, o parágrafo único do art. 1.º, CF/88, concretiza que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Vale dizer, mencionado artigo distingue **titularidade** de **exercício** do poder. O **titular** do poder é o **povo**. Como regra, o **exercício** desse poder, cujo titular, repita-se, é o povo, dá-se através dos **representantes do povo**, que, como veremos ao tratar do Poder Legislativo, são os Deputados Federais (âmbito federal), os Deputados Estaduais (âmbito estadual), os Deputados Distritais (âmbito do DF), os Vereadores (âmbito municipal) e os Deputados Territoriais (âmbito de eventuais Territórios Federais que venham a ser criados). Lembramos, desde já, que os Senadores da República Federativa do Brasil representam os Estados-Membros e o Distrito Federal, de acordo com o art. 46, CF/88.



Imagem sem descrição.

Além de desempenhar o poder de maneira indireta (democracia representativa), por intermédio de seus representantes, o povo também o realiza **diretamente** (democracia direta), concretizando a **soberania popular**, que, segundo o art. 1.º da Lei n. 9.709, de 18.11.1998 (que regulamentou o art. 14, I, II e III, CF/88), “é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante: **plebiscito, referendo e iniciativa popular**”.

Podemos falar, então, que a CF/88 consagra a **democracia semidireta** ou **participativa**, verdadeiro **sistema híbrido** e que será mais bem desenvolvido no *capítulo 17*, ao qual remetemos o nosso querido leitor (o estudo específico da iniciativa popular será feito no *capítulo 9*, no caso, no *item 9.13.3.4*).

■ 1.6. CONSTITUCIONALISMO POPULAR (TUSHNET) — “JUDICIAL REVIEW” — “TEORIAS DO DIÁLOGO CONSTITUCIONAL” (BATEUP) E “OS PAPÉIS DAS SUPREMAS CORTES E TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS” (BARROSO)

■ 1.6.1. Constitucionalismo popular: perspectivas

Um dos maiores desafios a ser enfrentado é aquele decorrente da dificuldade de se justificar e aceitar o modelo de revisão judicial pelo qual se invalida a vontade do povo materializada no trabalho legislativo fruto da atuação do parlamento.

Este conhecido fenômeno tem sido denominado pela doutrina clássica de **“dificuldade contramajoritária”**⁴³ (ou seja, a palavra final na interpretação sendo dada por juízes destituídos de legitimidade democrática).

Souza Neto e Sarmento, ao analisarem o modelo constitucional dos Estados Unidos e também reconhecerem a supremacia da Constituição como “um princípio jurídico judicialmente tutelado” (Marbury vs. Madison) e não apenas uma proclamação política, também destacam a **tensão** entre **supremacia judicial** e **“constitucionalismo popular”**.⁴⁴

Conforme observam, “é verdade que o controle judicial de constitucionalidade das leis (*judicial review*) sofre até hoje contestações nos Estados Unidos, sendo frequentemente apontado como um instituto antidemocrático, por transferir aos juízes, que não são eleitos, o poder de derrubar decisões tomadas pelos representantes do povo, com base nas suas interpretações pessoais sobre cláusulas constitucionais muitas vezes vagas, que se sujeitam a diversas leituras...”.⁴⁵

Nesses termos, **constitucionalismo popular** pode ser definido sob a perspectiva de que o **povo** — e não os juízes — seriam melhores e mais adequados intérpretes da Constituição.⁴⁶

Nimer Sultany,⁴⁷ por sua vez, em interessante proposta de “mapeamento” das respostas apresentadas para solucionar esta inegável **tensão** entre **constitucionalismo** e **democracia**, nesse contexto da crítica ao modelo de **revisão judicial** e à denominada “**dificuldade contramajoritária**”, identifica 4 grandes grupos de autores:

- “**deniers**”: negam a tensão e, assim, justificam e admitem o modelo de revisão judicial sem maiores dificuldades — *Ronald Dworkin, Bruce Ackerman e Frederick Schauer*;

- “**reconcilers**”: admitem a tensão, mas esta pode ser reconciliada, justificando, por consequência, a revisão judicial — *John Hart Ely, Cass Sunstein e Larry Kramer*;

- “**endorsers**”: apesar de reconhecerem a impossibilidade de reconciliação da tensão, a endossam, podendo a revisão judicial ser prudencialmente justificada — *Frank Michelman, Louis Seidman e Laurence Tribe*;

- “**dissolvers**”: dissolvem a tensão na medida em que renunciam à possibilidade de revisão judicial em relação à legislação, caracterizando-a como ilegítima — *Jeremy Waldron, Richard Parker e Mark Tushnet*.

Certamente, o estudo sobre o embate entre o modelo da *judicial review* (revisão judicial) e o *constitucionalismo popular* deverá ser aprofundado no Brasil, sendo a experiência dos Estados Unidos bastante importante e rica para essa compreensão.

■ 1.6.2. **Supremacia judicial “versus” soberania judicial: a nossa posição no sentido do diálogo constitucional**

Desde já, deixamos o nosso entendimento contrário às propostas que negam o *judicial review* de modo absoluto. Possuem razão Souza Neto e Sarmiento ao afirmarem não ser “(...) salutar atribuir a um único órgão qualquer a prerrogativa de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. (...). É preferível adotar-se um modelo que não atribua a nenhuma instituição — nem do Judiciário, nem do Legislativo — o ‘direito de errar por último’, abrindo-se a permanente possibilidade de correções recíprocas no campo da hermenêutica constitucional, com base na ideia de **diálogo**,⁴⁸ em lugar da visão tradicional, que concede a última palavra nessa área ao STF”.⁴⁹

Nesse sentido, parece interessante a proposta da noção de **“última palavra provisória”** a ser estabelecida pelo Judiciário, não se mostrando razoável a imposição de uma perspectiva de “soberania” judicial (no sentido de única palavra), conforme quadro, a partir das lições de Larry Kramer abaixo transcritas.⁵⁰ Vejamos:

LARRY KRAMER	
“WE THE PEOPLE” X “WE THE COURT”	
JUDICIAL SUPREMACY	JUDICIAL SOVEREIGNTY
■ “Having the last word”	■ “Having the only word”

Conforme propõe Kramer, há “um mundo de diferenças entre ter a **última palavra** (*last word*) e ter a **única palavra** (*only word*); entre **supremacia judicial** (*judicial supremacy*) e **soberania judicial** (*judicial sovereignty*). Podemos optar por aceitar a supremacia judicial porque precisamos de alguém para resolver certas questões constitucionais e, por uma variedade de razões históricas e jurisprudenciais, a Suprema Corte tem parecido ser a nossa melhor opção. Mas isso não significa que a Corte deva exercer a sua autoridade sobre todas as questões ou que, quando exerce a sua função, a Corte possa desprezar ou rapidamente substituir os pontos de

vista de outras instituições mais democráticas. Ou, ainda, em outras palavras, na doutrina da supremacia judicial, não há um comando propondo negar que a Constituição tem qualidades que a diferenciam do direito comum, ou que essas qualidades conferem legítima autoridade interpretativa aos atores políticos como meio de se garantir uma contribuição popular contínua na definição do significado constitucional”.⁵¹

■ 1.6.3. **Reversão (superação) legislativa da jurisprudência da Corte: possibilidade de mutação constitucional pela via legislativa**

O Min. Fux, no julgamento da **ADI 5.105** (j. 1.º.10.2015), identificou diversas situações de inegável **reversão legislativa de decisões do STF**, seja por emenda ou por lei, desautorizando, assim, o modelo da “supremacia judicial em sentido forte ou material” e, por consequência, não se aceitando a concepção de “última palavra definitiva”.⁵²

Conforme observa, “essa práxis dialógica, além de não ser incomum na realidade interinstitucional brasileira, afigura-se perfeitamente **legítima** — e, por vezes, **desejável** —, estimulando prodigioso **ativismo congressual**, desde que, é claro, observados os balizamentos constitucionais” (fls. 17 do acórdão). Isso porque “ao legislador é franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo”, negando-se a adoção de um “autoritarismo judicial” (fls. 21).

Como se sabe, o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado, ou mesmo em razão de edição de súmula vinculante, não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, podendo editar lei com conteúdo idêntico àquela que fora declarada inconstitucional pelo STF, em saudável **diálogo constitucional** (cf. *item 6.7.1.8* e o exemplo do amianto no *item 7.11.1*).

Esse entendimento encontra fundamento tanto na explicitação de que o **efeito vinculante** previsto nos arts. 102, § 2.º, e 103-A **não está direcionado para o legislador** (o texto fala apenas Judiciário e Administração Pública), assim como no dever de **fundamentação das decisões judiciais** (art. 93, IX), exigindo assim, em caso de nova provocação judicial decorrente da reversão legislativa, o enfrentamento da questão específica e de eventuais novos argumentos trazidos pelo legislador.

Em seu voto, o Min. Fux estabelece providências distintas de acordo com o instrumento utilizado para a superação da jurisprudência da Corte:

REVERSÃO LEGISLATIVA DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE — ADI 5.105 — VOTO MIN. FUX	
EMENDAS	LEIS
■ Limites ao poder de reforma	■ Presunção de inconstitucionalidade

■ **emenda constitucional**: o controle judicial incide apenas sobre os limites ao poder de reforma fixados na própria Constituição (art. 60);

■ **ato normativo infraconstitucional**: em sentido diverso das emendas constitucionais, os atos normativos infraconstitucionais nasceriam com presunção *iuris tantum* de inconstitucionalidade, “de modo que caberia ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária”, submetendo-se, em razão disso, a um **controle judicial mais rigoroso**.⁵³

Assim, em importante conclusão, observa que “a interpretação do sentido e do alcance das disposições constitucionais **não pode ser vista como apanágio exclusivo do Supremo Tribunal Federal**, em uma leitura anacrônica e arrogante do princípio da separação de poderes. Ao revés, a interpretação constitucional passa por um processo de construção

coordenada entre os poderes estatais — Legislativo, Executivo e Judiciário — e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, em um processo contínuo, ininterrupto e republicano, em que cada um destes *players* contribui com suas capacidades específicas no embate dialógico, no afã de avançar os rumos da empreitada constitucional, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Carta da República e no aperfeiçoamento das instituições democráticas” (fls. 28 do acórdão lavrado na ADI 5.105).

Ainda no julgamento da ADI 5.105, o Min. Barroso procura atenuar a visão tradicional e clássica da supremacia judicial, tendo em vista a influência da chamada **democracia deliberativa**. Vejamos: “(...) tem se compreendido que a supremacia judicial deve ceder espaço aos chamados **diálogos institucionais**. Nunca existiria, assim, uma decisão final e definitiva sobre determinada questão constitucional. A interpretação, ainda que consagrada pelo STF,⁵⁴ ficaria sempre aberta ao debate público e a novas propostas” (fls. 106).

■ 1.6.4. “Os papéis das Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais nas democracias contemporâneas” (Luís Roberto Barroso)

Fixada essa premissa de diálogos constitucionais, quais seriam, então, os papéis desempenhados pelas Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais? Barroso propõe interessante sistematização:⁵⁵



Imagem sem descrição.

A) O papel contramajoritário

Conforme ensina Barroso, “supremas cortes e tribunais constitucionais, na maior parte dos países democráticos, detêm o poder de controlar a constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo (e do Executivo também), podendo invalidar normas aprovadas pelo Congresso ou Parlamento. Esta possibilidade, que já havia sido aventada nos *Federalist Papers*⁵⁶ por Alexander Hamilton, teve como primeiro marco jurisprudencial a decisão da Suprema Corte americana em *Marbury v. Madison*, julgado em 1803. Isso significa que os juízes das cortes superiores, que jamais receberam um voto popular, podem sobrepor a sua interpretação da Constituição à que foi feita por agentes políticos investidos de mandato representativo e legitimidade democrática. A essa circunstância, que gera uma aparente incongruência no âmbito de um Estado democrático, a teoria constitucional deu o apelido de ‘dificuldade contramajoritária’”.⁵⁷

Segundo o autor, dois **fundamentos principais** asseguram a **legitimidade democrática da jurisdição constitucional**: “a) a proteção dos direitos fundamentais, que correspondem ao mínimo ético e à reserva de justiça de uma comunidade política, insuscetíveis de serem atropelados por deliberação política majoritária; e b) a proteção das regras do jogo democrático e dos canais de participação política de todos. A maior parte dos países do mundo confere ao Judiciário e, mais particularmente à sua Suprema Corte ou Corte Constitucional, o *status* de sentinela contra o risco da *tiranía das maiorias* (John Stuart Mill). Evita-se, assim, que possam deturpar o processo democrático ou oprimir as minorias. Há razoável consenso, nos dias atuais, de que o conceito de democracia transcende a ideia de governo da maioria, exigindo a incorporação de outros valores fundamentais”, devendo ser considerada, também, a sua dimensão substantiva, a incluir **igualdade, liberdade e justiça**.⁵⁸

B) O papel representativo

Barroso faz importante constatação a justificar esse denominado **papel representativo** que vem sendo desempenhado pelas Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais. Muito embora os juízes não sejam eleitos pelo povo, em algumas situações, a decisão da Corte estará muito mais na linha da vontade popular do que a lei ou ato normativo editado pelo Parlamento, que, como se sabe, representa a vontade popular. Ou seja, as escolhas políticas realizadas pelo Parlamento nem sempre coincidirão com o sentimento da maioria.

Segundo constata, é possível reconhecer uma **“crise de legitimidade, representatividade e funcionalidade dos Parlamentos”**, o que levou a uma “expansão do Poder Judiciário e, notadamente, das Supremas Cortes”.⁵⁹

Assim, “em certos contextos, por paradoxal que pareça, Cortes acabem sendo mais representativas dos anseios e demandas sociais do que as instâncias políticas tradicionais”, e isso pode ser justificado por algumas razões.⁶⁰

■ **qualificação técnica dos julgadores:** a escolha dos juízes, por regra, se implementa por concurso público no qual se enfatiza a qualificação técnica, afastando-se a influência política. Devemos alertar, contudo, que o modelo de escolha e nomeação de juízes de Cortes Constitucionais, como é a realidade brasileira, não consegue blindar aspectos políticos, o que, sem dúvida, estimula a revisitação do modelo previsto na Constituição brasileira;

■ **vitaliciedade:** os juízes não estão sujeitos “às circunstâncias de curto prazo da política eleitoral”;

■ **inércia:** “os juízes não atuam por iniciativa própria: dependem de provocação das partes e não podem decidir além do que foi pedido”;

■ **motivação das decisões judiciais:** as decisões judiciais, “para serem válidas, jamais poderão ser um ato de pura vontade discricionária: a ordem jurídica impõe ao juiz de qualquer grau o dever

de apresentar **razões**, isto é, os fundamentos e argumentos do seu raciocínio e convencimento”.

Dessa forma, em determinadas situações, as decisões judiciais não serão necessariamente contra a vontade da maioria e, assim, **não serão contramajoritárias**, já que, no caso, **representativas**, ou **coincidentes**, com a **vontade da maioria**.

Assim, Barroso sugere, com razão, uma **correção terminológica** para essas hipóteses nas quais a revisão judicial coincide com a vontade da maioria, preferindo denominar a decisão como sendo “contralegislativa”, “contracongressual” ou “contraparlamentar” e não contramajoritária. Barroso traz alguns exemplos interessantes dessa **atuação representativa da Corte**, tanto na jurisprudência estrangeira, como no Brasil, destacando-se.⁶¹

■ **Griswold v. Connecticut — 381 U.S. 479 (1965)**: a Suprema Corte dos EUA declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado de Connecticut que proibia o uso de contraceptivos mesmo por casais casados. Em sua observação, Barroso sustenta que a decisão judicial que prestigiou o *direito de privacidade* expressa muito mais o sentimento majoritário do que o ato normativo que proibia o uso de contraceptivos;

■ **Lawrence v. Texas — 539 U.S. 558 (2003)**: a Suprema Corte dos EUA invalidou lei do Estado do Texas que criminalizava relações íntimas homossexuais. Essa decisão, segundo observa Barroso, correspondeu à vontade da maioria, que não achava adequada referida criminalização prevista na lei;

■ **ADI 4.650 — Brasil**: o STF declarou a inconstitucionalidade do financiamento privado das campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Segundo Barroso, essa decisão da Suprema Corte brasileira encontrou amplo apoio popular, já que o modelo adotado pelo legislador

“reforçava a influência do poder econômico sobre o resultado das eleições e distorcia o sistema representativo”;

■ **Criminalização da “difamação” — Quênia:** a Suprema Corte do Quênia declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Código Penal que criminalizavam a “difamação”. Essa prescrição violava a liberdade de expressão dos cidadãos e era “frequentemente utilizada por políticos e autoridades públicas para silenciar críticas e denúncias de corrupção veiculadas por jornalistas ou mesmo por cidadãos comuns”;

■ **Aborto — Canadá:** em 1988, a Suprema Corte do Canadá declarou a inconstitucionalidade de dispositivo do Código Penal que criminalizava o aborto. Conforme relata Barroso, pesquisas de opinião realizadas há 6 anos da decisão já sinalizavam que 75% da população do Canadá era a favor da liberdade de escolha pela mulher grávida.

A justificativa do papel representativo da Corte encontraria fundamento na **dimensão deliberativa** da chamada **democracia contemporânea**,⁶² segundo proposta de sistematização trazida por Barroso.

Em suas palavras, “cabe aqui retomar a ideia de **democracia deliberativa**, que se funda, precisamente, em uma **legitimação discursiva**: as decisões políticas devem ser produzidas após debate público livre, amplo e aberto, ao fim do qual se forneçam as **razões** das opções feitas. Por isso se ter afirmado, anteriormente, que a democracia contemporânea inclui **votos** e **argumentos**. Um *insight* importante nesse domínio é fornecido pelo jusfilósofo alemão Robert Alexy, que se refere à Corte Constitucional como representante argumentativo da sociedade. Segundo ele, a única maneira de reconciliar a jurisdição constitucional com a democracia é concebê-la, também, como uma representação popular. Pessoas racionais são capazes de aceitar argumentos sólidos e corretos. O **constitucionalismo democrático** possui uma **legitimação discursiva**, que é um projeto de institucionalização da **razão** e da **correção**”.⁶³

C) O papel iluminista

Conforme explica Barroso, “ao longo da história, alguns avanços imprescindíveis tiveram de ser feitos, **em nome da razão, contra o senso comum, as leis vigentes e a vontade majoritária da sociedade**. A abolição da escravidão ou a proteção de mulheres, negros, homossexuais, transgêneros e minorias religiosas, por exemplo, nem sempre pôde ser feita adequadamente pelos mecanismos tradicionais de canalização de reivindicações sociais”.⁶⁴

Essa atuação do Poder Judiciário, no sentido de “**empurrar a história na direção do progresso social**”, superando bloqueios institucionais, caracteriza o **papel iluminista** das Cortes descrito pelo ilustre professor. Conforme adverte, “o termo iluminista está sendo empregado para identificar decisão que não corresponde à vontade do Congresso Nacional nem ao sentimento majoritário da sociedade, mas ainda assim é vista como correta, justa e legítima”.⁶⁵

Barroso alerta que esse papel iluminista desempenhado pelas Cortes deve ser **ocasional**: “trata-se de uma competência **perigosa**, a ser exercida com grande **parcimônia**, pelo **risco democrático** que ela representa e para que cortes constitucionais não se transformem em instâncias hegemônicas”.⁶⁶ Nesse sentido, o autor destaca, dentre outros, os seguintes exemplos, enaltecendo aqui a jurisprudência americana:

■ **Brown v. Board of Education — 347 U.S. 483 (1954)**: a Suprema Corte dos EUA, por unanimidade, entendeu que o estabelecimento de escolas para brancos e para negros separadamente acarretava violação à 14.^a Emenda, combatendo a proposta de segregação que até então era admitida. “O caráter iluminista do julgado se manifestou na superação do senso comum majoritário — que escondia o preconceito por trás da doutrina do ‘separados, mas iguais’ (*Plessy v. Ferguson*, 163 U.S. 537 — 1896) — e na consequente mudança de paradigma em matéria racial, tendo funcionado como um **catalisador** do moderno movimento pelos direitos civis. As reações do *status quo* vieram de formas

diversas: resistência ao cumprimento da decisão, a crítica política — a Corte teria agido como ‘uma terceira câmara legislativa’ e a crítica doutrinária: *Brown* não teria observado ‘princípios neutros’ de interpretação constitucional”;⁶⁷

■ **Loving v. Virginia — 388 U.S. 1 (1967):** a Suprema Corte dos EUA proferiu decisão histórica nulificando lei que proibia e considerava crime o casamento entre brancos e negros, superando, assim, o precedente estabelecido em *Pace v. Alabama* (106 U.S. 583, 1883). Por incrível que pareça, o Código da Virgínia capitulava a miscigenação como crime punível com pena de prisão de 1 a 5 anos. O casal *Loving* havia sido condenado a 1 ano de prisão e a sentença substituída pelo afastamento do Estado por no mínimo 25 anos (decisão proferida no ano de 1959). Referida lei do Estado da Virgínia e outras antimiscigenação foram consideradas inconstitucionais pela Corte, sendo, portanto, invalidadas em 1967. Conforme observa Barroso, o caráter iluminista dessa decisão é mais fácil de se perceber em relação aos estados do sul dos Estados Unidos, que ainda mantinham leis discriminatórias, apesar de supor que no plano nacional referidas leis já não eram mais admitidas e, sob essa perspectiva, o seu caráter seria representativo;⁶⁸

■ **Roe v. Wade — 410 U.S. 113 (1973):** a Suprema Corte dos EUA, por 7 x 2, reconheceu a possibilidade de interrupção da gravidez até o primeiro trimestre, tendo por fundamento o direito à privacidade da mulher e a interpretação dada à 14.^a emenda, assegurando-lhe a decisão sobre a continuidade ou não da gestação.⁶⁹ Conforme anotou Barroso, essa decisão veio a ser revisitada pela Corte em precedentes seguintes e, sem dúvida, contrariou a vontade de uma maioria, tendo, inclusive, gerado forte reação social (denominada *backlash*) dos segmentos derrotados;⁷⁰

■ **Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization — 597 U.S. (2022):** a Suprema Corte dos EUA (SCOTUS), em 24.06.2022, por 6 x 3, modificou o seu entendimento, estabelecendo que a **Constituição**

Federal não confere direito ao aborto. Dessa forma, *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113, e *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 U.S. 833, foram **superados**. “A autoridade para regular o aborto é devolvida ao povo e seus representantes eleitos”.

Nesse sentido, os **Estados-Membros** passam a ter autonomia para assegurar ou não o direito ao aborto, e, ao que tudo indica, ao menos 26 Estados sinalizaram a proibição total ou quase total, admitindo-o apenas em situações muito específicas, como risco de morte para a gestante.

Observamos que, antes mesmo do julgamento pela Suprema Corte, 13 Estados já haviam aprovado as denominadas **“trigger laws”**. Trata-se de termo informal (EUA) no sentido de que determinadas leis, normalmente estaduais, passam a valer se um evento específico ou uma condição futura ocorrer. Essas leis seriam **“acionadas”** ou **“disparadas”** a partir da ocorrência dessa condição e passariam a ter validade, no caso específico em análise, se o precedente da Suprema Corte em *Roe v. Wade* fosse superado (algumas já entrariam em vigor com a superação do entendimento, outras no prazo de 30 dias e outras depois de certificada por alguma autoridade, como o Governador de Estado ou o *Attorney General*, que se equipara ao AGU no Brasil).

Essa nova realidade, na medida em que a matéria criminal é regulada pelos Estados-Membros nos EUA, levará a um movimento de pessoas indo para outros Estados (que autorizem) para fazerem o aborto ou, ainda, gerará uma situação crítica de segregação em relação aos que não tenham condições de arcar com todos os gastos (claro, diante da decisão pessoal de cada um, além da orientação religiosa).

Finalmente, voltando ao tema proposto por Barroso, ao final, o autor faz um interessante alerta apontando eventuais riscos de desmedida ou excesso — e suas consequências, decorrentes desses papéis assumidos pela Corte: “o papel **contramajoritário** pode degenerar em excesso de intervenção no espaço da política, dando lugar a uma indesejável **ditadura do Judiciário**; o papel **representativo** pode desandar em **populismo**

judicial, que é tão ruim quanto qualquer outro; e a função **iluminista** tem como antípoda o desempenho eventual de um papel obscurantista, em que a suprema corte ou tribunal constitucional, em lugar de empurrar, **atrasa a história**". Mas observa com precisão: sociedades democráticas e abertas, com liberdade de expressão, debate público e consciência crítica, costumam ter mecanismos eficientes para evitar esses males.⁷¹

■ 1.7. CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO E “BACKLASH” (REAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DE DECISÃO DA CORTE)

O tema em questão tem sido pouco explorado pela doutrina brasileira. Em relação à jurisprudência do STF encontramos rápida passagem no voto do Min. Fux em julgado da Corte que reconheceu a constitucionalidade material da Lei da Ficha Limpa.⁷² Apesar de curta, a referência ao tema mostra-se extremamente densa e com perspectivas de amplas e calorosas discussões acadêmicas.

Conforme observa Fux, “a verdade é que a jurisprudência do STF nesta matéria vem gerando fenômeno similar ao que os juristas norte-americanos (...) identificam como *backlash*, expressão que se traduz como um **forte sentimento de um grupo de pessoas em reação a eventos sociais ou políticos**. É crescente e consideravelmente disseminada a crítica, no seio da sociedade civil, à resistência do Poder Judiciário na relativização da presunção de inocência para fins de estabelecimento das inelegibilidades” (fls. 27 do acórdão).

E continua: “obviamente, o Supremo Tribunal Federal não pode renunciar à sua condição de instância contramajoritária de proteção dos direitos fundamentais e do regime democrático. No entanto, **a própria legitimidade democrática da Constituição e da jurisdição constitucional depende, em alguma medida, de sua responsividade à opinião popular**” (fls. 27 do acórdão).

Em seguida, ao afirmar a necessidade de o Tribunal ter que considerar a “fortíssima opinião popular” sobre a Lei da Ficha Limpa, Fux conclui: “se a Suprema Corte é o último *player* nas sucessivas rodadas de interpretação da Constituição pelos diversos integrantes de uma sociedade aberta de intérpretes (cf. HÄBERLE), é certo que tem o privilégio de, observando os

movimentos realizados pelos demais, poder ponderar as diversas razões antes expostas para, ao final, proferir sua decisão” (fls. 27 do acórdão).

O tema tem sido debatido na doutrina norte-americana, destacando-se o trabalho de **Robert Post** e **Reva Siegel**,⁷³ no qual os professores da Universidade de Yale **refutam** tanto a noção de **constitucionalismo popular** (que propõe o afastamento total das Cortes — **Tushnet**⁷⁴), como a proposta de **cautela judicial** e **atuação minimalista dos tribunais** (mínima intervenção judicial e o aconselhamento aos tribunais para não assumirem posição em relação a temas polêmicos e com entendimentos antagônicos e diametralmente opostos — **Cass R. Sunstein**⁷⁵).

Post e Siegel resumem os 5 fundamentos elencados por **Sunstein** para justificar a atuação minimalista dos tribunais: “o minimalismo reduz os custos da decisão para os tribunais que estão buscando decidir casos. Reduz os custos de erros associados a julgamentos equivocados. Reduz as dificuldades relacionadas à ‘racionalidade limitada (*bounded rationality*), incluindo a falta de conhecimento de efeitos adversos imprevistos’. ‘Ajuda a sociedade a lidar com o pluralismo razoável’. E, ‘talvez o mais importante’, o minimalismo ‘permite ao processo democrático uma grande quantidade de espaço para se adaptar aos desenvolvimentos futuros, produzir mutuamente compromissos vantajosos e para adicionar novas informações e perspectivas a questões legais’”.⁷⁶

Conforme alertado, contudo, na visão do **constitucionalismo democrático** trazida por Post e Siegel, a proposta de minimalismo sustentada por Sunstein superestima os custos do *backlash* e subestima os seus benefícios (no mesmo sentido de Sunstein, Michael Klarman e William Eskridge, cujos ensinamentos também sofreram críticas dos professores de Yale).⁷⁷

Para os autores, a noção de **constitucionalismo democrático** considera a reação e o desacordo como fatores normais e até saudáveis, na medida em que sustenta a legitimidade de diversos atores para fazer valer a Constituição.

Aprofundando a terminologia *backlash*, o texto apresenta a sua evolução ao longo do tempo.⁷⁸ Em sua denotação clássica, o termo está relacionado a uma reação brusca ou contragolpe de uma roda ou conjunto de rodas conectadas em um mecanismo em razão de movimento não uniforme ou pressão súbita aplicada (*Oxford English Dictionary*). Para se ter um exemplo interessante do uso clássico da palavra, o meu querido leitor que gosta de pescar talvez já tenha passado pela experiência do “backlash”. Ao usar uma vara de pesca com carretilha, se eventualmente um peixe der uma fígada extremamente brusca e forte, a roldana da carretilha irá girar tão rápido sob o seu eixo que a linha ficará toda desorganizada na vara, como se fosse um emaranhado de fios, causando uma situação bastante desagradável para o pescador. A palavra em inglês “backlash” descreve essa situação crítica do pescador.

Em momento seguinte, a palavra passou a ser utilizada no contexto político para descrever reações desencadeadas por mudanças bruscas e ameaçadoras do *status quo*, destacando-se aqui, por exemplo, reações aos movimentos de conquista de direitos civis e aos movimentos feministas em busca de direitos etc.

Finalmente, Post e Siegel observam que a doutrina norte-americana passou a empregar o termo *backlash* — nesse sentido de reação, a partir do papel desempenhado pelas Cortes em relação a temas extremamente delicados para o seu momento histórico, como a separação entre brancos e negros em escolas do Sul dos Estados Unidos (*Brown v. Board of Education*) e o reconhecimento da possibilidade da interrupção da gravidez até o primeiro trimestre (*Roe v. Wade*), que, como indicamos anteriormente, veio a ser superado no julgamento de *Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization* — 597 U.S. (2022), dentre tantos outros.

Conforme explicam, a maioria dos autores refere-se ao fenômeno *backlash* sob a perspectiva dos tribunais e considerando o risco que a decisão, sem o apoio popular, possa trazer à própria existência (e legitimidade) do Poder Judiciário.

Contudo, sustentam que o constitucionalismo democrático consegue acomodar essa tensão e preservar o respeito à Constituição, demonstrando que, em muitas situações, a controvérsia e a reação apresentam-se como positivas.

De modo conclusivo, observam que “o constitucionalismo democrático assegura tanto o papel dos representantes do povo e da cidadania mobilizada no cumprimento da Constituição, como o papel dos tribunais no exercício de sua função de intérprete. Ao contrário do constitucionalismo popular, o **constitucionalismo democrático** não procura retirar a Constituição dos tribunais, reconhecendo o papel essencial das Cortes em fazer valer os direitos constitucionalmente previstos. Ao contrário da perspectiva de foco juricêntrico, o constitucionalismo democrático enaltece o papel extremamente relevante que o engajamento público desempenha na orientação e legitimação das instituições no processo de revisão judicial. Os julgamentos constitucionais baseados em razões jurídicas técnicas adquirem legitimidade democrática se os motivos técnicos da decisão estiverem enraizados em valores e ideais populares. O constitucionalismo democrático observa que a adjudicação está inserida em uma ordem constitucional que convida regularmente ao intercâmbio entre julgadores e cidadãos sobre questões de significado constitucional”.⁷⁹

E, finalmente, um alerta deve ser feito: por mais que o Judiciário deva estar sensível às demandas políticas e sociais dentro dessa perspectiva sugerida pelo constitucionalismo democrático, jamais se admitirá que a decisão, apesar de agradar a opinião pública, seja contrária à Constituição. Naturalmente, os critérios técnicos e jurídicos deverão estar presentes e, nesse sentido, bastante interessante a proposta de sistematização trazida por Barroso ao estabelecer o papel das Cortes, admitindo inclusive que, em certas situações, as decisões não encontrem respaldo popular, gerando o fenômeno *backlash* (cf. *item 1.6.4*).

■ 1.8. “CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO” (DAVID LANDAU): UM ALERTA QUE PREOCUPA E NÃO SE CONFUNDE COM O DENOMINADO “CONSTITUCIONALISMO AUTORITÁRIO” (MARK TUSHNET)

Em interessante estudo, David E. Landau, professor da *Florida State University College of Law*, desenvolve a noção do **constitucionalismo abusivo**,⁸⁰ pelo qual se observa o fenômeno do uso de mecanismos de mudança constitucional que acabam corroendo (erodindo, enfraquecendo) a ordem democrática.

Em seu estudo, após analisar a experiência de países como Colômbia, Venezuela e Hungria,⁸¹ Landau denuncia o uso de emendas ou de “substituição” da vigente Constituição por uma nova (promulgação de nova Constituição), dentro das regras legais, mas com o objetivo de “minar” (corroer, enfraquecer) a democracia.

Não se trata do uso da força, como pode ser observado nos períodos ditatoriais ou nos regimes implantados após golpes militares, nos quais a ruptura constitucional é evidente, inquestionável, declarada e assumida, mas da **transformação da ordem constitucional com mudanças sutis e que podem chegar até mesmo ao controle indireto da Suprema Corte** (*disable or pack courts*).

Conforme explica, os regimes continuam a ter eleições, não chegando a ser autoritários, mas, em verdade, passam a ser, lentamente, **menos democráticos**.

A proposta de Landau não se confunde com o **constitucionalismo autoritário** descrito por Tushnet.⁸² O professor da Universidade de Harvard, tendo Singapura como estudo de caso, identifica um sistema de governo que combina eleições razoavelmente livres e justas com um grau moderado de controle repressivo da liberdade de expressão e pessoal,

afastando-se, nesse sentido, do autoritarismo puro de um lado e do Estado de Direito de outro. O autor identifica **7 características** desse modelo:⁸³

- o regime, que é controlado por um partido dominante, implementa as relevantes decisões de políticas públicas, não havendo base normativa a contestar as escolhas tomadas. Esta característica define o seu lado autoritário;
- o regime não prende arbitrariamente os oponentes políticos, embora possa impor-lhes sanções como aquelas decorrentes de difamação;
- apesar de aplicar sanções, o regime ainda permite questionamentos e críticas ao governo e suas políticas;
- o regime realiza eleições razoavelmente livres e justas, mas, a partir de desenhos e divisões eleitorais, busca assegurar a vitória para manutenção no poder. Fraude e intimidação física até ocorrem, mas apenas esporadicamente e não sistematicamente;
- o partido dominante é sensível à opinião pública e altera as suas políticas, pelo menos ocasionalmente, em resposta aos anseios desta;
- desenvolvem-se mecanismos para garantir que a quantidade de divergência não exceda o nível considerado desejável;
- os tribunais são razoavelmente independentes e procuram manter o Estado de Direito. Embora os juízes, especialmente os de tribunais superiores, sejam sensíveis aos interesses do regime por causa do treinamento e dos mecanismos de seleção e promoção, raramente recebem instruções diretas do regime, chegando, inclusive, a afastar algumas decisões tomadas. A revisão judicial, contudo, quando negativa, mostra-se fraca, pois o regime tem mecanismos de alteração formal da Constituição para que a decisão política tomada esteja sempre de acordo com as (novas) regras constitucionais.

Isso posto e feita a diferenciação, nesse contexto, trazemos interessante voto do Min. Barroso, proferido no julgamento da medida cautelar na **ADPF 622**, que apreciou o Decreto presidencial n. 10.003/2019 (dispõe

sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente — CONANDA).

Referido decreto alterou as regras sobre a constituição e o funcionamento do CONANDA, destituindo, imotivadamente, todos os seus membros durante o cumprimento do mandato.

Segundo alega a PGR, “a norma impugnada, na prática, esvaziou a participação da sociedade civil no Conselho, em violação aos princípios da democracia participativa (arts. 1.º, par. único, CF), da igualdade (art. 5.º, I, CF), da segurança jurídica (art. 5.º, CF), da proteção à criança e ao adolescente (art. 227, CF) e de vedação ao retrocesso institucional (art. 1.º, *caput* e III; art. 5.º, XXXVI e § 1.º; art. 60, § 4.º)”.

Barroso, em seu voto, observa que “o constitucionalismo e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno razoavelmente novo: os **retrocessos democráticos**, no mundo atual, não decorrem mais de golpes de estado com o uso das armas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de **alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade**. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão **progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático**”.

Conforme ensina, “esse fenômeno tem recebido, na ordem internacional, diversas denominações, entre as quais: ‘**constitucionalismo abusivo**’, ‘**legalismo autocrático**’ e ‘**democracia iliberal**’. Todos esses conceitos aludem a experiências estrangeiras que têm em comum a atuação de líderes carismáticos, eleitos pelo voto popular, que, uma vez no poder, modificam o ordenamento jurídico, com o propósito de assegurar a sua permanência no poder. O modo de atuar de tais líderes abrange: (i) a tentativa de esvaziamento ou enfraquecimento dos demais Poderes, sempre que não compactuem com seus propósitos, com ataques ao Congresso Nacional e às Cortes; (ii) o desmonte ou a captura de órgãos ou instituições de controle, como conselhos, agências reguladoras, instituições de combate

à corrupção, Ministério Público etc.; (iii) o combate a organizações da sociedade civil, que atuem em prol da defesa de direitos no espaço público; (iv) a rejeição a discursos protetivos de direitos fundamentais, sobretudo no que respeita a grupos minoritários e vulneráveis — como negros, mulheres, população LGBTI e indígenas; (v) o ataque à imprensa, sempre que leve ao público informações incômodas para o governo”.

E continua: “a lógica de tal modo de atuar está em excluir do espaço público todo e qualquer ator que possa criticar, limitar ou dividir poder com o líder autocrático, em momento presente ou futuro, de forma a assegurar seu progressivo empoderamento e permanência no cargo. Experiências de tal gênero estão ou estiveram presentes na Hungria, na Polônia, na Romênia e na Venezuela. **O resultado final de tal processo tende a ser a migração de um regime democrático para um regime autoritário, ainda que se preserve a realização formal de eleições**”.

E conclui ao falar da realidade brasileira: “embora não me pareça ser o caso de falar em risco democrático no que respeita ao Brasil, cujas instituições amadureceram ao longo das décadas e se encontram em pleno funcionamento, é sempre válido atuar com cautela e aprender com a experiência de outras nações. Nessa linha, **as Cortes constitucionais e supremas cortes devem estar atentas a alterações normativas que, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, em verdade se inserem em uma estratégia mais ampla de concentração de poderes, violação a direitos e retrocesso democrático**” (ADPF 622-MC, j. 19.12.2019 — ratificação da cautelar e mérito julgados pelo Pleno em 1.º.03.2021).

■ 1.9. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

1

(NEO)CONSTITUCIONALISMO



Imagem sem descrição.



2

CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO

Nesta parte devemos conceituar e classificar *Constituição*. Lembramos que ao conceituar ou classificar qualquer instituto surgirão diversos critérios, não sendo um mais certo que outro, talvez, no máximo, mais adequado. Procuramos trazer os que mais aparecem nos concursos públicos, dado o objetivo deste trabalho.

■ 2.1. CONCEITO

Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo “Constituição”. Alguns autores preferem a ideia da expressão tipologia dos conceitos de Constituição em várias acepções. Vejamo-las.

■ 2.1.1. Sentido sociológico

Valendo-se do **sentido sociológico**, **Ferdinand Lassalle**, em seu livro *¿Qué es una Constitución?*, defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples “*folha de papel*”. A Constituição, segundo a conceituação de Lassalle, seria, então, a *somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade*.

■ 2.1.2. Sentido político

Na lição de **Carl Schmitt**, encontramos o **sentido político**, que distingue *Constituição de lei constitucional*. Constituição, conforme pondera José Afonso da Silva ao apresentar o pensamento de Schmitt, “... só se refere à decisão política fundamental (estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática etc.); as leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas não contêm matéria de decisão política fundamental”.¹

Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que, na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a Constituição produto de certa **decisão política**, ela seria, nesse sentido, a **decisão política do titular do poder constituinte**.

■ 2.1.3. Sentido material e formal

Constituição também pode ser definida tomando-se o *sentido material e formal*, critério esse que se aproxima da classificação proposta por Schmitt.

Do ponto de vista **material**, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter constitucional ou não será o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico. Constitucional será, então, aquela norma que defina e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais (formas de Estado, governo, seus órgãos etc.). Trata-se do que Schmitt chamou de “Constituição”.

Por outro lado, quando nos valemos do critério **formal**, que, de certa maneira, também englobaria o que Schmitt chamou de “lei constitucional”, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Nesse sentido, as normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano, por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento.

Valendo-nos das definições acima, fazemos duas observações:

a) em primeiro lugar, por mais que pareça estranho dizer, ao eleger o **critério material**, torna-se possível encontrarmos normas constitucionais *fora do texto constitucional*, na medida em que o que interessa no aludido conceito é o conteúdo da norma, e não a maneira pela qual ela foi introduzida no ordenamento interno. Como o próprio nome sugere e induz, o que é relevante no critério material é a **matéria**, pouco importando sua forma;

b) em segundo lugar, em se tratando do **sentido formal**, qualquer norma que tenha sido introduzida por um poder soberano, como aquelas fruto da manifestação do poder constituinte originário, ou aquelas introduzidas pelo poder constituinte derivado reformador ou revisor, terá natureza constitucional, não importando o seu conteúdo (vale dizer, tomando-se o sentido formal, o que nos interessa é a **forma** de nascimento da norma). Lembramos um exemplo que supomos ilustrar

bem o raciocínio: trata-se do art. 242, § 2.º, CF/88, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.

Pois bem, essa situação definida no citado art. 242, § 2.º, CF/88, do ponto de vista **material**, de modo algum traz elementos que, por sua essência, sejam constitucionais, traduzindo regras estruturais e fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista **formal**, essa norma será tão constitucional como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade. Isso porque o que nos interessa nesse sentido classificatório não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira pela qual foi introduzida no ordenamento interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte originário (e pelo derivado, desde que observadas as regras definidas pelo originário),² devendo todo ato normativo respeitá-la, sob pena de padecer do vício de inconstitucionalidade.

Verifica-se uma forte tendência no direito brasileiro a se adotar um critério misto em razão do art. 5.º, § 3.º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos (matéria) sejam incorporados como emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação.

■ 2.1.4. Sentido jurídico

Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocando a Constituição no mundo do **dever-ser**, e não no mundo do **ser**, caracterizando-a como fruto da **vontade racional** do homem, e não das leis naturais.

José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, conclui que “... Constituição é, então, considerada *norma* pura, puro *dever-ser*, sem qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos: no *lógico-jurídico* e no *jurídico-positivo*. De acordo com o primeiro,

Constituição significa *norma fundamental hipotética*, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição *jurídico-positiva*, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau”.³

Também assim o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria kelseniana, observando que o jurista de Viena descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por José Afonso da Silva: “o jurídico-positivo e o lógico-jurídico. Aquele corporificado pelas normas postas, positivadas. O outro (lógico-jurídico) situa-se em nível do suposto, do hipotético. Umas são normas postas; outra é suposta”.⁴

No direito percebe-se um verdadeiro **escalonamento de normas**, uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa **verticalidade hierárquica**. Uma norma, de hierarquia inferior, busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta, na seguinte, até chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional.

A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na **norma hipotética fundamental**, situada no **plano lógico**, e não no jurídico, caracterizando-se como fundamento de validade de todo o sistema, determinando a obediência a tudo o que for posto pelo Poder Constituinte Originário.

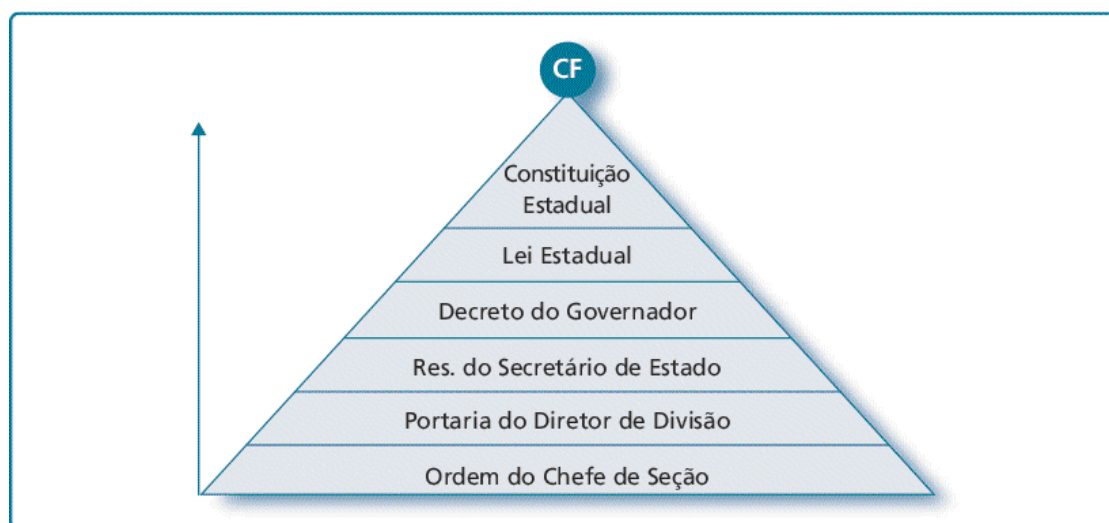
Para facilitar a fixação da matéria, destacamos a teoria de Kelsen no quadro a seguir:

PLANO LÓGICO-JURÍDICO
■ norma fundamental hipotética ■ plano do suposto ■ fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva
PLANO JURÍDICO-POSITIVO
■ norma posta, positivada

Esclarecedoras são as palavras de Michel Temer sobre a **verticalidade hierárquica** descrita, citando, como exemplo, o indeferimento, pelo chefe de seção de uma repartição pública, de um requerimento formulado. Trata-se de verdadeiro comando individual, que deverá estar em consonância com as normas superiores, ou seja: “... devo compatibilizar aquela ordem com a Portaria do Diretor de Divisão; esta com a Resolução do Secretário de Estado; a Resolução com o Decreto do Governador; este com a Lei Estadual; a Lei Estadual com a Constituição do Estado (se se tratar de Federação); esta com a Constituição Nacional. Tudo para verificar se os comandos expedidos pelas várias autoridades, sejam executivas ou legislativas, encontram verticalmente suporte de validade”.⁵

E, por fim, como visto, a Constituição Nacional encontrará o seu fundamento de validade na **norma hipotética fundamental**, esta, o fundamento de validade de todo o sistema. Trata-se de **norma suposta**, e não posta, uma vez que **não editada por nenhum ato de autoridade**. Figura, como referimos, no plano **lógico-jurídico**, prescrevendo a observância do estabelecido na Constituição e nas demais normas jurídicas do sistema, estas últimas fundamentadas na própria Constituição. A norma fundamental, hipoteticamente suposta, prescreve a observância da primeira Constituição histórica.⁶

Daí, partindo da exemplificação proposta por Michel Temer, estabelecemos, graficamente, a ideia da “pirâmide” de Kelsen, consagrando a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema e, assim, o princípio da supremacia da Constituição:



■ 2.1.5. Sentido culturalista

Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que nela pode influir. Ou, como destacou J. H. Meirelles Teixeira, trata-se de “... uma *formação objetiva de cultura* que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais, aí intervindo, portanto, não apenas fatores *reais* (natureza humana, necessidades individuais e sociais concretas, raça, geografia, uso, costumes, tradições, economia, técnicas), mas também *espirituais* (sentimentos, ideias morais, políticas e religiosas, valores), ou ainda elementos puramente *racionais* (técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas e conceitos jurídicos *a priori*), e finalmente elementos *voluntaristas*, pois não é possível negar-se o papel de vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social, e de organização do Direito e do Estado”.⁷

Em seguida, conclui o ilustre professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de uma **Constituição Total** em uma visão suprema e sintética que “... apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos *econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos*, a fim de abranger o seu conceito em uma *perspectiva unitária*”. Desse modo, sob o conceito

culturalista de Constituição, “... as Constituições positivas são *um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela Cultura total, e ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político*”.⁸

■ 2.1.6. Constituição aberta

Grande parte dos publicistas vem anunciando a ideia de uma Constituição aberta, no sentido de que ela possa permanecer dentro de seu tempo e, assim, evitar o risco de desmoronamento de sua “força normativa”.

Para Canotilho, dentro da perspectiva de uma **Constituição aberta**, “relativiza-se a *função material de tarefa* da Constituição e justifica-se a ‘desconstitucionalização’ de elementos substantivadores da ordem constitucional (Constituição econômica, Constituição do trabalho, Constituição social, Constituição cultural). A historicidade do direito constitucional e a indesejabilidade do ‘perfeccionismo constitucional’ (a Constituição como estatuto detalhado e sem aberturas) não são, porém, incompatíveis com o caráter de *tarefa e projecto* da lei constitucional. Esta terá de ordenar o processo da vida política fixando limites às tarefas do Estado e recortando dimensões prospectivas traduzidas na formulação dos fins sociais mais significativos e na identificação de alguns programas da conformação constitucional”.⁹

■ 2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país?

Virgílio Afonso da Silva, depois de fazer **críticas** às classificações (da Constituição) apresentadas pela doutrina brasileira (**tipologia**), muitas vezes, em sua opinião, sem utilidade prática ou teórica limitada, propõe a análise do **papel da Constituição**, ou, ainda, da sua **função no ordenamento jurídico** e a sua **relação com a atividade legislativa ordinária**, analisando a

capacidade de conformação atribuída ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada.¹⁰

Dentro dessa perspectiva de análise do papel da Constituição ou da sua função, destacamos, também, a concepção proposta no trabalho de Gustavo Zagrebelsky (*Il diritto mite*). Passamos, então, a analisar essas quatro propostas:

- **Constituição-lei;**
- **Constituição-fundamento (Constituição-total);**
- **Constituição-moldura;**
- **Constituição dúctil (Constituição maleável, *costituzione mite*).**

■ 2.1.7.1. **Constituição-lei**

Para o autor, muito embora não mais viável na maioria das democracias constitucionais contemporâneas, a **Constituição-lei** em muito **pouco se distingue da legislação ordinária**. “Talvez a principal defesa desse tipo de Constituição seja aquela formulada por Gerhard Anschütz em fins do século XIX. Segundo ele, **a Constituição ‘não está acima do poder legislativo, mas à disposição dele’**. Nesse sentido, a Constituição é, na verdade, *uma lei como qualquer outra*. Os dispositivos constitucionais, especialmente os direitos fundamentais, teriam uma função meramente indicativa, pois apenas indicariam ao legislador um possível caminho, que ele não precisaria necessariamente seguir.”¹¹ Esse modelo, certamente, permite a **justificação** da tese acerca da **supremacia do parlamento**, mitigada, contudo, em tempos mais recentes, como pode ser observado, para se ter um exemplo, na Inglaterra a partir da entrada em vigor do *Human Rights Act* (cf. item 2.4.2).

■ 2.1.7.2. **Constituição-fundamento (Constituição-total)**

Por sua vez, na **Constituição-fundamento (Constituição-total)**, a onipresença (**ubiquidade**) da Constituição é tamanha que a área reservada ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada se torna muito pequena. Assim, esses atos passam a ser encarados como instrumentos da realização da Constituição.

Conforme anota Virgílio Afonso da Silva, “a ideia central desse conceito consiste na reivindicação de que a Constituição é a lei fundamental, não somente de toda a atividade estatal e das atividades relacionadas ao Estado, mas também a **lei fundamental de toda a vida social**. Um dos exemplos mais marcantes nesse sentido é a teoria da constituição aberta, de Peter Häberle, que, embora não sustente um conceito de Constituição-total, defende uma concepção de interpretação constitucional que, por expandir de tal forma a abrangência da Constituição, acaba refletindo uma ideia de Constituição-total. Segundo Häberle, todo aquele que vive o que é regulado pela norma constitucional é também um intérprete dela. Isso significa que praticamente todas as ações humanas seriam ao mesmo tempo reguladas pela Constituição e uma manifestação de uma interpretação constitucional, o que teria como consequência o fato de que nenhuma área da vida teria independência das normas constitucionais. O legislador, nesse sentido, seria um mero intérprete da Constituição, e sua tarefa consistiria sobretudo na efetivação dos direitos fundamentais. Não é difícil notar que, para os outros ramos do direito, essa concepção de Constituição deixa pouco ou nenhum espaço livre. Na pena irônica de Forsthoff, tudo seria definido pela Constituição, até mesmo a produção de termômetros para a febre”.¹²

Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva identifica uma inegável **aproximação** entre a **Constituição dirigente** e esse descrito sentido de **Constituição-fundamento** ou **total**, já que a Constituição dirigente apresenta uma ideia subjacente, qual seja, a de **“fixar um plano de ação para a transformação da sociedade”**.¹³

Ao final, o autor apresenta uma severa e pouco reconhecida realidade que impera na jurisdição constitucional brasileira e na doutrina pátria. Muitas vezes, inegavelmente, esse sentido profundo de onipresença se verifica na

interpretação da amplitude de normas ditas de reprodução obrigatória da Constituição Federal nas Constituições Estaduais (não dando abertura para o constituinte derivado), ou mesmo ao se afirmar que o ato normativo extrapola os limites da Constituição, destacando-se, como exemplo, a posição da doutrina que entende inconstitucional a exigência de preenchimento de certos requisitos para o ingresso em juízo com a ação de *habeas data* (entendimento esse, aliás, já superado pelo STF — cf. *item 14.11.6.3*).

Como observa, “as normas constitucionais, nesse sentido, não somente irradiarão efeitos pelos outros ramos do direito: **elas determinarão o conteúdo deles por completo**”.¹⁴

■ 2.1.7.3. *Constituição-moldura*

A **Constituição-moldura** (que Canotilho prefere chamar de **Constituição-quadro**) seria uma **proposta intermediária** entre os dois conceitos trazidos *supra*, evitando-se a politização excessiva da *Constituição-lei* (já que a sua concretização fica destinada ao legislador, estando ao seu serviço), ou a judicialização excessiva, decorrente do sentido de *Constituição-total* (já que ao legislador não sobraria qualquer espaço de atuação, sobrecarregando o Judiciário para verificar se houve ou não abuso).

Como bem observa Virgílio Afonso da Silva, “a metáfora da moldura, no campo da teoria constitucional, é usada para designar uma Constituição que apenas sirva de limites para a atividade legislativa. Ela é apenas uma moldura, sem tela, sem preenchimento. À jurisdição constitucional cabe apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro da moldura. *Como* o legislador age no interior desses limites é uma questão de oportunidade política. Segundo Starck, entender a Constituição como moldura significa sustentar que nem tudo está predefinido pela Constituição e que inúmeras questões substanciais estão sujeitas à simples decisão da maioria parlamentar no processo legislativo ordinário. Definir a ‘largura’ da moldura, que funcionará como simples limitação ao poder estatal, é a tarefa da

interpretação constitucional. Mas essa seria sua única tarefa. Todo o resto é questão de oportunidade política”.¹⁵

■ 2.1.7.4. **Constituição dúctil (Constituição maleável, suave)**
(“*Costituzione mite*” — Gustavo Zagrebelsky)

Conforme observa Canotilho, entre as novas avançadas sugestões da moderna teoria da Constituição está a denominada por Zagrebelsky **Constituição dúctil** ou **maleável, suave** (*Costituzione mite*), “para exprimir a necessidade de a Constituição acompanhar a perda do centro ordenador do estado e **refletir o pluralismo social, político e econômico**. Neste sentido, a uma Constituição caberá a tarefa básica de assegurar apenas as condições possibilitadoras de uma vida em comum, mas já não lhe pertence realizar diretamente um projeto predeterminado dessa vida comunitária. As Constituições concebem-se, pois, como **plataformas de partida** para a realização de políticas constitucionais diferenciadas que utilizem em termos inventivos os ‘vários materiais de construção’ semeados nos textos constitucionais”.¹⁶

Assim, a sobrevivência da **sociedade complexa, pluralista e democrática**, reconhecendo-se a importância de uma dogmática “fluida”, depende da identificação de um modelo de *Constituição dúctil (maleável)* a assegurar, dentro dos seus limites e de uma perspectiva de **coexistência**, a espontaneidade da vida social e, assim, as condições para a vida em comum.¹⁷

■ 2.2. “CROWDSOURCED CONSTITUTION”: O LEGADO DA EXPERIÊNCIA PIONEIRA DA ISLÂNDIA (2011)¹⁸

Com a sua independência da Dinamarca em 1944, a **Islândia**, por referendo nacional, adotou documento provisório como a sua nova Constituição republicana, estabelecendo as perspectivas de sua necessária revisão. Por falta de consenso político, contudo, o processo revisional não foi implementado.

Em **2008**, a Islândia enfrentou grave **crise financeira**, surgindo, então, movimentos para uma imediata revisão constitucional, destacando-se a denominada, na língua inglesa, *Kitchenware Revolution* (algo como “Panelaço”), e que sinalizavam o total descontentamento da população com as autoridades que levaram o país ao **colapso econômico**.

Em 14 de novembro de 2009, um grupo de cerca de 1.200 participantes, mas sem reconhecimento oficial, realizou conferência na capital do país (*Reykjavík*, que, em português, pode ser traduzido como Reiquejavique ou Reiquiavique), intitulando-se Assembleia Nacional (*Thjodfundur*), comprovando a falta de aceitação popular dos governantes, bem como a real necessidade de uma nova Constituição.

Em 27 de novembro de 2010, houve a eleição pelo povo de 25 indivíduos para, em assembleia nacional constituinte, sem vinculação partidária, estabelecer a nova Constituição. Em razão de apontados problemas técnicos com o processo de escolha dos representantes, a Suprema Corte da Islândia invalidou as escolhas.

Os nomes, contudo, foram reconhecidos como legítimos e, assim, estabeleceu-se um “Conselho Constitucional” para a elaboração de um esboço (projeto, rascunho) de Constituição (*draft*).

As discussões foram transmitidas ao vivo e com a possibilidade de participação popular por meio das **redes sociais**, como o X (antigo Twitter), Facebook, Youtube e Flickr. Mais de 3.600 sugestões foram postadas na página oficial no Facebook. Em 29 de julho de 2011, o documento (*draft*) foi encaminhado ao Parlamento.

Antes da deliberação parlamentar, havia a previsão de análise do documento por **referendo popular**, sem caráter vinculativo e que foi realizado em 20 de outubro de 2012, contando com a participação de 49% dos eleitores e, desses, 73% reconhecendo o *draft* como a nova Constituição do país.

Infelizmente, o Parlamento não aprovou o documento, seja por sua troca durante o processo de elaboração do *draft* (perda de apoio político), seja pela presença, em sua composição, de uma ala extremamente conservadora.

A experiência islandesa, contudo, e apesar da particular realidade de ter mais de 95% de sua pequena população de cerca de 320.000 habitantes conectada à internet (o maior percentual no mundo!), revela uma **nova forma de democracia** e de **participação popular** por meio das **redes sociais** (internet) e que, sem dúvida, passa a servir de **modelo para o futuro**.

Estamos diante daquilo que vem sendo denominado **crowdsourced constitution** e que se implementa pela participação popular por meio da internet (*crowdsourcing*), em um **processo constituinte** bastante interessante de **“terceirização para a multidão”**.¹⁹ Sem dúvida, as **novas formas de democracia** utilizando as **ferramentas da tecnologia** podem ajudar nesse modelo de verdadeira **Constituição colaborativa**.

Dentro dessa perspectiva, influenciado pela experiência da Islândia, destacamos movimento similar que vem sendo percebido na **Inglaterra** no sentido de se elaborar ou não uma Constituição escrita. O debate acontece depois de **800 anos** do aniversário da **Magna Carta de 1215** e tem estimulado a participação popular por meio das redes sociais (*crowdsourcing*), já havendo a versão final do documento (*draft*).²⁰

No **Brasil**, com o lema “**participação virtual, cidadania real**”, lançado em 2009, destacamos o portal “**E-democracia**” da **Câmara dos Deputados** (<<https://edemocracia.camara.leg.br>>), criado para ampliar a participação social no processo legislativo e aproximar cidadãos e seus representantes por meio da interação digital. E, conforme sustentado no lançamento, “o envolvimento dos cidadãos na discussão de novas propostas de lei contribui para a formulação de políticas públicas mais realistas e implantáveis”.

O **Senado Federal**, por sua vez, pelo **Ato da Mesa n. 3/2011**, instituiu o programa e o portal “**E-Cidadania**” “com o objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por meio da tecnologia da informação e comunicação, nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação da Casa”.

Buscando sanar lacunas identificadas pela *Comissão Senado do Futuro (CSF)* e que ameaçavam “a continuidade e o sucesso do Programa, cujo maior objetivo é aproximar o cidadão dos trabalhos legislativos do Senado Federal”, foi editada a **Res. n. 19/2015/SF**, regulamentando-o.

Como se observa, existem três **ferramentas de participação** disponíveis no Portal:

■ **Ideia Legislativa:** “enviar e apoiar ideias legislativas, que são sugestões de alteração na legislação vigente ou de criação de novas leis. As ideias que receberem 20 mil apoios serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde receberão parecer”;

■ **Evento Interativo:** “participar de audiências públicas, sabatinas e outros eventos abertos. Para cada audiência/sabatina/evento, é criada uma página específica onde haverá: a transmissão ao vivo; espaço para publicação de comentários; apresentações, notícias e documentos referentes ao evento”;

■ **Consulta Pública:** “opinar sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e outras proposições em tramitação no Senado Federal até a deliberação final (sanção, promulgação, envio à Câmara dos Deputados ou arquivamento)”.

As experiências ainda se mostram muito tímidas e, infelizmente, pouco divulgadas, apesar das diversas “contas” nas redes sociais e portais específicos. Consideramos as propostas bastante interessantes e esperamos, no futuro, que essa importante instrumentação de **participação popular** possa ser utilizada como instrumento balizador e indispensável para a tomada de decisões políticas.

■ 2.3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA²¹

■ 2.3.1. Aspectos iniciais

A introdução da ideia de “**constitucionalização simbólica**” deve-se a Marcelo Neves em trabalho apresentado para a obtenção do cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco realizado em 1992.

Uma primeira versão foi publicada pela Editora Acadêmica, sendo, em seguida, o texto editado em alemão, quando sofreu ampla revisão.

Depois, referido trabalho foi trazido do alemão para o português, com acréscimo de alguns textos e notas. Vejamos as suas principais considerações.²²

Marcelo Neves, na apresentação do trabalho, esclarece que o estudo pretende “... abordar o significado social e político de textos constitucionais, exatamente na relação inversa da sua concretização normativo-jurídica. Em outras palavras, a questão refere-se à **discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização jurídica de diplomas constitucionais**. O problema não se reduz, portanto, à discussão tradicional sobre ineficácia das normas constitucionais. Por um lado, pressupõe-se a distinção entre texto e norma constitucionais; por outro, procura-se analisar os efeitos sociais da legislação constitucional normativamente ineficaz. Nesse contexto, discute-se a função simbólica de textos constitucionais carentes de concretização normativo-jurídica”.²³

■ 2.3.2. Legislação simbólica

Em um primeiro momento, o autor busca desenvolver o conceito de **legislação simbólica** partindo da teoria do direito e da ciência política alemã das duas últimas décadas do século XX.

Analisando o trabalho de diversos autores (Cassirer, Lévi-Strauss, Bourdieu, Freud, Jung, Lacan, Castoriadis, Peirce, Firth, Saussure, Carnap, Luhmann e outros), Marcelo Neves apresenta uma delimitação semântica da expressão “legislação simbólica” (após ter determinado a ambiguidade entre “símbolo”, “simbólico” e “simbolismo”).

Nas suas palavras, a **legislação simbólica** “... aponta para o predomínio, ou mesmo **hipertrofia**, no que se refere ao sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental” (grifamos).²⁴

Com base em **Harald Kindermann**, Marcelo Neves propõe, então, um modelo tricotômico para a “tipologia da legislação simbólica”, estabelecendo que o seu conteúdo pode ser: “a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios”.

■ 2.3.2.1. *Confirmação de valores sociais*

Nesse caso, o legislador assume uma posição em relação a determinados conflitos sociais e, ao consagrar certo posicionamento, para o grupo que tem a sua posição amparada na lei, essa “**vitória legislativa**” se caracteriza como verdadeira superioridade da concepção valorativa, **sendo secundária a eficácia normativa da lei**. Assim, o grupo prestigiado procura influenciar a atividade legiferante, fazendo prevalecer os seus valores contra os do grupo “adversário”.

Neves traz como exemplo clássico a **lei seca** nos Estados Unidos. Conforme destaca ao lembrar Gusfield, “a sua tese central afirma que os defensores da proibição de consumo de bebidas alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindo-se a respectiva legislação como símbolo de *status*. Nos conflitos entre protestantes/nativos defensores da lei proibitiva e católicos imigrantes contrários à proibição, a ‘vitória legislativa’ teria funcionado simbolicamente a um só tempo como ‘ato de deferência para os

vitoriosos e de degradação para os perdedores’, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais”.²⁵

Cita, ainda, a legislação sobre o **aborto** na Alemanha e sobre os **estrangeiros** na Europa. A confirmação de um dos valores antagônicos teria um papel muito mais simbólico que efetivo. A “legislação simbólica destinada primariamente à confirmação de valores sociais tem sido tratada basicamente como meio de diferenciar grupos e os respectivos valores ou interesses. Constituiria um caso de política simbólica por ‘gestos de diferenciação’, os quais ‘apontam para a glorificação ou degradação de um grupo em oposição a outros dentro da sociedade’”.²⁶

■ 2.3.2.2. *Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à solução dos problemas sociais (legislação-álibi)*

Além de ter o objetivo de confirmar valores de determinados grupos, a legislação simbólica pode ter o objetivo de assegurar **confiança** nos sistemas jurídico e político.

Diante de certa insatisfação da sociedade, a **legislação-álibi** aparece como uma resposta pronta e rápida do governo e do Estado.

Busca a legislação-álibi dar uma aparente solução para problemas da sociedade, mesmo que mascarando a realidade. Destina-se, como aponta Neves, “... a criar a imagem de um Estado que responde normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não sejam realmente normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras alternativas, desempenhando uma função ‘ideológica’”.²⁷

Enfim, a legislação-álibi tem o “poder” de introduzir um sentimento de “bem-estar” na sociedade, solucionando tensões e servindo à “lealdade das massas”.

Como exemplo, Neves lembra a **prestação de contas dos políticos** nos períodos eleitorais, sem se ter condições de assegurar que a lei criada cumpriu efetivamente o seu papel.

Lembra, ainda, após grave problema decorrente da venda de peixes causadores de doenças intestinais, na Alemanha, a divulgação de uma lei que procurou controlar a situação, sem sucesso, porém, dada a sua complexidade e a necessidade de outras medidas.

No Brasil, destaca **mudanças na legislação penal** como mera reação simbólica às pressões da sociedade buscando reduzir a criminalidade. Como exemplo temos a **Lei n. 11.923/2009**, que acrescenta parágrafo ao art. 158 do Código Penal, para tipificar o chamado **“sequestro relâmpago”**.

Neves faz, porém, um alerta sobre o uso exagerado da legislação simbólica e o risco de seu fracasso. “Isso porque o emprego abusivo da legislação-álibi leva à ‘descrença’ no próprio sistema jurídico, ‘transforma persistentemente a consciência jurídica’ (...); disso resulta que o público se sente enganado, os atores políticos tornam-se cínicos”.²⁸

■ 2.3.2.3. *Adiamento da solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios*

Ainda, conforme anota Neves, a **legislação simbólica** também pode “... servir para adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. Nesse caso, as divergências entre grupos políticos não são resolvidas por meio do ato legislativo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas partes envolvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da ineficácia da respectiva lei. O acordo não se funda então no conteúdo do diploma normativo, mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro indeterminado”.²⁹

Cita, como exemplos, a Constituição de Weimar e a lei norueguesa sobre empregados domésticos de 1948. Em relação a esta última, os empregados ficam satisfeitos, pois a lei aparentemente fortalece a proteção social. Por sua vez, os empregadores também se satisfazem, já que a lei,

como apresentada, não tem perspectiva de efetivação, devido à sua “evidente impraticabilidade”.

Dessa forma, conclui, “... abrandando-se um conflito político interno através de uma ‘lei aparentemente progressista’, ‘que satisfazia ambos os partidos’, transferindo-se para um futuro indeterminado a solução do conflito social subjacente”.³⁰

■ 2.3.2.4. *Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica*

Neves aponta que, além dessa visão simplista de inexistência ou irrelevância social da legislação simbólica, ela também apresenta **efeitos sociais latentes**, que, em muitos casos, seriam mais relevantes que os “efeitos manifestos” que lhe faltam.

Exemplifica com uma lei tributária que, muito embora seja eficaz, pode trazer com ela recessão, inflação. Ou, ainda, uma lei que, ao censurar os meios de comunicação, possa repercutir negativamente na criação artística.

Neves fala, assim, dos **efeitos colaterais** que as leis produzem.

Portanto, além do **sentido negativo** da legislação simbólica (de ineficácia normativa e vigência social), ela também se apresenta em um **sentido positivo**: produção de **efeitos políticos**, e não propriamente jurídicos.

■ 2.3.3. **Constitucionalização simbólica**

Marcelo Neves, valendo-se do modelo sistêmico proposto por **Niklas Luhmann**, define a Constituição como “... ‘acoplamento estrutural’ entre **política e direito**. Nessa perspectiva, a Constituição em sentido especificamente moderno apresenta-se como uma via de ‘prestações’ recíprocas e, sobretudo, como mecanismo de **interpenetração** (ou mesmo de interferências) entre dois **sistemas sociais autônomos**, a política e o direito, na medida em que ela ‘possibilita uma solução jurídica do problema de

autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico”³¹.

Diante desse conceito de *Constituição* (nos termos da teoria dos sistemas de Luhmann), é possível, segundo Neves, associá-lo à noção de **constitucionalização** e, então, enfrentar a problemática da **concretização** das normas constitucionais, analisando a relação entre o texto e a realidade constitucional.

Assim, Marcelo Neves, partindo dos modelos de **Müller** e **Häberle**, define a **constitucionalização simbólica**, também, tanto em sentido negativo como positivo.³²

Negativamente, o texto constitucional “não é suficientemente concretizado normativo-juridicamente de forma generalizada”.

Positivamente, “a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um relevante papel político-ideológico”, servindo para encobrir problemas sociais e obstruindo as transformações efetivas da sociedade.

Em seguida, o autor admite o desenvolvimento adotado para a legislação simbólica também para a **constitucionalização simbólica**, falando, aqui, então, em três formas de manifestações, já estudadas no ponto anterior: a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado (**constitucionalização-álibi**) e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios.

■ 2.3.4. **Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico**

Marcelo Neves desenvolve a ideia de constitucionalização simbólica como “alopoiese do direito”, isso quer dizer, “... a reprodução do sistema por critérios, programas e códigos de seu ambiente”,³³ e, então, discute a possibilidade de descrever o **direito da sociedade moderna como “autopoiético”**, o que quer dizer, capaz de autoproduzir-se a partir de critérios, programas e códigos de seu próprio ambiente.

Após distinguir os países da sociedade moderna periféricos dos centrais, estabelece que a **constitucionalização simbólica** aparece como uma realidade marcante da modernidade periférica (em razão da desigualdade econômica entre os países) e, nesse sentido, dentro desse contexto, percebe-se uma **hipertrofia da função político-simbólica** em relação à eficácia normativo-jurídica da Constituição (simbólica) nesses países (periféricos).

Constata-se, assim, uma preponderância (ou mais adequadamente uma **sobreposição**) do sistema **político** sobre o **jurídico**, não se percebendo o “acoplamento estrutural” entre os sistemas político e jurídico anteriormente apontado na teoria de Luhmann.

Nesses países, então, como afirma, há um bloqueio do sistema jurídico, havendo uma falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional. O texto da Constituição é utilizado de acordo com os interesses políticos.

A constitucionalização (simbólica), novamente, funciona como um **álibi**: “o ‘Estado’ apresenta-se como identificado com os valores constitucionais, que não se realizam no presente por ‘culpa’ do subdesenvolvimento da ‘sociedade’. Já na retórica dos grupos interessados em transformações reais nas relações de poder, os quais pretendem frequentemente representar a ‘subcidadania’, invocam-se os direitos proclamados no texto constitucional para denunciar a ‘realidade constitucional inconstitucional’ e atribuir ao Estado/governo dos ‘sobrecidadãos’ a ‘culpa’ pela não realização generalizada dos direitos constitucionais, que seria possível estivesse o Estado/governo em outras mãos...”³⁴.

Essa problemática, aponta o autor, é verificada não somente no sistema político-jurídico, mas, também, nos **sistemas econômico, educacional, de saúde etc.** (remetemos o nosso ilustre leitor para o *capítulo 14* — Direitos e Garantias Fundamentais, deste nosso estudo).

Por fim, conclui Marcelo Neves que a **constitucionalização simbólica** não seria um “jogo de soma zero”. Isso porque “... proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidos criticamente na realização

dos valores proclamados solenemente no texto constitucional e, portanto, integrados na luta política pela **ampliação da cidadania**". Ainda, "não se pode excluir a possibilidade, porém, de que a realização dos valores democráticos expressos no documento constitucional pressuponha um momento de ruptura com a ordem de poder estabelecida, com implicações politicamente contrárias à diferenciação e à identidade/autonomia do direito. Isso se torna tanto mais provável à proporção que os procedimentos previstos no texto constitucional sejam deformados no decorrer do processo de concretização e não se operacionalizem como mecanismos estatais de legitimação".³⁵

■ 2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das normas constitucionais

Diante de todo o exposto, percebe-se que a proposta de **constitucionalização simbólica** deve ser o ponto de partida para que, compreendendo a problemática, diante das expectativas colocadas, as normas não sirvam apenas como retórica política ou álibi dos governantes.

É preciso identificar os mecanismos de sua **concretização** e, nisso, além do papel da sociedade, parece-nos que o **Judiciário** tem uma importante missão, realizando a implementação da efetividade das normas constitucionais.

Identificamos, como será estudado neste nosso trabalho, uma **nova perspectiva** na utilização das técnicas do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (em relação às normas programáticas) e, assim, a consagração da figura do **ativismo judicial**, que, diante da omissão normativa por parte do Congresso Nacional, muitas vezes, como disse o Min. Gilmar, negligente e desidiosa (cf. ADO 3.682), mostra-se fundamental para a concretização dos direitos fundamentais (*vide*, por exemplo, o reconhecimento do *direito de greve do servidor público* no julgamento dos MIs 670, 708 e 712 — art. 37, VII, CF/88).

Por esse motivo, Écio Oto Ramos Duarte³⁶ define o **neoconstitucionalismo** partindo de uma **nova visão da Constituição**, buscando dar a ela **sentido** e, assim, superando o seu caráter meramente retórico, encontrando mecanismos para a real e efetiva concretização de seus preceitos.

■ 2.4. CLASSIFICAÇÃO (TIPOLOGIA)

Como advertimos, qualquer classificação depende de critérios escolhidos pelos estudiosos, não se podendo dizer que um é mais acertado que o outro, talvez mais adequado. Procuraremos trazer à baila os critérios classificatórios que aparecem nos concursos públicos, dada a finalidade deste trabalho. Vejamo-los.

■ 2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”

Quanto à origem, as Constituições poderão ser **outorgadas, promulgadas, cesaristas** (ou **bonapartistas**) e **pactuadas** (ou **dualistas**).

Outorgada é a Constituição imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo, ou governante), que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, as Constituições outorgadas foram as de 1824 (Império), 1937 (inspirada em modelo fascista, extremamente autoritária — *Getúlio Vargas*), 1967 (ditadura militar), sendo que alguns chegam inclusive a mencionar como exemplo de outorga a EC n. 1/69 (apesar de tecnicamente impreciso). As Constituições outorgadas recebem, por alguns estudiosos, o “apelido” de *Cartas Constitucionais*.

Conforme veremos ao estudar o *histórico das Constituições*, alguns autores entendem que o texto de **1967** teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art. 1.º, § 1.º, AI 4/66. Contudo, em razão do “autoritarismo” implantado pelo *Comando Militar da Revolução*, não possuindo o Congresso Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado que se instaurava, preferimos dizer que o texto de 1967 foi **outorgado** unilateralmente (apesar de formalmente votado, aprovado e “promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.

Também entendemos que, dado o seu caráter revolucionário, a EC n. 1/69 pode ser considerada como manifestação de um novo **poder constituinte originário**, imposta pelo governo de “Juntas Militares”, nos termos do AI 12, de 31.08.1969.

Promulgada, também chamada de **democrática**, **votada** ou **popular**, é aquela Constituição fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação da representação legítima popular. Os exemplos são a de 1891 (primeira da República), 1934 (inserindo a democracia social, inspirada na Constituição de Weimar), 1946 e, finalmente, a atual, de 1988, alterada por 6 emendas de revisão e 132 emendas, fruto do poder constituinte derivado reformador, podendo, ainda, com a regra do art. 5.º, § 3.º, trazida pela **EC n. 45/2004**, ter os seus direitos e garantias fundamentais ampliados por tratados e convenções internacionais de direitos humanos, os quais, observadas as formalidades, terão equivalência às emendas constitucionais.

Cesarista, segundo José Afonso da Silva, “... não é propriamente outorgada, mas tampouco é democrática, ainda que criada com participação popular”. E continua o mestre definindo-a como aquela “... formada por plebiscito popular sobre um projeto elaborado por um Imperador (plebiscitos napoleônicos)³⁷ ou um Ditador (plebiscito de Pinochet, no Chile). A participação popular, nesses casos, não é democrática, pois visa apenas ratificar a **vontade do detentor do poder**. Não destacamos esse tipo no esquema porque bem pode ser considerado um modo de outorga por interposta pessoa” (grifamos).³⁸ Complementando, cabe acrescentar que a participação popular pode dar-se não apenas por *plebiscito* como, também, na hipótese de ratificação, por **referendo**, já que este se caracteriza como instrumento de confirmação das decisões políticas e governamentais, ou seja, toma-se a decisão para, posteriormente, levar-se a referendo popular.

Nesse caso, contudo, “... os referendos são utilizados como um instrumento de **autocracia** (regime do chefe), e não da democracia, pois geralmente nem todas as correntes ideológicas participam do debate e não se

concede liberdade para uma efetiva discussão ou para eventual rejeição das propostas”.³⁹

Pactuada, também pouco cobrada nos concursos. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, as Constituições pactuadas “... surgem através de um pacto, são aquelas em que o poder constituinte originário se concentra nas mãos de mais de um titular. Por isso mesmo, trata-se de modalidade anacrônica, dificilmente ajustando-se à noção moderna de Constituição, intimamente associada à ideia de unidade do poder constituinte. Tais Constituições pactuadas foram bastante difundidas no seio da monarquia estamental da Idade Média, quando o poder estatal aparecia cindido entre o monarca e as ordens privilegiadas. Exemplificam-nas a Magna Carta de 1215, que os barões ingleses obrigam João Sem Terra a jurar”.⁴⁰

Para Bonavides, “a Constituição **pactuada** é aquela que exprime um compromisso instável de duas forças políticas rivais: a realeza absoluta debilitada, de uma parte, e a nobreza e a burguesia, em franco progresso, doutra. Surge então como termo dessa relação de equilíbrio a forma institucional da monarquia limitada. Entendem alguns publicistas que as Constituições pactuadas assinalam o momento histórico em que determinadas classes disputam ao rei um certo grau de participação política, em nome da comunidade, com o propósito de resguardar direitos e amparar franquias adquiridas. Na Constituição pactuada o equilíbrio é precário. Uma das partes se acha sempre politicamente em posição de força. O pacto selado juridicamente mal encobre essa situação de fato, ‘e o contrato se converte por conseguinte numa estipulação unilateral camuflada’, conforme se deu com a Magna Carta ou a Constituição francesa de 1791: ali a supremacia dos barões; aqui, a supremacia dos representantes da Nação reunidos em assembleia constituinte”.⁴¹

E qual a diferença entre “**Constituição**” e “**Carta**”?

De modo geral, **Constituição** é o *nomen juris* que se dá à Lei Fundamental **promulgada**, democrática ou popular, que teve a sua origem em uma Assembleia Nacional Constituinte. Já **Carta** é o nome reservado

para aquela Constituição **outorgada**, imposta de maneira unilateral pelo agente revolucionário mediante ato arbitrário e ilegítimo.

■ 2.4.2. Quanto à forma

Quanto à forma, as Constituições podem ser **escritas (instrumental)** ou **costumeiras (não escritas ou consuetudinárias)**.

Escrita (instrumental), o próprio nome nos ajuda a explicar, seria a Constituição formada por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado. Como exemplo, citamos a brasileira de 1988, a portuguesa, a espanhola etc.

Nesse particular, cabe alertar que, no direito brasileiro, vêm sendo encontrados textos escritos com natureza de Constituição (não se resumindo a um único código), por exemplo, nos termos do art. 5.º, § 3.º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros e que, dessa maneira, passam a ser equivalentes às emendas constitucionais. Por isso, parece interessante a ideia, apesar de tímida, de uma **Constituição legal** (Constituição escrita e que se apresenta esparsa ou fragmentada em textos, conforme apontou Paulo Bonavides — cf. *item 2.4.7*).

Costumeira (não escrita ou consuetudinária) seria aquela Constituição que, ao contrário da escrita, não traz as regras em um único texto solene e codificado. É formada por “textos” esparsos, reconhecidos pela sociedade como fundamentais, e baseia-se nos usos, costumes, jurisprudência, convenções. Exemplo clássico é a Constituição da Inglaterra.

A doutrina observa que “hoje, contudo, mesmo a Inglaterra (exemplo normalmente lembrado de país regido por uma Constituição não escrita) assenta princípios constitucionais em textos escritos, em que pesem os costumes formarem relevantes valores constitucionais”.⁴²

A classificação propõe, então, a utilização do conceito de *costumeira* em um sentido mais aberto, pois, como bem anota Paulo Bonavides, “na época contemporânea **inexistem Constituições totalmente costumeiras**, semelhantes àquela que teve a França no *ancien régime*, antes da Revolução Francesa de 1789, ou seja, ‘uma complexa massa de costumes, usos e decisões judiciais’ (Barthélemy)”.

Por esse motivo, Bonavides prefere classificar a experiência inglesa como sendo a de uma *Constituição não totalmente costumeira* ou, melhor dizendo, uma **Constituição parcialmente costumeira**, já que as “... leis abrangem o direito estatutário (*statute law*), o direito casuístico ou jurisprudencial (*case law*), o costume, mormente o de natureza parlamentar (*Parliamentary custom*) e as convenções constitucionais (*constitutional conventions*)”.⁴³

Quanto à norte-americana de 1787, Bonavides a define como **escrita**, porém **complementada** pelos **costumes**, sendo que “... o elemento consuetudinário entra igualmente como fator auxiliar e subsidiário importantíssimo para completar e corrigir o texto constitucional lacunoso ou suprir, pela interpretação, partes obscuras e controversas da Constituição”. Lembrando Carl J. Friedrich, destaca que a norte-americana é completada pela **doutrina da revisão judicial** (precedentes judiciais) e, além disso, as normas escritas “... têm que ser sumamente flexíveis, porque é impossível regulamentar com absoluta precisão as eventualidades do futuro”.⁴⁴

■ 2.4.3. Quanto à extensão

Quanto à extensão, podem as Constituições ser **sintéticas (concisas, breves, sumárias, sucintas, básicas)** ou **analíticas (amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas, inchadas)**.

Sintéticas seriam aquelas enxutas, veiculadoras apenas dos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Não descem a minúcias, motivo pelo qual são mais duradouras, na medida em que os seus princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios pela atividade da Suprema

Corte. O exemplo lembrado é a Constituição americana, que está em vigor há mais de 200 anos (é claro, com emendas e interpretações feitas pela Suprema Corte).

Pinto Ferreira, analisando o constitucionalismo pátrio, indica a Constituição de 1891 como exemplo de sintética.⁴⁵

Paulo Bonavides, a seu turno, e com precisão, observa que “as Constituições concisas ou breves resultam numa **maior estabilidade** do arcabouço constitucional, bem como numa flexibilidade que permite adaptar a Constituição a situações novas e imprevistas do desenvolvimento institucional de um povo, a suas variações mais sentidas de ordem política, econômica e financeira, a necessidades, sobretudo, de improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar na rigidez dos obstáculos constitucionais”.⁴⁶

Analíticas, por outro lado, são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do povo entenderem fundamentais. Normalmente descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam estar em leis infraconstitucionais, como, conforme já mencionamos, o art. 242, § 2.º, CF/88, que dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Assim, o clássico exemplo é a brasileira de 1988.

Segundo Bonavides, “as Constituições se fizeram desenvolvidas, volumosas, inchadas, em consequência principalmente de duas causas: a preocupação de dotar certos institutos de proteção eficaz, o sentimento de que a rigidez constitucional é anteparo ao exercício discricionário da autoridade, o anseio de conferir estabilidade ao direito legislado sobre determinadas matérias e, enfim, a conveniência de atribuir ao Estado, através do mais alto instrumento jurídico que é a Constituição, os encargos indispensáveis à manutenção da paz social”.⁴⁷

■ 2.4.4. Quanto ao conteúdo

O conceito de Constituição pode ser tomado tanto em sentido **material** como **formal**.

Materialmente constitucional será aquele texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Como exemplo podemos citar a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que, em seu art. 178, prescrevia ser constitucional somente o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não fosse constitucional poderia ser alterado, sem as formalidades referidas (nos arts. 173 a 177), pelas legislaturas ordinárias.

Formal, por seu turno, será aquela Constituição que elege como critério o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer regra nela contida terá o caráter de constitucional. A brasileira de 1988 é **formal**!

Cumpra observar (*e este tema ainda não está fechado*) que, com a introdução do § 3.º no art. 5.º, pela **EC n. 45/2004**, passamos a ter uma espécie de **conceito misto**, já que a nova regra só confere a natureza de emenda constitucional (*norma formalmente constitucional*) aos tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** (*matéria*), desde que observadas as **formalidades de aprovação** (*forma*).

Como se sabe (e voltaremos a essa análise), nos termos do art. 5.º, § 3.º, “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

Nesse sentido, podemos lembrar o **Decreto Legislativo n. 186/2008**, que aprova o texto da *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* e de seu *Protocolo Facultativo*, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo **Decreto n. 6.949, de 25.08.2009**, tendo sido, assim, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de norma constitucional.

Outro exemplo de tratado internacional de direitos humanos incorporado na forma do art. 5.º, § 3.º, CF/88, e, portanto, com *status* constitucional, é o **Tratado de Marraqueche**, que busca facilitar o acesso a

obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, celebrado em 28.06.2013, e que entrou em vigor no **plano internacional** em **setembro de 2016**, a partir da adesão do Canadá, o 20.º Estado-parte, conforme determina o art. 18 do tratado. No tocante ao direito brasileiro, o Tratado foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 261/2015, tendo sido promulgado pelo Decreto presidencial n. 9.522, de 08.10.2018.

Finalmente, devemos destacar a **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância**, adotada na Guatemala, por ocasião da 43.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 5 de junho de 2013. Aprovada pelo Congresso Nacional nos termos do Decreto Legislativo n. 1, de 18.02.2021, e na forma do art. 5.º, § 3.º, CF/88, a convenção foi promulgada pelo Decreto Presidencial n. 10.932, de 10.01.2022.

■ 2.4.5. Quanto ao modo de elaboração

Quanto ao modo de elaboração as Constituições poderão ser **dogmáticas** (também denominadas “*sistemáticas*”, segundo J. H. Meirelles Teixeira) ou **históricas**.

Dogmáticas, sempre escritas, consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do Estado ou, como bem observou Meirelles Teixeira, “... partem de teorias preconcebidas, de planos e sistemas prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos... São elaboradas de um só jato, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte”.⁴⁸ Como exemplo, destacamos a brasileira de 1988.

Históricas, constituem-se através de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se, assim, da costumeira e têm como exemplo a Constituição inglesa.

■ 2.4.6. Quanto à alterabilidade

Esse critério recebe diversas denominações pelos constitucionalistas pátrios. Além da citada *alterabilidade* (Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky⁴⁹), encontramos: *mutabilidade* (Michel Temer;⁵⁰ Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior⁵¹), *estabilidade* (José Afonso da Silva⁵² e Alexandre de Moraes⁵³) e *consistência* (Pinto Ferreira⁵⁴).

Em essência, deixando de lado a questão terminológica, as Constituições poderão ser **rígidas**, **flexíveis** (também chamadas de **plásticas**, segundo a denominação de Pinto Ferreira)⁵⁵ e **semirrígidas** (ou **semiflexíveis**). Alguns autores ainda lembram as **fixas** ou **silenciosas**, as **transitoriamente flexíveis**, as **imutáveis** (**permanentes**, **graníticas** ou **intocáveis**) e as **super-rígidas**.

Rígidas são aquelas Constituições que exigem, para a sua alteração (daí preferirmos a terminologia *alterabilidade*), um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais. Lembramos que, à exceção da Constituição de 1824 (considerada semirrígida), todas as Constituições brasileiras foram, inclusive a de 1988, rígidass!

A rigidez constitucional da CF/88 está prevista no art. 60, que, por exemplo, em seu § 2.º estabelece um *quorum* de votação de 3/5 dos membros de cada Casa, em dois turnos de votação, para aprovação das emendas constitucionais. Em contraposição, apenas para aclarar mais a situação lembrada, a votação das leis ordinárias e complementares dá-se em um único turno de votação (art. 65), com *quorum* de maioria simples (art. 47) e absoluta (art. 69), respectivamente para lei ordinária e complementar. Outra característica definidora da rigidez da CF/88 está prevista nos incisos I, II e III do art. 60, que estabelecem iniciativa restrita: a) de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; b) do Presidente da República; e c) de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela *maioria*

relativa de seus membros, enquanto a iniciativa das leis complementares e ordinárias é geral, de acordo com o art. 61.⁵⁶

Flexíveis são aquelas Constituições que **não** possuem um processo legislativo de alteração mais dificultoso do que o processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. Vale dizer, a dificuldade em alterar a Constituição é a mesma encontrada para alterar uma lei que não é constitucional.

Nesse sentido, do ponto de vista formal, devemos observar que, em se tratando de **Constituição flexível**, não existe hierarquia entre Constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei infraconstitucional posterior altera texto constitucional se assim expressamente o declarar, quando for com ele incompatível, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição.

Semiflexíveis ou **semirrígidas** são aquelas Constituições tanto rígidas como flexíveis, ou seja, algumas matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para alteração das leis infraconstitucionais, enquanto outras não requerem tal formalidade. O exemplo sempre lembrado é o da Constituição Imperial de 1824, que, em seu art. 178, dizia: “É só Constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, pode ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias”.

As **fixas**, segundo Kildare Gonçalves Carvalho, “... são aquelas que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual àquele que as criou, isto é, o poder constituinte originário. São conhecidas como **constituições silenciosas**, porque não estabelecem, expressamente, o procedimento para sua reforma. Têm valor apenas histórico, sendo exemplos destas Constituições o Estatuto do Reino da Sardenha, de 1848, e a Carta Espanhola de 1876”.⁵⁷

Para Bulos, as **Constituições transitoriamente flexíveis** “... são as suscetíveis de reforma, com base no mesmo rito das leis comuns, mas apenas por determinado período; ultrapassado este, o documento constitucional

passa a ser rígido. Nessa hipótese, o binômio rigidez/flexibilidade não coexiste simultaneamente. Apresenta-se de modo alternado...”. Como exemplo, o autor lembra a Constituição de Baden de 1947 e a Carta irlandesa de 1937 durante os primeiros três anos de vigência.⁵⁸

Imutáveis seriam aquelas Constituições inalteráveis, verdadeiras *reliquias históricas*⁵⁹ e que se pretendem eternas, sendo também denominadas **permanentes**, **graníticas** ou **intocáveis**.

Finalmente, segundo Alexandre de Moraes, a brasileira de 1988 seria exemplo de Constituição **super-rígida**, já que, além de possuir um processo legislativo diferenciado para a alteração de suas normas (rígida), excepcionalmente, algumas matérias apresentam-se como **imutáveis** (cláusulas pétreas, art. 60, § 4.º).⁶⁰

Esta última classificação, contudo, **não parece ser a posição adotada pelo STF**, que tem admitido a alteração de matérias contidas no art. 60, § 4.º, desde que a reforma não tenda a abolir os preceitos ali resguardados e dentro de uma ideia de razoabilidade e ponderação. Foi o caso da **reforma da previdência** que admitiu a **taxação dos inativos**, mitigando, assim, os direitos e garantias individuais (as situações já consolidadas das pessoas aposentadas que passaram a ser taxadas).⁶¹

■ 2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)

Valendo-se do **critério sistemático**, Pinto Ferreira divide as Constituições em **reduzidas** (ou **unitárias**) e **variadas**.⁶²

Reduzidas seriam aquelas que se materializariam em um só código básico e sistemático, como as brasileiras (ver crítica a seguir).

Variadas seriam aquelas que se distribuiriam em vários textos e documentos esparsos, sendo formadas de várias leis constitucionais, destacando-se a belga de 1830 e a francesa de 1875.

Nesse mesmo sentido, Bonavides distingue as Constituições **codificadas** das **legais**.

Codificadas (que correspondem às *reduzidas* de Pinto Ferreira) seriam “... aquelas que se acham contidas inteiramente num só texto, com os seus princípios e disposições sistematicamente ordenados e articulados em títulos, capítulos e seções, formando em geral um único corpo de lei”.

Por sua vez, as **legais** (também denominadas **Constituições escritas não formais**, e que equivalem às *variadas* de Pinto Ferreira) seriam aquelas “... escritas que se apresentam esparsas ou fragmentadas em vários textos. Haja vista, a título ilustrativo, a Constituição francesa de 1875. Compreendia ela Leis Constitucionais, elaboradas em ocasiões distintas de atividade legislativa, como as leis de estabelecimento dos poderes públicos, de organização do Senado e de relações entre os poderes. Tomadas em conjunto passaram a ser designadas como a Constituição da Terceira República”.⁶³

A **brasileira de 1988**, em um primeiro momento, como aponta Pinto Ferreira, seria **reduzida, codificada** ou **unitária**.

Contudo, especialmente diante da ideia de “bloco de constitucionalidade”, que será estudada no *item* 6.7.1.3, parece **caminharmos** (de maneira muito tímida, ainda) para um critério que se aproxima de Constituição **esparsa** (legal ou escrita não formal — escrita e que se apresenta fragmentada em vários textos), especialmente diante da regra contida no art. 5.º, § 3.º, que admite a constitucionalização dos tratados ou convenções internacionais de direitos humanos que forem incorporados com o *quorum* e procedimento das emendas constitucionais, destacando-se os seguintes exemplos, que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com o *status* de norma constitucional:

■ **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo:** aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 09.07.2008, foi promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25.08.2009;

■ **Tratado de Marraqueche:** aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 261, de 25.11.2015, foi promulgado pelo Decreto Presidencial n. 9.522, de 08.10.2018. Referido tratado busca

facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso;

■ **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância:** aprovada pelo Congresso Nacional nos termos do Decreto Legislativo n. 1, de 18.02.2021, o texto foi promulgado pelo Decreto Presidencial n. 10.932, de 10.01.2022.

Ainda, existem vários artigos de **emendas constitucionais** que não foram introduzidos no “corpo” da Constituição e, permanecendo como artigo autônomo das emendas, sem dúvida, têm **natureza constitucional** e, portanto, eventual lei que contrarie artigo de emenda constitucional poderá ser declarada inconstitucional, servindo a emenda como paradigma de confronto.

Outro exemplo interessante seria a introdução de disposições por emendas e, portanto, com *status* constitucional, sem que tenha havido alteração do corpo ou mesmo do ADCT, destacando-se:

■ **EC n. 91/2016:** altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade, excepcional e em período determinado, de desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato (cf. *item 18.5*);

■ **EC n. 106/2020:** institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia;

■ **EC n. 107/2020:** adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos.

Cabe alertar, contudo, que, apesar dessa percepção, de modo geral, as provas de concursos vêm definindo a Constituição brasileira de 1988 como **reduzida**.

■ 2.4.8. Quanto à dogmática

No tocante à **dogmática**, Pinto Ferreira, valendo-se do **critério ideológico** e lembrando as lições de **Paulino Jacques**, identifica tanto a Constituição **ortodoxa** como a **eclética**.

Ortodoxa é aquela formada por uma só ideologia, por exemplo, a soviética de 1977, hoje extinta, e as diversas Constituições da China marxista.

Eclética seria aquela formada por ideologias conciliatórias, como a brasileira de 1988 ou a da Índia de 1949.

Nessa linha, alguns autores aproximam a eclética da **compromissória**. De fato, parece possível dizer que a **brasileira de 1988 é compromissória**, assim como a portuguesa de 1976.

Nas palavras de Canotilho, “numa sociedade plural e complexa, a Constituição é sempre um produto do ‘pacto’ entre forças políticas e sociais. Através de ‘barganha’ e de ‘argumentação’, de ‘convergência’ e ‘diferenças’, de cooperação na deliberação mesmo em caso de desacordos persistentes, foi possível chegar, no procedimento constituinte, a um *compromisso constitucional* ou, se preferirmos, a vários ‘compromissos constitucionais’. O **carácter compromissório da Constituição de 1976** representa uma **força** e não uma debilidade. Mesmo quando se tratava de ‘conflitos profundos’ (*deep conflict*), houve a possibilidade de se chegar a bases normativas razoáveis. Basta referir o compromisso entre o princípio liberal e o princípio socialista, o compromisso entre uma visão personalista-individual dos direitos, liberdades e garantias e uma perspectiva dialético-social dos direitos econômicos, sociais e culturais, o compromisso entre ‘legitimidade eleitoral’ e ‘legitimidade revolucionária’, o compromisso entre princípio da unidade do Estado e o princípio da autonomia regional e local, o compromisso entre democracia representativa e democracia participativa”.⁶⁴

■ 2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência)

Karl Loewenstein distinguiu as Constituições **normativas**, **nominalistas (nominativas ou nominais)** e **semânticas**. Trata-se do **critério ontológico**, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional.

Segundo Pinto Ferreira, “as *Constituições normativas* são aquelas em que o processo de poder está de tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu controle procedimental. As *Constituições nominalistas* contêm disposições de limitação e controle de dominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com insuficiente concretização constitucional. Enfim, as *Constituições semânticas* são simples reflexos da realidade política, servindo como mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do seu conteúdo”.⁶⁵

Isso quer dizer que da **normativa** à **semântica** percebemos uma gradação de **democracia e Estado Democrático de Direito** para **autoritarismo**.

Enquanto nas **Constituições normativas** a pretendida limitação ao poder se implementa na prática, havendo, assim, correspondência com a realidade, nas **nominalistas** busca-se essa concretização, porém, sem sucesso, não se conseguindo uma verdadeira normatização do processo real do poder. Nas **semânticas**, por sua vez, nem sequer se tem essa pretensão, buscando-se conferir legitimidade meramente formal aos detentores do poder, em seu próprio benefício.

Para Guilherme Peña de Moraes, ao tratar do constitucionalismo pátrio, **a brasileira de 1988 “pretende ser” normativa**; as de 1824, 1891, 1934 e 1946 foram nominais (“... a Constituição é dotada de um aspecto educativo e prospectivo (...). Portanto, embora não haja concordância entre as normas constitucionais e a realidade política no presente, há a aspiração de que tal desiderato seja alcançado no futuro”). E as de 1937, 1967 e a EC n. 1/69 foram semânticas.⁶⁶

Marcelo Neves, fazendo uma releitura de Loewenstein, prefere denominar as semânticas **instrumentalistas**, já que instrumentos dos detentores do poder. Em sua opinião, o texto de 1988 seria **nominalista**, servindo como verdadeiro “álibi” para os governantes (no tocante à não concretização de seus preceitos), ao passo que as instrumentalistas (1937, 1967 e a EC n. 1/69) aparecem como “armas” na “luta política”.⁶⁷

■ 2.4.10. Quanto ao sistema

Segundo *Diogo de Figueiredo Moreira Neto*, a Constituição, quanto ao **sistema**, pode ser classificada em **principiológica** ou **preceitual**.

Na **principiológica**, conforme anotou Guilherme Peña de Moraes, “... predominam os **princípios**, identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração, consagradores de valores, pelo que é necessária a mediação concretizadora, tal como a Constituição brasileira”.

Por seu turno, na **preceitual** “... prevalecem as **regras**, individualizadas como normas constitucionais revestidas de pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é possível a aplicação coercitiva, tal como a Constituição mexicana”.⁶⁸

■ 2.4.11. Quanto à função

Quanto à função, as Constituições podem ser classificadas como **provisórias** ou **definitivas**.

De acordo com Jorge Miranda, “chama-se de *pré-Constituição*, *Constituição provisória* ou, sob outra ótica, *Constituição revolucionária* ao conjunto de normas com a dupla finalidade de definição do regime de elaboração e aprovação da Constituição formal e de estruturação do poder político no interregno constitucional, a que se acrescenta a função de eliminação ou erradicação de resquícios do antigo regime. Contrapõe-se à Constituição *definitiva* ou de *duração indefinida para o futuro* como pretende ser a Constituição produto final do processo constituinte”.⁶⁹

■ 2.4.12. Quanto à origem de sua decretação: heterônomas (heteroconstituições) x autônomas (“autoconstituições” ou “homoconstituições”)

Quando surge um novo Estado, ou o Estado que já existia restaura-se, ou sofre radical transformação de sua estrutura, essa nova manifestação atrela-se a uma Constituição material que já vem acompanhada da Constituição formal, ou que passa a ter uma Constituição formal estabelecida em momento seguinte.

A soberania do Estado está sedimentada na Constituição material, e a Constituição formal, normalmente, provém do próprio Estado.

De modo **incomum**, contudo, a doutrina identifica Constituições que foram decretadas de fora do Estado por outro (ou outros) Estado(s) ou por organizações internacionais.

Estamos diante daquilo que *Miguel Galvão Teles* denominou **heteroconstituição**.⁷⁰

Conforme anota Jorge Miranda, além da **raridade**, causam certa **perplexidade**, dando como exemplo: “... algumas das Constituições, ou das primeiras Constituições, dos **países da Commonwealth** aprovadas por leis do Parlamento britânico (Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Jamaica, Maurícia, etc.), a primeira Constituição da **Albânia** (obra de uma conferência internacional, de 1913) ou a Constituição **cipriota** (procedente dos acordos de Zurique, de 1960, entre a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia) ou a Constituição da **Bósnia-Herzegovina** (após os chamados acordos de Dayton de 1995)”, ou, ainda, no **plano puramente político**, “as Constituições surgidas por **imposição** de outros Estados: as Constituições das **Repúblicas Helvética** e **Batava** do tempo da Revolução francesa, a Constituição **espanhola** de **1808**, as **primeiras** Constituições da **Libéria** e das **Filipinas**, a Constituição **japonesa** de **1946**, as **Constituições das democracias populares do leste da Europa dos anos 40 e 50**, a **primeira** Constituição da **Guiné Equatorial**. E por imposição das Nações Unidas: as Constituições da **Namíbia** de **1990** e do **Camboja** de **1993**”.⁷¹

Interessante observar, como ensina o mestre português, que “... até a independência o fundamento de validade da Constituição estava na ordem jurídica donde proveio; com a independência transfere-se para a ordem jurídica local, investida de poder constituinte. Verifica-se, pois, uma verdadeira **novação** do **ato constituinte** ou (doutro prisma) uma **deslocação da regra de reconhecimento**; e **apenas** o **texto** que persista — correspondente a Constituição em sentido instrumental — **se liga à primitiva fonte, não o valor vinculativo das normas**”.⁷²

Diante do exposto, no entanto, pode-se afirmar que as Constituições brasileiras **não são heterônomas**, na medida em que elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado que irão reger. Podemos, assim, denominá-las, nesse sentido, Constituições **autônomas**, ou **autoconstituições**, ou, por que não, **homoconstituições** (fazendo um contraponto à terminologia proposta por *Miguel Galvão Teles*).

■ 2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves Ferreira Filho)

A Constituição **garantia** busca garantir a liberdade, limitando o poder; a **balanço** reflete um degrau de evolução socialista e a **dirigente** estabelece um projeto de Estado (ex.: portuguesa).

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “modernamente, é frequente designar a Constituição de tipo clássico de *Constituição-garantia*, pois esta visa a garantir a liberdade, limitando o poder. Tal referência se desenvolveu pela necessidade de contrapor-la à *Constituição-balanço*. Esta, conforme a doutrina soviética que se inspira em Lassalle, é a Constituição que descreve e registra a organização política estabelecida. Na verdade, segundo essa doutrina, a Constituição registraria um estágio das relações de poder. Por isso é que a URSS, quando alcançado novo estágio na marcha para o socialismo, adotaria nova Constituição, como o fez em 1924, 1936 e em 1977. Cada uma de tais Constituições faria o *balanço* do novo estágio. Hoje muito se fala em *Constituição-dirigente*. Esta seria a Constituição que estabeleceria um *plano*

para dirigir uma evolução política. Ao contrário da *Constituição-balanço* que refletiria o presente (o ser), a *Constituição-programa* anunciaria um *ideal* a ser concretizado. Esta *Constituição-dirigente* se caracterizaria em consequência de *normas programáticas* (que para não caírem no vazio reclamariam a chamada *inconstitucionalidade por omissão...*). A ideia de *Constituição-dirigente* é sobretudo encarecida por juristas de inspiração marxista, como o português Canotilho, que desejam prefigurar na Constituição a implantação progressiva de um Estado socialista, primeiro, comunista, a final. Exemplo, a Constituição portuguesa de 1976”.⁷³

■ 2.4.14. **Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) — conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)**

André Ramos Tavares propõe outra classificação, levando em conta o conteúdo ideológico das Constituições, classificando-as em **liberais** (ou **negativas**) e **sociais** (ou **dirigentes**).⁷⁴

Para ele, “as Constituições **liberais** surgem com o triunfo da ideologia burguesa, com os ideais do liberalismo”.

Nesse contexto, destacamos os direitos humanos de **1.ª dimensão** e, assim, a ideia da não intervenção do Estado, bem como a proteção das liberdades públicas. Poderíamos falar, portanto, em **Constituições negativas** (absenteísmo estatal).

Por outro lado, as Constituições **sociais** refletem um momento posterior, de necessidade da atuação estatal, consagrando a igualdade substancial, bem como os direitos sociais, também chamados de direitos de **2.ª dimensão**.

Trata-se da percepção de uma **atuação positiva** do Estado e, por isso, André Ramos Tavares aproxima as Constituições sociais da ideia de **dirigismo** estatal sugerida por Canotilho.

Segundo o autor, estamos diante do **Estado do Bem Comum**. E completa: “é bastante comum, nesse tipo de Constituição, traçar expressamente os grandes objetivos que hão de nortear a atuação

governamental, impondo-os (ao menos a longo prazo)”.

■ 2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)

Raul Machado Horta⁷⁵ inscreve a brasileira de 1988 no grupo das **Constituições expansivas**. Para o ilustre autor, “a expansividade da Constituição de 1988, em função dos temas novos e da ampliação conferida a temas permanentes, como no caso dos Direitos e Garantias Fundamentais, pode ser aferida em três planos distintos:” *conteúdo anatômico e estrutural da Constituição; comparação constitucional interna e comparação constitucional externa*:

■ **conteúdo anatômico e estrutural da Constituição**: destacam-se a estruturação do texto e sua divisão em títulos, capítulos, seções, subseções, artigos da parte permanente e do ADCT;

RAUL MACHADO HORTA — CONSTITUIÇÃO EXPANSIVA — CONTEÚDO ANATÔMICO E ESTRUTURAL DA CF/88	
■	Preâmbulo
■	Título I — Dos Princípios Fundamentais — arts. 1.º a 4.º
■	Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais — arts. 5.º a 17
■	Título III — Da Organização do Estado — arts. 18 a 43
■	Título IV — Da Organização dos Poderes — arts. 44 a 135
■	Título V — Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas — arts. 136 a 144
■	Título VI — Da Tributação e do Orçamento — arts. 145 a 169
■	Título VII — Da Ordem Econômica e Financeira — arts. 170 a 192

■ **Título VIII** — Da Ordem Social — arts. 193 a 232

■ **Título IX** — Das Disposições Constitucionais Gerais — arts. 233 a 250

■ **ADCT** — arts. 1.º a 137

■ **comparação constitucional interna:** relaciona-se a CF/88 com as Constituições brasileiras precedentes, considerando a extensão de cada uma e as suas alterações. Segundo o autor, referida *comparação interna* “... registra a dilatação da matéria constitucional e a evolução das Constituições brasileiras no tempo”;

■ **comparação constitucional externa:** relaciona a Constituição brasileira com as Constituições estrangeiras mais extensas.

Dentro dessa ideia, bastante interessante a proposta defendida por Luiz Sales do Nascimento, de uma *teoria científica do direito constitucional comparado*, sugerindo que a atividade comparativa siga verdadeiro e seguro roteiro metodológico.⁷⁶

■ 2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988

Valendo-nos de todos os critérios classificatórios anteriormente expostos e a seguir esquematizados, podemos dizer que a Constituição brasileira de 1988 singulariza-se por ser: **promulgada, escrita, analítica, formal** (cf. nova perspectiva classificatória decorrente do art. 5.º, § 3.º, introduzido pela EC n. 45/2004, sugerida no *item 2.4.4*), **dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa, principiológica, definitiva** (ou de **duração indefinida para o futuro**), **autônoma** (**autoconstituição** ou “**homoconstituição**”), **garantia, dirigente, social** e **expansiva**.

■ *quanto à origem:* outorgada, **promulgada**, cesarista (bonapartista) ou pactuada (dualista);

- *quanto à forma*: **escrita (instrumental)** ou costumeira (consuetudinária, não escrita);
- *quanto à extensão*: sintética (concisa, breve, sumária, sucinta, básica) ou **analítica (ampla, extensa, larga, prolixa, longa, desenvolvida, volumosa, inchada)**;
- *quanto ao conteúdo*: **formal** ou material (tendência para um critério **misto** — EC n. 45/2004);
- *quanto ao modo de elaboração*: **dogmática (sistemática)** ou histórica;
- *quanto à alterabilidade*: **rígida**, flexível, semirrígida (semiflexível), fixa (silenciosa), transitoriamente flexível, imutável (permanente, granítica, intocável), “super-rígida”;
- *quanto à sistemática (Pinto Ferreira)*: **reduzida (unitária)** ou variada;
- *quanto à dogmática (Paulino Jacques)*: ortodoxa ou **eclética** (destaque para o caráter **compromissório** do texto de 1988);
- *quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência — Karl Loewenstein)*: **normativa (pretende ser)**, nominalista ou semântica;
- *quanto ao sistema*: **principiológica** ou preceitual;
- *quanto à função*: pré-Constituição, Constituição provisória, ou Constituição revolucionária, e Constituição **definitiva**, ou de **duração indefinida para o futuro**;
- *quanto à origem de sua decretação*: heterônoma (“heteroconstituição”) ou **autônoma** (“**autoconstituição**” ou “**homoconstituição**”);
- *Manoel Gonçalves Ferreira Filho*: **garantia**, balanço e **dirigente**;
- *André Ramos Tavares (conteúdo ideológico das Constituições)*: liberais (negativas) e **sociais (dirigentes)**;
- *Raul Machado Horta*: **expansiva**.

■ 2.5. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Não obstante encontremos na Constituição um todo orgânico e sistematizado, as normas constitucionais estão agrupadas em títulos, capítulos e seções, com conteúdo, origem e finalidade diversos.

Esses dispositivos, trazendo valores distintos, caracterizam a natureza **polifacética** da Constituição, fazendo com que a doutrina agrupe as diversas normas de acordo com a sua finalidade, surgindo, então, o que se denominou **elementos da Constituição**.

A doutrina diverge em relação aos elementos da Constituição.⁷⁷ No entanto, parece ser mais completa a identificação do Professor José Afonso da Silva, de **cinco categorias de elementos**, assim definidas:⁷⁸

■ **elementos orgânicos:** normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder. Exemplos: *a)* Título III (Da Organização do Estado); *b)* Título IV (Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo); *c)* Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e da Segurança Pública); *d)* Título VI (Da Tributação e do Orçamento);

■ **elementos limitativos:** manifestam-se nas normas que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais (direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos políticos e democráticos), limitando a atuação dos poderes estatais. Exemplo: Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), excetuando o Capítulo II do referido Título II (Dos Direitos Sociais), estes últimos definidos como elementos socioideológicos;

■ **elementos socioideológicos:** revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social, intervencionista. Exemplos: *a)* Capítulo II do Título II (Dos Direitos Sociais); *b)* Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira); *c)* Título VIII (Da Ordem Social);

■ **elementos de estabilização constitucional:** consubstanciados nas normas constitucionais destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Constituem instrumentos de defesa do Estado e buscam garantir a paz social. Exemplos: *a)* art. 102, I, “a” (ação de inconstitucionalidade); *b)* arts. 34 a 36 (Da intervenção nos Estados e Municípios); *c)* arts. 59, I, e 60 (Processos de emendas à Constituição); *d)* arts. 102 e 103 (Jurisdição constitucional); *e)* Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, especialmente o Capítulo I, que trata do estado de defesa e do estado de sítio, já que os Capítulos II e III do Título V caracterizam-se como elementos orgânicos);

■ **elementos formais de aplicabilidade:** encontram-se nas normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições. Exemplos: *a)* preâmbulo; *b)* disposições constitucionais transitórias; *c)* art. 5.º, § 1.º, quando estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

■ 2.6. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS⁷⁹

CONSTITUIÇÃO	SURGIMENTO	VIGÊNCIA EM ANOS ⁸⁰
1824	25.03.1824 ⁸¹	65
1891	24.02.1891 ⁸²	39
1934	16.07.1934	03
1937	10.11.1937	08
1946	18.09.1946	20
1967	24.01.1967	02
EC n. 1/1969 ⁸³	17.10.1969	18
1988	05.10.1988	35 ⁸⁴

■ 2.6.1. Constituição de 1824

Em 1808, tendo em vista a ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas, a Família Real Portuguesa se transfere para o Brasil, passando a colônia brasileira a ser designada *Reino Unido a Portugal e Algarves*.

Em seguida, em decorrência da *Revolução do Porto* e por exigência dos nobres portugueses, o Rei Dom João VI, rei de Portugal, retorna a Lisboa em abril de 1821, deixando no Brasil D. Pedro de Alcântara, Príncipe Real do Reino Unido e Regente brasileiro (seu filho com a imperatriz D. Carlota Joaquina).

Esses acontecimentos, sem dúvida, contribuíram para a intensificação dos movimentos pela independência do Brasil, e, em 9 de janeiro de 1822, desrespeitando ordem da Corte portuguesa, que exigia seu retorno imediato na tentativa de efetivar a recolonização brasileira, D. Pedro I, tendo recebido diversas assinaturas coletadas pelos “liberais radicais”, disse: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico” (“**Dia do Fico**”).

Após ter declarado a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I convoca, em 1823, uma *Assembleia Geral Constituinte e Legislativa*, com **ideais marcadamente liberais**, que, contudo, vem a ser dissolvida, arbitrariamente, tendo em vista a existência de divergências com os seus ideais e pretensões autoritários.

Em substituição (da Assembleia Constituinte), D. Pedro I cria um *Conselho de Estado* para tratar dos “negócios de maior monta” e elaborar um novo projeto em total consonância com a sua vontade de “Majestade Imperial”.

A Constituição Política do Império do Brasil foi **outorgada** em 25 de março de 1824 e foi, dentre todas, **a que durou mais tempo**, tendo sofrido considerável influência da francesa de 1814. Foi marcada por forte **centralismo administrativo e político**, tendo em vista a figura do **Poder Moderador**, constitucionalizado, e também por **unitarismo** e **absolutismo**.

Algumas importantes características do texto de 1824 podem ser destacadas:

■ **Governo:** monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Tratava-se de forma **unitária de Estado**, com nítida centralização político-administrativa.

■ **Território:** as antigas capitanias hereditárias foram transformadas em **províncias**, que, por sua vez, poderiam ser subdivididas. As províncias eram subordinadas ao Poder Central e tinham um “Presidente”, nomeado pelo Imperador e que poderia ser removido a qualquer tempo (*ad nutum*) em nome do “bom serviço do Estado”.

■ **Dinastia imperante:** a do Senhor D. Pedro I, Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil. Durante o Império tivemos, também, a dinastia de D. Pedro II.

■ **Religião Oficial do Império:** Católica Apostólica Romana. Todas as outras religiões eram permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, não podendo, contudo, ter qualquer manifestação externa de templo.

■ **Capital do Império brasileiro:** a cidade do **Rio de Janeiro** foi a capital do Império brasileiro de 1822 a 1889. Com o Ato Adicional n. 16, de 12.08.1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em **Município Neutro** ou **Município da Corte**, entidade territorial para a sede da Monarquia. O Município Neutro apresentava importante característica: “o relacionamento direto com o poder central, ao invés da submissão ao poder da Província do Rio de Janeiro”.⁸⁵

Essa desvinculação em relação à Província do Rio de Janeiro encontrava fundamento no art. 1.º, 2.ª parte, do referido Ato Adicional de 1834, que, em cumprimento à Lei n. 12, de 12.10.1832 (que facultava a alteração de alguns artigos da Constituição de 1824, dentre eles o art. 72), inovando, passou a permitir a autoridade da *Assembleia Legislativa da Província* também na cidade do Rio de Janeiro (a capital).

A cidade do Rio de Janeiro foi a *sede do poder federal* mesmo com a proclamação da República, nos termos do art. 10 do Decreto n. 1, de 15.11.1889. A primeira Constituição da República, de 1891, como se verá, transformou o antigo Município Neutro (cidade do Rio de Janeiro, desvinculada da Província do Rio de Janeiro) em Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União.

■ **Organização dos “Poderes”:** seguindo as ideias de Benjamin Constant, não se adotou a separação tripartida de Montesquieu. Isso porque, além das funções legislativa, executiva e judiciária, estabeleceu-se a função **moderadora**. Nesse sentido, o art. 10 da Constituição do Império de 1824: “Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil

são **quatro**: o **Poder Legislativo**, o **Poder Moderador**, o **Poder Executivo**, e o **Poder Judicial**".

■ **Poder Legislativo**: exercido pela **Assembleia Geral**, com a sanção do Imperador, que era composta de duas Câmaras — **Câmara de Deputados** e **Câmara de Senadores**, ou **Senado**. A Câmara dos Deputados era eletiva e temporária; a de Senadores, vitalícia, sendo os seus membros nomeados pelo Imperador dentre uma lista tríplice enviada pela Província.

■ **Eleições para o Legislativo**: indiretas.

■ **Sufrágio**: censitário, ou seja, baseava-se em determinadas condições econômico-financeiras de seus titulares (para votar e ser votado).

■ **Poder Executivo**: a função executiva era exercida pelo **Imperador**, Chefe do Poder Executivo, por intermédio de seus Ministros de Estado. Em um primeiro momento, para continuar no poder, os Ministros não dependiam da confiança do Parlamento.

Contudo, a partir da abdicação do trono por D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, na fase da Regência (que durou 9 anos, durante a menoridade de D. Pedro II, que contava com 5 anos de idade, tendo existido 4 Regências) e, em seguida, graças ao espírito moderado de D. Pedro II, o segundo Imperador do Brasil, que assumiu o trono aos 15 anos de idade, em 18 de julho de 1841, contribuiu para a paulatina instituição do **parlamentarismo monárquico no Brasil** durante o Segundo Reinado.⁸⁶

O parlamentarismo se consolidou com a criação do cargo de *Presidente do Conselho de Ministros* pelo Decreto n. 523, de 20.07.1847, conforme o qual D. Pedro II escolhia o Presidente do Conselho e este, por sua vez, escolhia os demais Ministros, que deveriam ter a confiança dos Deputados e do Imperador, sob pena de ser dissolvido (alguns chegam a denominá-lo um "parlamentarismo às avessas", já que o Presidente do Conselho, que equivaleria ao Primeiro-Ministro da Inglaterra, era escolhido pelo Imperador e portanto a este subordinado, e não ao Parlamento).

■ **Poder Judiciário:** o denominado “Poder Judicial” era independente e composto de **juízes** e **jurados**. Os juízes aplicavam a lei; os jurados se pronunciavam sobre os fatos. Aos juízes de direito era assegurada a vitaliciedade (“os juízes de direito serão perpétuos”, só podendo perder o “lugar” por sentença), não se lhes assegurando, todavia, a inamovibilidade. O Imperador podia suspendê-los por queixas que lhe eram feitas. Para julgar as causas em segunda e última instância, nas Províncias do Império, foram criadas as “**Relações**”. Na Capital do Império foi estabelecido, como órgão de cúpula do Judiciário, o **Supremo Tribunal de Justiça**, composto de juízes togados, provenientes das “Relações” das Províncias e pelo critério da antiguidade.

■ **Poder Moderador:** sem dúvida, foi o “mecanismo” que serviu para assegurar a **estabilidade do trono** do Imperador durante o reinado no Brasil.

Afonso Arinos destaca que o criador da ideia de Poder Moderador, **Benjamin Constant**, sofreu forte influência de **Clermont Tonerre**.

Como relata, Benjamin Constant definia o Poder Moderador, por ele chamado de “**Poder Real**”, como “*la clef de toute organisation politique*”, frase esta consagrada no art. 98 da Constituição de 1824: “**o Poder Moderador é a chave de toda a organização Política**, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio e harmonia dos demais Poderes Políticos”.⁸⁷

Muita discussão houve sobre o Poder Moderador, especialmente em razão da tradução do termo “*clef*”, ou seja, significando “**fecho**” para alguns ou “**chave**” para outros, este último como consta do art. 98 da Constituição de 1824.

Para os **liberais**, a melhor tradução seria “**fecho**”, no sentido de “apoio e coordenação” em relação aos demais Poderes. Para os **conservadores**, a tradução mais adequada seria “**chave**”, dando a ideia de possibilidade de “abrir qualquer porta”, tendo em vista as constantes “intervenções” e “imposições” do Poder Moderador sobre os demais Poderes.⁸⁸

Assim, na prática, parece que a tradução “chave” refletiu a constante interferência do Poder Moderador sobre os demais Poderes e o significado de Imperador, que recebeu os Títulos de “Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, tendo o tratamento de “Majestade Imperial” e sendo a sua pessoa inviolável e sagrada, não sujeita a responsabilidade alguma (irresponsabilidade total do Estado — “*the king can do no wrong*” — “o rei não erra”).

O **Imperador**, que exercia o **Poder Moderador**, no âmbito do **Legislativo**, nomeava os Senadores, convocava a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionava e vetava proposições do Legislativo, dissolvia a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra, que a substituíria. No âmbito do **Executivo**, nomeava e exonerava livremente os Ministros de Estado. E, por fim, no âmbito do **Judiciário**, suspendia os Magistrados.

■ **Tentativa frustrada de se instalar o Estado Federativo durante o Império:** a Regência permanente, em nome do Imperador D. Pedro II, tendo em vista os poderes de reforma atribuídos pela Lei de 12.10.1832, nos termos do art. 1.º da Lei n. 16, de 12.08.1834 (**Ato Adicional**), criou as chamadas “Assembleias Legislativas Provinciais”, com considerável autonomia. Contudo, contrariamente ao interesse de determinados segmentos, não se conseguiu acabar com o Poder Moderador, nem com o absolutismo reinante, especialmente a partir do advento da Lei n. 105, de 12.05.1840, chamada “Lei de Interpretação”, que restabeleceu, fortemente, a ideia centralizadora e a figura do Poder Moderador.

■ **Insurreições populares:** durante o Império diversos movimentos populares eclodiram, seja por causas separatistas, seja por melhores condições sociais, destacando-se:

- a) Cabanagem (no Pará, 1835);
- b) Farroupilha (no Rio Grande do Sul, 1835);
- c) Sabinada (na Bahia, 1837);
- d) Balaiada (no Maranhão, 1838);
- e) Revolução Praieira (em Pernambuco, 1848).

■ **Constituição semirrígida:** nos termos do art. 178, conforme já estudamos, no tocante à classificação das Constituições quanto à *alterabilidade*, algumas normas, para serem alteradas, necessitavam de um procedimento mais árduo, mais solene e mais dificultoso; outras, entretanto, eram alteradas por um processo legislativo ordinário, sem nenhuma formalidade.

■ **Liberdades públicas:** por forte influência das Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), configurando a ideia de **constitucionalismo liberal**,⁸⁹ a Constituição de 1824 continha importante rol de Direitos Cíveis e Políticos. Sem dúvida influenciou as **declarações de direitos e garantias** das Constituições que se seguiram.

Não podemos, contudo, deixar de **execrar** a triste manutenção da escravidão, por força do regime que se baseava na “monocultura latifundiária e escravocrata”,⁹⁰ como mancha do regime até 13 de maio de 1888, data de sua abolição, quando da assinatura da **Lei Áurea** pela Princesa Isabel.⁹¹

Muito embora não prevista a garantia do *habeas corpus*, cabe lembrar que o *Decreto n. 114, de 23.05.1821*, alvará de D. Pedro I, antes do texto, já proibia prisões arbitrárias. A Constituição de 1824, por si, tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e também vedou qualquer hipótese de prisão arbitrária.

Foi somente a partir do *Código Criminal* de 16.12.1830 (arts. 183 a 188) que se passou a estabelecer a garantia do *habeas corpus*, regra prevista, também, no *Código de Processo Criminal de Primeira Instância* (Lei n. 127, de 29.11.1832, arts. 340 a 345) e no art. 18 da *Lei n. 2.033, de 20.09.1871* (que assegurou a impetração também por estrangeiros).

A garantia do “HC”, como se verá, constitucionaliza-se somente no texto de 1891.

■ 2.6.2. **Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da República**

A partir de 1860, começa-se a perceber um enfraquecimento da Monarquia. Em 1868, durante a *Guerra do Paraguai*, os militares passam a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a Monarquia, sentimento esse que se intensificou em razão da candente “marginalização política” e redução do orçamento e efetivo militares.

O *Manifesto do Centro Liberal* (1869) e o *Manifesto Republicano* (1870) também contribuíram para abalar a Monarquia, atacando a vitaliciedade dos Senadores e o papel do Conselho de Estado.

Em 1874 tivemos fortes entraves entre a Igreja Católica e a Monarquia.

Nesse contexto, “desmoronando” as “colunas de apoio” ao Império, em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando-se do poder D. Pedro II e toda a dinastia de Bragança, sem ter havido muita movimentação popular. Isso porque, como visto, tratava-se mais de um golpe de Estado militar e armado do que de qualquer movimento do povo. A República nascia, assim, sem legitimidade.

Consequentemente, as Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, passam a constituir os **Estados Unidos do Brasil**.

Entre 1889 e 1891 se instala no Brasil o **Governo Provisório** (Dec. n. 1, de 15.11.1889, redigido por Rui Barbosa), presidido por Deodoro da Fonseca e que tinha a importante missão de consolidar o novo regime e promulgar a primeira Constituição da República.

Nos termos do art. 10 do Decreto presidencial n. 1, de 15 de novembro de 1889, “o território do Município Neutro fica provisoriamente sob a administração imediata do Governo Provisório da República, e a **cidade do Rio de Janeiro** constituída, também provisoriamente, **sede do poder federal**”.

■ 2.6.3. Constituição de 1891

A Assembleia Constituinte foi eleita em 1890. Em 24 de fevereiro de 1891, a **primeira Constituição da República do Brasil** (a segunda do constitucionalismo pátrio) é promulgada, sofrendo pequena reforma em

1926. Vigorou até 1930.

A Constituição de 1891 teve por Relator o Senador **Rui Barbosa** e sofreu forte influência da Constituição norte-americana de 1787, consagrando o sistema de governo **presidencialista**, a forma de Estado **federal**, abandonando o unitarismo e a forma de governo **republicana** em substituição à monárquica.

■ **Forma de Governo e regime representativo:** nos termos do art. 1.º da Constituição de 1891, a Nação brasileira adotou, como forma de Governo, sob o **regime representativo**, a **República Federativa**, proclamada em 15 de novembro de 1889. Declarou, ainda, a **união perpétua** e **indissolúvel** das antigas Províncias, transformando-as em Estados Unidos do Brasil e vedando, assim, a possibilidade de secessão (qual seja, separação, segregação do pacto federativo).

■ **Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** nos termos do art. 2.º da Constituição de 1891, o antigo Município Neutro (Rio de Janeiro, que era a sede do Poder Central do Império) foi transformado em **Distrito Federal**, continuando a ser a **Capital da União**, enquanto não cumprida a determinação contida no art. 3.º da Constituição de 1891, com a seguinte previsão: “fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela **estabelecer-se a futura Capital Federal**. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um **Estado**”.

Nesse sentido, o art. 1.º da primeira Lei Orgânica do DF, a Lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, manteve a natureza “municipal” da capital do País (o Distrito Federal), ao estabelecer: “o Distrito Federal compreende o território do antigo Município Neutro, tem por sede a cidade do Rio de Janeiro e continua constituído em Município”.⁹²

■ **Não há mais religião oficial:** o Brasil, nos termos do que já havia sido estabelecido pelo *Decreto n. 119-A, de 07.01.1890*, constitucionaliza-se como um país leigo, laico ou não confessional. Retiraram-se os efeitos civis

do casamento religioso. Os cemitérios, que eram controlados pela Igreja, passaram a ser administrados pela autoridade municipal. Houve proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Não se invocou, no preâmbulo da Constituição, a expressão “sob a proteção de Deus” para a sua promulgação.

Lembramos, por fim, que nos termos do art. 4.º do Decreto n. 119-A, de 07.01.1890, já havia sido extinto o **padroado** (direito que o Imperador tinha de intervir nas nomeações dos bispos, bem como nos cargos e benefícios eclesiásticos), com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas.

Como não havia mais religião oficial, naturalmente também, com o texto de 1891, ficou extinta a concessão ou negativa de **beneplácito régio** aos Decretos dos Concílios e Letras Apostólicas e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas (ou seja, a aprovação estatal dos aludidos documentos para a vigência interna, não existindo mais nos termos do art. 102, XIV, da Constituição de 1824).

Ainda, em igual sentido, o fato de o Estado ter-se separado da Igreja determinou a extinção do **recurso à Coroa** para atacar as decisões dos Tribunais Eclesiásticos.

■ **Organização dos “Poderes”:** o Poder Moderador foi extinto, adotando-se a teoria clássica de Montesquieu da tripartição de “Poderes”. Nesses termos, o art. 15 da Constituição de 1891 estabeleceu: “são órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si”.

■ **Poder Legislativo:** o Poder Legislativo federal era exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, sendo este composto por dois “ramos”, ou Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Fixava-se, assim, o **“bicameralismo federativo”**.

A Câmara dos Deputados era composta de representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante **sufrágio direto**, garantida a representação da minoria. Cada Deputado exercia mandato de **3 anos**.

Já o Senado Federal representava os Estados e o Distrito Federal, sendo eleitos 3 Senadores por Estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos do mesmo modo que os Deputados, para mandato de **9 anos**, renovando-se o Senado pelo terço trienalmente (ou seja, 1 a cada 3 anos, já que o mandato era de 9 anos e junto com as eleições para Deputados, que tinham mandato de 3 anos).

O Poder Legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. Alguns Estados, curiosamente, possuíam duas Casas, caracterizando-se, assim, a ideia de **bicameralismo estadual**, como podia ser percebido em São Paulo e Pernambuco, que tinham, além da Câmara dos Deputados (Estaduais), um Senado Estadual.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação, era eleito junto com o Vice-Presidente por **sufrágio direto** da Nação, para mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente.

Cabe alertar, contudo, nos termos do art. 1.º das Disposições Transitórias da Constituição de 1891, muito embora a previsão e conquista das **eleições diretas**, que a primeira eleição da República foi **indireta**, pelo Congresso Nacional, elegendo-se o Presidente *Marechal Deodoro da Fonseca* e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil *Marechal Floriano Peixoto*.⁹³

O Presidente da República era auxiliado pelos Ministros de Estado, agentes de sua confiança que lhe subscreviam os atos e eram nomeados e exonerados livremente (*ad nutum*).

Interessante notar que alguns Estados designavam o seu Executivo local como “presidente”, enquanto outros, como “governador”. Assim, era possível perceber a figura de “presidentes estaduais” exercendo o Executivo local.

■ **Poder Judiciário:** o órgão máximo do Judiciário passou a chamar-se **Supremo Tribunal Federal**, composto de 15 “Juizes”. Estabeleceu-se a hipótese dos crimes de responsabilidade. Houve expressa previsão da garantia da vitaliciedade para os Juizes Federais (art. 57) e para os membros

do Supremo Tribunal Militar (art. 77, § 1.º). Para os Juízes Federais, houve expressa previsão da garantia da irredutibilidade de “vencimentos” (art. 57, § 1.º).

A **Justiça Federal** foi mantida na Constituição. Cabe mencionar que o **Decreto n. 848, de 11.10.1890**, por inspiração do modelo norte-americano da Constituição de 1787 (lembrando, ainda, o suíço de 1874 e o argentino, nos termos das Leis de 1882 e 1883), já havia criado a Justiça Federal no Brasil, exercida por um **Supremo Tribunal Federal** e por juízes inferiores intitulados **Juízes de Secção**.

■ **Constituição rígida:** nos termos do art. 90 previu-se um processo de alteração da Constituição mais árduo e mais solene do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Assim, perde sentido a anterior distinção que era feita no texto de 1824 entre norma material e formalmente constitucional. Estabeleceu-se, como cláusula pétrea, a **forma republicano-federativa** e a **igualdade da representação dos Estados no Senado**.

■ **Declaração de direitos:** a declaração de direitos foi aprimorada, abolindo-se a pena de galés (que já havia sido extinta pelo Dec. n. 774, de 20.09.1890),⁹⁴ a de banimento e a de morte, ressalvadas, neste último caso, as disposições da legislação militar em tempo de guerra.⁹⁵ Houve prevalência de proteção às clássicas liberdades privadas, civis e políticas, não se percebendo a previsão de direitos dos trabalhadores nos termos do que vai ser sentido no texto de 1934.

No tocante às **garantias constitucionais**, na Constituição de 1891 houve expressa previsão, pela primeira vez no constitucionalismo pátrio, do remédio constitucional do ***habeas corpus***.

Embora não prevista a garantia do *habeas corpus* no texto de 1824, cabe lembrar que o *Decreto n. 114, de 23.05.1821*, alvará de D. Pedro I, proibia prisões arbitrárias; a Constituição de 1824, por si, tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e vedou a prisão arbitrária; já a partir do *Código Criminal* de 16.12.1830 (arts. 183 a 188), passou-se a estabelecer a garantia do *habeas corpus*, regra prevista também no *Código de Processo Criminal de Primeira Instância*, Lei n. 127, de 29.11.1832 (arts. 340 a 345) e

no art. 18 da Lei n. 2.033, de 20.09.1871 (que assegurou a impetração também por estrangeiros).

Em 03.09.1926 foi editada Emenda n. 1 à Constituição de 1891, limitando a chamada “teoria (ou doutrina) brasileira do *habeas corpus*” e restringindo o remédio constitucional do *habeas corpus* exclusivamente à **liberdade de locomoção**.

■ **Reforma de 03.09.1926:** houve centralização do poder, restringindo a autonomia dos Estados. Segundo Celso Bastos, a Reforma de 1926 foi “... marcada por uma conotação nitidamente racionalista, autoritária, introduzindo alterações no instituto da intervenção da União nos Estados, no Poder Legislativo, no processo legislativo, no fortalecimento do Executivo, nos direitos e garantias individuais e na Justiça Federal”. Isso tudo vai diminuir a sua “longevidade”, especialmente em razão do movimento armado de 1930, que pôs fim ao período chamado de “Primeira República”.⁹⁶

■ 2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República

A chamada *República Velha* tem o seu fim com a *Revolução de 1930*, que instituiu o Governo Provisório nos termos do **Decreto n. 19.398, de 11.11.1930**, levando Getúlio Vargas ao poder.⁹⁷

Barroso aponta dois aspectos mais graves a ensejar a ruína da República Velha: o **domínio das oligarquias** e a **fraude eleitoral institucionalizada**. Lembra, ainda, a **grave crise econômico-financeira de 1929** (“Grande Depressão”), uma **pequena burguesia** em ascensão, o **Tenentismo** (movimento contra o regime oligárquico que dirigia o Brasil) e o surgimento de uma **classe operária** descontente em razão do processo de industrialização estimulado pela Primeira Guerra.⁹⁸

Um outro episódio também contribuiu para a mobilização da oposição em prol da Revolução de 30, qual seja, o **assassinato de João Pessoa**, em 26 de julho de 1930, que deflagrou o **movimento militar** iniciado no Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, em 1930 uma Junta Militar transfere o poder para um **Governo Provisório**, que o exerceria até a promulgação do texto de 1934, motivada (a promulgação do texto democrático) por alguns elementos de pressão e contestação aos métodos arbitrários empregados, como o marcante papel da *Revolução Constitucionalista de São Paulo*, de 9 de julho de 1932.⁹⁹

Nos termos do art. 1.º do Decreto n. 19.398/30, cabia ao Governo Provisório exercer, discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e atribuições não só do **Poder Executivo** como também do **Poder Legislativo**, até que, eleita a Assembleia Constituinte, se estabelecesse a reorganização constitucional do País.

O art. 2.º do aludido Decreto confirmava a dissolução do Congresso Nacional, das atuais Assembleias Legislativas dos Estados (sejam quais forem as suas denominações), Câmaras ou Assembleias Municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos Estados, nos Municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os que ainda o não tivessem sido de fato.

Foi nomeado um **interventor** para cada Estado, havendo controle, também, sobre os Municípios (art. 11).

A função legislativa, concentrada no Governo Provisório, como vimos, era exercida por **decretos** expedidos pelo Chefe do Governo e subscritos pelo Ministro respectivo (art. 17).

Como ponto positivo, em 1932 Getúlio Vargas decretou o importante **Código Eleitoral** (Dec. n. 21.076, de 24.02.1932), que instituiu a Justiça Eleitoral, trazendo, assim, garantias contra a política anterior, que “sepultou” a Primeira República, retirando a atribuição de proclamar os eleitos das assembleias políticas, e, ainda, adotou o **voto feminino**¹⁰⁰ e o **sufrágio universal, direto e secreto**.

Conforme visto, esse segundo Governo Provisório da República durou até o advento da Constituição de 1934, promulgada em 16.07.1934.

■ 2.6.5. Constituição de 1934

A crise econômica de 1929, consoante referido, bem como os diversos movimentos sociais por melhores condições de trabalho, sem dúvida, influenciaram a promulgação do texto de 1934, abalando, assim, os ideais do liberalismo econômico e da democracia liberal da Constituição de 1891.

Por isso é que a doutrina afirma, com tranquilidade, que o texto de 1934 sofreu forte influência da **Constituição de Weimar** da Alemanha de 1919, evidenciando, portanto, os **direitos humanos de 2.ª geração ou dimensão** e a perspectiva de um **Estado social de direito** (democracia social).

Há influência, também, do **fascismo**, já que o texto estabeleceu, o que se verá abaixo, além do voto direto para a escolha dos Deputados, a modalidade indireta, por intermédio da chamada **“representação classista”** do Parlamento.

Dentro do constitucionalismo pátrio, o texto de 1934 teve curtíssima duração, sendo abolido pelo golpe de 1937.

Foram mantidos alguns princípios fundamentais, como a República, a Federação, a tripartição de Poderes, o presidencialismo e o regime representativo, destacando-se as seguintes características:

■ **Forma de Governo e regime representativo:** nos termos do art. 1.º, a Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime **representativo**, a **República federativa** proclamada em 15 de novembro de 1889.

Os poderes da União foram consideravelmente aumentados, discriminando-se as rendas tributárias entre União, Estados e Municípios.

■ **Capital da República — Distrito Federal — tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** o Distrito Federal, administrado por um Prefeito, foi mantido, com sede na cidade do Rio de Janeiro, como Capital da República. Nos termos do art. 4.º das disposições transitórias, havia a previsão de transferência da Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que a Constituição entrasse em vigor, nomearia uma Comissão que, sob instruções do Governo, procederia a estudos de várias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos

tais estudos, os resultados seriam apresentados à Câmara dos Deputados, que escolheria o local e tomaria, sem perda de tempo, as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o **Distrito Federal** passaria a constituir um **Estado**.

Nos termos do art. 5.º, XVI, a União editou a Lei n. 196, de 18.01.1936, a segunda Lei Orgânica do Distrito Federal, fixando amplo regime de autonomia para o DF, elevando-o à condição de **“supermunicípio”**, conforme o art. 1.º da referida lei, que o aproximava dos Estados, nos seguintes termos: “o atual Distrito Federal tem **autonomia equivalente à dos Estados**, ressalvadas as limitações decorrentes aos preceitos da Constituição Federal”.

■ **Mantida a inexistência de religião oficial:** o País continua leigo, laico ou não confessional, sendo inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costumes.

Amenizando o “sentimento” antirreligião do texto de 1891, na dicção do art. 146, passou-se a admitir o **casamento religioso com efeitos civis**, nos seguintes termos: “o casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil”. Ainda, segundo o art. 153, **facultou-se o ensino religioso nas escolas públicas**.

Finalmente, destaca-se a previsão de **“Deus”** no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica de Montesquieu da tripartição de “Poderes” foi mantida. De acordo com o art. 3.º, são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.

■ **Poder Legislativo:** era exercido pela Câmara dos Deputados com a **colaboração** do Senado Federal. Rompia-se, assim, com o princípio do **bicameralismo rígido** ou **paritário**, no qual as duas Casas exercem funções básicas idênticas. Estabelecia-se, por consequência, um **bicameralismo desigual**, também chamado pela doutrina de **unicameralismo imperfeito**, já que, como visto, o SF era mero colaborador da CD.¹⁰¹

O mandato dos Deputados era de 4 anos. A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos mediante **sistema proporcional** e **sufrágio universal**, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicasse (**representação corporativa de influência fascista**).¹⁰²

Já em relação ao **Senado Federal**, nos termos do art. 41, § 3.º, a competência legislativa se reduzia às matérias relacionadas à Federação, como a iniciativa das leis sobre a intervenção federal e, em geral, das que interessassem determinadamente a um ou mais Estados.

Conforme o art. 89, o Senado Federal era composto de dois representantes de cada Estado e o do Distrito Federal, eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto, por **8 anos**, dentre brasileiros natos, alistados eleitores e maiores de 35 anos, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado, renovava-se pela metade, conjuntamente com a eleição da Câmara dos Deputados.

Por fim, dispunha o art. 88 que cabia ao Senado Federal, conforme os arts. 90, 91 e 92, a incumbência de promover a coordenação dos Poderes federais entre si,¹⁰³ manter a continuidade administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos de sua competência.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o vice por sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos para mandato de 4 anos, vedada a reeleição. O Presidente da República seria auxiliado pelos Ministros de Estado, que passaram a ter responsabilidade pessoal e solidária com o Presidente.

■ **Poder Judiciário:** foram estabelecidos como órgãos do Poder Judiciário: a) a Corte Suprema; b) os Juízes e Tribunais federais; c) os Juízes e Tribunais militares; d) os Juízes e Tribunais eleitorais, estabelecendo-se aos juízes as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de “vencimentos”. A Corte Suprema, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, compunha-se de 11 Ministros.

■ **Constituição rígida:** nos termos do art. 178, *caput*, “a Constituição poderá ser emendada, quando as alterações propostas não modificarem a estrutura política do Estado (arts. 1.º a 14, 17 a 21); a organização ou a competência dos poderes da soberania (Capítulos II, III e IV do Título I; o Capítulo V do Título I; o Título II; o Título III; e os arts. 175, 177, 181, este mesmo art. 178); e revista, no caso contrário”. O art. 178, § 5.º, fixou, como cláusula pétrea, a forma republicana federativa.

■ **Declaração de direitos:** nos termos do art. 108, constitucionaliza-se o **voto feminino**, com valor igual ao masculino, conforme já havia sido previsto no art. 2.º do Código Eleitoral de 1932 (Dec. n. 21.076, de 24.02.1932). Outra garantia foi a constitucionalização do **voto secreto** (também chamado de “**voto australiano**” por ter surgido, pela primeira vez, na Austrália, em 1856), que já havia sido assegurada pelo Código Eleitoral de 1932.

Vários direitos clássicos são mantidos. Inovando, em razão do caráter social da Constituição, são destacados novos títulos, como o da ordem econômica e social (Título IV), da família, educação e cultura (Título V) e da segurança nacional (Título VI).

Prestigiam-se, assim, a legislação trabalhista e a representação classista.

Dentre as novidades dos remédios constitucionais, destacamos a previsão, pela primeira vez, do **mandado de segurança** (art. 113, n. 33) e da **ação popular** (art. 113, n. 38).¹⁰⁴

■ 2.6.6. Constituição de 1937

Getúlio Vargas foi eleito e empossado para governar de 1934 até 1938. Contudo, durante esse período, um forte antagonismo foi percebido entre a **direita fascista** de um lado (em especial a *Ação Integralista Brasileira — AIB*), defendendo um Estado **autoritário**, e o **movimento de esquerda** de outro, destacando ideais socialistas, comunistas e sindicais (em especial a formação, em 1935, da *Aliança Nacional Libertadora — ANL*).

■ direita fascista	X	■ movimento de esquerda
■ Estado autoritário		■ ideais socialistas, comunistas e sindicais
■ <i>Ação Integralista Brasileira — AIB</i>		■ <i>Aliança Nacional Libertadora — ANL</i>

Em 11 de julho de 1935, o Governo fechou a Aliança Nacional Libertadora — ANL, considerando-a ilegal com base na “Lei de Segurança Nacional”, cujo estopim da crise foi o manifesto lançado por Luís Carlos Prestes.

Em razão da **Intentona Comunista** (novembro de 1935 — Natal, Recife e Rio de Janeiro — insurreição político-militar que contava com o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de ex-tenentes — agora militares comunistas —, e que tinha o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e instalar o socialismo no Brasil), o **estado de sítio** foi decretado pelo Governo e se deflagrou um forte movimento de repressão ao comunismo, inclusive com o apoio da famigerada “Polícia Especial”.

Getúlio Vargas e o Governo tiveram o apoio do Congresso Nacional, que decretou o **“estado de guerra”**.

Em 30 de setembro de 1937, os jornais noticiaram que o Estado-Maior do Exército havia descoberto um plano comunista para a tomada do Poder (**“Plano Cohen”**). Este foi o “estopim” para que o Governo decretasse o golpe como suposta “salvação” contra o comunismo que parecia “assolar” o País.

Tendo o apoio dos Generais Góis Monteiro (Chefe do Estado-Maior do Exército) e Eurico Gaspar Dutra (Ministro da Guerra), bem como diante de uma nova decretação de “estado de guerra” pelo Congresso Nacional, em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas dá o golpe ditatorial, centralizando o poder e fechando o Congresso Nacional.

Era o início do que **Vargas** intitulou de “**nascer da nova era**”, outorgando-se a Constituição de 1937, influenciada por ideais **autoritários** e **fascistas**, instalando a **ditadura** (“Estado Novo”), que só teria fim com a redemocratização pelo texto de 1945, e se declarando, em todo o País, o **estado de emergência**.

A **Carta de 1937**, elaborada por **Francisco Campos**, foi apelidada de “**Polaca**” em razão da influência sofrida pela Constituição polonesa fascista de 1935, imposta pelo *Marechal Josef Pilsudski*. Deveria ter sido submetida a plebiscito nacional, nos termos de seu art. 187, o que nunca aconteceu.

Além de fechar o Parlamento, o Governo manteve amplo domínio do Judiciário. A Federação foi abalada pela nomeação dos interventores. Os direitos fundamentais foram enfraquecidos, sobretudo em razão da atividade desenvolvida pela “Polícia Especial” e pelo “DIP — Departamento de Imprensa e Propaganda”. Para piorar, pelo Decreto-Lei n. 37, de 02.12.1937, os partidos políticos foram dissolvidos.

Apesar do regime extremamente autoritário, na medida em que o Estado, centralizador, atuava diretamente na economia, não se pode negar o seu importante crescimento nesse setor.

Buscando atrair o apoio popular, a política desenvolvida foi denominada “populista”, consolidando-se as Leis do Trabalho (CLT) e importantes direitos sociais, como o salário mínimo.

Algumas características, então, podem ser esquematizadas:

■ **Forma de Governo:** nos termos do art. 1.º, o Brasil é uma **República**. O poder político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, de sua honra, de sua independência e de sua prosperidade.

■ **Forma de Estado:** o Brasil é um Estado **federal**, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.

Na prática, contudo, as autonomias estaduais foram reduzidas, e podemos dizer que o regime federativo foi simplesmente “**nominal**”, havendo constante, senão até permanente, assunção dos governos estaduais por interventores federais. Por sua vez, os vereadores e prefeitos eram nomeados pelos interventores de cada Estado.

■ **Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro:** nos termos do art. 7.º, o Distrito Federal, que continuou como capital federal, como sede do Governo da República, era administrado pela União. Explicitando, de acordo com o art. 30, o Distrito Federal era administrado por Prefeito nomeado pelo Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal, e demissível *ad nutum*, cabendo as funções deliberativas ao Conselho Federal.

■ **Não há mais religião oficial:** continuava o Brasil como país leigo, laico ou não confessional, não havendo, contudo, a invocação da “proteção de Deus” no preâmbulo da Constituição.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi *formalmente* mantida. Entretanto, na prática, tendo em vista o forte traço autoritário do regime, o Legislativo e o Judiciário foram “esvaziados”.

■ **Poder Legislativo:** de acordo com o art. 38, o Poder Legislativo seria exercido pelo **Parlamento Nacional** com a colaboração do **Conselho da Economia Nacional** e do **Presidente da República**.

Havia a previsão de composição do Parlamento Nacional por duas Câmaras: a **Câmara dos Deputados** e o **Conselho Federal**. Como se percebe, o **Senado Federal deixou de existir durante o Estado Novo**.

A Câmara dos Deputados seria composta de representantes do povo, eleitos mediante **sufrágio indireto** para mandato de 4 anos. Já o Conselho Federal seria composto de representantes dos Estados e 10 membros

nomeados pelo Presidente da República. A duração do mandato era de 6 anos.

Cabe alertar, no entanto, que, segundo o art. 178, foram **dissolvidos** a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais, marcando-se eleições futuras para o novo Parlamento. Enquanto não se reunisse o Parlamento nacional, o Presidente da República tinha o poder de expedir **decretos-leis** sobre todas as matérias da competência legislativa da União. Na prática, o Legislativo nunca chegou a se instalar.

■ **Poder Executivo:** na dicção do art. 73, o Presidente da República, **autoridade suprema do Estado**, coordenava a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirigia a política interna e externa, promovia ou orientava a política legislativa de interesse nacional, e superintendia a administração do País.

A **eleição indireta** foi estabelecida para a escolha do Presidente da República, que cumpriria mandato de 6 anos.

■ **Poder Judiciário:** eram órgãos do Poder Judiciário (art. 90): *a)* o Supremo Tribunal Federal; *b)* os Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; *c)* os Juízes e Tribunais militares. A Justiça Eleitoral foi extinta e, conforme já visto, também os partidos políticos.

O Judiciário, contudo, foi **“esvaziado”**. Como exemplo, nos termos do art. 96, parágrafo único, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, fosse necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmasse por 2/3 dos votos em cada uma das Câmaras, **ficaria sem efeito a decisão do Tribunal**.

Outra demonstração de “força” do poder central está no art. 170, ao estabelecer que, durante o estado de emergência ou o estado de guerra, os atos praticados em virtude deles não poderiam ser conhecidos por qualquer Juiz ou Tribunal.

■ **Declaração de direitos:** não houve previsão do mandado de segurança nem da ação popular. Não se tratou dos princípios da irretroatividade das leis e da reserva legal. O direito de manifestação do pensamento foi restringido, pois previa o art. 122, n. 15, “a”, que, com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a **censura prévia** da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão podia ser exercida, facultando-se à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação.

Nenhum jornal poderia recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei (art. 122, n. 15, “b”).

Segundo o art. 122, n. 13 (e em sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 1, de 16.05.1938), além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a **pena de morte** poderia ser aplicada para **crimes políticos** e nas hipóteses de **homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade**.

Nos termos do art. 177, que vigorou durante todo o Estado Novo, embora o seu prazo inicial tenha sido limitado a 60 dias (tendo em vista a faculdade trazida pela Lei Constitucional n. 2, de 16.05.1938), o Governo poderia **aposentar** ou **reformar**, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impusesse a juízo exclusivo do “Governo”, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime.

Foi declarado o **estado de emergência** (art. 186), que, suspendendo direitos e garantias individuais, só veio a ser revogado pela Lei n. 16, de 30.11.1945.

A **greve** e o **lock-out** foram **proibidos**, tendo sido declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139).

O art. 173, na sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 7, de 30.09.1942, estabeleceu a possibilidade de declarar o **“estado de guerra”**, com restrição a direitos fundamentais e, ainda, o julgamento de crimes cometidos contra a **estrutura das instituições**, a **segurança do Estado** e dos

cidadãos pela Justiça Militar ou pelo **Tribunal de Segurança Nacional**. Este último só veio a ser extinto pela Lei Constitucional n. 14, de 17.09.1945.

A **tortura** foi utilizada como instrumento de repressão, situação essa simbolizada pela entrega de Olga Benário, mulher de Luís Carlos Prestes, líder comunista no Brasil, que viria a ser assassinada em campo de concentração nazista na Alemanha.

■ **Nacionalização formal da economia e conquista de direitos e vantagens trabalhistas:** muito embora essa “triste” realidade ditatorial, durante o período houve inegável “nacionalização formal da economia”, bem como “controle sobre certas áreas estratégicas de produção, como mineração, aço e petróleo”, configurando, assim, importante “expansão capitalista”.¹⁰⁵

Podemos citar as seguintes estatais criadas durante o período: Companhia Vale do Rio Doce (1942), Companhia Nacional de Álcalis (1943), Fábrica Nacional de Motores (1943) e Companhia Hidroelétrica do São Francisco (1945).

Também tivemos avanços no campo trabalhista. Contudo, como anota Barroso, nesse contexto, “... a Constituição não desempenhou papel algum, substituída pelo mando personalista, intuitivo, autoritário. Governo de fato, de suporte policial e militar, sem submissão sequer formal à Lei maior, que não teve vigência efetiva, salvo quanto aos dispositivos que outorgavam ao chefe do Executivo poderes excepcionais”.¹⁰⁶

■ 2.6.7. Constituição de 1946

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Governo brasileiro declarou ofensiva contra os países do **“Eixo”** (destacando-se como principais potências a Alemanha, a Itália e o Japão), entrando no confronto ao lado dos **“Aliados”** (destacando-se como principais potências a China, a França, a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos). Como marco histórico, em 1943, ressaltamos a criação da **FEB — Força Expedicionária Brasileira**.

A entrada na Guerra fez com que Vargas perdesse importante apoio, situação essa materializada na publicação, em 24 de outubro de 1943, do **Manifesto dos Mineiros**, carta assinada por intelectuais que apontava a contradição entre a política interna e a externa.

Isso porque, ao aderir à Guerra ao lado dos “Aliados”, buscando enfrentar as ditaduras nazifascistas de Mussolini e Hitler (países do “Eixo”), parecia natural que o fascismo fosse “varrido” da realidade brasileira, não se sustentando, internamente, a contradição de manter um Estado arbitrário com base em uma Constituição inspirada no modelo fascista e externamente lutar contra esse regime.

Outros documentos, na mesma linha do *Manifesto dos Mineiros*, foram assinados. Essa crise política forçou Vargas a assinar o **Ato Adicional** em 1945 (Lei Constitucional n. 9, de 28.02.1945), convocando eleições presidenciais e marcando a derrocada final do “Estado Novo”.

Durante a campanha eleitoral, surge o movimento chamado **“queremismo”**, que significava “Queremos Getúlio”, e tudo levava a crer, especialmente com o apoio do partido comunista, agora legalizado, que Getúlio iria continuar e, eventualmente, até dar um novo golpe.

Em 29 de outubro de 1945, Vargas tentou substituir o chefe de Polícia do Distrito Federal por seu irmão, Benjamin Vargas. Além disso, nomeou João Alberto para Prefeito do Rio de Janeiro, fatos que precipitariam o fim do Estado Novo, já que davam a entender a vontade de Vargas continuar no Poder.

Esses fatos culminaram com a “expulsão” de **Vargas** do poder pelos Generais Gaspar Dutra e Góis Monteiro, sendo, assim, **deposto pelas Forças Armadas**.

Convocado pelas Forças Armadas, o Executivo passou a ser exercido pelo então **Presidente do STF**, *Ministro José Linhares*, que governou de 29.10.1945 a 31.01.1946, até assumir, eleito pelo **voto direto** e com mais de 55% de aprovação dos eleitores, o *General Gaspar Dutra* como o novo Presidente da República.

José Linhares praticou importantes atos, como: **a)** a revogação do art. 177 (que permitia a aposentadoria ou reforma compulsórias, a exclusivo juízo do Governo, de funcionários civis e militares); **b)** a extinção do *Tribunal de Segurança Nacional*; **c)** a revogação do *estado de emergência*; **d)** a extinção do *Conselho de Economia Nacional*; **e)** a abolição da regra que permitia o esvaziamento da efetividade das decisões do STF em controle de constitucionalidade (art. 96, parágrafo único).

A Lei Constitucional n. 13, de 12.11.1945, atribuiu **poderes constituintes** ao Parlamento que seria eleito em 02.12.1945 para a elaboração da nova Constituição do Brasil.

A Assembleia Constituinte foi instalada em 1.º.02.1946, vindo o texto a ser **promulgado** em 18.09.1946. Tratava-se da **redemocratização do País**, repudiando-se o Estado totalitário que vigia desde 1930.

O texto inspirou-se nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da de 1934. Na ordem econômica, procurou harmonizar o princípio da livre-iniciativa com o da justiça social.

■ **Forma de Governo Republicana e Forma de Estado Federativa:** nos termos do art. 1.º, os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República. Prestigiam o municipalismo.

■ **Capital da União:** o Distrito Federal continuou como a Capital da União e na área geográfica do antigo Município Neutro (a cidade do Rio de Janeiro).

Cabe lembrar, contudo, a previsão do art. 4.º, ADCT: a Capital da União será **transferida** para o planalto central do País. Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em 60 dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital. O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União. Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da Capital. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o **Estado da Guanabara**.

Como se sabe, cumprindo o “Plano de Metas” (“50 anos em 5”), *Juscelino Kubitschek*, além de suas importantes realizações econômicas, implementa a construção de **Brasília**, inaugurada em **21 de abril de 1960**. Nessa data, conforme mandamento estabelecido na Constituição, o então Distrito Federal é transformado no **Estado da Guanabara**, com os mesmos limites geográficos, tendo por capital e sede do Governo a cidade do Rio de Janeiro (cf. **Lei n. 3.752/60**, conhecida como *Lei San Tiago Dantas*, deputado federal encarregado de elaborar o projeto de criação do novo Estado, que ditou normas para a convocação da Assembleia Constituinte).

A título de curiosidade, o Estado da Guanabara não foi dividido em municípios, decisão essa que encontrou apoio popular no **plebiscito** realizado em 21 de abril de 1963, além de ter curta duração (1960-1975). Por força do art. 8.º da **LC n. 20/74**, a partir de 15.03.1975, os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passaram a constituir um único Estado (fusão), sob a denominação de **Estado do Rio de Janeiro**, sendo a cidade do Rio de Janeiro a Capital.

■ **Inexistência de religião oficial:** continuou o País leigo, muito embora a expressa menção a “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi restabelecida.

■ **Poder Legislativo:** consoante previa o art. 37, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, reaparecendo o bicameralismo igual.

A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos, segundo o sistema de representação proporcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territórios, para mandato de 4 anos.

O Senado Federal, por sua vez, compunha-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário e para mandato de 8 anos. Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegia 3 Senadores, renovando-se a representação de cada Estado e a do Distrito Federal de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.

Nos termos do art. 61, as funções de Presidente do Senado Federal eram exercidas pelo **Vice-Presidente da República**.

Nos termos do art. 141, § 13, constitucionalizaram-se os Partidos Políticos, sendo vedada a organização, o registro ou o seu funcionamento nas hipóteses em que o programa ou a ação contrariassem o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.

■ **Poder Executivo:** retomando a normalidade democrática, o Presidente da República deveria ser eleito de **forma direta** para mandato de **5 anos**, junto com o vice, que, como visto, acumulava a função de Presidente do Senado Federal.

■ **Poder Judiciário:** foi retomada a situação de normalidade.

O Poder Judiciário era exercido pelos seguintes órgãos: a) Supremo Tribunal Federal; b) Tribunal Federal de Recursos; c) Juízes e Tribunais militares; d) Juízes e Tribunais eleitorais; e) Juízes e Tribunais do trabalho.

■ **Declaração de direitos:** o mandado de segurança e a ação popular foram restabelecidos no texto constitucional.

O art. 141, § 4.º, consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ao estabelecer que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito *individual*”.

Conforme referido, passa-se, pela primeira vez, a prever regras para os partidos políticos (art. 141, § 13).

Pelo art. 141, § 31, **vedou-se**, caracterizando o cunho humanitário, a **pena de morte** (salvo as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro), a de **banimento**, a de **confisco** e a de **caráter perpétuo**.

Nos termos do art. 158, foi **reconhecido** o **direito de greve**. As várias garantias dos trabalhadores já conquistadas durante o “Estado Novo” foram mantidas, marcando importante “degrau” na evolução social do País.

■ **Instituição do parlamentarismo:** perdendo o apoio político, tanto do centro como da direita, o Presidente Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, encaminhando carta ao Congresso Nacional pela qual afirmava que teria sido pressionado por “forças ocultas terríveis”.

O Vice-Presidente João Goulart (Jango) estava na China e, assim, as Forças Armadas tentaram impedir o seu retorno, tendo em vista o receio com suas ligações comunistas.

Não aceitando o inconstitucional afastamento de Jango, o Congresso Nacional, tentando ser conservador, aprovou, em 02.09.1961, o regime parlamentarista (que também já havia sido experimentado durante o Império).

A grande novidade era a dualidade do Executivo, exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a estes a responsabilidade política do Governo. Conforme o art. 3.º, I, EC n. 4/61, o Presidente da República nomeava o Primeiro-Ministro, que, por sua vez, escolhia os demais Ministros a serem nomeados pelo Presidente da República.

Feito o **referendo**, em 06.01.1963, o povo determinou o retorno imediato ao presidencialismo, conforme será estudado no *item 17.1.2.1*, que remanesceria até a Revolução Militar de 1964.

■ 2.6.8. Golpe Militar de 1964

Jango foi derrubado por um movimento militar que eclodiu em 31.03.1964, tendo sido acusado de estar a serviço do “comunismo internacional”. Instalava-se, assim, uma nova “ordem revolucionária” no País.

O General *Costa e Silva*, o Brigadeiro *Francisco Correia de Melo* e o Almirante *Augusto Rademaker*, militares vitoriosos, constituíram o chamado *Supremo Comando da Revolução* e, em 09.04.1964, baixaram o Ato Institucional n. 1, de autoria de Francisco Campos (o mesmo que elaborou a Carta de 1937), com muitas restrições à democracia: **a)** o Comando da

Revolução poderia decretar o estado de sítio (art. 6.º); **b)** conferia-se o poder de aposentar civis ou militares (art. 7.º); **c)** sem as limitações previstas na Constituição estabelecia-se a possibilidade de suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluía a apreciação judicial desses atos etc. (art. 10).

O AI 2/65, após ter estabelecido **eleições indiretas** para Presidente e Vice-Presidente da República, foi seguido pelo de n. 3, que também as estabeleceu em âmbito estadual.

O Congresso Nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto, posteriormente, nos termos do AI 4/66 para aprovar a Constituição de 1967.

Alguns autores entendem que o texto de 1967 teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art. 1.º, § 1.º, do AI 4/66. Contudo, em razão do “autoritarismo” implantado pelo *Comando Militar da Revolução*, não possuindo o Congresso Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado que se instaurava, preferimos dizer que o texto de 1967 foi **outorgado** unilateralmente (apesar de formalmente votado, aprovado e “promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.

Em conclusão, pode-se afirmar que a Constituição de 1946 foi suplantada pelo Golpe Militar de 1964. Embora continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e Complementares,¹⁰⁷ com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e “drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil.

■ 2.6.9. Constituição de 1967

Na mesma linha da Carta de 1937, a de 1967 concentrou, bruscamente, o poder no âmbito federal, esvaziando os Estados e Municípios e conferindo amplos poderes ao Presidente da República. Houve forte preocupação com a **segurança nacional**. Algumas características podem ser destacadas:

■ **Forma de Governo:** República.

■ **Forma de Estado:** muito embora o art. 1.º estabelecesse ser o Brasil uma República **Federativa**, constituída, sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, na prática, o que se percebeu foi um **duro “golpe” no federalismo**, mais se aproximando de um Estado unitário centralizado do que federativo.

■ **Capital da União:** nos termos do art. 2.º, o **Distrito Federal** permaneceu como a Capital da União, lembrando que os Poderes da República já haviam sido transferidos para Brasília, no **Planalto Central do País**, inaugurada em 21 de abril de 1960.

■ **Inexistência de religião oficial:** continuou o Brasil a ser um país leigo, embora houvesse a expressa menção a “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi formalmente mantida. Anota Celso Bastos, acertadamente, que, apesar da previsão da tripartição de Poderes, “... no fundo existia um só, que era o Executivo, visto que a situação reinante tornava por demais mesquinhas as competências tanto do Legislativo quanto do Judiciário...”.¹⁰⁸

■ **Poder Legislativo:** a teor do art. 29, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, que se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados era formada por representantes do povo, eleitos por voto direto e secreto, em cada Estado e Território e para mandato de 4 anos. O Senado Federal compunha-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário. Cada Estado elegia 3 Senadores, com mandato de 8 anos, renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.

Na prática, contudo, como visto, o Legislativo teve a sua competência diminuída.

Além disso fortaleceu-se a representação dos Deputados nos Estados menores: “o número de Deputados será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para cada trezentos mil habitantes, até vinte e cinco

Deputados, e, além desse limite, um para cada milhão de habitantes” (art. 41, § 2.º).

■ **Poder Executivo:** fortalecido, era eleito para mandato de 4 anos, de maneira **indireta** por sufrágio do Colégio Eleitoral, composto pelos membros do Congresso Nacional e de Delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados, em sessão pública e mediante votação nominal.

O Presidente da República legislava por **decretos-leis**, que poderiam ser editados em casos de *urgência* ou de *interesse público relevante*, e desde que não resultassem em aumento de despesa sobre as seguintes matérias: *a)* segurança nacional; *b)* finanças públicas.

O art. 58, parágrafo único, previa a criticada **aprovação por decurso de prazo** do decreto-lei, já que, publicado o texto, que tinha vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovava ou o rejeitava, dentro de 60 dias, não podendo emendá-lo. Se, porém, nesse prazo não houvesse deliberação, o texto seria tido como aprovado.

Nos termos do art. 60, estrategicamente, estabeleceu-se a **iniciativa exclusiva** do Presidente da República para certas matérias, ou seja, só ele poderia deflagrar (dar início) o processo legislativo.

■ **Poder Judiciário:** o Poder Judiciário da União era exercido pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal; Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes do Trabalho. Havia previsão da Justiça Estadual. Em razão do centralismo, o Judiciário também teve a sua competência diminuída.

■ **Declaração de direitos:** havia exagerada possibilidade de suspensão de direitos políticos por 10 anos (art. 151).

Houve a previsão de se tornar perdida a propriedade para fins de reforma agrária, mediante o pagamento de indenização com títulos da dívida pública.

Os direitos dos trabalhadores foram definidos com maior eficácia.

■ **Sistema tributário:** conforme anota Celso Bastos, “... o Sistema Tributário Nacional, que há pouco sofrera uma modificação, por meio da Emenda Constitucional n. 18 à Constituição de 1946, foi em princípio mantido. Contudo, a discriminação de rendas, ampliando a técnica do **federalismo cooperativo**, acabou por permitir uma série de participações de uma entidade na receita da outra, com acentuada centralização. Quanto à matéria orçamentária aparecem o orçamento-programa, os programas plurianuais de investimento, além da própria atualização do sistema orçamentário” (grifamos).¹⁰⁹

■ **AI-5, de 13.12.1968:** o AI-5, o famigerado e mais violento ato baixado pela ditadura, perduraria até a sua revogação pela EC n. 11, de 17.10.1978, fixando as seguintes “atrocidades”,¹¹⁰ nos termos de sua ementa:

- a) formalmente, foram mantidas a Constituição de 24.01.1967 e as Constituições Estaduais, com as modificações constantes do AI-5;
- b) o Presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando a funcionar quando convocados seus membros pelo Presidente da República;
- c) o Presidente da República, no interesse nacional, poderia decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição;
- d) os direitos políticos de quaisquer cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais;
- e) ficaram suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo;
- f) o Presidente da República, em quaisquer dos casos previstos na Constituição, poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo;

- g) o Presidente da República poderia, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tivessem enriquecido ilicitamente, no exercício do cargo ou função;
- h) suspendeu-se a garantia de *habeas corpus*, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular (art. 10 do AI-5);
- i) finalmente, a triste previsão do art. 11 do AI-5: “excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos”.

No mesmo dia em que o AI-5 foi baixado por *Costa e Silva*, o **Congresso Nacional** foi **fechado**, nos termos do Ato Complementar n. 38, de 13.12.1968, situação essa que perdurou por mais de 10 meses.

■ 2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969

A EC n. 1/69 não foi subscrita pelo Presidente da República Costa e Silva (15.03.1967 a 31.08.1969), impossibilitado de governar por sérios problemas de saúde, nem, “estranhamente”, pelo Vice-Presidente Pedro Aleixo, um civil.

Com base no AI 12, de 31.08.1969, consagrou-se no Brasil um governo de **“Juntas Militares”**, uma vez que referido ato permitia que, enquanto Costa e Silva estivesse afastado por motivos de saúde, governassem os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Nesse sentido, e com “suposto” fundamento, é que a EC n. 1/69 foi baixada pelos Militares, já que o Congresso Nacional estava fechado.¹¹¹

Sem dúvida, dado o seu caráter revolucionário, podemos considerar a EC n. 1/69 como a manifestação de um novo **poder constituinte originário**, outorgando uma nova Carta, que “constitucionalizava” a utilização dos Atos Institucionais. Nos termos de seu art. 182, manteve em vigor o AI-5 e todos

os demais atos baixados. O mandato do Presidente foi aumentado para **5 anos**, continuando a eleição a ser **indireta**.

Durante o governo do General Emílio Médici (30.10.1969 a 15.03.1974), o País experimentou o denominado **“milagre econômico”**,¹¹² que trouxe uma pequena ilusão de pontos positivos ao novo regime (extremamente duro e autoritário, deixe-se bem claro).

Logo em seguida, do ponto de vista econômico, o governo de Ernesto Geisel (15.03.1974 a 15.03.1979) foi marcado por **forte inflação** e **grave crise econômica** (sobretudo em razão do petróleo). O governo perdia força e temia a oposição, especialmente após a derrota nas eleições legislativas de novembro de 1974.

Nesse contexto, o governo baixou a **Lei Falcão** (Lei n. 6.339, de 1.º.07.1976, assim apelidada já que *Armando Ribeiro Falcão* era o Ministro da Justiça que referendava o ato), reduzindo a propaganda política e, portanto, prejudicando a oposição.

O Presidente Geisel baixou, também, o **Pacote de Abril de 1977**, dissolvendo o Congresso Nacional e editando 14 emendas e 6 decretos, destacando-se as seguintes medidas:

- a)** redução do *quorum* para aprovação de EC de 2/3 para maioria absoluta, **flexibilizando**, assim, a teórica rigidez constitucional;
- b)** estabelecimento da **avocatória**, conforme o previsto no art. 119, I, “o”, EC n. 1/69, introduzido pela EC n. 7/77: “as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais, cuja avocação deferir a pedido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido”;¹¹³
- c)** um terço dos Senadores passou a ser “eleito” pelas Assembleias Legislativas, ou melhor, pelo Colégio Eleitoral estadual, nos termos do art. 41, § 2.º, na redação conferida pela EC n. 8/77. Como a ARENA (partido governamental) detinha a maioria (com a exceção do Estado da

Guanabara, no qual saiu vitorioso o MDB), na prática se presenciou uma esquisita “nomeação” dos Senadores (já que a ARENA detinha a maioria nos Estados), que, ironicamente, foram apelidados pela população de **Senadores biônicos**;

d) aumento do mandato do Presidente da República de 5 (EC n. 1/69) para **6 anos** (EC n. 8/77);

e) manutenção da regra da **proporcionalidade** para a eleição de Deputados o que beneficiava os Estados menores, nos quais, supostamente, o governo teria maior controle.

Em seguida, tivemos o **pacote de junho de 1978**, destacando-se:

a) a revogação total ao AI-5;

b) a suspensão das medidas que, com base no AI-5, cassaram direitos políticos;

c) a previsão de impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo Presidente da República, eliminando, assim, alguns poderes presidenciais.

Era o início de um processo de redemocratização¹¹⁴ que viria a ganhar força durante a presidência de João Figueiredo (15.03.1979 a 15.03.1985 — mandato de **6 anos**, conforme a EC n. 8/77), que por sua vez teve a missão de pôr fim ao governo militar.

■ **Lei da Anistia (Lei n. 6.683, de 28.08.1979)**: foi concedida a anistia para todos que, no período compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao Poder Público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. Nesse particular, cabe destacar que o STF, em 29.04.2010, no julgamento da **ADPF 153**, rejeitou o pedido de revisão da referida “Lei

da Anistia” (cf. discussão sobre este assunto e a punição do Brasil pela *Corte Interamericana dos Direitos Humanos* no item 21.4.2).

■ **Reforma Partidária — Lei n. 6.767, de 20.12.1979:** ao modificar dispositivos da Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), a teor do art. 152 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional n. 11/78, trouxe a importante novidade de pôr fim ao bipartidarismo (ARENA v. MDB), regulamentando o **pluripartidarismo partidário**. A ARENA passou a chamar-se PDS (Partido Democrático Social), e do MDB estabeleceram-se cinco partidos novos: PMDB, PP, PT, PDT e PTB.

■ **EC n. 15, de 21.11.1980 — eleições diretas em âmbito estadual:** em 1982, tivemos importante marco histórico, qual seja, a **eleição direta** para Governadores de Estado em razão da alteração trazida pela EC n. 15/80. O PDS ganhou em 12 Estados, o PMDB, em 10, e o PDT, em 1.

■ **“Diretas Já”:** em 18.04.1983, o então Deputado Federal Dante de Oliveira apresentou a PEC n. 5/83, propondo **eleição direta** para Presidente e Vice-Presidente da República. A PEC ganhou o apoio popular e se transformou no importante movimento que ficou conhecido como “Diretas Já”. Apesar da pressão da sociedade civil, em 25.04.1984, a denominada **“PEC Dante de Oliveira”** foi rejeitada. Diante dessa situação, o Colégio Eleitoral acabou elegendo, em 15.01.1985, embora pelo **voto indireto**, pela primeira vez, após mais de 20 anos de ditadura militar, um civil — o que caracterizou o fim do regime militar —, **Tancredo Neves**, mineiro de São João Del Rei, que prometeu estabelecer a “Nova República”, democrática e social.

Sua posse estava marcada para o dia 15.02.1985, mas Tancredo Neves adoeceu gravemente na véspera, não tomou posse e veio a falecer, para tristeza e comoção do País, no dia 21.04.1985. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa — José Sarney (15.03.1985 a 15.03.1990), o Vice-Presidente, assumiu a presidência com importante particularidade: era o primeiro governo civil após o movimento militar de 1964.

Embora não tenha tomado posse em razão de sua enfermidade, a **Lei n. 7.465/86** incluiu o nome de **Tancredo Neves** na “**galeria dos que foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Magistratura**”, ou seja, na galeria dos **ex-Presidentes da República**.¹¹⁵

Na medida em que Tancredo Neves sempre cogitou da elaboração de uma “Comissão de Notáveis” para elaborar um anteprojeto de Constituição, José Sarney, o novo Presidente, considerando o compromisso assumido pela Aliança Democrática perante a Nação, instituiu, pelo Decreto n. 91.450/85, junto à Presidência da República, uma **Comissão Provisória de Estudos Constitucionais**, composta de 50 membros de livre escolha do Chefe do Executivo e com o objetivo de desenvolver pesquisas e estudos fundamentais, no interesse da Nação brasileira, para futura colaboração com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.

Essa Comissão, conhecida por **Comissão Afonso Arinos**, nome de seu presidente, entregou um anteprojeto de Constituição em 18.09.1986, que foi publicado no *DOU* de 26.09.1986, com 436 artigos no corpo e 32 nas Disposições Gerais e Transitórias.

O texto final elaborado pela *Comissão Afonso Arinos*, todavia, foi rejeitado por José Sarney, tendo em vista, entre outras razões, ter optado pelo sistema **parlamentarista**, o que diminuiria os poderes do Presidente.

Em seguida, buscando cumprir o mandamento da EC n. 26, de 27.11.1985,¹¹⁶ que determinou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, finalmente ela foi instalada, mesmo sem partir de um projeto previamente elaborado, em 1.º.02.1987, sob a presidência do Ministro do STF José Carlos Moreira Alves.

Como anota Barroso, “além das dificuldades naturais, advindas da heterogeneidade das visões políticas, também a metodologia de trabalho utilizada contribuiu para as deficiências do texto final. Dividida, inicialmente, em 24 subcomissões e, posteriormente, em 8 comissões, cada uma delas elaborou um anteprojeto parcial, encaminhado à Comissão de Sistematização. Em 25 de junho do mesmo ano, o relator desta Comissão, Deputado Bernardo Cabral, apresentou um trabalho em que reuniu todos

estes anteprojetos em uma peça de 551 artigos! A falta de coordenação entre as diversas comissões, e a abrangência desmesurada com que cada uma cuidou de seu tema, foram responsáveis por uma das maiores vicissitudes da Constituição de 1988: as superposições e o detalhismo minucioso, prolixo, casuístico, inteiramente impróprio para um documento dessa natureza. De outra parte, o assédio dos *lobbies*, dos grupos de pressão de toda ordem, gerou um texto com inúmeras esquizofrenias ideológicas e densamente corporativo”.¹¹⁷

Depois de tanto trabalho e dificuldades, como se sabe, a Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro, redemocratizando o País, com importantes avanços.

Trata-se da denominada por **Ulysses Guimarães**, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, **Constituição Cidadã**, tendo em vista a ampla **participação popular** durante a sua elaboração e a constante busca de efetivação da **cidadania**.

■ 2.6.11. Constituição de 1988

Durante o governo *Sarney*, o **pluripartidarismo foi ampliado**, legalizando-se partidos como o PCB e o PC do B, surgindo novos como o PSDB (dissidência de membros do PMDB) e o PL (Partido Liberal), formado por ideais neoliberais do empresariado. Outro avanço foi a erradicação da “famigerada” censura à imprensa, que assolou o País durante o governo militar. O sindicalismo e grandes centrais (CUT e CGT) consolidaram-se.

Era a solidificação da transição entre o antigo regime e a “Nova República”. Em 1989, depois de 25 anos de regime de exceção, o povo elegeu, pelo voto direto, em dois turnos, *Fernando Collor de Mello* (15.03.1990 a 29.12.1992). Tendo em vista os vários escândalos de corrupção, em 02.10.1992, a Câmara dos Deputados autoriza a abertura do processo de *impeachment*. Em 29.12.1992, Collor renuncia ao mandato e os Senadores aprovam sua inabilitação política por 8 anos.

O Vice-Presidente de Collor, *Itamar Franco* (29.12.1992 a 1.º.01.1995), assume de modo definitivo a Presidência da República, em razão da vaga do cargo.

Em seguida, tivemos a eleição direta do sociólogo *Fernando Henrique Cardoso* (1.º.01.1995 a 1.º.01.1999) para mandato de 4 anos (mandato reduzido de 5 anos — redação original do texto de 1988 — para 4 anos, por força da EC de Revisão n. 5, de 07.06.1994). Durante o seu mandato, foi aprovada a EC n. 16, de 04.06.1997, que, mantendo o mandato de 4 anos, permitiu uma única reeleição subsequente.

Com fundamento na nova redação conferida aos arts. 82 e 14, § 5.º, Fernando Henrique se torna o primeiro presidente da história da República reeleito para um período subsequente (1.º.01.1999 a 1.º.01.2003).

Posteriormente, e também de forma democrática pelo voto direto, o povo elege o metalúrgico de Garanhuns-PE, *Luiz Inácio Lula da Silva*, que exerceu seu primeiro mandato de 1.º.01.2003 a 1.º.01.2007. Lula foi reeleito em outubro de 2006 (em 2.º turno, com 60,83% dos votos válidos, em disputa com Geraldo Alckmin), assumindo o novo mandato em 1.º.01.2007 e permanecendo até 1.º.01.2011, quando o Executivo Federal passou a ter por Chefe *Dilma Vana Rousseff*, a **primeira mulher** em toda a história da nossa República, reeleita (em segundo turno, com 51,64% dos votos válidos) junto com o Vice-Presidente da República, *Michel Temer*, para o seu segundo mandato, que se iniciou em 1.º.01.2015. Suspensa de suas funções em 12.05.2016, em razão da instauração do processo de *impeachment*, o Senado Federal, em 31.08.2016, por 61 x 20 (total de 81 Senadores da República), julgou procedente a Denúncia n. 1/2016 por crimes de responsabilidade, impondo a Dilma Rousseff a **sanção de perda do cargo**. Em razão da vaga definitiva decorrente da condenação, na referida data, **Michel Temer** tomou posse no cargo de Presidente da República, cumprindo o mandato até 1.º.01.2019, quando assumiu **Jair Messias Bolsonaro**, eleito em outubro de 2018 com 57.797.847 dos votos, ou seja, 55,13% do eleitorado brasileiro (1.º.01.2019 a 1.º.01.2023).

A eleição de 2022 para Presidente da República foi uma das mais acirradas de toda a história, marcadamente **polarizada**, situação que se refletiu nas urnas, qual seja, uma diferença muito pequena entre os candidatos (em segundo turno, **Lula** com **50,90%** e **Bolsonaro** com **49,10%** dos **votos válidos**, com **apenas 1,8% de diferença**, qual seja, **2.139.645 votos**). Pela primeira vez, um presidente no exercício do mandato, candidato à reeleição, não se reelegeu.

Cabe lembrar que a **EC n. 111/2021** alterou a data da posse de 1.º de janeiro para o dia 5 de janeiro, regra essa a ser aplicada somente a partir das eleições de 2026. Por esse motivo, *Luiz Inácio Lula da Silva*, o Presidente da República eleito em 2022, junto com o seu Vice-Presidente, *Geraldo Alckmin* (Alckmin, que saiu concorrente de Lula nas eleições de outubro de 2006!), tomaram posse em 1.º de janeiro de 2023, sendo que o mandato perdurará até a posse de seu sucessor, em 5 de janeiro de 2027 (em tese, e só o tempo e o povo-eleitor dirão, é possível uma nova reeleição de Lula, já que seria a primeira subsequente desse terceiro mandato, que não foi subsequente aos dois anteriores, uma vez que, depois do segundo mandato de Lula, assumiram Dilma Rousseff, Michel Temer e Bolsonaro).

■ **Plebiscito**: conforme já indicamos, tivemos o primeiro **plebiscito** no Brasil, com data inicial prevista para 7 de setembro de 1993 (art. 2.º, ADCT), antecipada para 21 de abril de 1993 pela EC n. 2/92. O **resultado** todos já conhecem, qual seja, a manutenção da **república constitucional** e do **sistema presidencialista de governo**.

Ainda, nos termos do art. 3.º, ADCT, que fixava a manifestação do **poder constituinte derivado revisor** após 5 anos contados da promulgação do texto, em 07.10.1993 foi instalada a sessão inaugural dos trabalhos de “revisão constitucional”.

Após 237 dias de trabalho, tendo recebido cerca de 30.000 propostas, foram elaborados 74 projetos de Emenda de Revisão, dos quais apenas **6** foram aprovados como EC de Revisão.

Além das citadas Emendas de Revisão (**poder constituinte derivado revisor**), o texto original já foi alterado 132 vezes¹¹⁸ (**poder constituinte derivado reformador**), sofrendo profundas modificações, tendo sido constantemente interpretadas as suas normas e preceitos pelo STF.

No **preâmbulo** da CF/88 foi instituído um Estado Democrático, destinado a assegurar os seguintes **valores supremos** de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias:

- o exercício dos direitos sociais e individuais;
- a liberdade;
- a segurança;
- o bem-estar;
- o desenvolvimento;
- a igualdade;
- a justiça.

Sendo **democrática e liberal**, a Constituição de 1988, que sofreu forte influência da Constituição portuguesa de 1976, foi a que apresentou maior **legitimidade popular**, podendo ser destacadas as seguintes características:

■ **Forma de Governo:** República, confirmada pelo plebiscito do art. 2.º, ADCT.

■ **Sistema de Governo:** presidencialista, confirmado pelo plebiscito do art. 2.º, ADCT.

■ **Forma de Estado:** Federação. Percebe-se sensível ampliação da autonomia administrativa e financeira dos Estados da Federação, bem como do Distrito Federal e Municípios. Inegavelmente, contudo, a União continua fortalecida, caracterizando-se o texto como centralizador.

Foi criado o Estado de Tocantins (art. 13, ADCT), e os Territórios Federais de Roraima e do Amapá foram transformados em Estados Federados (art. 14, ADCT). O Território Federal de Fernando de Noronha foi

extinto, e sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco (art. 15, ADCT).

■ **Capital Federal:** nos termos do art. 18, § 1.º, **Brasília** é a Capital Federal. Assim, o Distrito Federal, ainda localizado no Planalto Central do Brasil, deixa de ser simples autarquia territorial e passa a ser considerado **ente federativo**, com autonomia político-constitucional, apesar de parcialmente tutelada pela União, como será estudado no *item 7.7.3*.

■ **Inexistência de religião oficial:** o Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, muito embora haja a previsão de “Deus” no preâmbulo.

■ **Organização dos “Poderes”:** foi retomada a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu. Diferentemente do regime anterior, buscou-se um maior equilíbrio, especialmente pela técnica dos “freios e contrapesos”, abrandando a supremacia do Executivo, que imperava.

■ **Poder Legislativo:** bicameral, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a primeira composta de representantes do povo, eleitos pelo voto direto, secreto e universal e pelo sistema proporcional para mandato de 4 anos, e a segunda composta de representantes dos Estados-Membros e do Distrito Federal, para mandato de 8 anos (duas legislaturas), eleitos pelo sistema majoritário, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3.

■ **Poder Executivo:** exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o Vice e auxiliado pelos Ministros de Estado. Atualmente, após a EC n. 16/97, como visto, o mandato é de 4 anos, permitindo-se uma única reeleição subsequente. O decreto-lei foi substituído pela medida provisória.

■ **Poder Judiciário:** nos termos do art. 92, são órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça (EC n. 45/2004); o Superior Tribunal de Justiça; o Tribunal Superior do Trabalho (EC n. 92/2016); os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Em relação ao controle de constitucionalidade das leis, tema que será estudado, houve ampliação dos legitimados para a propositura da ADI.

A CF/88 criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o Brasil, sendo órgão de convergência da Justiça comum. Nesse sentido, o STF passou a cuidar de temas predominantemente constitucionais.

A EC n. 45/2004, *Reforma do Poder Judiciário*, trouxe importantes modificações.

■ **Constituição rígida:** existe um processo de alteração mais árduo, mais solene e mais dificultoso que o processo de alteração das demais espécies normativas, daí a rigidez constitucional.

■ **Declaração de direitos:**

a) os princípios democráticos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos estão consolidados no texto, consagrando direitos fundamentais de maneira inédita, por exemplo, ter tornado o racismo e a tortura (que já havia sido abolida — art. 179, XIX, da Constituição de 1824) crimes **inafiançáveis**;

b) os direitos dos trabalhadores foram ampliados;

c) pela primeira vez se estabeleceu o controle das omissões legislativas, seja pelo mandado de injunção (controle difuso), seja pela ADI por omissão (controle concentrado), temas a serem estudados;

d) introduziu-se a ADPF — arguição de descumprimento de preceito fundamental, tema a ser desenvolvido no capítulo sobre o controle de constitucionalidade;

e) outros remédios também foram previstos pela primeira vez no texto, quais sejam, o mandado de segurança coletivo e o *habeas data*;

f) há previsão específica, pela primeira vez, de um capítulo sobre o “meio ambiente” (art. 225);

g) nesse sentido, destacam-se, dentre as funções institucionais do Ministério Público, a de promover o inquérito civil e a **ação civil pública**, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, *caput*, e 129, III). Lembramos que, de acordo com o art. 129, § 1.º, a legitimação do Ministério Público para as ações civis não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei;¹¹⁹

h) outra relevante função institucional do MP é a de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V);

i) importante previsão da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5.º, LXXIV. Por força das alterações promovidas pela Lei n. 11.448/2007 e pela LC n. 132/2009 (consagradas na EC n. 80/2014), a Defensoria tornou-se parte legítima para a propositura de ação civil pública, atribuição esta reconhecida como constitucional pelo Pleno do STF no julgamento da **ADI 3.943** (j. 07.05.2015, cf. *item 12.5.13.10*).

■ **Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social:** a primeira Constituição brasileira a separar a *ordem econômica* da *ordem social* foi a de 1988.

A ordem econômica recebeu tratamento sistemático, pioneiramente, na Constituição do México de 1917. No Brasil, sob a influência da *Constituição de Weimar*, de 1919, a primeira a tratar da ordem econômica e da ordem social em título único (Título IV) foi a de **1934**.

A Constituição de 1937, embora mantendo as matérias sobre a ordem econômica e social, aboliu a utilização de títulos e passou a destacar, de modo simplificado, a ordem econômica.

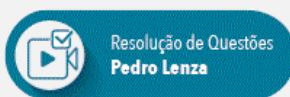
As Constituições de 1946, 1967 e a EC n. 1/69 seguiram a mesma estrutura da de 1934, agregando a ordem econômica e a ordem social em um único título.

A Constituição de 1988, conforme visto, inova e passa a tratar da ordem social em título próprio, **desvinculando-a** da ordem econômica que, por sua vez, recebe matérias sobre o sistema financeiro nacional (Título VII). Alguns temas da ordem social que eram assegurados nas Constituições anteriores, como os *direitos dos trabalhadores*, foram deslocados para o Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais (direitos sociais).

■ 2.7. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

2

CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO





3

HERMENÊUTICA: MUTAÇÃO X REFORMA. REGRAS X PRINCÍPIOS. “DERROTABILIDADE”. POSTULADOS NORMATIVOS. CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO

■ 3.1. MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS “VERSUS” REFORMAS CONSTITUCIONAIS

Neste tópico restringiremos a apresentação a alguns aspectos pontuais, sem, contudo, aprofundar a matéria.¹

As Constituições devem ser interpretadas, função essa atribuída ao *exegeta*, que buscará o real significado dos termos constitucionais.

Tal função é extremamente importante, na medida em que a Constituição dará validade para as demais normas do ordenamento jurídico (Kelsen). Assim, devemos decifrar o seu verdadeiro alcance, a fim de sabermos, por consequência, a abrangência de uma norma infraconstitucional.²

O hermeneuta, dessa forma, levando em consideração a história, as ideologias, as realidades sociais, econômicas e políticas do Estado, definirá o verdadeiro significado do texto constitucional.

Como regra fundamental, lembramos que, onde não existir dúvida, não caberá ao exegeta interpretar (*vide*, por exemplo, o art. 18, § 1.º, CF/88, que aponta, como Capital Federal, Brasília — não cabendo qualquer trabalho hermenêutico).

A interpretação deverá levar em consideração todo o sistema. Em caso de antinomia de normas, buscar-se-á a solução do aparente conflito através de uma interpretação sistemática, orientada pelos princípios constitucionais.

Colocadas essas premissas, o **sentido** da Constituição **interpretada** pode mostrar-se **inadequado**. Nessas circunstâncias, dentro dos limites colocados pelo Constituinte originário, poderão ser observadas alterações tanto do ponto de vista **formal** (*reforma constitucional*) como do **informal** (*mutações constitucionais*).

Reforma constitucional seria a modificação do texto constitucional, mediante mecanismos definidos pelo poder constituinte originário (emendas), alterando, suprimindo ou acrescentando artigos ao texto original.³

As **mutações**, por seu turno, não seriam alterações “físicas”, “palpáveis”, materialmente perceptíveis, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo de um texto constitucional. A transformação não está no texto em si, mas na interpretação daquela regra enunciada. O texto permanece inalterado.

As **mutações constitucionais**, portanto, exteriorizam o caráter **dinâmico** e de **prospecção** das normas jurídicas, por meio de **processos informais**. Informais no sentido de não serem previstos dentre aquelas mudanças formalmente estabelecidas no texto constitucional.

Buscando a sua origem na doutrina alemã, Uadi Lammêgo Bulos denomina **mutação constitucional** “... o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da interpretação, em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio da construção (*construction*), bem como dos usos e dos costumes constitucionais”.⁴

Barroso, por sua vez, afirma que “... a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura do que deve ser considerado ético ou justo. Para que

seja legítima, a mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular”.⁵

Damos um exemplo, valendo-nos do Código Penal brasileiro, apenas para ilustrar: antes do advento da **Lei n. 11.106/2005**, os arts. 215, 216 e 219 do CP traziam a expressão “mulher honesta”. Quando falamos que essa expressão sofreu uma **mutação interpretativa**, não queremos dizer que o artigo em si foi alterado, mas, sim, que o conceito de “mulher honesta”, ao longo do tempo, levando em consideração os padrões aceitos pela sociedade da época, adquiriu significados diversos. “Mulher honesta” no começo do século XX tinha determinado significado, diverso do que adquire a “mulher honesta” dos dias atuais. “Mulher honesta” em uma cidade talvez tenha um significado diverso do que adquire em cidade de outra localidade.

Como visto, essa evolução da sociedade, que vinha sendo percebida pelo Judiciário, sensibilizou o legislador, que revogou por meio da Lei n. 11.106/2005 diversos dispositivos do CP, como os citados, que faziam menção à figura da “mulher honesta”.

Outro exemplo, agora de mutação constitucional, citado por Olavo Alves Ferreira, foi o cancelamento da Súmula 394 do STF, modificando o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função.⁶

Ainda, podemos lembrar a mudança de entendimento pelo STF sobre a competência para julgar HC impetrado em face de decisão de turma recursal, determinando a competência do TJ. Vejamos:

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, modificando sua jurisprudência, assentou a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para julgar *habeas corpus* contra ato de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, impõe-se a imediata remessa dos autos à respectiva Corte local para reinício do julgamento da causa, ficando sem efeito os votos já proferidos. Mesmo tratando-se de **alteração de competência** por efeito de **mutação constitucional** (nova interpretação à Constituição Federal), e não propriamente de alteração no texto da Lei

Fundamental, o fato é que se tem, na espécie, hipótese de competência absoluta (em razão do grau de jurisdição), que não se prorroga. Questão de ordem que se resolve pela **remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**, para reinício do julgamento do feito” (HC 86.009-QO, Rel. Min. Carlos Britto, j. 29.08.2006, *DJ* de 27.04.2007).

Podemos destacar diversas outras interpretações dadas pelo STF ao instituto da “quarentena de entrada” (art. 93, I), à vedação da progressão de regime prevista na Lei de Crimes Hediondos, à anencefalia, à competência trabalhista para julgar ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho, à união homoafetiva, ao não cabimento da prisão civil do depositário infiel (cf. HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.09.2008, *DJE* de 06.02.2009) etc.

Sistematizando, a partir da doutrina clássica, Barroso⁷ procurou identificar os **mecanismos de mutação constitucional**. Vejamos:



■ **interpretação judicial:** em relação à interpretação judicial, podemos apontar os vários exemplos acima citados, sendo, assim, a evolução da jurisprudência da Corte, nos limites propostos, inegável exteriorização da mutação constitucional;

■ **interpretação administrativa:** a evolução interpretativa poderá ser verificada, também, no âmbito administrativo. Como destaque, Barroso lembra a Res. n. 7/CNJ, que, reconhecendo novas perspectivas aos princípios da impessoalidade e da moralidade, deu novo e restritivo sentido ao nepotismo;

■ **por via de costumes constitucionais:** o autor aduz não ser pacífica a existência de costumes em países de Constituição escrita e rígida.⁸ Porém, admite que certas práticas reiteradas ensejaram mudanças no sentido interpretativo da Constituição. Como exemplo, menciona a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo negar a aplicação de lei que de modo fundamentado considere inconstitucional. Lembra, ainda, o voto de liderança no Parlamento, sem a submissão da matéria ao Plenário. Outro exemplo, antes do advento da EC n. 32/2001, destaca a reedição de medida provisória, desde que não houvesse expressa rejeição ou alteração do texto. Barroso evidencia, também, a evolução da interpretação em relação aos poderes da CPI, passando a Suprema Corte a admitir a quebra de sigilos bancários e fiscais;

■ **atuação do legislador:** verifica-se a mutação constitucional por atuação do legislador quando, por ato normativo primário, procurar alterar o sentido já dado a alguma norma constitucional. Como exemplo, depois de modificado o entendimento sobre a prerrogativa de foro pelo STF, que, inclusive, conforme visto, cancelou a Súmula 394, o Congresso Nacional procurou resgatar o sentido dessa súmula, nos termos da Lei n. 10.628/2002. Cabe lembrar que o STF declarou inconstitucional referido ato normativo (cf. *item 9.9.2.3*). Para se ter um outro exemplo, agora de “reversão legislativa da jurisprudência da Corte” por emenda constitucional, lembramos, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da vaquejada pelo STF, a aprovação da EC n. 96/2017 (cf. *item 19.8.7.4*).⁹

Naturalmente, a mutação e a nova interpretação não poderão afrontar os **princípios estruturantes** da Constituição, sob pena de serem inconstitucionais.

■ 3.2. REGRAS E PRINCÍPIOS

A doutrina vem se debruçando sobre a importante e complexa distinção entre **regras** e **princípios**, partindo da premissa de que ambos são espécies de **normas** e que, como referenciais para o intérprete, **não** guardam, entre si, **hierarquia**, especialmente diante da ideia da **unidade** da Constituição.

Canotilho refere-se ao *sistema jurídico do Estado de direito democrático português* como “**um sistema normativo aberto de regras e princípios**”:

- **sistema jurídico**: “porque é um sistema dinâmico de normas”;
- **sistema aberto**: “porque tem uma estrutura *dialógica* (Caliess) traduzida na disponibilidade e ‘capacidade de aprendizagem’ das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da ‘verdade’ e da ‘justiça’”;
- **sistema normativo**: porque a estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas é feita por meio de *normas*;
- **sistema de regras e de princípios**: “pois as normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de *princípios* como sob a sua forma de *regras*”.¹⁰

Humberto Ávila, por sua vez, esclarece que “... um sistema não pode ser composto somente de princípios, ou só de regras. Um sistema só de **princípios** seria demasiado **flexível**, pela ausência de guias claros de comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. E um sistema só de **regras**, aplicadas de modo formalista, seria demasiado **rígido**, pela ausência de válvulas de abertura para o amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos. Com isso se quer dizer que, a rigor, não se pode dizer nem que os princípios

são mais importantes do que as regras, nem que as regras são mais necessárias que os princípios. Cada **espécie normativa** desempenha funções diferentes e complementares, não se podendo sequer conceber uma sem a outra, e a outra sem a uma. Tal observação é da mais alta relevância, notadamente tendo em vista o fato de que a Constituição Brasileira é repleta de regras, especialmente de competência, cuja finalidade é, precisamente, alocar e limitar o exercício do poder”.¹¹

Segundo Ávila, a *interpretação* e a *aplicação* de **princípios** e **regras** dar-se-ão com base nos **postulados normativos inespecíficos**, quais sejam, a **ponderação** (atribuindo-se pesos), a **concordância prática** e a **proibição de excesso** (garantindo a manutenção de um mínimo de eficácia dos direitos fundamentais), e *específicos*, destacando-se o postulado da **igualdade**, o da **razoabilidade** e o da **proporcionalidade**.¹²

Canotilho, no tocante à diferenciação, sistematiza a matéria, estabelecendo os seguintes **critérios**:¹³

■ **grau de abstração**: “os *princípios* são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as *regras* possuem uma abstração relativamente reduzida”;

■ **grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto**: “os *princípios*, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as *regras* são susceptíveis de aplicação direta”;

■ **carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito**: “os *princípios* são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito)”;

■ **“proximidade” da ideia de direito**: “os *princípios* são ‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘ideia de direito’ (LARENZ); as *regras* podem ser

normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional”;

■ **natureza normogenética:** “os *princípios* são fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a *ratio* de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante”.

Barroso, avançando, identifica uma distinção **qualitativa** ou **estrutural** entre *regras* e *princípios*.

Conforme anota, “... a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central. A mudança de paradigma nessa matéria deve especial tributo às concepções de *Ronald Dworkin* e aos desenvolvimentos a ela dados por *Robert Alexy*. A conjugação das ideias desses dois autores dominou a teoria jurídica e passou a constituir o conhecimento convencional da matéria”.¹⁴ E, em seguida, conclui:

■ **regras:** relatos descritivos de condutas a partir dos quais, mediante **subsunção**, havendo enquadramento do fato à previsão abstrata, chega-se à conclusão. Diante do conflito entre regras, apenas uma prevalece dentro da ideia do *tudo ou nada* (*all or nothing*). A “... **regra** somente **deixará de incidir** sobre a hipótese de fato que contempla se for **inválida**, se houver outra **mais específica** ou se **não estiver em vigor**” (ou seja, acrescente-se, critérios *hierárquico*, da *especialidade* ou *cronológico*);

■ **princípios:** a previsão dos *relatos* se dá de maneira mais abstrata, sem se determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado para que o intérprete dê o exato **peso** entre os eventuais princípios em **choque** (*colisão*). Assim, a aplicação dos princípios “não será no esquema *tudo ou nada*, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato”. Destaca-se, assim, a técnica da **ponderação** e do

balanceamento, sendo, portanto, os princípios **valorativos** ou **finalísticos**.

Nessa linha, partindo da proposta de diferenciação formulada por Dworkin,¹⁵ Robert Alexy dela se afasta e **avança** ao caracterizar os **princípios** como **mandamentos** ou **mandados de otimização** (sendo esta a sua principal contribuição à ideia inicial). Em suas palavras:

■ **regras**: “... são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, **determinações** no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma **distinção qualitativa**, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio”;

■ **princípios**: “... normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, **mandamentos de otimização**, que são caracterizados por poderem ser **satisfeitos em graus variados** e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das **possibilidades jurídicas**. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes” (grifamos).¹⁶

Cabe alertar que as teses sobre as distinções entre regras e princípios defendidas por Dworkin e Alexy **não se confundem**.

De acordo com Virgílio Afonso da Silva, “... não só as teses de ambos os autores não são idênticas — a própria ideia de otimização não está presente nas obras de Dworkin —, como também a possibilidade de única resposta correta é rejeitada expressamente pela teoria dos princípios na forma defendida por Alexy. O que o conceito de **mandamento de otimização** impõe é o que se pode chamar de ideia regulativa, ou seja, uma

ideia que sirva para *guiar a argumentação em um determinado sentido*. Várias podem ser as respostas que satisfaçam as exigências de otimização. Quanto maior o número de variáveis — e de direitos — envolvidos em um caso concreto, maior tenderá a ser a quantidade de respostas que satisfaçam o critério de otimização”.¹⁷

De modo geral, partindo das ideias expostas, podemos **esquematizar** as distinções essenciais entre **regras** e **princípios**:

REGRAS	PRINCÍPIOS
■ dimensão da validade , especificidade e vigência	■ dimensão da importância , peso e valor
■ conflito entre regras (uma das regras em conflito ou será afastada pelo princípio da especialidade, ou será declarada inválida — <i>cláusula de exceção</i> , que também pode ser entendida como “declaração parcial de invalidade”)	■ colisão entre princípios (não haverá declaração de invalidade de qualquer dos princípios em colisão. Diante das condições do caso concreto, um princípio prevalecerá sobre o outro)
■ “tudo ou nada”	■ ponderação, balanceamento, sopesamento entre princípios colidentes
■ mandamentos ou mandados de definição	■ mandamentos ou mandados de otimização

Finalmente, correta a constatação de Barroso ao perceber que mais recentemente e avançando as ideias de Dworkin e os novos desenvolvimentos analíticos trazidos por Alexy, “... já se discute tanto a aplicação do esquema **tudo ou nada** aos **princípios** como a possibilidade de também as **regras** serem **ponderadas**. Isso porque, como visto, determinados princípios — como o princípio da dignidade da pessoa humana e outros — apresentam um núcleo de sentido ao qual se atribui natureza de regra, aplicável biunivocamente. Por outro lado, há situações em que uma regra, perfeitamente válida em abstrato, poderá gerar uma

inconstitucionalidade ao incidir em determinado ambiente, ou, ainda, há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar...”¹⁸

Essa perspectiva de possibilidade de ponderação de regras, desenvolvida no item seguinte, contudo, tem sofrido críticas por parte da doutrina. Streck observa que, “em Alexy, a ponderação seria um dos fatores centrais que marcam a distinção entre regras e princípios (uma das máximas alexyanas é: ‘princípios se aplicam por ponderação; regras por subsunção’)”. Assim, indaga: “se a ponderação é o procedimento do qual o resultado será uma regra posteriormente subsumida ao caso concreto, o que temos como resultado da ‘ponderação de regras’? Uma ‘regra’ da regra? Como fica, portanto, em termos práticos, a distinção entre regras e princípios, uma vez que deixa de ter razão de ser a distinção entre subsunção e ponderação? A tese faz com que a ponderação se transforme em um procedimento generalizado de aplicação do Direito”.¹⁹

■ 3.3. DERROTABILIDADE (“DEFEASIBILITY”)²⁰

De modo geral, conforme estabelece Humberto Ávila, existem várias **justificativas** para a **obediência às regras**, destacando-se:²¹

- “eliminação da controvérsia e da incerteza, e dos custos morais a elas associados”;
- eliminação ou redução da “... arbitrariedade que pode potencialmente surgir no caso de aplicação direta de valores morais”;
- busca para “evitar problemas de coordenação, deliberação e conhecimento”. No tocante à *coordenação*, sem a regra, haveria o risco de cada indivíduo querer defender o seu ponto de vista. Em relação à *deliberação*, inexistindo solução predefinida em determinada regra, observar-se-ia um aumento de custos para soluções casuísticas e individuais. Finalmente, a falta de regra poderia produzir soluções por pessoas que não têm o *conhecimento* técnico de determinada matéria ou área.

Com isso, observa Ávila que “... as regras não devem ser obedecidas somente por serem regras e serem editadas por uma autoridade. Elas **devem ser obedecidas**, de um lado, porque sua **obediência** é **moralmente boa** e, de outro, porque produz efeitos relativos a valores prestigiados pelo próprio ordenamento jurídico, como **segurança**, **paz** e **igualdade**. Ao contrário do que a atual exaltação dos princípios poderia fazer pensar, as regras não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais”.²²

Apesar dessa constatação, muitos autores, conforme já enunciado, começam a reconhecer a **derrotabilidade** (*defeasibility*) das regras, superando o modelo “tudo ou nada” de Dworkin.

A ideia de **derrotabilidade** (Ávila se refere a ela como **superabilidade**), historicamente, vem sendo atribuída a **Hart**, na seguinte passagem: “quando o estudante aprende que na lei inglesa existem condições positivas exigidas para a existência de um contrato válido, ele ainda tem que aprender o que pode derrotar a reivindicação de que há um contrato válido, mesmo quando todas essas condições são satisfeitas”, daí por que “o estudante tem ainda que aprender o que pode seguir as palavras ‘a menos que’, as quais devem acompanhar a indicação dessas condições”.²³

Nesse sentido, Ávila, reconhecendo que as regras não são superáveis com facilidade,²⁴ propõe algumas **condições necessárias**, destacando-se:

■ **requisitos materiais (ou de conteúdo)**: a superação da regra pelo caso individual não pode prejudicar a concretização dos valores inerentes à regra. E explica o autor: “... há casos em que a decisão individualizada, ainda que incompatível com a hipótese da regra geral, não prejudica nem a promoção da **finalidade subjacente à regra**, nem a **segurança jurídica** que suporta as regras, em virtude da pouca probabilidade de reaparecimento frequente de situação similar, por dificuldade de ocorrência ou comprovação”;²⁵

■ **requisitos procedimentais (ou de forma)**: a superação de uma regra deve ter **a) justificativa condizente** — devendo haver a “... demonstração de incompatibilidade entre a hipótese da regra e sua finalidade subjacente. É preciso apontar a discrepância entre aquilo que a hipótese da regra estabelece e o que sua finalidade exige”. E, ainda, a “... demonstração de que o afastamento da regra não provocará expressiva insegurança jurídica”. Em outras palavras, a *justiça individual* não poderá afetar substancialmente a *justiça geral*; **b) fundamentação condizente** — as razões de superação da regra devem ser **exteriorizadas**, para que, assim, possam ser controladas. “A fundamentação deve ser escrita, juridicamente fundamentada e logicamente estruturada”; **c) comprovação condizente** — “... não sendo necessárias, notórias nem presumidas, a ausência do aumento

excessivo das controvérsias, da incerteza e da arbitrariedade e a inexistência de problemas de coordenação, altos custos de deliberação e graves problemas de conhecimento devem ser comprovadas por meios de provas adequados, como documentos, perícias ou estatísticas. A mera alegação não pode ser suficiente para superar uma regra”.

Analisando os requisitos propostos por Ávila para a eventual **superação das regras**, concordamos com a crítica apontada por Vasconcellos, no tocante aos requisitos materiais, no sentido de que se poderia pensar em certa “**universalização/generalização das decisões baseadas na derrotabilidade**”, e não que essa generalização pudesse gerar a sugerida insegurança.

Conforme aponta Vasconcellos, “... o requisito material mais importante da derrotabilidade é a **coerência** do julgador ou órgão durante a decisão. (...). Em nome da coerência, o processo de inserção da *exceção* no interior da regra impõe o fenômeno da **universalização**, a partir do qual a decisão singular se torna **paradigmática, referência e modelo** às ulteriores (posteriores, acrescente-se) decisões de casos similares”.²⁶

CUIDADO: do ponto de vista jurisprudencial, alertamos que o **STF** ainda não utilizou a expressão **derrotabilidade**.

Destacamos, contudo, interessantes julgados que utilizaram a ideia para a fundamentação de suas decisões:

■ **TRF1 — EDAMS 5.553 — GO 2001.35.00.005553-9 — j. 16.03.2005 — 6.^a T., DJ de 18.04.2005** — discutia-se a regra contida no art. 99 da Lei n. 8.112/90, que **assegura** ao servidor estudante (ao seu cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial) que mudar de sede no interesse da administração, na localidade da nova residência ou na mais próxima, **matrícula em instituição de ensino congênere**, em qualquer época, independentemente de vaga (cf. a discussão sobre o assunto, no

presente trabalho, no *item 14.10.2.5*). Esse entendimento já foi, inclusive, confirmado pelo STF, no julgamento da **ADI 3.324**, que destacou a necessidade de ser o estabelecimento de ensino congênere, ou seja, a transferência deverá ser de escola particular para particular e de pública para pública. No caso concreto dos autos, contudo, como não havia na localidade instituição da mesma natureza, o TRF1 entendeu que “... a vedação em causa é **‘derrotável’**, porquanto o legislador, ao editar o dispositivo em referência, não considerou essa circunstância em sua formulação normativa, de forma que o *princípio do direito constitucional à educação* (Carta Magna, art. 205), bem como o de que as *normas restritivas devem ser interpretadas restritivamente* **‘derrotam’** a vedação contida no referido dispositivo legal”;²⁷

■ **Recurso JEF n. 200535007164388 — TJ/GO:** no caso, discutia-se o direito ao recebimento do *benefício de prestação continuada* previsto no art. 20, § 3.º, da Lei n. 8.742/93 (LOAS — Lei Orgânica da Assistência Social), que consiste na garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e à pessoa idosa com 65 anos (redação dada pela Lei n. 12.435/2011) ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, sendo que se considera incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 do salário mínimo. No caso concreto, o Juiz **Juliano Taveira Bernardes** utilizou a ideia de **derrotabilidade** para afastar a regra geral, sem que o seu entendimento ferisse, inclusive, o posicionamento do STF.²⁸

Sobre esse tema específico, cabe lembrar que o STF, no julgamento da **ADI 1.232**, declarou **constitucional** o **critério objetivo** previsto na lei (Rel. p/ o ac. Min. Nelson Jobim, j. 27.08.1998). **Contudo**, como observou o Min. Gilmar, “elaboraram-se maneiras de se **contornar** o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade

social das famílias com pessoas idosas ou com deficiência. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais (...). O STF, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do **processo de inconstitucionalização** decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)”. Por esse motivo, no julgamento do **RE 567.985**, foi declarada a inconstitucionalidade parcial do referido art. 20, § 3.º, da Lei n. 8.742/93, porém, sem a pronúncia de nulidade (Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013, Pleno, com repercussão geral).

■ Essa perspectiva jurisprudencial acabou influenciando o Parlamento, que, ao introduzir o § 11 no art. 20 da LOAS (pela **Lei n. 13.146/2015**), passou a admitir, para a concessão do benefício em análise, a utilização de **outros elementos probatórios** da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. Assim, apesar de o critério objetivo continuar prescrito, outros aspectos poderão ser considerados no caso concreto, como, por exemplo, a necessidade de tratamentos e medicamentos caros por parte de integrantes da família.

A **EC n. 107/2020** pode ser um outro interessante exemplo de “derrotabilidade de regra”. Isso porque, em razão da pandemia da Covid-19, adiou as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos, afastando a aplicação do art. 16, CF/88.

■ 3.4. NORMAS DE SEGUNDO GRAU: POSTULADOS NORMATIVOS

Humberto Ávila, como já apontamos, refere-se à categoria dos **postulados normativos**, que não se confundem com as regras e os princípios.

Segundo afirma, os postulados podem ser qualificados como **metanormas** ou **normas de segundo grau**, instituindo “... critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da aplicação”.

Assim, podem ser caracterizados como **normas metódicas**, fornecendo “critérios bastante precisos para a aplicação do Direito”, destacando-se os *postulados inespecíficos* (**ponderação**, **concordância prática** e **proibição de excesso**) e os *postulados específicos* (**igualdade**, **razoabilidade** e **proporcionalidade**).²⁹

■ 3.5. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO



Imagem sem descrição.

Anota Canotilho que “a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de **métodos**, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes mas, em geral, reciprocamente complementares”.³⁰ Nessa linha, limitar-nos-emos a expor algumas características de cada um dos métodos destacados pelo mestre português.

■ 3.5.1. Método jurídico ou hermenêutico clássico

Para os que se valem desse método, a Constituição deve ser encarada como uma **lei** e, assim, todos os **métodos tradicionais** de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa, valendo-se dos seguintes elementos de exegese:

- **elemento genético:** busca investigar as origens dos conceitos utilizados pelo legislador;
- **elemento gramatical ou filológico:** também chamado de literal ou semântico, pelo qual a análise deve ser realizada de modo textual e literal;
- **elemento lógico:** procura a harmonia lógica das normas constitucionais;
- **elemento sistemático:** busca a análise do todo;
- **elemento histórico:** analisa o projeto de lei, a sua justificativa, exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e psicológicas que resultaram na elaboração da norma;
- **elemento teleológico ou sociológico:** busca a finalidade da norma;
- **elemento popular:** a análise se implementa partindo da participação da massa, dos “corpos intermediários”, dos partidos políticos, sindicatos, valendo-se de instrumentos como o plebiscito, o referendo, o *recall*, o veto popular etc.;
- **elemento doutrinário:** parte da interpretação feita pela doutrina;
- **elemento evolutivo:** segue a linha da mutação constitucional.

Nesse método, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da norma, o seu sentido e, assim, atribui-se grande importância ao texto da norma.

■ 3.5.2. Método tópico-problemático (ou método da tópica)

Por meio desse método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados.

A Constituição é, assim, um sistema **aberto** de regras e princípios.

■ 3.5.3. Método hermenêutico-concretizador

Diferentemente do método tópico-problemático, que parte do caso concreto para a norma, o método hermenêutico-concretizador parte da Constituição para o problema, destacando-se os seguintes pressupostos interpretativos:

■ **pressupostos subjetivos:** o intérprete vale-se de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma;

■ **pressupostos objetivos:** o intérprete atua como mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como “pano de fundo” a realidade social;

■ **círculo hermenêutico:** é o “movimento de ir e vir” do subjetivo para o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma.

O fato de se partir das pré-compreensões do intérprete pode distorcer não somente a realidade, como também o próprio sentido da norma.

■ 3.5.4. Método científico-espiritual

A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da **realidade social** e dos valores subjacentes do texto da Constituição.

Assim, a Constituição deve ser interpretada como algo **dinâmico** e que se **renova constantemente**, no compasso das modificações da vida em sociedade.

Sustenta Inocêncio Mártires Coelho que, segundo o método científico-espiritual, “... tanto o direito quanto o Estado e a Constituição são vistos como **fenômenos culturais** ou fatos referidos a **valores**, a cuja realização eles servem de instrumento”.³¹

■ 3.5.5. Método normativo-estruturante

A doutrina que defende esse método reconhece a inexistência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.

Isso porque o teor literal da norma (elemento literal da doutrina clássica), que será considerado pelo intérprete, deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social.

A norma terá de ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas, também, pela atividade do Judiciário, da administração, do governo etc.

Para Coelho, “em síntese, no dizer do próprio Müller, o teor literal de qualquer prescrição de direito positivo é apenas a ‘ponta do *iceberg*’; todo o resto, talvez a parte mais significativa, que o intérprete-aplicador deve levar em conta para realizar o direito, isso é constituído pela *situação normada*, na feliz expressão de Miguel Reale”.³²

■ 3.5.6. Método da comparação constitucional

A interpretação dos institutos se implementa mediante comparação nos vários ordenamentos.

Estabelece-se, assim, uma comunicação entre as várias Constituições. Partindo dos 4 *métodos* ou elementos desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático), Peter Häberle sustenta a **canonização** da comparação constitucional como um *quinto* método de interpretação.³³

■ 3.6. PRINCÍPIOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Ao lado dos métodos de interpretação, a doutrina³⁴ estabelece alguns **princípios específicos de interpretação** e que podem ser assim esquematizados:



Imagem sem descrição.

■ 3.6.1. Princípio da unidade da Constituição

A Constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade, como um todo, e, assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas. Nesse sentido, conforme anota Konrad Hesse, “todas as normas constitucionais hão de ser interpretadas de tal modo que se evitem contradições com outras normas da Constituição”.³⁵

Não existe, portanto, hierarquia entre as normas constitucionais originárias, que deverão ser harmonizadas na hipótese de eventual conflito (aparente). As normas deverão ser vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios.

Anota Canotilho que, “como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’ e ‘factor hermenêutico de decisão’, o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a Constituição na sua **globalidade** e a procurar **harmonizar os espaços de tensão** (...) existentes entre as normas constitucionais a concretizar (ex.: princípio do Estado de Direito e princípio democrático, princípio unitário e princípio da autonomia regional e local)”.³⁶

■ 3.6.2. Princípio do efeito integrador

Muitas vezes associado ao princípio da unidade, conforme ensina Canotilho, “... na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Como tópico argumentativo, o princípio do efeito integrador não se assenta numa concepção integracionista de Estado e da sociedade (conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos políticos), antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras”.³⁷

Portanto, entre uma decisão (com fundamento constitucional) que possa trazer a **desordem** e outra que **estimule e fortaleça a integração política e social e o reforço da unidade política**, naturalmente, essa última deverá ser a escolha do intérprete.

■ 3.6.3. Princípio da máxima efetividade

Também chamado de princípio da **eficiência** ou da **interpretação efetiva**, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social.

Segundo Canotilho, “é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas programáticas (THOMA), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)”.³⁸

■ 3.6.4. Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção) funcional

O intérprete máximo da Constituição, no caso brasileiro o STF, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer a *força normativa* da Constituição, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é o caso da separação de poderes, no sentido de preservação do Estado de Direito.

O seu intérprete final “... não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido (EHMKE)”.³⁹

Conforme esclarece Hesse, “se a Constituição regula, de certa maneira, a competência dos agentes das funções estatais, **o órgão de interpretação deve manter-se no marco das funções que lhe são atribuídas**; esse órgão não deverá modificar a distribuição de funções pela forma e resultado dessa interpretação. Isto se aplica, em particular, às relações entre legislador e tribunal constitucional: porque ao **tribunal** só compete, em face do legislador, uma função de controle, **é-lhe vedada qualquer interpretação que restrinja a liberdade de conformação do legislador além dos limites estabelecidos pela Constituição ou, inclusive, a uma conformação feita pelo próprio tribunal**”.⁴⁰

Nos momentos de crise, acima de tudo, as relações entre o Parlamento, o Executivo e a Corte Constitucional deverão ser pautadas pela irrestrita **fidelidade e adequação à Constituição**.

■ 3.6.5. Princípio da concordância prática ou harmonização

Partindo da ideia de **unidade** da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando, assim, evitar o sacrifício (total) de um princípio em relação a outro em choque. Dessa forma, Hesse sustenta que, na hipótese de eventual colisão de bens jurídicos constitucionalmente protegidos, na solução do problema, todos eles deverão ter a sua identidade preservada, tendo em vista um necessário trabalho de “otimização”: “faz-se necessário estabelecer os **limites** (fixados, em cada caso concreto, a partir do **princípio da proporcionalidade**, acrescente-se) de ambos os bens a fim de que os dois alcancem uma **efetividade ótima**”.⁴¹ O fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os princípios.

Nas palavras de Canotilho, “o campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens

jurídicos constitucionalmente protegidos). Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens constitucionais (e não uma diferença de hierarquia) que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens”.⁴²

■ 3.6.6. Princípio da força normativa

Os aplicadores da Constituição, ao solucionar conflitos, devem conferir a máxima efetividade às normas constitucionais.

Assim, de acordo com Canotilho, “na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da Constituição (normativa), contribuem para uma eficácia ótima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a ‘atualização’ normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e permanência”.⁴³

Nesse sentido, como anota Gilmar Mendes, “sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos e sociais para a força normativa da Constituição, confere Hesse peculiar realce à chamada *vontade da Constituição* (*Wille zur Verfassung*). A Constituição, ensina Hesse, transforma-se em força ativa se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem presentes, na consciência geral — particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de poder (*Wille zur Macht*), mas também a vontade de Constituição (*Wille zur Verfassung*)”.⁴⁴

■ 3.6.7. Princípio da interpretação conforme a Constituição

Diante de **normas plurissignificativas** ou **polissêmicas** (que possuem mais de uma interpretação), deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da Constituição e, portanto, que não seja contrária ao texto constitucional, daí surgirem várias dimensões a serem consideradas, seja pela doutrina,⁴⁵ seja pela jurisprudência, destacando-se que a interpretação conforme será implementada pelo Judiciário e, em última instância, de maneira final, pela Suprema Corte:

■ **prevalência da Constituição:** deve-se preferir a interpretação não contrária à Constituição;

■ **conservação de normas:** percebendo o intérprete que uma lei pode ser interpretada em conformidade com a Constituição, ele deve assim aplicá-la para evitar a sua não continuidade;

■ **exclusão da interpretação *contra legem*:** o intérprete não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição;

■ **espaço de interpretação:** só se admite a interpretação conforme a Constituição se existir um espaço de decisão e, dentre as várias a que se chegar, deverá ser aplicada aquela em conformidade com a Constituição;

■ **rejeição ou não aplicação de normas inconstitucionais:** uma vez realizada a interpretação da norma, pelos vários métodos, se o juiz chegar a um resultado contrário à Constituição, em realidade, deverá declarar a inconstitucionalidade da norma, proibindo a sua correção contra a Constituição;

■ **intérprete não pode atuar como legislador positivo:** não se aceita a interpretação conforme a Constituição quando, pelo processo de hermenêutica, se obtiver uma regra nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória, em seu sentido literal ou objetivo. Deve-se, portanto, afastar qualquer interpretação em contradição com os objetivos pretendidos pelo legislador. Avançando,

se a vontade do legislador violar a Constituição, confira interessante discussão dentro da ideia de **decisões manipulativas** (item 3.7.2).

■ 3.6.8. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade

Ao expor a doutrina de Karl Larenz,⁴⁶ Coelho esclarece: “utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das *restrições* de direitos — muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na *concessão* de poderes, privilégios ou benefícios —, o princípio da *proporcionalidade* ou da *razoabilidade*, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”.⁴⁷

Trata-se de princípio extremamente importante, em especial na situação de colisão entre valores constitucionalizados.

Como parâmetro, podemos destacar a necessidade de preenchimento de 3 importantes elementos:

■ **necessidade**: por alguns denominada **exigibilidade**, a adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa;

■ **adequação**: também chamado de **pertinência** ou **idoneidade**, quer significar que o meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido;

■ **proporcionalidade em sentido estrito**: sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termos de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição.

Finalmente, lembramos importantes **dispositivos normativos** que explicitamente adotam o princípio da proporcionalidade (que, no plano constitucional, não está enunciado de modo formal e categórico, mas decorre do devido processo legal, em sua acepção **substantiva** — art. 5.º, LIV):

■ **Art. 2.º, VI, da Lei n. 9.784/99:** “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, **razoabilidade**, **proporcionalidade**, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) VI — **adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público**”.

■ **Art. 156, CPP:** “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I — ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a **necessidade**, **adequação** e **proporcionalidade** da medida” (incluído pela Lei n. 11.690/2008).

■ **Art. 282, I e II, CPP:** “As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I — **necessidade** para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II — **adequação** da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (redação e inclusões pela Lei n. 12.403/2011).

■ **Art. 438, §§ 1.º e 2.º, CPP:** “A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1.º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo,

assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. § 2.º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da **proporcionalidade** e da **razoabilidade**” (redação e inclusões pela Lei n. 11.689/2008).

■ 3.7. LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Diante das premissas de interpretação postas, surge a necessidade de se estabelecerem parâmetros objetivos e critérios firmes de interpretação, à luz da ideia de **certeza** e **segurança jurídica**.

Não se pode desconhecer a realidade atual e inevitável de, muitas vezes, **criação judicial do direito**, já que entre a declaração de nulidade absoluta total da lei ou ato normativo e o não conhecimento da ação, em termos de segurança, preferem-se as **decisões interpretativas com efeitos modificativos ou corretivos**.

Nesse sentido, o **texto constitucional** apresenta-se como porto seguro para os necessários limites da interpretação, destacando-se a **interpretação conforme a Constituição** como verdadeira **técnica de decisão**.

Conforme Hesse, “para uma interpretação constitucional que parte da **primazia do texto**, é este último o limite inultrapassável da sua atuação”, isso quer dizer, a Constituição escrita “se converte em **limite inultrapassável** da interpretação constitucional”.⁴⁸

Inocêncio Mártires Coelho alerta que a atual realidade “... parece condenar ao esquecimento a concepção kelseniana de *legislador negativo*, tantas têm sido as decisões das Cortes Constitucionais — *e.g.*, as diversas espécies de sentenças *normativas* — por via das quais, a pretexto de *otimizar e/ou realizar* a Constituição, esses supertribunais assumem nítida postura legislativa, criando normas de caráter geral e vinculante, como atestam a jurisprudência nacional e a estrangeira, esta em maior expressão”.⁴⁹

Estamos diante de verdadeira **atividade legislativa heterônoma**, destacando-se, segundo **Riccardo Guastini**,⁵⁰ as seguintes espécies de *interpretação conforme* ou de *adequação* das leis à Constituição:



Imagem sem descrição.

■ 3.7.1. Decisões interpretativas em sentido estrito

■ 3.7.1.1. *Sentença interpretativa de rechaço (repelir/contrapor)*

Diante de duas possíveis interpretações que determinado ato normativo possa ter, por meio das **sentenças interpretativas de rechaço**, a Corte Constitucional adota aquela que se conforma à Constituição, **repudiando** qualquer outra que contrarie o texto constitucional.

Assim, o enunciado “permanece válido, mas só poderá ser interpretado de maneira conforme à Constituição, o que significa dizer que, implicitamente, e sob pena de vir a considerá-la nula, a Corte proíbe que se dê ao citado dispositivo interpretação contrária à Constituição”.⁵¹

■ 3.7.1.2. *Sentença interpretativa de aceitação*

Por sua vez, nas **sentenças interpretativas de aceitação**, a Corte Constitucional **anula** decisão tomada pela magistratura comum (instâncias ordinárias), que adotou interpretações ofensivas à Constituição.

Não se “... anula o dispositivo *mal interpretado*, mas apenas uma das suas interpretações, dizendo que esse preceito é inconstitucional se interpretado de modo contrário à Constituição ou *na parte em que expressa uma norma inconstitucional*. Também nesse caso, prossegue Guastini, o preceito questionado continua válido, mas a norma extraída da sua interpretação **inconstitucional** é anulada em caráter definitivo e com eficácia *erga omnes*”.⁵²

■ 3.7.2. Decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)

As **decisões manipuladoras (ou manipulativas) (ou normativas)** são originárias da doutrina e jurisprudência italianas (*decisioni manipolative*).

Conforme observou Coelho, as decisões **manipuladoras** (ou **manipulativas**) (ou **normativas**) podem ser caracterizadas como “... sentenças de aceitação em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade das normas que lhe são submetidas, mas, agindo como legislador positivo, modifica (= manipula) diretamente o ordenamento jurídico, adicionando-lhe ou substituindo-lhe normas, a pretexto ou com o propósito de adequá-lo à Constituição. Daí a existência das chamadas sentenças *aditivas* e *substitutivas*, como subespécies das decisões normativas ou manipuladoras”.⁵³

■ **3.7.2.1. Sentenças aditivas (ou sentenças manipulativas de efeito aditivo). Declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo**

No entendimento de Mendes, pela **sentença aditiva** (ou “manipulativa de efeito aditivo”), “... a Corte Constitucional declara inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência”.⁵⁴

A sentença aditiva pode ser justificada, por exemplo, em razão da não observância do **princípio da isonomia**, notadamente nas situações em que a lei concede certo benefício ou tratamento a determinadas pessoas, mas exclui outras que se enquadrariam na mesma situação.

Nessas hipóteses, o Tribunal Constitucional declara inconstitucional a norma na parte em que trata desigualmente os iguais, sem qualquer razoabilidade e/ou nexo de causalidade.

Assim, a decisão se mostra **aditiva**, já que a Corte, ao decidir, “cria uma norma autônoma”, estendendo aos excluídos o benefício.

Estamos em face daquilo que Canotilho denominou **declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo (aditivo)**, na medida em que a sentença do Tribunal “alarga o âmbito normativo de um preceito, declarando inconstitucional a disposição na ‘parte em que não prevê’,

contempla uma ‘exceção’ ou impõe uma ‘condição’ a certas situações que deveria prever **(sentenças aditivas)**”.⁵⁵

As sentenças aditivas já são realidades na Suprema Corte brasileira, destacando-se os seguintes julgados, conforme anotou Mendes:⁵⁶

■ **ADPF 54 — antecipação terapêutica do parto em casos de gravidez de feto anencefálico:** como destacamos no *item 14.10.1.3*, o STF, em 12.04.2012, por maioria, ao julgar a ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde — CNTS, produziu **decisão manipulativa com eficácia aditiva**, atuando como **legislador positivo**, já que, ao dar interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 128 do CP, acrescentou mais uma excludente de ilicitude ao crime de aborto (para o STF, trata-se de conduta atípica). Acrescentando, podemos chamar a atenção para o grande debate envolvendo a decisão da 1.^a Turma do STF, no **HC 124.306**, notadamente o voto do Min. Barroso, que reconheceu a “inconstitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre” e que ainda terá de ser profundamente debatida pelo Pleno da Corte (cf. análise no *item 14.10.1.4*).

■ **MI 670/ES, MI 708/DF, MI 712/PA — direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, CF/88):** o STF, ao julgar os referidos mandados de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo — SINDIPOL, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa — SINTEM e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará — SINJEP, reconheceu **(sentença aditiva)** que fosse garantido o direito de greve a todo servidor público, aplicando-se, no que couber, a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada.

■ **RMS 22.307 — reajuste para os servidores civis não contemplado por lei que o concedeu aos militares:** o STF entendeu, de modo aditivo, que o reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares, pelas Leis n. 8.662/93 e n. 8.627/93, deveria ser estendido também aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais (nesse sentido, cf. **SV 51/STF**). **Cuidado:** essa previsão de que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-ia sempre na mesma data era estabelecida no art. 37, X, CF/88, **antes de sua modificação pela EC n. 19/98**, que acabou com a correlação.

■ **ADIs 1.105 e 1.127 — Estatuto da Advocacia:** o STF, ao dar interpretação conforme a Constituição a diversos preceitos da Lei n. 8.906/94, adicionou-lhe conteúdo normativo, conforme apontamos no *item 12.4.1* deste estudo.

■ **MS 26.602, 26.603 e 26.604 — fidelidade partidária:** como estudaremos no *item 18.5*, o STF entendeu que a fidelidade partidária é princípio constitucional, e, por isso, aquele candidato eleito pelo **sistema proporcional** que mudar de partido (*transferência de legenda*) sem motivo justificado perderá o cargo eletivo (entendimento que não se aplica para os eleitos pelo sistema majoritário — **ADI 5.081**, j. 27.05.2015).

■ **Pet 3.388 — demarcação Raposa Serra do Sol:** o STF reconheceu o modelo **contínuo** de demarcação da terra indígena e, para tanto, determinou diversas **condições**, em caráter marcadamente aditivo (cf. *item 19.10.3.2*).

■ **ADI 2.332, ADI 2.084, ADI 1.797, ADI 2.087, ADI 1.668, ADI 1.344, ADI 1.105, ADI 1.127.**

■ **ADIs 4.357 e 4.425 — questões de ordem referentes à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (j. 25.03.2015):** o STF “conferiu ao Conselho Nacional de Justiça poderes

para fazer diagnóstico do sistema de pagamentos pelas diversas unidades da federação e propor medidas, inclusive de caráter normativo, para assegurar a liquidação do estoque de precatórios, em prazo razoável. Deliberou-se que as propostas do CNJ deveriam ser analisadas, em sessão jurisdicional, prosseguindo o julgamento da questão de ordem na ação de controle concentrado, pelo próprio STF”.

■ **ADPF 347:** adotando a técnica do *complex enforcement*,⁵⁷ “o STF deferiu medidas de caráter liminar, voltadas à superação do caos do sistema carcerário (09.09.2015). O pedido daquela ação é justamente para que o Tribunal expeça determinações de caráter aberto e fiscalize seu cumprimento, retendo a jurisdição”.

■ **RE 641.320:** “Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal” (Pleno, j. 11.05.2016, *DJE* de 1.º.08.2016).

■ **MI 943, 1.010, 1.074 e 1.090:** julgando procedentes os mandados de injunção em assentada anterior, o STF, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, determinou a aplicação dos parâmetros da Lei n. 12.506/2011 no caso concreto. O Tribunal autorizou os Ministros a decidirem monocraticamente casos idênticos.

Estes últimos exemplos (mandados de injunção) não foram listados por Gilmar Mendes, mas se mostram muito interessantes. Trata-se de julgados envolvendo o direito fundamental dos trabalhadores ao **aviso prévio proporcional ao tempo de serviço**, sendo no mínimo de trinta dias, *nos termos da lei* (**art. 7.º, XXI**).

Estamos diante de norma de **eficácia limitada** que só veio a ser regulamentada mais de 20 anos após a promulgação da CF/88, no caso, pela **Lei n. 12.506, de 11.10.2011**.

O STF, no julgamento dos referidos MIs, *antes do advento da norma*, julgou procedente o pedido para reconhecer a mora e garantir a concretização do direito previsto na Constituição e para o caso concreto (**MI 943, 1.010, 1.074 e 1.090**, j. 22.06.2011).

Contudo, diante de indecisão sobre qual parâmetro adotar em razão da quantidade e diversidade de sugestões oferecidas pelos Ministros do STF (e, assim, estabelecer o efeito **aditivo**), até porque, diferentemente do direito de greve supracitado, naquele momento não havia nenhum critério normativo preestabelecido a ser observado, houve **suspensão do julgamento**.

Em seguida, antes da explicitação do dispositivo final da decisão nos referidos mandados de injunção que estavam com o julgamento suspenso, com censurável atraso, o Congresso Nacional aprovou a citada Lei n. 12.506/2011, que não retroagiu e, assim, não resolveu a situação dos trabalhadores demitidos antes de sua vigência e que *ajuizaram mandado de injunção*, naquele momento, *pendente de julgamento*.

O STF, então, concluindo o julgamento dos referidos mandados de injunção, determinou a utilização dos critérios e padrões normativos estabelecidos na Lei n. 12.506/2011 (**sentença aditiva**, portanto), adotando, como anotou o Min. Gilmar Mendes, um “posicionamento menos invasivo às competências do Congresso Nacional e perfeitamente cabível para o deslinde das ações mandamentais” (fls. 47 do acórdão, j. 06.02.2013).⁵⁸

■ **ADO 26 e MI 4.733: O enquadramento da homofobia e da transfobia como crimes de racismo pelo STF.**

O Tribunal, por maioria, reconheceu o “**estado de mora constitucional**” do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5.º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT”.

Assim, diante da existência de **omissão normativa constitucional do Poder Legislativo da União**, a Corte **cientificou o Congresso Nacional**, constituindo-o em mora formal.

Contudo, sem dar qualquer prazo ou obrigar o Congresso Nacional a legislar (o que poderia significar afronta à separação de poderes), o STF deu “interpretação conforme à Constituição, em face dos **mandados constitucionais de incriminação** inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5.º da Carta Política, para **enquadrar a homofobia e a transfobia**, qualquer que seja a forma de sua manifestação, **nos diversos tipos penais definidos na Lei n. 7.716/89**, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que as **práticas homotransfóbicas** qualificam-se como espécies do gênero **racismo**, na dimensão de **racismo social** consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais **comportamentos de homotransfobia** ajustam-se ao conceito de **atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão**” (ADO 26, j. 13.06.2019).

Nesse caso, muito embora não conste da lista trazida por Gilmar Mendes, parece-nos ser um interessante caso de sentença aditiva e em um grau tamanho que nos faz indagar até que ponto não teria havido violação da separação de poderes. Poderia o Poder Judiciário ter estabelecido um tipo penal? Teria havido violação ao princípio da reserva legal? Realmente, um grande tema que analisamos no *item 14.10.28.2*.

■ 3.7.2.2. *Sentenças substitutivas (declaração de inconstitucionalidade com efeito substitutivo)*

Na lição de Branco, ao editar **sentenças substitutivas**, “... a Corte declara a inconstitucionalidade de um preceito *na parte em que expressa certa norma em lugar de outras*, substancialmente distinta, que dele deveria constar para que fosse compatível com a Constituição. Atuando dessa forma, a Corte não apenas **anula** a norma impugnada, como também a **substitui por outra**, essencialmente diferente, criada pelo próprio tribunal, o que implica a produção heterônoma de atos legislativos ou de um *direito judicial*, como o denomina Prieto Sanchís, para quem tais normas já nascem enfermas porque **desprovidas de fundamento democrático**. Apesar dessa ressalva, esse mesmo jurista pondera que, embora os juízes não ostentem uma *legitimidade de origem*, de que desfruta o Parlamento por força de eleições periódicas, é de se reconhecer à magistratura uma **legitimidade de exercício**, de resto passível de controle pela crítica do seu comportamento”.⁵⁹

Como exemplo, podemos citar a **liminar** concedida na **ADI 2.332** (Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.09.2001, Plenário, DJ de 02.04.2004) contra dispositivos da MP 2.183-56, que, alterando o Decreto-Lei n. 3.365/41, **estabeleceu**, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, que a **incidência** de juros compensatórios será de até **6% ao ano** sobre o **valor da diferença eventualmente apurada**, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Neste primeiro momento, e veja que, em seguida, a Corte altera o seu entendimento em relação ao percentual dos juros, de acordo com a decisão do STF, a limitação de 6% ao ano viola o entendimento adotado na Súmula 618/STF (“na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano”). Ainda, a fixação da base de cálculo

como sendo “o valor da diferença eventualmente apurada” também viola o princípio constitucional do direito à **justa indenização**.

Assim, **no julgamento da cautelar**, a taxa de juros de 6% ao ano foi declarada inconstitucional pelo STF e **substituída** pela de 12%. No tocante à base de cálculo dos juros compensatórios contida no introduzido *caput* do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, para que não se ferisse o princípio constitucional do prévio e justo preço, foi dada interpretação conforme a Constituição, para se ter como constitucional (aqui a **substituição**) o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença.

CUIDADO: analisamos o exemplo para efeito de informação, mas devemos destacar que a Corte **alterou** esse entendimento no **julgamento de mérito** da referida ADI, fixando as seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de **juros compensatórios de 6%** ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação (houve a declaração de inconstitucionalidade do vocábulo ‘até’); (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (**ADI 2.332**, Pleno, j. 17.05.2018, *DJE* de 16.04.2019. Nesse sentido, cf. **Rcl 36.199**, Min. Fux, j. 17.03.2020).

Em razão desse novo entendimento estabelecido pelo STF, o **STJ** fez ampla revisão de sua jurisprudência sobre a matéria (cf. teses 126, 184, 280, 281, 282, 283 e Súmulas 12, 70, 102, 141 e 408, fixando-se, dentre outras, a seguinte tese: “o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP

1.577/97” — **Pet 12.344**, Rel. Min. Og Fernandes, 1.^a Seção, j. 28.10.2020, DJE de 13.11.2020).

■ 3.7.3. **Lacuna constitucional e o “pensamento jurídico do possível” na jurisprudência do STF**

O denominado “**pensamento jurídico do possível**” foi destacado no julgamento de embargos infringentes opostos pelo PGR contra acórdão proferido pelo STF na **ADI 1.289**, no qual se discutia o preenchimento da regra do “quinto constitucional” no âmbito do TRT.

Como veremos (*itens 11.7 e 11.8.4.2*), o art. 115, I, CF/88, prescreve que os TRTs serão compostos por 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício, **observado o disposto no art. 94**.

Referido art. 94 estabelece um procedimento rígido, ao prescrever que o órgão de classe elabore uma lista sêxtupla com nomes que preencham os requisitos do art. 94. Em seguida, o Tribunal escolhe 3 dentre os 6 indicados, e o Executivo escolhe 1 da lista tríplice e o nomeia.

O texto é claro ao definir que a lista tríplice será formada dentro do universo dos 6 nomes indicados e que a escolha final do Executivo se dará dentre os 3 escolhidos pelo Tribunal. Ou seja, se a lista elaborada pelo órgão de classe for de 5 nomes, a escolha de 3 ficará prejudicada, pois o Tribunal não terá mais o universo de 6.

Isso posto, surgiu um problema. No caso concreto, em se tratando de vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público, não havia membros suficientes com mais de 10 anos de efetivo exercício.

A Corte deparou-se com inegável **lacuna constitucional**: a Carta não dispôs sobre a hipótese excepcional de faltarem membros no Ministério Público que preenchessem os requisitos constitucionais.

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes lembrou o trabalho de **Gustavo Zagrebelsky** sobre o **direito dúctil**, especialmente diante das características das **sociedades pluralistas atuais**, marcadas pela

diversidade de grupos sociais, interesses e ideologias e, em razão das circunstâncias do caso concreto, concluiu pela adoção do denominado **“pensamento do possível”**.

Destaca Mendes: “... parece dominar a aspiração a algo que é conceitualmente impossível, porém altamente desejável na prática: a não prevalência de um só valor e de um só princípio, senão a salvaguarda de vários simultaneamente. O imperativo teórico da não contradição — válido para a *scientia juris* — não deveria obstaculizar a atividade própria da *jurisprudencia* de intentar realizar positivamente a **‘concordância prática’ das diversidades, e inclusive das contradições que, ainda que assim se apresentem na teoria, nem por isso deixam de ser desejáveis na prática**. ‘Positivamente’: não, portanto mediante a simples amputação de potencialidades constitucionais, senão principalmente mediante prudentes soluções acumulativas, combinatórias, compensatórias, que conduzam os princípios constitucionais a um **desenvolvimento conjunto** e não a um declínio conjunto (Zagrebelsky, *El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia*. Trad. de Marina Gascón. 3. ed. Edt. Trotta S.A., Madrid, 1999. p. 16 — grifamos)”.

Continua Gilmar Mendes lembrando **Peter Häberle** como talvez o mais expressivo defensor da ideia de “ser o **‘pensamento jurídico do possível’ expressão, consequência, pressuposto e limite para uma interpretação constitucional aberta** (Häberle, P. Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken, in: *Die Verfassung des Pluralismus*, Königstein/TS, 1980, p. 9 — grifamos)”.

Ainda, Mendes fala de uma **“teoria constitucional de alternativas”** na medida em que, como sustentado por Häberle, **“o pensamento do possível é o pensamento em alternativas**. Deve estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades, assim como para compromissos. Pensamento do possível é pensamento indagativo (*fragendes Denken*). Na *res publica* existe um *ethos* jurídico específico do pensamento em alternativa, que contempla a **realidade** e a **necessidade**, sem se deixar dominar por elas. O **pensamento do possível** ou o **pensamento pluralista de alternativas** abre

suas perspectivas para ‘novas’ realidades, para o fato de que a realidade de hoje pode corrigir a de ontem, especialmente a adaptação às necessidades do tempo de uma visão normativa, sem que se considere o novo como o melhor” (Häberle, *Die Verfassung des Pluralismus*, cit., p. 3 — grifamos”).

E conclui Mendes: “... valendo-nos da lição de Scheuner citada por Häberle, se quiser preservar **força regulatória** em uma **sociedade pluralista**, a **Constituição** não pode ser vista como texto acabado ou definitivo, mas sim como **‘projeto’ (‘Entwurf’) em contínuo desenvolvimento** (Häberle, *Die Verfassung des Pluralismus*, cit., p. 4 — grifamos)”.

Pedimos vênia, então, para transcrever a ementa do julgado que reconheceu, na linha do voto do Min. Gilmar Mendes, a teoria do **pensamento do possível**:

“EMENTA: (...). Cargos vagos de juízes do TRT. Composição de lista. Requisitos dos arts. 94 e 115 da Constituição: quinto constitucional e lista sêxtupla. Ato normativo que **menos se distancia do sistema constitucional**, ao assegurar aos órgãos participantes do processo a margem de escolha necessária. **Salvaguarda simultânea de princípios constitucionais em lugar da prevalência de um sobre o outro. Interpretação constitucional aberta** que tem como pressuposto e limite o chamado **‘pensamento jurídico do possível’**. Lacuna constitucional. Embargos acolhidos para que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a ADI 1.289, declarando-se a constitucionalidade da norma impugnada” (**ADI 1.289-EI**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.2003, Plenário, *DJ* de 27.02.2004).

Finalmente, podemos lembrar outros exemplos de aplicação pela Corte do **pensamento do possível**, como a técnica da **lei “ainda constitucional”** em relação ao prazo em dobro para a defensoria pública no processo penal (cf. *item 6.7.1.6*).

■ 3.7.4. Críticas ao “pamprinciologismo” (Lenio Streck) e a realidade de uma inegável “Supremocracia” (Oscar Vilhena Vieira)

Parte da doutrina vem tecendo (severas) críticas à exacerbação dos (pseudo)princípios, ou seja, a criação de princípios de acordo com o “sentire” ou a vontade de cada julgador, de modo arbitrário, em decisão “solipsista” (seguindo a orientação pessoal de cada intérprete) e em violação à Constituição, o que pode levar à discricionariedade e a um inaceitável e antidemocrático *decisionismo* (julgamento discricionário e sem fundamentação, surgindo decisões contraditórias a fragilizar a isonomia) — tendo sido essa problemática-constatação denominada “pamprinciologismo”.⁶⁰

Streck observa em outro trabalho que os **princípios** devem ter **densidade deontológica**. Assim, “não podem ser criados *ad hoc*, sem vínculos históricos, pois não são passíveis de um controle intersubjetivo de seus sentidos juridicamente possíveis. Basta ver, para tanto, a algaravia gerada pelo pamprinciologismo, em que princípios são inventados pela doutrina, jurisprudência ou pelo legislativo, sem haver, no entanto, nenhuma preocupação com a sua imperatividade e sua legitimidade”.⁶¹

E conclui com precisão: “o modo incorreto de manejar princípios os transforma em meros **álibis teóricos**, que, ao fim e ao cabo, fragilizam a autonomia do Direito. Dessa forma, os princípios devem refletir um **sentido constitucional reconhecido** em nossa comunidade de modo vinculante, ainda que passível de exceções”, devendo ter, também, um **caráter de transcendência**. Ou seja, afirma Streck, “os princípios não são ornamentos e nem conceitos vazios que apontam para a direção que aprouver ao intérprete. Diferentemente, sua normatividade direciona sentidos que espelham a comum-idade a que pertencem”.⁶²

Nesse sentido, Daniel Sarmiento deixa um importante e valioso recado: “no Estado Democrático de Direito, não só os princípios, mas também as regras devem ser ‘levadas a sério’, evitando-se a ‘anarquia metodológica’ e

a ‘carnavalização’ da Constituição”.

Essa preocupação aparece ao se revelar o criticável lado do “decisionismo e do oba-oba”: “muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de, através deles, buscarem a justiça — ou o que entendem por justiça —, passaram a negligenciar do seu dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos. Esta ‘euforia’ com os princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto, orgulhoso com os seus jargões grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras ‘varinhas de condão’: com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser”.

E continua: “esta prática é profundamente **danosa** a valores extremamente caros ao Estado Democrático de Direito. Ela é **prejudicial à democracia**, porque permite que juízes não eleitos imponham as suas preferências e valores aos jurisdicionados, muitas vezes passando por cima de deliberações do legislador. Ela **compromete a separação de poderes**, porque dilui a fronteira entre as funções judiciais e legislativas. E ela **atenta contra a segurança jurídica**, porque torna o Direito muito menos previsível, fazendo-o dependente das idiosincrasias do juiz de plantão, e prejudicando com isso a capacidade do cidadão de planejar a própria vida com antecedência, de acordo com o conhecimento prévio do ordenamento jurídico. Ela **substitui**, em suma, **o governo da lei pelo governo dos juízes**”.⁶³

As **decisões**, sem dúvida, devem encontrar **sustentação na Constituição**, que, como afirmamos (*item 3.7*), deve ser o **porto seguro** para os necessários limites da interpretação, **evitando-se**, assim, os riscos de uma **ditadura do Poder Judiciário**.

As regras devem ser prestigiadas, mas, diante de colisão e impossibilidade de convivência, os princípios deverão ser destacados (aliás, inimaginável o sistema sem os princípios). As soluções devem ser com base nos verdadeiros princípios, que encontram fundamento histórico na luta por

uma Constituição democrática (essa a grande dificuldade, qual seja, a identificação desses princípios). Devem ser evitados os pseudoprincípios, que serviriam, muitas vezes, de álibis teóricos para as decisões sem fundamentação firme.

A solução proposta por **Humberto Ávila**, já lançada, mostra-se bastante equilibrada. Conforme sustenta, a *interpretação* e a *aplicação* de **princípios** e **regras** dar-se-ão com base nos **postulados normativos inespecíficos**, quais sejam, a **ponderação** (atribuindo-se pesos), a **concordância prática** e a **proibição de excesso** (garantindo a manutenção de um mínimo de eficácia dos direitos fundamentais), e *específicos*, destacando-se o postulado da **igualdade**, o da **razoabilidade** e o da **proporcionalidade**.⁶⁴

Essa preocupação ganha relevância com a posição que a Suprema Corte adquiriu após a Constituição de 1988 e com a Reforma do Poder Judiciário, tudo em razão da inegável **hiperconstitucionalização** do pós-Segunda Grande Guerra na reconstrução do Estado Democrático de Direito.

Sem dúvida, esse modelo fez surgir aquilo que a doutrina denominou **“Supremocracia”** e que tem um duplo sentido: **a)** autoridade que o STF assume em relação às instâncias inferiores, já que, no modelo brasileiro, adquire o papel de intérprete final da Constituição; **b)** a partir da CF/88, o deslocamento do STF para o centro do arranjo político, observando-se uma inegável expansão de sua autoridade em detrimento dos demais poderes.⁶⁵

Conforme anotou Vieira, “esta posição institucional vem sendo paulatinamente ocupada de forma substantiva, em face a enorme tarefa de guardar tão extensa Constituição. A ampliação dos instrumentos ofertados para a jurisdição constitucional tem levado o Supremo não apenas a exercer uma espécie de poder moderador, mas também de responsável por emitir a última palavra sobre inúmeras questões de natureza substantiva, ora validando e legitimando uma decisão dos órgãos representativos, outras vezes substituindo as escolhas majoritárias”.

Essa expansão da autoridade do STF deve-se às ampliadas atribuições de tribunal constitucional, de foro especializado e originário de várias matérias (veja o julgamento da AP 470 — mensalão, para se ter um exemplo), bem como de tribunal de recursos de última instância.⁶⁶

Sem dúvida, parece ter razão Vieira ao propor uma **autocontenção** da atuação da Corte, que passaria a julgar de modo mais qualitativo os grandes temas inseridos na Constituição, o que provocaria o seu fortalecimento e, por consequência, o fortalecimento das instâncias inferiores.

■ 3.7.5. Desacordo moral razoável

Desacordos morais razoáveis surgem em razão de inexistência de consenso em relação a temas polêmicos e com entendimentos antagônicos e diametralmente opostos e que se fundam em conclusão racional, como, por exemplo, a interrupção da gravidez. Assumir uma das posições significa negar a outra, e essa realidade é marca de uma sociedade plural, característica das democracias modernas (posições religiosas, morais, filosóficas etc.).

Nesse sentido, conforme anotou Barroso, “além dos problemas de ambiguidade da linguagem, que envolvem a determinação semântica de sentido da norma, existem, também, em uma **sociedade pluralista e diversificada**, o que se tem denominado de **desacordo moral razoável**. Pessoas bem-intencionadas e esclarecidas, em relação a múltiplas matérias, pensam de maneira radicalmente contrária, **sem conciliação possível**. Cláusulas constitucionais como direito à vida, dignidade da pessoa humana ou igualdade dão margem a construções hermenêuticas distintas, por vezes contrapostas, de acordo com a pré-compreensão do intérprete. Esse fenômeno se revela em questões que são controvertidas em todo o mundo, inclusive no Brasil, como, por exemplo, interrupção de gestação, pesquisas com células-tronco embrionárias, eutanásia/ortotanásia, uniões homoafetivas, em meio a inúmeras outras.⁶⁷ **Nessas matérias, como regra**

geral, o papel do direito e do Estado deve ser o de assegurar que cada pessoa possa viver sua autonomia da vontade e suas crenças. Ainda assim, inúmeras complexidades surgem, motivadas por visões filosóficas e religiosas diversas”.⁶⁸

■ 3.8. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS

Conforme anotou o Min. Celso de Mello, em interessante julgado, a **teoria dos poderes implícitos** decorre de doutrina que, tendo como precedente o célebre caso *McCULLOCH* v. *MARYLAND* (1819), da Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelece: “... a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos” (MS 26.547-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.05.2007, DJ de 29.05.2007).

Podemos acrescentar que os meios implicitamente decorrentes das atribuições estabelecidas de modo explícito devem passar por uma análise de **razoabilidade** e **proporcionalidade**.

Encontramos alguns precedentes na jurisprudência pátria.

Em um primeiro caso, o STF reconhece o **poder implícito** de concessão de **medidas cautelares** pelo TCU no exercício de suas atribuições explicitamente fixadas no art. 71, CF/88 (MS 26.547-MC/DF).

Em outro precedente, o STF admite a possibilidade de o TJ estadual conhecer e julgar **reclamação** para a preservação de sua competência e a autoridade de suas decisões. Entendeu a Corte que a **reclamação**, situada no âmbito do exercício do **direito de petição** (art. 5.º, XXXIV, “a”) e, tendo em vista o **princípio da simetria** e o da **efetividade das decisões judiciais**, dentro de uma ideia de **poderes implícitos**, poderia ser **apreciada pelo tribunal estadual**, superando, assim, antiga jurisprudência que a fixava como privativa do STF (ADI 2.212) (cf. ADI 2.480, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, DJ de 15.06.2007).

Em outro caso interessante e bastante polêmico, com base na **teoria dos poderes implícitos**, a 2.ª Turma do STF, ao analisar a temática dos **poderes investigatórios do MP**, entendeu que a denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo próprio *Parquet*, não

havendo necessidade de prévio inquérito policial ([RE 535.478](#), Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.10.2008, *DJE* de 21.11.2008. Nesse sentido: [HC 89.837](#), Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2009, 2.^a T., *Inf.* 564/STF e [RHC 83.492](#), j. 16.12.2010).

Enfrentando o tema, o **Pleno** do STF, em momento seguinte, prescrevendo que os arts. 5.º, LIV e LV, 129, III e VIII, e 144, § 1.º, IV, CF/88, **não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia**, nem afastam os poderes de investigação do MP, afirmou a seguinte tese: “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei n. 8.906/94, art. 7.º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado Democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante n. 14), praticados pelos membros dessa Instituição” ([RE 593.727](#), j. 14.05.2015, *DJE* de 04.09.2015. O poder de investigação do MP foi reafirmado pelo STF ao interpretar os incisos IV, VIII e IX do art. 3.º-B do CPP, incluídos pela Lei n. 13.964/2019 — Pacote Anticrime, no julgamento das [ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305](#), Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.08.2023, *DJE* de 19.12.2023).

■ 3.9. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA A INTERPRETAÇÃO PLURALISTA E “PROCEDIMENTAL” DA CONSTITUIÇÃO

SOCIEDADE FECHADA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO	SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO
■ Sociedade fechada ■ Intérpretes jurídicos vinculados às corporações ■ Elemento cerrado ou fechado com <i>numerus clausus</i> de intérpretes da Constituição	■ Interpretação constitucional pela e para a sociedade aberta ■ Sociedade pluralista ■ Intérpretes jurídicos (convivem com os intérpretes da sociedade aberta e pluralista) ■ Órgãos estatais ■ Potências públicas ■ Cidadãos ■ Grupos ■ Sistema público e opinião pública ■ Participantes materiais do processo social ■ “Constituição e realidade constitucional” — incorporação das ciências sociais, teorias jurídico-funcionais e métodos de interpretação voltados para o atendimento do interesse público e do bem-estar geral ■ Subsistência da jurisdição constitucional — juízes e tribunais, normalmente a última palavra na interpretação ■ Direito de participação democrática

	■ Democratização da interpretação constitucional ■ Intérpretes constitucionais em sentido <i>lato</i> (amplo) ■ Maior legitimidade das decisões jurisdicionais em razão da pluralização do debate
--	---

Conforme anotou Gilmar Mendes ao lembrar as lições de Peter Häberle, “não existe norma jurídica, senão **norma jurídica interpretada** (...),⁶⁹ ressaltando que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública (...).⁷⁰ Assim, se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, tem-se, necessariamente, de indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional sobre as forças ativas da *Law in public action*”.⁷¹

Daí propor Häberle que se supere o modelo de interpretação de uma *sociedade fechada* (nas mãos de juízes e em procedimentos formalizados) para a ideia de uma **sociedade aberta dos intérpretes da Constituição**, vale dizer, uma interpretação **pluralista** e **democrática**.

Ao afirmar que a interpretação não mais deve ficar confinada dentro de uma *sociedade fechada*, Häberle propõe a ideia de que a interpretação não possa ficar restrita aos órgãos estatais, mas que deve ser **aberta** para todos os que “vivem” a norma (a Constituição), sendo, assim, esses destinatários, legítimos intérpretes, em um interessante **processo de revisão** da metodologia jurídica tradicional de interpretação.

Häberle observa que, dentro de um conceito mais amplo de hermenêutica, “**cidadãos** e **grupos, órgãos estatais, o sistema público** e a **opinião pública** (...) representam **forças produtivas de interpretação** (...); eles são intérpretes constitucionais em **sentido lato**, atuando nitidamente, pelo menos, como **pré-intérpretes** (...). **Subsiste** sempre a responsabilidade da **jurisdição constitucional**, que fornece, em geral, a última palavra sobre

a interpretação (...). Se se quiser, tem-se aqui uma democratização da interpretação constitucional”.⁷²

Nesse sentido, **quanto mais pluralista for a sociedade, mais abertos serão os critérios de interpretação.**

Finalmente, Häberle observa que “os instrumentos de informação dos juízes constitucionais — não apesar, mas em razão da própria vinculação à lei — devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere às formas gradativas de participação e à própria possibilidade de participação no processo constitucional (especialmente nas audiências e nas ‘intervenções’). Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. A interpretação constitucional realizada pelos juízes pode-se tornar, correspondentemente, mais elástica e ampliativa sem que se deva ou possa chegar a uma identidade de posições com a interpretação do legislador”.⁷³

Nesse sentido, no direito brasileiro, destacamos a figura do ***amicus curiae***⁷⁴ e das **audiências públicas** como importantes instrumentos de pluralização do debate e que serão retomados no *item 6.7.1.16* deste estudo (cf. também no *item 1.6* o debate sobre os **diálogos constitucionais**).

■ 3.10. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO⁷⁵



Imagem sem descrição.

■ 3.10.1. Preâmbulo

■ 3.10.1.1. Esquematização

Estruturalmente, a CF/88 contém um **preâmbulo**, **nove títulos (corpo)** e o **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)**.

Nas provas de concursos, tem sido muito comum o examinador exigir o conhecimento da literalidade do preâmbulo, bem como os direitos e preceitos estabelecidos ou nele referidos. Assim, procuramos, abaixo, esquematizar a leitura para facilitar a memorização:

PREÂMBULO
■ Nós,
■ representantes do povo brasileiro,
■ reunidos em Assembleia Nacional Constituinte
■ para instituir um Estado Democrático,
■ destinado a assegurar o exercício
■ dos direitos sociais e individuais,
■ a liberdade,
■ a segurança,
■ o bem-estar,
■ o desenvolvimento,
■ a igualdade

■ e a justiça
■ como valores supremos
■ de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
■ fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
■ com a solução pacífica das controvérsias,
■ promulgamos,
■ sob a proteção de Deus,
■ a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

■ 3.10.1.2. *Qual a natureza jurídica do preâmbulo? Tem ele relevância jurídica?*

Três são as posições apontadas pela doutrina e sistematizadas por Jorge Miranda: a) **tese da irrelevância jurídica**: o preâmbulo situa-se no domínio da política, sem relevância jurídica; b) **tese da plena eficácia**: tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais, sendo, porém, apresentado de forma não articulada; c) **tese da relevância jurídica indireta**: ponto intermediário entre as duas, já que, muito embora participe “das características jurídicas da Constituição”, não deve ser confundido com o articulado.

Jorge Miranda ensina que o preâmbulo, “... proclamação mais ou menos solene, mais ou menos significativa, anteposta ao articulado constitucional, não é componente necessário de qualquer Constituição, mas tão somente um elemento natural de Constituições feitas em momentos de ruptura histórica ou de grande transformação político social”. Assim,

conclui Miranda, o preâmbulo “não cria direitos ou deveres” e “não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo”.⁷⁶

Nesse sentido, o Min. Carlos Velloso, Relator da ADI 2.076, após interessante estudo, conclui que “o preâmbulo ... não se situa no âmbito do Direito, mas **no domínio da política**, refletindo posição **ideológica** do constituinte (...). **Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica.** O preâmbulo não constitui norma central da Constituição, de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro. O que acontece é que o preâmbulo contém, de regra, proclamação ou exortação no sentido dos princípios inscritos na Carta (...). Esses princípios sim, **inscritos na Constituição**, constituem normas centrais de reprodução obrigatória, ou que não pode a Constituição do Estado-membro dispor de forma contrária, dado que, reproduzidos, **ou não**, na Constituição estadual, incidirão na ordem local...”.⁷⁷

Por todo o exposto, podemos estabelecer, adotando a **tese da irrelevância jurídica**, que o preâmbulo da Constituição não é norma de reprodução obrigatória nos Estados, nem pode servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade.

■ **3.10.1.3. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios? Referida previsão enfraquece a laicidade do Estado brasileiro?**

Não.

Como se sabe, desde o advento da República (Dec. n. 119-A, de 07.01.1890), existe total separação entre o Estado e a Igreja, sendo o Brasil um país **leigo, laico** ou **não confessional**, não existindo, portanto, nenhuma religião oficial da República Federativa do Brasil.⁷⁸

Laicidade não se confunde com **laicismo**. Laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo, uma atitude de intolerância e hostilidade estatal em relação às religiões. Portanto, a **laicidade** é marca da República Federativa do Brasil, e não o laicismo, mantendo-se o Estado brasileiro em posição de neutralidade axiológica, mostrando-se indiferente ao conteúdo das ideias religiosas (cf. voto do Min. Celso de Mello na ADPF 54 — *anencefalia*).

Todas as Constituições pátrias, exceto as de 1891 e 1937, invocaram a “*proteção de Deus*” quando promulgadas, exprimindo, assim, inegável símbolo de religiosidade.⁷⁹

Em âmbito estadual essa realidade se repetiu, com exceção, em sua redação original, da Constituição do Estado do **Acre, que não continha, em um primeiro momento, a referida expressão**.⁸⁰ Tal omissão foi objeto de questionamento no STF pelo Partido Social Liberal. O STF, definindo a questão, além de estabelecer e declarar a **irrelevância jurídica do preâmbulo**, assinalou que a invocação da “*proteção de Deus*” **não é norma de reprodução obrigatória** na Constituição estadual, não tendo força normativa (**ADI 2.076-AC**, Rel. Min. Carlos Velloso).

O STF também confirmou que a invocação a Deus no preâmbulo **não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro**, que, inclusive, nos termos do **art. 5.º, VI**, declara ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias.

Ainda, o **art. 5.º, VIII**, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Finalmente, o **art. 19, I**, determina, tendo em vista a inexistência de religião oficial, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a **colaboração de interesse público**.

Como exemplo de *colaboração de interesse público*, podemos citar a **decretação de ponto facultativo** para os servidores municipais de São Paulo quando, em 11 de maio de 2007, o **Papa Bento XVI** esteve em São Paulo para celebrar a missa de **canonização de Frei Galvão**.

Interessante, ainda, a crítica de José Afonso da Silva: “um Estado leigo não deveria invocar Deus em sua Constituição. Mas a verdade também é que o **sentimento religioso** do povo brasileiro, se não impõe tal invocação, a **justifica**. Por outro lado, para os **religiosos** ela é **importante**. Para os **ateus**, há de ser **indiferente**. Logo, não há por que condená-la. Razão forte a justifica: o *sentimento popular de quem provém o poder constituinte*”.⁸¹

Apesar dessa crítica apresentada por Silva, Branco chega a afirmar que “o Estado brasileiro não é confessional, mas **tampouco é ateu**, como se deduz do preâmbulo da Constituição, que invoca a proteção de Deus. Por isso, admite, ainda que sob a forma de disciplina de matrícula facultativa, o ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental (CF, art. 210, § 1.º), permitindo, assim, o ensino da doutrina de uma dada religião para os alunos interessados. Admite, igualmente, que o casamento religioso produza efeitos civis, na forma do disposto em lei (CF, art. 226, §§ 1.º e 2.º)” (grifamos).⁸²

Cabe lembrar que no dia 27.09.2017, por 6 x 5, o STF julgou **improcedente** a **ADI 4.439**, ajuizada pela PGR, tendo por objeto o art. 33, *caput* e §§ 1.º e 2.º, da Lei n. 9.394/96 (*Lei de Diretrizes e Bases da Educação — LDB*) e o art. 11, § 1.º, do acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé, aprovado pelo DL n. 698/2009 e promulgado pelo Decreto n. 7.107/2010, estabelecendo que o **ensino religioso** nas escolas públicas de ensino fundamental, que constituirá disciplina dos horários normais, **poderá ter natureza confessional**, na medida em que a sua matrícula é **facultativa** nos termos do citado art. 210, § 1.º, CF/88 (cf. *itens* 7.3.4.2.6 e 14.10.6.2).

Daniel Sarmiento, por sua vez, estabelece que “**Estado laico não significa Estado ateu**, pois o ateísmo não deixa de ser uma concepção religiosa. Na verdade, o **Estado laico** é aquele que mantém uma postura de **neutralidade** e **independência** em relação a todas as concepções religiosas, em respeito ao **pluralismo** existente em sua sociedade”.⁸³

Esse posicionamento doutrinário, de não se confundir **Estado laico** com **Estado ateu**, encontra reconhecimento no voto do Min. Marco Aurélio no julgamento da **ADPF 54 (anencefalia)**, ao afirmar que o Brasil é um Estado secular tolerante, ou seja, “o Estado não é religioso, **tampouco é ateu**. O Estado é simplesmente **neutro**”.

Assim, continua, “a crença religiosa e espiritual — ou a ausência dela, o ateísmo — serve precipuamente para ditar a **conduta** e a **vida privada** do indivíduo que a possui ou não a possui. **Paixões religiosas de toda ordem não de ser colocadas à parte na condução do Estado**. Não podem a fé e as orientações morais dela decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja” (fls. 44).

Do mesmo entendimento, com precisão, Daniel Sarmiento, ao afirmar que “... as razões religiosas são válidas na esfera da consciência de cada um, mas não podem ser o fundamento dos atos estatais”.⁸⁴

Por todo o exposto, podemos sustentar que o **preâmbulo não tem relevância jurídica, não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória**, servindo, apenas, como **norte interpretativo das normas constitucionais**. Por essas características e por não constituir norma central, a invocação à divindade **não é de reprodução obrigatória** nos preâmbulos das Constituições estaduais e leis orgânicas do DF e dos Municípios. Conforme visto, o Brasil é um país **leigo, laico** ou **não confessional, lembrando que Estado laico não significa Estado ateu**.

■ 3.10.2. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)

■ 3.10.2.1. Apontamentos gerais sobre o ADCT

Disposições Constitucionais Transitórias são encontradas nas Constituições brasileiras anteriores, exceto na primeira, de 1824.

Nas Constituições de 1891, 1934 e 1946, assim como na atual, de 1988, o **ADCT** aparece como **ato destacado**, possuindo, respectivamente, 8, 26 e 36 artigos, sendo que, na redação original da CF/88, promulgada em 5 de outubro, o texto continha **70** artigos, estando, atualmente, com **137**, em razão de reformas constitucionais.

Nos textos autoritários de 1937, 1967 e na EC n. 1/69, as disposições transitórias foram apresentadas em conjunto, no mesmo título, com as *disposições finais ou gerais*.

Outra característica interessante dos textos nos quais o **ADCT** se apresenta de **forma destacada** (inclusive com promulgação autônoma em relação às disposições do corpo)⁸⁵ é a particular **técnica redacional** de se iniciar uma **nova numeração dos artigos**, bem como a inexistência de divisão em *títulos, capítulos, seções* ou *subseções*.

Conforme observou Raul Machado Horta, “os temas são tratados indistintamente, sem a preocupação de ordenação, unidade e sistematização. É o terreno do depósito residual, da miscelânea e da mistura normativa. O traço que aproxima as normas heterogêneas é a temporariedade e a transitoriedade”.⁸⁶

■ 3.10.2.2. **Finalidade do ADCT**

A finalidade do ADCT é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, instituído pela manifestação do poder constituinte originário, providenciando a **acomodação** e a **transição** do antigo e do novo direito edificado.

Segundo Barroso, “destinam-se as normas dessa natureza a auxiliar na transição de uma ordem jurídica para outra, procurando neutralizar os efeitos nocivos desse confronto, no tempo, entre regras de igual hierarquia — Constituição nova *versus* Constituição velha — e de hierarquia diversa

— Constituição nova *versus* ordem ordinária preexistente”,⁸⁷ interligando-se, portanto, nesse aspecto, com o instituto da *recepção*.

Observa-se, assim, por consequência, que, historicamente, algumas constituições, em outros países, **não estabeleceram regras de transição**, sobretudo quando o novo regime apresentava-se totalmente desvinculado da organização político-jurídica que até então vigorava, rompendo-se de modo revolucionário.

Como exemplo, podemos identificar a *Constituição norte-americana de 1787*, que estabeleceu a federação (superando o imperialismo britânico e extinguindo o modelo confederativo), bem como a *francesa de 1791*, que, abolindo o feudalismo e o antigo regime, consagrou “(...) a Monarquia Constitucional, a representação política fundada na soberania nacional e os direitos naturais e imprescritíveis do homem: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”.⁸⁸

Nesse sentido, destacou Raul Machado Horta: “as Constituições vinculadas **às transformações profundas da ordem social, política e econômica** não se preocupam com a inclusão de normas ou disposições transitórias em seu texto.”⁸⁹ Voltadas para a edificação de nova Sociedade, as Constituições revolucionárias, que demoliram e substituíram os fundamentos do antigo regime, não se interessam pelas normas de acomodação e de transição entre o direito anterior e o novo direito. A teleologia do constitucionalismo revolucionário repele acomodações que embarçam a construção do novo Direito e a edificação criadora de nova estrutura social, política e econômica”.⁹⁰

■ 3.10.2.3. *Classificação das disposições do ADCT*

Analisando o seu conteúdo durante o ano inicial de sua vigência, **Raul Machado Horta** identificou as seguintes categorias normativas:⁹¹

■ **normas exauridas:** aquelas que já desapareceram, em virtude da realização da condição ou do ato nela previstos, como, por exemplo, os arts. 1.º; 4.º, § 4.º; 15 etc.;

■ **normas dependentes de legislação e de execução:** arts. 10, § 1.º; 12, § 1.º; 14, §§ 1.º, 2.º e 4.º etc.;

■ **normas dotadas de duração temporária expressa:** art. 40, que manteve, por 25 anos, a partir da promulgação da Constituição, a Zona Franca de Manaus (prazo esse acrescido de 10 anos pela EC n. 42/2003, nos termos do art. 92, ADCT, e, findo esse prazo, acrescido de mais 50 anos, nos termos da EC n. 83/2014, nos termos do art. 92-A, também do ADCT); art. 42, também alterado por emenda, modificando as regras de transição;

■ **normas de recepção:** art. 34, § 5.º; art. 66 etc.;

■ **normas sobre benefícios e direitos:** arts. 53 e 54, que asseguraram direitos;⁹²

■ **normas com prazos constitucionais ultrapassados:** nessa classificação, o autor identificou, à época (no primeiro ano de vigência do ADCT), todos os artigos que dependiam de legislação para sua implementação, como o art. 29, § 1.º, que fixava prazo para o encaminhamento de projeto de lei complementar dispendo sobre a organização e o funcionamento da AGU, e o art. 48, ADCT, que estabelecia prazo para que o Congresso Nacional elaborasse o *Código de Defesa do Consumidor*. Muitos dispositivos, como os citados, já foram regulamentados.

Por sua vez, **Barroso**,⁹³ identificando espécies distintas de disposições transitórias, estabeleceu três categorias:

■ **disposições transitórias propriamente ditas:** são as disposições típicas que regulam de modo transitório determinadas relações, estando sujeitas a condição resolutiva ou termo. Como exemplo, o autor lembra o art. 10, § 1.º,⁹⁴ e o art. 23, *caput*,⁹⁵

■ **disposições de efeitos instantâneos e definitivos:** essas disposições não aguardam uma condição ou um termo, operando imediatamente ou no prazo estabelecido. Nesse sentido, podemos citar o art. 13, *caput*, ADCT, que criou o Estado do Tocantins, ou o art. 15, que extinguiu o Território Federal de Fernando de Noronha, reincorporando a sua área ao Estado de Pernambuco;

■ **disposições de efeitos diferidos:** são aquelas que “sustam a operatividade da norma constitucional por prazo determinado ou até a ocorrência de um determinado evento”. Como exemplo, o autor menciona o art. 5.º, *caput*, ADCT, que determinou a não aplicação do disposto no art. 16 e das regras do art. 77 do corpo da Constituição às eleições previstas para 15.11.1988.

■ 3.10.2.4. *O natural exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento*

Vimos que as disposições transitórias, como o próprio nome já sinaliza, exercem o papel de **acomodação** e **transição** do ordenamento jurídico anterior com a nova ordem constitucional.

Por natureza, portanto, diante de sua **eficácia temporária** (essa a ideia das disposições de transição), após produzirem os seus efeitos, ou diante do advento da condição ou termo estabelecidos, **esgotam-se**, tornando-se normas de **eficácia exaurida**.

Nesse momento, aponta José Afonso da Silva, a norma do ADCT que se esgotou “... não é mais norma jurídica, mas **simples proposição sintática**, com **valor meramente histórico**”, não mais se restabelecendo.⁹⁶

Daí, Raul Machado Horta conclui que “**norma permanente** nas Disposições Transitórias é **norma anômala**. Foi dessa categoria o conhecido art. 180⁹⁷ da Carta de 1937, que, prevendo competência transitória do Presidente da República — ‘enquanto não se reunir o Parlamento Nacional’ —, como a condição não se verificou na vigência da Carta de 1937, o art. 180 tornou-se regra permanente, para fundamentar a

pletórica atividade legislativa do Presidente da República na via dos Decretos-leis”.⁹⁸

Essa sistemática, contudo, vem sendo desvirtuada pelo constituinte reformador, que, por vezes, introduziu, por emenda ao ADCT, normas **permanentes, sem qualquer conteúdo de direito intertemporal e sem qualquer conexão com o momento de transição**, em total *atecnia legislativa*, como, por exemplo, o seu art. 96 (acrescentado pela EC n. 57/2008), que, de modo inconstitucional (e, por que não dizer, imoral), convalidou a criação de municípios em total violação ao art. 18, § 4.º, CF/88 (cf. *item 6.7.4.9*).

■ 3.10.2.5. **Qual a natureza jurídica das disposições do ADCT?**

O ADCT, como o nome já induz (Ato das Disposições **Constitucionais** Transitórias), tem **natureza jurídica de norma constitucional** e poderá, portanto, trazer exceções às regras colocadas no corpo da Constituição. Assim como no corpo encontramos regras (por exemplo, tratamento igual entre brasileiro nato e naturalizado, art. 12, § 2.º) e exceções a essas regras (por exemplo, art. 12, § 3.º, I, que reserva o cargo de Presidente da República somente para brasileiros natos), também o ADCT poderá excepcionar regras gerais do corpo,⁹⁹ por apresentar a mesma natureza jurídica delas.

Dessa forma, **em virtude de sua natureza constitucional**, a alteração das normas do ADCT ou o acréscimo de novas regras dependerão da manifestação do *poder constituinte derivado reformador*, ou seja, necessariamente por meio de **emendas constitucionais**, que, por sua vez, deverão observar os **limites ao poder de reforma** (cf., abaixo, *item 3.10.2.6*), sendo que essas disposições novas estabelecidas por emenda serão suscetíveis ao controle de constitucionalidade. Também, em razão de sua natureza jurídica, as disposições do ADCT servirão de **parâmetro** ou **paradigma de confronto** para a análise da constitucionalidade dos demais

atos normativos. Nesse sentido decidiu a Corte (**RE 160.486**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, 1.^a T., *DJ* de 09.06.1995. No mesmo sentido: **RE 215.107-AgR**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.11.2006, 2.^a T., *DJ* de 02.02.2007).

■ 3.10.2.6. *As disposições do ADCT estão imunes ao poder de reforma?*

Diante da constatação de diversas emendas ao ADCT (lembre de que, originalmente, ele foi promulgado com 70 artigos, contendo, atualmente, **137**), temos de analisar a possibilidade ou não de reformas das disposições transitórias em razão da manifestação do *poder constituinte derivado reformador*. Ou seja, poderiam, de fato, as normas do ADCT ter sofrido alterações (modificações ou acréscimos) por emenda?

Entendemos que, se a norma de transição já se tiver **exaurido**, nesse caso específico, não pareceria razoável o Constituinte reformador *modificar* o sentido da transição já concretizado conforme estabelecido pelo *poder constituinte originário*, até porque, como se afirmou, nessa hipótese, a norma de transição estará **esgotada**.

Por outro lado, se o comando de transição não se tiver realizado e a disposição produzido os seus efeitos, entendemos possível a sua alteração, desde que sejam observados, naturalmente, os **princípios intangíveis** e os **limites ao poder de reforma**, explícitos e implícitos (cf. *item 9.14.1*).

Assim, um direito fundamental estabelecido no ADCT, por exemplo, o art. 68, que reconhece, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, não poderia ser subtraído por meio de reforma (emenda constitucional) por violar o limite material da **cláusula pétrea** contida no art. 60, § 4.^o, IV.

Nesses casos, citando os exemplos dos arts. 8.^o (concessão de anistia) e 19 (concessão de estabilidade no serviço público), ADCT, pelos quais se **atribuiu um regime vantajoso a um grupo concreto de destinatários**,

consoante observa Branco, “... pode-se reconhecer que o constituinte originário quis investir beneficiários certos em direitos determinados, de tal sorte que, se o constituinte de reforma lhes subtraísse ou diminuísse a vantagem, estaria perpetrando, senão um ataque à cláusula pétrea da segurança jurídica ou do direito adquirido, certamente que uma fraude ao constituinte originário”.¹⁰⁰

Por outro lado, a EC n. 2/92, que antecipou a data do plebiscito de que trata o art. 2.º, ADCT, do dia 07.09.1993 para o dia 21.04.1993, foi considerada constitucional pelo STF. Dessa forma, no referido *leading case*, a **Corte** passou a **admitir**, explicitamente, a **alteração de disposições do ADCT por emenda** desde que, é claro, fossem respeitados os limites ao poder de reforma.

Em seu voto, o Min. Moreira Alves, Relator, **reconhecendo o caráter constitucional das normas do ADCT**, não admitiu qualquer natureza de imutabilidade em razão de sua transitoriedade, **reconhecendo-se**, nesses termos, **a possibilidade de reforma**, desde que, é claro, como se disse, fossem observados os limites ao poder de reforma. Vejamos:

“(...) a transitoriedade em si mesma não torna impossível a alteração de norma constitucional dessa natureza. Com efeito, se é possível alterar-se, por emenda, a regra da parte permanente para estender-se a todos, e sem limitações, o que a exceção transitória outorgava a alguns com limitações; se é possível criar-se exceção permanente à regra também permanente; é **absolutamente ilógico pretender-se que a exceção transitória, por causa da sua transitoriedade, seja imutável, inclusive para restringir-se ou dilargar-se o período da transitoriedade**” (ADI 829, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.04.1993, Plenário, DJ de 16.09.1994).

■ 3.11. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

3

HERMENÊUTICA: MUTAÇÃO X REFORMA. REGRAS X PRINCÍPIOS. “DERROTABILIDADE”. POSTULADOS NORMATIVOS. CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO

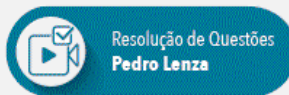
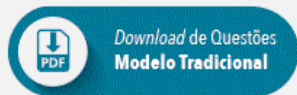


 Imagem sem descrição.

4

Poder Constituinte

4.1. Esquema geral

 Imagem sem descrição.

4.2. CONCEITO E TITULARIDADE

De acordo com a lição de Canotilho, “o poder constituinte se revela sempre como uma questão de ‘poder’, de ‘força’ ou de ‘autoridade’ política que está em condições de, numa determinada situação concreta, **criar, garantir** ou **eliminar** uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política” (grifamos).¹

A **titularidade** do poder constituinte, como aponta a doutrina moderna, pertence ao **povo**. Nesse sentido, Canotilho afirma que “poder constituinte significa, assim, **poder constituinte do povo**”, e que deve ser concebido “como uma ‘grandeza pluralística’ (Peter Häberle), ou seja, como uma pluralidade de forças culturais, sociais e políticas tais como partidos, grupos, igrejas, associações, personalidades, decisivamente influenciadoras da formação de ‘opiniões’, ‘vontades’, ‘correntes’ ou ‘sensibilidades’ políticas nos momentos preconstituintes e nos procedimentos constituintes”.²

Nesse sentido, seguindo a tendência moderna, o parágrafo único do art. 1.º, CF/88: “todo o poder emana do **povo**, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (democracia semidireta ou participativa — cf. *cap. 17*).

4.3. HIATO CONSTITUCIONAL (REVOLUÇÃO — MUTAÇÃO — REFORMA — HIATO AUTORITÁRIO)

A expressão “**hiato constitucional**” se deve a Ivo Dantas, quando desenvolveu o tema em sua dissertação de mestrado defendida em 1976.³

Dantas analisa a relação entre o “direito legislado”, a “Constituição política” e a “sociedade” ou “realidade social”.

O **hiato constitucional**, também chamado pelo autor de **revolução**, verifica-se quando há um **choque** (ou “divórcio”) entre o conteúdo da *Constituição política* (uma das formas do *direito legislado*) e a *realidade social ou sociedade*.

De acordo com o que define, a **dinâmica constitucional** (Garcia Pelayo) pode ser caracterizada como “... a constante tentativa de adaptar o texto político às *novas realidades-valores sociais*, o que, quando inexistente, dará margem a **Hiato Constitucional** ou, se desejarem, **Revolução...**”.

Assim, a “revolução” deve ser encarada “... como uma quebra do processo político e histórico normal da organização política”.

Tomando por base essa ideia, qual seja, que o *hiato constitucional* caracteriza verdadeira **lacuna, intervalo, interrupção de continuidade**, entendemos que vários fenômenos poderão ser verificados, destacando-se:

- convocação da **Assembleia Nacional Constituinte** e elaboração de nova Constituição;
- **mutação constitucional**;
- **reforma constitucional**;
- **hiato autoritário**.

A partir da quebra do processo constitucional, vale dizer, diante da não correspondência entre o texto posto e a realidade social, poderá surgir espaço para o denominado “momento constituinte” democrático e, assim, diante da manifestação do *poder constituinte originário*, a elaboração de novo documento que encontre legitimidade social.

Ainda, diante da *lacuna* poderá também ser verificada a necessidade de mudança no sentido interpretativo da norma posta, ou seja, o instituto, já desenvolvido no *item 3.1*, da **mutação constitucional**, pelo qual a “letra fria” do texto é mantida,

mas se atribui um novo sentido interpretativo, nos exatos termos da realidade social evolutiva.

Em outro sentido, o vácuo de correspondência poderá sinalizar a necessidade de manifestação (formal) do **poder de reforma**, por meio das emendas constitucionais, fazendo com que haja a manifestação do *poder constituinte derivado reformador*.

Finalmente, a *quebra* poderá dar espaço para a ilegítima outorga constitucional, manifestando-se o poder autoritário e fazendo com que o *hiato constitucional* se transforme em **hiato autoritário**, que persistirá mesmo diante da edição de textos (ilegítimos) como foi, por exemplo, durante o regime militar, o AI-5, textos que buscam suprir o hiato constitucional, mas, por falta de legitimidade, sucumbem, abrindo espaço para o nefasto e combatido *hiato autoritário*.

4.4. Poder constituinte originário (GENUÍNO OU DE 1.º GRAU)

4.4.1. Conceito

O **poder constituinte originário** (também denominado **inicial, inaugural, genuíno** ou de **1.º grau**) é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente.

O objetivo fundamental do poder constituinte originário, portanto, é **criar um novo Estado**, diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente.

Reproduzimos interessante conceituação trazida por Temer a respeito do assunto: “ressalte-se a ideia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, provenha ela de movimento revolucionário ou de assembleia popular. O Estado brasileiro de 1988 não é o de 1969, nem o de 1946, o de 1937, de 1934, de 1891, ou de 1824. Historicamente é o mesmo. Geograficamente pode ser o mesmo. Não o é, porém, juridicamente. A cada manifestação constituinte, editora de atos constitucionais como Constituição, Atos Institucionais e até Decretos (veja-se o Dec. n. 1, de 15.11.1889, que proclamou a República e instituiu a Federação como forma de Estado), nasce o Estado. Não importa a rotulação conferida ao ato constituinte. Importa a sua natureza. Se dele decorre a certeza de rompimento com a ordem jurídica anterior, de edição normativa em desconformidade

intencional com o texto em vigor, de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se novo Estado”.⁴

4.4.2. Uma subdivisão

O poder constituinte originário pode ser subdividido em **histórico** (ou **fundacional**) e **revolucionário**. *Histórico* seria o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando, pela primeira vez, o Estado. *Revolucionário* seriam todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando uma nova, um novo Estado.

4.4.3. Características

O poder constituinte originário é *inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, um poder de fato e político, permanente*.

a) inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por completo, com a ordem jurídica anterior;

b) autônomo, visto que a estruturação da nova constituição será determinada, autonomamente, por quem exerce o poder constituinte originário;

c) ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de respeitar os limites postos pelo direito anterior, com as ressalvas a seguir indicadas e que passam a ser uma tendência para os concursos públicos;

d) incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem de submeter-se a qualquer forma prefixada de manifestação;

e) poder de fato e poder político, podendo, assim, ser caracterizado como uma energia ou força social, tendo natureza pré-jurídica, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação, e não antes dela;

f) permanente, já que o poder constituinte originário não se esgota com a edição da nova Constituição, **sobrevivendo** a ela e fora dela como forma e expressão da **liberdade humana**, em verdadeira ideia de **subsistência**. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, essa

característica decorre de fórmula clássica prevista no art. 28 da *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão*, editada como *preâmbulo da Constituição francesa de 1793* e “... no sentido de que o homem, embora tenha tomado uma decisão, pode rever, pode mudar posteriormente essa decisão...”.⁵ Isso não significa que o poder constituinte originário permanente e “adormecido” sairá desse estado de “hibernação” e de “latência” a todo e qualquer momento, até porque instauraria indesejada insegurança jurídica. Para tanto, deve haver o “momento constituinte”, uma situação tal que justifique e requeira a **quebra abrupta** da ordem jurídica.

Lembramos, contudo, a corrente *jusnaturalista*, para a qual o poder constituinte originário não seria totalmente autônomo na medida em que haveria uma limitação imposta: ao menos o respeito às normas de direito natural. Como o Brasil adotou a corrente **positivista**, o poder constituinte originário é totalmente ilimitado (do ponto de vista jurídico, reforce-se), apresentando natureza **pré-jurídica**, uma energia ou força social, já que a ordem jurídica começa com ele e não antes dele. Assim, para o Brasil e os positivistas, nem mesmo o *direito natural* (por alguns denominado *direito suprapositivo*)⁶ limitaria a atuação do poder constituinte originário.

Anota J. H. Meirelles Teixeira: “... esta *ausência de vinculação*, note-se bem, é apenas de caráter *jurídico-positivo*, significando apenas que o Poder Constituinte não está ligado, em seu exercício, por *normas jurídicas anteriores*. Não significa, porém, e nem poderia significar, que o Poder Constituinte seja um poder arbitrário, absoluto, que não conheça quaisquer limitações. *Ao contrário, tanto quanto a soberania nacional, da qual é apenas expressão máxima e primeira, está o Poder Constituinte limitado pelos grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral, da razão.* Todos estes grandes *princípios, estas exigências ideais*, que não são jurídico-positivas, devem ser respeitados pelo Poder Constituinte, para que este se exerça legitimamente. O Poder Constituinte deve acatar, aqui, ‘a voz do reino dos ideais promulgados pela consciência jurídica’, na bela expressão de Recaséns Siches”.⁷

Nesse sentido, **afastando-se** da ideia de *onipotência do poder constituinte* derivada da *teologia política* “... que envolveu a sua caracterização na Europa da Revolução Francesa (1789)”, atualmente ultrapassada, posiciona-se Canotilho, o qual, sugerindo ser entendimento da doutrina moderna, observa que o *poder constituinte* “... é estruturado e obedece a **padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais** radicados na consciência jurídica geral da

comunidade e, nesta medida, considerados como ‘vontade do povo’”. Fala, ainda, na necessidade de observância de **princípios de justiça** (suprapositivos e supraleais) e, também, dos **princípios de direito internacional** (princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de direitos humanos — neste último caso de vinculação jurídica, chegando a doutrina a propor uma juridicização e evolução do poder constituinte).⁸

Paulo Branco também perfilha o entendimento da existência de **limitações políticas** inerentes ao exercício do poder constituinte originário.

Em suas palavras, “se o poder constituinte é a **expressão da vontade política da nação**, não pode ser entendido sem a referência aos **valores éticos, religiosos, culturais** que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Por isso, um grupo que se arrogue a condição de representante do poder constituinte originário, se se dispuser a redigir uma Constituição que hostilize esses valores dominantes, não haverá de obter o acolhimento de suas regras pela população, não terá êxito no seu empreendimento revolucionário e **não será reconhecido como poder constituinte originário**. Afinal, só é dado falar em atuação do poder constituinte originário se o grupo que diz representá-lo colher a anuência do povo, ou seja, se vir ratificada a sua invocada representação popular. Do contrário, estará havendo apenas uma insurreição, a ser sancionada como delito penal. Quem tenta romper a ordem constitucional para instaurar outra e não obtém a adesão dos cidadãos não exerce poder constituinte originário, mas age como rebelde criminoso” (grifamos).⁹

4.4.4. Poder constituinte originário formal e material

A doutrina ainda fala em poder constituinte *formal* e *material*:

■ **formal:** é o ato de criação propriamente dito e que atribui a “roupagem” com *status* constitucional a um “complexo normativo”;

■ **material:** é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o *status* de norma constitucional. Assim, será o orientador da atividade do constituinte originário formal que, por sua vez, será o responsável pela “roupagem” constitucional. O material diz o que é constitucional; o formal materializa e sedimenta como constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados.

Assim, para Jorge Miranda, o **poder constituinte formal** confere “... *estabilidade e garantia* de permanência e de supremacia hierárquica ou sistemática ao princípio normativo inerente à **Constituição material**. Confere *estabilidade*, visto que a certeza do Direito exige o estatuto da regra. Confere *garantia*, visto que só a Constituição formal coloca o poder constituinte material (ou o resultado da sua ação) ao abrigo das vicissitudes da legislação e da prática quotidiana do Estado e das forças políticas” (grifamos).¹⁰

4.4.5. Formas de expressão

Duas são as formas de expressão do poder constituinte originário: **a) outorga; b) assembleia nacional constituinte (ou convenção)**.

■ **outorga:** caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário (movimento revolucionário — exemplo: Constituições de 1824, 1937, 1967 e EC n. 1/69, lembrando que a Constituição de 1946 já havia sido suplantada pelo Golpe Militar de 1964 — *AI 1, de 09.04.1964*). Conforme vimos, embora a Constituição de 1946 continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e Complementares, com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e “drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil;

■ **assembleia nacional constituinte ou convenção:** por seu turno, nasce da deliberação da representação popular, destacando-se os seguintes exemplos: CF de 1891, 1934, 1946 e 1988.

4.4.6. A proposta de convocação de uma “assembleia nacional constituinte exclusiva e específica” para a reforma política: aberração jurídica; violência ao sistema

Inegavelmente, o Estado brasileiro precisa passar pela “engavetada” e necessária **reforma política** e, como se sabe, dentro do modelo atual, o instrumento para a sua implementação seria uma proposta de emenda à Constituição (**PEC**).

Buscando dar uma resposta aos vários movimentos sociais que tomaram conta do país no ano de 2013 (manifestações, passeatas, reivindicações etc.), deflagrados pelo aumento das tarifas de ônibus (e, claro, todos sabem que não foram os “vinte centavos” o fator de mobilização e do descontentamento com o modelo de representação), a então Presidente Dilma Rousseff, em discurso um pouco tardio,

enaltecendo a “voz das ruas”, propôs a **convocação de uma assembleia nacional constituinte exclusiva e específica para a reforma política**.

Em suas palavras, ditas na abertura da reunião com governadores e prefeitos realizada em **24.06.2013**, propondo soluções para a crise, sugeriu *5 pactos nacionais* (responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transportes públicos e educação pública). No tocante à **reforma política**, sugeriu a sua implementação por meio de uma **constituinte exclusiva**, autorizada por **plebiscito popular**.^{[11](#)}

Nesse ponto, com o máximo respeito, mesmo que buscando “escutar a voz das ruas”, mesmo que houvesse legitimação por plebiscito popular, admitir uma **constituinte específica** ensejaria total **afronta** à Constituição.

Conforme dissemos e retomamos a seguir, a única maneira de se alterar a Constituição no momento atual é mediante a aprovação de uma PEC, com todos os limites explícitos e estabelecidos no art. 60, CF/88, bem como os limites implícitos que decorrem do sistema.

A proposta de se estabelecer uma constituinte exclusiva e específica seria o mesmo que admitir uma parcial manifestação do poder constituinte originário, o que, por suas características e forma de expressão, seria inimaginável.

O **poder constituinte originário** (também denominado **inicial, inaugural, genuíno** ou de **1.º grau**), ao se manifestar, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente, cria o novo Estado desvinculado do que então vigorava, saindo do seu estado de “hibernação” e “latência”, em razão da existência de inquestionável “momento constituinte”.

Não é o caso. Não se vislumbra esse tal “momento constituinte”. A convocação de instrumento de alteração específico afrontaria, dentre outros, a **implícita proibição de se alterar a titularidade do poder constituinte originário**, bem como a do **poder de reforma que se implementa por ato exclusivo do Congresso Nacional**, assim como os seus limites colocados na Constituição.

É preciso, sim, escutar a voz do povo, mas não se pode violentar o processo de reforma da Constituição.

Como alternativa, e o tema precisa ser amadurecido, poderíamos pensar nos instrumentos de soberania popular (e esse passou a ser o novo discurso de Dilma Rousseff), destacando-se o plebiscito e o referendo, não para se dar um “cheque em branco” para a tal constituinte parcial e específica, mas para **referendar** — e

esse seria um modelo melhor — uma eventual alteração que fosse concretizada e, claro, respeitando o modelo constitucional, qual seja, por **necessária e formal proposta de emenda**, nos **limites das regras estabelecidas pelo poder constituinte originário**.

4.4.7. “Lipoaspiração constitucional” e a proposta de realização de plebiscito para a elaboração de uma nova Constituição

Durante a vigência da atual Constituição, várias propostas surgem para a sua reforma. O tema, dada a sua complexidade e constante discussão, está sendo abordado em vídeo na plataforma.

4.5. Poder constituinte derivado (instituído, constituído, secundário, de 2.º grau ou remanescente)

4.5.1. Conceito e espécies

PODER CONSTITUINTE

■ Poder constituinte originário

■ Poder de fato¹²

■ Poder constituinte derivado

■ Poder político

■ Energia ou força social

■ Natureza jurídica

■ Natureza pré-jurídica

■ A ordem jurídica começa com o poder constituinte originário e não antes dele

O **poder constituinte derivado** é também denominado **instituído, constituído, secundário, de segundo grau, remanescente**.

Como o próprio nome sugere, o poder constituinte *derivado* é criado e instituído pelo *originário*.

Ao contrário de seu “criador”, que é, do ponto de vista jurídico, ilimitado, incondicionado, inicial, o *derivado* deve obedecer às regras colocadas e impostas pelo *originário*, sendo, nesse sentido, limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos.

Alguns autores preferem a utilização da terminologia *competências*, em vez de poder constituinte derivado, pois só seria poder constituinte o que derivasse diretamente da soberania popular e fosse ilimitado. No entanto, mantemos a utilização da expressão “poder constituinte” na medida em que dele decorre a produção de normas de caráter constitucional. (Nas provas preambulares também vem sendo, de maneira geral, utilizada a nomenclatura “poder constituinte derivado”).

Derivam, pois, do originário o **reformador**, o **decorrente** e o **revisor**. Vejamos cada um deles.

4.5.2. Poder constituinte derivado reformador

O **poder constituinte derivado reformador**, chamado por alguns de *competência reformadora*,¹³ tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira *revolução*.

O poder de reforma constitucional, assim, tem **natureza jurídica**, ao contrário do originário, que é um *poder de fato*, um poder *político*, ou, segundo alguns, *uma força ou energia social*.¹⁴

A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se através das **emendas constitucionais** (arts. 59, I, e 60, CF/88), que abordaremos melhor quando tratarmos das espécies normativas.

Neste momento, já adiantamos algumas características do poder de reforma, decorrentes de sua natureza constituída, instituída, ou de segundo grau. Como vimos, ao contrário do originário, que é incondicionado, o **derivado é condicionado** pelas regras colocadas pelo originário, este último, sim, um poder de fato que tudo pode!

Enfim, o originário permitiu a alteração de sua obra, mas obedece a alguns limites como: *quorum* qualificado de 3/5, em cada Casa, em dois turnos de votação para aprovação das emendas (art. 60, § 2.º); proibição de alteração da

Constituição na vigência de estado de sítio, defesa, ou intervenção federal (art. 60, § 1.º), um núcleo de matérias intangíveis, vale dizer, as *cláusulas pétreas* do art. 60, § 4.º, CF/88, etc.

Dessa forma, além das **limitações expressas** ou **explícitas** (*formais ou procedimentais* — art. 60, I, II, III e §§ 2.º, 3.º e 5.º; *circunstanciais* — art. 60, § 1.º; e *materiais* — art. 60, § 4.º), a doutrina identifica, também, as **limitações implícitas** (como *impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador*, bem como a *proibição de se violar as limitações expressas*, não tendo sido adotada, no Brasil, portanto, a *teoria da dupla revisão*, ou seja, uma primeira revisão acabando com a limitação expressa e a segunda reformando aquilo que era proibido).¹⁵

4.5.3. Poder constituinte derivado decorrente

4.5.3.1. Estados-Membros

O **poder constituinte derivado decorrente**,¹⁶ assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário.

Sua missão é **estruturar** a Constituição dos Estados-Membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, **modificá-la**. Tal competência decorre da capacidade de **auto-organização** estabelecida pelo poder constituinte originário. Como veremos ao tratar dos Estados-Membros, no tópico Federação (*item 7.3*), a eles foi atribuída *autonomia*, manifestada pela capacidade de **auto-organização** (art. 25, *caput*); **autogoverno** (arts. 27, 28 e 125, que estabelecem regras para a estruturação dos “Poderes” Legislativo: *Assembleia Legislativa*; Executivo: *governador do Estado*; e Judiciário: *Tribunais e juízes*) e **autoadministração** (arts. 18 e 25 a 28 — regras de competência legislativas e não legislativas, que serão oportunamente estudadas).

Segundo Anna Cândida da Cunha Ferraz, em uma das mais completas monografias sobre o tema no direito pátrio, o poder constituinte derivado decorrente se divide em **duas modalidades**:

■ **poder constituinte decorrente inicial (“instituidor” ou “institucionalizador”)**: responsável pela **elaboração** da Constituição estadual. Como anotou Anna Cândida, “... intervém para exercer uma tarefa de caráter nitidamente constituinte, qual seja a de estabelecer a

organização fundamental de entidades componentes do Estado Federal. Tem o Poder Constituinte Decorrente um caráter de complementaridade em relação à Constituição; destina-se a perfazer a obra do Poder Constituinte Originário nos Estados Federais, para estabelecer a Constituição dos seus Estados componentes”;¹⁷

■ **poder constituinte decorrente de revisão estadual (“poder decorrente de segundo grau”)**: tem a finalidade de **modificar** o texto da Constituição estadual, implementando as reformas necessárias e justificadas e nos *limites* colocados na própria constituição *estadual* (nesse sentido, por derivar de um poder que já derivou de outro, caracteriza-se como de *segundo grau*)¹⁸ e na *federal*.

Pois bem, em relação à *capacidade de auto-organização*, prevista no art. 25, *caput*, CF/88, foi categórico o poder constituinte originário ao definir que “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, **observados os princípios desta Constituição**”. Esta última parte do texto demonstra, claramente, o caráter de derivação e vinculação do poder decorrente em relação ao originário; vale dizer, os Estados têm a capacidade de auto-organizar-se, desde que, é claro, observem as regras que foram estabelecidas pelo poder constituinte originário. Havendo afronta, estaremos diante de um vício formal ou material, caracterizador da inconstitucionalidade.

E o que deve ser entendido por **princípios desta Constituição**? Quais são os limites à manifestação do **poder constituinte derivado decorrente**? Em interessante síntese, da qual nos valem, Uadi Lammêgo Bulos fixa, como limites à manifestação do poder constituinte derivado decorrente, os **princípios constitucionais sensíveis**, os **princípios constitucionais estabelecidos** (organizatórios) e os **princípios constitucionais extensíveis**:¹⁹

■ **princípios constitucionais sensíveis**: terminologia adotada por Pontes de Miranda; encontram-se expressos na Constituição, daí serem também denominados *princípios apontados ou enumerados*. Nesse sentido, os Estados-Membros, ao elaborar as suas constituições e leis, deverão observar os limites fixados no **art. 34, VII, “a-e”, CF/88**, sob pena de, declarada a inconstitucionalidade da referida norma e a sua suspensão insuficiente para o restabelecimento da normalidade, ser decretada a intervenção federal no Estado (a este assunto voltaremos no *item 6.7.5*, quando estudarmos a *ADI interventiva*, no capítulo sobre o controle de constitucionalidade);

■ **princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios):** segundo Bulos, “... são aqueles que limitam, vedam, ou proíbem a ação indiscriminada do Poder Constituinte Decorrente. Por isso mesmo, funcionam como balizas reguladoras da capacidade de auto-organização dos Estados (...) podem ser extraídos da interpretação do conjunto de normas centrais, dispersas no Texto Supremo de 1988, que tratam, por exemplo, da repartição de competência, do sistema tributário nacional, da organização dos Poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos e garantias individuais, dos direitos sociais, da ordem econômica, da educação, da saúde, do desporto, da família, da cultura etc.”. O autor os divide em três tipos: a) **limites explícitos vedatórios:** proíbem os Estados de praticar atos ou procedimentos contrários ao fixado pelo poder constituinte originário — exs.: arts. 19, 35, 150, 152, ou **limites explícitos mandatórios:** restrições à liberdade de organização — exs.: arts. 18, § 4.º, 29, 31, § 1.º, 37 a 42, 92 a 96, 98, 99, 125, § 2.º, 127 a 130, 132, 134, 135, 144, IV e V, §§ 4.º a 7.º; b) **limites inerentes:** implícitos ou tácitos, vedam qualquer possibilidade de invasão de competência por parte dos Estados-Membros; c) **limites decorrentes:** decorrem de disposições expressas. Exs.: necessidade de observância do princípio federativo, do Estado Democrático de Direito, do princípio republicano (art. 1.º, *caput*); da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III); da igualdade (art. 5.º, *caput*); da legalidade (art. 5.º, II); da moralidade (art. 37), do combate a desigualdades regionais (art. 43) etc.;

■ **princípios constitucionais extensíveis:** mais uma vez na conceituação de Bulos, “são aqueles que integram a estrutura da federação brasileira, relacionando-se, por exemplo, com a forma de investidura em cargos eletivos (art. 77), o processo legislativo (arts. 59 e s.), [20](#) os orçamentos (arts. 165 e s.), os preceitos ligados à Administração Pública (arts. 37 e s.) etc.”.

Finalmente, é de lembrar que o exercício do poder constituinte derivado decorrente foi concedido às **Assembleias Legislativas**, nos termos do art. 11, *caput*, ADCT, que diz: “Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, **obedecidos os princípios desta**” (grifamos).

Nesse sentido, determinando a aplicação do **princípio da simetria**, o STF estabeleceu que “as normas disciplinadoras do **processo legislativo de reforma constitucional**, como o *quorum* de aprovação, são de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes. (**ADI 486**, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03.04.1997, *DJ* 10.11.2006 e **ADI 1.722 MC**, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10.12.1997)”. Portanto, não se pode ter *quorum* diferente do previsto para a CF em relação à aprovação das emendas às constituições estaduais (e para a alteração da Lei Orgânica do DF — **ADI 7.205**, j. 16.12.2022). Ou seja, a aprovação também tem que se dar em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **3/5 dos votos dos respectivos membros** (**ADI 6.453**, j. 10.02.2022).

4.5.3.2. Distrito Federal

O **Distrito Federal**, de acordo com o art. 32, *caput*, CF/88, será regido por **lei orgânica**, votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por **2/3 da Câmara Legislativa**, que a promulgará. Tal lei orgânica deverá obedecer aos princípios estabelecidos na **Constituição Federal**.²¹

Dessa forma, embora a posição particular ocupada pelo DF na Federação, já que a sua **autonomia é parcialmente tutelada pela União** (arts. 21, XIII e XIV, e 22, XVII), além de **acumular** competências legislativas reservadas tanto aos **Estados** como aos **Municípios** (art. 32, § 1.º), a vinculação da lei orgânica será **diretamente** com a CF.

Nesse sentido, em interessante demonstração, o Min. Carlos Britto afirmou que, “conquanto submetido a regime constitucional **diferenciado**, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos **Estados-membros** do que da arquitetura constitucional dos Municípios” (**ADI 3.756**, j. 21.06.2007, *DJ* de 19.10.2007).

Assim, na medida em que a derivação é **direta** em relação à Constituição Federal, parece razoável afirmarmos, **mudando de posição firmada em edições anteriores à 13.^a**,²² que, no âmbito do DF, verifica-se a **manifestação do poder constituinte derivado decorrente**, qual seja, a competência que o DF tem para elaborar a sua lei orgânica (verdadeira **Constituição distrital**) ou modificá-la, sujeitando-se aos mesmos limites já apontados para os Estados-Membros e, pois, aplicando-se, por analogia, o art. 11, ADCT.²³

Por esse motivo, é perfeitamente possível o controle concentrado no âmbito do **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)** tendo como paradigma a Lei Orgânica do DF, com a mesma natureza das Constituições Estaduais, regra essa, inclusive, introduzida, de modo expresso, no art. 30 da Lei n. 9.868/99 e, também, na Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STF (cf. RE 577.025, voto do Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2008, Plenário, *DJE* de 06.03.2009).

Finalmente, conforme vimos no item anterior, as regras de processo legislativo previstas na CF para os Estados também deverão ser observadas em relação ao Distrito Federal. Assim, muito embora a aprovação da Lei Orgânica do DF seja por 2/3 (em razão de explícita previsão constitucional no art. 32, *caput*), a sua alteração não poderá se dar por este *quorum* mais rígido. Tendo em vista o princípio da simetria, o *quorum* deverá ser por 3/5 (2/3 é um *quorum* de maior dificuldade para ser atingido) (**ADI 7.205**, j. 16.12.2022, *DJE* de 20.04.2023).

Conforme decidiu o STF em outro julgado, “a Lei Orgânica do DF tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, **podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-Membros**, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta” (ADI 980, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 06.03.2008).

4.5.3.3. Municípios: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?

Não.

Os **Municípios** (que por força dos arts. 1.º e 18, CF/88, fazem parte da Federação brasileira, sendo, portanto, autônomos em relação aos outros componentes, na medida em que também têm autonomia “F.A.P.” — Financeira, Administrativa e Política) elaborarão **leis orgânicas** como se fossem “Constituições Municipais”.

Desse modo, a *capacidade de auto-organização municipal* está delimitada no art. 29, *caput*, CF/88, e seu exercício caberá à Câmara Municipal, nos termos do parágrafo único do art. 11, ADCT: “promulgada a Constituição do Estado, caberá à **Câmara Municipal**, no prazo de 6 meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, **respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual**” (grifamos).

Como se observa, o respeito ao conteúdo dar-se-á tanto em relação à **Constituição Estadual** como à **Federal**, obedecendo, desta feita, como advertiram Araujo e Nunes, “a dois graus de imposição legislativa constitucional”. Em virtude disso e trazendo à baila entendimento jurisprudencial emanado pelo TJSP, os autores concluem que “o poder constituinte decorrente, conferido aos Estados-membros da Federação, **não foi estendido aos Municípios**” (grifamos).²⁴

Nesse sentido, Noemia Porto assinala: “o **poder constituinte derivado decorrente** deve ser de **segundo grau**, tal como acontece com o poder revisor e o poder reformador, isto é, encontrar sua **fonte de legitimidade direta da Constituição Federal**. No caso dos **Municípios**, porém, se descortina um poder de **terceiro grau**, porque mantém relação de subordinação com o poder constituinte estadual e o federal, ou, em outras palavras, observa necessariamente dois graus de imposição legislativa constitucional. Não basta, portanto, ser componente da federação, sendo necessário que o poder de auto-organização decorra diretamente do poder constituinte originário. Assim, o **poder constituinte decorrente**, conferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal, **não se faz na órbita dos Municípios**. Por essa razão, ato local questionado em face da lei orgânica municipal enseja controle de **legalidade**, e não de constitucionalidade” (grifamos).²⁵

4.5.3.4. Territórios Federais: manifestação do poder constituinte derivado decorrente?

Não.

Os **Territórios Federais** (que, como veremos, hoje não mais existem, mas poderão vir a ser criados), de acordo com o art. 18, § 2.º, integram a União, **não** se falando em autonomia federativa, e, portanto, **não se cogitando em manifestação de poder constituinte derivado decorrente**. Trata-se de descentralização administrativo-territorial da União, com natureza jurídica de autarquia federal.

Por todo o exposto, devemos concluir que o **poder constituinte derivado decorrente** (para aqueles que aceitam caracterizá-lo como *constituente* — vide comentário de Celso Bastos em nota anterior) é **apenas** o poder que os Estados-Membros, por meio das Assembleias Legislativas, têm de elaborar e modificar as suas Constituições Estaduais, bem como o Distrito Federal, por meio da Câmara Legislativa, de elaborar e modificar a sua Lei Orgânica, devendo, ambas,

obedecer aos limites impostos pela Constituição Federal, nos exatos termos dos arts. 25, *caput*, e 32, *caput*, CF/88.²⁶

Essa particularidade, contudo, não se estende aos Municípios, como visto acima, e muito menos aos Territórios Federais que eventualmente venham a ser criados.

4.5.4. Poder constituinte derivado revisor

O **poder constituinte derivado revisor**, assim como o reformador e o decorrente, é fruto do trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele **vinculado**. É, ainda, um “poder” **condicionado e limitado** às regras instituídas pelo originário, sendo, assim, um **poder jurídico**.

Como advertimos, melhor seria a utilização da nomenclatura **competência de revisão**, na medida em que não se trata, necessariamente, de um “poder”, uma vez que o processo de revisão está limitado por uma força maior que é o poder constituinte originário, este sim um verdadeiro poder, inicial e ilimitado, totalmente autônomo do ponto de vista jurídico.

O art. 3.º, ADCT, determinou que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional, em **sessão unicameral**.

Instituiu-se um particular **procedimento simplificado** de alteração do texto constitucional, excepcionando a regra geral das PECs, que exige aprovação por 3/5 dos votos dos membros **de cada Casa**, e obedecendo, assim, às regras da bicameralidade (art. 60, § 2.º).

O procedimento da revisão foi disciplinado na **Resolução n. 1-RCF**, do Congresso Nacional, de 18.11.1993 (alterada pela *Res. n. 2, de 1993-RCF*, e pela *Res. n. 1, de 1994-RCF*), que dispôs sobre o *funcionamento dos trabalhos de revisão constitucional*.

O art. 3.º, ADCT, introduziu verdadeira competência de revisão para “atualizar” e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontasse como necessárias, **não estando a aludida revisão vinculada ao resultado do plebiscito do art. 2.º, ADCT** (que admitia a volta à monarquia e ao parlamentarismo).

Como o próprio texto constitucional prescreve, após 5 anos, contados de 05.10.1988, seria realizada uma **revisão** na Constituição. Desde já observamos

que referida revisão constitucional deveria dar-se após, pelo menos, 5 anos, podendo ser 6, 7, 8... e apenas **uma única vez**, sendo impossível uma segunda produção de efeitos.

Em se tratando de manifestação de um “poder” derivado, os limites foram estabelecidos pelo poder constituinte originário. Muito se questionou a respeito da amplitude desses limites. Teorias surgiram apontando uma ilimitação total; outras apontando a condicionalidade da produção da revisão desde que o plebiscito previsto no art. 2.º, ADCT, modificasse a forma ou sistema de governo. A teoria que prevaleceu foi a que fixou como limite material o mesmo determinado ao poder constituinte derivado reformador, qual seja, o limite material fixado nas “cláusulas pétreas” do art. 60, § 4.º, CF/88, vale lembrar, a proibição de emendas tendentes a abolir:

- a forma federativa de Estado;
- o voto direto, secreto, universal e periódico;
- a separação dos Poderes;
- os direitos e garantias individuais.

Nesse sentido, o art. 4.º, § 3.º, da referida *Resolução n. 1-RCF* determinou ser vedada a apresentação de propostas revisionais que:

- incidam na proibição constante do § 4.º do art. 60 da Constituição (as já comentadas cláusulas pétreas);
- substituam integralmente a Constituição;
- digam respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas;
- contrariem a forma republicana de Estado e o sistema presidencialista de governo.

Interessante notar que a *Resolução n. 1-RCF* (art. 4.º, I e II, e §§ 4.º e 5.º), diferentemente do art. 60, I, II e III, CF/88, dispôs sobre a possibilidade de oferecimento de propostas revisionais:

- por qualquer congressista;

- por representação partidária com assento no Congresso Nacional, por meio de líder;
- pelas Assembleias Legislativas de 3 ou mais Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus membros;
- pela apresentação de proposta revisional popular, desde que subscrita por 15.000 ou mais eleitores, em listas organizadas por, no mínimo, 3 entidades associativas legalmente constituídas, que se responsabilizaram pela idoneidade das assinaturas, obedecidas condições fixadas na *resolução*.

Ainda, não obstante o **procedimento simplificado** prescrito no art. 3.º, ADCT (*quorum* da **maioria absoluta** e **sessão unicameral**, ou seja, os deputados e senadores, durante a revisão, passam a ser tratados, sem qualquer distinção, como **congressistas revisores**), o art. 13, *Resolução n. 1-RCF*, estabeleceu a votação das matérias em **2 turnos**.

No ordenamento jurídico pátrio, a *competência revisional* do art. 3.º, ADCT, proporcionou a elaboração de meras 6 Emendas Constitucionais de Revisão (n. 1, de 1.º.03.1994 — *DOU*, 02.03.1994 —, e as de ns. 2 a 6, de 07.06.1994, publicadas no *DOU* em 09.06.1994), não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da **eficácia exaurida** e **aplicabilidade esgotada** da aludida regra.

Todo esse entendimento foi corroborado pelo STF, destacando-se o seguinte julgado:

“EMENTA: (...). **Emenda** ou **revisão**, como processos de mudança na Constituição, são manifestações do poder constituinte **instituído** e, por sua natureza, **limitado**. Está a ‘revisão’ prevista no art. 3.º do ADCT de 1988 sujeita aos **limites estabelecidos no § 4.º e seus incisos do art. 60 da Constituição**. O resultado do **plebiscito** de 21 de abril de 1993 **não tornou sem objeto a revisão** a que se refere o art. 3.º do ADCT. Após 5 de outubro de 1993, cabia ao **Congresso Nacional** deliberar no sentido da **oportunidade** ou **necessidade** de proceder à aludida revisão constitucional, a ser feita **‘uma só vez’**. As mudanças na Constituição, decorrentes da ‘revisão’ do art. 3.º do ADCT, estão sujeitas ao **controle judicial**, diante das **‘cláusulas pétreas’**”

consignadas no art. 60, § 4.º e seus incisos, da Lei Magna de 1988” (ADI 981-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.03.1993, Plenário, DJ de 05.08.1994).

Mas, afinal, qual a diferença entre o poder constituinte derivado **reformador** e o poder constituinte derivado **revisor**?

4.6. PODER CONSTITUINTE DIFUSO

O **poder constituinte difuso**²⁷ pode ser caracterizado como um **poder de fato** e que serve de **fundamento** para os mecanismos de atuação da **mutação constitucional** (tema estudado no *capítulo 3*, sobre *hermenêutica*).²⁸

Se por um lado a mudança implementada pelo *poder constituinte derivado reformador* se verifica de modo formal, palpável, por intermédio das emendas à Constituição, a modificação produzida pelo **poder constituinte difuso** se instrumentaliza de modo **informal** e **espontâneo**, como verdadeiro **poder de fato**, e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos, encontrando-se em estado de latência. Trata-se de **processo informal de mudança da Constituição**, alterando-se o seu **sentido interpretativo**, e **não o seu texto**, que permanece intacto e com a mesma literalidade.

Nesse sentido, anota Anna Cândida da Cunha Ferraz, “tais alterações constitucionais, operadas fora das modalidades organizadas de exercício do poder constituinte instituído ou derivado, justificam-se e têm fundamento jurídico: são, em realidade, obra ou manifestação de uma espécie inorganizada do poder constituinte, o chamado **poder constituinte difuso**, na feliz expressão de **Burdeau**”.²⁹ E continua: “destina-se a função constituinte difusa a completar a Constituição, a preencher vazios constitucionais, a continuar a obra do Constituinte. Decorre diretamente da Constituição, isto é, o seu fundamento flui da Lei Fundamental, ainda que implicitamente, e de modo difuso e inorganizado” (grifamos).³⁰

Nesses mesmos termos, conclui Barroso que “além do poder constituinte originário e do poder de reforma constitucional existe uma terceira modalidade de poder constituinte: o que se exerce em **caráter permanente**, por **mecanismos informais**, não expressamente previstos na Constituição, mas indubitavelmente por ela admitidos, como são a **interpretação de suas normas** e o **desenvolvimento dos costumes constitucionais**. Essa terceira via já foi

denominada por célebre publicista francês **poder constituinte difuso**, cuja titularidade remanesce no povo, mas que acaba sendo exercido por via representativa pelos órgãos do poder constituído, em sintonia com as demandas e sentimentos sociais, assim como em casos de necessidade de afirmação de certos direitos fundamentais”.³¹

Mendes, Coelho e Branco constataam que, “... por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. O **texto é o mesmo**, mas o **sentido** que lhe é atribuído é **outro**. Como a norma não se confunde com o texto, repara-se, aí, uma **mudança da norma, mantido o texto**. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional”.³²

Naturalmente, a mutação e a nova interpretação não poderão macular os **princípios estruturantes** da Constituição, sob pena de se caracterizar inaceitável interpretação inconstitucional e, portanto, combatida mutação inconstitucional.

4.7. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL

O **poder constituinte supranacional**³³ busca a sua fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e em um conceito remodelado de soberania.³⁴

Segundo Maurício Andreiuolo Rodrigues, agindo de fora para dentro, o poder constituinte supranacional busca estabelecer uma Constituição supranacional legítima: “faz as vezes do poder constituinte porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos Estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade, inclusive, para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Da mesma forma, e em segundo lugar, é supranacional, porque se distingue do ordenamento positivo interno assim como do direito internacional”.³⁵

Em interessante estudo, Marcelo Neves demonstra a tendência mundial de superação do “constitucionalismo provinciano ou paroquial pelo

transconstitucionalismo”, mais adequado para solução dos problemas de direitos fundamentais ou humanos e de organização legítima de poder.^{[36](#)}

Não há dúvida de que o tema terá de ser aprofundado e repensado, especialmente diante dessa tendência de **globalização do direito constitucional**, chegando alguns autores, como Canotilho (com base em Lucas Pires), a sugerir, inclusive, a formulação da denominada **teoria da interconstitucionalidade**, na busca de estudar “as relações interconstitucionais, ou seja, a concorrência, convergência, justaposição e conflito de várias constituições e de vários poderes constituintes no mesmo espaço político”.^{[37](#)}

Analisando a União Europeia, Souza Neto e Sarmento vislumbram “(...) um processo de ‘constitucionalização’ do Direito Comunitário europeu, pelo qual este vem ganhando características *sui generis*, que se aproximam daquelas tradicionalmente atribuídas às constituições estatais. Porém, não há como vislumbrar, pelo menos até o momento, a existência de um verdadeiro poder constituinte europeu, sobretudo no sentido de democrático, de um poder constituinte do povo”.^{[38](#)}

Em sentido oposto, os reflexos do episódio que ficou conhecido como “**Brexit**” (*Britain + exit*), ou seja, a decisão de retirada do Reino Unido da União Europeia, também terão de ser observados. No dito “referendo” realizado em 23.06.2016 (entendemos tratar-se de plebiscito, pois a retirada ainda dependia de formalidades ditadas pelo art. 51 do *Tratado da União Europeia*), com 51,89% dos votos, a maioria dos britânicos manifestou-se pelo *Brexit (leave)*, contra 48,11%, que sustentavam a permanência (*remain*).

Como se sabe, em **31.01.2020**, o Reino Unido deixou formalmente a União Europeia, iniciando, então, o período de transição, ou melhor, de implementação, durante o qual muito ainda deverá ser discutido e ajustado.

4.8. Nova Constituição e ordem jurídica anterior

Após estudarmos o tema do Poder Constituinte, devemos analisar o que acontece com as normas que foram produzidas na vigência da Constituição anterior com o advento de uma nova Constituição, um novo Estado. Elas são revogadas? Perdem a validade? Devem ser novamente editadas?

Estamos diante de um dos temas mais fascinantes do direito, qual seja, o do **direito intertemporal *lato sensu***, vale dizer, a relação do direito com **passado, presente e futuro**. Aponta Carlyle Popp que sua importância social reside no tocante à “*segurança dos cidadãos no que concerne ao passado ... O respeito ao direito adquirido, com a consequente proibição da retroatividade da norma legal, é um verdadeiro instrumento de paz social, impeditivo do arbítrio e do abuso de poder por parte do detentor deste*”.³⁹

Nesse sentido, enfatizando o possível arbítrio, o abuso dos governantes, assinala Pontes de Miranda que “*a irretroatividade defende o povo; a retroatividade expõe-no à prepotência*”.⁴⁰

4.8.1. Recepção

O que acontecerá com as normas infraconstitucionais elaboradas antes do advento da nova Constituição?

Todas as normas que forem **incompatíveis** com a nova Constituição serão **revogadas**, por **ausência de recepção**. Vale dizer, *a contrario sensu*, a norma infraconstitucional (pré-constitucional), que não contrariar a nova ordem, será **recepcionada**, podendo, inclusive, adquirir uma outra “roupagem”. Como exemplo lembramos o CTN (Código Tributário Nacional — Lei n. 5.172/66), que, embora tenha sido elaborado com natureza jurídica de lei ordinária, foi recepcionado pela nova ordem como lei complementar, sendo que os ditames que tratam das matérias previstas no art. 146, I, II e III, CF, só poderão ser alterados por lei complementar, aprovada com o *quorum* da maioria absoluta (art. 69).

Pode-se afirmar, então, que, nos casos de normas infraconstitucionais produzidas antes da nova Constituição, incompatíveis com as novas regras, não se observará qualquer situação de inconstitucionalidade, mas, apenas, como vimos, de **revogação** da lei anterior pela nova Constituição, por falta de **recepção**.

Nessa situação, acrescente-se, **inadmite-se** a realização de controle de constitucionalidade via ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADI), por falta de previsão no art. 102, I, “a”, CF/88. O controle de constitucionalidade pressupõe a existência de **relação de contemporaneidade** entre o ato normativo editado e a Constituição tomada como parâmetro ou paradigma de confronto (ADI 7, Pleno, j. 07.02.1992).

Deve-se destacar desde já, contudo, que, apesar de não ser cabível o aludido controle de constitucionalidade concentrado pela via da ação direta de inconstitucionalidade genérica, será perfeitamente cabível a **arguição de descumprimento de preceito fundamental** — ADPF, introduzida pela Lei n. 9.882/99.^{[41](#)}

4.8.1.1. Inconstitucionalidade superveniente?

Por todo o exposto, fica claro que o STF **não** admite o **fenômeno da inconstitucionalidade superveniente** de ato normativo produzido antes da nova Constituição e perante o novo paradigma.

Nesse caso, ou se fala em **compatibilidade** e aí haverá **recepção**, ou em revogação por **inexistência de recepção**.

Estamos diante da noção de **contemporaneidade**, ou seja, uma lei só é constitucional ou inconstitucional perante o paradigma de confronto em relação ao qual ela foi produzida (para aprofundamento, cf. *item 6.1.5*).

4.8.1.2. Uma lei que fere o processo legislativo previsto na Constituição sob cuja regência foi editada, mas que, até o advento da nova Constituição, nunca fora objeto de controle de constitucionalidade, poderá ser recebida pela nova Constituição se com ela for compatível?

A questão, pela primeira vez, foi objeto de pergunta no concurso público da PFN (2005/2006-ESAF), gerando muita discussão. Apareceu, também, em outros momentos como, para se ter um exemplo, em certame elaborado pelo CESP/UnB no concurso de Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados de 2014.

No entender de parte da doutrina, se a lei produzida antes de 1988 ainda não tivesse sido declarada inconstitucional na vigência do antigo ordenamento, teoricamente, como ela se presume constitucional, poderia ser recebida pelo novo ordenamento se com ele fosse compatível do ponto de vista meramente material.

Contudo, parece-nos que o Judiciário, ao fazer a análise da recepção, terá de verificar, também, se a lei que pretende ser recebida pelo novo ordenamento era compatível, não só do ponto de vista **formal**, como, também, **material**, com a Constituição sob cuja regência foi editada.

Sobre esse tema, assinala Paulo G. G. Branco: “uma vez que vigora o princípio de que, em tese, a inconstitucionalidade gera a nulidade — absoluta — da lei, uma norma na situação em tela já era nula desde quando editada, pouco importando a compatibilidade material com a nova Constituição, que não revigora diplomas nulos”.⁴²

Trata-se, como se verificou, da noção de **contemporaneidade**, e a lei que “nasceu maculada” possui **vício congênito**, insanável, impossível de ser corrigido pelo fenômeno da recepção. O vício *ab origine* nulifica a lei, tornando-a ineficaz ou írrita.

Como exemplo, podemos citar a discussão sobre a possibilidade de decreto-lei dispor sobre o regime do PIS no **ordenamento jurídico anterior** (Constituição Federal de 1967/69).

Conforme decidiu o STF, no regime anterior (sendo diferente a regra perante o texto de 1988, que nem mais prevê a figura do decreto-lei e admite que as contribuições já discriminadas no art. 195, I-IV, podem ser regulamentadas por lei ordinária — cf. *item 19.2.5*), referido ato normativo podia dispor sobre normas tributárias.

Todavia, conforme entendeu o STF, como o **PIS**, então, não tinha essa natureza, mas a de **contribuição**, pela regra específica do **regime anterior**, deveria ser regulamentado por lei complementar, concluindo, então, pelo vício formal de sua instituição, pelos Decretos-leis n. 2.445, de 29.06.1988, e 2.449, de 21.07.1988 (lembrando que o novo texto constitucional foi promulgado em outubro/88).

Assim, como havia incompatibilidade formal perante o texto sob cuja regência referidos Decretos-leis foram editados, não se poderia falar em recepção pelo novo ordenamento.

A análise se deu no caso concreto (difuso), no **RE 148.754**. Sustentamos a possibilidade do uso da **ADPF** para a análise em abstrato de recepção de atos editados antes do novo ordenamento (como se confirmou no julgamento da **ADPF 130**, em 30.04.2009, pela qual o STF declarou que a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) é incompatível com a atual ordem constitucional, tendo sido, portanto, **revogada** pelo novo ordenamento).

Nessa linha de entendimento, uma lei anterior que nasceu inconstitucional não será “consertada” pela nova Constituição, não será convalidada. Assim, não se admite o fenômeno da “constitucionalidade superveniente”.

Podemos concluir que, para uma lei ser recepcionada pelo novo ordenamento jurídico, deverá preencher os seguintes requisitos:

- estar em vigor no momento do advento da nova Constituição;
- não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior;
- ter compatibilidade **formal** e **material** perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada (no ordenamento anterior);
- ter compatibilidade somente **material** perante a nova Constituição, pouco importando a compatibilidade formal.

4.8.1.3. Características conclusivas sobre o fenômeno da recepção

Diante do acima exposto, podemos estabelecer algumas regras sobre o fenômeno da recepção:

- no fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade **material** perante a **nova** Constituição;
- a lei, para ser recebida, como vimos no item anterior, precisa ter compatibilidade **formal** e **material** perante a **Constituição sob cuja regência ela foi editada**;
- como a análise perante o novo ordenamento é somente do ponto de vista material, uma lei pode ter sido editada como ordinária e ser recebida como complementar (**“nova roupagem”**);
- em complemento, um ato normativo que deixe de ter previsão no novo ordenamento também poderá ser **recebido**. É o caso, por exemplo, do decreto-lei, que não mais existe perante o ordenamento de 1988: o Código Penal (DL n. 2.848/40) foi recebido como lei ordinária;
- se incompatível, a lei anterior será **revogada**, não se falando em inconstitucionalidade superveniente;
- nesse caso, a técnica de controle ou é pelo sistema **difuso** ou pelo **concentrado**, mas, neste último caso, **somente** por meio da ADPF.

Isso porque só se fala em ADI de uma lei editada a partir de 1988 e perante a CF/88 (**contemporaneidade**);

■ é possível, também, **mudança de competência federativa para legislar**, ou seja, matéria que era de competência da União pode perfeitamente passar a ser de competência legislativa dos Estados-Membros (como exemplo, citamos a instituição de *região metropolitana* que, na atual Constituição, passou a ser de competência estadual — art. 25, § 3.º, CF/88. Cf. discussão no *item 7.5.5*);

■ é possível, ainda, a **recepção de somente parte de uma lei**, como um artigo, um parágrafo etc.;

■ a recepção ou a revogação acontecem no momento da **promulgação** do novo texto. Entendemos, contudo, que o STF poderá **modular** os efeitos da decisão, declarando a partir de quando a sua decisão passa a valer. Nesse caso, a aplicação da técnica da modulação poderia se implementar tanto no controle difuso como no controle concentrado por meio da ADPF (cf. *item 6.7.3.7*).

4.8.2. Repristinação

Vejam os a situação: uma norma produzida na vigência da CF/46 não é recepcionada pela de 1967, pois incompatível com ela. Promulgada a CF/88, verifica-se que aquela lei, produzida na vigência da CF/46 (que fora revogada — não recepcionada — pela de 1967), em tese poderia ser recepcionada pela CF/88, visto que totalmente compatível com ela. Nessa situação, poderia aquela lei, produzida durante a CF/46, voltar a produzir efeitos? Ou seja, repristinaria? Como regra geral, o Brasil adotou a **impossibilidade do fenômeno da repristinação**, salvo se a nova ordem jurídica expressamente assim se pronunciar.

Nesse sentido, destacamos o posicionamento do STF sobre o assunto:

“EMENTA: Agravo regimental — Não tem razão o agravante. A recepção de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de **efeito repristinatório**, porque o nosso sistema

jurídico, **salvo disposição em contrário, não admite a repristinação** (artigo 2.º, § 3.º, da Lei de Introdução ao Código Civil — atualmente, acrescente-se, nos termos da Lei n. 12.376/2010, *Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro*). Agravo a que se nega provimento” (AGRAG 235.800/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 25.06.1999, p. 16, *Ement.* v. 01956-13, p. 2660, 1.ª T. — grifamos).

O tema aqui em estudo (repristinação) não deve ser confundido com o chamado “efeito repristinatório”, decorrente da declaração de inconstitucionalidade, que será estudado no *item* 6.7.1.17.3. Entendemos, contudo, oportuno já fazer essa distinção, remetendo o nosso ilustre leitor para o vídeo na plataforma.

4.8.3. Desconstitucionalização

Trata-se do fenômeno pelo qual as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem, permanecem em vigor, mas com o *status* de lei infraconstitucional. Ou seja, as normas da Constituição anterior são recepcionadas com o *status* de norma infraconstitucional pela nova ordem.

Fernanda Dias Menezes de Almeida e Anna Cândida da Cunha Ferraz, em trabalho extremamente interessante, observam que, “surgida na França e aceita por juristas como Carré de Malberg, Duguit, Esmein, Jellinek, Carl Schmitt e, entre nós, por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pontes de Miranda e José Afonso da Silva, a doutrina da desconstitucionalização afirma a possibilidade de sobrevivência de certos dispositivos da Constituição que perde a validade, não, porém, com o caráter de normas constitucionais, e sim como normas ordinárias”.⁴³

Exposta a doutrina, resta indagar: o fenômeno da desconstitucionalização é verificado no Brasil? Como regra geral, **não!** No entanto, poderá ser percebido quando a nova Constituição, **expressamente**, assim o requerer, tendo em vista ser o poder constituinte originário ilimitado e autônomo do ponto de vista jurídico. A Constituição pode prever o aludido fenômeno desde que o faça, como referido, de **maneira inequívoca e expressa**.

Os exemplos trazidos pelas professoras do Largo São Francisco são: **a) Portugal:** art. 292 da Constituição de 1976; **b) Brasil:** dentre outros, o art. 147 da Constituição do Estado de São Paulo de 1967, nos seguintes termos: “consideram-se vigentes, com o caráter de lei ordinária, os artigos da

Constituição promulgada em 9 de julho de 1947 que não contrariem esta Constituição”.

4.8.4. Recepção material de normas constitucionais

Fernanda Dias Menezes de Almeida e Anna Cândida da Cunha Ferraz resgataram o fenômeno da **recepção material das normas constitucionais** de acordo com a doutrina do Professor Jorge Miranda, apontando outra possibilidade além do já mencionado fenômeno da desconstitucionalização: “a da persistência de normas constitucionais anteriores que guardam, se bem que a título secundário, a antiga qualidade de normas constitucionais. Assim, diz o eminente professor (Jorge Miranda), ‘a par das normas que são direta expressão da nova ideia de Direito e que ficam sendo o núcleo da Constituição formal, perduram, então, por referência a elas, outras normas constitucionais’ (cf. *Manual de direito constitucional*, Coimbra, Coimbra Ed., 1988, t. II, p. 240)”.⁴⁴

Como exemplo, também colacionado pelas ilustres professoras, lembramos o art. 34, *caput*, e seu § 1.º, ADCT, CF/88, que asseguram, expressamente, a continuidade da vigência de artigos da Constituição anterior, com o caráter de norma constitucional, no novo ordenamento jurídico instaurado.⁴⁵

Note-se, porém, que referidas normas são recebidas por **prazo certo**, em razão de seu **caráter precário**, características marcantes no fenômeno da **recepção material das normas constitucionais**.

Desde já, porém, há de se observar que pela própria teoria do poder constituinte originário exposta, que rompe por completo com a antiga ordem jurídica, instaurando uma nova, um novo Estado, o fenômeno da **recepção material** só será admitido se **houver expressa manifestação da nova Constituição**; caso contrário, as normas da Constituição anterior, como visto, serão **revogadas**.

Isso porque, explica José Afonso da Silva, está-se diante da regra da **compatibilidade horizontal de normas de mesma hierarquia**. A posterior revoga a anterior, não podendo conviver com aquela simultaneamente, mesmo que não seja com ela incompatível. **A revogação se concretiza com a simples manifestação do poder constituinte originário** (*lex posterior derogat priori*).⁴⁶

4.9. poder constituinte e direito adquirido. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA

CONSTITUCIONAL: máximo, médio ou mínimo?

Para facilitar o estudo do tema, valemo-nos de interessante compilação feita pelo Min. Moreira Alves na **ADI 493**, ao destacar o magistério de José Carlos de Matos Peixoto:

■ **retroatividade máxima ou restitutória:** a lei ataca fatos consumados. Verifica-se “quando a lei nova prejudica a coisa julgada (sentença irrecorrível) ou os fatos jurídicos já consumados”. Como exemplo, lembramos o art. 96, parágrafo único, da Carta de 1937, que permitia ao Parlamento rever a decisão do STF que declarara a inconstitucionalidade de uma lei;

■ **retroatividade média:** “a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela”. Ou seja, a lei nova atinge as prestações vencidas, mas ainda não adimplidas. Como exemplo o autor cita uma “lei que diminuísse a taxa de juros e se aplicasse aos já vencidos, mas não pagos” (prestação vencida, mas ainda não adimplida);

■ **retroatividade mínima, temperada ou mitigada:** “... a lei nova atinge apenas os efeitos dos fatos anteriores, verificados após a data em que ela entra em vigor”. Trata-se de prestações futuras de negócios firmados antes do advento da nova lei.

O STF vem se posicionando no sentido de que as **normas constitucionais** fruto da manifestação do poder constituinte originário têm, por regra geral, **retroatividade mínima**, ou seja, aplicam-se a fatos que venham a acontecer após a sua promulgação, referentes a negócios passados.

Podemos mencionar o art. 7.º, IV, que, ao vedar a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, significou que a nova regra deverá valer para fatos e prestações futuras de negócios celebrados antes de sua vigência (prestações periódicas). Nesse sentido:

“EMENTA: Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7.º da Constituição de 1988. Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos

futuros de fatos passados (**retroatividade mínima**). Salvo disposição expressa em contrário — e a Constituição pode fazê-lo —, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 140.499/GO, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 09.09.1994, p. 23444).

Como outro exemplo de **retroatividade mínima**, lembramos a nova regra trazida pela EC n. 35/2001, que, dentre outras, acabou com a necessidade de prévia licença da Casa para o processamento dos parlamentares. O STF entendeu que a nova regra que dispensa a prévia autorização tem aplicação imediata, alcançando todos os casos que aguardavam manifestação das Casas, vale dizer, referentes a fatos ocorridos antes do advento da nova emenda constitucional.

Sendo regra, portanto, a **retroatividade mínima**, nada impede que a norma constitucional revolucionária, já que manifestação do poder constituinte originário ilimitado e incondicionado juridicamente, tenha **retroatividade média ou máxima**. Para tanto, contudo, deve existir **expresso pedido** na Constituição. Vejamos:

“EMENTA: Foro especial. Prefeito que não o tinha na época do fato que lhe é imputado como crime, estando em curso a ação penal quando da promulgação da atual Constituição que outorgou aos Prefeitos foro especial (art. 29, X, da Constituição Federal). A Constituição tem eficácia imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Para alcançar, porém, hipótese em que, no passado, não havia foro especial **que só foi outorgado quando o réu não mais era Prefeito** — hipótese que configura retroatividade média, por estar tramitando o processo penal —, **seria mister que a Constituição o determinasse expressamente, o que não ocorre no caso**. Por outro lado, não é de aplicar-se sequer o princípio que inspirou a Súmula 394.⁴⁷ Recurso extraordinário não conhecido” (**RE 168.618/PR**, Rel. Min. Moreira Alves, j. 06.09.1994, 1.^a T., *DJ* de 09.06.1995, p. 17260).

Como se percebe, outra coisa seria se, pendente a ação em relação a fato passado (antes da CF/88), o referido réu ainda fosse Prefeito. Nessa hipótese sim, sem

dúvida, deveriam os autos ser remetidos para o TJ local, já que a nova Constituição atingiria a situação atual (estar no cargo de Prefeito), referente a crime praticado no passado.

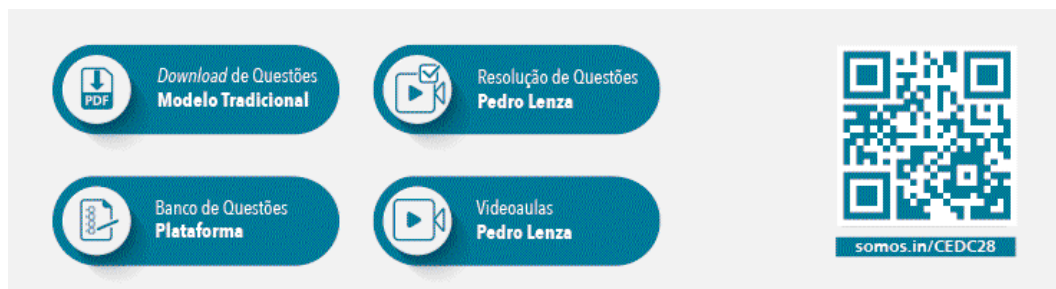
Assim, podemos esquematizar:

- a) as **normas constitucionais**, por regra, têm **retroatividade mínima**, aplicando-se a fatos ocorridos a partir de seu advento, mesmo que relacionados a negócios celebrados no passado — ex.: art. 7.º, IV;
- b) é possível a **retroatividade máxima e média** da norma introduzida pelo **constituente originário** desde que haja **expressa previsão**, como é o caso do art. 51, ADCT, CF/88. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência afirmam que **não há direito adquirido contra a Constituição**;
- c) por outro lado, as Constituições Estaduais (**poder constituinte derivado decorrente** — limitado juridicamente) e demais dispositivos legais, vale dizer, as **leis infraconstitucionais**, bem como as **emendas à Constituição** (fruto do **poder constituinte derivado reformador**, também limitado juridicamente), estão sujeitos à observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei (**retroatividade mínima**) (art. 5.º, XXXVI — “lei” em sentido amplo), com pequenas exceções, como a regra da lei penal nova que beneficia o réu (nesse sentido, cf. AI 292.979-ED, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 19.12.2002).⁴⁸

4.10. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

4

PODER CONSTITUINTE



The banner contains four blue buttons with white icons and text:

- Top-left: PDF icon, "Download de Questões", "Modelo Tradicional"
- Top-right: Checkmark icon, "Resolução de Questões", "Pedro Lenza"
- Bottom-left: Document icon, "Banco de Questões", "Plataforma"
- Bottom-right: Video icon, "Videoaulas", "Pedro Lenza"

On the right side of the banner is a QR code and a URL: somos.in/CEDC28



EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

■ 5.1. EFICÁCIA JURÍDICA E EFICÁCIA SOCIAL

Como regra geral, todas as normas constitucionais apresentam **eficácia**, algumas **jurídica** e **social** e outras apenas **jurídica**.

Michel Temer observa que a “*eficácia social* se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. *Eficácia jurídica*, por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam”.¹

As normas constitucionais, segundo **José Afonso da Silva**, podem ser de eficácia: **plena, contida** e **limitada**. Vejamo-las.²

■ 5.2. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA PLENA

Normas constitucionais de **eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral** são aquelas normas da Constituição que, no momento que esta entra em vigor, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional (situação esta que pode ser observada, também, na hipótese de introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º). Em regra, criam órgãos ou atribuem aos entes federativos competências. Não têm a necessidade de ser integradas. Aproximam-se do que a doutrina clássica norte-americana chamou de normas autoaplicáveis (*self-executing*, *self-enforcing* ou *self-acting*).

José Afonso da Silva destaca que as **normas constitucionais de eficácia plena** “... são as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da Constituição. Não necessitam de providência normativa ulterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo exigíveis”.³

Como exemplo, lembramos os arts. 2.º; 5.º, III; 14, § 2.º; 16; 17, § 4.º; 19; 20; 21; 22; 24; 28, *caput*; 30; 37, III; 44, parágrafo único; 45, *caput*; 46, § 1.º; 51; 52; 60, § 3.º; 69; 70; 76; 145, § 2.º; 155; 156; 201, §§ 5.º e 6.º (cf. AI 396.695-AgR, *DJ* de 06.02.2004); 226, § 1.º; 230, § 2.º (gratuidade de transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos — cf. ADI 3.768, *DJ* de 26.10.2007), todos da CF/88. Abaixo, pedimos vênua para destacar o importante reconhecimento, pelo STF, da autonomia da Defensoria Pública Estadual, nos termos da *Reforma do Poder Judiciário*:

“Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2.º, inciso IV, ‘c’, da Lei n. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do art. 134, § 2.º, da Constituição Federal, com a redação da EC 45/04: inconstitucionalidade declarada. A EC 45/04 outorgou expressamente **autonomia funcional e administrativa** às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2.º): donde, ser **inconstitucional** a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado. A norma de autonomia inscrita no **art. 134, § 2.º**, da Constituição Federal pela EC 45/04 é de **eficácia plena e aplicabilidade imediata**, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força da LC est. (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo texto constitucional. É da jurisprudência do Supremo Tribunal — malgrado o dissenso do Relator — que a antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se resolve em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta. O mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional modificado: precedentes” (**ADI 3.569**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, *DJ* de 11.05.2007).

Um outro precedente importante a ser destacado é o **RE 1.008.166**, cuja tese do *tema 548* da repercussão geral ficou assim estabelecida:

“1. A educação básica em todas as suas fases — educação infantil, ensino fundamental e ensino médio — constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (Plenário STF, j. 22.09.2022).

Trata-se de direito fundamental previsto desde 1988, em **norma constitucional de eficácia plena**, segundo agora explicitou o STF. Dessa forma, se o Poder Público não o implementou nesses anos todos, que revise o modo de gestão dos recursos públicos.

Isso não é ativismo judicial. É nítida manifestação dos “freios e contrapesos” e interpretação constitucional à luz do **princípio da máxima efetividade**, consagrando a **noção de justiça ou conformidade (correção) funcional**.

Um país sem educação é um país fadado ao fracasso. A educação transforma e deve ser uma das prioridades. Dizer que não há dinheiro não é argumento a se sustentar. Não implementar à luz de uma sugerida reserva financeira do possível não convence. Dinheiro há! O que falta é uma boa gestão, prioridade e vontade política.

■ 5.3. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA CONTIDA

As normas constitucionais de **eficácia contida** ou **prospectiva** têm **aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral**. Embora tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição, ou da entrada em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), produzir todos os seus efeitos, poderá haver a redução de sua abrangência. Ao contrário do que ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada, como será visto no item seguinte, em relação às quais o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora amplia o âmbito de sua eficácia e aplicabilidade, no tocante às **normas constitucionais de eficácia contida** percebemos verdadeira **limitação** (restrição) à eficácia e à aplicabilidade.

A restrição de referidas normas constitucionais pode-se concretizar não só através de **lei infraconstitucional**, mas, também, em outras situações, pela **incidência de normas da própria Constituição**, desde que ocorram certos pressupostos de fato, por exemplo, a decretação do estado de defesa ou de sítio, limitando diversos direitos (arts. 136, § 1.º, e 139, CF/88).

Além da restrição da eficácia das referidas normas de eficácia contida tanto por lei como por outras normas constitucionais, conforme referido acima, a restrição poderá implementar-se, em outras situações, por **motivo de ordem pública, bons costumes e paz social**, conceitos vagos cuja redução se efetiva pela Administração Pública.

Enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena.

Como **exemplo** citamos o **art. 5.º, XIII**, CF/88, que assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, garante-se o

direito do livre exercício profissional, mas uma lei, por exemplo, o Estatuto da OAB, pode exigir que para nos tornarmos advogados sejamos aprovados em um **exame de ordem**. Sem essa aprovação, infelizmente, não poderemos exercer a profissão de advogado, sendo apenas bacharéis em direito. O que a **lei infraconstitucional** fez foi reduzir a amplitude do direito constitucionalmente assegurado.

A questão foi posta, e o STF entendeu que “o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de **proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício**. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição — assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade — aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional” (**RE 603.583**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2011, Plenário, *Inf. 646/STF*, e, para aprofundamento do estudo, cf. *item 12.4.1.5*).

Cabe alertar, contudo, conforme estabeleceu a Corte ao analisar referido dispositivo constitucional (art. 5.º, XIII), que “**nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício**. A regra é a liberdade. Apenas quando houver **potencial lesivo** na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. **A atividade de músico prescinde de controle**. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão” (**RE 414.426**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.08.2011, Plenário, *DJE* de 10.10.2011 [tema reforçado no julgamento da **ADPF 183**, j. 27.09.2019, *DJE* de 18.11.2019, tendo sido negado seguimento aos embargos de declaração, j. 10.02.2020]. No mesmo sentido: *RE 795.467-RG*, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014; *RE 635.023-ED*, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2011, 2.ª T.; *RE 509.409*, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 31.08.2011 etc.).

As normas constitucionais que asseguram o **direito de greve** também devem ser analisadas. A **Constituição de 1988** manteve o direito de greve para os trabalhadores em geral (art. 9.º) e, **pela primeira vez**, fez expressa previsão desse direito para os **servidores públicos** (art. 37, VII). No primeiro caso, a garantia está materializada em norma de **eficácia contida**, já que o § 1.º do art. 9.º prescreve que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, reduzindo, assim, a sua amplitude (cf. Lei n. 7.783/89); no segundo, em norma de **eficácia limitada**, pois o seu exercício se dará nos termos e nos limites definidos em **lei específica**, ainda não editada pelo Congresso Nacional.

Outros exemplos, ainda, podem ser constatados nos incisos VII,⁴ VIII, XV, XXIV, XXV,⁵ XXVII e XXXIII do art. 5.º; arts. 15, IV; 37, I; 170, parágrafo único etc.⁶

Importante notar que, como veremos, em algumas provas de concursos, o examinador utilizou a nomenclatura sugerida por Michel Temer para as normas constitucionais de eficácia contida, qual seja, **normas constitucionais de eficácia redutível** ou **restringível**, apesar de sua *aplicabilidade plena*. Segundo Temer, referidas normas “são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que podem ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional”.⁷

■ 5.4. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA LIMITADA

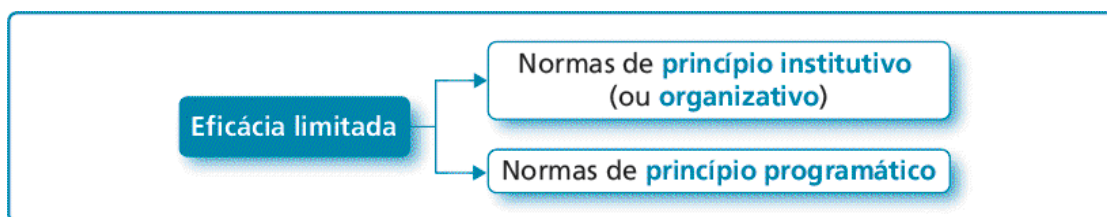
São aquelas normas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, ou entra em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional a ser editada pelo Poder, órgão ou autoridade competente, ou até mesmo de integração por meio de emenda constitucional, como se observou nos termos do art. 4.º, EC n. 47/2005.⁸ São, portanto, de **aplicabilidade indireta, mediata e reduzida**, ou, segundo alguns autores, **aplicabilidade diferida**.

Devemos salientar que, ao contrário da doutrina norte-americana, José Afonso da Silva, concordando com a opinião de Vezio Crisafulli, observa que as *normas constitucionais de eficácia limitada* produzem um mínimo efeito, ou, ao menos, o efeito de vincular o legislador infraconstitucional aos seus vetores.

Assim, José Afonso da Silva, em sede conclusiva, assevera que referidas normas têm, ao menos, **eficácia jurídica imediata, direta e vinculante**, já que: **a)** estabelecem um dever para o legislador ordinário; **b)** condicionam a legislação futura, com a consequência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; **c)** informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; **d)** constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; **e)** condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário; **f)** criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem.⁹ Todas elas — em momento seguinte concluiu o mestre¹⁰ — possuem eficácia ab-rogativa da legislação precedente incompatível (Geraldo Ataliba diria “paralisante da

eficácia destas leis”, sem ab-rogá-las — nosso acréscimo) e criam situações subjetivas simples e de interesse legítimo, bem como direito subjetivo negativo. Todas, enfim, geram situações subjetivas de vínculo.

O mestre do Largo São Francisco divide-as em dois grandes grupos: **normas de princípio institutivo (ou organizativo)** e **normas de princípio programático**.



As *normas de eficácia limitada, declaratórias de princípios institutivos ou organizativos* (ou *orgânicos*) contêm **esquemas gerais (iniciais) de estruturação de instituições, órgãos ou entidades**. Podemos exemplificar com os arts. 18, § 2.º; 22, parágrafo único; 25, § 3.º; 33; 37, VII; 37, XI; 88; 90, § 2.º; 91, § 2.º; 102, § 1.º; 107, § 1.º; 109, VI; 109, § 3.º; 113; 121; 125, § 3.º; 128, § 5.º; 131; 146; 161, I; 224...¹¹

Já as *normas de eficácia limitada, declaratórias de princípios programáticos*, **veiculam programas a serem implementados pelo Estado**, visando à realização de fins sociais (arts. 6.º — direito à alimentação; 196 — direito à saúde; 205 — direito à educação; 215 — cultura; 218, *caput* — ciência, tecnologia e inovação (EC n. 85/2015); 227 — proteção da criança...).¹²

Alguns outros exemplos podem ser “colhidos” do vasto estudo desenvolvido por José Afonso da Silva. Vinculadas ao **princípio da legalidade**, o autor menciona algumas **normas programáticas**: **a)** art. 7.º, XI (participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, *conforme definido em lei*, observando que já existe ato normativo concretizando o direito); **b)** art. 7.º, XX (proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, *nos termos da lei*); **c)** art. 7.º, XXVII (proteção em face da automação, *na forma da lei*); **d)** art. 173, § 4.º (*a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros — vide CADE*); **e)** art. 216, § 3.º; **f)** art. 218, § 4.º etc.¹³

Outros dois exemplos, de interesse prático, podem ser encontrados na jurisprudência do STF, já declarados como **normas de eficácia limitada**: **a)** juros legais de 12% ao ano; **b)** teto do funcionalismo público.

Em relação ao primeiro, o STF entendia, apesar da nossa crítica e de diversos outros autores, bem como de alguns tribunais (*vide Julgados do TARGS*, 81/314), que o **revogado art. 192, § 3.º**, que fixava as taxas dos **juros reais** não superiores a **12% a.a.**, era norma constitucional de eficácia limitada, dependente de lei complementar para sua aplicação prática.¹⁴

Convém lembrar a novidade trazida pela EC n. 40, de 29.05.2003 (PEC n. 53/99 da CD e n. 21/97 do SF), que, ao tratar do *Sistema Financeiro Nacional*, alterou a redação do inciso V do art. 163 e do *caput* do art. 52, ADCT, revogando todos os incisos e parágrafos do art. 192, permitindo a sua regulamentação por **mais de uma lei complementar**. Em razão dessa nova sistemática, a já desprestigiada taxa de juros reais de 12% a.a. desconstitucionaliza-se, infelizmente, assim como as importantes regras que constavam do referido art. 192. No parecer do relator à PEC n. 53, a reforma buscou “... superar as dificuldades de regulamentação do art. 192 da Constituição Federal e viabilizar a aprovação de uma nova lei estruturadora do sistema financeiro nacional”, uma vez que o STF já havia resolvido que, na vigência da antiga regra, antes da EC n. 40/2003, portanto, o sistema financeiro deveria ser regulamentado por uma única lei complementar (cf. **Súmula Vinculante 7/2008**).

O segundo exemplo diz respeito ao **teto do funcionalismo público**. Como se sabe, a Reforma Administrativa (EC n. 19/98) fixou o teto correspondente ao subsídio mensal, em espécie, dos **Ministros do STF**, nos termos dos arts. 37, XI; 39, § 4.º, e 48, XV. Tratava-se, como definiu o STF, de **norma não autoaplicável, dependente de lei formal de iniciativa**

conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observadas as regras dos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III e 153, § 2.º, I.¹⁵ Essas regras, contudo, não persistem, tendo em vista a promulgação da EC n. 41/2003.

A **Reforma da Previdência** (EC n. 41, de 19.12.2003) também estabeleceu como teto do funcionalismo público o subsídio pago ao Ministro do STF, a ser fixado por lei. Inovando, acaba com a denominada “iniciativa conjunta”, já que a fixação do teto dar-se-á por **lei de iniciativa exclusiva do Presidente do STF** (arts. 48, XV, e 96, II, “b” — sendo a CD a Casa iniciadora e o SF, a revisora — art. 64, *caput*) e não mais em conjunto pelos Presidentes dos “Poderes”.

Verificaremos que foram criados subtetos, nos termos do art. 37, XI, e §§ 11 e 12 (parágrafos introduzidos pela EC n. 47/2005), tema a ser estudado quando tratarmos da exclusão da regra da iniciativa conjunta (*item 9.13.3.5*).

A perspectiva de que referida regra (art. 37, XI) continue sendo classificada pelo STF como de **eficácia limitada** decorre não só do antigo posicionamento da Suprema Corte como, principalmente, da regra contida no art. 8.º, EC n. 41/2003.

Alexandre de Moraes considera o texto do inciso XI do art. 37 **autoaplicável**.¹⁶ Em nossa interpretação, concordamos que o texto seja autoaplicável. Essa autoaplicabilidade, contudo, não decorre da eficácia plena da norma (que, em nosso entender, é de **eficácia limitada**, já que prescreve a sua regulamentação por lei de iniciativa do Presidente do STF), mas do comando fixado no art. 8.º, EC n. 41/2003.

Tanto é verdade que o teto inicial, que era provisório, foi redefinido pela **Lei n. 11.143/2005**, tendo sido reajustado nos termos da **Lei n. 12.041/2009**. Em momento seguinte, veio a ser regulamentado pelas **Leis ns. 12.771/2012** e **13.091/2015 (a)** R\$ 28.059,29, a partir de 1.º.01.2013; **b)** R\$ 29.462,25, a partir de 1.º.01.2014; e **c)** R\$ 33.763,00, a partir de 1.º.01.2015). A **Lei n. 13.752, de 26.11.2018**, reajustou o valor para **R\$**

39.293,22 (as regras sobre o **teto do funcionalismo** foram modificadas pela **EC n. 47/2005**).

Finalmente, a **Lei n. 14.520**, de **09.01.2023**, fixou novos valores para o subsídio dos Ministros do STF, nos seguintes termos:

- **R\$ 41.650,92** — a partir de 1.º.04.2023;
- **R\$ 44.008,52** — a partir de 1.º.02.2024;
- **R\$ 46.366,19** — a partir de 1.º.02.2025.

Então, uma coisa é a regra contida na Constituição, que depende de lei para sua regulamentação (eficácia limitada). Outra é o seu **valor provisório** (teto de retribuição) estabelecido no citado art. 8.º, **EC n. 41/2003**. Esse dispositivo foi declarado pelo STF como de “**eficácia imediata**”, já que definiu um específico valor a ser observado até o formal estabelecimento do teto do funcionalismo por lei específica (**RE 609.381/GO**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.10.2014, *DJE* de 11.12.2014).

■ 5.5. A CLASSIFICAÇÃO DE MARIA HELENA DINIZ

Em primorosa monografia sobre o tema, Maria Helena Diniz, baseando-se em diversas classificações das **normas constitucionais quanto à sua eficácia**, apresentadas pela doutrina (Cooley, Rui Barbosa, Caetano Azzariti, Franchini, Vezio Crisafulli, José Afonso da Silva, Pinto Ferreira, Celso Bastos e Carlos A. Britto, Celso Antônio Bandeira de Mello), tendo por critério a questão da intangibilidade e da produção dos efeitos concretos, classifica as normas constitucionais (segundo a sua eficácia) em: **normas supereficazes** ou com **eficácia absoluta**; **normas de eficácia plena**; **normas com eficácia relativa restringível**; **normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa**.¹⁷

■ **Normas supereficazes ou com eficácia absoluta:** são intangíveis, não podendo ser emendadas. Contêm uma força paralisante total de qualquer legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las. Exemplos: textos constitucionais que amparam: a) a **federação** (arts. 1.º; 18; 34, VII, “c”; 46, § 1.º); b) o **voto direto, secreto, universal e periódico** (art. 14); c) a **separação de Poderes** (art. 2.º); d) os **direitos e garantias individuais** (art. 5.º, I a LXXVIII), enfim, as normas **intangíveis** por força dos arts. 60, § 4.º (as chamadas **cláusulas pétreas**), e 34, VII, “a” e “b”.

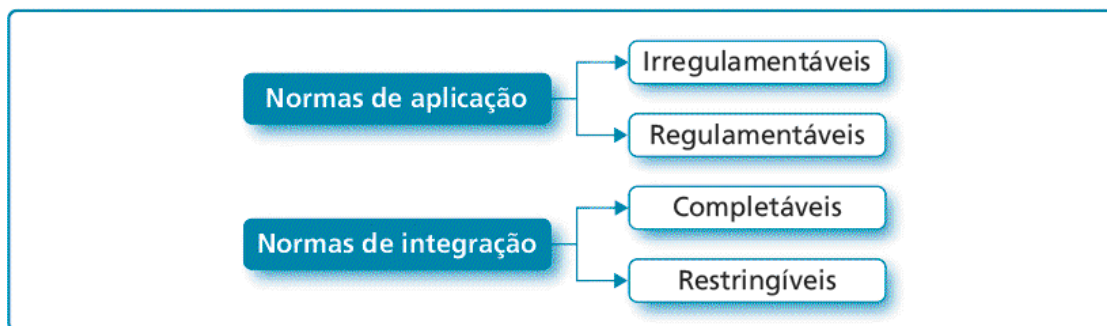
■ **Normas com eficácia plena:** contêm “... todos os elementos imprescindíveis para que haja a possibilidade da produção imediata dos efeitos previstos, já que, apesar de suscetíveis de emenda, não requerem normação subconstitucional subsequente. Podem ser imediatamente aplicadas. Consistem, por exemplo, nos preceitos que contenham proibições, confirmam isenções, prerrogativas e que não indiquem órgãos ou processos especiais para sua execução”.

Exemplos: arts. 1.º, parágrafo único; 14, § 2.º; 17, § 4.º; 21; 22; 37, III; 44, parágrafo único; 69; 153; 155; 156 etc.

■ **Normas com eficácia relativa restringível:** correspondem às normas de eficácia contida na classificação exposta de José Afonso da Silva, com preferência para a nomenclatura proposta por Michel Temer (**eficácia redutível** ou **restringível**), sendo de aplicabilidade imediata ou plena. Enquanto não sobrevier a restrição, o direito nelas contemplado será pleno. Exemplos: arts. 5.º, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXIV, LX, LXI; 84, XXVI; 139; 170, parágrafo único; 184 etc.

■ **Normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa:** dependem de lei complementar ou ordinária para o exercício do direito ou benefício consagrado. “Sua possibilidade de produzir efeitos é mediata, pois, enquanto não for promulgada aquela lei complementar ou ordinária, não produzirão efeitos positivos, mas terão eficácia paralisante de efeitos de normas precedentes incompatíveis e impeditivas de qualquer conduta contrária ao que estabelecerem.” Podem ser de **princípio institutivo** (“dependentes de lei para dar corpo a instituições, pessoas, órgãos, nelas previstos” — exemplos: arts. 17, IV; 25, § 3.º; 43, § 1.º etc.), ou **normas programáticas** (programas a serem desenvolvidos mediante lei infraconstitucional — exemplos: arts. 205; 211; 215; 218; 226, § 2.º etc.).

■ 5.6. A CLASSIFICAÇÃO DE CELSO RIBEIRO BASTOS E CARLOS AYRES BRITTO



Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto classificam as normas constitucionais em *normas de aplicação* (irregulamentáveis ou regulamentáveis) e *normas de integração* (completáveis ou restringíveis).¹⁸

As **normas de aplicação** já estão aptas a produzir todos os seus efeitos, dispensando regulamentação (ex.: art. 2.º, CF/88) ou permitindo-a, mas, nesta hipótese, sem qualquer restrição do conteúdo constitucional.

Já as **normas de integração**, como o nome sugere, são **integradas** pela legislação infraconstitucional. Entre elas e a sua aplicação real coloca-se outra norma integradora de sentido, fazendo surgir uma unidade de conteúdo entre as duas espécies normativas. Ora são **completáveis** (exigem uma legislação integrativa para a completa produção de seus efeitos — *sentido de complemento, colmatação ou preenchimento de um vazio regradório preexistente*), ora **restringíveis** (estabelecem a possibilidade de o legislador infraconstitucional reduzir o comando constitucional — *acepção de encurtamento, redução ou contração de um campo regulatório de maior abrangência*).

■ 5.7. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA EXAURIDA E APLICABILIDADE ESGOTADA

Sugeridas por Uadi Lammêgo Bulos,¹⁹ as normas de eficácia exaurida, ou esvaída, “... são aquelas, como o próprio nome diz, que já extinguiram a produção de seus efeitos. Por isso, estão esgotadas, dissipadas, ou desvanecidas, condicionando, assim, sua aplicabilidade”. São próprias do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), notadamente aquelas normas que já cumpriram o papel, encargo ou tarefa para o qual foram propostas. Exemplos: arts. 1.º, 2.º, 3.º, 14, 20, 25, 48 e vários outros do ADCT.

Muito embora **próprias do ADCT**, pela própria lógica das normas que são identificadas como de *disposição constitucional transitória*, entendemos ser possível encontrar norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada em outras disposições de caráter constitucional, como, por exemplo, no corpo do texto, em emendas, ou mesmo em tratados internacionais com *status* de Constituição (art. 5.º, § 3.º), apesar, reforçamos, entendemos ser esperado esse tipo de situação em relação às normas que integram o ADCT. Vamos a um exemplo.

Conforme já tivemos a oportunidade de observar em outras passagens desta obra, a **EC n. 91/2016** não alterou formalmente nenhum artigo da Constituição, nem introduziu disposição na Carta. No caso, estamos diante de uma norma constitucional que está fora do texto, mas que, naturalmente, pelo “bloco de constitucionalidade”, tem, inegavelmente, caráter constitucional.

Pois bem, referida disposição constitucional alterou a regra sobre perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, estabelecendo a possibilidade, **excepcional e em período determinado**, de desfiliação, sem prejuízo do mandato (cf. *item 18.5*). Essa faculdade constitucional pôde ser exercida somente nos 30 dias seguintes à promulgação da emenda

constitucional. Assim, entendemos que referida disposição, findo o prazo, passou a ter eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada.

Muito embora referidas normas tenham cumprido a sua “missão”, entendemos que as mesmas continuam existindo no ordenamento com **eficácia jurídica**. Dessa forma, por exemplo, se uma lei futura violar o direito introduzido pela disposição constitucional transitória, certamente poderá ser declarada inconstitucional tendo como parâmetro a referida norma de eficácia exaurida.

■ 5.8. NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E O GRADUALISMO EFICACIAL DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o art. 5.º, § 1.º, CF/88, têm **aplicação imediata**.

O termo “aplicação” **não** se confunde com “aplicabilidade”, na teoria de José Afonso da Silva, que entende, como visto, terem as normas de eficácia **plena** e **contida** “aplicabilidade” **direta** e **imediata**, e as de eficácia **limitada**, aplicabilidade **mediata** ou **indireta**.

Ensina José Afonso da Silva que ter **aplicação imediata** significa que as normas constitucionais são “dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. A regra é que as normas definidoras de *direitos e garantias individuais* (direitos de 1.ª dimensão, acrescente-se) sejam de *aplicabilidade imediata*. Mas aquelas definidoras de *direitos sociais, culturais e econômicos* (direitos de 2.ª dimensão, acrescente-se) nem sempre o são, porque não raro dependem de providências ulteriores que lhes completem a eficácia e possibilitem sua aplicação”.²⁰

Dessa maneira, “por regra, as normas que consubstanciam os *direitos fundamentais democráticos e individuais* são de *aplicabilidade imediata*, enquanto as que definem os *direitos sociais* tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de *eficácia limitada e aplicabilidade indireta*”.²¹

Como exemplo de norma definidora de direito e garantia fundamental que depende de lei, podemos citar o **direito de greve** dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, ou o da **aposentadoria especial**, garantido nos termos do art. 40, § 4.º, devendo ser observadas as regras

trazidas pela **EC n. 103/2019** (Reforma da Previdência), inclusive as suas regras de transição.

Então, qual seria o sentido dessa regra inscrita no art. 5.º, § 1.º?

José Afonso da Silva explica: “*em primeiro lugar*, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. *Em segundo lugar*, significa que o Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma **situação concreta** nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes”.²²

Assim, diante da omissão de **medida** para tornar efetiva norma constitucional, a CF/88 trouxe duas importantes novidades:

■ **ação direta de inconstitucionalidade por omissão — ADO:** regulamentada pela Lei n. 12.063/2009 — cf. *item 6.7.4*);

■ **mandado de injunção:** regulamentado pela Lei n. 13.300/2016 — cf. *item 14.11.5*.

Estamos diante de “remédios” para combater a denominada “síndrome de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada. De acordo com a jurisprudência do STF, de modo geral, em se tratando de “Poder”, a ADO seria o instrumento para fazer um **apelo** ao legislador, constituindo-o em mora, enquanto o MI, por seu turno, seria o importante instrumento de **concretização** dos direitos fundamentais (cf. *item 14.11.5.7*) e, assim, dando um exato sentido ao art. 5.º, § 1.º, que fala em **aplicação imediata** (cf. MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.º.07.2008, Plenário, DJE de 26.09.2008).²³

Conforme bem definiu a Min. Cármen Lúcia, no julgamento de vários Mandados de Injunção (MI 828/DF, MI 841/DF, MI 850/DF, MI 857/DF, MI 879/DF, MI 905/DF, MI 927/DF, MI 938/DF, MI 962/DF, MI 998/DF), “o mandado de injunção é ação constitucional de **natureza mandamental**, destinada a **integrar a regra constitucional ressentida, em sua eficácia**, pela ausência de norma que assegure a ela o vigor pleno”.

Qualquer outro entendimento geraria o mais nefasto sentimento de frustração e desprestígio aos direitos fundamentais, reduzindo a importante conquista do MI a um nada.

Finalmente, vale lembrar os ensinamentos de Maria Helena Diniz, que identifica um **gradualismo eficaz das normas constitucionais**. “Há um escalonamento na intangibilidade e nos efeitos dos preceitos constitucionais... Todas têm juridicidade, mas seria uma utopia considerar que têm a mesma eficácia, pois o seu grau eficaz é variável. Logo, **não há norma constitucional destituída de eficácia**. Todas as disposições constitucionais têm a possibilidade de produzir, a sua maneira, concretamente, os efeitos jurídicos por elas visados.”²⁴

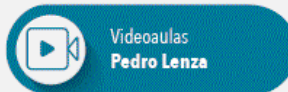
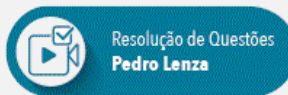
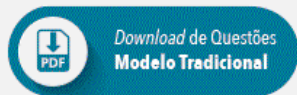
■ 5.9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO STF

Dado o objetivo do presente estudo, acreditamos interessante **esquematizar** importantes julgados do STF definindo a eficácia e aplicabilidade de algumas normas da Constituição — o que, certamente, facilitará para as provas e concursos —, bem como para o nosso ilustre e nobre professor trabalhar os precedentes em sala de aula com os alunos (*cases*), remetendo-os para a plataforma.

■ 5.10. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

5

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS





CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

■ 6.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: DIREITO COMPARADO E SISTEMA BRASILEIRO¹

■ 6.1.1. Noções preliminares

O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na “Lei Maior”.

Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma **Constituição rígida** e a **atribuição de competência a um órgão** para resolver os problemas de constitucionalidade, órgão esse que variará de acordo com o sistema de controle adotado.

Conforme já estudado, **Constituição rígida** é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso, mais árduo, mais solene que o processo legislativo de alteração das normas não constitucionais. A CF brasileira é rígida, diante das regras procedimentais solenes de alteração previstas em seu art. 60.

A ideia de controle, então, emanada da rigidez, pressupõe a noção de um **escalonamento normativo**, ocupando a Constituição o grau máximo na aludida relação hierárquica, caracterizando-se como **norma de validade** para os demais atos normativos do sistema.

Trata-se do **princípio da supremacia da Constituição**, que, nos dizeres do Professor José Afonso da Silva, reputado por Pinto Ferreira como “pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito político”, “significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei

suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as *normas fundamentais* de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas”. Desse princípio, continua o mestre, “resulta o da *compatibilidade vertical* das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a Constituição. As que não forem compatíveis com ela são inválidas, pois a *incompatibilidade vertical* resolve-se em favor das normas de grau mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores”.²

A Constituição está, pois, no ápice da pirâmide, orientando e “iluminando” os demais atos infraconstitucionais.

Alertamos que há uma tendência a ampliar o conteúdo do parâmetro de constitucionalidade de acordo com aquilo que a doutrina vem chamando de **bloco de constitucionalidade** e que será estudado no *item 6.7.1.3*.

■ 6.1.2. **A inconstitucionalidade das leis e a regra geral da “teoria da nulidade”. Sistema austríaco (Kelsen) “versus” Sistema norte-americano (Marshall). Anulabilidade “versus” nulidade**

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da **teoria da nulidade** ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando **o plano da validade**).

Trata-se, nesse sentido, de ato **declaratório** que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento”, de “origem” do ato normativo.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (*natimorta*), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão do vício de inconstitucionalidade) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade”

(ou paradigma de controle), consagra a **teoria da nulidade**, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”.³

A doutrina tradicional já se manifestava nessa linha, destacando-se os ensinamentos de Rui Barbosa,⁴ Alfredo Buzaid,⁵ Castro Nunes⁶ e Francisco Campos.⁷

Cappelletti, ao descrever o sistema “norte-americano”, observa que “... a lei inconstitucional, porque contrária a uma *norma superior*, é considerada *absolutamente nula* (‘null and void’) e, por isto, *ineficaz*, pelo que o juiz, que exerce o poder de controle, não anula, mas, meramente, *declara (preexistente) nulidade da lei inconstitucional*”.⁸

Contra esse entendimento, destaca-se a **teoria da anulabilidade da norma inconstitucional** defendida por Kelsen⁹ e que influenciou a Corte Constitucional austríaca, caracterizando-se como constitutiva a natureza jurídica da decisão que a reconhece.¹⁰

Segundo Cappelletti, no **sistema austríaco**, diferentemente do sistema norte-americano da nulidade, “... a Corte Constitucional não declara uma nulidade, mas *anula, cassa* (‘aufhebt’) uma lei que, até o momento em que o pronunciamento da Corte não seja publicado, é *válida e eficaz*, posto que inconstitucional (*sic*). Não é só: mas — coisa ainda mais notável — a Corte Constitucional austríaca tem, de resto, o poder discricionário de dispor que a anulação da lei opere somente a partir de uma determinada data *posterior* (‘Kundmachung’) de seu pronunciamento, contanto que este diferimento de eficácia constitutiva do pronunciamento não seja superior a um ano...”.¹¹

Na linha da **teoria da anulabilidade** da lei inconstitucional (ineficácia a partir da decisão), no **Brasil**, em sede doutrinária e minoritária, destacam-se Pontes de Miranda¹² e Regina Nery Ferrari.¹³

A confrontação dos sistemas pode ser assim esquematizada:

SISTEMA AUSTRIACO (KELSEN)

SISTEMA NORTE-AMERICANO

	(MARSHALL)
■ decisão tem eficácia constitutiva (caráter constitutivo-negativo)	■ decisão tem eficácia declaratória de situação preexistente
■ por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da eficácia	■ por regra, o vício de inconstitucionalidade é aferido no plano da validade
■ por regra, decisão que reconhece a inconstitucionalidade produz efeitos ex nunc (prospectivos)	■ por regra, decisão que declara a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc (retroativos)
■ a lei inconstitucional é ato anulável (a anulabilidade pode aparecer em vários graus)	■ a lei inconstitucional é ato nulo (null and void), ineficaz (nulidade ab origine), írrito e, portanto, desprovido de força vinculativa
■ lei provisoriamente válida , produzindo efeitos até a sua anulação	■ invalidação ab initio dos atos praticados com base na lei inconstitucional, atingindo-a no berço
■ o reconhecimento da ineficácia da lei produz efeitos a partir da decisão ou para o futuro (ex nunc ou pro futuro), sendo <i>erga omnes</i> , preservando-se, assim, os efeitos produzidos até então pela lei	■ a lei, por ter nascido morta (natimorta), nunca chegou a produzir efeitos (não chegou a “viver”), ou seja, apesar de existir, não entrou no plano da eficácia

Esse quadro representa tanto a teoria da nulidade (que prevalece na realidade brasileira) como a da anulabilidade em seus extremos. Ao longo dos tempos, doutrina e jurisprudência procuraram flexibilizá-las. É o que passamos a estudar.

■ 6.1.3. Flexibilização das teorias da “nulidade absoluta da lei declarada inconstitucional” e da “anulabilidade da norma inconstitucional” no direito estrangeiro (brevíssima noção)

Cappelletti observa que tanto o rigor da regra da **não retroatividade** do sistema austríaco como o da técnica da **nulidade absoluta** do sistema norte-americano tiveram de ser reavaliados, visto que insubsistentes.¹⁴

■ 6.1.3.1. *Áustria*

Em relação à **Áustria**, em 1929, a regra que negava qualquer retroatividade às decisões e pronunciamentos da Corte Constitucional foi atenuada, fixando-se a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão anulatória.

Regina Ferrari observa que “o efeito voltado para o futuro — *ex nunc* — é o normal das sentenças constitutivas, mas não pertence à sua essência: o essencial é a produção de um estado jurídico que não existia antes de tal decisão”.

Conclui em seguida que “... a norma inconstitucional é anulável e os atos praticados sob o império dessa lei devem ser considerados válidos, até e enquanto não haja decisão que a fulmine com tal vício, operando eficaz e normalmente como qualquer outra disposição válida, já que o é até a decretação de inconstitucionalidade”. Finalmente, admite que referida sentença pode ter alcance *ex tunc*.¹⁵

■ 6.1.3.2. *Estados Unidos*

Quanto à técnica “fria” da nulidade *ab origine* (de origem norte-americana — “*the unconstitutional statute is not law at all*”¹⁶ — e adotada no Brasil), Cappelletti passa a imaginar situações práticas que apontariam a sua inadequação.

Como ficariam todos os atos praticados, durante longos anos, sob a vigência de uma lei que venha a ser declarada inconstitucional? Como resolver a questão de um contrato que tenha sido celebrado e servido de base para a prestação de um serviço público por longos anos? Como ficarão os efeitos da lei? Como sustentar o cumprimento de uma pena que tenha

fundamento em lei que venha a ser declarada inconstitucional? Que fazer com os efeitos já consolidados? E a coisa julgada? E o mínimo de certeza e estabilidade que todas as relações jurídicas devem ter?

Nos **Estados Unidos**, o precedente lembrado é o caso *Linkletter v. Walker*, 381 U.S. 618 (1965), em relação ao qual, realizando análise política, a Suprema Corte entendeu que o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei que permitia certo sistema de colheita de provas não retroagiria para invalidar decisões já tomadas com base naquele sistema.

Conforme relatado por Gilmar Mendes,¹⁷ toda a polêmica decorreu do julgamento do caso *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961), no qual a Suprema Corte entendeu, nos termos da 4.^a Emenda, que a prova obtida ilegalmente não poderia ser considerada no juízo penal, seja nas Cortes Federais, como também, e inovando, nas Estaduais, superando-se a doutrina fixada em *Wolf v. Colorado*, 338 U.S. 25 (1949).

O objetivo era desestimular “ações ilegais da polícia, proteger a privacidade das vítimas e ensejar que os órgãos federais e estaduais operassem com base nos mesmos padrões jurídicos”. Contudo, à decisão não foi atribuído efeito retroativo, para evitar, segundo o Juiz Clark, a quebra de confiança depositada em *Wolf v. Colorado* e impor “desmedida carga de trabalho para a administração da Justiça”.¹⁸

Assim, o pedido de se considerar ilegal, no caso *Linkletter v. Walker*, a obtenção da prova por arrombamento, agora com base no novo precedente fixado em *Mapp v. Ohio*, foi indeferido para evitar sério problema de administração de justiça (e a perspectiva de diversos pedidos no mesmo sentido de revisão), surgindo, pois, uma importante atenuação ao rígido princípio da nulidade absoluta da lei.¹⁹

Parafraseando Sérgio Resende de Barros, parecia estar sendo desatado o “nó górdio” do sistema de controle, flexibilizando o sistema da nulidade absoluta e se permitindo a **modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade**.²⁰

■ 6.1.3.3. *Espanha*

García de Enterría, na **Espanha**, destaca a hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e *pro futuro* tendo como precedente a **Sentença n. 45/1989**.²¹

■ 6.1.3.4. **Portugal**

Em **Portugal**, muito embora a declaração de nulidade da lei inconstitucional seja a regra geral, há expressa autorização constitucional permitindo a modulação dos efeitos da decisão, bem como a desconstituição da coisa julgada em matérias específicas e desde que haja expressa determinação pelo Tribunal Constitucional.

■ 6.1.3.5. **Alemanha**

Na **Alemanha**, o princípio da nulidade da lei inconstitucional está consagrado como regra geral, nos termos do § 78 da Lei do *Bundesverfassungsgericht*.

Contudo, ensina Gilmar Mendes, várias técnicas surgem no sentido de resolver alguns problemas trazidos pela rigidez do princípio da nulidade (que é reconhecido como constitucional, como visto), destacando-se o “**apelo ao legislador**” ou “**situação ainda constitucional**” (*Appellentscheidung*)²² e a **declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade** (*Unvereinbarkeitserklärung* — omissão parcial; exclusão de benefício incompatível com o princípio da isonomia;²³ ameaça de caos jurídico, lacunas ameaçadoras etc.).²⁴

■ 6.1.4. **Flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro**

A regra geral da nulidade absoluta da lei inconstitucional vem sendo, casuisticamente, afastada pela jurisprudência brasileira e repensada pela doutrina.

Ao lado do **princípio da nulidade**, que adquire, certamente, o *status* de **valor constitucionalizado**, tendo em vista o princípio da **supremacia da Constituição**, outros valores, de igual hierarquia, destacam-se, por exemplo, o princípio da **segurança jurídica** e o da **boa-fé**.

Nesses termos, valendo-se da evolução da jurisprudência norte-americana, Lúcio Bittencourt afirma que a “... doutrina da *ineficácia ab initio* da lei inconstitucional não pode ser entendida em termos absolutos, pois que os efeitos *de fato* que a norma produziu não podem ser suprimidos, sumariamente, por simples obra de um decreto judiciário”.²⁵

■ 6.1.4.1. *A mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado — art. 27 da Lei n. 9.868/99 e art. 11 da Lei n. 9.882/99*

Toda evolução e movimento verificados no direito estrangeiro também foram considerados no Brasil, que “legalizou” a tendência jurisprudencial que já vinha sendo percebida,²⁶ muito embora lentamente, a flexibilizar a rigidez do princípio geral — e que ainda é regra, diga-se de passagem — da **nulidade** da lei declarada inconstitucional no controle concentrado.

Nesse sentido, com bastante propriedade, estabelece o **art. 27 da Lei n. 9.868/99**:

“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de **2/3** de seus membros, **restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado**” (no mesmo sentido, cf. art. 11 da Lei n. 9.882/99 — ADPF).

Trata-se da denominada, pela doutrina, técnica de **modulação dos efeitos da decisão** e que, nesse contexto, permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando, por consequência e

conforme visto, outros valores também constitucionalizados, como os da **segurança jurídica**, do **interesse social**, da **boa-fé**, da **proteção da confiança legítima**, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito (impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico) (Celso de Mello, ARE 709.212).

Nesse sentido foram as razões apontadas na *exposição de motivos* do projeto de lei que deu origem à referida Lei n. 9.868/99: “Entendeu, portanto, a Comissão que, ao lado da ortodoxa declaração de nulidade, há de se reconhecer a possibilidade de o Supremo Tribunal, em casos excepcionais, mediante decisão da maioria qualificada (dois terços dos votos), estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a inconstitucionalidade com eficácia *ex nunc* ou *pro futuro*, especialmente naqueles casos em que a declaração de nulidade se mostre inadequada (v.g.: lesão positiva ao princípio da isonomia) ou nas hipóteses em que a lacuna resultante da declaração de nulidade possa dar ensejo ao surgimento de uma situação ainda mais afastada da vontade constitucional”.²⁷

■ 6.1.4.2. *A mitigação do princípio da nulidade no controle difuso*

A regra geral do art. 27 da Lei n. 9.868/99, em casos particulares, também tem sido aplicada, por analogia, ao controle difuso.

Em importante precedente, destaca-se ação civil pública ajuizada pelo MP de São Paulo objetivando reduzir o número de vereadores do Município de **Mira Estrela**, de 11 para 9, adequando-se ao mínimo constitucional previsto na redação original²⁸ do art. 29, IV, CF/88. Pouco razoável seria um Município com 2.651 habitantes ter 11 vereadores, 2 além do mínimo constitucional.

O MP de São Paulo pedia a **devolução dos subsídios indevidamente pagos** e a **declaração incidental da inconstitucionalidade da lei** (controle difuso), com efeitos **retroativos**.

Porém, conforme ponderou o Min. Maurício Corrêa na parte final de seu voto, “... a declaração de nulidade com os ordinários efeitos *ex tunc* da composição da Câmara representaria um **verdadeiro caos quanto à validade**, não apenas, em parte, das eleições já realizadas, mas dos atos legislativos praticados por esse órgão sob o manto presuntivo da legitimidade. Nessa situação específica, tenho presente excepcionalidade tal a justificar que a presente decisão prevaleça **tão somente para as legislaturas futuras**, assegurando-se a prevalência, no caso, do sistema até então vigente em nome da segurança jurídica...”.²⁹

Partindo desse precedente, interessante a análise de tantos outros julgados no sentido de se **modular os efeitos da decisão** também no controle difuso, destacando-se os julgamentos do **RE-AgR 434.222/AM** e do **MS 22.357/DF**.

O STF, portanto, à luz do **princípio da segurança jurídica**, do **princípio da confiança**, da **ética jurídica**, da **boa-fé**, todos **constitucionalizados**, em verdadeira **ponderação de valores**, vem, casuisticamente, mitigando os efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade das leis também no controle difuso, preservando-se situações pretéritas consolidadas com base na lei objeto do controle.

Sem dúvida, de maneira coerente, imprescindível essa tendência de **mitigação do princípio da nulidade**, tanto em sede de controle concentrado como em sede de controle difuso.

■ 6.1.5. Constitucionalidade e inconstitucionalidade superveniente?

REGRA	EXCEÇÃO
■ proibição do fenômeno da constitucionalidade superveniente (vício congênito — ato nulo)	■ ADI 2.240 e ADO 3.682: caso Luís Eduardo Magalhães — possibilidade de constitucionalidade superveniente decorrente de decisão judicial ■ EC n. 57/2008: correção de vício congênito por decisão política do parlamento

■ proibição do fenômeno da inconstitucionalidade superveniente (lei nasceu “perfeita”, sem vício formal e sem vício material)	■ mutação constitucional ■ mudança do substrato fático da norma
---	--

Em regra, não se pode admitir nem o fenômeno da constitucionalidade superveniente, nem o da inconstitucionalidade superveniente.

A) Constitucionalidade superveniente

Constitucionalidade superveniente significa o fenômeno pelo qual uma lei ou ato normativo que tenha “nascido” com algum vício de inconstitucionalidade, seja formal ou material, e se constitucionaliza. Esse fenômeno é inadmitido na medida em que o vício congênito não se convalida. Ou seja, se a lei é inconstitucional, trata-se de ato nulo (*null and void*), írrito, natimorto, ineficaz e, assim, por regra, não pode ser “corrigido”, pois o vício de inconstitucionalidade não se convalida, é um vício insanável, “incurável”.

Como exceção a essa regra, lembramos o julgamento da ADI 2.240 e da ADO 3.682, pelas quais se possibilitaria, artificialmente, a “correção” do processo de criação do município Luís Eduardo Magalhães, conforme estudamos no *item 6.7.1.9*. Estaríamos diante do fenômeno da constitucionalidade superveniente por **decisão judicial**, o que não se verificou, pois o prazo fixado na ADO 3.682, para se corrigir o vício congênito da lei estadual que criou o novo município, transcorreu *in albis*.

Como se sabe (e, como se disse, o tema poderá ser compreendido no *item 6.7.1.9*), a convalidação dos extraordinários vícios de inconstitucionalidade se deu pela **EC n. 57/2008**, que, então, poderia ser um “triste”, porque flagrantemente “inconstitucional”, exemplo de constitucionalidade superveniente por emenda constitucional e, assim, decisão política do parlamento, sempre passível, nesse caso específico, de controle judicial.

B) Inconstitucionalidade superveniente

Inconstitucionalidade superveniente, por sua vez, seria o fenômeno pelo qual uma lei ou ato normativo que “nasceu” “perfeita”, sem nenhum tipo de vício de inconstitucionalidade, vem a se tornar inconstitucional.

Em regra, esse fenômeno não é observado. A seguir, dois exemplos clássicos, na visão da jurisprudência do STF, que afastam essa possibilidade em razão da caracterização de outros institutos específicos e próprios:

■ **lei editada antes do advento da nova Constituição (fenômeno da recepção)**: se a lei foi editada antes do advento de uma nova Constituição, duas situações surgem: ou a lei é compatível e será recepcionada, ou a lei é incompatível e, então, nesse caso, será **revogada** por não recepção (cf. *item 4.8.1*).

Não se pode falar em inconstitucionalidade superveniente nesse caso, pois não haverá preenchimento da regra da contemporaneidade. Ou seja, para se falar em controle de constitucionalidade, a lei tem que ter sido editada na vigência do texto de 1988 e ser confrontada (parâmetro de controle) perante a CF/88 ou toda normatividade que tenha *status* de Constituição, dentro de uma perspectiva de “bloco de constitucionalidade” (cf. *item 6.7.1.3*).

■ **lei editada já na vigência da nova Constituição e superveniência de emenda constitucional futura que altere o fundamento de constitucionalidade da lei**: o STF entende que, se a lei foi editada já na vigência da nova Constituição sem nenhum tipo de vício, eventual emenda constitucional que mude o parâmetro de controle pode deixar de assegurar validade à referida norma, e, assim, a nova emenda constitucional **revogaria** a lei em sentido contrário. Não se trata, portanto, do fenômeno de inconstitucionalidade superveniente.

A regra da impossibilidade de inconstitucionalidade superveniente, contudo, apresenta duas exceções: **a)** mutação constitucional; **b)** mudança no substrato fático da norma.

No primeiro caso (**mutação constitucional**), a redação do dispositivo da Constituição não é alterada, mas o seu sentido interpretativo muda, surgindo, então, uma nova norma jurídica. As **mutações constitucionais**, portanto, exteriorizam o caráter **dinâmico** e de **prospecção** das normas jurídicas, por meio de **processos informais**. Informais no sentido de não serem previstos dentre aquelas mudanças formalmente estabelecidas no texto constitucional, como, por exemplo, as alterações por emendas constitucionais (cf. *item 3.1*).

Vamos imaginar uma lei que proibia a união estável homoafetiva e que, durante muito tempo, encontrou fundamento na CF/88, especialmente na hoje ultrapassada (literal) leitura do art. 226, § 3.º, que dispõe, para efeito da proteção do Estado, ser reconhecida a união estável entre o **homem** e a **mulher** como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Assim, no exemplo, em um primeiro momento, a referida lei, que só admitia a união estável entre o homem e a mulher, era considerada constitucional.

Com a evolução da sociedade e do entendimento da Corte, passou-se a admitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo, especialmente ao se fazer uma releitura do art. 226, § 3.º, à luz da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) e do art. 3.º, IV, que prescreve, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o de promover o bem de todos, **sem preconceitos** de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A lei, então, que nasceu constitucional, tornar-se-ia inconstitucional em razão da mudança no sentido interpretativo do parâmetro de constitucionalidade.

No segundo caso (**mudança no substrato fático da norma**), não se tem uma alteração no parâmetro da Constituição, mas nos novos aspectos de fato que surgem e que não eram claros no momento da primeira interpretação.

Como exemplo, lembramos o precedente do **amianto** (cf. *item 7.11.1*). Em um primeiro momento, o STF pronunciou-se no sentido de se declarar a constitucionalidade da lei federal que admitia o uso controlado de uma das

modalidades do amianto (asbesto branco). Em momento seguinte, em razão da mudança no substrato fático da norma, referida disposição se tornou inconstitucional, passando a norma por um **processo de inconstitucionalização**.

Percebam, seja na primeira interpretação, seja 22 anos depois quando houve a mudança de entendimento, a Constituição sempre proibiu substâncias que fizessem mal à saúde ou ao meio ambiente. O que se observou foi um novo diagnóstico do potencial de violação à saúde, inclusive em razão dos avanços tecnológicos e de pesquisa. Por esse motivo é que estamos fazendo uma distinção com o fenômeno da mutação constitucional, quando a alteração é do sentido da própria Constituição.

Conforme anotou o Min. Dias Toffoli em seu voto proferido no julgamento da **ADI 3.937**, “as percepções dos níveis de consenso e dissenso em torno da necessidade ou não do banimento do amianto não são mais os mesmos observados quando da edição da referida norma geral (Lei n. 9.055/95, acrescente-se). Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se naquela época na **possibilidade do uso controlado dessa substância**, hoje (**22 anos depois**, acrescente-se), o que se observa é um consenso em torno da **natureza altamente cancerígena do mineral** e da **inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura**, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador” (Pleno, j. 24.08.2017, fls. 15 do voto do Min. Dias Toffoli, *DJE* de 1.º.02.2019, mantido o entendimento no julgamento dos embargos de declaração, j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023).

Além de toda a argumentação destacando os documentos internacionais de proteção a direitos humanos, o Min. Dias Toffoli ainda observa: “quando da edição da Lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, hoje já existem materiais alternativos. Além de ser importado desde 2003, o **PVA**, por exemplo, passou a ser produzido no Brasil a partir de matéria-prima nacional, o fio de polipropileno, possibilitando a substituição da crisotila. Ressalte-se que a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Saúde já recomendaram a substituição do amianto pelas fibras de poliálcool vinílico (PVA) ou de polipropileno (PP), conforme Nota Técnica elaborada por Grupo de Trabalho dessa autarquia federal (fl. 1068)...” (fls. 24 do voto).

Finalmente, conclui: “esse conjunto de fatores — quais sejam, (i) o consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila; (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 (vinte e dois anos) anos — revela a **inconstitucionalidade superveniente** (sob a óptica material) da Lei Federal n. 9.055/95, por ofensa, sobretudo, ao direito à saúde (arts. 6.º e 196, CF/88); ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7.º, XXII, CF/88); e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88)” (fls. 25).

■ 6.2. BREVE ANÁLISE EVOLUTIVA DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE³⁰

■ 6.2.1. Constituição de 1824

No tocante ao **sistema brasileiro de controle de constitucionalidade**,³¹ a Constituição Imperial de 1824 não estabeleceu nenhum sistema de controle, consagrando o **dogma da soberania do Parlamento**, já que, sob a influência do direito francês (*a lei como “expressão da vontade geral”*) e do inglês (*supremacia do Parlamento*), somente o Órgão Legislativo poderia saber o verdadeiro sentido da norma.

No entanto, nas precisas palavras de Clèmerson Merlin Clève, “não foi apenas o dogma da soberania do Parlamento que impediu a emergência da fiscalização jurisdicional da constitucionalidade no Império. O Imperador, enquanto detentor do Poder Moderador, exercia uma função de coordenação; por isso, cabia a ele (art. 98) manter a ‘independência, o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes’. Ora, o papel constitucional atribuído ao Poder Moderador, ‘chave de toda a organização política’ nos termos da Constituição, praticamente inviabilizou o exercício da função de fiscalização constitucional pelo Judiciário. Sim, porque, nos termos da Constituição de 1824, ao Imperador cabia solucionar os conflitos envolvendo os Poderes, e não ao Judiciário”. Portanto, completa o ilustre jurista, “o dogma da ‘soberania do Parlamento’, a previsão de um Poder Moderador e mais a influência do direito público europeu, notadamente inglês e francês, sobre os homens públicos brasileiros, inclusive os operadores jurídicos, explicam a inexistência de um modelo de fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis no Brasil ao tempo do Império”.³²

■ 6.2.2. Constituição de 1891

A partir da Constituição Republicana de 1891, sob a influência do direito norte-americano, consagra-se, no direito brasileiro, mantida até a CF/88, a técnica de controle de constitucionalidade de lei ou ato com indiscutível caráter normativo (desde que infraconstitucionais), por qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência e organização judiciária. Trata-se do denominado **controle difuso** de constitucionalidade, repressivo, posterior, ou aberto, pela via de exceção ou defesa, pelo qual a declaração de inconstitucionalidade se implementa de modo incidental (*incidenter tantum*), prejudicialmente ao mérito.³³

■ 6.2.3. Constituição de 1934

A **Constituição de 1934**, mantendo o sistema de controle difuso, estabeleceu, além da **ação direta de inconstitucionalidade interventiva**, a denominada **cláusula de reserva de plenário** (a declaração de inconstitucionalidade só poderia ser pela **maioria absoluta** dos membros do tribunal) e a atribuição ao **Senado Federal** de competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato declarado inconstitucional por decisão definitiva.

Asseverou Gilmar Ferreira Mendes, ao comentar as novidades trazidas pela Constituição de 1934 em relação ao sistema de controle de constitucionalidade, que “talvez a mais fecunda e inovadora alteração (...) se refira à ‘declaração de inconstitucionalidade para evitar a intervenção federal’, tal como a denominou Bandeira de Mello, isto é, a representação interventiva, confiada ao Procurador-Geral da República, nas hipóteses de ofensa aos princípios consagrados no art. 7.º, I, *a a h*, da Constituição. Cuidava-se de fórmula peculiar de composição judicial dos conflitos federativos, que condicionava a eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado (art. 41, § 3.º), à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, § 2.º)”.³⁴

■ 6.2.4. Constituição de 1937

A **Constituição de 1937**, denominada **Polaca**, já que elaborada sob a inspiração da Carta ditatorial polonesa de 1935, não obstante tenha mantido o sistema difuso de constitucionalidade, estabeleceu a possibilidade de o Presidente da República influenciar as decisões do Poder Judiciário que declarassem inconstitucional determinada lei, já que, **de modo discricionário**, poderia submetê-la ao Parlamento para o seu reexame, podendo o Legislativo, pela decisão de 2/3 de ambas as Casas, tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade, desde que confirmasse a validade da lei.³⁵ Referidas regras, inegavelmente, implicavam o desproporcional fortalecimento do Executivo.

■ 6.2.5. **Constituição de 1946**

A **Constituição de 1946**, fruto do movimento de redemocratização e reconstitucionalização instaurado no País, flexibilizou a hipertrofia do Executivo, restaurando a tradição do sistema de controle de constitucionalidade. Através da **EC n. 16, de 26.11.1965**, criou-se no Brasil uma nova modalidade de **ação direta de inconstitucionalidade**, de competência originária do STF, para processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, a ser proposta, exclusivamente, pelo Procurador-Geral da República. Estabeleceu-se, ainda, a possibilidade de controle concentrado em âmbito estadual.

■ 6.2.6. **Constituição de 1967 e EC n. 1/69**

Esta última regra foi retirada pela **Constituição de 1967**, embora a **EC n. 1/69** tenha previsto o controle de constitucionalidade de lei municipal, em face da Constituição Estadual, para fins de intervenção no Município.

■ 6.2.7. **Constituição de 1988**

A **Constituição de 1988**, elaborada pela *Assembleia Nacional Constituinte* convocada pela **EC n. 26, de 27.11.1985**³⁶ (DOU de 28.11.1985, p. 17422, col. 1), trouxe quatro principais novidades no sistema de controle de constitucionalidade.

Em relação ao controle concentrado em âmbito federal, **ampliou a legitimação para a propositura da representação de inconstitucionalidade**, acabando com o monopólio do Procurador-Geral da República. Em consonância com o art. 103, CF/88, o art. 2.º da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, legalizando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, dispõe que a ação direta de inconstitucionalidade poderá ser proposta pelos seguintes legitimados: *Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional*.

Estabeleceu-se, também, a possibilidade de **controle de constitucionalidade das omissões legislativas**, seja de forma concentrada (*ações diretas de inconstitucionalidade por omissão — ADO*, nos termos do art. 103, § 2.º), seja de modo incidental, pelo controle difuso (*mandado de injunção — MI*, na dicção do art. 5.º, LXXI — sobre a evolução da utilização do mandado de injunção, cf. *item 14.11.5*).

Nos termos do art. 125, § 2.º, os **Estados** poderão instituir a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedando, contudo, a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Por fim, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, facultou-se a criação da **arguição de descumprimento de preceito fundamental** (ADPF), no parágrafo único do art. 102.

Posteriormente, a **EC n. 3/93** estabeleceu a **ação declaratória de constitucionalidade** (ADC)³⁷ e reenumerou o parágrafo único do art. 102, CF/88, transformando-o em § 1.º, mantendo a redação original da previsão da ADPF, nos seguintes termos: “a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.

Enfim, a **EC n. 45/2004** (Reforma do Judiciário) ampliou a legitimação ativa para o ajuizamento da ADC (ação declaratória de constitucionalidade), igualando aos legitimados da ADI (ação direta de inconstitucionalidade), alinhados no art. 103, e estendeu o efeito vinculante, que era previsto de maneira expressa somente para a ADC, agora, também (apesar do que já dizia o art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 e da jurisprudência do STF), para a ADI. Tudo caminha para a expressa consagração da ideia de efeito dúplice ou ambivalente entre as duas ações, faltando somente a igualação dos seus objetos.

Por todo o exposto, valendo-nos das palavras de José Afonso da Silva, “o Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema misto e peculiar que combina o critério difuso por via de defesa com o critério concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, incorporando também, agora timidamente, a ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, *a* e III, e 103). A outra novidade está em ter reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal à matéria constitucional. Isso não o converte em Corte Constitucional. Primeiro porque não é o único órgão jurisdicional competente para o exercício da jurisdição constitucional, já que o sistema perdura fundado no critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer da prejudicial de inconstitucionalidade, por via de exceção. Segundo, porque a forma de recrutamento de seus membros denuncia que continuará a ser um Tribunal que examinará a questão constitucional com critério puramente técnico-jurídico, mormente porque, como Tribunal, que ainda será, do recurso extraordinário, o modo de levar a seu conhecimento e julgamento as questões constitucionais nos casos concretos, sua preocupação,

como é regra no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se possível, sem declarar inconstitucionalidades”.³⁸

■ 6.3. ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE E O “ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL”

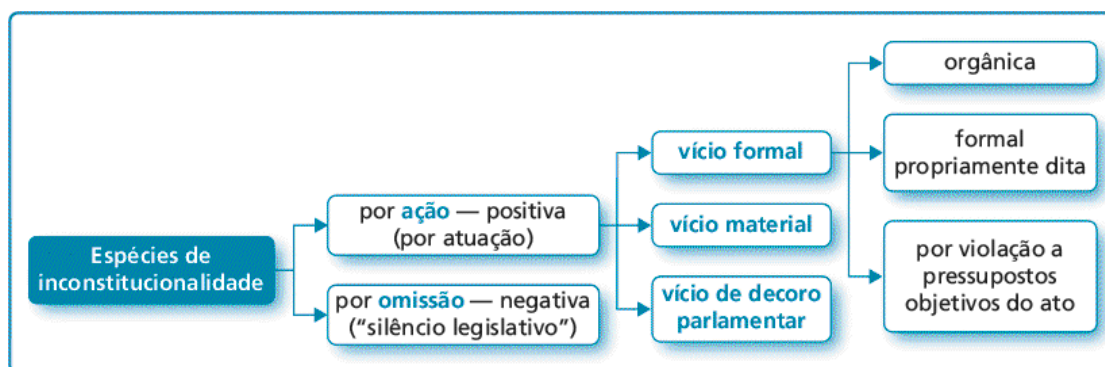
■ 6.3.1. Inconstitucionalidade por ação e por omissão (quadro esquemático)

O que se busca com esse tema é saber quando uma norma infraconstitucional padecerá do vício de inconstitucionalidade, que poderá verificar-se em razão de ato **comissivo** ou por **omissão** do Poder Público.

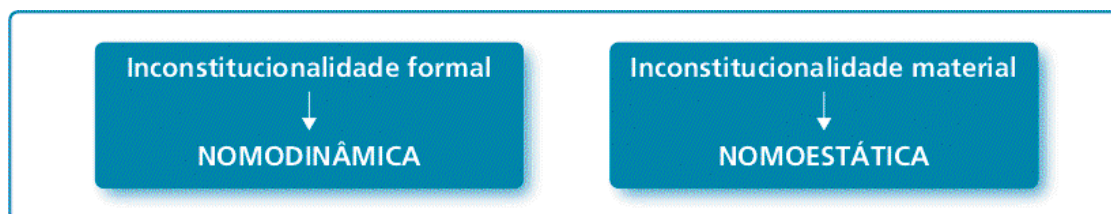
Fala-se, então, em inconstitucionalidade por **ação** (positiva ou por atuação), a ensejar a **incompatibilidade vertical** dos atos inferiores (leis ou atos do Poder Público) com a Constituição,³⁹ e, em sentido diverso, em inconstitucionalidade por **omissão**, decorrente da inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de **eficácia limitada**.

Para Canotilho, enquanto a inconstitucionalidade por **ação** pressupõe a existência de normas inconstitucionais, a inconstitucionalidade por **omissão** pressupõe a “violação da lei constitucional pelo *silêncio legislativo* (violação por omissão)”.⁴⁰

Particularizando, a inconstitucionalidade por **ação** pode-se dar: a) do ponto de vista **formal**; b) do ponto de vista **material**; c) e estamos pensando em uma terceira forma em razão dos escândalos dos denominados “mensalão” e “mensalinho” para votar em um sentido ou em outro, “batizada” de **“vício de decoro parlamentar”**.⁴¹



No tocante ao vício **formal** e **material**, a doutrina também tem distinguido as expressões **nomodinâmica** e **nomoestática**, respectivamente, para a inconstitucionalidade.⁴² Na medida em que o *vício formal* decorre de afronta ao *devido processo legislativo* de formação do ato normativo, isso nos dá a ideia de *dinamismo*, de movimento. Por sua vez, o *vício material*, por ser um vício de matéria, de conteúdo, a ideia que passa é de vício de substância, estático.



■ 6.3.2. Vício formal (inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade formal propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato)

Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como **nomodinâmica**, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.

Segundo Canotilho, os vícios formais “... incidem sobre o *ato normativo enquanto tal*, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese *inconstitucionalidade formal*, viciado é o *ato*, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”.⁴³

Podemos, então, falar em **inconstitucionalidade formal orgânica**, em **inconstitucionalidade formal propriamente dita** e em **inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato**.

■ 6.3.2.1. *Inconstitucionalidade formal orgânica*

A inconstitucionalidade formal **orgânica** decorre da inobservância da **competência legislativa** para a elaboração do ato.

Para se ter um exemplo, o STF entende inconstitucional lei municipal que discipline o uso do cinto de segurança, já que se trata de competência da União, nos termos do art. 22, XI, legislar sobre trânsito e transporte.

Outro exemplo, dentre tantos já apreciados pelo STF (cf. *item 7.10* desta obra), foi assim ementado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei n. 11.446/1997, do Estado de Pernambuco). *Vício formal*. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros (CF, art. 22, I e VII). Precedente: ADI n. 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, *DJ* 19/12/02, Pleno, maioria” (ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.08.2006, *DJ* de 07.12.2006). No mesmo sentido: ADI 1.595, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.03.2005, *DJ* de 07.12.2006.

■ 6.3.2.2. *Inconstitucionalidade formal propriamente dita*

Por sua vez, a inconstitucionalidade **formal propriamente dita** decorre da inobservância do **devido processo legislativo**. Podemos falar, então, além de vício de competência legislativa (inconstitucionalidade orgânica), em vício no procedimento de elaboração da norma, verificado em momentos distintos: na **fase de iniciativa** ou nas **fases posteriores**.⁴⁴

■ **Vício formal subjetivo:** o vício formal subjetivo verifica-se na fase **de iniciativa**. Tomemos um exemplo: algumas leis são de *iniciativa exclusiva (reservada)*⁴⁵ do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.º, I, CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, **exclusiva** ou **reservada**, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional.

■ **Vício formal objetivo:** por seu turno, o vício formal objetivo será verificado nas demais fases do processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa. Como exemplo citamos uma lei complementar sendo votada por um *quorum* de maioria relativa. Existe um vício formal objetivo, na medida em que a lei complementar, por força do art. 69, CF/88, deveria ter sido aprovada por maioria absoluta.

Outro exemplo seria uma PEC votada com *quorum* diferente do previsto no art. 60, § 2.º (3/5 em cada Casa e em 2 turnos de votação). Se isso ocorrer, a emenda promulgada padecerá de vício formal objetivo de inconstitucionalidade.

Outra hipótese seria a violação ao princípio do bicameralismo federativo. Como se sabe, os projetos de lei federal devem ser aprovados nas duas Casas do Congresso Nacional — Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Se, eventualmente, projeto de lei for modificado **em sua substância** pela Casa revisora, terá a emenda de voltar para a análise da Casa iniciadora, sob pena de configurar o vício formal objetivo.

Nesse ponto, a denominada “**emenda de redação**” pode existir na Casa revisora, mas desde que não signifique substancial modificação do texto aprovado na Casa iniciadora. Se isso ocorrer, terá de voltar para a análise da outra Casa (art. 65, parágrafo único), sob pena de se configurar o vício formal objetivo.

■ 6.3.2.3. *Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo*

Segundo Canotilho, “hoje, põe-se seriamente em dúvida se certos elementos tradicionalmente não reentrantes no processo legislativo não poderão ocasionar vícios de inconstitucionalidade. Estamos a referir-nos aos chamados pressupostos, constitucionalmente considerados como elementos determinantes de competência dos órgãos legislativos em relação a certas matérias (pressupostos objectivos)”.⁴⁶

Exemplificando, o autor lembra o art. 229, 2.º, da Constituição portuguesa, que determina a audiência obrigatória, pelos órgãos de soberania, dos órgãos do governo regional, quanto a questões relativas às regiões autónomas, sob pena de faltar um pressuposto para o exercício da competência e, assim, caracterizar-se irregularidade do ato.

Nesse caso, a audiência e participação obrigatórias “... são elementos externos ao procedimento de formação das leis...”, e a sua falta gera a **inconstitucionalidade formal**, já que os **pressupostos** do ato legislativo devem ser entendidos como “elementos vinculados do ato legislativo”.⁴⁷

Transportando a teoria de Canotilho para o direito brasileiro, valemo-nos de exemplos trazidos por Clèmerson Merlin Clève, quais sejam, a edição de medida provisória sem a observância dos requisitos da relevância e urgência (art. 62, *caput*) ou a criação de Municípios por lei estadual sem a observância dos requisitos do art. 18, § 4.º.

Neste último exemplo, o ilustre professor observa que a “... lei estadual dispondo sobre a criação de novo Município, ainda que regularmente votada e sancionada, mas sem observar o pressuposto referido, estará maculada por

inafastável vício de inconstitucionalidade formal. O mesmo se verifica no caso do art. 18, § 3.º, da Lei Fundamental da República”.⁴⁸

Também concordamos com esse pensamento. O tema foi apreciado no julgamento da **ADI 2.240**, na qual se discutia a constitucionalidade da lei baiana n. 7.619/2000, que criou o Município de *Luís Eduardo Magalhães*, sem a total observância dos pressupostos fixados no art. 18, § 4.º. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, mas não pronunciou a nulidade do ato, mantendo sua vigência por mais 24 meses (**efeito prospectivo** ou para o futuro), tema que será retomado no *item 6.7.1.9* deste trabalho. Cabe lembrar que a **EC n. 57/2008** convalidou a criação de vários Municípios, em nosso entender, de modo inconstitucional, ilegítimo e até imoral (cf. *item 6.7.4.9*).

■ 6.3.3. Vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário)

Por seu turno, o vício **material** (de conteúdo, substancial ou doutrinário) diz respeito à “matéria”, ao conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da Lei Maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material. Não nos interessa saber aqui o procedimento de elaboração da espécie normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. Por exemplo, uma lei discriminatória que afronta o princípio da igualdade.

Nas palavras de Barroso, “a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Pode traduzir-se no confronto com uma **regra constitucional** — *e.g.*, a fixação da remuneração de uma categoria de servidores públicos acima do limite constitucional (art. 37, XI) — ou com um **princípio constitucional**, como no caso de lei que restrinja ilegitimamente a participação de candidatos em concurso público, em razão do sexo ou idade (arts. 5.º, *caput*, e 3.º, IV), em desarmonia com o mandamento da isonomia. O controle material de constitucionalidade pode ter como parâmetro todas as

categorias de normas constitucionais: de organização, definidoras de direitos e programáticas”.⁴⁹

A inconstitucionalidade material é também conhecida como **nomoestática**.⁵⁰

Observamos que uma lei pode padecer somente de vício formal, somente de vício material, ou ser duplamente inconstitucional por apresentar tanto o vício formal como o material.

■ 6.3.4. Vício de decoro parlamentar (?)

Como se sabe e foi publicado em jornais, revistas etc., muito se falou em um esquema de compra de votos, denominado “mensalão”, para votar de acordo com o governo ou em certo sentido.

As CPIs vinham investigando e a Justiça apurando, e, uma vez provados os fatos, os culpados sofriam as sanções de ordem criminal, administrativa, civil etc.

O grande questionamento que se fazia, contudo, era se, uma vez comprovada a existência de compra de votos, haveria mácula no processo legislativo de formação das **emendas constitucionais** a ensejar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Entendemos que **sim**, e, no caso, trata-se de **vício de decoro parlamentar**, já que, nos termos do art. 55, § 1.º, “é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o **abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional** ou a **percepção de vantagens indevidas**”.

Dito isso, cabe lembrar que, no julgamento da **AP 470** (conhecida como “**mensalão**”), ficou demonstrado o **esquema de corrupção para compra de apoio político**.⁵¹

De acordo com a Min. Rosa Weber, “**‘houve, sem dúvida, um conluio’ para a compra de apoio de deputados federais** — não todos — para as votações a favor do governo na Câmara dos Deputados. O dinheiro, prossegue a ministra, veio de recursos, pelo menos em parte, públicos. Ela

ressaltou que os parlamentares receberam dinheiro ilicitamente, ‘caso contrário o pagamento não teria ocorrido pela forma como foi feito, sempre às escondidas, mediante a utilização de terceiros e o recebimento de vultosos valores em espécie, inclusive malas em quartos de hotel’” (*Notícias STF*, 04.10.2012).

E continua: “‘aos meus olhos, ficou evidente que o Partido dos Trabalhadores costumava alcançar dinheiro a outros partidos, entregando-o a parlamentares ou membros da organização partidária’, considerou a Ministra. Tal prática, conforme ela, ocorria para a **obtenção de apoio político no Parlamento**. ‘Disso, resulta a verossimilhança na descrição dos fatos pela denúncia. Foi criado um **esquema para pagar deputados federais em troca de seus votos na Câmara Federal e os valores eram expressivos**. Esses recursos tinham origem em peculato, em gestão fraudulenta do Banco Rural, em empréstimos simulados, foi o que se concluiu por este Plenário, ainda que por maioria’, completou a Min. Rosa Weber” (*Notícias STF*, 04.10.2012 — grifamos — cf. *Inf.* 682 e 683/STF).

Pois bem, diante do julgamento da citada AP 470, a *Associação dos Delegados de Polícia do Brasil — ADEPOL* (**ADI 4.887**), a *Confederação dos Servidores Públicos do Brasil — CSPB* (**ADI 4.888**) e o *Partido Socialismo e Liberdade — PSOL* (**ADI 4.889**) ajuizaram ADIs no STF objetivando a declaração de inconstitucionalidade da **Reforma da Previdência** (ECs ns. 41/2003 e 47/2005), alegando **aprovação mediante compra de votos de parlamentares**, liderados por réus condenados no “mensalão”, qual seja, o por nós denominado **vício de decoro parlamentar**. Nesse mesmo sentido, na semana anterior à propositura dessas ações, já havia sido ajuizada pela AMB a **ADI 4.885**.

A “tese” que lançamos no ano de **2005**, e já descrita neste nosso livro a partir de sua 9.^a edição, foi **admitida pela PGR** em seu parecer na ADI 4.887, tendo sido denominada “**vício na formação da vontade no procedimento legislativo**”, a ensejar a violação aos princípios democráticos e do devido processo legislativo, implicando, necessariamente, a

inconstitucionalidade do ato normativo (fls. 18 do parecer/PGR n. 10.323-RG, item 27).

O parecer do MPF, contudo, foi no sentido da improcedência da ADI. Vejamos: “na ação penal 470, foram condenados 7 parlamentares em razão da sua participação no esquema de compra e venda de votos e apoio político que ficou conhecido como ‘mensalão’. Não se pode presumir, sem que tenha havido a respectiva condenação judicial, que outros parlamentares foram beneficiados pelo esquema e, em troca, venderam seus votos para a aprovação das ECs 41/2003 e 47/2005. Assim, mesmo com a desconsideração dos votos dos 7 deputados condenados, os dois turnos de votação das emendas constitucionais na Câmara dos Deputados superaram o *quorum* qualificado exigido pela Constituição para a sua aprovação” (fls. 19 do parecer/MPF).

Diante das ações propostas, o STF teria de analisar se a tese do vício de decoro parlamentar era plausível e, neste caso, se deveriam ser considerados apenas e isoladamente os 7 votos dos parlamentares condenados (parecer do PGR) ou, por outro lado, se prevaleceria a premissa exposta pela Min. Rosa Weber no sentido de que o Partido dos Trabalhadores alimentava e incentivava o esquema a contaminar, como um todo, o procedimento ou, ao menos, a contaminar os votos dos parlamentares eleitos pela legenda e sua base aliada.

Em nosso entender, sem dúvida, o **comprovado** esquema de compra e venda de votos para conseguir apoio político **enseja** o por nós denominado **vício de decoro parlamentar** a caracterizar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, pois que **maculados a essência do voto** e o conceito de **representatividade popular**.

Ainda, vislumbramos o sentido de uma contaminação mais ampla do procedimento que parece poder ser extraído do julgamento da AP 470, que, ao identificar os focos do esquema, reconheceu a **capacidade de manipulação**, sugerindo-se uma **“contaminação” mais avassaladora**. Vejamos a ementa:

“(...) 5. Parlamentares beneficiários das transferências ilícitas de recursos **detinham poder de influenciar os votos de outros parlamentares de seus respectivos partidos, em especial por ocuparem as estratégicas funções de Presidentes de partidos políticos, de líderes parlamentares, líderes de bancadas e blocos partidários**. Comprovada a participação, no recebimento da propina, de intermediários da estrita confiança dos parlamentares, beneficiários finais do esquema. Depoimentos e recibos informais apreendidos no curso das investigações compõem as provas da prática criminosa” (AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, Plenário, DJE de 22.04.2013, fls. 51.626-51.629).

Em 27.06.2018, a Corte indeferiu o pedido de **medida cautelar** na **ADI 4.885** (mérito pendente). O Min. Marco Aurélio, Relator, mostrou-se reticente a esse controle de eventual vício na vontade do parlamentar, sustentando o papel da Corte como legislador negativo a atuar com “cerimoniosa parcimônia” (fls. 9).

Por outro lado, em referido julgamento, o Min. Edson Fachin, apesar de sinalizar a presunção de constitucionalidade da lei, reconheceu a possibilidade de, em tese, se aceitar “eventual **fraude no processo de votação**” (fls. 13), o que não se observou no caso concreto.

Nesse sentido, o Min. Barroso também admitiu a possibilidade de “**processo legislativo fraudulento**”, decorrente de fraude violadora do **princípio da moralidade**. Conforme explica, “a **inconstitucionalidade por violação ao devido processo legislativo** também pode decorrer da prática de atos ilícitos que ocasionem **vício na manifestação de vontade dos representantes do povo**. Naqueles casos em que houver **flagrante violação da moralidade legislativa** através de **evidências concretas da compra e venda de votos para a prevalência de interesses particulares**, o Judiciário possui o dever de intervir e invalidar a norma nascida sob tais circunstâncias. No caso dos autos, contudo, não houve plena demonstração pelas requerentes

de que o vício da vontade dos parlamentares fosse tamanho a ponto de alterar o quadro de aprovação da EC n. 41/2003”.

A Min. Rosa Weber, por sua vez, apesar de não ser a hipótese dos autos, pois **“ausentes provas cabais”**, admitiu a tese do vício de decoro. “A interferência espúria no sentido de cooptar a manifestação da vontade parlamentar — seja mediante violência, ameaça, suborno ou outras formas de corrupção — não denota, a meu juízo, mera inobservância de formalidade, e sim **procedimento marcadamente antidemocrático**, na medida em que subverte do ambiente deliberativo o livre convencimento da vontade, **traindo o debate público sobre as normas que irão regular a vida em sociedade e transformando, assim, o governo democrático em mero simulacro**” (fls. 44).

Em **11.11.2020**, o STF, por unanimidade, julgou **improcedentes** as ADIs 4.887, 4.888 e 4.889, eis que o número de 7 parlamentares condenados na AP 470 (“mensalão”) não seria suficiente para alterar o resultado da votação.

Em Plenário virtual, por 10 x 0, a Corte acompanhou o voto da Relatora, que entendeu **não** estar demonstrado e provado o alegado **“processo legislativo fraudulento”** a corromper **“a expressão da vontade popular”** e, portanto, demonstrado o **“vício de corrupção da vontade do parlamentar”**, caracterizar a inconstitucionalidade da lei.

Em seu voto (ADI 4.887), a Min. Cármen Lúcia, apesar de reconhecer a tese do vício de decoro, citando, inclusive, este nosso trabalho (fls. 9), não conseguiu encontrar a fraude a macular o processo legislativo específico.

Conforme destacou, “admite-se o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador quando eivada de **vício na manifestação de vontade do parlamentar** no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a **moralidade**, a **proibidade administrativa** e **fragilizam a democracia representativa**”. Contudo, diante do “princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos legislativos”, deve haver demonstração inequívoca de votos viciados a contaminar o processo legislativo, o que não se verificou

no caso concreto, já que a condenação se deu apenas em relação a 7 parlamentares, a não alterar o resultado da votação (ADI 4.887, fls. 11).

■ 6.3.5. “Estado de coisas inconstitucional” (ECI)

A terminologia “**estado de coisas inconstitucional**” (ECI) foi utilizada pelo Min. Marco Aurélio, no julgamento da cautelar na **ADPF 347** (j. 09.09.2015), a partir de decisão proferida pela **Corte Constitucional da Colômbia** (mérito pendente).

Segundo esclareceu, “presente quadro de **violação massiva e persistente de direitos fundamentais**, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como ‘**estado de coisas inconstitucional**’”.

Em **04.10.2023**, o Pleno do STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na referida arguição de descumprimento de preceito fundamental para:

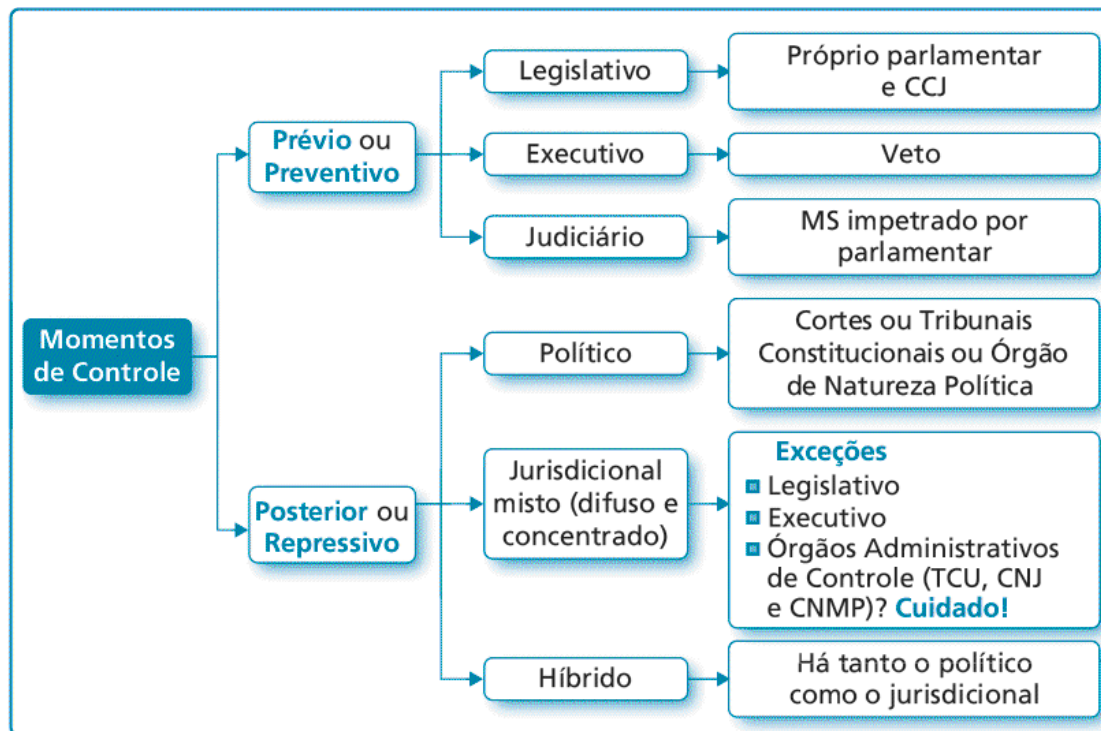
- “1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro;
- 2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário;
- 3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN;
- 4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação;

5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de ■ até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano;
- 6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local;
- 7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito;
- 8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional;
- 9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar;
- 10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito;
- 11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte;
- 12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final

pelo STF em segunda etapa”.

A Corte estabeleceu a seguinte tese de julgamento: “1. **Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos.** Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, **União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ),** deverão elaborar **planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal,** nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente **voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.** 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Redator para o acórdão, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio (Relator). Não votou o Min. André Mendonça, sucessor do Relator. Plenário, 04.10.2023.

■ 6.4. MOMENTOS DE CONTROLE



A classificação que passamos a analisar diz respeito ao momento em que será realizado o controle, qual seja, antes de o projeto de lei virar lei (**controle prévio** ou **preventivo**), impedindo a inserção no sistema normativo de normas que padeçam de vícios, ou já sobre a lei, geradora de efeitos potenciais ou efetivos (**controle posterior** ou **repressivo**).

■ 6.4.1. Controle prévio ou preventivo

Como vimos acima, o controle prévio é o realizado durante o **processo legislativo de formação do ato normativo**. Logo no momento da apresentação de um projeto de lei, o iniciador, a “pessoa”, o órgão que

deflagrar o processo legislativo, em tese, já deve verificar a regularidade material do aludido projeto de lei.

O controle prévio também é realizado pelo **Legislativo**, pelo **Executivo** e pelo **Judiciário**.

■ 6.4.1.1. *Controle prévio ou preventivo realizado pelo Legislativo*

O Legislativo verificará, através de suas **comissões de constituição e justiça**, se o projeto de lei, que poderá virar lei, contém algum vício a ensejar a inconstitucionalidade.

De acordo com o art. 32, IV, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o controle será realizado pela *Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania* (vide Res. da CD n. 20, de 2004 — DCD, de 18.03.2004, Suplemento, p. 3), enquanto no Senado Federal o controle será exercido pela *Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania — CCJ*, de acordo com o art. 101 de seu Regimento Interno. O plenário das referidas Casas também poderá verificar a inconstitucionalidade do projeto de lei, o mesmo podendo ser feito durante as votações.

Michel Temer observa que tal controle nem sempre se verifica em relação a todos os projetos de atos normativos, citando a sua inocorrência, por exemplo, sobre projetos de **medidas provisórias, resoluções dos Tribunais e decretos**.⁵²

Questão interessante pode surgir indagando se o parecer negativo das Comissões de Constituição e Justiça, declarando a inconstitucionalidade do projeto de lei, inviabilizaria o seu prosseguimento.

O § 2.º do art. 101, Regimento Interno do Senado Federal,⁵³ dispõe que, em se tratando de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. No entanto, a regra geral é a do seu § 1.º, ao estabelecer que, quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada **rejeitada e arquivada definitivamente**, por despacho do Presidente do Senado, salvo, desde que não seja unânime o parecer, se houver recurso interposto nos

termos do art. 254 do RI, ou seja, interposto por no mínimo **1/10** dos membros do Senado, manifestando opinião favorável ao seu processamento.

Da mesma forma, o art. 54, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados⁵⁴ estabelece que será “terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria” (inciso com redação adaptada à Resolução n. 20/2004). No entanto, há a previsibilidade de recurso para o plenário da Casa contra referida deliberação, nos termos dos arts. 132, § 2.º; 137, § 2.º; e 164, § 2.º, do referido Regimento Interno.

■ 6.4.1.2. *Controle prévio ou preventivo realizado pelo Executivo*

Como veremos melhor ao estudar o processo legislativo, o Chefe do Executivo, aprovado o projeto de lei, poderá sancioná-lo (caso concorde) ou vetá-lo.

O veto dar-se-á quando o Chefe do Executivo considerar o projeto de lei **inconstitucional** ou **contrário ao interesse público**. O primeiro é o **veto jurídico**, sendo o segundo conhecido como **veto político**.

Assim, caso o Chefe do Executivo entenda ser inconstitucional o projeto de lei poderá vetá-lo, exercendo, desta feita, o controle de constitucionalidade **prévio ou preventivo**, antes de o projeto de lei transformar-se em lei.

Referido **veto**, necessariamente, nos termos do art. 66, § 4.º, CF/88, será apreciado em **sessão conjunta** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dentro de **30 dias** a contar de seu recebimento, podendo, pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores, em **votação ostensiva**, ou seja, por voto “aberto” (lembramos que a **EC n. 76/2013** aboliu a votação secreta nessa hipótese), ser rejeitado (afastado), produzindo, nesse caso, os mesmos efeitos que a sanção.

Derrubado o veto, o projeto deverá ser enviado ao Presidente da República para **promulgação da lei** no prazo de 48 horas e, se este não o fizer, caberá ao Presidente do Senado Federal a promulgação, em igual prazo,

e, caso este não a promulgue, caberá ao Vice-Presidente do Senado Federal fazê-lo (art. 66, § 7.º, CF/88).

Na hipótese de o veto ser mantido, o projeto será arquivado, aplicando-se a regra contida no art. 67, que consagra a regra da irrepetibilidade.

Imaginando a hipótese de **derrubada do veto** e a consequente **promulgação da lei**, naturalmente, a correspondente lei, ato normativo, poderá ser objeto de controle de constitucionalidade, agora, porém, o chamado *controle posterior* ou *repressivo*.

■ 6.4.1.3. ***Controle prévio ou preventivo realizado pelo Judiciário***

O controle prévio ou preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário sobre PEC ou projeto de lei em trâmite na Casa Legislativa busca garantir ao **parlamentar** o respeito ao **devido processo legislativo**, vedando a sua participação em procedimento **desconforme com as regras da Constituição**. Trata-se, como visto, de controle exercido, no caso **concreto**, pela **via de exceção ou defesa**, ou seja, de modo incidental.

Assim, deve-se deixar claro que a legitimação para a impetração do MS é **exclusiva** do **parlamentar**, na medida em que o **direito público subjetivo** de participar de um *processo legislativo hígido* (**devido processo legislativo**) pertence somente aos **membros do Poder Legislativo**. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de **negar a legitimidade ativa *ad causam* a terceiros, que não ostentem a condição de parlamentar**, ainda que invocando a sua potencial condição de destinatários da futura lei ou emenda à Constituição, sob pena de indevida transformação em controle preventivo de constitucionalidade em abstrato, inexistente em nosso sistema constitucional (*vide* RTJ 136/25-26, Rel. Min. Celso de Mello; RTJ 139/783, Rel. Min. Octavio Gallotti, e, ainda, MS 21.642-DF, MS 21.747-DF, MS 23.087-SP, MS 23.328-DF).

E a perda superveniente do mandato parlamentar?

Parece ter razão o Min. Celso de Mello ao afirmar que a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo **desqualifica a legitimação ativa do congressista**. Isso porque “... a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação **legitimante e necessária**, tanto para a **instauração** quanto para o **prosseguimento da causa** perante o STF. Inexistente, originariamente, essa situação, ou, como se registra no caso, configurada a ausência de tal condição, em virtude da **perda superveniente do mandato parlamentar** no Congresso Nacional, **impõe-se a declaração de extinção do processo de mandado de segurança**, porque ausente a legitimidade ativa *ad causam* do ora impetrante, que não mais ostenta a condição de membro de qualquer das Casas do Congresso Nacional” (**MS 27.971**, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 1.º.07.2011, *DJE* de 1.º.08.2011).

Outro entendimento acarretaria a conversão do mandado de segurança, que não pode ser utilizado para a impugnação de normas em tese, em ADI, situação essa não admitida em nosso ordenamento jurídico.

E quais os limites do controle judicial?

Nos termos da jurisprudência do STF, o controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Judiciário durante o processo legislativo abrange somente a garantia de um procedimento em total conformidade com a **Constituição, não lhe cabendo**, contudo, a extensão do controle sobre **aspectos discricionários concernentes às questões políticas e aos atos interna corporis**, vedando-se, desta feita, interpretações das normas regimentais (cf.: MS 22.503-3/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 06.06.1997, p. 24872, *Ement.* v. 01872-03, p. 385; j. 08.05.1996 — Tribunal Pleno,⁵⁵ descrevendo o posicionamento da Suprema Corte).

Nesse sentido, há tese fixada pelo STF: “em respeito ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2.º da Constituição Federal, **quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo**, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas

meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria *interna corporis*” (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 11.06.2021, DJE de 04.08.2021).

Admitindo o controle jurisdicional, os seus **limites** foram bem delimitados pela Corte no julgamento do MS 32.033 (Rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, j. 20.06.2013, Plenário, DJE de 18.02.2014), impetrado, preventivamente, por parlamentar, questionando projeto de lei que criava novas regras em relação à *transferência dos recursos do fundo partidário e ao horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão* nas hipóteses de migração partidária (PL n. 4.470/2012 — aprovado pela Câmara e recebido no Senado Federal como PLC n. 14/2013, tendo sido transformado na Lei n. 12.875/2013).

De acordo com o voto do Min. Teori Zavascki, que abriu a divergência, contrário a uma posição mais elástica sustentada pelo Min. Gilmar Mendes (vencido), a Constituição admite o controle judicial preventivo, por meio de mandado de segurança a ser impetrado exclusivamente por parlamentar, em duas únicas hipóteses:

■ **PEC** manifestamente ofensiva a **cláusula pétrea** (MS 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves — *leading case* — j. 08.10.1980);

■ **projeto de lei** ou **PEC** em cuja tramitação se verifique **manifesta ofensa** a cláusula constitucional que disciplina o correspondente **processo legislativo**.

Ou seja, em relação a **projeto de lei**, o STF restringiu o controle preventivo apenas para a hipótese de violação ao **devido processo legislativo**, não se admitindo a discussão sobre a matéria, buscando, assim, resguardar a **regularidade jurídico-constitucional do procedimento**, sob pena de se violar a **separação de poderes**.

Observem que essa delimitação de atuação do controle judicial se deu em relação ao **projeto de lei**, e não à **PEC** (proposta de emenda à Constituição). Isso porque o art. 60, § 4.º, veda a **proposta de emenda** tendente a abolir cláusula pétrea. Em nenhum momento a Constituição vedou

a tramitação de *projeto de lei* que tenda a abolir cláusula pétrea. Ou seja, procurando ser mais claro: **a)** em relação a projeto de lei, o controle judicial não analisará a matéria, mas apenas o processo legislativo; **b)** em relação à PEC, o controle será mais amplo, abrangendo não apenas a regularidade de procedimento, mas, também, a matéria, permitindo o trancamento da tramitação de PEC que tenda a abolir cláusula pétrea.

Com esse entendimento, a Corte **evitou** a **universalização** do controle preventivo e a necessidade de enfrentamento judicial **precoce** de questões políticas, que encontram um ambiente muito mais adequado de discussão, que é a Casa Legislativa.⁵⁶ Vejam que o questionamento sobre a matéria da lei (se o projeto de lei for transformado) poderá ser realizado em momento oportuno no controle concentrado a ser provocado pelos legitimados do art. 103.

Conforme estabeleceu o Min. Fux em seu voto, “essa aparente contradição entre os valores albergados pelo Estado Democrático de Direito impõe um dever de **cautela** redobrado no exercício da jurisdição constitucional. Com efeito, certo é que **os tribunais não podem asfixiar a autonomia pública dos cidadãos**, substituindo as escolhas políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como, aliás, testemunhado pela história constitucional norte-americana durante a cognominada *Era da Lochner* (1905-1937), período em que a Suprema Corte daquele país freou a implantação do Estado social a partir de uma exegese inflacionada da cláusula aberta do devido processo legal (CHEMERINSKY, Erwin. *Constitutional law: principles and policies*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2011, p. 630-645)”.

E delimitou com precisão: “no caso vertente, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. A questão deve permanecer em discussão, sob pena de um paternalismo judicial ou, para utilizar uma expressão bastante em voga, uma **supremocracia**. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição, diversamente do que abreviar a discussão, como pretende o Impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicana, transparentes e com os canais de

participação abertos a todos os que queiram deles participar. Esse sim é o modelo de atuação legislativa legítima, tal qual concebido por John Hart Ely” (fls. 19 de seu voto).

■ **6.4.1.4. *Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Judiciário e a perspectiva das “normas constitucionais interpostas” (Zagrebelsky)***

O posicionamento acima exposto (**MS 22.503**), pela total não apreciação e interpretação de normas do Regimento Interno do Parlamento e que é a **regra (INCLUSIVE PARA SER ADOTADA NOS CONCURSOS PÚBLICOS)**, poderia ser visto com temperamentos quando se tratar de **normas constitucionais interpostas**.

A tese foi discutida pelo Min. Gilmar Mendes no **MS 26.915**,⁵⁷ no qual se questionava a amplitude do art. 43 do RI da CD, que veda Deputado Federal relator de certa proposta de presidir a Comissão na qual será apreciada a matéria (“Art. 43. *Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator. Parágrafo único. Não poderá o Autor de proposição ser dela Relator, ainda que substituto ou parcial*”).

Referido mandado de segurança impugnava a nomeação do Deputado Pedro Novais (PMDB/MA) para a presidência da Comissão especial que analisou a PEC n. 558/2006, a qual trata da prorrogação da CPMF, tendo em vista que ele seria um dos autores da proposição.

Em um primeiro momento (voto monocrático e em sede de medida cautelar), o Rel. Min. Gilmar Mendes analisou o Regimento Interno à luz do devido processo legislativo e, assim, entendeu que a regra fixada no art. 43 do RI da CD não se aplica aos projetos de Emenda Constitucional (PEC), indeferindo, portanto, o pedido de medida liminar, por estarem ausentes a *fumaça do bom direito* (plausibilidade jurídica) e o *perigo na demora da decisão*.

Mendes, trazendo em pauta o estudo de **Gustavo Zagrebelsky**, asseverou que “... se as normas constitucionais fizerem referência expressa a outras disposições normativas, a violação constitucional pode advir da violação dessas outras normas, que, muito embora não sejam formalmente constitucionais, vinculam os atos e procedimentos legislativos, constituindo-se **normas constitucionais interpostas** (ZAGREBELSKY, Gustavo. *La giustizia costituzionale*. Bologna, Mulino, 1979, p. 40-41). Na verdade, o órgão jurisdicional competente deve examinar a regularidade do processo legislativo, sempre tendo em vista a constatação de eventual afronta à Constituição (CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional*, apud MENDES, Gilmar. *Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos*. Saraiva, 1990, p. 35-36), mormente, aos direitos fundamentais” (MS 26.915-MC/DF, 08.10.2007).

Assim, o tema ganha outro “colorido” à luz dessa nova perspectiva, devendo o conceito de matéria *interna corporis* ser temperado à luz da ideia das *normas constitucionais interpostas*, que, segundo o Min. Gilmar Mendes, apresentariam uma força normativa diferenciada por derivar diretamente da Constituição (**tema pendente de julgamento e aprofundamento pelo STF, já que o referido MS foi extinto sem a apreciação da matéria**).⁵⁸

■ 6.4.2. Controle posterior ou repressivo

O controle posterior ou repressivo será realizado sobre a lei, e não mais sobre o projeto de lei, como ocorre no controle preventivo.

Vale dizer, os **órgãos de controle** verificarão se a lei, ou ato normativo, ou qualquer ato com indiscutível caráter normativo, possuem um **vício formal** (produzido durante o processo de sua formação), ou se possuem um vício em seu conteúdo, qual seja, um **vício material**. Mencionados órgãos variam de acordo com o sistema de controle adotado pelo Estado, podendo ser **político, jurisdicional** ou **híbrido**.

■ 6.4.2.1. Controle político

Verifica-se em Estados onde o controle é exercido por um órgão distinto dos três Poderes, órgão esse garantidor da supremacia da Constituição. Tal sistema é comum em países da Europa, como Portugal e Espanha, sendo o controle normalmente realizado pelas **Cortes** ou **Tribunais Constitucionais**.⁵⁹

Luís Roberto Barroso, como José Afonso da Silva, destaca o **modelo francês** estabelecido na Constituição de 1958 e que fixou um *Conselho Constitucional*, composto de 9 Conselheiros escolhidos pelo Presidente da República e pelo Parlamento, tendo como membros natos os ex-Presidentes da República, como exemplo de **controle político**.

No Brasil, Barroso sustenta que o veto do Executivo a projeto de lei, por entendê-lo inconstitucional (veto jurídico), bem como a rejeição de projeto de lei na CCJ seriam exemplos de controle político.⁶⁰

■ 6.4.2.2. *Controle jurisdicional*

O sistema de controle jurisdicional dos atos normativos é realizado pelo Poder Judiciário, tanto por um único órgão (**controle concentrado**) — no caso do direito brasileiro, pelo STF e pelo TJ — como por qualquer juiz ou tribunal (**controle difuso**), admitindo, naturalmente, o seu exercício por juízes em estágio probatório, ou seja, sem terem sido vitaliciados, bem como por juízes dos juizados especiais.

O Brasil adotou o sistema jurisdicional **misto**, porque realizado pelo Poder Judiciário — daí ser *jurisdicional* —, tanto de forma concentrada (controle concentrado) como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso).⁶¹

Importante anotar que os controles difuso e concentrado são realizados com autonomia, não podendo um condicionar a sua admissibilidade à inviolabilidade do outro. Claro que se já houver decisão no controle concentrado, mesmo em sede de medida cautelar, poderá haver repercussão sobre o controle difuso.

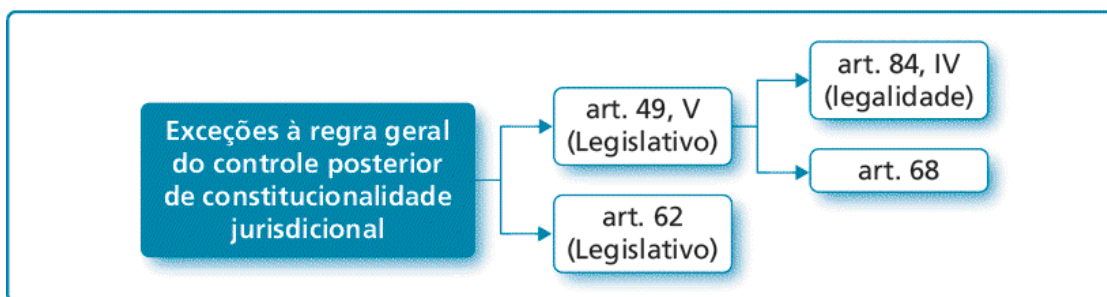
■ 6.4.2.3. *Controle híbrido*

No controle que chamamos de **híbrido**, temos uma *mistura* dos outros dois sistemas acima noticiados. Assim, algumas normas são levadas a controle perante um órgão distinto dos três Poderes (controle político), enquanto outras são apreciadas pelo Poder Judiciário (controle jurisdicional).

■ 6.4.2.4. *Exceções à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo*

Vimos que o controle posterior ou repressivo (sucessivo) no Brasil, por regra, é exercido pelo Poder Judiciário, de forma concentrada ou difusamente. A essa regra, no entanto, surgem exceções, destacando-se a atuação do **Poder Legislativo** e do **Poder Executivo**, assim como a particular atribuição dos ditos **órgãos administrativos autônomos de controle** (TCU, CNJ, CNMP), que, conforme veremos, não exercem o controle de constitucionalidade propriamente dito.

■ 6.4.2.4.1. *Controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo*



A **primeira exceção** à regra geral do controle posterior jurisdicional misto (difuso e concentrado) vem prevista no **art. 49, V**, CF/88, que estabelece ser competência exclusiva do Congresso Nacional *sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa*. Mencionado controle será realizado através

de **decreto legislativo** a ser expedido pelo Congresso Nacional. Vamos às hipóteses:

a) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar: como veremos melhor ao tratar do Poder Executivo, é de competência exclusiva do Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 84, IV). Portanto, ao Chefe do Executivo compete regulamentar uma lei expedida pelo Legislativo, e tal procedimento será feito por decreto presidencial. Pois bem, se no momento de regulamentar a lei o Chefe do Executivo extrapolá-la, disciplinando além do limite nela definido, este “a mais” poderá ser afastado pelo Legislativo por meio de decreto legislativo. Cabe alertar que, no fundo, esse controle é de **legalidade** e não de inconstitucionalidade, como apontado por parte da doutrina, pois o que se verifica é em que medida o decreto regulamentar extrapolou os limites da **lei**;

b) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites de delegação legislativa: como veremos ao estudar as espécies normativas, a Constituição atribuiu competência ao Presidente da República para elaborar a **lei delegada**, mediante delegação do Congresso Nacional, através de **resolução**, especificando o conteúdo e os termos de seu exercício (art. 68). Pois bem, no caso de elaboração de lei delegada pelo Presidente da República, extrapolando os limites da aludida resolução, poderá o Congresso Nacional, utilizando-se de **decreto legislativo**, sustar o referido ato que exorbitou dos limites da delegação legislativa.

A **segunda exceção** à regra geral está prevista no **art. 62**, CF/88. Conforme estudaremos adiante, em caso de **relevância** e **urgência**, o Presidente da República poderá adotar **medidas provisórias**, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao **Congresso Nacional** (Poder Legislativo). Entendendo-a **inconstitucional** (vejam: as medidas provisórias têm força de lei), o Congresso Nacional estará realizando controle de

constitucionalidade. Trata-se de exceção à regra geral, haja vista que, nessa hipótese, o controle não é exercido pelo Judiciário (lembrem: o Brasil adotou o **sistema de controle jurisdicional misto**), mas sim pelo Legislativo.

■ 6.4.2.4.2. *Controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo*

Como se sabe, o **princípio da supremacia da Constituição** produz **efeitos irradiantes** em todos os Poderes da República, os quais, por sua vez, devem cumprir as leis que se coadunem com a Constituição.

O grande problema surge quando a lei é inconstitucional. Devem os Poderes necessariamente aplicá-la, ou podem, sem qualquer formalidade, deixar de cumpri-la sob o fundamento de violação da Constituição?

■ **Entendimento antes do advento da CF/88:** como vimos, o controle concentrado surge somente com a EC n. 16/65, que estabelece, como exclusivo legitimado, o PGR. Assim, antes do texto de 1988, que ampliou a legitimação ativa para o ajuizamento da ADI, os Chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores dos Estados e do DF e Prefeitos) não tinham competência para ajuizar ação buscando, em controle concentrado, discutir a constitucionalidade da lei.

Nesse primeiro momento, portanto, doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que o Chefe do Executivo poderia deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional, cabendo-lhe, ainda, baixar determinação, na condição de **superior hierárquico**, para que os seus subordinados também não cumprissem a lei.

Isso porque a análise da constitucionalidade da lei não era tida como monopólio do Judiciário, embora tivesse o seu controle final (Caio Tácito, *RDA* 59/339 e s.).

Naturalmente a ação ou omissão do Poder Executivo poderia ser discutida no Judiciário, que daria a “palavra final” sobre a aplicação ou não da lei (como se sabe, o Judiciário é o intérprete final da lei), obrigando, após a decisão, à necessária observância do dispositivo legal.⁶²

■ **Entendimento a partir do advento da CF/88:** já vimos que o argumento para justificar a possibilidade de descumprimento da lei pelo Executivo fundava-se no fato de a legitimação para o controle concentrado de constitucionalidade das leis ser **exclusiva** do PGR.

Assim, aparentemente, com o advento da CF/88, que ampliou a legitimação para o ajuizamento da ADI (art. 103, expandida para a ADC pela EC n. 45/2004), não mais se admitiria o descumprimento de lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo.

A tese ganhou alguns adeptos na doutrina.⁶³ Outros, porém, alertaram para uma realidade: de fato, pela nova regra, são legitimados o **Presidente da República** (art. 103, I) e os **Governadores dos Estados e do DF** (art. 103, V). E quanto aos **Prefeitos**?

Estes não estão previstos no rol de legitimados do art. 103. Então alguns sustentavam que poderiam os Prefeitos, e somente eles, descumprir a lei flagrantemente inconstitucional, determinando a sua não aplicação para os subordinados hierárquicos.

Essa tese, contudo, mostrou-se bastante complicada, pois, em certa medida, acarretava maior atribuição de poderes aos Chefes dos Executivos municipais em detrimento dos estaduais e em relação ao Presidente da República.

Em virtude dessa situação, buscou a doutrina outra justificativa, que não a meramente formal, para a configuração da tese do descumprimento da lei e, assim, manter a regra que prevalecia antes do texto de 1988: princípio da **supremacia da Constituição** e da regra de que a aplicação de lei inconstitucional é o mesmo que a negativa de aplicação da própria Constituição.⁶⁴

Entendemos que a **tese** a ser adotada é a da **possibilidade de descumprimento da lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo**.

Isso porque entre os efeitos do controle concentrado está a **vinculação** dos demais órgãos do Poder Judiciário e do **Executivo** (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 e art. 102, § 2.º, CF/88 — EC n. 45/2004).

Outro argumento a fortalecer a ideia da possibilidade de descumprimento da lei flagrantemente inconstitucional pelo Executivo decorre dos efeitos da **súmula vinculante** (*Reforma do Judiciário*), que, uma vez editada, vinculará a Administração Pública, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal (art. 64-B da Lei n. 9.784/99, introduzido pela Lei n. 11.417/2006).

Antes, porém, *a contrario sensu* e desde que não exista qualquer medida judicial em sentido contrário, tecnicamente, poderá o Chefe do Executivo determinar a não aplicação de lei flagrantemente inconstitucional.

■ E qual a posição do STF e do STJ sobre o tema?

Encontramos apenas um precedente no **STF**, que não aprofunda muito o assunto: “... O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia — e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade —, **podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais**” (ADI 221-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves; DJ de 22.10.1993, p. 22251, *Ement.* v. 01722-01, p. 28 — grifamos).

A 1.^a Turma do **STJ**, por sua vez, já enfrentou o tema com maior veemência, **consagrando a tese do controle posterior ou repressivo pelo Executivo**: “Lei inconstitucional — Poder Executivo — Negativa de eficácia. O poder executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional” (**REsp 23121/GO**, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; 1.^a T., j. 06.10.1993, DJ de 08.11.1993, p. 23521, *LEXSTJ* 55/152).

■ 6.4.2.4.3. “Órgãos administrativos autônomos de controle” (TCU, CNJ e CNMP) exercem controle de constitucionalidade?

Não!

Referidos órgãos **não** exercem nem o controle concentrado, nem mesmo o controle difuso de constitucionalidade.

A atuação dos ditos “órgãos administrativos autônomos de controle” vem sendo discutida tanto pela doutrina como pela jurisprudência, especialmente em razão da **S. 347/STF**, editada em 13.12.1963, que tem a seguinte orientação, causando muita divergência: “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”.

A **subsistência da S. 347** em seu sentido original vem sendo discutida no **STF**, destacando-se importantes precedentes, conforme se observa a seguir.

Segundo fundamentou o Min. Gilmar Mendes no julgamento da liminar proferido em 22.03.2006 (**MS 25.888-MC**), inclusive em sede doutrinária, a S. 347 foi editada no ano de **1963**, na vigência da Constituição de 1946 e **quando ainda não existia qualquer forma de controle concentrado no Brasil**. Lembre-se de que, naquele momento, vigorava apenas o controle difuso, já que a introdução do controle concentrado se deu pela EC n. 16/65, que estabeleceu um exclusivo legitimado, qual seja, o PGR.

Naquele contexto, argumenta, admitia-se a não aplicação da lei considerada inconstitucional. Contudo, com o advento da CF/88 e a alteração radical na legitimação ativa para a propositura da ADI genérica (art. 103), não mais se justificaria o entendimento firmado na S. 347.

Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, “a própria **evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil**, verificada desde então, **está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 347** em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988” (em sentido contrário, aplicando a S. 347 sob o argumento de que ainda não revogada expressamente, cf. voto do Min. Marco Aurélio: **MS 31.439-MC**, decisão monocrática, j. 19.07.2012, *DJE* de 07.08.2012. Em 05.03.2021, o processo foi extinto sem o exame de mérito em razão do silêncio do impetrante, a demonstrar a sua falta de interesse na continuidade do processo — art. 485, VI, CPC).

CUIDADO: essa perspectiva extrema lançada por Gilmar Mendes em sua decisão proferida em 22.03.2006 — e que foi por ele reavaliada no julgamento do agravo regimental em **22.08.2023** (MS 25.888 AgR) — parece ter se enfraquecido em apreciação pelo STF de decisão do **CNJ** que considerou irregular a contratação, pelo TJ da Paraíba, de 100 assistentes de administração **nomeados sem concurso público** (sendo observado, ainda, que, no julgamento proferido em 14.09.2020 — que julgou prejudicado o MS —, parece ter o Min. Gilmar esclarecido melhor o seu posicionamento).

Ao que tudo indica — e explicaremos melhor a seguir —, o STF vem fazendo uma **releitura** da referida súmula, tendo chegado, o próprio Min. Gilmar, em um primeiro momento, a admitir a possibilidade de os órgãos da administração deixarem de aplicar normas vigentes **quando essa determinação decorrer de interpretação já estabelecida na Corte** (cf. MS 26.739, 2.^a T., j. 1.^o.03.2016).

O atual posicionamento da Corte no sentido de que os referidos órgãos administrativos de controle **não exercem controle de constitucionalidade** está consagrado no julgamento da **Pet 4.656** (Pleno, j. 19.12.2016, *DJE* de 04.12.2017).

Conforme sustentou a Min. Cármen Lúcia ao analisar o caso concreto da Paraíba, o órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura (CNJ) atuou “nos limites de sua competência, afastando a validade de atos administrativos e, para tanto, **adotando como fundamento a invalidade da lei estadual**, que ele reputou contrária ao princípio constitucional de ingresso no serviço público, por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizados para a criação de cargos comissionados”.

Em seu voto, a Ministra Relatora distinguiu o **afastamento da lei pelo CNJ** do ato de **declaração de inconstitucionalidade**, que seria, este último, atribuição exclusiva do **Poder Judiciário**. Isso porque o CNJ atuou nos limites de sua competência constitucional (art. 103-B, § 4.^o, II), “**afastando a validade dos atos administrativos** e, para tanto, a aplicação de lei estadual como seu fundamento e que ele reputou contrária ao princípio constitucional

de ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizadores do cargo comissionado. **Não há declaração de inconstitucionalidade** da qual resulte a anulação ou revogação da lei discutida, com exclusão de sua eficácia. Teve-se na espécie a **nulidade dos atos** questionados para o que se afirmou **inaplicável, administrativamente, lei estadual com vício de inconstitucionalidade**, vinculando-se apenas a atuação de órgão judicial cujos atos administrativos foram submetidos ao controle do Conselho Nacional de Justiça. Não se há cogitar, portanto, de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a qual seria passível de impugnação por meio constitucional próprio, como efetivamente se deu” (fls. 27 do acórdão).

Concordamos com o STF — e assim já havíamos nos manifestado em edições anteriores — que “a possibilidade de afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento”, deve se dar por ato expresso e formal tomado pela **maioria absoluta** dos membros do Conselho (aplicação analógica do art. 97, CF/88).

Dessa forma, os ditos “órgãos administrativos autônomos” (CNJ, CNMP e TCU), com a função constitucional de controlar a **validade de atos administrativos**, poderão afastar a aplicação de lei ou ato normativo violador da Constituição. **Mas que fique claro: isso não é controle de constitucionalidade** (nesse sentido, fazendo distinção entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação da lei, por ser esta a obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado (RMS 8.372/CE, Rel. Min. Pedro Chaves, Pleno, j. 11.12.1961) (cf. medida cautelar no **MS 31.923**, decisão monocrática, Min. Celso de Mello, j. 14.04.2013, fls. 9).

Conforme observou o Min. Barroso, “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição” (Pet 4.656, fls. 46).

De acordo com a proposta estabelecida pelo Min. Gilmar Mendes em *obiter dictum* no julgamento que reconheceu a prejudicialidade do **MS 25.888** em razão da superveniência da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais), que revogou o ato normativo que teria sido declarado inconstitucional pelo TCU e que, então, ensejou a discussão sobre essa efetiva atribuição da Corte de Contas, teríamos uma **aplicação renovada da S. 347**, nos seguintes termos: “confere aos Tribunais de Contas a possibilidade de **afastar a aplicação** de normas **manifestamente inconstitucionais** quando **já houver entendimento pacificado do STF acerca da inconstitucionalidade chapada, notória** ou **evidente**, da solução normativa eventualmente em exame” (fls. 27 da decisão), deixando claro que as decisões do Supremo, ainda que proferidas na **via incidental**, ostentam **força cogente**, tendo em vista o reconhecimento da mutação constitucional do art. 52, X, adotada no julgamento das **ADIs 3.406 e 3.470** (fls. 26 da decisão — cf. a ampla discussão da matéria no *item* 6.6.5.5 e o nosso posicionamento sobre a necessidade de cumprimento de algumas formalidades).

O tema voltou a ser enfrentado pela Corte no julgamento do **MS 35.410** (j. 13.04.2021), que, para alguns, teria o STF inovado o seu entendimento no sentido de não se permitir nem mesmo o afastamento da lei.

Pensamos, contudo, que, no fundo, apesar de não estar o acórdão muito claro (o julgamento foi em Plenário virtual, pelo qual, como se sabe, não existe debate entre os Ministros), o entendimento firmado na Pet 4.656 continuou válido.

Conforme estabelecido na ementa do acórdão de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, “o Tribunal de Contas da União, **órgão sem função jurisdicional**, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos *erga omnes* e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal. (...). Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública

Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os *erga omnes* e vinculantes”.

Muito embora o Min. Alexandre tenha sugerido uma reavaliação ou reconhecimento de superação da S. 347, ou, ainda, que **a subsistência do verbete estaria comprometida desde a promulgação da Constituição de 1988** (fls. 17), ao que parece, o ponto crucial em seu voto, na linha da própria ementa, seria a transcendência dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade de determinados atos normativos, chegando a afirmar que o seu afastamento com efeito *erga omnes* incorreria no mesmo vício.

Conforme argumenta, a declaração de inconstitucionalidade pelo TCU ensejaria triplo desrespeito à Constituição, seja por atentar contra o Legislativo, seja por afrontar as competências jurisdicionais do Judiciário e as privativas do STF.

A leitura do acórdão em análise (MS 35.410), contudo, muito embora tenha sido sustentado um novo entendimento, em nosso entender, sinaliza a manutenção do decidido na **Pet 4.656**, qual seja, a possibilidade de afastamento da aplicação de lei desde que em um caso concreto e sem o efeito *erga omnes*. Isso, como se disse, não seria controle de constitucionalidade, vetado ao TCU e aos demais órgãos administrativos autônomos de controle.

Nesse sentido, o Min. Gilmar Mendes, depois de não admitir a declaração de inconstitucionalidade pelo TCU, bem como por qualquer órgão pertencente a outro Poder que não o Judiciário, como Banco Central, CADE, Agências Reguladoras, CNJ, CNMP, CARF, afirma, destacando a necessidade, conforme visto anteriormente, de prévio pronunciamento do STF: “Observo, no entanto, que, apesar desse entendimento pacífico, **não há empecilho para que a Administração Pública deixe de aplicar lei ou ato normativo inconstitucional ou interpretação tida como incompatível com a Constituição pela Suprema Corte**, consoante jurisprudência pacífica” (fls. 77 do acórdão, MS 35.410).

Por sua vez, a expressa ressalva feita pelo Min. Barroso, que acompanhava o Min. Relator, não parece afastar o nosso entendimento de que a orientação estabelecida na Pet 4.656 persiste. Barroso vai além ao admitir a possibilidade de os órgãos administrativos autônomos de controle declararem incidentalmente a inconstitucionalidade de lei, desde que limitada ao caso concreto (fls. 26).

Nesse mesmo sentido de se manter a aplicação do entendimento firmado na Pet 4.656, manifesta-se o Min. Fachin (fls. 47), **apesar de ter sido reconhecido o seu voto como vencido** e, portanto, contrário ao do relator.

Essa nossa percepção e linha de orientação está reafirmada no julgamento do agravo regimental (agravo interno) no **MS 25.888** (j. **22.08.2023**, Pleno). Apesar de os votos escritos não focarem nesse ponto e de o julgamento ter sido realizado em Plenário Virtual (sem o debate presencial), o voto do Min. Gilmar Mendes, evoluindo o seu primeiro entendimento firmado em 2006, quando do julgamento da medida cautelar, **reafirma a lógica de aplicação renovada da S. 347**.

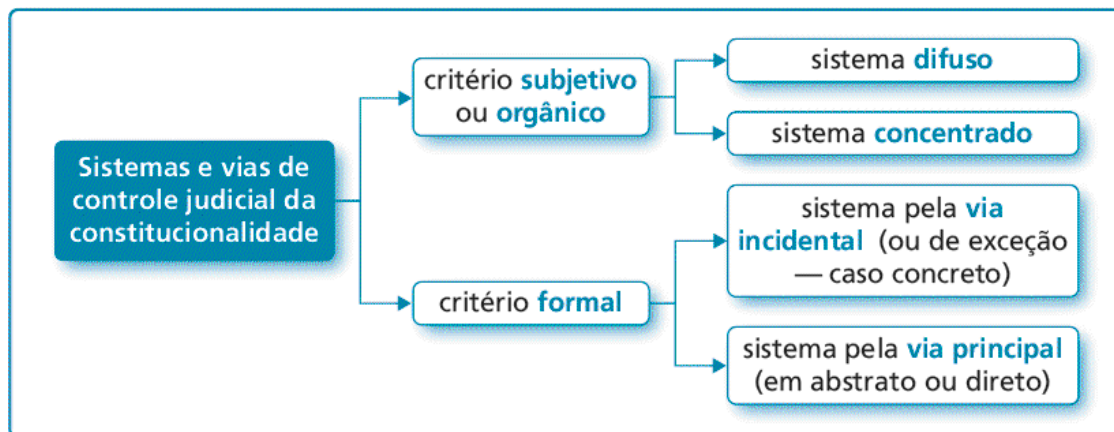
Segundo a sua proposta interpretativa, o afastamento do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos por parte do Tribunal de Contas **dependeria** do preenchimento dos seguintes requisitos: inconstitucionalidade manifesta; existência de jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade; entendimento doutrinário também no sentido da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo.

Dessa forma, conforme o item 5 da ementa: “Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal: compatibilidade com a ordem constitucional de 1988: o verbete confere aos Tribunais de Contas — caso imprescindível para o exercício do controle externo — **a possibilidade de afastar (incidenter tantum) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria)**. Inteligência do enunciado, à luz de seu precedente representativo (RMS 8.372/CE, Rel. Min. Pedro Chaves, Pleno, julgado em 11.12.1961)”.

E que fique claro, **isso não é controle de constitucionalidade**. A **impossibilidade** de se realizar o controle abstrato de constitucionalidade, ou a “emissão de declaração de inconstitucionalidade com efeitos *erga omnes* por parte de Tribunais de Contas” (fls. 35 do acórdão — MS 25.888 AgR), ficou explícita no item 6 da ementa, reafirmando a jurisprudência do STF (MS 35.410, MS 35.490, MS 35.494, MS 35.498, MS 35.500, MS 35.812, MS 35.824, MS 35.836, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13.04.2021).

Em igual medida, o afastamento de uma determinada lei diante dos parâmetros existentes, como, no caso, interpretação já dada pelo STF, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, também não se confunde com a “declaração formal de inconstitucionalidade do preceito normativo federal, estadual ou municipal” (fls. 30, MS 25.588 AgR).

■ 6.5. SISTEMAS E VIAS DE CONTROLE JUDICIAL



Assim, como se percebe pelo quadro acima, partindo de um critério **subjetivo** ou **orgânico**, o controle judicial de constitucionalidade poderá ser **difuso** ou **concentrado**.

O sistema **difuso** de controle significa a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência, realizar o controle de constitucionalidade.

Por seu turno, no sistema **concentrado**, como o nome já diz, o controle se “concentra” em um ou mais de um (porém em número limitado) órgão. Trata-se de **competência originária** do referido órgão.

Sob outra perspectiva, do ponto de vista **formal**, o sistema poderá ser pela **via incidental** ou pela **via principal**.

No sistema de controle pela **via incidental** (também chamado pela via de exceção ou defesa), o controle será exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal.

Nesse ponto, é conveniente fazer uma crítica ao uso da terminologia “pela via de exceção ou defesa”, na medida em que será possível que a via incidental (análise de questão prejudicial) se dê, também, como fundamento

da pretensão do autor, o que se vê nas ações constitucionais, a exemplo do mandado de segurança.

Já no sistema de controle pela **via principal** (abstrata ou pela via de “ação”), a análise da constitucionalidade da lei será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa.

Mesclando as duas classificações, verifica-se que, regra geral, o sistema **difuso** é exercido pela via **incidental**, destacando-se, aqui, a experiência norte-americana, que, inclusive, influenciou o surgimento do controle difuso no Brasil.

Por sua vez, o sistema **concentrado** é exercido pela via **principal**, como decorre da experiência austríaca e se verifica no sistema brasileiro.

Essa regra, contudo, apresenta **exceções**, tanto no *direito estrangeiro* como no *direito brasileiro*.

Conforme anota Barbosa Moreira ao tratar sobre o **direito estrangeiro** “características ecléticas apresentam os sistemas atuais de controle na **Itália** e na **República Federal da Alemanha**, que reconhecem a um único órgão judicial competência para apreciar a questão da constitucionalidade, mas lhe deferem o exercício dessa competência quer pela via *principal* (mediante provocação de algum legitimado), quer por via *incidental*, a propósito de caso concreto, sujeito à cognição de qualquer outro órgão judicial, que submete a questão à Corte Constitucional, a fim de que esta a resolva com força vinculativa, ficando suspenso, nesse meio-tempo, o processo em que se suscitou a questão. Na mesma corrente insere-se a Constituição espanhola de 1978 (arts. 161 a 165)”.⁶⁵

No **direito brasileiro**, como exceção à regra do controle **concentrado e abstrato de constitucionalidade**, podemos pensar em situação na qual o controle será **concentrado** (em órgão de cúpula, com competência originária), mas **incidental**, discutindo-se a questão de constitucionalidade como questão prejudicial ao objeto principal da lide.

Como exemplo de controle concentrado e incidental, então, citamos o art. 102, I, “d”, que estabelece ser **competência originária do STF** processar e julgar o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas

alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.

■ 6.6. CONTROLE DIFUSO

■ 6.6.1. Origem histórica: Marbury “versus” Madison, Sessão de fev. de 1803 (I, repertório de Cranch, 137-180)

CONTROLE DIFUSO — HISTÓRICO		
■ John Adams (Presidente EUA) ■ William Marbury — nomeado “juiz de paz” (juiz federal) — mas a “comissão” para o cargo, embora assinada, não lhe foi entregue	X	■ Thomas Jefferson (novo Presidente EUA) ■ James Madison — nomeado Secretário de Estado — não efetivou a “comissão” por ordem de Jefferson
■ John Marshall, Chief Justice ■ A lei (seção 13 do Judiciary Act, de 1789) x a Constituição de 1787, que não fixou competência originária para apreciar a questão ■ Solução: Havendo conflito entre a aplicação de uma lei e a Constituição, aplica-se a regra constitucional, por ser hierarquicamente superior		

John Adams, presidente dos EUA, foi derrotado na eleição presidencial por Thomas Jefferson.

Adams resolveu, antes de ser sucedido por Jefferson, nomear diversas pessoas ligadas ao seu governo como juízes federais, destacando-se William Marbury, cuja “comissão” para o cargo de “juiz de paz” do condado de Washington foi assinada por Adams, sem, contudo, ter-lhe sido entregue.

Jefferson, por sua vez, ao assumir o governo, nomeou James Madison como seu Secretário de Estado e, ao mesmo tempo, por entender que a nomeação de Marbury era incompleta até o ato da “comissão”, já que esta ainda não lhe havia sido entregue, determinou que Madison não mais efetivasse a nomeação de Marbury.

Naturalmente, Marbury acionou Madison pedindo explicações. Sem resposta, Marbury resolveu impetrar *writ of mandamus*, buscando efetivar a sua nomeação.

Depois de dois longos anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América resolveu enfrentar a matéria. John Marshall, *Chief Justice*, em seu voto, analisou vários pontos, dentre os quais a questão de se a Suprema Corte teria competência para apreciar ou não aquele remédio de *writ of mandamus*.

Isso porque, segundo a Constituição dos EUA, “o Supremo Tribunal terá jurisdição originária em todas as causas concernentes a embaixadores, outros ministros públicos e cônsules, e nos litígios em que for parte um Estado. Em todas as outras causas, o Supremo Tribunal terá jurisdição em grau de recurso”.⁶⁶

Ou seja, na prática, pela primeira vez teria a Suprema Corte de analisar se deveria prevalecer a lei (seção 13 do *Judiciary Act*, de 1789, que determinava a apreciação da matéria pela Suprema Corte) ou a Constituição de 1787, que não fixou tal competência originária, em verdadeiro conflito de normas.

Até então, a regra era a de que a lei posterior revogava a lei anterior. Assim, teria a lei revogado o artigo de Constituição que tratava das regras sobre competência originária?

Depois de muito meditar, inclusive sobre o papel da Constituição escrita, Marshall conclui: “assim, a ‘fraseologia’ particular da Constituição dos Estados Unidos confirma e corrobora o princípio essencial a todas as constituições escritas, segundo o qual é **nula** qualquer lei incompatível com a Constituição; e que os tribunais, bem como os demais departamentos, são vinculados por esse instrumento”.⁶⁷

Pode-se, assim, afirmar que a noção e a ideia de controle difuso de constitucionalidade, historicamente, devem-se ao famoso caso julgado pelo Juiz *John Marshall* da Suprema Corte norte-americana, que, apreciando o precedente **Marbury v. Madison**, em 1803, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei em um caso concreto e a Constituição, **deve prevalecer a Constituição**, por ser hierarquicamente superior.

Como anota Oscar Vilhena, referido precedente “... é resultado, única e exclusivamente, de uma leitura expandida da Constituição americana e, posteriormente, na tradição da *common law*, da ação reiterada dos magistrados. Este poder de controlar a compatibilidade das leis com a Constituição decorre, assim, da jurisprudência americana, e não de uma autorização positivada de forma expressa pelo constituinte”.⁶⁸

■ 6.6.2. Noções gerais

O **controle difuso**, repressivo, ou posterior, é também chamado de controle pela via de **exceção** ou **defesa**, ou controle **aberto**, sendo realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário. Quando dizemos qualquer juízo ou tribunal, devem ser observadas, é claro, as regras de competência processual, a serem estudadas no processo civil.

O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de inconstitucionalidade dá-se de forma incidental (*incidenter tantum*), prejudicialmente ao exame do mérito.

Pede-se algo ao juízo, fundamentando-se na inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou seja, a alegação de inconstitucionalidade será a *causa de pedir processual*.

Exemplo: na época do Presidente Collor, os interessados pediam o desbloqueio dos cruzados fundando-se no argumento de que o ato que motivou tal bloqueio era inconstitucional. O pedido principal não era a declaração de inconstitucionalidade, mas sim o desbloqueio!

■ 6.6.3. Controle difuso nos tribunais e a cláusula de reserva de plenário (“full bench”). Art. 97, CF/88

■ 6.6.3.1. Regras gerais

Observadas as regras do processo civil, a parte sucumbente poderá devolver a análise da matéria ao tribunal *ad quem* (nessa hipótese estamos imaginando um processo que começou na primeira instância — juízo monocrático, sendo interposto recurso de apelação para o tribunal competente).

No tribunal competente, distribuído o processo para turma, câmara ou seção (depende da organização interna do tribunal a ser estabelecida em seu regimento interno), **arguida**, em controle difuso, a **inconstitucionalidade** de lei ou de ato normativo do Poder Público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão ao referido órgão fracionário ao qual competir o conhecimento do processo, que poderá proferir duas decisões:

- **rejeitar a arguição:** o julgamento prosseguirá;
- **acolher a arguição:** a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Para esta última situação, o **art. 97, CF/88**, estabelece que somente pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a **inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo do Poder Público.⁶⁹ Temos aqui a chamada **cláusula de reserva de plenário**, também denominada regra do **full bench**.

Descrevendo o procedimento, o art. 950, CPC/2015, estabelece que, remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento, observando-se as seguintes regras:

- **pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado:** poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal;
- **parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103, CF/88:** poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-

lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos;

■ **amicus curiae**: considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Após o julgamento da questão incidental de inconstitucionalidade pelo pleno ou órgão especial do tribunal, o **órgão fracionário**, vinculado à decisão, seja em que sentido for, **julgará a questão principal de mérito**.

Observam-se, portanto, a lavratura de **3 acórdãos**: **a)** arguida a questão incidental de inconstitucionalidade, a primeira decisão será tomada pelo órgão fracionário no sentido de acolher ou não o incidente. Acolhido, cinde-se o julgamento e se remetem os autos para o órgão especial ou plenário analisar o incidente de inconstitucionalidade; **b)** submetida a questão ao órgão especial ou plenário, haverá, com o julgamento, um segundo acórdão, declarando a constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo; **c)** finalmente, julgada a questão incidental, o órgão fracionário, vinculado à decisão, julgará a questão principal e será lavrado o terceiro acórdão.

Então, surge a indagação: diante desses **3 acórdãos**, qual será o momento para a interposição do eventual recurso extraordinário?

A resposta encontra a sua orientação na **S. 513/STF**, ao se estabelecer que a decisão que enseja a interposição do recurso extraordinário não é a do órgão especial ou plenário que julga o incidente de inconstitucionalidade, mas a terceira e final, do órgão fracionário, que, completando o julgamento do feito, decide a questão principal (o pedido).⁷⁰

Outro ponto interessante diz respeito à interpretação do referido art. 97, CF, no sentido de ser ou não sempre necessária a apreciação pelo órgão especial ou pleno da **questão prejudicial**, qual seja, a realização do controle *incidenter tantum* de constitucionalidade da lei ou ato normativo pelos aludidos órgãos.

Assevera Marcelo Caetano, citado pelo Min. Celso de Mello (RE 190.725-8/PR), que “... a exigência de maioria qualificada para a declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo justifica-se pela preocupação de só permitir ao Poder Judiciário tal declaração quando o vício seja manifesto e, portanto, salte aos olhos de um grande número de julgadores experientes caso o órgão seja colegiado. Sendo atingida a majestade da lei a qual, em princípio, se beneficia da presunção de estar de acordo com a Constituição, é necessário que o julgamento resulte de um consenso apreciável e não brote de qualquer escassa maioria (...). Essa exigência, por outro lado, acautela contra uma futura variação de jurisprudência no mesmo Tribunal. Assim, a inconstitucionalidade tem de ser declarada pelos votos conformes de um número de juízes equivalente a metade e mais um dos membros do Tribunal ou do órgão competente nele formado”.⁷¹

A regra do art. 97 destaca-se como verdadeira **condição de eficácia jurídica da própria declaração de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público**.⁷² Nesse sentido, destacamos a **Súmula Vinculante 10/STF**:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

No entanto, enaltecendo o **princípio da economia processual, da segurança jurídica** e na busca da desejada **racionalização orgânica da instituição judiciária brasileira**, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de se dispensar o procedimento do art. 97 toda vez que já houvesse decisão do órgão especial ou pleno do tribunal, ou do STF, o guardião da Constituição sobre a matéria.

Segundo o Min. Ilmar Galvão, “declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, pela maioria absoluta dos membros de certo Tribunal, soaria como verdadeiro despropósito, notadamente nos tempos atuais, quando se verifica, de maneira inusitada, a repetência desmesurada de causas versantes da mesma questão jurídica, vinculadas à

interpretação da mesma norma, que, se exigisse, em cada recurso apreciado, a renovação da instância incidental da arguição de inconstitucionalidade, levando as sessões da Corte a uma monótona e interminável repetição de julgados da mesma natureza” (RE 190.725-8/PR).

Essa tendência foi confirmada pela **Lei n. 9.756/98**, que, acrescentando um parágrafo único ao art. 481 do revogado CPC/73 (regra mantida no art. 949, parágrafo único, CPC/2015), estabeleceu: “Os órgãos fracionários dos tribunais (entenda-se Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções) **não submeterão ao plenário**, ou ao **órgão especial**, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamentos destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”, podendo, inclusive, referida ação ser, de plano, apreciada, conhecida e julgada pelo relator, conforme prescreve o art. 932, IV, “a”, e V, “a”, CPC/2015.⁷³

A **mitigação da cláusula de reserva de plenário** vem sendo observada em outras situações. Conveniente, portanto, esquematizar a matéria. Em conclusão, não há a necessidade de se observar a regra do art. 97, CF/88:

- na citada hipótese do art. 949, parágrafo único, CPC/2015;
- se o Tribunal **mantiver a constitucionalidade do ato normativo**, ou seja, não afastar a sua presunção de validade (o art. 97 determina a observância do *full bench* para declarar a *inconstitucionalidade* de lei ou ato normativo do Poder Público);
- nos casos de **normas pré-constitucionais**, porque a análise do direito editado no ordenamento jurídico anterior em relação à nova Constituição não se funda na teoria da inconstitucionalidade, mas, como já estudado, em sua recepção ou revogação;
- quando o Tribunal utilizar a técnica da **interpretação conforme a Constituição**, pois não haverá declaração de inconstitucionalidade;
- nas hipóteses de decisão em sede de **medida cautelar**, já que não se trata de decisão definitiva.

■ 6.6.3.2. *A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas do STF no julgamento de RE?*

De acordo com o art. 9.º, III, *RISTF*, é **competência das Turmas** (1.ª ou 2.ª) o julgamento de **recurso extraordinário**, que será distribuído a um Ministro e ficará atrelado à Turma em relação a qual o Ministro integra, ressalvadas as hipóteses regimentais de prevenção.

Apesar dessa regra geral, consoante o art. 11, I, *RISTF*, a **Turma** remeterá o feito ao julgamento do Plenário independente de acórdão e de nova pauta:

- quando considerar **relevante a arguição de inconstitucionalidade** ainda não decidida pelo Plenário, e o Relator não lhe houver afetado o julgamento;
- quando, não obstante decidida pelo Plenário a questão de inconstitucionalidade, algum **Ministro** propuser o seu **reexame**;
- quando algum **Ministro** propuser **revisão da jurisprudência** compendiada na Súmula.

Ainda, o art. 22, *RISTF*, permite que o **Relator afete** a questão ao **Plenário** quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida, notadamente:

- quando houver matérias em que **divirjam** as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário;
- quando, em razão da **relevância da questão jurídica** ou da necessidade de **prevenir divergência entre as Turmas**, convier pronunciamento do Plenário.

Portanto, tendo como premissa que o julgamento do RE é de competência da Turma no STF, o encaminhamento do RE ao Plenário **depende** do preenchimento das hipóteses regimentais, e não, simplesmente, de requerimento da parte.

Dessa forma, de acordo com as **normas regimentais** — e apresentaremos crítica em seguida —, **a cláusula de reserva de plenário não se aplica às Turmas do STF no julgamento do RE**, seja por não se tratar de “tribunal” no sentido fixado no art. 97 (e essa poderia ser uma “forçada” justificativa para não ficarmos apenas com o fundamento regimental, apesar de não concordarmos), seja, tendo em vista ser função primordial e essencial da Corte a declaração de inconstitucionalidade, a possibilidade de afetação dessa atribuição aos seus órgãos fracionários, no caso, as Turmas.

Nesse sentido, destacamos **controvertido** precedente da 2.^a Turma do STF que, inclusive, já foi cobrado na prova do *MPF/2011*. Vejamos:

“O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, **tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da CF**” (RE 361.829-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02.03.2010, 2.^a T., *DJE* de 19.03.2010).

CRÍTICA: com o máximo respeito, entendemos esse posicionamento **inadequado** e **violador** da regra do art. 97, CF/88, que se mostra extremamente clara e didática:

“**Art. 97.** Somente pelo voto da maioria absoluta de **seus membros** ou dos **membros do respectivo órgão especial** poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Ou seja, a atribuição foi expressamente fixada para o Plenário ou para o órgão especial, e não para a Turma. Como o STF não tem órgão especial, a atribuição, então, seria do **Plenário**. Portanto, a norma regimental não respeita a regra constitucional do art. 97. Eventual outro entendimento dependeria de **reforma da Constituição**, não sendo suficiente mera alteração do Regimento Interno do STF.

Propondo **interpretação intermediária**, o **Min. Roberto Barroso** apresenta a seguinte orientação: “a **cláusula da reserva de plenário não é exigida** quando o Supremo Tribunal Federal, na sua **competência recursal**, **mantém acórdão recorrido** que declarou a inconstitucionalidade de norma local em processo de controle por ação direta estadual. Nesses casos, assenta-se tão somente a conformidade do *decisum* recorrido com o entendimento desta Corte, órgão incumbido do papel de intérprete máximo da Constituição. **Hipótese diversa** é aquela em que, afastada a inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem, esta Corte **dá provimento ao recurso extraordinário para extinguir do ordenamento jurídico a norma impugnada**. Em tais condições, em observância ao disposto no art. 97 da Constituição Federal, deve ser o julgamento do feito **afetado** ao Plenário desta Corte” (ARE 661.288, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.05.2014, 1.^a T., *DJE* de 29.09.2014, fls. 27 do acórdão). Vamos aguardar manifestação plenária sobre o assunto **(pendente)**.

O tema, certamente, precisará ser **rediscutido** pelo Plenário do STF, com a manifestação da sua nova composição, esperando que a Corte retome formalmente a exigibilidade de observância ao art. 97, CF/88, especialmente diante do atual reconhecimento do efeito *erga omnes* e vinculante em razão da declaração de inconstitucionalidade em **recurso extraordinário com repercussão geral**, propondo uma real aproximação do controle difuso com o controle concentrado (cf. **ADIs 3.406 e 3.470**, nas quais o STF reconheceu a **mudança constitucional do art. 52, X**, reafirmando esse entendimento no julgamento dos embargos de declaração — j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023 — *item 6.6.5.5* deste nosso estudo, consolidando a evolução no julgamento dos **REs 955.227 e 949.297**, j. 08.02.2023 — *item 6.6.5.7*).

Certamente, a produção desse pretendido efeito em razão da declaração de inconstitucionalidade depende, necessariamente, da manifestação de ao menos **6 Ministros** (maioria absoluta dos 11 Ministros) no sentido da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo (art. 97, CF/88).

■ 6.6.3.3. *A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais?*

Não.

Isso porque, embora órgão recursal, as Turmas de Juizados não são consideradas “tribunais”.

O art. 97, CF/88, refere-se aos tribunais indicados no art. 92 e respectivos órgãos especiais mencionados no art. 93, XI. As **Turmas dos Juizados**, no âmbito recursal, **não funcionam sob o regime de plenário ou de órgão especial** (ARE 792.562-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.03.2014, 2.^a T., DJE de 02.04.2014).

Dessa forma, as Turmas Recursais, órgãos colegiados dos Juizados, poderão declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar a sua incidência no todo ou em parte sem que isso signifique violação ao art. 97, CF/88, e à SV 10/STF.

Isso não impede, contudo, que a parte sucumbente interponha recurso extraordinário contra a decisão da Turma Recursal, para o STF apreciar a questão constitucional (S. 640/STF).

Apenas se faz o alerta de que, conforme já decidiu o STF, embora a cláusula de reserva de plenário não se aplique às Turmas Recursais de Juizados, isso não significa que os requisitos de admissibilidade inerentes ao cabimento do RE (art. 102, III, CF/88) poderão ser desrespeitados. Assim, indispensável a **juntada do inteiro teor da decisão que tenha declarado a inconstitucionalidade e que será objeto do recurso extraordinário**. Nesse sentido:

“EMENTA: A regra da chamada **reserva do plenário** para declaração de inconstitucionalidade (art. 97 da CF) **não se aplica**, deveras, **às turmas recursais de Juizado Especial**. Mas tal circunstância em nada atenua nem desnatura a **rigorosa exigência de juntada de cópia integral do precedente que tenha, ali, pronunciado inconstitucionalidade de norma objeto de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, ‘b’, da Constituição da República**, pela mesmíssima razão por que, a igual

título de admissibilidade do recurso, não se dispensa juntada de cópia de acórdão oriundo de plenário” (RE 453.744-AgR, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.06.2006, 1.^a T., DJ de 25.08.2006. No mesmo sentido: RE 529.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.05.2011. Ainda, AI 561.181-AgR, RE 369.696-AgR, AI 431.863-AgR, RE 466.834).

■ 6.6.3.4. *A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira instância?*

Não.

Como visto, a regra do art. 97 é estabelecida para “tribunal”, não estando, portanto, direcionada para o juízo monocrático, mesmo que, incidentalmente, no controle difuso, declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Vejamos as lições do Min. Celso de Mello:

■ “EMENTA: A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Política, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a **competência funcional** por objeto do juízo para proferir decisões declaratórias de inconstitucionalidade. Órgãos fracionários dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispõem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. **A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal**, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, **não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional** (RT 554/253)” (HC 69.921, voto do Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.02.1993, 1.^a T., DJ de 26.03.1993).

■ 6.6.4. Efeitos da decisão

■ 6.6.4.1. *Para as partes*

Regra geral, os efeitos de qualquer sentença valem somente para as partes que litigaram em juízo, não extrapolando os limites estabelecidos na lide.

No momento que a sentença declara ser a lei inconstitucional (controle difuso realizado incidentalmente), produz efeitos pretéritos, atingindo a lei desde a sua edição, tornando-a **nula** de pleno direito. Produz, portanto, **efeitos retroativos**.

Assim, no **controle difuso**, para as partes os efeitos serão (regra):

■ **inter partes**: a decisão está limitada às partes do processo (e essa regra terá que ser lida com os temperamentos decorrentes da perspectiva de efeito *erga omnes* da tese do julgamento a partir de uma perspectiva de mutação constitucional do art. 52, X, que discutimos nos itens seguintes);

■ **ex tunc**: consagra-se a regra na nulidade. Se a lei ou o ato normativo é inconstitucional, estamos diante de vício congênito, ou seja, vício de “nascimento”. Assim, a declaração de inconstitucionalidade produz, em regra, efeito retroativo.

Essas regras, contudo, apresentam exceções.

No tocante à perspectiva da **nulidade**, o STF tem admitido a técnica da **modulação dos efeitos da decisão** também no controle difuso, aplicando-se, por analogia, o art. 27 da Lei n. 9.868/99 (lei da ADI), que estabelece: “ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de **segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

O *leading case*, nesse sentido, foi o julgamento do **RE 197.917**, pelo qual o STF reduziu o número de vereadores do Município de Mira Estrela de 11 para 9 e determinou que a aludida decisão só atingisse a próxima legislatura. Entendeu a Corte estar diante de “situação excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos *ex tunc*, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos *pro futuro* à declaração incidental de inconstitucionalidade, valendo apenas para as eleições seguintes” (se os efeitos fossem normais, toda a atuação do parlamento anterior à decisão, que atuou com 11 e o correto seriam 9 vereadores, estaria comprometida) (cf. RE 197.917, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, Pleno, *DJ* de 07.05.2004, destacando-se, em relação ao tema, o denso voto do Min. Gilmar Mendes, que vale a leitura).

Agora, em relação ao efeito *inter partes*, a perspectiva de expansão da tese de julgamento começa a ganhar adeptos. Isso seria conveniente em ações cujo objeto seja comum a um número muito grande de pessoas, como os *cruzados bloqueados*, a **cobrança de um tributo que entendam inconstitucional**, por exemplo, a extinta CPMF etc.

Sobre esse assunto, estudaremos a regra contida no art. 52, X. Em seguida, destacaremos uma nova tendência/realidade em razão daquilo que vem sendo chamado de **transcendência dos motivos determinantes da sentença** em controle difuso, de **abstrativização do controle difuso** ou de **objetivação** do controle difuso (temática já enfrentada pelo STF no julgamento da Rcl 4.335, j. 20.03.2014, *DJE* de 21.10.2014, e, com profundas alterações, no debate do julgamento das **ADIs 3.406** e **3.470**, j. 29.11.2017, no qual se reconheceu a mutação constitucional do art. 52, X, confirmando-se esse entendimento no julgamento dos embargos de declaração em 23.02.2023, bem como em razão de explicitação no julgamento dos **REs 955.227** e **949.297**, j. 08.02.2023).

■ **6.6.4.2. Para terceiros (art. 52, X): visão clássica e tradicional do papel do Senado Federal no controle difuso considerando**

que não houve mutação constitucional

Conforme explicamos no *item* 6.6.5, a perspectiva de mutação constitucional do art. 52, X, consolidou-se em debate travado em processo de controle concentrado e abstrato, ou seja, em declaração de inconstitucionalidade incidental em processo abstrato (ADIs 3.406 e 3.470, j. 29.11.2017), tendo sido reforçado tal entendimento no julgamento dos REs 955.227 e 949.297 que, no caso, se tratava de controle difuso propriamente dito.

Deixamos claro que, em referido julgamento, por **7 x 2**, o STF acatou a tese de que **o papel do Senado Federal seria apenas para dar publicidade à decisão que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei de modo incidental, como questão prejudicial**, e que **o efeito vinculante e erga omnes decorreria da própria decisão judicial**, não havendo a necessidade de atuação do Senado Federal.

A matéria não foi destacada de modo formal como questão preliminar a ser enfrentada no referido julgamento. Apesar disso, acreditamos que a mutação constitucional do art. 52, X, passou a ser uma **realidade** para o STF, que a confirmou no julgamento dos REs 955.227 e 949.297, no qual se explicitou esse entendimento na hipótese de decisão formulada pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.

Continuamos descrevendo neste estudo a **regra clássica do art. 52, X**, isto é, como deveria ser o papel do Senado Federal no controle difuso se ainda válida, pois acreditamos que, em algumas situações, ainda se poderá pensar na sua manutenção, qual seja, na hipótese de julgamento de recurso extraordinário antes da repercussão geral, bem como de não destaque da questão prejudicial pelo STF quando do julgamento do controle difuso com repercussão geral.

Entendemos que, para o STF dar efeito *erga omnes* e vinculante em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei nulificada incidentalmente, terá a Corte que formalmente assim se pronunciar e, no caso, fazer constar expressamente como tese do julgamento e na ementa do acórdão.

CUIDADO: para efeito de provas de concursos, conforme estamos sentindo essa inegável aproximação entre o controle difuso e o controle concentrado proclamada pelo STF, o novo entendimento deverá ser considerado, especialmente diante das regras trazidas pelo CPC/2015 em relação aos **precedentes** e que explicaremos em outro item.

■ 6.6.4.2.1. *Procedimento (art. 52, X) (visão clássica)*

Vimos anteriormente que, através da interposição de *recurso extraordinário*, nas hipóteses constitucionalmente previstas, a questão poderá ser levada à apreciação do STF, que, também, realizará o controle difuso de constitucionalidade, de forma incidental.

Declarada inconstitucional a lei pelo STF, no controle difuso, desde que tal decisão seja definitiva e deliberada pela **maioria absoluta** do pleno do tribunal (art. 97, CF/88),⁷⁴ o art. 178, Regimento Interno do STF (*RISTF*), estabelece que será feita a comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do trânsito em julgado, ao **Senado Federal**, para os efeitos do art. 52, X, CF/88.

O art. 52, X, CF/88, por sua vez, estabelece ser competência privativa do Senado Federal, mediante o instrumento da **resolução**, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão **definitiva** do STF.

Regulamentando o assunto, o art. 386 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece que o Senado conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo STF, de inconstitucionalidade, total ou parcial, de lei mediante: *a)* comunicação do Presidente do Tribunal; *b)* representação do Procurador-Geral da República; *c)* projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A comunicação, a representação e o projeto a que se refere o artigo anterior deverão ser instruídos com o **texto da lei cuja execução se deva suspender, do acórdão do Supremo Tribunal Federal, do parecer do**

Procurador-Geral da República e da **versão do registro taquigráfico do julgamento**, isso tudo conforme o art. 387 do Regimento Interno do Senado.

E o art. 388 conclui o procedimento determinando que, após a leitura em plenário, a comunicação ou representação será encaminhada à **Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania**, que formulará projeto de **resolução** suspendendo a execução da lei, no todo ou em parte (CF, art. 52, X).

■ 6.6.4.2.2. *Amplitude do art. 52, X (visão clássica)*

A suspensão pelo Senado Federal poderá dar-se em relação a leis **federais, estaduais, distritais** ou mesmo **municipais** que forem declaradas inconstitucionais pelo STF, de modo incidental, no controle difuso de constitucionalidade.⁷⁵

Em se tratando de lei municipal ou lei estadual confrontadas perante a **Constituição Estadual**, Michel Temer entende que, em face do princípio federativo, “pode e deve o Tribunal de Justiça ou Tribunal de Alçada,⁷⁶ após declarar a inconstitucionalidade, remeter essa declaração à Assembleia Legislativa para que esta suspenda a execução da lei (evidentemente, nos Estados em que as Constituições confirmam essa competência à Assembleia)”.⁷⁷

■ 6.6.4.2.3. *A expressão “no todo ou em parte” (art. 52, X) (visão clássica)*

Como visto, nos termos do art. 52, X, compete ao Senado Federal, por meio de **resolução**, suspender a execução, **no todo ou em parte**, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A expressão “no todo ou em parte” deve ser interpretada como sendo impossível o Senado Federal ampliar, interpretar ou restringir a extensão da decisão do STF.

Se toda a lei foi declarada inconstitucional pelo STF, em controle difuso, de modo incidental, se entender o Senado Federal pela conveniência da suspensão da lei, deverá fazê-lo “no todo”, vale dizer, em relação a toda a lei que já havia sido declarada inconstitucional, não podendo suspender menos do que o decidido pela Excelsa Corte.

Em igual sentido, se, por outro lado, o Supremo, no controle difuso, declarou inconstitucional apenas parte da lei, entendendo o SF pela conveniência para a suspensão, deverá fazê-lo exatamente em relação à “parte” que foi declarada inválida, não podendo suspender além da decisão do STF.

■ 6.6.4.2.4. *Efeitos propriamente ditos (art. 52, X) (visão clássica)*

Desde que o Senado Federal suspenda a execução, no todo ou em parte, da lei levada a controle de constitucionalidade de maneira incidental e não principal, a referida suspensão atingirá a todos, porém valerá a partir do momento que a resolução do Senado for publicada na Imprensa Oficial.

O nome ajuda a entender: *suspender a execução* de algo que vinha produzindo efeitos significa dizer que se suspende a partir de um momento, não fazendo retroagir para atingir efeitos passados. Por exemplo, quem tiver interesse em “pedir de volta” um tributo declarado inconstitucional deverá mover a sua ação individualmente para reaver tudo antes da Resolução do Senado, na medida em que ela não retroage.

Assim, os efeitos serão *erga omnes*, porém *ex nunc*, não retroagindo.⁷⁸

Destaca-se o art. 1.º, § 2.º, do **Decreto n. 2.346/97**, que, expressamente, fixa a produção de efeitos *ex tunc*, exclusivamente em relação à **Administração Pública Federal direta e indireta**, na hipótese de haver a edição de **resolução do Senado Federal**, suspendendo a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

Referido decreto, em seu art. 1.º, § 3.º, ainda estabelece que o Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União,

poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto.

■ 6.6.4.2.5. ***O Senado é obrigado a suspender os efeitos? (art. 52, X) (visão clássica)***

Não.

Essa questão é muito debatida na doutrina. Tanto que nos limitaremos a apontar nosso posicionamento, que coincide com o do STF, Senado Federal e grande parte da doutrina, devendo, pois, ser o observado nas provas preambulares.

Deve-se, pois, entender que o Senado Federal **não** está obrigado a suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de discricionariedade política, tendo o Senado Federal total liberdade para cumprir o art. 52, X, CF/88. Caso contrário, estaríamos diante de afronta ao princípio da separação de Poderes.

Uma vez editada a resolução, não nos parece possível a sua posterior revogação pelo próprio Senado Federal com o objetivo de se restabelecer a eficácia da norma declarada inconstitucional no controle difuso. No caso, o restabelecimento da norma dependeria de nova atuação pelo Poder Legislativo editando um novo ato. A **resolução** que suspende o ato declarado inconstitucional é **irrevogável**.⁷⁹

■ 6.6.5. **Para terceiros (art. 52, X): mutação constitucional do papel do Senado Federal no controle difuso. Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso: análise crítica — abstrativização do controle difuso — tendência para uma maior expansividade das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias individuais. Perspectivas do controle incidental em controle concentrado. Limitação do cabimento da reclamação⁸⁰**

■ 6.6.5.1. ***Abstrativização do controle difuso: aspectos doutrinários***

Como sabemos, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é jurisdicional misto, tanto *difuso* como *concentrado*.

No controle **difuso**, a arguição de inconstitucionalidade se dá de modo **incidental**, constituindo **questão prejudicial**. No controle **concentrado** (ADI genérica), por sua vez, a declaração se implementa de modo **principal**, constituindo o **objeto** do processo.

A doutrina clássica sempre sustentou, com **Buzaid**⁸¹ e **Grinover**, que, “se a declaração de inconstitucionalidade ocorre incidentalmente, pela acolhida da questão prejudicial que é fundamento do pedido ou da defesa, a decisão não tem autoridade de coisa julgada, nem se projeta, mesmo *inter partes* — fora do processo no qual foi proferida”.⁸²

Contudo, respeitável parte da doutrina e alguns julgados do STF (“Mira Estrela”⁸³ e “progressividade do regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos”⁸⁴) e do STJ⁸⁵ propunham uma **nova interpretação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso** pelo STF.

Na doutrina, em importante estudo, **Gilmar Mendes** afirma ser “... possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma **autêntica mutação constitucional** em razão da completa **reformulação do sistema jurídico** e, por conseguinte, da **nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X**, da Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica ‘**reforma da Constituição sem expressa modificação do texto**’ (Ferraz, 1986, p. 64 *et seq.*, 102 *et seq.*; Jellinek, 1991, p. 15-35; Hsü, 1998, p. 68 *et seq.*)”.⁸⁶

Nessa mesma linha, **Teori Albino Zavascki**, também em sede doutrinária, sustenta a transcendência, com caráter vinculante, de decisão sobre a constitucionalidade da lei, **mesmo em sede de controle difuso**.⁸⁷

Lúcio Bittencourt, em tese arrojada, muito embora demonstrasse conhecimento da doutrina de Liebman e da distinção entre *autoridade da coisa julgada* e *eficácia natural da sentença*, chegou a afirmar, inspirado pela regra do *stare decisis* norte-americano, que **a declaração de inconstitucionalidade** no **caso concreto** e no **controle difuso** brasileiro (já

que inexistente à época de seu estudo o controle concentrado por meio de ADI, enfatize-se), reconhecendo a invalidade da lei, **teria eficácia para todos**.⁸⁸

Os principais argumentos a justificar esse novo posicionamento podem ser assim resumidos:

- força normativa da Constituição;
- princípio da supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários;
- o STF enquanto guardião da Constituição e seu intérprete máximo;
- dimensão política das decisões do STF.

A esses fundamentos, poderíamos acrescentar os **princípios da integridade e da coerência da jurisprudência dos Tribunais** e, no caso, da jurisprudência da Suprema Corte, introduzidos no art. 926, *caput*, CPC/2015, por sugestão de Lenio Streck e que fazem parte dos, denominados pelo autor, **“princípios-padrões”** que devem ser obedecidos nas decisões judiciais.⁸⁹

Os tribunais também têm discutido o tema. No julgamento do **RE 197.917** (redução do número de vereadores — “Mira Estrela”), nos termos do voto do Min. Celso de Mello, o Min. Gilmar Mendes “... ressaltou a aplicabilidade, ao E. Tribunal Superior Eleitoral, do **efeito vinculante** emergente da própria *ratio decidendi* que motivou o julgamento do precedente mencionado”.⁹⁰

Nessa linha, em seu voto, **vencido**, no julgamento da **Rcl 4.335** (cf. *item 14.10.28.1*), o Min. Gilmar Mendes “sepultou”, de vez, a regra do art. 52, X, aproximando o controle difuso do controle concentrado, traduzindo importante perspectiva em termos de **“abstrativização”** do controle difuso e de consagração da tese da transcendência da *ratio decidendi*.

Conforme afirma, “... parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples **efeito de publicidade**. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a

comunicação ao Senado Federal para que este **publique** a decisão no *Diário do Congresso*. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. **A própria decisão da Corte contém essa força normativa.** (...) Assim, o Senado não terá a faculdade de publicar ou não a decisão, uma vez que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de simples dever de publicação, tal como reconhecido a outros órgãos políticos em alguns sistemas constitucionais (...) Portanto, a não publicação, pelo Senado Federal, de Resolução que, nos termos do art. 52, X, da Constituição, suspenderia a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, não terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia jurídica” (fls. 55-56 do acórdão).

Essa perspectiva, contudo, sempre foi **veementemente criticada** por vários autores, entre eles **Alfredo Buzaid**, que não admitia a qualidade da imutabilidade para as questões prejudiciais decididas incidentalmente no processo (art. 469, III, CPC/73 — entendimento esse mantido no CPC/2015 na medida em que a regra do art. 503, § 1.º, não se aplica, já que o juízo no controle difuso não teria competência em razão da matéria para apreciar referida questão incidental como principal).⁹¹

Embora a tese da transcendência decorrente do controle difuso pareça bastante **sedutora, relevante e eficaz**, inclusive em termos de **economia processual**, de **efetividade do processo**, de **celeridade processual** (art. 5.º, LXXVIII — **Reforma do Judiciário**) e de implementação do princípio da **força normativa da Constituição** (Konrad Hesse), afigura-se **faltar**, ao menos em sede de controle difuso, dispositivos e regras **constitucionais** para a sua implementação.

O **efeito erga omnes** da decisão foi previsto somente para o **controle concentrado** e para a **súmula vinculante** (EC n. 45/2004), de acordo com os arts. 102, § 2.º, CF/88 e 103-A, e, em se tratando de controle difuso, nos termos da regra do **art. 52, X, CF/88**, somente após atuação discricionária e política do Senado Federal.

No controle difuso, portanto, se ainda aplicável em sua literalidade o art. 52, X, CF/88, não havendo suspensão da lei pelo Senado Federal, a lei continuaria válida e eficaz, só se tornando nula no caso concreto, em razão de sua não aplicação.

Assim, na medida em que a análise da constitucionalidade da lei no controle difuso pelo STF não produz efeito vinculante, parece que somente mediante necessária **reforma constitucional** (modificando o art. 52, X, e a regra do art. 97) é que seria possível assegurar a constitucionalidade dessa nova tendência — repita-se, **bastante “atraente”** — da transcendência dos motivos determinantes no controle difuso, com caráter vinculante.

Admitir que o STF interprete no sentido de ter havido mutação do art. 52, X, e, assim, transformar o Senado Federal em órgão para simples publicidade da decisão concreta é sustentar **inadmitida mutação inconstitucional**. Ao STF, não foi dado o poder de reforma.

CUIDADO: esse entendimento, contudo, como se verá, encontra-se **superado** a partir do julgamento das **ADIs 3.406 e 3.470**, nas quais o STF reconheceu a mutação constitucional do art. 52, X, reafirmando esse entendimento no julgamento dos embargos de declaração — j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023 (cf. *item* 6.6.5.5) — e consolidando a evolução no julgamento dos **REs 955.227 e 949.297** — j. 08.02.2023 (cf. *item* 6.6.5.7).

■ **6.6.5.2.** ***Rcl 4.335: por 8 x 2 o STF não aceitou a tese da mutação constitucional do art. 52, X — decisão proferida na vigência do revogado CPC/73***

ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO?		
■ Gilmar Mendes ■ Eros Grau	■ Teori Zavascki ■ Luís Roberto Barroso ■ Rosa Weber ■ Celso de Mello	■ Sepúlveda Pertence ■ Joaquim Barbosa ■ Ricardo Lewandowski⁹² ■ Marco Aurélio

Entendimento	Entendimento	Entendimento
■ SIM ■ art. 52, X — reconhecimento de mutação constitucional ■ o Senado Federal daria simplesmente publicidade à decisão de inconstitucionalidade declarada de modo incidental no controle difuso pelo STF ■ esses 2 Ministros conheceram e julgaram procedente a reclamação	■ NÃO ■ preservação da regra estabelecida no art. 52, X — não acolhimento da tese da mutação constitucional ■ reconhecimento de fato superveniente, qual seja, a SV 26/2009 — aplicação do art. 462, CPC/73 (art. 493, CPC/2015) ■ esses 4 Ministros conheceram e julgaram procedente a reclamação	■ NÃO ■ preservação da regra estabelecida no art. 52, X — não acolhimento da tese da mutação constitucional ■ utilização da súmula vinculante para se dar efeitos <i>erga omnes</i> ■ esses 4 Ministros concederam HC de ofício e não conheceram da reclamação
8 Ministros contra 2 entendem que não houve mutação constitucional do art. 52, X		
RCL 4.335, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 20.03.2014, DJE DE 22.10.2014		

O papel do Senado Federal foi discutido no julgamento da **Rcl 4.335**, na qual se analisava a inconstitucionalidade do art. 2.º da lei de crimes hediondos (remetemos o nosso leitor para a leitura do *item 14.10.28.1*, no qual explicamos toda a problemática, especialmente a evolução da jurisprudência e as alterações trazidas pelo *Pacote Anticrime* — **Lei n. 13.964/2019**).

O STF, consolidando o entendimento fixado no HC 82.959, no sentido de observância à **garantia constitucional** da **individualização da pena** (art. 5.º, XLVI), editou, em 16.12.2009, com **efeito *erga omnes*** e **vinculante**, a **SV 26/2009** (DJE de 23.12.2009), que tem o seguinte teor: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do

benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.⁹³

No julgamento da mencionada reclamação, 2 Ministros, Gilmar Mendes e Eros Grau, sustentavam, no caso concreto da Rcl 4.335, a partir do julgamento do referido HC, mesmo sem a edição da súmula vinculante, o efeito transcendente e *erga omnes* da decisão (tese da mutação constitucional do art. 52, X). Por sua vez, Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio não admitiam a mutação constitucional e, assim, para o efeito *erga omnes*, a necessidade de resolução do Senado Federal ou a edição de súmula vinculante. Como esses 4 concordavam com a tese da inconstitucionalidade do regime fechado, não conheceram da reclamação, mas concederam *habeas corpus* de ofício.

Com o voto-vista do Min. Teori Zavascki, devolvido em 20.03.2014, acompanhado pelos Mins. Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello, no julgamento da referida Rcl 4.335-AC, esses outros 4 Ministros julgaram procedente a reclamação não em razão da tese da abstrativização, mas diante da existência de **fato superveniente** (art. 462 do CPC/73, correspondente ao art. 493 do CPC/2015), qual seja, a **SV 26**.

Deve-se deixar bem claro que o Min. Teori Zavascki, muito embora admitisse — o que concordamos — uma **inegável expansividade das decisões do STF**, mesmo quando tomadas em controvérsias de índole individual, esse reconhecimento não seria suficiente para fundamentar o cabimento da reclamação com base no art. 102, I, “I”, sob pena de transformar a Corte em órgão recursal. Assim, **nesse primeiro momento**, sustentou uma necessária **interpretação estrita** dessa competência, sob pena de se caracterizar acesso *per saltum* à Suprema Corte e combatida supressão de instância. Vejamos:

“O mesmo **sentido restritivo** há de ser **conferido à norma de competência sobre cabimento de reclamação**. É que, considerando o vastíssimo elenco de decisões da Corte Suprema com eficácia expansiva, e a tendência de universalização dessa eficácia, **a admissão**

incondicional de reclamação em caso de descumprimento de qualquer delas, transformará o Supremo Tribunal Federal em verdadeira Corte executiva, suprimindo instâncias locais e atraindo competências próprias das instâncias ordinárias. Em outras palavras, **não se pode estabelecer sinonímia entre força expansiva e eficácia vinculante *erga omnes* a ponto de criar uma necessária relação de mútua dependência entre decisão com força expansiva e cabimento de reclamação**. Por outro lado, conforme ficou decidido na Reclamação (AgRg) 16.038 (Min. Celso de Mello, 2.^a T., j. 22.10.2013) ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’” (fls. 168 do acórdão — grifamos).

Muito embora o STF tenha, por maioria de 6 x 4, conhecido e julgado procedente a referida Rcl 4.335, entre esses 6 Ministros (no sentido de procedência da reclamação), apenas os Mins. Gilmar Mendes e Eros Grau fundamentaram com base na tese da mutação.

Deve-se deixar claro, então, que **8 Ministros** (os outros 4 dos 6 que conheciam da reclamação, bem como os 4 que não conheciam da reclamação) se pronunciaram no sentido de **não se admitir a mutação do art. 52, X**. Em outras palavras, o efeito *erga omnes* no controle difuso **ainda** dependia de **resolução do Senado Federal**, que, sem dúvida, não se transformou, **naquele primeiro momento**, em um mero “menino de recados”, ou, ainda, de **súmula vinculante do STF**.

Destacamos que todo esse entendimento foi proferido na vigência do revogado CPC/73, e, assim, não houve apreciação explícita das novas regras trazidas pelo CPC/2015.

Por isso, abaixo e nos itens seguintes trazemos novas perspectivas em relação ao Novo Código de Processo Civil, assim como o entendimento fixado no julgamento das **ADIs 3.406 e 3.470**, pelo qual o STF reconhece,

formalmente, a **mutação constitucional do art. 52, X**, reforçando tal entendimento no julgamento dos **REs 955.227 e 949.297**.

■ 6.6.5.3. ***Valorização dos precedentes: a necessidade de se criar uma nova cultura***

A valorização dos precedentes não se verificou de maneira natural e tradicional no direito brasileiro.

Estamos construindo uma mudança de comportamentos e, sem dúvida, o CPC/2015, bem como a evolução da Corte vêm contribuindo nesse sentido.

Para ilustrar essa constatação, trazemos a discussão sobre a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (HC 126.292).

Conforme observou o **Min. Celso de Mello** ao se referir ao aludido precedente que admitia a execução provisória (e essa tese foi afastada posteriormente — cf. *item 14.10.28.6*), “é necessário enfatizar, pelo fato de haver sido proferida em processo de perfil eminentemente subjetivo, (a referida decisão) **não se reveste de eficácia vinculante**, considerado o que prescrevem o art. 102, § 2.º, e o art. 103-A, *caput*, da Constituição da República, a significar, portanto, que aquele aresto, embora respeitabilíssimo, **não se impõe à compulsória observância dos juízes e Tribunais em geral**” (**HC 135.100**, j. 1.º.07.2016).

Na mesma linha da primeira decisão proferida pelo Min. Celso de Mello no precedente acima citado, manifestou-se o Min. Fachin, ao julgar reclamação, instituto definido por sua Excelência como de **natureza constitucional**, formulada contra decisão proferida no âmbito do STJ, que deferiu a liminar para o fim de obstar a execução provisória da pena privativa de liberdade decorrente de condenação criminal confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em suas palavras: “a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A

reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante” (**Rcl 23.535**, j. 11.05.2016).

Em igual sentido, afirmando não ser vinculante a decisão proferida no referido precedente que admitia a execução provisória de acórdão penal condenatório (HC 126.292), confira a parte final da decisão do Min. Dias Toffoli, proferida no **HC 135.041** (j. 28.06.2016).

Também no sentido de não vinculação, destacam-se as liminares concedidas monocraticamente pelo Min. Marco Aurélio nos HCs 138.086, 138.088 e 138.092 (e que foram **revogadas** no julgamento de mérito nas Turmas que fizeram prevalecer o entendimento da possibilidade de execução provisória de condenação penal confirmada em grau recursal) e a decisão do Min. Ricardo Lewandowski no HC 147.427 (j. 11.10.2017), afastando-se a tese da execução provisória da pena e que, tendo em vista a não interposição de recurso, transitou em julgado.

Conforme discutimos no *item 14.10.28.6*, apesar de existir, durante certo período, jurisprudência consolidada no sentido de se admitir a execução provisória (cf. liminar negada nas ADCs 43 e 44, ARE 964.246 e HC 152.752), mesmo havendo a definição da tese nos referidos julgados, **alguns Ministros não a aplicavam**.

No referido estudo, no *capítulo 14*, vamos deixar claro que, em 07.11.2019, observamos **nova** viragem jurisprudencial, passando o STF a não mais admitir a execução provisória da pena (ADCs 43, 44 e 54).

O ponto dessa nossa análise é criticar a não observância do precedente, pronunciando alguns Ministros da Corte em sentido contrário.

Apesar dessa inicial realidade de dificuldade de respeito aos precedentes (**mesmo entre os Ministros da Corte**), deve-se reconhecer que a sua **valorização**, nos exatos termos das regras introduzidas pelo CPC/2015, está cada vez mais evidente no STF, dentro de uma perspectiva de **objetivação do controle difuso**.

Nesse sentido, lembramos o art. 926, CPC/2015, ao estabelecer que os tribunais devem **uniformizar sua jurisprudência** e mantê-la **estável, íntegra** e **coerente**. Essas perspectivas, sem dúvida, influenciaram o acatamento da tese da mutação constitucional do art. 52, X, CF/88, que estudaremos em seguida.

Destacamos a **Recomendação n. 134/2022 do CNJ**, que estimula a valorização do precedente para a “promoção da segurança jurídica, da estabilidade e do ambiente de negócios no Brasil”. Nesse sentido, de acordo com o seu art. 8.º, **“os precedentes devem ser respeitados, a fim de concretizar o princípio da isonomia e da segurança jurídica, bem como de proporcionar a racionalização do exercício da magistratura”**.

■ **6.6.5.4. *Controle incidental em controle concentrado abstrato e o seu efeito “erga omnes” — eficácia da decisão do STF — ADI 4.029, j. 08.03.2012 — perspectivas para a mutação constitucional do art. 52, X, apesar de proferida incidentalmente em controle concentrado***

Como se sabe, no **controle difuso** a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo **incidental** e se caracteriza como **questão prejudicial incidental**. Ou seja, julga-se procedente ou improcedente o pedido formulado tendo em vista a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. A inconstitucionalidade, nesse caso, não é o pedido, mas a causa de pedir. Dessa forma, na sentença a ser proferida, o dispositivo contém a “resposta” (julgamento) ao pedido, e a análise da constitucionalidade dar-se-á na fundamentação.

Por outro lado, no **controle concentrado** a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo **principal** e é o próprio pedido formulado na ação (ADI) que se fundamenta em violação formal ou material à Constituição. Por exemplo, uma lei que cria cargo sem a observância do princípio do concurso público é inconstitucional por violar o art. 37, II, CF/88.

Agora, imaginemos que em determinada hipótese de controle concentrado e em abstrato, ao verificar os fundamentos para nulificar ou não uma lei, entenda o STF que outro ato normativo, que não fazia parte do pedido, é inconstitucional.

É como se estivéssemos diante do procedimento de cisão previsto para o controle difuso, no qual, diante de questão de ordem suscitada, paralisa-se o julgamento, cinde-se o processo e encaminha-se a análise da inconstitucionalidade para o Pleno do Tribunal (art. 97 — cláusula de reserva de plenário).

Avançando, vamos supor que essa questão de ordem a ser resolvida seja suscitada não no controle difuso, mas em determinada ADI (controle concentrado).

Estamos diante da problemática que surgiu no julgamento da **ADI 4.029**, que tinha por objeto a Lei n. 11.516/2007, fruto de conversão da MP n. 366/2007 e que dispôs sobre a criação do *Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)*, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Dentre os vários argumentos discutidos na referida ADI, estava a tese do **vício formal**, por violação ao **art. 62, § 9.º, CF/88**, que estabelece ser atribuição de **comissão mista** de Deputados e Senadores **examinar** as medidas provisórias e sobre elas **emitir parecer**, de caráter **opinativo**, acrescente-se, antes de serem **apreciadas**, em **sessão separada**, pelo **plenário** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

No caso concreto, referida MP foi convertida na lei objeto da ADI **sem** a apreciação pela comissão mista de Deputados e Senadores, havendo apenas a emissão de **parecer individual de seu relator**, nos termos do art. 6.º, § 2.º,⁹⁴ da Res. n. 1/2002-CN.

Segundo ficou estabelecido na ementa do acórdão, “as comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da **necessidade**, imposta pela Constituição, de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado

pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo Plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se, assim, que o **parecer** desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, uma **garantia de que o Legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo Executivo**. O art. 6.º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, é **inconstitucional**” (**ADI 4.029**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2012, Plenário, *DJE* de 27.06.2012).

Dessa forma, embora a lei objeto da ADI **tivesse** seguido o procedimento de tramitação das medidas provisórias previsto na **Res. n. 1/2002-CN**, entendeu o Tribunal que referido procedimento não se conforma ao art. 62, § 9.º, CF/88.

Decidiu então a Corte declarar **incidentalmente** a **inconstitucionalidade** dos **arts. 5.º, caput, e 6.º, caput, e §§ 1.º e 2.º, Res. n. 1/2002-CN**.

Por consequência, todas as medidas provisórias já convertidas em lei ou mesmo em tramitação que não tivessem observado o procedimento do art. 62, § 9.º (necessidade de apreciação pela comissão mista, não bastando manifestação unipessoal de relator), seriam inconstitucionais.

O interessante é que a **declaração incidental de inconstitucionalidade** (muito embora em controle concentrado e em ADI genérica) produziria efeitos *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, acarretando a inconstitucionalidade de centenas de medidas provisórias que não observaram o citado procedimento constitucional, apesar de não serem objeto na ação direta de inconstitucionalidade em julgamento.

É como se houvesse a ampliação de efeitos da decisão, a partir de **declaração incidental**, atingindo vários atos normativos que não eram objeto da ADI, em nítido privilégio da eficácia da decisão da Corte. Ou seja, o efeito *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante decorria da declaração incidental (e, repita-se, apenas para deixar bem claro, em **CONTROLE CONCENTRADO E EM ABSTRATO**, e não em controle difuso — apesar de estarmos tratando desse assunto em seção do livro que cuida sobre o controle difuso).

O que estamos procurando mostrar é essa **tendência** de **ampliação dos efeitos da decisão** e que, atualmente, passa a ser uma realidade. Seria como se a decisão que estabeleceu a imprescindível necessidade de análise pela comissão mista estivesse sendo veiculada em **súmula vinculante** e acarretando a nulificação de diversos atos normativos que não eram o objeto da ADI genérica.

Diante dessa consequência do resultado da declaração incidental, que repercutiria sobre os mais diversos setores da vida do País, decidiu o Tribunal, aplicando o art. 27 da Lei n. 9.868/99,⁹⁵ modular os efeitos da decisão, dando **eficácia ex nunc** em relação à **pronúncia de nulidade dos dispositivos da resolução do Congresso Nacional**, passando a exigir o respeito ao art. 62, § 9.º, somente a partir daquela decisão. Assim, todas as leis aprovadas de acordo com o procedimento da Res. n. 1/2002 que dispensaram a emissão de parecer pela comissão mista foram declaradas, por esse aspecto, **constitucionais**.

Podemos afirmar, dessa forma, que o modelo de apreciação da medida provisória fixado na resolução do Congresso Nacional foi declarado **“ainda constitucional”** até o julgamento da referida ADI 4.029, e, a partir de então, o STF declarou inconstitucional qualquer inobservância ao art. 62, § 9.º, CF/88, ficando, por consequência, **preservadas a validade e a eficácia** de todas as medidas provisórias convertidas em lei até aquela data, bem como daquelas que estavam tramitando no Legislativo nos termos do procedimento fixado nos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, Res. n. 1/2002-CN, que permitiam a continuidade do iter procedimental de apreciação da medida provisória mesmo na hipótese de não haver parecer emitido pela comissão mista no prazo rígido de 14 dias contados da sua publicação.

■ 6.6.5.5. *ADIs 3.406 e 3.470, j. 29.11.2017, DJE de 1.º.02.2019 — mutação constitucional do art. 52, X (7 x 2) . Entendimento reiterado no julgamento dos embargos de declaração (j. 23.02.2023, DJE de 02.05.2023)*

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 52, X?		
■ Gilmar Mendes ■ Celso de Mello ■ Dias Toffoli ■ Rosa Weber ■ Edson Fachin ■ Luiz Fux ■ Cármen Lúcia	■ Marco Aurélio ■ Alexandre de Moraes	■ Ricardo Lewandowski ■ Roberto Barroso
Entendimento	Entendimento	Entendimento
■ SIM ■ art. 52, X — reconhecimento de mutação constitucional ■ o Senado Federal daria simplesmente publicidade à decisão de inconstitucionalidade declarada de modo incidental pelo STF	■ NÃO ■ preservação da regra estabelecida no art. 52, X — não acolhimento da tese da mutação constitucional ■ a maneira de se dar efeito vinculante seria apenas nos termos da Constituição, qual seja, em processo abstrato e concentrado ou em razão de edição de súmula vinculante	■ NÃO SE MANIFESTARAM ■ Impedido o Min. Barroso e ausente o Min. Lewandowski
7 Ministros contra 2 entendem que houve mutação constitucional do art. 52, X		
ADIS 3.406 E 3.470, REL. MIN. ROSA WEBER, J. 29.11.2017, <i>DJE</i> DE 1.º.02.2019 (ENTENDIMENTO REITERADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, J. 23.02.2023, <i>DJE</i> DE 02.05.2023)		

As ações em análise enfrentaram a problemática do **amianto** e, para o conhecimento do tema, remetemos os nossos queridos leitores para o *item 7.11.1.*

Nesta parte do trabalho vamos apresentar a perspectiva de **mutação constitucional do art. 52, X**, estabelecida pelo STF na parte final do referido julgamento. Muito embora a pronúncia da nova interpretação tenha sido

dada em um processo de **controle concentrado**, essa passa a ser a nova tendência/realidade da Corte, apesar de tecermos críticas e sustentarmos tratar-se de proposta de **inadmitida mutação inconstitucional**, conforme apresentamos no *item 6.6.5.1*.

As ações em análise tinham por objeto lei estadual do Rio de Janeiro que proibiu a extração do asbesto/amianto em todo território daquela unidade da federação, estabelecendo, ainda, a progressiva substituição da produção e da comercialização de produtos que contivessem amianto.

Conforme explicamos no *item 7.11.1*, no fundo, a questão era saber se a lei estadual teria invadido o campo de competência da lei federal (normas gerais) e, assim, por se tratar de matéria de **competência concorrente**, se teria ou não infringido o disposto no art. 24, §§ 1.º ao 4.º.

Em julgamento anterior, o STF já havia declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade da lei federal que disciplina o amianto, em ação cujo objeto era uma lei do Estado de São Paulo (ADI 3.937, j. 24.08.2017).

Como a declaração de inconstitucionalidade se deu incidentalmente e não houve pronunciamento de nulidade com efeito *erga omnes*,⁹⁶ diferente, então, da discussão travada na ADI 4.029 (cf. *item 6.6.5.4*), nesse caso do Rio de Janeiro (ADIs 3.406 e 3.470 em análise), a Corte debruçou-se, novamente, sobre a problemática da lei federal e foi além, não só reafirmando a sua inconstitucionalidade como, também, dando **efeito erga omnes** e **vinculante** a essa decisão sobre a questão prejudicial (o item 8 da ementa do acórdão publicado em 1.º.02.2019 é explícito nesse sentido).

A declaração de inconstitucionalidade se deu incidentalmente em um processo de controle concentrado e abstrato que tinha como objeto principal a lei estadual do Rio de Janeiro. Para apreciar o pedido formulado na ADI, a Corte teve que analisar a constitucionalidade da lei federal, que, contudo, não era objeto da ação. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade se deu **incidentalmente**, como **questão prejudicial**, em **processo objetivo de controle abstrato**.

Essa pronúncia de nulidade com efeito *erga omnes* e vinculante da **questão prejudicial** gerou ampla discussão na Corte, e, ao final, por **7 x 2**, o STF entendeu ter havido mutação constitucional do art. 52, X, sustentando que o papel do Senado Federal seria apenas o de dar publicidade à decisão judicial.⁹⁷

Em razão da importância do tema, estamos trazendo dados do *Inf. 886/STF*, assim como transcrevendo ou descrevendo parte dos votos que podem ser analisados a partir da página do *Youtube* da TV Justiça, lembrando que o Min. Lewandowski esteve ausente e o Min. Barroso não participou do julgamento por estar impedido. Ou seja, tivemos **7 x 2** acatando a tese da **mutação constitucional** do **art. 52, X** (anotamos que, no julgamento dos embargos de declaração **(23.02.2023)**, o Min. Lewandowski aderiu à tese da mutação constitucional, afirmando superar o seu anterior entendimento contrário, firmado no julgamento da Rcl 4.335 (ver *item 6.6.5.2* deste estudo e fls. 73 e 74 do acórdão dos embargos). Vejamos:

■ **Min. Marco Aurélio:** não admite a tese da mutação constitucional do art. 52, X. Entende que, para afastar a atribuição que foi dada pelo constituinte originário ao Senado Federal, haveria a necessidade de emenda constitucional e não de simples atuação do STF, que, da maneira como agiu, **violou a independência e harmonia entre os poderes**. A atuação do Senado Federal caracteriza provimento constitutivo de suspensão da execução da lei em todo território nacional e não meramente declaratório.

Em suas palavras, transcritas de seu voto na sessão, ele manifesta **repúdio** ao entendimento da mutação constitucional: “tempos estranhos, aonde vamos parar. Somos 11 Presidente, a integrar o Supremo e temos, realmente, a última palavra sobre o direito positivo. Mas temos a última palavra sobre o direito positivo considerado o grande sistema revelado pela Carta da República. E aí, não posso ignorar o que se contém nessa mesma Carta da República; não posso desconsiderar que 81 são os Senadores e 513 os Deputados, eleitos representantes do povo brasileiro” (...). “Recuso-me,

Presidente, a dizer que o Senado da República é um verdadeiro diário oficial; que simplesmente deve publicar as decisões do Supremo formalizadas no controle concreto de inconstitucionalidade, formalizadas no âmbito do controle difuso de inconstitucionalidade” (...). “O art. 52, X, atende à independência e harmonia entre os poderes; que sinaliza que o sistema nacional é um sistema equilibrado, ao prever, e ao prever em bom vernáculo, que compete ao Senado não simplesmente publicar a decisão, mas **suspender a execução...**”

■ **Min. Alexandre de Moraes:** sustentou que a perspectiva de mutação constitucional do art. 52, X, não foi formalmente votada por não ter sido levantada como questão de ordem. Assim, a proposta de se atribuir o efeito *erga omnes* e vinculante se mostrava extremamente delicada. Ainda, não admitia a proposta de mutação, pois as hipóteses de efeito vinculante foram revistas pela EC n. 45, que introduziu a súmula vinculante e o instrumento da repercussão geral. Assim, não poderia o STF alterar o sentido do art. 52, X, pois, no caso, estaria legislando.

■ **Min. Gilmar Mendes:** há tempos sustenta a proposta de mutação constitucional do art. 52, X (cf. *item 6.6.5.1*). A sua proposta ganha força com o advento do CPC/2015, destacando-se os arts. 525, § 12, e 535, § 5.º, que aproximam o controle difuso do controle concentrado, evitando-se, assim, anomias e fragmentação da unidade. Dessa forma, a sua leitura seria a seguinte: a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação, intensificando a publicidade. O efeito *erga omnes* e vinculante decorre da própria decisão judicial.

■ **Min. Celso de Mello:** evoluindo o seu entendimento já apresentado neste nosso trabalho, “considerou se estar diante de verdadeira **mutação constitucional** que expande os poderes do STF em tema de jurisdição constitucional. Para ele, o que se propõe é uma interpretação que confira ao Senado Federal a possibilidade de simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão do STF. Mas **a eficácia vinculante**

resulta da decisão da Corte. Daí se estaria a reconhecer a **inconstitucionalidade da própria matéria**".

■ **Min. Dias Toffoli:** sustentou a eficácia geral plena, para todo território nacional, da decisão tomada incidentalmente, evitando que o STF tenha que aguardar eventual atuação discricionária do Senado Federal e seja forçado a agir burocraticamente, tendo que falar em inúmeros processos o que já decidiu.

É interessante observar, ao assistirmos à sessão do dia 29.11.2017, que, depois de um aparte ao final do Min. Marco Aurélio dizendo que, com aquela transmutação, passaria a ser possível, agora, o cabimento de Rcl constitucional, o Min. Dias Toffoli "temperou" o seu pensamento dizendo que se tratava de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado (ADI estadual), nulificando incidentalmente a lei federal. Contudo, ao que parece, o STF, por maioria de 7 x 2, não fez distinção entre processo objetivo e eventual processo subjetivo, sugerindo, de modo geral, a mutação constitucional do art. 52, X.

■ **Min. Rosa Weber:** admitiu a tese da mutação constitucional.

■ **Min. Edson Fachin:** sustentou que "a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma **preclusão consumativa** da matéria. Isso **evita que se caia numa dimensão semicircular progressiva e sem fim**".

■ **Min. Luiz Fux:** adotou a proposta de equivalência entre o controle difuso e o controle concentrado, sustentando, então, que o art. 52, X, CF/88 apenas permitiria a chancela formal do Senado Federal, que não poderia alterar a essência da declaração de inconstitucionalidade pelo STF.

■ **Min. Cármen Lúcia:** sustentou que a Corte, seguindo o modelo dos países de *common law*, está caminhando no sentido de não ter que declarar inconstitucionalidade de cada ato normativo, mas, no fundo, da própria matéria da discussão.

Diante do exposto, podemos afirmar que **o STF admitiu a mutação constitucional do art. 52, X**, prescrevendo, então, que o papel do **Senado Federal** é apenas para dar **publicidade à decisão**. O efeito *erga omnes* e vinculante decorreria da própria decisão judicial.

Esse entendimento foi fixado em controle concentrado de lei estadual, como questão prejudicial. Contudo, apesar das particularidades, entendemos que o STF evoluiu a questão e não terá mais volta.

Essa perspectiva se confirma no julgamento dos **embargos de declaração** nas ADIs 3.356, 3.357, 3.937, 3.406, 3.470 e na ADPF 109 (j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023), tendo, inclusive, conforme anunciamos, o Min. Lewandowski superado o seu entendimento anterior, firmado no julgamento da Rcl 4.335. Vejamos:

■ **Min. Ricardo Lewandowski:** “eu acho que as palavras agora ditas pelo Ministro Gilmar Mendes são muito sábias. Penso que o Supremo Tribunal Federal detém a **última palavra no que diz respeito à guarda da Constituição**, sobretudo quando se debruça de forma abrangente sobre uma questão. Portanto, tendo em conta este aspecto de que **o Supremo é o guardião último da Constituição** e considerando também o **princípio da supremacia das normas constitucionais**, eu penso que os nossos pronunciamentos devem, sim, ter **efeito vinculante**”. E avança ao destacar o entendimento do Min. Gilmar Mendes no sentido da mutação constitucional em razão da **alteração da legislação superveniente**, bem como do Min. Alexandre de Moraes ressaltando os impactos decorrentes do instituto da **repercussão geral**: “essa leitura do art. 52, X, foi contra a minha opinião à época, que entendia que era cláusula pétrea, que não podíamos invocar o instituto da mutação constitucional para, de certa forma, agredir o princípio da separação dos poderes, mas fui vencido. E ficou muito claro que, **quando o Supremo Tribunal Federal se pronuncia sobre uma questão de constitucionalidade, quer numa ação direta, quer no controle difuso, o papel do Senado é meramente o papel de dar publicidade à nossa**

decisão” (fls. 74 do acórdão, ADI 3.406 ED, j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023).

Teremos que aguardar agora a problemática do cabimento da reclamação constitucional, com algumas discussões no item seguinte.

Em nossa opinião, para que a declaração de inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo produza efeitos *erga omnes* e vinculante, independentemente de resolução do Senado Federal, partindo do pressuposto de que, de fato, houve mutação constitucional do art. 52, X, entendemos que o STF deve observar 3 pontos fundamentais:

- formalmente deliberar sobre a questão, destacando-a como questão prejudicial;
- alcançar o *quorum* de no mínimo 6 Ministros (art. 97, CF/88) no sentido da inconstitucionalidade;
- fazer integrar a questão resolvida na ementa do acórdão, deliberando sobre os efeitos e podendo, se acharem conveniente, inclusive, modular os efeitos da decisão, observando, naturalmente, o *quorum* de 2/3, previsto no art. 27 da Lei n. 9.868/99.

Se eventualmente o STF não pronunciar o efeito *erga omnes* e vinculante, por algum motivo, pensamos que o Senado Federal continuará com a sua missão prevista no art. 52, X. Mas isso, naturalmente, é um pensamento e teremos que acompanhar como a Corte irá enfrentar essa nova realidade (pendente).

■ 6.6.5.6. ***Eficácia expansiva das decisões. Objetivação (“dessubjetivação”) do recurso extraordinário. Limites à reclamação constitucional. Inconstitucionalidades no CPC/2015?***

Em relação ao tema exposto (eficácia expansiva das decisões e objetivação ou “dessubjetivação” do recurso extraordinário), gostaríamos de destacar alguns exemplos dessa perspectiva para, ao final, concluir, reforçando o item anterior, que, para o uso específico da **reclamação constitucional**, devemos adotar uma **postura mais restritiva**, sob pena de tornar o STF uma Corte de revisão, um órgão recursal, tendo em vista a criação de um inadmissível (porque **inconstitucional**) atalho processual. Vejamos os exemplos a demonstrar a inegável e muito bem-vinda **valorização dos precedentes**:

CPC/73	REGRA CPC/73	CPC/2015	REGRA/CORRESPONDÊNCIA/ NOVIDADE CPC/2015
■ art. 120, parágrafo único	■ possibilidade de o relator decidir de plano o conflito de competência havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada	■ art. 955	■ deixa claro que a jurisprudência dominante é do STF, STJ ou do próprio Tribunal ■ aumenta o poder decisório do relator quando a tese tiver sido firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
■ art. 285-A	■ improcedência de plano — julgamento de mérito sem a citação do réu se já houver demandas idênticas no juízo	■ art. 332	■ houve ampliação dos poderes do juiz de primeira instância, permitindo o julgamento de mérito não somente em razão de decisões do juízo, mas também nas hipóteses de: I — enunciado de súmula do STF ou do STJ; II — acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; III — entendimento firmado

			em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência; IV — enunciado de súmula de TJ sobre direito local.
■ art. 475, § 3.º	■ inexistência de reexame necessário quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente	■ art. 496, §§ 3.º e 4.º	■ dispensa da remessa necessária de acordo com os valores da condenação (novidade) ■ mantém a ideia de dispensa em razão de decisões do STF e do STJ e inova em relação a entendimento firmado em IRDR ou em assunção de competência ■ inova, também, de maneira muito interessante, ao dispensar o reexame quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
■ art. 475-L, § 1.º	■ impugnação à fase executiva no cumprimento de sentença para declarar a inexigibilidade do título quando houver declaração de inconstitucionalidade da lei que funda o título	■ art. 525, §§ 12 a 15	■ mantém a ideia com as observações e críticas que fizemos no <i>item 6.7.1.17.4.3</i> deste estudo
■ art. 741, parágrafo único	■ impugnação na execução contra a Fazenda Pública para declarar a inexigibilidade do título quando	■ art. 535, §§ 5.º a 8.º	■ mantém a ideia com as observações e críticas que fizemos no <i>item 6.7.1.17.4.3</i> deste estudo

	houver declaração de inconstitucionalidade da lei que funda o título		
■ art. 479	■ recomendação para a uniformização da jurisprudência	■ art. 926	■ os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la <i>estável, íntegra e coerente</i>
■ art. 481, § 1.º	■ dispensa da cláusula de reserva de plenário no controle difuso	■ art. 949, parágrafo único	■ regra prevista de modo idêntico
■ art. 518, § 1.º	■ espécie de súmula impeditiva de recurso, caracterizada como um pressuposto de admissibilidade negativo do recurso, já que o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do STF	■ art. 1.011, I, c/c art. 932, IV	■ a admissibilidade negativa é transferida para o Relator no Tribunal, e não mais para o juízo <i>a quo</i> que proferiu a sentença, podendo decidir monocraticamente (no Novo Código, não há mais juízo de admissibilidade pelo juiz que proferiu a sentença — art. 1.010, § 3.º) ■ na linha das novidades do CPC/2015, o Relator poderá negar provimento ao recurso que for contrário a: súmula do STF ou do STJ; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetidos; incidente firmado em IRDR ou assunção de competência
■ arts. 543-A, 543-B e 543-C	■ análise da repercussão geral no recurso extraordinário. Julgamento por amostragem — processos-modelos tanto no recurso extraordinário como no especial	■ arts. 1.035 e 1.036 e segs.	■ a regra da repercussão geral foi mantida e mais bem disciplinada a técnica do julgamento de recursos extraordinário e especial <i>repetidos</i>
■ arts. 544, § 4.º,	■ atribuição dada ao relator	■ art. 932, IV e	■ poderes dados ao relator

I e II, e 557, <i>caput</i> e § 1.º-A	do agravo em recurso especial ou extraordinário para, monocraticamente, com base em jurisprudência do STJ ou do STF, conhecer do agravo e provê-lo ou negar-lhe seguimento. Essa previsão está explícita, também, para os recursos em geral (art. 557)	V	para negar provimento a recurso ou dar provimento em razão de súmula do STF ou do STJ, acórdão em julgamento de recursos repetidos, entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência
■ art. 555, § 1.º	■ ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso	■ art. 947	■ o novo Código criou um capítulo próprio para o que chamou de incidente de assunção de competência — IAC ■ o art. 947, § 3.º, prevê que o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários , exceto se houver revisão de tese, fazendo a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância do referido precedente (art. 988, IV)
■ não há correspondência	■ não há correspondência	■ art. 927, III, IV e V	■ Os juízes e os tribunais observarão: III — os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV — os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V — a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados

A) Exposição da matéria

Analizados os dispositivos normativos acima listados, não temos dúvidas em reconhecer, tanto no revogado CPC/73 como no de 2015, o **inegável processo de expansividade das decisões proferidas em casos concretos**, bem como a **força dada à jurisprudência dos tribunais**.

Todos os exemplos indicam uma inegável tendência de **valorização dos precedentes**, na linha do que o CPC/2015 denominou **jurisprudência dos tribunais estável, íntegra e coerente** (art. 926, *caput*).

Aliás, devemos destacar que o texto original do Senado Federal estabelecia apenas uma valorização da **estabilidade** da jurisprudência. A previsão da **integridade** e da **coerência** se verificou em razão de sugestão feita por Lenio Streck à comissão de especialistas na Câmara dos Deputados (por todos, Fredie Didier), bem como ao Relator, Deputado Paulo Teixeira, e que veio a ser acatada pelo Senado Federal, na votação final do substitutivo.

Devemos, então, analisar a amplitude dessa dita **“emenda streckiana-dworkiniana”** ao projeto de lei (assim chamada por Streck),⁹⁸ especialmente no sentido de se verificar a amplitude da vinculação da jurisprudência dos tribunais em relação aos juízes do Brasil e a potencialização supostamente dada para o cabimento da **reclamação constitucional**.

Em primeiro lugar, temos que aplaudir essa importante potencialização dada à jurisprudência no CPC/2015, ao prever um sentido bastante técnico desses **vetores principiológicos** a partir de uma concepção de **dignidade da pessoa humana**, considerando os princípios da **segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia** (art. 927, § 4.º, CPC/2015).

Para Streck, “a estabilidade é diferente da integridade e da coerência do Direito, pois a **‘estabilidade’ é um conceito autorreferente, isto é, numa relação direta com os julgados anteriores**. Já a **integridade** e a **coerência** guardam um substrato ético-político em sua concretização, isto é, são dotadas de consciência histórica e consideram a facticidade do caso”.⁹⁹ Nesse sentido, o autor define com precisão os necessários “atributos” das decisões judiciais:

coerência: “... em casos semelhantes, deve-se proporcionar a garantia de **isonômica aplicação principiológica**. Haverá coerência se os mesmos princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos. A coerência assegura a **igualdade**, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte dos juízes. Isso somente pode ser alcançado através de um **holismo interpretativo**, constituído a partir do **círculo hermenêutico**”;¹⁰⁰

■ **integridade:** segundo o autor, valendo-se das lições de Dworkin (*O império do direito*, Quartier Latin, 2008, p. 213), é duplamente composta: **a) princípio legislativo**, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente; **b) princípio jurisdicional**, que demanda que a lei, tanto quanto o possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito. Trata-se de uma garantia contra arbitrariedades interpretativas. A integridade limita a ação dos juízes; mais do que isso, coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é uma forma de virtude política. A integridade significa rechaçar a tentação da arbitrariedade”.¹⁰¹ E, no citado texto de 18.12.2014, Streck chegou a afirmar ser a integridade **antitética ao voluntarismo, ao ativismo e à discricionariedade**.

Pois bem, definido esse **novo sentido da jurisprudência**, resta analisar a amplitude da vinculação dos juízes e tribunais e, no caso, o cabimento ou não desse inegável direito fundamental (verdadeiro direito de petição — art. 5.º, XXXIV, “a”), denominado **reclamação constitucional**.

Pelos dispositivos normativos citados no quadro acima, o CPC/2015 seguiu a tendência que já se verificava em relação às últimas minirreformas do Código Buzaidiano de 1973, aumentando o poder decisório dos relatores e a “vinculação” sugestiva decorrente de posicionamentos já sumulados e pacificados nos tribunais superiores.

O CPC/2015, contudo, **avançou e supervalorizou o cabimento da reclamação** e, assim, o **efeito vinculante das decisões**. A sua modificação pela **Lei n. 13.256/2016**, apesar de minimizar essa vinculação, continuou prevendo situações que, em nosso entender, afrontam a Constituição.

Destacamos, então, as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional nos termos do art. 988, CPC/2015, para:

- preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “I”, CF/88, e art. 988, I e II, CPC/2015);
- garantir a observância da **tese jurídica** fixada em enunciado de **súmula vinculante** e em decisão do Supremo Tribunal Federal em **controle concentrado de constitucionalidade** (art. 988, III e § 4.º, CPC/2015);
- garantir a observância da **tese jurídica** firmada em acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas — **IRDR** ou de incidente de assunção de competência — **IAC** (art. 988, IV e § 4.º, CPC/2015);
- garantir a observância da **tese jurídica** extraída de acórdão de recurso extraordinário **com repercussão geral reconhecida** ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial **repetitivos, quando esgotadas as instâncias ordinárias** (art. 988, § 5.º, II).

Na nova redação conferida ao art. 988, III, pela Lei n. 13.256/2016, o legislador foi bem sensato ao prescrever, em um mesmo inciso, as situações de verdadeiro efeito vinculante previstas na Constituição para o cabimento da reclamação constitucional, quais sejam, **enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado**.

No inciso IV do art. 988 houve a indicação de situações que se aproximam e foram criadas pelo CPC/2015, quais sejam, o cabimento de reclamação constitucional para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (**IRDR** — nesse sentido, cf. também art. 985, § 1.º) ou de incidente de assunção de

competência **(IAC)**. Mesmo com as particularidades desses institutos, entendemos que a fixação de efeito vinculante sem a previsão na Constituição (que só estabelece em razão de edição de SV ou decorrente de decisão proferida em controle concentrado) apresenta-se com duvidosa constitucionalidade.

A última hipótese de cabimento da reclamação constitucional foi estabelecida para garantir a **observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida** ou **de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos**, desde que **esgotadas as instâncias ordinárias** (art. 988, § 5.º, CPC, introduzido pela Lei n. 13.256/2016).

O fato de criar uma condição, qual seja, **o esgotamento das instâncias ordinárias**, em nosso entender, não afasta a inconstitucionalidade do dispositivo, apesar da posição restritiva do STF para a admissão de reclamação constitucional.

Sobre esse tema específico, a interpretação da expressão **“instâncias ordinárias”** foi estabelecida no precedente firmado pelo **Min. Teori Zavascki** da 2.ª Turma do STF, em 2017: “em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5.º, II, do CPC/2015 deve ser **fundamentalmente teleológica**, e não estritamente literal. O **esgotamento da instância ordinária**, em tais casos, significa o percurso de todo o *iter* recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, **se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação**” (**Rcl 24.686 ED-AgR**, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 25.10.2016, 2.ª T., *DJE* de 11.04.2017).

Esse entendimento tem sido seguido pela 2.ª Turma (**Rcl 52.605 AgR**, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2022, *DJE* de 06.06.2022) e, também, pela 1.ª Turma do STF, que aderiu ao referido precedente em 2018 (cf. **Rcl 32.277**, j. 07.12.2018, e reafirmação na **Rcl 45.909 AgR**, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.06.2021, *DJE* de 21.06.2021), havendo, inclusive, orientação

do **Pleno** no mesmo sentido (**Rcl 47.262 AgR**, j. 15.09.2021, *DJE* de 24.09.2021).

Como disse o Min. Fachin, “não há como entender percorrido o *iter* recursal a hipótese em que a reclamação constitucional é ajuizada logo após o julgamento da apelação pelo Tribunal de origem” (Rcl 52.605 AgR).

Esse percurso de **todo o iter processual**, disse o Min. Barroso, **exige a interposição de agravo interno** “contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2.º, do CPC/2015. Ou seja, é **imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta**” (Rcl 45.909 AgR).

Para o preenchimento da regra, deve haver, também, a necessária interposição **simultânea** dos recursos especial e extraordinário **na origem** quando for o caso, bem como a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do STJ, quando cabível, ou mesmo em face da decisão de outros tribunais (**Rcl 59.345 AgR**, j. 22.08.2023, j. 25.08.2023).

Reforçando essa orientação restritiva decorrente da “natureza eminentemente excepcional” do instituto da reclamação (Rcl 41.511 AgR, Rel. Min. Fux, Pleno), afirmou o Min. Lewandowski em julgado do Pleno do STF: “a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmita o recurso extraordinário” (**Rcl 47.262 AgR**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 15.09.2021, *DJE* de 24.09.2021).

De todo modo, em sendo aceita a **vinculação** da **tese jurídica** firmada em referidos procedimentos novos (IRDR e IAC) e no caso do art. 988, § 5.º, II, CPC/2015, entendemos que a vinculação, nesses casos específicos, **restringir-se-á ao âmbito do Poder Judiciário**, não atingindo a administração pública, sob pena de se violar o princípio da separação de poderes (a Constituição estabelece o efeito vinculante em relação à

Administração Pública apenas nos casos de controle concentrado — art. 102, § 2.º, CF/88 — e de súmula vinculante — art. 103-A, CF/88).

B) Nossa opinião

Apresentadas as perspectivas de constitucionalidade das novas hipóteses de reclamação trazidas pela **lei** (não previstas expressamente na Constituição), temos de trazer a nossa opinião.

Em nosso entender, essas regras de vinculação e o consequente cabimento da reclamação constitucional não poderiam ter sido introduzidos por legislação infraconstitucional, porque dependeriam, necessariamente, de **emenda constitucional** a prever outras hipóteses de decisões com efeito vinculante, além daquelas já previstas na Constituição.

Como se sabe, na CF/88, o **efeito vinculante** (no caso, premissa para se falar nessa hipótese de cabimento da reclamação constitucional) somente se observa em razão das decisões em **controle concentrado de constitucionalidade** (art. 102, § 2.º)¹⁰² ou em **razão de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante** (art. 103-A),¹⁰³ regra essa, aliás, na linha do que sustentamos, introduzida pela **EC n. 45/2004**.

Não podemos confundir **efeitos processuais** dos instrumentos elencados acima com ampliação das **hipóteses de cabimento da reclamação constitucional** (art. 102, I, “I”) para a garantia da autoridade das decisões dos tribunais.

Até podemos admitir, aplicando-se os instrumentos de **coerência e integridade**, o que, de modo muito interessante, Streck denominou “**vinculação orgânica-material**”¹⁰⁴ dos julgadores.

Entretanto, essa dita “vinculação”, no controle da decisão judicial, **não poderá ensejar o cabimento da reclamação constitucional**. Trata-se de norma de caráter programático, e não de imposição. Busca-se criar uma **cultura de observância dos precedentes**, mas não a hipótese de reclamação constitucional que não encontra fundamento na Constituição.

Como se disse, sem dúvida, ferramentas processuais serão importantes para abreviar a entrega da prestação jurisdicional (aliás, como sabemos, a **razoável duração do processo** é direito fundamental — art. 5.º, LXXIII, CF/88). Exemplificando, é perfeitamente admissível a introdução por lei de julgamento monocrático pelo relator no tribunal em observância à jurisprudência dominante do STF ou do STJ, ou a restrição das hipóteses de remessa necessária.

Contudo, isso não pode significar o cabimento da reclamação constitucional. Assim, entendemos **inconstitucional** essa pretensão trazida no CPC/2015.

Estamos nos referindo aos **arts. 988, IV e § 5.º, II; 985, § 1.º; 947, § 3.º**, e, também, ao **art. 927, III, IV e V** (CPC/2015), ao se estabelecer que os juízes e tribunais observarão:

- os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
- os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
- a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Dizer que “devem” observar significa vincular. Não poderia ser outra a interpretação, pois, do contrário, não faria sentido explicitar o dever de “observar” ao lado de outros incisos que, por sua essência, já trazem, ínsita, a vinculação, como são os incisos I (**decisões do STF em controle concentrado**) e II (**enunciados de súmula vinculante**), em relação aos quais inquestionável o cabimento da reclamação constitucional.

Não estamos a condenar os efeitos processuais, aliás, **muito bem-vindos** e uma realidade já no CPC/73 em razão de suas minirreformas, como já dissemos. Estamos, por outro lado, unicamente **a não reconhecer o efeito vinculante para o cabimento da reclamação constitucional**.

Esse alerta em relação aos incisos IV e V do art. 927 tem encontrado apoio na maioria da doutrina, já que **não previstos nas hipóteses do art. 988** que tratam do instituto específico da reclamação.

C) O que responder nas provas de concurso público? O CPC deverá ser observado!

CUIDADO: sobre o tema específico deste capítulo, a nossa perspectiva de distinção entre o controle difuso e o controle concentrado perde força a partir do voto do Min. Teori no julgamento da **ADI 2.418**, acompanhado pela maioria do STF, com exceção do Min. Marco Aurélio (nesse ponto específico, 10 x 1 — j. 04.05.2016, *DJE* de 17.11.2016).

No caso, a Corte analisava a constitucionalidade do art. 525, § 1.º, III e § 12, CPC/2015 (cf. *item 6.7.1.17.4.3*), que admite a interposição de embargos rescisórios se, na execução, o título estiver fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, seja em controle **difuso** ou **concentrado**!

Em seu voto, seguido pela maioria, afirma o Min. Teori que a **distinção entre controle difuso ou concentrado é irrelevante**, independentemente da edição de resolução pelo Senado Federal. E enfatiza: “A distinção restritiva, entre precedentes em controle incidental e em controle concentrado, não é compatível com a evidente intenção do legislador, já referida, de valorizar a autoridade dos precedentes emanados do órgão judiciário guardião da Constituição, que não pode ser hierarquizada simplesmente em função do procedimento em que a decisão foi tomada. Sob esse enfoque, **há idêntica força de autoridade nas decisões do STF tanto em ação direta quanto nas proferidas em via recursal**, estas também com natural vocação expansiva, conforme reconheceu o STF no julgamento da Reclamação 4.335, Min. Gilmar Mendes, *DJE* 22.10.14, a evidenciar que está ganhando autoridade a recomendação da doutrina clássica de que a eficácia *erga omnes* das decisões que reconhecem a inconstitucionalidade, **ainda que incidentalmente**, deveria ser considerada ‘efeito natural da sentença’ (BITTENCOURT, Lúcio, op. cit., p. 143; CASTRO NUNES, José. *Teoria e prática do Poder Judiciário*. Rio de Janeiro: Forense, 1943. p. 592)” (fls. 32 e 33 do acórdão).

Dado o objetivo deste nosso estudo, para as provas de concurso público, enquanto não afastadas pelo STF, essas novas hipóteses de reclamação constitucional previstas na lei devem ser observadas e admitidas, lembrando, claro, a **interpretação restritiva** dada pela 2.^a Turma do STF no julgamento da **Rcl 24.686 ED-AgR**, acima comentada, ao tratar do art. 988, § 5.º, II, CPC/2015, introduzida pela Lei n. 13.256/2016, que orientou o entendimento no sentido da **excepcionalidade do instituto da reclamação**, conforme, inclusive, declarado pelo **Pleno** do STF (**Rcl 41.511 AgR**, j. 18.12.2021).

■ **6.6.5.7. REs 955.227 e 949.297 (j. 08.02.2023): a consagração do efeito “erga omnes” e vinculante nas decisões proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral — mutação constitucional do art. 52, X, CF/88**

Toda essa nova perspectiva que estudamos foi retomada no julgamento dos **REs 955.227 e 949.297**.

No caso concreto, o Min. Barroso, Relator, **explicitou a mutação constitucional do art. 52, X**, em relação ao controle difuso, a partir do advento do instituto da **repercussão geral**, introduzido pela EC n. 45/2004 e regulamentado pela Lei n. 11.418/2006 como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, **consolidando o processo de abstrativização do controle difuso**, “resultando em uma maior integridade à teoria de precedentes, bem como no aprimoramento do controle de constitucionalidade brasileiro” (fls. 24 do acórdão).

Veja que o art. 1.035, § 1.º, CPC/2015 (na linha do que dizia o art. 543-A do revogado CPC/73, introduzido pela Lei n. 11.418/2006), prescreve que, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que **ultrapassem os interesses subjetivos do processo**”, devendo haver uma explicitação formal da **súmula da decisão** sobre a repercussão geral (art. 1.035, § 11, CPC/2015).

Nas palavras do Min. Barroso, “assim, aproveito para afirmar ser necessário que esta Corte reconheça que a **declaração de inconstitucionalidade**, em sede de **recurso extraordinário com repercussão geral**, possui os **mesmos efeitos vinculantes e eficácia erga omnes** atribuídos às **ações de controle abstrato**. Nesses casos, a resolução do Senado, a que faz menção o art. 52, X, da CF/1988, possuirá a finalidade de **publicizar** as decisões de inconstitucionalidade, não configurando requisito para a atribuição de efeitos vinculantes *erga omnes*” (fls. 21 do acórdão).

■ 6.6.6. Controle difuso em sede de ação civil pública

Como vimos, o **controle difuso** de constitucionalidade é realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário, sendo a declaração de inconstitucionalidade proferida de **modo incidental**, produzindo, em regra, efeitos somente para as partes (salvo a hipótese de resolução do Senado Federal — art. 52, X, ou, a nova perspectiva de mutação constitucional do referido dispositivo, se o STF resolver a inconstitucionalidade como questão prejudicial e expressamente assim deliberar, devendo ser observado o *quorum* de no mínimo 6 Ministros — cf. item 6.6.5.5).

Portanto, só será cabível o controle difuso, em sede de ação civil pública “... como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a *controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal*” (Min. Celso de Mello, Rcl 1.733-SP, DJ de 1.º.12.2000 — Inf. 212/STF. Nesse sentido de não se confundir a alegação de inconstitucionalidade com o pedido principal e admitindo a sua apreciação como questão incidental, cf. RE 595.213 AgR e RE 1.293.322 AgR, j. 24.02.2021).

Por conseguinte, a jurisprudência do STF “... exclui a possibilidade do exercício da ação civil pública, quando, nela, o autor deduzir pretensão efetivamente destinada a viabilizar o controle abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo (RDA 206/267, Rel. Min. Carlos Velloso — Ag. 189.601-GO (AgRg), Rel. Min. Moreira Alves). Se, contudo, o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover, *incidenter tantum*, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do Poder Público. Incensurável, sob tal perspectiva, a lição de Hugo Nigro Mazzilli (‘O Inquérito Civil’, p. 134, item n. 7, 2. ed., 2000, Saraiva): ‘Entretanto, nada impede que, por meio de ação civil pública da Lei n. 7.347/85, se faça, não o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade das leis, mas, sim, seu controle difuso ou incidental. (...) assim como ocorre nas ações populares e mandados de segurança, nada impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações individuais ou coletivas (não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas), como causa de pedir (não o próprio pedido) dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas’” (Min. Celso de Mello, Rcl 1.733-SP, DJ de 1.º.12.2000 — Inf. 212/STF).

Mas atente à regra geral mais uma vez: **a ação civil pública não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, pois, em caso de produção de efeitos *erga omnes*, estaria provocando verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, usurpando competência do STF** (cf. STF, Rcl 633-6/SP, Min. Francisco Rezek, DJ de 23.09.1996, p. 34945).

No entanto, sendo os efeitos da declaração reduzidos somente às partes (sem amplitude *erga omnes*), ou seja, tratando-se de “... ação ajuizada, entre partes contratantes, na persecução de bem jurídico concreto, individual e perfeitamente definido, de ordem patrimonial, objetivo que jamais poderia ser alcançado pelo reclamado em sede de controle *in abstracto* de ato normativo” (STF, Rcl 602-6/SP), aí sim seria possível o controle difuso em sede de ação

civil pública, verificando-se a declaração de inconstitucionalidade de modo incidental e restringindo-se os efeitos *inter partes*. O pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental terá, enfatize-se, de constituir verdadeira causa de pedir (cf. RE 424.993, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12.09.2007, DJ de 19.10.2007).

Como exemplo, de maneira precisa, Alexandre de Moraes cita determinada ação civil pública ajuizada pelo MP, em defesa do patrimônio público, para anulação de licitação baseada em lei municipal incompatível com o art. 37, CF, declarando o juiz ou tribunal, no caso concreto, a inconstitucionalidade da referida lei, reduzidos os seus efeitos somente às partes.¹⁰⁵

Quando a questão chegar ao STF, confirmada a perspectiva de **mutação constitucional do art. 52, X**, proposta pelo STF no julgamento das **ADIs 3.406 e 3.470** (cf. *item 6.6.5.5*) e se a Corte assim se pronunciar, além dos efeitos normais da ação civil pública, poderá ser reconhecido, também, o efeito *erga omnes* e vinculante da declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo STF como questão prejudicial. Mas, conforme já alertamos, entendemos que o STF tem que formalmente deliberar sobre a questão, alcançar o *quorum* de no mínimo 6 Ministros (art. 97, CF/88) e fazer integrar essa decisão na ementa do acórdão.

Essa proposta ganha relevância a partir da **declaração de inconstitucionalidade** da regra trazida pela **Lei n. 9.494/97** ao **art. 16 da Lei da Ação Civil Pública**, que, **limitando a eficácia subjetiva da coisa julgada**, estabeleceu que a sentença civil fará coisa julgada *erga omnes* **nos limites da competência territorial do órgão prolator**.

Conforme explicamos em nossa dissertação de mestrado, essa “primeira tentativa de restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator vai totalmente em **sentido contrário** a toda evolução de proteção dos interesses transindividuais em juízo (ondas renovatórias) e da molecularização dos conflitos (...). O objetivo das ações coletivas (...) foi trazer maior celeridade ao processo, evitando o conflito de decisões e sua multiplicação, fenômenos responsáveis pelo

asoberbamento do Judiciário. Outra grande valia do processo coletivo reside na capacidade de assegurar o acesso à Justiça de interesses transindividuais, muitos deles marginalizados quando individualmente considerados”. Assim, no referido trabalho, sustentamos a inconstitucionalidade e insubsistência da regra trazida pela Lei n. 9.494/97.¹⁰⁶

O STF, na linha do que já havia decidido o STJ (**EREsp 1.134.957/SP**, Corte Especial, j. 24.10.2016), declarou inconstitucional a referida limitação, em julgamento que consideramos um dos mais importantes na história da Suprema Corte e para o futuro da tutela coletiva, tendo sido fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“I — É **inconstitucional** a redação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterada pela Lei n. 9.494/97, sendo repristinada sua redação original.

II — Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

III — Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas” (**RE 1.101.937**, Pleno, j. 08.04.2021, *DJE* de 14.06.2021).

■ 6.7. CONTROLE CONCENTRADO

O controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo recebe tal denominação pelo fato de “concentrar-se” em um único tribunal. Pode ser verificado em cinco situações:

AÇÃO	FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL	REGULAMENTAÇÃO
■ ADI — Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica	■ art. 102, I, “a”	■ Lei n. 9.868/99
■ ADC — Ação Declaratória de Constitucionalidade	■ art. 102, I, “a”	■ Lei n. 9.868/99
■ ADPF — Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental	■ art. 102, § 1.º	■ Lei n. 9.882/99
■ ADO — Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	■ art. 103, § 2.º	■ Lei n. 12.063/2009
■ IF ¹⁰⁷ — Representação Interventiva (ADI Interventiva)	■ art. 36, III, c/c art. 34, VII	■ Lei n. 12.562/2011

■ 6.7.1. ADI genérica

■ 6.7.1.1. Conceito (ADI genérica)

O que se busca com a **ADI genérica** é o controle de constitucionalidade de lei ou de ato normativo, sendo esse controle realizado em **tese, em abstrato**, marcado pela **generalidade, impessoalidade e abstração**.

Ao contrário da via de **exceção ou defesa**, pela qual o controle (difuso) se verificava em casos concretos e incidentalmente ao objeto principal da lide, no **controle concentrado** a **representação de inconstitucionalidade**, em virtude de ser em relação a um ato normativo em tese, tem por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. O que se busca saber, portanto, é se a lei (*lato sensu*) é inconstitucional ou não, manifestando-se o Judiciário de forma específica sobre o aludido objeto. A ação direta, portanto, nos dizeres de Ada Pellegrini Grinover, “tem por objeto **a própria questão da inconstitucionalidade, decidida principaliter**”.¹⁰⁸

Em regra, através do controle concentrado, almeja-se expurgar do sistema lei ou ato normativo viciado (material ou formalmente, assim como a nossa proposta de “vício de decoro parlamentar”), buscando, por conseguinte, a sua **invalidação**.

■ 6.7.1.2. **Objeto (ADI genérica)**

O objeto da ADI genérica será a **lei** ou o **ato normativo** que se mostrarem incompatíveis com o parâmetro ou paradigma de confronto.

Assim, não se admite o controle de constitucionalidade jurisdicional preventivo e abstrato (ADI) de meras proposições normativas, já que estas não ensejam inovação formal na ordem jurídica. O próprio art. 102, I, “a”, CF/88, conforme apontado, estabelece como objeto da ADI *lei ou ato normativo* e não *projeto de lei* ou *projeto de ato normativo*.

Conforme afirmou o Min. Celso de Mello, “atos normativos ‘in fieri’, ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam e nem dão margem ao **controle concentrado ou em tese de constitucionalidade**, que supõe — ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante — a existência de **espécies normativas**

definitivas, perfeitas e acabadas” (ADI 466, j. 03.04.1991, Pleno, DJ de 10.05.1991). Nesse sentido, cf. ADI 7.081, Pleno, j. 24.10.2022.

Isso definido, lançamos a seguinte questão: e a lei ou o ato normativo em *vacatio legis*, pode ser objeto de controle concentrado via ADI? Ou seja, a lei ou o ato normativo existe, foi publicado, mas ainda não está em vigor. Poderia haver controle concentrado abstrato via ADI?

Entendemos que **sim**, já que a lei ou o ato normativo existe e, por isso, encontra-se formalmente incorporado ao sistema de direito positivo, podendo, então, ser objeto de controle sem a necessidade de se sustentar o cabimento preventivo da ação direta.

E acrescentamos mais um ponto para sustentar o nosso entendimento: se a lei em *vacatio legis* pode ser revogada (cf. HC 72.435), poderá, também, ser objeto de ADI, buscando, inclusive, evitar a insegurança jurídica durante o período de preparação para a sua efetiva aplicação, aliás, um dos sentidos da *vacatio legis*.

Nesses termos, Gilmar Mendes admite o controle da lei ou do ato normativo **após a conclusão definitiva do processo legislativo**, mesmo que ainda não esteja em vigor,¹⁰⁹ conforme sustentado por Celso de Mello no interessante *leading case* acima citado, que definiu o objeto da ADI como sendo leis ou atos normativos já **promulgados, editados e publicados**, não exigindo, ao menos a partir da leitura do acórdão, a sua vigência (ADI 466).

Em outro precedente, em ADI que objetivava nulificar a *PEC da Reforma da Previdência* (PEC 287/2016), a Min. Rosa Weber, monocraticamente, negou seguimento à referida ação por entender inexistir eficácia jurídica em relação à proposição de alteração da Constituição. E afirmou: “a existência formal da lei ou do ato normativo — ou, no caso, da emenda à Constituição — na ordem jurídica, **o que se dá após a conclusão do processo legislativo**, traduz pressuposto de constituição válida e regular da relação processual de índole objetiva inaugurada pela ação direta de constitucionalidade” (ADI 5.669, j. 15.03.2017).

Em sua decisão, contudo, a Ministra prescreve que a ADI é vocacionada para assegurar a “higidez constitucional da ordem jurídica vigente”, sendo que “o interesse na tutela judicial, por essa via objetiva, pressupõe, em consequência, ato normativo **em vigor**”, a fim de caracterizar “efetivo e atual descumprimento da Constituição”.

Com o máximo respeito, entendemos ser possível a ADI mesmo em *vacatio legis*, conforme acima exposto, já que estaremos diante de lei ou ato normativo — requisitos constitucionais (art. 102, I, “a”), apesar de ainda não vigente. Não se discute, na ação de controle abstrato, direito subjetivo, mas, como se sabe, a lei em tese, em processo marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração (destacando, contudo, ainda não haver uma decisão recente do Pleno do STF enfrentando esse assunto — pendente).

Finalmente, lembramos ser possível o controle judicial preventivo de constitucionalidade (durante a tramitação) na hipótese de mandado de segurança a ser impetrado exclusivamente por Parlamentar, nos termos da discussão e dos limites já estudados no *item 6.4.1.3*.

■ 6.7.1.2.1. *Leis*

Entendam-se por **leis** todas as espécies normativas do art. 59, CF/88, quais sejam: *emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções*.¹¹⁰

■ 6.7.1.2.2. *Atos normativos*

Conforme anotou o Min. Celso de Mello, “a noção de **ato normativo**, para efeito de controle concentrado de constitucionalidade, **pressupõe**, além da **autonomia jurídica** da deliberação estatal, a constatação de seu coeficiente de **generalidade abstrata**, bem assim de sua **impessoalidade**. Todos esses elementos — **autonomia jurídica, abstração, generalidade e impessoalidade** — qualificam-se como **requisitos essenciais** que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo,

como norma revestida de **eficácia subordinante** de comportamentos estatais ou de condutas individuais” (ADI 2.321 MC, j. 25.10.2000, fls. 76 do acórdão).

Nesse sentido, segundo Alexandre de Moraes,¹¹¹ atos normativos podem ser: a) **resoluções administrativas dos tribunais**; b) **atos estatais de conteúdo meramente derogatório**, como as resoluções administrativas, desde que incidam sobre atos de caráter normativo.

O autor, valendo-se das palavras de Castanheira A. Neves, observa que poderá ser objeto de controle qualquer “ato revestido de **indiscutível caráter normativo**”,¹¹² motivo pelo qual incluímos aí os **regimentos internos dos tribunais**.

Alexandre de Moraes, em sede jurisdicional, estabelece: “quando a circunstância evidenciar que o ato encerra um **dever-ser** e **veicula**, em seu **conteúdo**, enquanto manifestação subordinante de vontade, uma **prescrição destinada a ser cumprida pelos órgãos destinatários** (KELSEN, Hans. *Teoria geral das normas*. Porto Alegre: Fabris, 1986. p. 2-6), deverá ser **considerado**, para efeito de controle de constitucionalidade, como **ato normativo** (ADI 1352-1-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, *DJ*, 04.10.1995), não impedindo, portanto, o controle abstrato de constitucionalidade dos **decretos autônomos** (por exemplo: CF, art. 84, incisos VI e XII) ou, ainda, de **demais atos normativos que possam ter invadido matéria reservada à lei** (ADI 1.553/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão: 13.05.2004. *Informativo STF* n. 348; ADI 1.969-4/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, *DJ* de 05.03.2004)” (**ADI 5.543**, j. 11.05.2020, fls. 121 do acórdão).

Podem, também, ser objeto de controle de constitucionalidade:

■ as **deliberações administrativas dos órgãos judiciários** (precedente: STF, ADI 728, Rel. Min. Marco Aurélio). Nesse sentido:

■ “EMENTA: Resolução administrativa do TRT da 3.^a Região. **Natureza normativa da resolução.** Atribuição do Congresso Nacional para ato normativo que aumenta vencimentos de servidor. Inconstitucionalidade da resolução configurada. Precedentes do STF” (**ADI 1.614**, Rel. p/ ac. Min. Nelson Jobim, j. 18.12.98, Plenário, *DJ* de 06.08.99). “É cabível o controle concentrado de resoluções de tribunais que deferem reajuste de vencimentos. Precedentes” (**ADI 2.104**, Rel. Min. Eros Grau, j. 21.11.2007, Plenário, *DJE* de 22.02.2008).

■ as **deliberações dos Tribunais Regionais do Trabalho judiciários** que determinam o pagamento a magistrados e servidores das diferenças de plano econômico (precedente: STF, **ADI 681/DF**, Rel. Min. Néri da Silveira, reconhecendo o seu caráter normativo), **salvo** as convenções coletivas de trabalho;¹¹³

■ **resolução do Conselho Interministerial de Preços — CIP** (STF, Pleno, **ADI 8-0/DF**, Rel. Min. Carlos Velloso), que concedeu aumento de preço aos produtos farmacêuticos, permitindo, portanto, a verificação de sua compatibilidade com a Constituição Federal.

Outros exemplos reconhecidos como atos normativos a ensejar o cabimento de ADI foram o art. 64, IV, da *Portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde* e o art. 25, XXX, “d”, da *Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)*, que **restringem a doação de sangue por homossexuais**. A Corte reconheceu que referidas disposições constituem atos normativos federais que se revestem de **conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade e impessoalidade**, possuindo **alta densidade normativa** e **não se caracterizando como simples atos regulamentares**.

No mérito, a ação foi julgada procedente, declarando a **inconstitucionalidade** dos referidos atos normativos, por caracterizar **discriminação** em razão da orientação sexual, havendo afronta à **dignidade da pessoa humana, autonomia privada, autonomia pública e igualdade**: “o estabelecimento de grupos — e não de condutas — de risco incorre em

discriminação e viola a dignidade humana e o direito à igualdade, pois lança mão de uma interpretação consequencialista desmedida que concebe especialmente que homens homossexuais ou bissexuais são, apenas em razão da orientação sexual que vivenciam, possíveis vetores de transmissão de variadas enfermidades. Orientação sexual não contamina ninguém, condutas de risco sim” (item 2 da ementa, **ADI 5.543**, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.05.2020, *DJE* de 26.08.2020).

■ 6.7.1.2.3. *Súmulas?*

De acordo com a ADI 594-DF, só podem ser objeto de controle perante o **STF leis e atos normativos federais** ou **estaduais**. **Súmula** de jurisprudência não possui o grau de normatividade qualificada, não podendo, portanto, ser questionada perante o STF através do controle concentrado.

E a súmula vinculante pode ser objeto de ADI?

Como se sabe, a **EC n. 45/2004** fixou a possibilidade de o **STF** (e exclusivamente o STF), de ofício ou por provocação, mediante decisão de **2/3** dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar **súmula** que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá **efeito vinculante** em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 103-A).

O seu § 2.º, por seu turno, fixa a possibilidade de, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, proceder-se a **aprovação, revisão** ou **cancelamento** de súmula, mediante provocação daqueles que podem propor a **ação direta de inconstitucionalidade**.

Assim, tendo em vista o fato de a **súmula** não ser marcada pela generalidade e abstração, diferentemente do que acontece com as leis, não se pode aceitar a técnica do “controle de constitucionalidade” de súmula, mesmo no caso da súmula vinculante.

O que existe é um **procedimento de revisão** pelo qual se poderá **cancelar** a súmula. O cancelamento desta significará a não mais aplicação do entendimento que vigorava. Nesse caso, naturalmente, a nova posição produzirá as suas consequências a partir do novo entendimento, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Cabe alertar que o procedimento de **aprovação, revisão** ou **cancelamento** de súmula vinculante foi disciplinado pela **Lei n. 11.417/2006**.

Todavia, em algumas decisões, a Min. Ellen Gracie entendeu que o mecanismo para se rever a súmula vinculante seria a própria ADI (com o que não concordamos, pelos motivos acima expostos). Tratava-se de hipótese na qual se discutia a impetração de *habeas corpus* tendo em vista a edição da **SV 11**¹¹⁴ sobre o uso de algemas (HC 96.301, 06.10.2008, Min. Ellen Gracie).

Em **05.12.2008**, o Presidente do STF, no uso de suas atribuições, editou a **Res. n. 388**, disciplinando o processamento de proposta de edição, revisão e cancelamento de súmulas, vinculantes ou não. Posteriormente, de modo específico, a **Emenda Regimental n. 46/2011** acresceu os arts. 354-A a 354-G ao *RISTF*, regulamentando o procedimento. Trata-se, sem dúvida, de instituto que difere da ADI (cf. *item 11.14.11.5*).

■ 6.7.1.2.4. *Emendas constitucionais?*

Como dissemos, as **emendas constitucionais** podem ser objeto de controle, embora introduzam no ordenamento normas de caráter constitucional. O que temos com o processo de emendas é a manifestação do **poder constituinte derivado reformador**, e, como vimos ao estudar a teoria do poder constituinte, a derivação dá-se em relação ao poder constituinte originário. Este último é ilimitado juridicamente e autônomo. O derivado reformador, por seu turno, deve observar os limites impostos e estabelecidos pelo originário, como decorre da observância às regras do art. 60, CF/88. Assim, desobedecendo aos referidos limites, inevitável declarar

inconstitucional a emenda que introduziu uma alteração no texto constitucional.¹¹⁵

Conforme alertamos, o **poder constituinte derivado revisor** (art. 3.º, ADCT), assim como o **reformador** (art. 60, CF/88) e o **decorrente** (art. 25, CF/88 — Constituições estaduais), é fruto do trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele **vinculado**. É, ainda, um “poder” **condicionado** e **limitado** às regras instituídas pelo originário, sendo, assim, um **poder jurídico**.

Dessa maneira, as **emendas de revisão** também poderão ser “controladas”, tanto em seu aspecto formal (procedimento previsto no art. 3.º, ADCT) como no material (cláusulas pétreas — art. 60, § 4.º, I a IV) (cf. *item* 4.5.4).

■ 6.7.1.2.5. *Medidas provisórias?*

Somente o ato estatal de conteúdo normativo, em plena vigência, pode ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade. Como a medida provisória tem **força de lei**, poderá ser objeto de controle, já que ato estatal, em plena vigência.

No entanto, sendo ela **convertida em lei**, ou tendo **perdido a sua eficácia por decurso de prazo**, nos termos do art. 62, § 3.º, CF/88 (confira as profundas alterações trazidas pela **EC n. 32/2001** em relação à tramitação das medidas provisórias e por nós comentadas no *item* 9.14.4), considerar-se-á **prejudicada a ADI** (que questionava a constitucionalidade da MP) pela perda do objeto da ação. O autor da ADI, na primeira hipótese, deverá aditar o seu pedido à nova lei de conversão.

Essa regra da prejudicialidade no caso da **lei de conversão**, contudo, não se verifica na hipótese de inexistência de alteração substancial da norma, pois haverá **continuidade normativa** (cf. *item* 6.7.1.2.11). A jurisprudência do STF também afasta a prejudicialidade quando houver alegação de **inconstitucionalidade formal** por violação aos requisitos de relevância e urgência na MP, já que o vício alegado não se convalidará com a conversão

da MP em lei (cf. questão de ordem na MP na [ADI 3.090](#), j. 11.10.2006, resgatada no voto do Min. Edson Fachin no julgamento da [ADI 5.599](#), j. 23.10.2020.)

Então, os requisitos constitucionais de relevância e urgência (art. 62) podem ser objeto de controle jurisdicional?

SIM, mas **excepcionalmente**. O STF decidiu serem passíveis de controle desde que o exame seja feito *cum grano salis*, ou seja, com muita **parcimônia**, devendo ser demonstrada “a inexistência cabal desses requisitos” ([RE 592.377](#)). Assim, “conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgência’ (art. 62 da CF), apenas em **caráter excepcional** se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2.º da CF) (ADI n. 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 23.04.2004; ADI n. 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 26.03.1999; ADI n. 1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 12.06.1998; ADI n. 162-MC, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 19.09.1997)” (ADC 11-MC, voto do Min. Cezar Peluso, j. 28.03.2007, *DJ* de 29.06.2007). Nesse sentido, [ADI 4.029](#), j. 08.03.2012.

E como deve ser a forma de se realizar esse controle?

Conforme estabeleceu a Corte, “a forma de se realizar esse controle deve depender da **motivação** apresentada pelo chefe do Poder Executivo. ‘A motivação, embora não seja requisito constitucional expreso, facilita o controle da legitimidade e dos requisitos constitucionais autorizadores, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário’. Existindo motivação, ainda que a parte não concorde com os motivos explicitados pelo Presidente da República para justificar a urgência da medida provisória, não se pode dizer que eles não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente. Ressalte-se que, na hipótese, não se está a proceder juízo de mérito quanto aos argumentos utilizados para justificar a urgência na edição da medida provisória, mas tão somente verificar a legitimidade de tais argumentos, para assim realizar ou

não a intervenção judicial almejada pela parte” (**ADI 5.599**, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Sessão Virtual de 16.10.2020 a 23.10.2020).

E os requisitos constitucionais de imprevisibilidade e urgência (art. 62 c/c o art. 167, § 3.º) da MP que abre crédito extraordinário¹¹⁶ podem ser objeto de controle jurisdicional?

Dada a magnitude do julgamento, pedimos vênia para transcrever a ementa que resume a nova posição do STF, **revendo**, inclusive, a jurisprudência que não admitia o controle para os denominados atos de efeito concreto (cf. *item 6.7.1.2.10*):

“EMENTA: Limites constitucionais à **atividade legislativa excepcional** do Poder Executivo na edição de **medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário**. Interpretação do art. 167, § 3.º c/c o art. 62, § 1.º, inciso I, alínea d, da Constituição. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 62), a Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita apenas para atender a **despesas imprevisíveis e urgentes**. Ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de **imprevisibilidade e urgência** (art. 167, § 3.º) recebem **densificação normativa da Constituição**. Os conteúdos semânticos das expressões ‘guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ constituem **vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3.º c/c o art. 62, § 1.º, inciso I, alínea d, da Constituição**. ‘Guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ são conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de consequências imprevisíveis para “a ordem pública e a paz social, e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas singulares e extraordinárias...” (**ADI 4.048-MC**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.05.2008, *DJE* de 22.08.2008). No mesmo sentido: **ADI 4.049-MC**, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.11.2008.

Essa nova posição mostra-se bastante relevante, freando o desvirtuamento dado pelo Executivo às medidas provisórias e, assim, “chamando” o Legislativo para que exerça, de maneira muito mais democrática, a análise da questão orçamentária. Ou seja, a abertura de crédito tem de ser vista com muito critério.

■ 6.7.1.2.6. *Regulamentos subordinados ou de execução e decretos? Inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua*

Os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Executivo (art. 84, IV, CF) e demais atos normativos secundários poderiam ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade?

Como regra geral, **não!** Tais atos não estão revestidos de autonomia jurídica a fim de qualificar-se como atos normativos suscetíveis de controle,¹¹⁷ não devendo, assim, sequer ser conhecida a ação. Trata-se de **questão de legalidade**, e referidos atos, portanto, serão **ilegais** e não inconstitucionais.

Estamos diante daquilo que o STF chamou de **crise de legalidade**, caracterizada pela inobservância do dever jurídico de **subordinação normativa à lei**, escapando das balizas previstas na Constituição Federal (STF, Pleno, ADI 264/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *RTJ* 152/352; STF, ADI 1.253-3, medida liminar, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* 1, de 25.08.1995, p. 26022).

Nessas hipóteses, o objeto **não** seria ato normativo primário, com fundamento de validade diretamente na Constituição, mas ato secundário, com base na lei, não se admitindo, portanto, controle de inconstitucionalidade **indireta, reflexa** ou **oblíqua** (cf. ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.03.1994, Plenário, *DJ* de 06.05.1994. No mesmo sentido: ADI 3.805-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.04.2009; ADI 2.999, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.03.2008; ADI 365-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.11.1990).

O STF, **excepcionalmente**, tem admitido o controle de constitucionalidade na hipótese de **decretos autônomos** que não se prestam a regulamentar a lei, mas a inovar do ponto de vista normativo.

Em interessante precedente, estabelece a Suprema Corte: “Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos, expressões da função normativa, cujas espécies compreendem a função regulamentar (do Executivo), a função regimental (do Judiciário) e a função legislativa (do Legislativo). Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não detém o monopólio da função normativa, mas apenas de uma parcela dela, a função legislativa” (ADI 2.950-AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, j. 06.10.2004, *DJ* de 09.02.2007). Confira, entre outros julgados:

■ “EMENTA: Impugnação de resolução do Poder Executivo estadual. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos análogos. **Ato normativo autônomo**. Conteúdo de lei ordinária em sentido material. Admissibilidade do pedido de controle abstrato. Precedentes. Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade o ato normativo subalterno cujo conteúdo seja de lei ordinária em sentido material e, como tal, goze de autonomia nomológica” (ADI 3.731-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.08.2007, *DJ* de 11.10.2007).

■ “EMENTA: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. **Impugnação de decreto autônomo**, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. **Introdução de novidade normativa**. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se **autônomo** e, como tal, é **suscetível de controle concentrado de constitucionalidade...**” (ADI 3.664, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1.º.06.2011, *DJE* de 20.09.2011).

■ 6.7.1.2.7. *Tratados internacionais*

Estudaremos no *item* 9.14.5.2 (“Breves notas sobre o processo de formação dos tratados internacionais e a novidade trazida pela EC n. 45/2004”) que o processo de incorporação no ordenamento jurídico interno dos **tratados internacionais** passa por quatro fases distintas, a saber: **a) celebração do tratado internacional** (negociação, conclusão e assinatura) pelo **Órgão do Poder Executivo** (ou posterior adesão [terceira etapa], art. 84, VIII — Presidente da República); **b) aprovação** (**referendo** ou “**ratificação**” *lato sensu*), pelo Parlamento, do tratado, acordo ou ato internacional, por intermédio de **decreto legislativo**, resolvendo-o definitivamente (Congresso Nacional, art. 49, I); **c) troca** ou **depósito** dos instrumentos de **ratificação** (ou **adesão**, caso não tenha tido prévia celebração) pelo **Órgão do Poder Executivo** em âmbito internacional; **d) promulgação** por **decreto presidencial**, seguida da **publicação** do texto em português no *diário oficial*. Nesse momento o **tratado, acordo ou ato internacional adquire executoriedade no plano do direito positivo interno**, guardando estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias**.

Apesar de nossa opinião pessoal diferente,¹¹⁸ a maior parte da doutrina e pacificamente os tribunais (salvo alguns juízes do extinto 1.º TACSP), inclusive, de forma majoritária, o STF, **entendiam** (sem qualquer distinção) que os tratados internacionais de qualquer natureza, mesmo sobre direitos humanos (esse entendimento vai ser superado), ingressam no ordenamento interno com o caráter de **norma infraconstitucional**, guardando estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias** editadas pelo Estado brasileiro (*RTJ* 83/809 e *Inf.* 73/STF — *DJ* de 30.05.1997), podendo, por conseguinte, ser revogados (*ab-rogação* ou *derrogação*) por norma posterior e ser questionada a sua constitucionalidade perante os tribunais, de forma concentrada ou difusa.¹¹⁹

A **Reforma do Judiciário** (EC n. 45/2004) acrescentou um § 3.º ao art. 5.º, nos seguintes termos: “os tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** que forem aprovados, **em cada Casa do Congresso**

Nacional, em **dois turnos**, por **três quintos dos votos dos respectivos membros**, serão equivalentes às **emendas constitucionais**”.

A novidade trazida pela Reforma (e esse tema é ampliado no *item 9.14.5.2.2*, remetendo o leitor para a sua análise) consiste em diferenciar os *tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos* dos *tratados e convenções internacionais de outra natureza*. Aqueles (sobre direitos humanos), desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 2 turnos de votação (cf. art. 60, § 2.º), passam a ter **a mesma natureza jurídica das emendas constitucionais**. Isso significa que, inexistindo afronta aos “limites do poder de reforma”, o tratado internacional sobre direitos humanos, desde que observado o *quorum* diferenciado de aprovação pelo Congresso Nacional (igual ao das ECs), passa a ter **paridade normativa** com as **normas constitucionais**.

Remetemos o leitor para o *item 9.14.5.2.3*, no qual discutimos a tese de **supralegalidade** dos tratados sobre direitos humanos defendida, inicialmente, pelo Min. Gilmar Mendes (RE 466.343, *Inf. 449/STF*), sustentando serem mais que a lei, porém estando abaixo da Constituição.

Então, esquematizando, podemos afirmar:

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 2 turnos de votação (cf. art. 60, § 2.º, e art. 5.º, § 3.º):** equivalem a *emendas constitucionais* e, como visto, podem ser objeto de controle de constitucionalidade;

■ **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pela regra anterior à Reforma:** malgrado posicionamento pessoal deste autor já exposto, de acordo com a jurisprudência do STF, guardam estrita relação de **paridade normativa** com as **leis ordinárias** e, portanto, podem ser objeto de controle de constitucionalidade;

■ **tese da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos (Gilmar Mendes):** embora tenham o condão de “paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa

infraconstitucional com ela conflitante” (voto no RE 466.343), podem sofrer controle de constitucionalidade, já que devem respeito ao princípio da supremacia da Constituição;

■ **tratados e convenções internacionais de outra natureza:** podem ser objeto de controle e têm força de lei ordinária.

O STF, por 5 x 4, em **03.12.2008**, no julgamento do **RE 466.343**, decidiu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se não incorporados na forma do art. 5.º, § 3.º (quando teriam natureza de norma constitucional), têm natureza de normas **supralegais**, paralisando, assim, a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional em sentido contrário.¹²⁰

Dessa forma, como diversos documentos internacionais de que o Brasil é signatário não mais admitem a prisão do depositário infiel (por exemplo, o art. 7.º, § 7.º, do *Pacto de São José da Costa Rica*, o art. 11 do *Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos*, a *Declaração Americana dos Direitos da Pessoa Humana*), a única modalidade de prisão civil a prevalecer na realidade brasileira é a do devedor de alimentos.

Com o máximo respeito, acompanhamos a divergência na linha do bem fundamentado voto do Min. Celso de Mello (natureza constitucional em razão da matéria, ampliando o conceito de “bloco de constitucionalidade” — cf. *item 6.7.1.3*).

Ademais, não conseguimos sustentar a manutenção de um documento que o STF declara acima da lei, mas abaixo da Constituição, contrariando o texto expresso que ainda persiste, no caso, o art. 5.º, LXVII.

Finalmente, entendemos prevalecer a afirmação exarada por Araujo e Nunes Júnior em relação à regra anterior, qual seja, a de que “o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto legislativo que ratifica um tratado internacional não torna o ajuste internacional nulo, mas apenas exclui o Brasil de seu cumprimento, sujeitando-o, no entanto, a sanções internacionais decorrentes do descumprimento”.¹²¹

De qualquer maneira, apesar dessas considerações doutrinárias, o STF, na prática, não vem aceitando mais a prisão civil do depositário infiel, entendimento este, agora, materializado na **SV 25/2009** (DJE de 23.12.2009): “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

■ 6.7.1.2.8. *Normas constitucionais originárias*

Já observamos, ao tratar do poder constituinte, que as normas constitucionais fruto do trabalho do poder constituinte originário serão sempre constitucionais, não se podendo falar em controle de sua constitucionalidade. Os aparentes conflitos devem ser harmonizados por meio da atividade interpretativa, de forma sistêmica.

Quanto ao trabalho dos poderes derivados, como visto, pode ser declarado inconstitucional, uma vez que referidos poderes são condicionados aos limites e parâmetros impostos pelo originário.

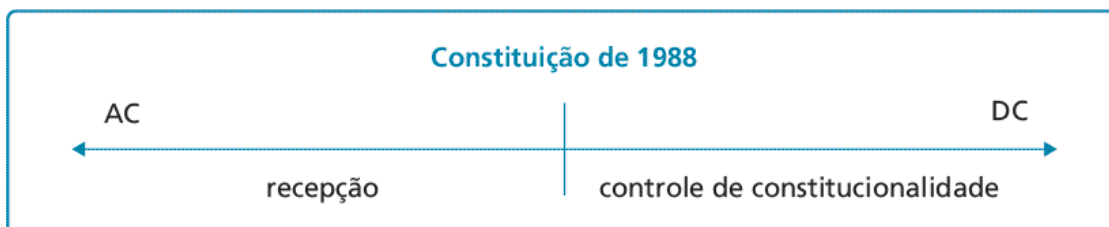
Nesse sentido, a jurisprudência do STF: “Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Inadmissibilidade. Art. 14, § 4.º, da CF. Norma constitucional originária. Objeto nomológico insuscetível de controle de constitucionalidade. **Princípio da unidade hierárquico-normativa e caráter rígido** da Constituição brasileira. Doutrina. Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida. Indeferimento da petição inicial. Agravo improvido. **Não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário**” (ADI 4.097-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08.10.2008, DJE de 07.11.2008).

Apesar dessa **posição firme do STF** (a ser adotada em fases preambulares), em eventual discussão em banca de concurso¹²² é interessante que o ilustre candidato proponha uma releitura desse entendimento, especialmente diante dos **grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral e da razão**, afastando-se a perspectiva rígida de uma

“onipotência do poder constituinte” e na linha de consagração do princípio da proibição do retrocesso em relação aos direitos fundamentais.¹²³

■ 6.7.1.2.9. *O fenômeno da recepção*

Conforme já estudamos, todo ato normativo anterior à Constituição (“AC”) não pode ser objeto de controle de constitucionalidade perante a nova Constituição. O que se verifica é se foi ou não **recepção** pelo novo ordenamento jurídico. Quando for compatível (do ponto de vista material), será recebido, recepcionado. Quando não, não será recepcionado e, portanto, será **revogado** pela nova ordem, **não se podendo falar em inconstitucionalidade superveniente**.¹²⁴ Assim, somente os atos editados depois da Constituição (“DC”) é que poderão ser questionados perante o STF, através do controle de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade), tendo em vista a regra da contemporaneidade. Vejamos o esquema:



Para maior entendimento do tema, confrontar o que expusemos (*item* 6.7.3) sobre o fenômeno da recepção com a **arguição de descumprimento de preceito fundamental — ADPF**, estabelecida no art. 102, § 1.º, CF/88, regulamentada pela Lei n. 9.882/99, que permitiu o controle de atos normativos anteriores à Constituição (AC).

Resta saber se o STF entende ser possível a **modulação dos efeitos** da decisão em sede de declaração de não recepção da lei pré-constitucional pela norma constitucional superveniente, aplicando-se, por analogia, o art. 27 da Lei n. 9.868/99.

Em um primeiro momento, o STF não admitiu a modulação dos efeitos da decisão de recepção de lei ou ato normativo editado antes da nova Constituição (cf. RE-AgR 353.508, j. 15.07.2007). **Contudo**, em divergência, o Min. Gilmar Mendes consignou a sua posição como sendo perfeitamente possível. Nesse caso, cf. AI 582.280 AgR, voto do Min. Celso de Mello, j. 12.09.2006, *DJ* de 06.11.2006).

O entendimento firmado pelo Min. Gilmar Mendes fazia total sentido, até porque a Corte havia admitido a teoria da **lei ainda constitucional** no caso da ação civil *ex delicto* (cf. *item* 6.7.1.6.1.2).

Em momento seguinte, devemos registrar, superando o entendimento anterior, a Corte reconheceu, expressamente, a possibilidade de **modulação dos efeitos de não recepção** de ato normativo editado antes de 1988 (**RE 600.885**, j. 09.02.2011 — cf. *item* 13.6.8).

Outro ponto interessante é analisar a possibilidade de aplicação da técnica do **arrastamento** (cf. *item* 6.7.1.5) no bojo de julgamento de recepção de determinado ato normativo. Ou seja, havendo pedido de declaração de não recepção de um dispositivo, será que a Corte poderia declarar revogado outro que, apesar de não impugnado, guarda relação de interdependência e interconexão com aquele objeto de análise específica?

Entendemos que sim se no controle concentrado em ADPF. Há um exemplo interessante na jurisprudência do STF que declarou não recepcionado o § 4.º do art. 23 da Lei n. 1.079/50 (*impeachment*), pelo fato de ter a Corte reconhecido como não recepcionados os §§ 1.º e 5.º do referido artigo, expressamente impugnados e que guardavam relação “consequencial” (a definição do papel da Câmara dos Deputados no processo de *impeachment* do Presidente da República — §§ 1.º e 5.º — tornou sem sentido o § 4.º, revogado por arrastamento) (cf. **ADPF 378 MC**, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2015, Plenário, *DJE* de 08.03.2016, item IV.9 da ementa, e proposta apresentada pelo Min. Celso de Mello — fls. 398-399 do acórdão).

■ **6.7.1.2.10. Atos estatais de efeitos concretos e atos estatais de efeitos concretos editados sob a forma de lei (exclusivamente**

formal)

De modo geral, o STF afirma que, em razão da inexistência de densidade jurídico-material (densidade normativa), os **atos estatais de efeitos concretos** não estão sujeitos ao controle abstrato de constitucionalidade (STF, *RTJ* 154/432), na medida em que a ação direta de inconstitucionalidade não constitui sucedâneo da ação popular constitucional.

Assim, **em um momento inicial**, o STF passou a decidir no sentido de não se conhecer “... de ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos de efeitos concretos”. No caso, tratava-se da Lei n. 11.744/2002, do Estado do Rio Grande do Sul, que declarava como bens integrantes do patrimônio cultural e histórico estadual o prédio e a destinação do Quartel General da Brigada Militar em Porto Alegre (ADI 2.686-RS, Rel. Min. Celso de Mello, 03.10.2002, *Inf.* 284/STF).

A Corte mantinha o entendimento de que “... só constitui ato normativo idôneo a submeter-se ao controle abstrato da ação direta aquele dotado de um coeficiente mínimo de **abstração** ou, pelo menos, de **generalidade**. Precedentes (v.g. ADI 767, Rezek, de 26.08.92, *RTJ* 146/483; ADI 842, Celso, *DJ* 14.05.93)” (ADI 1.937-MC/QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.06.2007, *DJ* de 31.08.2007).

CUIDADO: o STF, contudo, **modificou** o seu posicionamento. Trata-se de votação bastante apertada e em sede de **medida cautelar** (e por isso temos de acompanhar mais essa evolução da jurisprudência) que distingue o **ato de efeito concreto editado pelo Poder Público sob a forma de lei** do **ato de efeito concreto não editado sob a forma de lei**.

Portanto, mesmo que de efeito concreto, se o ato do Poder Público for materializado por **lei** (ou medida provisória, no caso a que **abre créditos extraordinários**, cf. *item* 9.14.4.8), poderá ser objeto do controle abstrato.

O STF, **modificando o seu entendimento**, destacou que “essas leis formais decorreriam ou da vontade do legislador ou do próprio constituinte, que exigiria que certos atos, **mesmo que de efeito concreto**, fossem **editados sob a forma de lei**. Assim, se a Constituição submeteu a lei ao processo de controle abstrato, meio próprio de inovação na ordem jurídica e instrumento

adequado de concretização da ordem constitucional, **não seria admissível que o intérprete debilitasse essa garantia constitucional**, isentando um grande número de atos aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de normas e, talvez, de qualquer forma de controle. Aduziu-se, ademais, **não haver razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas**, e que estudos e análises no plano da teoria do direito apontariam a possibilidade tanto de se formular uma lei de efeito concreto de forma genérica e abstrata quanto de se apresentar como lei de efeito concreto regulação abrangente de um complexo mais ou menos amplo de situações. Concluiu-se que, em razão disso, o Supremo não teria andado bem ao reputar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle abstrato de normas” (**ADI 4.048-MC/DF**, Rel. Min. Gilmar Mendes, 17.04.2008).

Tendo em vista que a decisão foi tomada em **medida cautelar**, repetimos, resta aguardar como se dará a evolução da jurisprudência do STF. O **PGR**, em seu parecer encaminhado à **ADI 4.047**, cujo objeto foi a MP n. 409/2007, que abriu crédito extraordinário de R\$ 750 milhões em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, sustentava a impossibilidade de o STF analisar ato de efeito concreto, requerendo, em razão de a votação ter sido bastante apertada (**ADIs 4.048 e 4.049**, vide também *Inf. 527/STF*), a **revisão da matéria**, retomando o entendimento anterior que não admitia ADI tendo por objeto ato de efeito concreto (cf. *Notícias STF*, 06.01.2009) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Nos outros julgamentos já realizados, também não houve a apreciação da questão no mérito — as decisões foram no julgamento das cautelares (**ADI 4.048 e ADI 4.049**), tendo havido entendimento no sentido da **prejudicialidade** das ações por **perda superveniente do objeto**, uma vez que, nos termos do art. 167, § 2.º, os créditos extraordinários abertos ou já tinham sido utilizados ou perderam a sua vigência (o STF entende que “o exaurimento da eficácia de normas eminentemente temporárias, impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade, enseja a sua prejudicialidade, independentemente de terem ou não produzido efeitos concretos” — ADI

4.047). De todo modo, podemos afirmar essa tendência de mudança da orientação da Corte de acordo com os julgamentos proferidos nas cautelares.

■ 6.7.1.2.11. *Ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida*

O STF **não** admite a interposição de ADI para atacar lei ou ato normativo revogado ou de eficácia exaurida, na medida em que “não deve considerar, para efeito do contraste que lhe é inerente, a existência de paradigma revestido de valor meramente histórico”.¹²⁵

Em razão de não caber a ADI e nem mesmo a ADC (pelos motivos expostos e em razão da ambivalência dessas ações), tendo em vista o princípio da subsidiariedade (art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 — cf. *item* 6.7.3.6), a Corte tem admitido o cabimento da **ADPF** contra ato normativo revogado ou com a sua eficácia exaurida (**ADPF 77-MC**, Rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, j. 19.11.2014, Plenário, *DJE* de 11.02.2015).

■ 6.7.1.2.12. *Lei revogada ou que tenha perdido a sua vigência após a propositura da ADI — regra geral da prejudicialidade. O caso particular da fraude processual. Novas perspectivas: singularidades do caso (não prejudicialidade)*

Nessa hipótese, estando em curso a ação e sobrevindo a revogação (total ou parcial) da lei ou ato normativo, assim como a perda de sua vigência (o que acontece com a medida provisória), ocorrerá, por regra, a **prejudicialidade** da ação, por “perda do objeto”.¹²⁶

Isso porque, segundo entendimento do STF, a declaração em tese de lei ou ato normativo não mais existente transformaria a ADI em instrumento de proteção de **situações jurídicas pessoais e concretas** (STF, Pleno, ADI 737/DF, Rel. Min. Moreira Alves). Esses questionamentos deverão ser alegados na via ordinária e em ações que discutam o caso concreto.

Nesse sentido, “a superveniente revogação — total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) — do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado” (**ADI 2.010-QO/DF**, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).¹²⁷

O **Min. Gilmar Mendes**, relator, no julgamento de questão de ordem na ADI 1.244, **propôs a revisitação da jurisprudência do STF**: “(...) para o fim de admitir o prosseguimento do controle abstrato nas hipóteses em que a norma atacada tenha perdido a vigência após o ajuizamento da ação, seja pela revogação, seja em razão do seu caráter temporário, restringindo o alcance dessa revisão às ações diretas pendentes de julgamento e às que vierem a ser ajuizadas. O Min. Gilmar Mendes, considerando que a remessa de controvérsia constitucional já instaurada perante o STF para as vias ordinárias é incompatível com os **princípios da máxima efetividade** e da **força normativa da Constituição**, salientou não estar demonstrada nenhuma razão de base constitucional a evidenciar que somente no âmbito do controle difuso seria possível a aferição da constitucionalidade dos efeitos concretos de uma lei”.¹²⁸

Essa proposta, contudo, não foi admitida. Em 19.12.2019, a Corte, por unanimidade, julgou prejudicada a referida ADI 1.244, tendo, inclusive, o Min. Gilmar Mendes, relator, reajustado o seu voto.

Podemos, então, afirmar que o entendimento pacificado do STF é no sentido da **prejudicialidade** da ação, conforme, por exemplo, o julgamento da ADI 514/PI, em **24.03.2008**, Rel. Min. Celso de Mello (*Inf. 499/STF*), e tantos outros precedentes.¹²⁹

Nesse sentido, o STF, novamente por unanimidade, **reafirmou a jurisprudência** ao esclarecer que “a **revogação expressa** ou **tácita** da norma impugnada, bem como sua **alteração substancial**, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a **perda superveniente do seu objeto**, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela

decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente” (**ADI 2.049**, Plenário Virtual, j. 05.11.2019, *DJE* de 26.11.2019. Cf., também, **ADI 282**, j. 05.11.2019).

CUIDADO: colocada a regra, devemos, agora, destacar alguns importantes precedentes nos quais o STF **superou** a preliminar de prejudicialidade:

- **ADI 3.232:** fraude processual;
- **ADI 3.306:** fraude processual;
- **ADI 951 ED:** comunicação tardia de revogação da lei objeto da ADI (após o STF ter julgado o mérito da ação, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei);
- **ADI 4.426:** singularidades do caso;
- **ADI 2.501:** inexistência de alteração substancial da norma (continuidade normativa);
- **ADI 2.418:** inexistência de alteração substancial da norma (continuidade normativa).

Na **ADI 3.232** (Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.08.2008, *DJE* de 03.10.2008), o STF afastou a prejudicialidade por se tratar de revogação da lei objeto da ação apenas para frustrar o julgamento, especialmente por já estar pautada a ação. Entendeu o STF que se tratava de verdadeira **fraude processual** e, assim, superou a questão de ordem.

Nesse sentido, como sublinhou o Min. Peluso, “... em conformidade com tese reafirmada em recente julgamento, de que foi Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito — que o fato de a lei objeto da impugnação ter sido revogada, não diria, no curso dos processos, mas já quase ao cabo deles, **não subtrai à Corte a jurisdição nem a competência para examinar a constitucionalidade da lei até então vigente e suas consequências jurídicas**, que, uma vez julgadas procedentes as três ações, não seriam, no caso, de pouca monta” (**ADI 3.232**, cf. *Inf. 515/STF*).

Nessa mesma linha, o julgamento da preliminar na **ADI 3.306** ao estabelecer que, “configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados” (ADI 3.306, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2011, Plenário, *DJE* de 07.06.2011).

No caso específico do julgamento dos embargos declaratórios na **ADI 951**, a **comunicação** da revogação da lei objeto da ação se deu somente quando da interposição dos referidos embargos declaratórios, ou seja, **em momento tardio**.

Entendeu o STF que não se poderia desprezar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, especialmente por ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma. Se outro fosse o entendimento, haveria a problemática de se manter no ordenamento jurídico norma violadora da Constituição.

Conforme prescreveu o Min. Barroso, relator, “permitir que se pleiteie a desconstituição do julgamento em sede de embargos de declaração depois de decidido o seu mérito **equivaleria** abrir à parte a **possibilidade de manipular a decisão do Supremo**”. E argumentou: “Se esta lhe for favorável, bastará não invocar a perda de objeto e usufruir de seus efeitos. Se, ao contrário, lhe for desfavorável, o reconhecimento da prejudicialidade a imunizará contra os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade” (*Notícias STF*, 27.10.2016).

No outro precedente, qual seja, no julgamento da **ADI 4.426**, **singularidades do caso** justificaram o excepcional afastamento da jurisprudência atual que adota a regra da prejudicialidade da ação, na medida em que houve “**impugnação em tempo adequado** e a sua **inclusão em pauta antes do esaurimento da eficácia da lei temporária impugnada**, existindo a **possibilidade de haver efeitos em curso**” (ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.02.2011, Plenário, *DJE* de 18.05.2011. Cf. também a ADI 4.356).

Finalmente, nos julgamentos da **ADI 2.501** (04.09.2008) e da **ADI 2.418** (04.05.2016), apesar de ter havido revogação do dispositivo objeto da ação, a **modificação introduzida pela nova lei não foi substancial**,

passando a haver tratamento normativo semelhante, não se identificando desatualização significativa no conteúdo dos institutos tratados.

Nesse sentido, o destaque feito pelo Min. Edson Fachin no julgamento das **ADIs 5.604** (j. 20.04.2017) e **5.599** (j. 26.10.2020): “se é proposta ADI contra uma medida provisória e, antes de a ação ser julgada, a MP é convertida em lei **com o mesmo texto que foi atacado**, esta **ADI não perde o objeto e poderá ser conhecida e julgada**. Como o texto da MP foi mantido, não cabe falar em prejudicialidade do pedido. Isso porque não há a convalidação (‘correção’) de eventuais vícios existentes na norma, razão pela qual permanece a possibilidade de o STF realizar o juízo de constitucionalidade. Neste caso, ocorre a **continuidade normativa** entre o ato legislativo provisório (MP) e a lei que resulta de sua conversão. Ex.: foi proposta uma ADI contra a MP 449/1994 e, antes de a ação ser julgada, houve a conversão na Lei n. 8.866/94. Vale ressaltar, no entanto, que **o autor da ADI deverá peticionar informando esta situação ao STF e pedindo o aditamento da ação**. STF. Plenário. ADI 1.055/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15.12.2016 (Info 851)”.

■ **6.7.1.2.13. *Alteração do parâmetro constitucional invocado. Novo precedente na linha de não ocorrência de prejuízo desde que analisada a situação concreta. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria na hipótese de inadmitida constitucionalidade superveniente***

Prevalece o entendimento no STF de que, havendo alteração no **parâmetro constitucional invocado** (no caso, por emenda constitucional), e já proposta a ADI, esta deve ser julgada **prejudicada** em razão da perda superveniente de seu objeto (já que a emenda constitucional, segundo a Corte, revoga a lei infraconstitucional em sentido contrário e que era o objeto da ADI).

Nesse sentido, o Min. Celso de Mello aduz que “... a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o regime constitucional anterior, tem proclamado que tanto a superveniente **revogação global** da Constituição da

República (*RTJ* 128/515, 130/68, 130/1002, 135/515 e 141/786) quanto a **posterior derrogação (ou alteração substancial) da norma constitucional** (*RTJ* 168/436, 169/834, 169/920, 171/114, 172/54-55 e 179/419; ADI 296/DF, 595/ES, 905/DF, 906/PR, 1.120/PA, 1.137/RS, 1.143/AP, 1.300/AP, 1.510/SC e 1.885-QO/DF), por afetarem o paradigma de confronto invocado no processo de controle concentrado de constitucionalidade, configuram hipóteses caracterizadoras de **prejudicialidade** da ação direta ou da ação declaratória, em virtude da evidente perda de seu objeto...”.

Podemos citar dois exemplos nos quais se percebia essa orientação, ou seja, que a **mudança de paradigma** acarretava, por regra, a prejudicialidade da ADI previamente ajuizada:

a) revogação primitiva do art. 39, § 1.º, pela EC n. 19/98 — *RTJ* 172/789-90, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:

“... II. Controle direto de inconstitucionalidade: prejuízo. Julga-se prejudicada total ou parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade no ponto em que, depois de seu ajuizamento, emenda à Constituição haja ab-rogado ou derogado norma de Lei Fundamental que constituísse paradigma necessário à verificação da procedência ou improcedência dela ou de algum de seus fundamentos, respectivamente: orientação de aplicar-se no caso, no tocante à alegação de inconstitucionalidade material, dada a revogação primitiva do art. 39, § 1.º, CF/88, pela EC 19/98” (ADI 1.434/SP, Rel. Min. Sepúlveda, *DJ* de 25.02.2000).

b) alteração do art. 40, *caput*, pela EC n. 41/2003, agora permitindo a taxação dos inativos:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 3.310/99. Cobrança de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. EC 41/2003. Alteração substancial do Sistema Público de

Previdência. Prejudicialidade. 1. Contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Norma editada em data posterior ao advento da EC 20/98. Inconstitucionalidade da lei estadual em face da norma constitucional vigente à época da propositura da ação. 2. Superveniência da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o sistema previdenciário. Prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de aferição da regra legal impugnada. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada” (ADI 2.197/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 02.04.2004, p. 8).

CUIDADO: mudança de entendimento pelo STF para se evitar a inadmitida constitucionalidade superveniente da lei objeto da ADI (15.09.2010).

Entretanto, no julgamento da questão de ordem na **ADI 2.158**, o STF rejeitou a preliminar de prejudicialidade, mesmo tendo havido a alteração no parâmetro de confronto.

No caso concreto, discutia-se lei do Estado do Paraná que, antes da novidade introduzida pela EC n. 41/2003, estabelecia a taxaço dos inativos.

Como se sabe, a possibilidade de taxaço dos inativos foi introduzida **somente** com o advento da EC n. 41/2003 (*Reforma da Previdência*), e não na redação original da Constituição.

Assim, antes da modificação introduzida pela EC n. 41/2003, nenhum ato normativo, mesmo na vigência das regras trazidas pela EC n. 20/98, poderia prescrever a taxaço dos inativos.

Por esse motivo, toda lei que eventualmente assim disciplinasse, como foi o caso do Paraná, conteria **vício congênito** de inconstitucionalidade e, portanto, teria “nascido morta”.

A partir do momento que a EC n. 41/2003 passou a admitir a taxaço dos inativos (anteriormente não admitida, já que inconstitucional), foi como se a referida lei, ainda no ordenamento, pudesse ser “recebida” pela nova emenda, já que com ela (a nova regra trazida por emenda) adequada.

Como, porém, o STF **não** admite o fenômeno da **constitucionalidade superveniente**, por esse motivo a referida lei, que nasceu inconstitucional, deve ser nulificada perante a regra da Constituição que vigorava à época de sua edição (**princípio da contemporaneidade**).

Dessa forma, examinando a situação do caso concreto, e **modificando o seu entendimento**, o STF não admitiu o pedido de prejudicialidade, analisando a constitucionalidade da lei à luz da regra constitucional que à época vigorava (**ADI 2.158** e **ADI 2.189**, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.09.2010, Plenário, *DJE* de 16.12.2010).

■ 6.7.1.2.14. *Divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo*

O STF entendeu **não** caracterizar situação de controle de constitucionalidade, na medida em que a simples divergência entre a ementa da lei e o seu conteúdo não seria suficiente para configurar afronta à Constituição (STF, Pleno, ADI 1.096-4, medida liminar, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 1, de 22.09.1995, p. 30589).

■ 6.7.1.2.15. *Respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral*

Julgou o STF não configurarem objeto de ADI as respostas emitidas pelo TSE às consultas que lhe forem endereçadas, na medida em que referidos atos não possuem “eficácia vinculativa aos demais órgãos do Poder Judiciário” (STF, ADI 1.805-MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, *Inf. 104/STF*), tratando-se de ato de caráter administrativo.

■ 6.7.1.2.16. *Leis orçamentárias?*

De modo geral, o STF entendia que as leis orçamentárias, ou a lei de diretrizes orçamentárias, não poderiam ser objeto de controle, já que se tratava de **leis com efeito concreto, ato administrativo em sentido**

material, vale dizer, **leis com objeto determinado e destinatário certo** (cf. *Inf.* 99, ADI(QO) 1.640; *Inf.* 175/STF, ADI 2.100).

Em uma jurisprudência inicial, o STF decidiu que, se demonstrado “um certo grau de abstração e generalidade” da lei, seria admitido o controle em abstrato mediante a ADI. Como exemplo citamos os *Informativos STF* ns. 255 e 333 (ADI 2.925), este último no qual se discutia a abstração da norma que tratava da “suplementação de crédito para reforço de dotações vinculadas aos recursos da CIDE-Combustíveis”.

Evoluindo a jurisprudência (cf. *itens* 6.7.1.2.5 e 6.7.1.2.10), o STF passou a admitir o controle de constitucionalidade das leis orçamentárias. Confira: “Controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias. **Revisão de jurisprudência.** O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, **independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade.** (...) Medida cautelar deferida. Suspensão da vigência da Lei n. 11.658/2008, desde a sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008” (ADI 4.048-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.05.2008, *DJE* de 22.08.2008). No mesmo sentido: ADI 4.049-MC, cf. *Inf.* 527/STF.

Isso porque a **lei orçamentária** é um ato de efeito concreto na aparência, já que, como decidido, para que seja executada, dependerá da edição de muitos outros atos, estes, sim, de efeito concreto.

Observamos que a **abertura de crédito extraordinário** pode, segundo o STF, ser comparada à lei orçamentária e, assim, mesmo que por MP, vir a ser o ato questionado por ADI (cf. ADIs 4.048 e 4.049, *Infs.* 502, 506 e 527/STF e discussão da matéria no *item* 9.14.4.8).

Conforme alertado, considerando que a decisão foi tomada em **medida cautelar**, resta aguardar a evolução da jurisprudência do STF. Relembre-se que o **PGR**, em seu parecer encaminhado à **ADI 4.047**, entendeu que o STF não pode analisar ato de efeito concreto, pedindo, tendo em conta que a

votação foi bastante apertada (**ADIs 4.048 e 4.049**, vide também *Inf. 527/STF*), uma **revisão da matéria**, retomando o entendimento anterior que não admitia ADI tendo por objeto ato de efeito concreto (cf. *Notícias STF*, 06.01.2009) (**matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Cumpra-se aqui que, em dois julgamentos já realizados (**ADIs 4.048 e 4.049**), entendeu-se pela **prejudicialidade** das ações por **perda superveniente do objeto**. Isso porque, nos termos do art. 167, § 2.º, os créditos extraordinários abertos ou já tinham sido utilizados ou perderam a sua vigência. Assim, podemos afirmar essa tendência de mudança da orientação da Corte de acordo com os julgamentos proferidos nas cautelares.

■ 6.7.1.2.17. **Resoluções do CNJ e do CNMP**

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (art. 103-B, § 4.º), bem como o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) (art. 103-A, § 2.º), introduzidos pela *Reforma do Poder Judiciário* (EC n. 45/2004), no exercício de suas atribuições constitucionais e regimentais, podem elaborar **resoluções**.

Algumas dessas resoluções, segundo o STF, são dotadas da qualidade da **generalidade**, **impessoalidade** e **abstração** (cf., por exemplo, ambas do CNJ, a *Res. n. 7/2005* — que proíbe o nepotismo — e a *Res. n. 175/2013* — que veda às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo).

Nessas situações, o STF vem reconhecendo a natureza jurídica de **ato normativo primário** dessas resoluções, que inovam a ordem jurídica a partir de parâmetros constitucionais e, assim, permitem o controle concentrado por meio de ADI genérica.¹³⁰

Veda-se, portanto, de acordo com a jurisprudência da Corte, a impetração de **mandado de segurança** para o questionamento desses atos normativos primários, com fundamento na **S. 266/STF**, por se tratar de “lei” em tese.

■ 6.7.1.2.18. *Ato administrativo normativo genérico (ADI 3.202 — agravo regimental em processo administrativo)*

O tema discutido nos autos da **ADI 3.202** (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.02.2014, Plenário, *DJE* de 21.05.2014) é bastante interessante. Diversos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte conseguiram, quer administrativa quer judicialmente, determinada gratificação por trabalho científico, técnico ou administrativo que exija conhecimento especial.

Partindo desses precedentes paradigmáticos, com base no princípio da isonomia, dois servidores fizeram pedido administrativo perante o Tribunal de Justiça objetivando a mesma gratificação, já que estavam em situação idêntica àquela das pessoas que tiveram o seu reconhecimento.

Inicialmente, o pedido foi indeferido. Interposto agravo regimental no Processo Administrativo n. 102.138/2003, o Plenário do TJRN deu provimento para conferir aos agravantes (dois servidores) a gratificação e, **extrapolando** o pedido, também com base no princípio da isonomia, “determinou a **extensão** desse benefício aos servidores que se encontravam em níveis correspondentes àqueles que obtiveram idêntica vantagem”.

Então foi posta a **questão preliminar**: a decisão proferida no agravo regimental no referido processo administrativo que **estendeu os efeitos** para todos os servidores em situação idêntica pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade por meio de ADI genérica? Estamos diante de ato administrativo normativo genérico?

A Corte, por 9 x 1, entendeu que sim e, portanto, a **extensão** poderia ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade por meio da ADI genérica, já que, como bem colocou o Min. Celso de Mello, trata-se de “ato impregnado de suficiente densidade normativa, considerados os aspectos de generalidade abstrata e de impessoalidade que o tipificam” (fls. 32 do acórdão).

■ 6.7.1.3. ***Elementos essenciais do controle de constitucionalidade:***
a) elemento conceitual (o conceito de “bloco de constitucionalidade”); b) elemento temporal

O tema proposto foi muito bem explorado pelo Min. Celso de Mello no julgamento da *ADI 595-ES (Inf. 258/STF)* e de indispensável leitura pelo candidato vitorioso!

No referido julgamento fixa-se, com precisão, a ideia de dois **elementos essenciais** para se falar em controle de constitucionalidade.

O primeiro, para o ilustre Ministro, denominado **elemento conceitual**, “... consiste na determinação da própria ideia de Constituição e na definição das premissas jurídicas, políticas e ideológicas que lhe dão consistência”. O outro, “o **elemento temporal**, cuja configuração torna imprescindível constatar se o padrão de confronto, alegadamente desrespeitado, ainda vige, pois, sem a sua concomitante existência, descaracterizar-se-á o fator de contemporaneidade, necessário à verificação desse requisito”.

O *elemento temporal* já foi analisado tanto no tocante à revogação de lei (cuja constitucionalidade está sendo questionada, qual seja, o objeto da ação), como na hipótese de alteração do parâmetro constitucional invocado (em relação ao qual se afere a compatibilidade vertical) (cf. *itens 6.7.1.2.12 e 6.7.1.2.13*).

Em relação ao **elemento conceitual**, a ideia é identificar o que deve ser entendido como parâmetro de constitucionalidade. Trata-se de nítido processo de aferição da *compatibilidade vertical* das normas inferiores em relação ao que foi considerado como “modelo constitucional” (**vínculo de ordem jurídica**, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição — **paradigma de confronto**).

Nesse sentido, duas posições podem ser encontradas. Uma **ampliativa** (englobando não somente as normas formalmente constitucionais como, também, os princípios não escritos da “ordem constitucional global” e, inclusive, valores suprapositivos) e outra **restritiva** (o parâmetro seriam somente as normas e princípios expressos da Constituição escrita e positivada).

Quanto à perspectiva ampliativa, o Min. Celso de Mello (*Inf. 258/STF*) vislumbra possam ser “... considerados não apenas os preceitos de índole positiva, expressamente proclamados em documento formal (que consubstancia o texto escrito da Constituição), mas, sobretudo, que sejam havidos, igualmente, por relevantes, em face de sua transcendência mesma, os valores de caráter suprapositivo, os princípios cujas raízes mergulham no direito natural e o próprio espírito que informa e dá sentido à Lei Fundamental do Estado”.

E completa: “não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, certa vez, e para além de uma perspectiva meramente reducionista, veio a proclamar — distanciando-se, então, das exigências inerentes ao positivismo jurídico — que a Constituição da República, muito mais do que o conjunto de normas e princípios nela formalmente positivados, há de ser também entendida em função do próprio espírito que a anima, afastando-se, desse modo, de uma concepção impregnada de evidente minimalismo conceitual (*RTJ 71/289, 292 e 77/657*)”.

Diante de todo o exposto, busca-se fixar, com clareza para o direito brasileiro, o conceito de **bloco de constitucionalidade**, qual seja, o que deverá servir de parâmetro para que se possa realizar a confrontação e aferir a constitucionalidade.¹³¹

A tendência ampliativa parece-nos **tímida** na jurisprudência brasileira, que adotou, do ponto de vista jurídico, a ideia de **supremacia formal**, apoiada no conceito de **rigidez constitucional** e na consequente obediência aos **princípios e preceitos decorrentes da Constituição**.

Nesse sentido, Bernardes observa que “... no direito brasileiro prevalece a restrição do parâmetro direto de controle — que aqui poderia ser chamado de *bloco de constitucionalidade em sentido estrito* — às normas contidas, ainda que não expressamente, em texto constitucional (normas formalmente constitucionais)”.¹³²

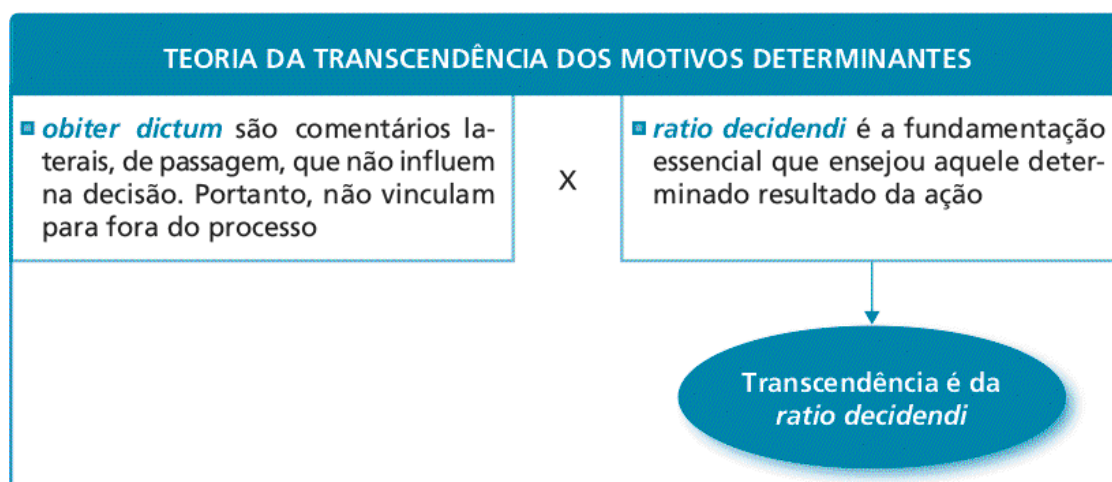
Com o advento da **EC n. 45/2004** pode-se asseverar ter havido ampliação do “bloco de constitucionalidade” na medida em que se passa a ter um novo parâmetro (*norma formal e materialmente constitucional*) — os

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais,¹³³ nos termos do art. 5.º, § 3.º, CF/88.

Outro exemplo interessante é a **EC n. 91/2016**, que, sem introduzir qualquer artigo, seja no corpo ou mesmo no ADCT, alterou regra sobre perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, estabelecendo a possibilidade, excepcional e em período determinado, de desfiliação, sem prejuízo do mandato (cf. *item 18.5*).

Podemos citar, ainda, as **ECs ns. 106 e 107/2020**, que, no contexto da pandemia da **Covid-19**, trouxeram regras específicas para o período de calamidade pública e que não foram formalmente inseridas seja no corpo ou no ADCT da Constituição. Naturalmente, referidas disposições têm natureza jurídica de Constituição.

■ **6.7.1.4. Teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes?) (“Ratio decidendi” — “holding” versus “obiter dictum” — “dictum”)**



O STF vinha atribuindo efeito vinculante não somente ao dispositivo da sentença, mas, também, aos **fundamentos determinantes da decisão**.

Falava-se, então, em **transcendência dos motivos determinantes**, ou **efeitos irradiantes** ou **transbordantes dos motivos determinantes**.

Há de se observar, inicialmente, a distinção entre *ratio decidendi* e *obiter dictum*.

Obiter dictum (“coisa dita de passagem”) ou simplesmente **dictum** são comentários laterais, que não influem na decisão, sendo perfeitamente dispensáveis. Portanto, aceita a “**teoria do transbordamento**”, não sealaria em irradiação de *obiter dictum*, com efeito vinculante, para fora do processo. Por outro lado, a **ratio decidendi**, sendo **holding** a denominação mais usual na experiência norte-americana,¹³⁴ é a fundamentação essencial que ensejou aquele determinado resultado da ação. Nessa hipótese, aceita a “teoria dos efeitos irradiantes”, a “razão da decisão” passaria a vincular outros julgamentos.

Como exemplo, no julgamento da ADI 3.345/DF, que declarou constitucional a Resolução do TSE que reduziu o número de vereadores de todo o país, o STF entendeu que a Suprema Corte conferiu “... efeito transcendente aos próprios motivos determinantes que deram suporte ao julgamento plenário do RE 197.917”.

Sobre a **transcendência dos motivos determinantes**, cf. Rcl 2.986 MC/SE (*Inf. 379/STF*) e Rcl 2.475 (*Inf. 335/STF*), com os comentários já feitos em relação ao controle difuso (cf. *item 6.6.5*).

CUIDADO: no julgamento da **Rcl 10.604** (08.09.2010), o STF **afastou** a técnica do **transbordamento dos motivos determinantes**.

Em referido julgado, há referência à questão de ordem na **Rcl 4.219**, na qual se sinalizava a manifestação de 6 Ministros **contra** a teoria da transcendência (para conhecimento, informamos que, em razão da morte do reclamante, o STF, nos termos do art. 21, IX, do *Regimento Interno*, julgou prejudicado o pedido na referida reclamação).

Nas palavras do relator, Min. Ayres Britto, “... no julgamento da Rcl 4.219, esta nossa Corte retomou a discussão quanto à aplicabilidade dessa mesma teoria da ‘transcendência dos motivos determinantes’, oportunidade em que deixei registrado que tal aplicabilidade implica prestígio máximo ao

órgão de cúpula do Poder Judiciário e **desprestígio igualmente superlativo aos órgãos da judicatura de base**, o que se contrapõe à essência mesma do **regime democrático**, que segue lógica inversa: a lógica da desconcentração do poder decisório. Sabido que democracia é movimento ascendente do poder estatal, na medida em que opera de baixo para cima, e nunca de cima para baixo. No mesmo sentido, cinco ministros da Casa esposaram entendimento rechaçante da adoção do transbordamento operacional da reclamação, ora pretendido. Sem falar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já **rejeitou**, em diversas oportunidades, a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes das suas decisões (cf. Rcl 2.475-AgR, da relatoria do ministro Carlos Velloso; Rcl 2.990-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; Rcl 4.448-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 3.014, de minha própria relatoria)” (Min. Ayres Britto, j. 08.09.2010). (Cf., ainda, nesse mesmo sentido, Rcl 11.477 AgR, 1.^a T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.05.2012; Rcl 8.168, Pleno, j. 19.11.2015, *DJE* de 29.02.2016).

Trata-se de verdadeira **jurisprudência defensiva**, no sentido de se evitar o número crescente de reclamações.

Com o máximo respeito, **não parece razoável** desprezar a teoria da transcendência no **controle concentrado**, já que a **tese jurídica** terá sido resolvida e o dispositivo deve ser lido, em uma perspectiva moderna, à luz da fundamentação (lembrando que somos contra a teoria da transcendência no controle difuso, apesar de ter sinalizado o STF que essa passa a ser uma nova realidade no controle difuso — cf. *item* 6.6.5.5).

Inegavelmente, contudo, temos de reconhecer que a perspectiva de transcendência dos motivos determinantes deve ser revista à luz do CPC/2015, destacando-se os arts. 927 e 988.¹³⁵ Já expusemos a nossa crítica à vinculação ampliada pela lei processual, lembrando que a Constituição se limita a estabelecer o efeito vinculante nas ações de controle concentrado e em razão de edição de súmula vinculante.

Nesse sentido, como afirmam Barroso e Mello, “se o CPC/2015 acolheu tal concepção de **tese jurídica vinculante**, inclusive em sede de controle concentrado da constitucionalidade, isso significa que, com a sua vigência, **o**

entendimento do STF que rejeitava a eficácia transcendente da fundamentação precisará ser revisitado. É que a eficácia transcendente significa justamente atribuir efeitos vinculantes à *ratio decidendi* das decisões proferidas em ação direta. Mesmo que este entendimento não fosse acolhido pelo STF no passado, o fato é que, ao que tudo indica, o novo Código o adotou”.¹³⁶

■ **6.7.1.5. Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou inconstitucionalidade consequencial, ou inconstitucionalidade consequente ou derivada, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”**

Esse importante tema aparece intimamente ligado aos limites objetivos da coisa julgada e à produção dos efeitos *erga omnes*.¹³⁷

Pela referida teoria da **inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados”, ou “inconstitucionalidade por reverberação normativa”,** se em determinado processo de controle concentrado de constitucionalidade for julgada inconstitucional a norma principal, em futuro processo, outra norma dependente daquela que foi declarada inconstitucional em processo anterior — tendo em vista a **relação de instrumentalidade** que entre elas existe — também estará eivada pelo vício de inconstitucionalidade “consequente”, ou por “arrastamento” ou “atração”.

Poder-se-ia pensar, neste ponto, que a consequência prática da coisa julgada material, que se projeta para fora do processo, impediria não só que a mesma pretensão fosse julgada novamente, como também, sob essa interessante perspectiva, que a norma consequente e dependente ficasse vinculada tanto ao dispositivo da sentença (principal) quanto à *ratio decidendi*, invocando, aqui, a “teoria dos motivos determinantes”.

Esses dois temas no âmbito do controle de constitucionalidade vislumbram uma perspectiva *erga omnes* para os limites objetivos da coisa julgada, em importante avanço em relação à teoria clássica.¹³⁸

Naturalmente, essa técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pode ser aplicada tanto em processos distintos como em um mesmo processo, situação que vem sendo verificada com mais frequência na jurisprudência do STF.

Ou seja, já na própria decisão, a Corte define quais normas são atingidas, e no dispositivo, por “**arrastamento**”, também reconhece a **invalidade** das normas que estão “**contaminadas**”, mesmo na hipótese de não haver pedido expresse na petição inicial.

Essa “contaminação”, ou, mais tecnicamente, **perda de validade**, pode ser reconhecida, também, em relação a decreto que se fundava em lei declarada inconstitucional. Então, o STF vem falando em inconstitucionalidade por arrastamento do decreto que se fundava na lei (cf., por exemplo, ADI 2.995/PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2006).¹³⁹ Interessante observar que o decreto regulamentar, por si, conforme visto, não pode ser isoladamente objeto de ADI, na medida em que deve ser confrontado com a lei (que regulamenta), e não diretamente perante a Constituição. A *crise é de legalidade*, e apenas de *modo indireto, reflexo* ou *oblíquo* é que poderia haver violação da Constituição. Pela técnica do arrastamento, contudo, a declaração de sua invalidade dar-se-á no julgamento da própria ADI.

Partindo desse precedente, observa-se que a reverberação, sem dúvida, poderá ser reconhecida entre normas interconectadas por uma relação hierárquica, observando-se, assim, um **arrastamento no plano vertical**. Dessa forma, para se ter outro exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma de determinada Constituição estadual implicaria o reconhecimento da perda de validade das normas hierarquicamente inferiores e que se fundavam naquele dispositivo.

Em outro julgado, declarada a inconstitucionalidade de um dispositivo, os outros que estavam na mesma lei e que tinham relação com aquele nulificado, por **perderem a sua razão de ser**, foram também declarados inconstitucionais, de acordo com aquilo que o Min. Ayres Britto denominou **inconstitucionalidade por reverberação normativa** (cf. voto do Min. Ayres Britto proferido na **ADI 1.923** — *Inf.* 622/STF — e na **ADI 4.357** — *Inf.* 643/STF).

Essa ideia de conexão e consequente “contaminação” também foi observada em **ADPF**. O STF declarou não recepcionado o § 4.º do art. 23 da Lei n. 1.079/50 (*impeachment*), por ter a Corte reconhecido como não recepcionados os §§ 1.º e 5.º do referido artigo, expressamente impugnados e que guardavam relação “consequencial” (a definição do papel da Câmara dos Deputados no processo de *impeachment* do Presidente da República — §§ 1.º e 5.º — tornou sem sentido o § 4.º, revogado por arrastamento, apesar de não ter havido pedido expreso) (cf. **ADPF 378 MC**, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2015, Plenário, *DJE* de 08.03.2016, item IV.9 da ementa, e proposta apresentada pelo Min. Celso de Mello — fls. 398-399 do acórdão).

O instituto do “arrastamento” é, sem dúvida, **exceção** à regra de que o juiz deve ater-se aos limites da lide fixados na exordial, especialmente em virtude da correlação, conexão ou interdependência dos dispositivos legais e do caráter político do controle de constitucionalidade realizado pelo STF.¹⁴⁰ Estamos diante de inegável revisitação da *regra da congruência* (ou *correlação*) entre o pedido e a sentença (arts. 128 e 460 do CPC/73 — arts. 141 e 492, CPC/2015), decorrente do *princípio dispositivo* e que deve ser analisada sob esse novo e particular aspecto do processo objetivo.

Por força do **art. 10, CPC/2015**, como o juiz não pode decidir, **em grau algum de jurisdição** e, portanto, no STF, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, entendemos que deverá ser aberto prazo para que as partes se pronunciem sobre a perspectiva de nulificação de norma em razão da técnica do “arrastamento”

(como o Código não distingue entre processo subjetivo e objetivo, o tema terá de ser enfrentado pelo Plenário do STF — pendente).

■ 6.7.1.6. *Lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade”*

■ 6.7.1.6.1. *A instituição da Defensoria Pública pela CF/88 e a sua potencialização pela EC n. 80/2014*

O art. 5.º, LXXIV, CF/88, dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Esse direito e garantia fundamental instrumentaliza-se por meio da **Defensoria Pública**, instituída pela CF/88, **amplificada** pela **EC n. 80/2014** (art. 134, *caput*) e organizada em **carreira própria** nos seguintes termos: instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º, CF.

Pelo fato de ter sido instituída pela Constituição de 1988, a Defensoria Pública tem de ser **efetivamente instalada**, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou distrital, o que leva certo tempo.

Esse comando que se extrai desde a sua previsão no texto de 1988 é fortalecido pela **EC n. 80/2014**. Ao acrescentar o art. 98 ao ADCT e prescrever que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população, **fixa-se** o prazo de **8 anos** para que a União, os Estados e o Distrito Federal passem a contar com defensores públicos em **todas** as unidades jurisdicionais.

Durante o decurso desse prazo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, **prioritariamente**, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

O que fazer, então, durante esse período de transição, necessário para a efetiva instalação da Defensoria Pública?

Para analisar o tema, trouxe duas questões práticas já enfrentadas pelo STF: **a)** a previsão de prazo em dobro para a Defensoria Pública no processo penal; **b)** a ação civil *ex delicto* ajuizada pelo MP depois do advento da CF/88.

■ 6.7.1.6.1.1. *A questão do “prazo em dobro” para a Defensoria Pública no processo penal — rejeição de inconstitucionalidade “rebus sic stantibus”*

Nos termos dos arts. 44, I, 89, I, e 128, I, da LC n. 80/94, é prerrogativa dos membros da Defensoria Pública receber **intimação pessoal** em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em **dobro todos os prazos**.¹⁴¹

Em relação ao **processo civil**, a regra não sofreu nenhuma repreensão por parte do STF, até porque há equivalente para o MP (e a Fazenda Pública), conforme o art. 188 do CPC/73 (cf. arts. 180, 183 e 186, CPC/2015).

No tocante ao **processo penal**, contudo, na medida em que o MP não goza dessa prerrogativa de prazo em dobro, questionou-se se, de fato, a regra poderia ser estabelecida para a Defensoria Pública quando atua como defensora em acusação formulada pelo MP, especialmente em relação ao princípio da isonomia e ao do devido processo legal.

O STF, ao analisar o tema do **prazo em dobro para o processo penal**, entendeu que referida regra é constitucional até que a Defensoria Pública efetivamente se instale.

Assim, o prazo em dobro para o processo penal só valerá enquanto a Defensoria Pública ainda não estiver eficazmente organizada. Quando isso se verificar, a regra tornar-se-á **inconstitucional**. Trata-se, portanto, de **norma em trânsito para a inconstitucionalidade**.

Nesse sentido, confira o precedente **HC 70.514**, j. 23.03.1994: “EMENTA: Direito Constitucional e **Processual Penal**. Defensores Públicos: prazo em dobro para interposição de recursos (§ 5.º do art. 1.º da Lei n. 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 08.11.1989). Constitucionalidade. ‘Habeas Corpus’. Nulidades. Intimação pessoal dos Defensores Públicos e prazo em dobro para interposição de recursos. 1. Não é de ser reconhecida a inconstitucionalidade do § 5.º do art. 1.º da Lei n. 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 08.11.1989, no ponto em que confere **prazo em dobro**, para recurso, às Defensorias Públicas, **ao menos até que sua organização, nos Estados, alcance o nível de organização do respectivo Ministério Público, que é a parte adversa, como órgão de acusação, no processo da ação penal pública...**” (grifamos).

Interessante, também, o voto do Min. Moreira Alves, que pedimos vênua para transcrever: “a única justificativa que encontro para esse tratamento desigual em favor da Defensoria Pública em face do Ministério Público é a de caráter temporário: a circunstância de as Defensorias Públicas ainda não estarem, por sua recente implantação, devidamente aparelhadas como se acha o Ministério Público. Por isso, para casos como este, parece-me deva adotar-se a construção da Corte Constitucional alemã no sentido de considerar que uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser inconstitucional, não o sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se apresentarem com a intensidade necessária para que se tornem inconstitucionais. Assim, **a lei em causa será constitucional enquanto a Defensoria Pública, concretamente, não estiver organizada com a estrutura que lhe possibilite atuar em posição de igualdade com o Ministério Público, tornando-se inconstitucional, porém, quando essa circunstância de fato não mais se verificar**” (grifamos).

■ **6.7.1.6.1.2. Ação civil “ex delicto” ajuizada pelo MP — art. 68, CPP (lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção)**

O art. 68, CPP, estabelece: “quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1.º e 2.º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público”.

Retorna-se então à dúvida: o art. 68, CPP, previu a ação civil *ex delicto*, que deve ser ajuizada pelo MP. Essa atribuição, no entanto, a partir de 1988, passou a ser da Defensoria Pública, seja em razão de sua previsão constitucional (art. 134), seja em razão da regra contida no art. 129, IX, que autoriza o MP a exercer outras funções que lhe forem conferidas, **desde que compatíveis com a sua finalidade**, vedando, assim, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Então, pelo exposto, o art. 68, CPP, teria sido **revogado**, por não recepção, pelo texto de 1988.

A Defensoria Pública, por sua vez, não se instalou efetivamente logo após a promulgação da CF/88. Para se ter um argumento, só a partir da *Reforma do Judiciário* (**EC n. 45/2004**) a Defensoria Pública Estadual passou a ter autonomia funcional e administrativa, e a autonomia da Defensoria Pública do DF veio a ser reconhecida apenas na **EC n. 69/2012**, já que antes organizada e mantida pela União. Ainda, foi somente com a **EC n. 74/2013** que a Defensoria Pública da União, por sua vez, passou a ter autonomia (art. 134, § 3.º, CF/88), e, finalmente, com a **EC n. 80/2014**, houve sensível potencialização da instituição, fixando-se prazo para sua efetiva instalação nos termos do art. 98, ADCT (cf. *item 12.5*).

Portanto, vem o STF entendendo, de maneira acertada, que o art. 68, CPP, é uma lei **ainda constitucional** e que está **em trânsito, progressivamente, para a “inconstitucionalidade”**, à medida que as Defensorias Públicas forem sendo, **efetiva e eficazmente**, instaladas.

Apenas deixamos o alerta de que a terminologia utilizada pela Suprema Corte não é a mais adequada, uma vez que, por se tratar de ato editado antes de 1988 (art. 68, CPP), referido dispositivo seria revogado por não recepção. Trata-se, assim, em razão das circunstâncias, de reconhecida modulação do momento de revogação do ato normativo pré-constitucional, e por isso

preferimos a denominação **lei ainda constitucional e em trânsito para revogação por não recepção**.

A técnica da “lei ainda constitucional”, conforme noticiado, está consagrada no STF:¹⁴² “Ministério Público: legitimação para promoção, no juízo cível, do ressarcimento do dano resultante de crime, pobre o titular do direito à reparação: C. Pr. Pen., art. 68, ainda constitucional (cf. RE 135.328): **processo de inconstitucionalização das leis**. 1. A alternativa radical da jurisdição constitucional ortodoxa, entre a constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou revogação por inconstitucionalidade da lei, com fulminante eficácia *ex tunc*, faz abstração da evidência de que **a implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato instantâneo**, mas um processo no qual a possibilidade de realização da norma da Constituição — ainda quando teoricamente não se cuide de preceito de eficácia limitada — subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fática que a viabilizem. 2. No contexto da Constituição de 1988, a atribuição anteriormente dada ao Ministério Público pelo art. 68 C. Pr. Penal — constituindo modalidade de assistência judiciária — deve reputar-se transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim, só se pode considerar existente, onde e quando **organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134** da própria Constituição e da lei complementar por ela ordenada: até que — na União ou em cada Estado considerado — se implemente essa condição de viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições, o art. 68 C. Pr. Pen. será considerado **ainda vigente**: é o caso do Estado de São Paulo, como decidiu o plenário no RE 135328” (RE 147.776/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª T., RTJ 175/309-310).

- 6.7.1.6.2. ***Procedimento de aprovação das medidas provisórias: apreciação pela comissão mista nos termos do art. 62, § 9.º, CF/88. Arts. 5.º, “caput”, e 6.º, “caput”, e §§ 1.º e 2.º, Res. n. 1/2002-CN***

Conforme já estudamos no *item* 6.6.5.4, a Res. n. 1/2002-CN, integrante do *Regimento Comum*, dispôs sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, de medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62, Constituição Federal.

Os seus arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput*, e §§ 1.º e 2.º, permitiam que o parecer da comissão mista fosse emitido por relator ou relator revisor designado.

Esse procedimento vinha sendo adotado na apreciação de várias medidas provisórias, até como um mecanismo de funcionalidade do procedimento.

Segundo o Min. Cezar Peluso, no julgamento da **ADI 4.029** (08.03.2012), **vencido** nesse ponto, não se percebia qualquer “coisa anômala ou atípica” na fixação de prazo para atuação da comissão, até porque, “doutro modo, pensando-se que o Congresso não possa fazê-lo, temos o quê? Temos que essa comissão não se sentirá obrigada, em nenhum instante, a manifestar-se, e vai se escoar o prazo após o qual a medida provisória perde a eficácia. Noutras palavras, é **método de operacionalidade do próprio Legislativo**. Se o Legislativo não estabelece esse prazo, a comissão evidentemente não se sentirá de nenhum modo movida a exercer a competência que a Constituição lhe atribui” (fls. 69).

Esse, contudo, não foi o entendimento que prevaleceu diante da regra contida no **art. 62, § 9.º, CF/88**, que deve ser interpretado restritivamente, pois, consoante observou o Min. Ayres Britto em seu voto, as medidas provisórias “investem o Presidente da República — vamos ficar no plano federal para facilitar o debate — num poder excepcional, numa competência excepcional de ser a fonte produtora de uma norma primária, inovadora, portanto, do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição”.

Referido dispositivo constitucional estabelece ser atribuição da **comissão mista** de Deputados e Senadores **examinar** as medidas provisórias e sobre elas **emitir parecer**, de caráter **opinativo**, acrescente-se, antes de serem **apreciadas**, em **sessão separada**, pelo **plenário** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Sendo assim, conforme anotou a Corte, o procedimento estabelecido na Res. n. 1/2002-CN, que permite a emissão de parecer por meio de relator nomeado, e não pela comissão mista, é **inconstitucional**.

Apesar de o mencionado parecer ser **opinativo**, isso não autoriza o Parlamento a violar a regra contida no art. 62, § 9.º, CF/88. Se eventualmente não houver apreciação pela comissão mista, significa que a MP foi rejeitada por não apreciação, perdendo a sua eficácia desde a sua edição (art. 62, § 3.º, CF/88).

Dessa forma, o STF declarou a **inconstitucionalidade dos arts. 5.º, caput, e 6.º, caput, e §§ 1.º e 2.º, da Res. n. 1/2002-CN**.

O ponto interessante é que, durante todo esse tempo, ou seja, por mais de 10 anos, o Congresso Nacional adotou esse “costume” (**inconstitucional**) de não fazer cumprir a regra de atuação da comissão mista, contentando-se com a permissão de parecer por relator designado, antes da apreciação em sessão separada pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Em julgamento anterior, o Min. Gilmar Mendes, na linha do dito *costume inconstitucional*, havia flexibilizado a exigência do art. 62, § 9.º, CF/88, nos seguintes termos: “(...) considerando que ainda estamos em uma **fase de consolidação do novo modelo** trazido pela Emenda 32 para as medidas provisórias, não vejo como adotar interpretação com os rigores pretendidos pelo requerente na ADI 3.289. No caso, resta evidenciado que por duas vezes foi convocada a reunião para instalação da Comissão, não se chegando, todavia, ao *quorum* necessário. Essa falha procedimental, considerado o **atual estágio de implementação** da Emenda 32, assim como as **circunstâncias do caso**, em que resta demonstrada a tentativa, por duas vezes, de instalação da comissão mista, no meu entendimento, **ainda** não permite a formulação de um juízo de inconstitucionalidade por ofensa ao referido § 9.º” (**ADI 3.289** e **ADI 3.290**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.05.2005, Plenário, *DJ* de 24.02.2006).

Surgia, então, o impasse. Se o procedimento contido na Res. n. 1/2002-CN foi declarado inconstitucional, o que fazer em relação a todas as medidas provisórias que foram convertidas em lei sem a emissão de parecer pela

comissão mista, na forma do art. 62, § 9.º, CF/88?

Em tese, seriam todas inconstitucionais. Para evitar essa situação de **insegurança jurídica** e diante do **excepcional interesse social**, a Corte determinou a aplicação do art. 27 da Lei n. 9.868/99 (modulação dos efeitos da decisão), declarando a inconstitucionalidade do procedimento fixado na Res. n. 1/2002-CN a partir da decisão proferida na **ADI 4.029** — efeito *ex nunc* (j. 08.03.2012).

Assim, o modelo de apreciação da medida provisória fixado na resolução do Congresso Nacional foi declarado **“ainda constitucional”** até o julgamento da referida ADI 4.029 e, a partir de então, o STF declarou inconstitucional qualquer inobservância ao art. 62, § 9.º, CF/88, ficando, por consequência, **preservadas a validade e a eficácia** de todas as medidas provisórias convertidas em lei até aquela data, bem como daquelas que estavam tramitando no Legislativo nos termos do procedimento fixado nos arts. 5.º, *caput*, e 6.º, *caput* e §§ 1.º e 2.º, Res. n. 1/2002-CN, que permitiam a continuidade do iter procedimental de apreciação da medida provisória mesmo na hipótese de não haver parecer emitido pela comissão mista no prazo rígido de 14 dias contados da sua publicação.

■ 6.7.1.7. **“Inconstitucionalidade circunstancial”**

O tema agora é diferente do analisado no item anterior.

Busca-se, diante de uma lei formalmente constitucional, identificar que, **circunstancialmente**, a sua aplicação caracterizaria uma inconstitucionalidade, que poderíamos até chamar de **axiológica**.

Trata-se daquilo que foi denominado pela doutrina **“inconstitucionalidade circunstancial”** e, por que não, fazendo um paralelo não muito rígido com o tema anterior, de uma **“lei ainda inconstitucional”** em determinadas situações (enquanto persistirem certas circunstâncias).

Como bem afirma Barcellos, “trata-se da *declaração de inconstitucionalidade da norma produzida pela incidência da regra sobre uma determinada situação específica*... É possível cogitar de situações nas

quais um enunciado normativo, válido em tese e na maior parte de suas incidências, ao ser confrontado com determinadas **circunstâncias concretas**, produz uma norma inconstitucional. Lembre-se que, em função da complexidade dos efeitos que se pretendam produzir e/ou da multiplicidade de circunstâncias de fato sobre as quais incidem, também as **regras** podem justificar diferentes condutas que, por sua vez, vão dar conteúdo a normas diversas. Cada uma dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser confrontada com um conjunto específico de outras incidências normativas, justificadas por enunciados diversos. Por isso, não é de estranhar que **determinadas normas possam ser inconstitucionais em função desse seu contexto particular, a despeito da validade geral do enunciado do qual derivam**".¹⁴³

Como interessante exemplo, destacamos a **ADI 223**, na qual se discutia a constitucionalidade de normas que proibiam a concessão de tutela antecipada e liminares em face da Fazenda Pública.

Sem dúvida, diz Barcellos, a análise pelo Judiciário seria diferente para duas situações distintas: **a)** reenquadramento de servidor público; **b)** concessão de tutela antecipada para que o Estado custeasse cirurgia de vida ou morte.

Nesse segundo caso, sem dúvida, **dada a circunstância**, a lei seria inconstitucional, especialmente diante do art. 5.º, XXXV.

■ 6.7.1.8. *O efeito vinculante para o Legislativo e o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição”. Possibilidade de reversão legislativa da jurisprudência da Corte. A denominada “mutação constitucional pela via legislativa”*

Como veremos e já comentamos em outro estudo,¹⁴⁴ o efeito vinculante em ADI e ADC, na linha de interpretação dada pelo STF, não atinge o Poder Legislativo no exercício de sua **função típica de legislar**, produzindo eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do **Poder Judiciário** e à **Administração Pública** direta e indireta, nas esferas

federal, estadual e municipal (exceto, entendemos, no exercício por esses órgãos de suas funções atípicas de caráter normativo, como, para se ter um exemplo, quando o Presidente da República edita medida provisória — ato normativo).

Ao analisar a possibilidade de vinculação também para o Legislativo (no caso de sua função típica), o Min. Cezar Peluso indica, com precisão, que essa possível interpretação (diversa da literalidade constitucional) significaria o **“inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição”**.

O Legislativo, assim, poderá, inclusive, legislar em sentido diverso da decisão dada pelo STF, ou mesmo contrário a ela, sob pena, em sendo vedada essa atividade, de significar inegável **petrificação** da evolução social.

Isso porque o valor **segurança jurídica**, materializado com a ampliação dos efeitos *erga omnes* e *vinculante*, sacrificaria o valor **justiça da decisão**, já que impediria a constante atualização das Constituições e dos textos normativos por obra do Poder Legislativo.

A mesma orientação poderá ser adotada, também, para o efeito vinculante da súmula, que, em realidade, possui idêntica significação prática em relação ao efeito vinculante do controle concentrado de constitucionalidade.

Entendimento diverso, manifestou o Min. Peluso, “... comprometeria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, reduzindo este a papel subalterno perante o poder incontrolável daquele, com evidente prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo” (**Rcl 2.617, Inf. 386/STF**).

O Min. Fux, ao reconhecer a possibilidade de **reversão legislativa da jurisprudência da Corte**,¹⁴⁵ estabeleceu providências distintas de acordo com o instrumento utilizado:

■ **manifestação do poder constituinte derivado:** “a emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses

de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais”;

■ **manifestação do poder normativo infraconstitucional:** “a legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis *in your face*) nasce com presunção *iuris tantum* de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, **a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso**, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas” (ADI 5.105, j. 1.º.10.2015, DJE de 16.03.2016).

- 6.7.1.9. ***Criação do Município de Luís Eduardo Magalhães — ADI 2.240/BA — análise do voto do Min. Eros Grau. Contraponto: voto do Min. Gilmar Mendes — Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Efeito prospectivo. Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Dogma da nulidade da lei e garantia da segurança jurídica***

No julgamento da ADI 2.240, ajuizada pelo PT contra a Lei n. 7.619/2000, do Estado da Bahia, o STF analisou o processo de criação do *Município de Luís Eduardo Magalhães* tendo em vista o desmembramento de área do Município de Barreiras.

Dentre os principais argumentos da inconstitucionalidade da lei destacava-se a violação ao art. 18, § 4.º,¹⁴⁶ CF, na medida em que:

- o novo Município foi criado em ano de eleições municipais;

- não existia lei complementar federal fixando período para a criação de Municípios;
- a nova lei estadual violou o regime democrático, na medida em que a consulta prévia plebiscitária não foi realizada com a totalidade da população envolvida no processo de emancipação, mas somente em relação à população do Município que se formou;
- os estudos de viabilidade municipal foram publicados em momento posterior ao plebiscito.

Resumindo, a criação do novo Município violou, frontalmente, a regra do art. 18, § 4.º, fato esse, inclusive, reconhecido pelo relator, Min. Eros Grau, que, contudo, tendo em vista a **excepcionalidade do caso**, julgou improcedente o pedido, tendo por fundamento os, por ele ditos, “princípios”, que podem ser assim enumerados:¹⁴⁷

- **Município putativo** — à semelhança do que acontece com o casamento putativo e a sociedade de fato;
- **princípio da “reserva do impossível”** — “a diferença entre o casamento putativo e o ‘Município putativo’ está em que, embora possível a anulação do primeiro, a anulação da decisão política de que resultou a criação do Município avança sobre o que poderíamos chamar de ‘reserva do impossível’, no sentido de não ser possível anularmos o fato dessa decisão política de caráter institucional sem agressão ao princípio federativo”;
- **princípio da continuidade do Estado** — que encontra fundamento no art. 1.º, CF, e não se confunde com o princípio da continuidade do serviço público;
- **princípio federativo** — justifica a não anulação da decisão política de caráter institucional;
- **princípio da segurança jurídica** — que assegura a preservação da realidade de fato, qual seja, a existência de Município criado há mais de 6 anos;

■ **princípio da confiança (Karl Larenz)** — tendo como componente a ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé;

■ **princípio da força normativa dos fatos (Georg Jellinek)** — o Município foi efetivamente criado, assumindo existência de fato como ente federativo dotado de autonomia municipal a partir de uma decisão política;

■ **princípio da situação excepcional consolidada** — “não prevista pelo direito, porém instalada pela força normativa dos fatos” e “justificada” pela inércia do Poder Legislativo que até então não editara a lei complementar federal fixando prazo para criação de novos Municípios, como determinou a EC n. 15/96, que deu nova redação ao art. 18, § 4.º, CF/88. Assim, “a não edição da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica violação da ordem constitucional”.

A partir da 11. ed. deste estudo, já havíamos manifestado a nossa discordância em relação ao entendimento proposto pelo Min. Eros Grau, uma vez que não parecia razoável o resultado da construção (declaração de *constitucionalidade* da lei), o que poderia abrir precedentes para novas violações ao art. 18, § 4.º.

Em certa medida, tendo em vista o postulado da razoabilidade, a inexistência, até hoje (desde a EC n. 15, de 12.09.1996), de lei complementar federal fixando prazo e procedimento para a criação de novos Municípios até poderia ser superada. Contudo, não achávamos nada razoável a violação dos outros **pressupostos constitucionais**, como a necessidade de estudo de viabilidade prévio e de consulta plebiscitária a toda a população diretamente interessada (a da área a ser desmembrada e a da área que se desmembra). Assim, a criação de novos Municípios sem o cumprimento desses requisitos ensejaria a configuração de inevitável **vício formal** de inconstitucionalidade por violação a pressupostos objetivos do ato.

Havíamos alertado que a jurisprudência pacífica do STF consolidou-se no sentido da total observância dos pressupostos e condições de procedibilidade do art. 18, § 4.º.¹⁴⁸

Nessa linha, nos termos do voto-vista do Min. Gilmar Mendes, o Plenário do STF declarou inconstitucional a Lei baiana n. 7.619/2000, mas não pronunciou a nulidade do ato, mantendo sua vigência por mais 24 meses. O Min. Eros Grau, por sua vez, revendo o seu voto inicial, acompanhou o voto do Min. Gilmar Mendes também no sentido de declarar a inconstitucionalidade, mas não a nulidade, pelo prazo de 24 meses.

Utilizando a *técnica alternativa* de ponderação entre o **princípio da nulidade da lei**, de um lado, e o **princípio da segurança jurídica**, de outro, entendeu o STF que a lei é inconstitucional, mas, aplicando o art. 27 da Lei n. 9.868/99, e tendo em conta razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, apesar de inconstitucional por violar o art. 18, § 4.º, deverá continuar vigorando por 24 meses.

Consagra-se, dessa forma, a técnica da **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade**, já que, dependendo do caso concreto, como disse o Min. Gilmar Mendes, a “... nulidade da lei inconstitucional pode causar uma **verdadeira catástrofe** — para utilizar a expressão de Otto Bachof — do ponto de vista político, econômico e social”.

Observa Gilmar Mendes que o princípio da nulidade continua a ser a regra. “O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui, como no direito português, a não aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio”.

E, no Brasil, há uma particularidade de aspecto procedimental, qual seja, o *quorum* qualificado de 2/3 dos votos dos Ministros para reconhecer a **modulação de efeitos** com a possibilidade de estabelecer efeitos

prospectivos, ou *pro futuro*, ou a partir do momento que o STF entender razoável.

Nesse caso concreto, o prazo de 24 meses foi o que o STF entendeu ser possível para corrigir a situação, até porque, no julgamento da **ADO 3.682**, os Ministros reconheceram razoável o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional elaborar a lei complementar federal e, assim, dar cumprimento ao dispositivo fixado no art. 18, § 4.º, pela EC n. 15/96 (nova regra que o STF, inclusive, já declarou constitucional e como “freio” para o crescimento exagerado do número de Municípios).¹⁴⁹

Trata-se de reconhecimento da omissão com **apelo ao legislador**, para que elabore a lei dentro de 18 meses. Elaborada a lei complementar federal, os Municípios terão o prazo de mais 6 meses (já que se fixou em 24 meses o prazo de vigência das leis estaduais) para corrigir os vícios.

Parece-nos, aqui, que o STF, **diferentemente do entendimento que ainda adota como regra**,¹⁵⁰ admitiu, para esse caso concreto, uma **inédita** e inegável possibilidade do fenômeno da **constitucionalidade superveniente**, permitindo que uma lei que “nasceu” viciada (*vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato*) seja corrigida mediante um procedimento futuro de adequação ao art. 18, § 4.º.

E se não for elaborada referida LC federal pelo CN?

Conforme será discutido no *item 6.7.4.9* (julgamento da ADO 3.682), o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional elabore a LC federal nos termos do art. 18, § 4.º, foi fixado no dispositivo da decisão, tendo, assim, na linha de proposta da doutrina alemã, **caráter mandamental** (cf. a íntegra do acórdão — de *indispensável leitura*).

Nossa impressão é a de que teria sido imposta ao Congresso Nacional a obrigatoriedade de elaborar a lei, e, assim, se descumprida, tendo a decisão caráter mandamental, parece que o STF poderia determinar a elaboração ou, quem sabe, inclusive, por analogia, dentro da ideia de travamento de pauta, ou algum instrumento que derive do art. 64 e seus parágrafos, determinar medida coercitiva para o cumprimento, ou, ainda, na tendência de controle de

omissões, manifestada pelo STF no julgamento do **MI 712** (cf. *item 14.11.5.7*), quem sabe até mesmo suprir a omissão.

Cabe alertar, todavia, que, restringindo nossa opinião, o **Ministro Presidente do STF** determinou, em **12.09.2008**, por meio do *Ofício n. 346/GP*, fosse esclarecido ao Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando o inteiro teor do acórdão de fls. 132-187: **“não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável**, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI ns. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios”.

E se, elaborada a LC federal, os Municípios não se adequarem ao novo procedimento?

Como disse a Min. Ellen Gracie, o STF deu **sobrevida** à legislação atacada e fixou o prazo (para essa sobrevida) de 24 meses. Nesse sentido, nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “até 24 meses porque, aí, ou ele estará criado por novos atos ou estará **desconstituído**”, ficando, assim, na interpretação do Min. Marco Aurélio, o Município submetido a uma **condição resolutiva**. Dessa forma, pelo exposto nas discussões da ADI 2.240, o Município deixaria de existir, voltando ao *statu quo ante*.

A lei complementar não foi elaborada, e, na prática, a **EC n. 57/2008**, de maneira inconstitucional, convalidou os vícios indicados, tema que será discutido nos *itens 6.7.4.9 e 7.6.1*.

■ **6.7.1.10. Proibição do “atalhamento constitucional” e do “desvio de poder constituinte” (utilização de meio aparentemente legal buscando atingir finalidade ilícita)**

Conforme veremos no *capítulo 18* deste trabalho (*item 18.4*), a **EC n. 52/2006** buscou acabar, de vez, com a regra consagrada pelo TSE (*Res. n. 21.002/2002*) da obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias

em razão do caráter nacional dos partidos políticos.

Ao modificar o art. 17, § 1.º, CF/88, a EC n. 52/2006 estabeleceu ser assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, **sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal**, devendo seus estatutos prever normas de disciplina e fidelidade partidária.

O art. 2.º, EC n. 52/2006, por sua vez, determinou a aplicação do novo preceito (que acabava com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias) às eleições que ocorreram no ano de 2002. Sem dúvida, o objetivo dessa remissão era fazer com que a regra, supostamente direcionada para as eleições de 2002, pudesse já ser aplicada às eleições de 2006, na medida em que, aparentemente, intacta estaria a disposição contida no art. 16, CF/88.

Como se sabe (e estudaremos no *capítulo 18*), o art. 16, CF/88, consagra a regra da **anualidade eleitoral** ao dispor que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, **não se aplicando à eleição que ocorra em até um ano da data de sua vigência**.

O objetivo do art. 16 é assegurar a estabilidade e a segurança jurídica do processo eleitoral, evitando que as regras mudem no “meio do jogo”. Ou seja, a regra pode mudar, contudo só valerá a partir de um ano de sua vigência.

Pode-se afirmar, com o Min. *Ricardo Lewandowski*, em seu voto,¹⁵¹ que a manobra empreendida pelo constituinte reformador (art. 2.º, EC n. 52/2006) “... incorre no vício que os publicistas franceses de longa data qualificam de *détournement de pouvoir*, isto é, de ‘desvio de poder ou de finalidade’, **expediente mediante o qual se busca atingir um fim ilícito utilizando-se de um meio aparentemente legal**”.

E continua: “em outras palavras, repita-se, buscou-se, no caso, como se viu, **atalhar** o princípio (sic) da anualidade, dando efeito retroativo à emenda 52, promulgada em plena vigência do moralizador artigo 16 da Carta Magna. Trata-se, nas palavras do ilustre Professor Fábio Konder Comparato, que elaborou parecer sobre a matéria, de um ‘desvio de poder constituinte’, que

os autores alemães denominam *Verfassunsbeseitigung*, expressão que, traduzida literalmente, significa ‘**atalhamento da Constituição**’.

Consagra-se, portanto, a proibição de “**atalhamento da Constituição**”, vale dizer, qualquer artifício que busque abrandar, suavizar, abreviar, dificultar ou impedir a ampla produção de efeitos dos preceitos constitucionais, como, no caso, da regra da *anualidade eleitoral* (art. 16).

■ 6.7.1.11. *Inconstitucionalidade “chapada”, “enlouquecida”, “desvairada”*

A expressão “chapada” começou a ser utilizada pelo Min. Sepúlveda Pertence quando queria caracterizar uma inconstitucionalidade mais do que **evidente, clara, flagrante, escancarada**, não restando qualquer dúvida sobre o vício, seja formal, seja material.

Atualmente, vem sendo utilizada pelos Ministros, sempre no sentido inaugurado pelo Min. Pertence, destacando-se alguns julgados, como ADI 2.527, ADI 3.715, ADI 1.923-MC (cf. *Inf. 474/STF*), ADI 1.802-MC etc.

Inovando, o Min. Carlos Britto, no sentido de descrever uma inconstitucionalidade **manifesta**, chegou a caracterizá-la como “**enlouquecida, desvairada**” (ADI 3.232).

■ 6.7.1.12. *Início da eficácia da decisão que reconhece a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei em processo objetivo de controle abstrato*

De modo geral, o STF entende que a decisão passa a valer a partir da **publicação da ata de julgamento no DJE**, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, “exceto nos casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão” (cf. **ADI 711-QO**, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.08.1992, *DJ* de 11.06.1993 — critério adotado em julgamento de medida cautelar, mas que parece se adequar ao julgamento de mérito); Rcl 2.576 e *Notícias STF*, 23.06.2004; Rcl

3.309 e *Inf. 395/STF*; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Carlos Britto, j. 24.10.2007, *DJ* de 23.11.2007). Nesse sentido:

■ “EMENTA: 1. **Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida.** Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade — ADI 2.335 — a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no *Diário da Justiça* da ata da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC/73), **não impede a implementação da decisão.**¹⁵² Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente” (**Rcl 2.576**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2004, *DJ* de 20.08.2004).

Dessa forma, para a jurisprudência do STF, não se pode confundir, em se tratando de **ações objetivas de controle de constitucionalidade**,¹⁵³ a publicação da **ata de julgamento** com a publicação do **acórdão**.

O efeito da decisão passa a valer, **inclusive para eventual interposição de reclamação**, a partir da publicação da **ata** de julgamento no *DJE*. Publicado o acórdão, em momento seguinte, inicia-se o prazo para a interposição de eventual recurso, no caso dos processos objetivos em análise, dos embargos declaratórios. Só então, julgados os embargos, é que haverá a **certificação** do trânsito em julgado da decisão, sem que isso impeça, como visto, desde a publicação da ata, a produção dos **efeitos** da decisão. Pedimos, novamente, vênica para destacar a jurisprudência do STF:

“1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia *erga omnes* desde a publicação da **ata** de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (**Rcl 3.632-AgR**, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, *DJ* 18.08.2006. Nesse sentido, cf. decisão monocrática da Min. Cármen Lúcia na Rcl 17.446, j. 31.03.2014).¹⁵⁴

Para **abreviar** esse período (publicação da ata de julgamento e publicação do acórdão, com a certificação do trânsito em julgado), que em muitos casos já chegou a levar anos, **destacamos** a **Portaria n. 536/STF, de 16.10.2014**, que dispõe sobre o prazo para a publicação de acórdãos e já vem surtindo efeitos relevantes (para se ter uma ideia da gravidade da situação, mesmo diante da regra contida no art. 5.º, LXXVIII, CF/88, que trata da celeridade enquanto garantia fundamental, quando da publicação da referida Resolução, havia a pendência de publicação de cerca de 2.000 acórdãos proferidos pelas Turmas e pelo Plenário do STF!).

■ 6.7.1.13. **Competência (ADI genérica)**

A competência para processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade será definida em conformidade com a natureza do **objeto da ação**, qual seja, lei ou ato normativo federal, estadual, municipal ou distrital e o **parâmetro** ou **paradigma de confronto**, no caso, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Distrito Federal (que tem *status* de Constituição) ou qualquer preceito com força normativa constitucional (ampliação dentro da ideia de “bloco de constitucionalidade”, por exemplo, a EC n. 91/2016, que, sem introduzir qualquer artigo, seja no corpo ou mesmo no ADCT, alterou regra sobre perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, estabelecendo a possibilidade,

excepcional e em período determinado, de desfiliação, sem prejuízo do mandato). Vejamos as hipóteses.

■ **6.7.1.13.1. *Lei ou ato normativo federal ou estadual em face da CF***
(art. 102, I, “a”)

O art. 102, I, “a”, CF/88, estabelece que compete ao **STF**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, **originariamente**, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) de **lei ou ato normativo federal** ou **estadual**. Trata-se de controle concentrado, sendo a ação proposta diretamente no STF, de forma originária. Assim:

■ Lei ou ato normativo **federal/estadual** que contrariar a **CF → STF**.

■ **6.7.1.13.2. *Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da CE***
(art. 125, § 2.º)

O art. 125, § 2.º, CF/88, dispõe que caberá aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de **leis ou atos normativos estaduais ou municipais** em face da **CE**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Ou seja, cada Estado criará o seu sistema de controle concentrado de constitucionalidade, mas agora de lei ou ato normativo estadual ou municipal que contrariarem a Constituição do aludido Estado-Membro. Quem terá competência para o julgamento será o **Tribunal de Justiça do Estado** (TJ).¹⁵⁵ Vejamos o esquema:

■ Lei ou ato normativo **estadual/municipal** que contrariar a **CE → TJ local**.

■ **6.7.1.13.3. *Lei ou ato normativo municipal em face da CF***

Nesse caso, por falta de expressa previsão constitucional, seja no art. 102, I, “a”, seja no art. 125, § 2.º, por regra, **inexistirá controle concentrado originário por ADI genérica**, podendo a questão ser analisada incidentalmente no controle difuso, chegando ao STF via recurso extraordinário.

Esse silêncio acerca da hipótese do aludido controle concentrado no âmbito do STF, de forma proposital, é chamado de **silêncio eloquente** a traduzir uma regra, qual seja, a de que não cabe ADI genérica **no STF** tendo por objeto lei municipal confrontada em face da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF, pela ADI 347-SP, corroborando o entendimento acima exposto, suspendeu a eficácia do art. 74, XI, da CE/SP, que dizia ser o controle das leis municipais que contrariassem a CF feito pelo TJ local.

CUIDADO: a partir do julgamento do **RE 650.898** (1.º.02.2017), tendo sido o entendimento reafirmado na **ADI 5.646** (j. 07.02.2019), o STF estabeleceu a seguinte tese, excepcionando a regra geral acima exposta: “é constitucional o exercício pelos **Tribunais de Justiça** do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de **normas de reprodução obrigatória** pelos Estados-Membros” (nesse mesmo sentido manifestou-se novamente a Corte no julgamento da **ADI 5.647**, j. 04.11.2021).

Confrontar, por fim, a discussão exposta acima sobre a regra geral com a **arguição de descumprimento de preceito fundamental — ADPF**, estabelecida no art. 102, § 1.º, CF/88, regulamentada pela Lei n. 9.882/99 e por nós comentada no *item 6.7.3*, que admite referida ação tendo por objeto lei municipal perante a CF/88!

Como regra geral, o esquema é o seguinte:

■ Lei ou ato normativo **municipal** que contrariar a **CF** → **não há controle concentrado através de ADI genérica a ser julgada pelo STF, só difuso. Há, contudo, a possibilidade de ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por**

objeto lei municipal confrontada perante a CF e sendo julgada originariamente pelo STF.

■ **6.7.1.13.4. *Lei ou ato normativo distrital em face da CF/88***

No tocante ao Distrito Federal, o poder constituinte originário de 1988 deixou de fazer previsão expressa ao controle de constitucionalidade das leis emanadas do legislativo do Distrito Federal.

Apesar disso, o art. 32, § 1.º, dispõe que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos **Estados e Municípios**. Assim, o controle concentrado a ser exercido pelo STF será possível ou não de acordo com a natureza da norma constitucional elaborada pelo Distrito Federal. Vejamos:

■ Lei ou ato normativo **distrital** de **natureza estadual** que contrariar a **CF → STF**;

■ Lei ou ato normativo **distrital** de **natureza municipal** que contrariar a **CF → não há controle concentrado no STF através de ADI**,¹⁵⁶ **só difuso**. Há, contudo, a possibilidade do ajuizamento da **arguição de descumprimento de preceito fundamental** tendo por objeto lei ou ato normativo **distrital**, de natureza **municipal**, confrontada perante a **CF**. **CUIDADO:** pela atual jurisprudência do STF (RE 650.898 e ADI 5.646), admite-se, no âmbito do TJDF, o controle concentrado de constitucionalidade de leis distritais de natureza municipal, utilizando-se como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelo DF (cf. *item* 6.8.5.2).

■ **6.7.1.13.5. *Lei ou ato normativo distrital em face da Lei Orgânica Distrital***

De acordo com o art. 32, *caput*, CF/88, o Distrito Federal, vedada a sua divisão em Municípios, reger-se-á por **lei orgânica**. Indagamos, então: seria possível o controle concentrado de lei ou ato normativo distrital, em face da Lei Orgânica Distrital?

Fazendo pesquisa na jurisprudência do TJDF, encontramos julgados permitindo o referido controle, corroborados pelo Regimento Interno do TJDF (arts. 206 a 209). Vejamos:

■ “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei local em face da LODE. Competência. Liminar. Requisitos. I — O leito processual adequado para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de **lei local em face da lei orgânica do Distrito Federal** é a ação direta de inconstitucionalidade. II — Não há lacunas na Constituição Federal relativamente à competência para o processo e julgamento da ADI. Ocorre, tão só, falta de explicitude da Lei Maior. Tal competência é afeta ao **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**, por interpretação sistemática, quanto ao método, e extensiva, quanto ao alcance, dos arts. 125, § 2.º, e 32, § 1.º, da CF. III — O procedimento a ser adotado na ADI encontra-se descrito no *RISTF*, de aplicação subsidiária” (grifamos).¹⁵⁷

Esse entendimento jurisprudencial passou a encontrar expresso amparo legal. A **Lei n. 9.868/99**, que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e da ADC perante o STF, alterou a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 8.185/91), acrescentando a alínea “n” ao inciso I do art. 8.º, que atribui competência ao TJ local para processar e julgar, originariamente, a *ADI de lei ou ato normativo do DF em face da sua Lei Orgânica*.

Referida lei foi revogada pela **Lei n. 11.697/2008** (lei federal que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), que manteve a mencionada competência no art. 8.º, I, “n” e, ainda, estabeleceu, na alínea “o”, a atribuição para processar e julgar, originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua Lei Orgânica.

A previsão da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão), que já constava no art. 30 da Lei n. 9.868/99, foi mantida no art. 8.º, § 4.º, II, da Lei n. 11.697/2008.

Ainda, seguindo a orientação da Lei n. 9.868/99, nos termos do art. 8.º, § 5.º, da comentada Lei n. 11.697/2008, ficou mantida a regra no sentido de se aplicarem, no que couber, ao processo e julgamento da **ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica**, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

Esse entendimento, qual seja, apresentar-se a **Lei Orgânica do DF** como parâmetro ou paradigma de confronto, encontra-se pacificado na jurisprudência do STF:

“EMENTA: Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, anoto que, muito embora não tenha o constituinte incluído o Distrito Federal no art. 125, § 2.º, que atribui competência aos Tribunais de Justiça dos Estados para instituir a representação de inconstitucionalidade em face das constituições estaduais, a Lei Orgânica do Distrito Federal apresenta, no dizer da doutrina, a natureza de verdadeira Constituição local, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta confere a tal ente federado. Por essa razão, entendo que se mostrava cabível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pelo MPDFT no caso em exame” (RE 577.025, voto do Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2008, Plenário, *DJE* de 06.03.2009).

■ 6.7.1.13.6. *Lei municipal em face da lei orgânica do Município*

Nesse caso não estaremos diante de controle de constitucionalidade, mas de simples controle de **legalidade**, cujas regras deverão ser explicitamente previstas na Lei Orgânica de cada Município.

Manoel Carlos, de forma interessante, reconhecendo a natureza constitucional da lei orgânica de Município, sugere que a possibilidade de controle seja pela via incidental, como **abstratamente**, lembrando a previsão de controle concentrado de lei municipal em face da lei orgânica, nos termos do art. 61, I, “I”, da Constituição do Estado de Pernambuco.¹⁵⁸

Resta aguardar como o STF vai evoluir sobre esse assunto (**matéria pendente**), mostrando-se bastante sedutora a proposta doutrinária.

Por enquanto, contudo, parece que a melhor orientação (no caso dos *concursos públicos*) seria seguir a conclusão de André Ramos Tavares, no sentido de que o controle seria feito pelo **sistema difuso** apenas.¹⁵⁹

■ 6.7.1.14. **Legitimidade (ADI genérica)**

No tocante à legitimidade, estudaremos os legitimados para a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal, contestados em face da CF, sendo julgada pelo STF.

As partes legítimas para propositura da ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, contestados em face da CE perante o TJ local, serão especificadas em cada Constituição Estadual. O art. 125, § 2.º, CF/88, veda, no âmbito estadual, a atribuição da legitimação a um único órgão (cf. *item 6.8.4*).

A CF/88, ampliando o rol de legitimados, que até 1988 apenas se limitava ao Procurador-Geral da República (PGR), previu, em seu art. 103, que a ADI genérica, para questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual contestados em face da própria CF, poderá ser proposta (no plano da ADI no STF, o **rol é taxativo** — *numerus clausus*):

- I** — pelo Presidente da República;
- II** — pela Mesa do Senado Federal;
- III** — pela Mesa da Câmara dos Deputados;¹⁶⁰
- IV** — pela Mesa de Assembleia Legislativa de Estado ou pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (alterado pela EC n. 45/2004);¹⁶¹

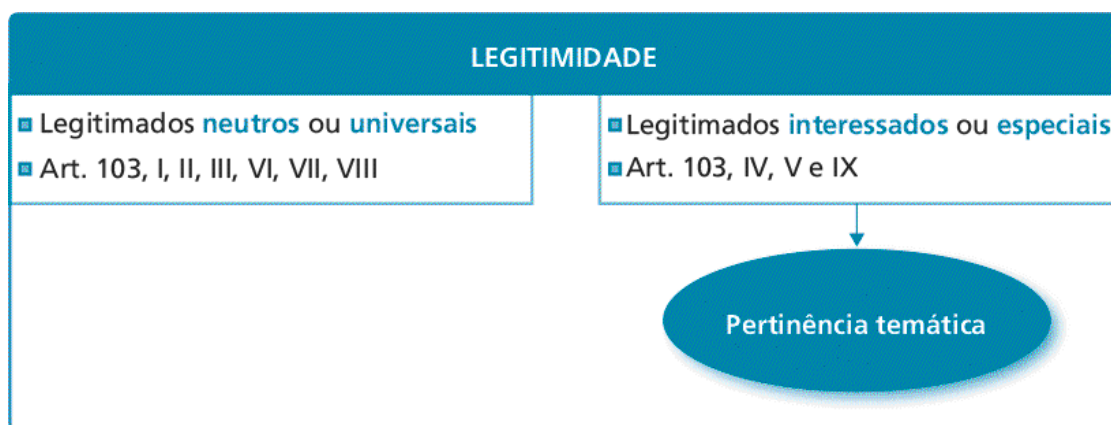
V — pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal (alterado pela EC n. 45/2004);¹⁶²

VI — pelo Procurador-Geral da República;

VII — pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII — por partido político com representação no Congresso Nacional;¹⁶³

IX — por confederação sindical^{164–165} ou entidade de classe¹⁶⁶ de âmbito nacional.



Quanto aos legitimados, o STF prescreve que alguns devem demonstrar interesse na aludida representação, em relação à sua **finalidade institucional**. Todos os membros acima citados são **neutros** ou **universais**, possuidores de **legitimação ativa universal**, ou seja, não precisam demonstrar a **pertinência temática**, exceto os dos incisos **IV** — *Mesa de Assembleia Legislativa de Estado* (e, como vimos, também a Mesa da Câmara Legislativa); **V** — *Governador de Estado* (também o Governador do DF) e **IX** — *confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional*, que são autores **interessados** ou **especiais**, ou seja, devem demonstrar o interesse na propositura da ação relacionado à sua finalidade institucional.

■ E “associação de associação” pode ser classificada como entidade de classe para a propositura da ADI?

Inicialmente, o STF negou legitimidade ativa à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) (ADI 591-MC/DF, RTJ 138/81) por se tratar de “associação de associação”.

Entretanto, a Suprema Corte **modificou o seu entendimento** ao analisar o caso concreto da *Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique (FENACA)*. Vejamos: “Associação de Associações: Legitimidade para ADI (Transcrições) (v. *Informativo* 356), ADI 3.153 AgR/DF, Relator p/ acórdão: Min. Sepúlveda Pertence. Voto: Presidente, volta ao Plenário um problema cuja solução, na jurisprudência da Corte, jamais, pessoalmente, me convenceu: é a que baniu da legitimação para a ação direta de inconstitucionalidade o que se tem chamado ‘associação de associações’. A meu ver, nada o justifica. Chegou-se a falar que uma ‘associação de associações’ só poderia defender os interesses das suas associadas, vale dizer, das associações que congrega. Mas, *data venia*, o paralogismo é patente. A entidade é de classe, da classe reunida nas associações estaduais que lhe são filiadas. O seu objetivo é a defesa da mesma categoria social. E o fato de uma determinada categoria se reunir, por mimetismo com a organização federativa do País, em associações correspondentes a cada Estado, e essas associações se reunirem para, por meio de uma entidade nacional, perseguir o mesmo objetivo institucional de defesa de classe, a meu ver, não descaracteriza a entidade de grau superior como o que ela realmente é: uma entidade de classe. No âmbito sindical, isso é indiscutível. As entidades legitimadas à ação direta são as confederações, que, por definição, não têm como associados pessoas físicas, mas, sim, associações delas. **Não vejo, então, no âmbito das associações civis comuns não sindicais, como fazer a distinção.** Peço todas as vênias ao eminente Relator — aliás já discutimos a respeito, desde pelo menos o caso CUT e CGT, na ADI 271 (lembrando, como visto em nota anterior, que o STF não admite a legitimação ativa das centrais sindicais citadas)¹⁶⁷ — para dar provimento ao agravo regimental, a fim de que se processe a ação direta” (*Inf. 361/STF*).

■ E as associações que representam fração de categoria profissional?

Conforme consta no *Inf. 826/STF*, “as associações que representam fração de categoria profissional não são legitimadas para instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapole o universo de seus representados. Com base nessa orientação, o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, desproveu agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se discutia a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (**ANAMAGES**). Na espécie, a referida associação questionava dispositivo da LC 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). A Corte assentou a ilegitimidade ativa da mencionada associação. Manteve o entendimento firmado na decisão agravada de que, se o ato normativo impugnado repercute sobre a esfera jurídica de toda uma classe, não seria legítimo permitir-se que associação representativa de apenas uma parte dos membros dessa mesma classe impugnasse a norma, pela via abstrata da ação direta” (ADPF 254, Min. Luiz Fux, 18.05.2016).

■ “Entidade de Classe” — a evolução da jurisprudência do STF: revisitação dos requisitos impostos pela jurisprudência defensiva (restritiva e de “autodefesa”) da Corte

A jurisprudência do STF, **em um primeiro momento**, consolidou-se no sentido de estabelecer o preenchimento de alguns requisitos para se caracterizar **entidade de classe** para o ajuizamento da ADI (art. 103, IX), quais sejam, a necessidade de ser entidade representativa de **categorias de natureza profissional** ou **econômica determinada** e, ainda, **homogênea**, no sentido de representar um único segmento. Vejamos os precedentes:

■ **ADI 89**: o STF negou legitimidade à União Nacional dos Estudantes (UNE), por entender tratar-se de **classe estudantil**, e não de classe profissional;

■ **ADI 386:** o STF passou a exigir que a entidade de classe preencha o requisito da **homogeneidade**. Nesse sentido, reafirmou a Corte: “a heterogeneidade da composição da autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do STF” (ADI 3.381, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.06.2007, Plenário. No mesmo sentido: ADI 3.805 AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.04.2009, Plenário. Cf., ainda, ADI 57, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 31.10.1991; ADI 941 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 21.10.1993).

CUIDADO: observa-se uma tendência/realidade de revisitação desses requisitos impostos pela jurisprudência defensiva (restritiva e de “autodefesa”) da Corte, destacando-se os seguintes julgados em sentido diametralmente oposto aos acima mencionados:

■ **ADPF 527-MC:** o Min. Barroso reconheceu a legitimação ativa da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), **mesmo não sendo uma categoria econômica ou profissional**. Vejamos a ementa: “superação da jurisprudência. A missão precípua de uma Suprema Corte em matéria constitucional é a proteção de direitos fundamentais em larga escala. Interpretação teleológica e sistemática da Constituição de 1988. **Abertura do controle concentrado à sociedade civil, aos grupos minoritários e vulneráveis**” (decisão monocrática proferida em 29.06.2018);¹⁶⁸

■ **ADI 3.413:** o STF reconheceu a legitimação ativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos — ABIMAQ: “o fato de a associação requerente congregar diversos segmentos existentes no mercado não a descredencia para a propositura da ADI — evolução da jurisprudência” (j. 1.º.06.2011), **afastando-se a necessidade de homogeneidade**.

Conforme observou o Min. Barroso no julgamento da **ADPF 324** (Pleno, j. 30.08.2018, *DJE* de 06.09.2019), a partir do julgamento da **ADI 4.079** (Pleno, j. 26.02.2015), que reconheceu a legitimação ativa da *Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação — CNTE*, “o critério que passou a determinar o reconhecimento da legitimidade ativa das associações de classe e das confederações sindicais passou a ser o **critério da ‘representatividade adequada’**, segundo o qual deve-se abandonar um critério formalista de aferição de tal legitimidade e adotar um **exame material**, a fim de verificar se a associação reúne suficientes membros de uma categoria a ponto de que possa falar em nome desta” (fls. 43).

Nessa linha, o Min. Marco Aurélio vinha sinalizando: “estou convencido, a mais não poder, ser a hora de o Tribunal **evoluir na interpretação do artigo 103, inciso IX**, da Carta da República, vindo a concretizar o propósito nuclear do constituinte originário — **a ampla participação social, no âmbito do Supremo, voltada à defesa e à realização dos direitos fundamentais**. A jurisprudência, até aqui muito restritiva, limitou o acesso da sociedade à jurisdição constitucional e à dinâmica de proteção dos direitos fundamentais da nova ordem constitucional. Em vez da participação democrática e inclusiva de diferentes grupos sociais e setores da sociedade civil, as decisões do Supremo produziram acesso seletivo. As portas estão sempre abertas aos debates sobre interesses federativos, estatais, corporativos e econômicos, mas fechadas às entidades que representam segmentos sociais historicamente empenhados na defesa das liberdades públicas e da cidadania” (**ADI 5.291**, j. 06.05.2015).

Nesse sentido, o Min. Barroso destacou estudo empírico: “um levantamento sobre as ações diretas de inconstitucionalidade apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, no período de 1988 a 2012, constatou que a maioria das ações diretas que versam sobre direitos fundamentais referem-se a interesses corporativos de servidores públicos, advogados públicos, magistrados, membros do Ministério Público etc. Obviamente, esse quadro tem íntima relação com quem pode propor uma ação direta. Se apenas entidades de classe representativas de interesses econômicos e profissionais

podem deflagrar o controle concentrado, esses serão os interesses debatidos nesse âmbito (...). Assim, limitar as entidades de classe às categorias econômicas e políticas significa valer-se do controle de constitucionalidade para preservar interesses de grupos que dispõem de força política e **frustrar o acesso à jurisdição constitucional justamente pelos grupos que mais precisam dela**".¹⁶⁹

Toda essa evolução foi mais uma vez destacada no julgamento da **ADPF 262 AgR**, pela qual o Pleno **superou a necessidade do requisito da homogeneidade**. Conforme bem anotou o Min. Barroso, as restrições que foram colocadas (pertinência temática, classe econômica e homogeneidade) são fruto da jurisprudência da Corte e não de previsão constitucional. O que deve haver é o efetivo controle da **"representatividade adequada"** e não a imposição de outras restrições que não estão previstas na Constituição (fls. 21). Conforme ficou sedimentado, "as Confederações Nacionais são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresse mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes" (j. 17.10.2018).¹⁷⁰

Assim, a proposta lançada pelo Min. Barroso em julgamento monocrático proferida na ADPF 527 parece trazer importante resumo sobre tudo o que se falou acima e marcar a linha de transformação (mutação) da jurisprudência da Corte: "considera-se classe, para os fins do 103, IX, CF/1988, o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma **atividade econômica, profissional** ou pela **defesa de interesses de grupos vulneráveis e/ou minoritários cujos membros as integrem**".

■ E a perda de representação do partido político no Congresso?

Tendo em vista a importância do novo entendimento, já anunciado em nota anterior, cabe destacar que o STF decidiu que a perda de representação do partido político no Congresso Nacional, após o ajuizamento da ADI, não descaracteriza a legitimidade ativa para o prosseguimento na ação. Dessa forma, "... a aferição da legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação..." (ADI 2.159 AgR/DF, Rel. orig. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 12.08.2004. Vencidos o Min. Carlos

Velloso, relator, e o Min. Celso de Mello, que consideravam que a perda da representação implicava a perda da capacidade postulatória).

■ E a necessidade de advogado?

O STF entendeu que somente os **partidos políticos** e as **confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional** é que precisarão contratar **advogado** para a propositura da ADI (art. 103, VIII e IX), devendo, no instrumento do mandato (procuração — art. 653, CC), haver a outorga de **poderes específicos** para atacar a norma impugnada, **indicando-a** (ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24.05.2000, Plenário, *DJ* de 12.12.2003). Quanto aos demais legitimados (art. 103, I-VII), a capacidade postulatória decorre da Constituição.

Nesse sentido: “O Governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, **possuem capacidade processual plena** e dispõem, *ex vi*, da própria norma constitucional, de **capacidade postulatória**. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado” (ADI 127-MC/QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.11.1989, *DJ* de 04.12.1992).

Devo alertar, contudo, que a 2.^a Turma do STF (e veja que a decisão foi tomada, no caso, por uma das Turmas do STF e não pelo Plenário), entendeu que, “... por ser uma decisão política, somente os legitimados no art. 103 da Constituição Federal, ou, por simetria, os que previstos em constituição estadual, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade”. Por outro lado, “os **atos de natureza técnica**, subsequentes ao ajuizamento da ação, devem ser empreendidos pelos **procuradores da parte legitimada**” (**RE 1.126.828 AgR/SP**, 2.^a T., j. 04.02.2020). Ou seja, muito embora os legitimados previstos nos incisos I a VII do art. 103 tenham legitimação ativa

e capacidade postulatória para iniciar o procedimento, ou melhor, para propor a ação, os atos técnicos dependeriam de órgão técnico.

CUIDADO: em momento seguinte, o Pleno do STF analisou novamente a questão da interposição de recurso extraordinário contra acórdão do TJ que julgou representação de inconstitucionalidade. Neste caso, o **Pleno** entendeu que “os **procuradores públicos** têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, **nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais**”, formalidade que não havia sido exigida pela 2.^a Turma do STF.

Neste novo julgado, “embora a petição de recurso extraordinário não tenha sido subscrita por prefeito municipal, mas somente por dois procuradores, sendo um deles o chefe da procuradoria do município, há, nos autos, **documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos**” (RE 1.068.600 AgR-ED-EDv/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.06.2020, DJE de 12.11.2020).

■ 6.7.1.15. *Procedimento e características marcantes do processo objetivo (ADI genérica)*

O procedimento vem delimitado nos §§ 1.º e 3.º do art. 103, CF/88, explicitado nos arts. 169 a 178, *RISTF*, bem como nas regras trazidas pela Lei n. 9.868, de 10.11.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Diversos aspectos da referida lei foram discutidos pelo STF nas ADIs 2.154 e 2.258. Em 03.04.2023, a Corte declarou a sua constitucionalidade, preservando os seguintes dispositivos:

- **art. 26:** veda o ajuizamento de ação rescisória;
- **art. 11, § 2.º, parte final:** prevê o efeito repristinatório na hipótese de concessão de medida cautelar;
- **art. 21:** medida cautelar na ADC;
- **art. 27:** possibilidade de modulação dos efeitos da decisão.

Como vimos, a ação será proposta por um dos legitimados do art. 103, CF/88, que deverá indicar na petição inicial o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, bem como o pedido, com suas especificações.

De acordo com o parágrafo único do art. 3.º da Lei n. 9.868/99, corroborando a jurisprudência do STF, a petição inicial, quando subscrita por advogado, deverá vir acompanhada de **procuração** (e, acrescente-se, outorgada com **poderes especiais** para a instauração do pertinente processo de controle normativo abstrato perante a Corte Constitucional, indicando, objetivamente, a lei ou o ato normativo e respectivos preceitos — quando for o caso — que estejam sendo levados à apreciação do Judiciário através da ADI — cf. STF, Pleno, ADI 2.187-7/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, *DJ* de 19.05.2000), e será apresentada em duas vias,¹⁷¹ devendo conter cópia da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

O art. 4.º da Lei n. 9.868/99 estabelece que a **petição inicial inepta, não fundamentada** e a **manifestamente improcedente** serão liminarmente **indeferidas** pelo **relator**. Contra essa decisão que indeferir a petição inicial caberá o recurso de **agravo** a ser interposto no prazo de **5 dias** (cf. art. 317, *RISTF*) e apreciado pelo **Pleno**.

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º),

passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, se dar em **dias úteis**.

Naturalmente, em se tratando de decisão do **Pleno** da Corte que não conhece de ação direta de inconstitucionalidade, **não será cabível o agravo**, já que só admissível contra decisão do **relator** que liminarmente indefere petição inicial (ADI 2.073-AgRQO, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.10.2000, DJ de 24.11.2000).

A jurisprudência do STF considera **manifestamente improcedente** a ação direta de inconstitucionalidade que versar sobre norma cuja constitucionalidade já tenha sido expressamente declarada pelo Plenário da Corte, **mesmo que em recurso extraordinário** (ADI 4.071-AgR, j. 22.04.2009. No mesmo sentido: **ADI 4.466**, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 13.02.2012. Sobre a tendência de *objetivação do recurso extraordinário*, cf. *item 6.6.5.6*).

Em referido julgado ressaltou-se a possibilidade de alteração da jurisprudência do Pleno, o que, entretanto, “pressupõe a **ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica**, ou, quando muito, a **superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes**”, o que não se verificou.

Não sendo o caso de indeferimento liminar, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, devendo tais informações ser prestadas no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido.

A jurisprudência do STF tem reconhecido a faculdade de o relator requisitar **informações complementares**, “... com o objetivo de permitir-lhe uma avaliação segura sobre os fundamentos da controvérsia” (ADI 2.982-ED e ADI 3.832, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 05.04.2010, DJE de 16.04.2010).

Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o **Advogado-Geral da União** e o **Procurador-Geral da República**, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias. O primeiro defenderá

o ato impugnado, enquanto o segundo poderá dar parecer tanto favorável como desfavorável.

Temos percebido, **contudo**, algumas situações nas quais o AGU, segundo orientação do STF, “não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade” (vide ADIs 1.616/PE, 2.101/MS, 3.121/SP e 3.415/AM). Ainda, evoluindo a jurisprudência firmada na ADI 72, a partir da **interpretação sistemática**, na **ADI 3.916**, entendeu o STF que a AGU tem **direito de manifestação** (cf. os vários precedentes no *item 12.3.7.4*).

O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades (art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99). Trata-se da importante figura do *amicus curiae*, que discutimos no *item 6.7.1.16.1* e seguintes.

Ainda, desde que haja necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o **relator** requisitar outras, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria (art. 9.º, § 1.º, da Lei n. 9.868/99).¹⁷²

O relator poderá, também, solicitar **informações** aos Tribunais Superiores, aos Tribunais Federais e aos Tribunais Estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.

Finalmente, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para o julgamento, lembrando que a definição de pauta e agenda do Plenário é atribuição do Ministro Presidente da Corte.

A declaração de inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada (ou mesmo de constitucionalidade no caso de improcedência da ADI, em razão de seu caráter dúplice ou ambivalente) será proferida se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos **6** Ministros (**maioria absoluta** — art. 97, CF/88), desde que observado o *quorum de instalação da*

sessão de julgamento, qual seja, a presença de pelo menos 8 dos 11 Ministros (arts. 22 e 23 da Lei n. 9.868/99).

De acordo com o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória, confirmando, assim, a ambivalência das referidas ações.

Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato.

Como já apontamos, de modo geral, o STF entende que a decisão passa a valer a partir da **publicação da ata da sessão de julgamento no DJE**, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, “exceto nos casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão” (cf. **ADI 711-QO**, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.08.1992, *DJ* de 11.06.1993 — critério adotado em julgamento de medida cautelar, mas que parece adequar-se ao julgamento de mérito; Rcl 2.576 e *Notícias STF*, 23.06.2004; Rcl 3.309 e *Inf. 395/STF*; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Carlos Britto, j. 24.10.2007, *DJ* de 23.11.2007).

Nos termos do art. 28 da Lei n. 9.868/99, dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o STF fará publicar em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União* a parte dispositiva do acórdão.

Por se tratar de **processo objetivo** de controle abstrato de constitucionalidade, algumas regras são muito importantes e particulares, destacando-se:

inexistência de prazo recursal em dobro ou diferenciado para ■ contestar, mesmo para a interposição de RE em sede de controle abstrato contra acórdão do TJ: a norma inscrita no art. 188 do CPC/73 (que determina que se compute em **quádruplo** o prazo para **contestar** e em **dobro** para **recorrer**, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público) restringe-se ao “... domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais”, **não** se aplicando, portanto, ao **processo objetivo** de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, *DJ* de 14.12.2001).¹⁷³

No CPC/2015, essa regra de “benefício de prazo” ou “prerrogativa de prazo” passou a ser o **prazo em dobro** (não havendo previsão de prazo em quádruplo) para **todas as manifestações processuais** do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública (arts. 180, 183 e 186). Esse benefício da contagem em dobro, contudo, não se aplica quando a lei estabelecer, **de forma expressa, prazo próprio** para o Ministério Público, para o ente público ou para a Defensoria Pública (arts. 180, § 2.º, 183, § 2.º, e 186, § 4.º). Assim, como a Lei n. 9.868/99 prevê os prazos próprios, a regra geral do prazo em dobro está excepcionada pela própria legislação e, portanto, não se aplica ao **processo objetivo** de controle abstrato de constitucionalidade, seguindo o mesmo entendimento que se tinha à luz do revogado CPC/73.

Muito embora o Min. Dias Toffoli tenha proposto a mudança dessa interpretação para a hipótese de RE em sede de controle abstrato estadual (ARE 661.288, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.05.2014, 1.ª T., *DJE* de 29.09.2014, fls. 7 do acórdão), o Pleno do STF não aceitou a tese, reafirmando a jurisprudência no sentido de não admitir o prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade (**ADI 5.814** e **ARE 830.727**, Pleno, j. 06.02.2019, e **AI 827.810**, Plenário Virtual, j. 22.03.2019).

Esse entendimento também deve ser aplicado para a hipótese de interposição de recurso extraordinário contra acórdão do TJ em ação de controle concentrado estadual (cf. *item* 6.8.5.3).

Isso porque, nessa hipótese, estamos diante da utilização de recurso inerente ao processo subjetivo (controle difuso — RE) no **processo objetivo** (controle concentrado — ADI genérica julgada pelo TJ), tanto é que a decisão proferida no acórdão do RE terá os mesmos efeitos da ADI genérica.

■ **inexistência de prazo prescricional ou decadencial**,¹⁷⁴

■ **não admissão da assistência jurídica a qualquer das partes, nem intervenção de terceiros**, de acordo com o art. 169, § 2.º, *RISTF* (conforme o art. 7.º da Lei n. 9.868/99), salvo a figura do *amicus curiae*;¹⁷⁵

■ **vedada, expressamente, a desistência da ação proposta**: de acordo com o art. 5.º, *caput*, da Lei n. 9.868/99;

■ **irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo**: o art. 26 da Lei n. 9.868/99 estabelece a irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória, **ressalvada** a interposição de **embargos declaratórios**.¹⁷⁶

Outra exceção a essa regra da irrecorribilidade, muito particular — e por isso aqui destacada —, é a hipótese de interposição de **recurso extraordinário** em face de acórdão do Tribunal de Justiça estadual em ADI estadual tendo por objeto lei estadual ou lei municipal contestada em face de norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal, ou mesmo, a partir de importante precedente, de norma de reprodução obrigatória da CF mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida no âmbito da CE (sobre esse modelo, cf. RE 650.898 e *item* 6.8.6).

■ **agravo**: muito embora a regra da irrecurribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo acima apontada, como visto, o art. 4.º da Lei n. 9.868/99 estabelece que a **petição inicial inepta, não fundamentada** e a **manifestamente improcedente** serão **liminarmente indeferidas** pelo **relator**. Contra essa decisão que indeferir a petição inicial cabe, de acordo com a literalidade do parágrafo único do referido art. 4.º da Lei n. 9.868/99, **agravo** a ser apreciado pelo **Pleno** e interposto no prazo de 5 dias contados da decisão do relator (art. 317, *RISTF*, até então denominado *agravo regimental*). **CUIDADO**: em relação ao prazo de interposição, devemos alertar, conforme já destacamos, que o CPC/2015 especificou a figura do chamado **agravo interno** contra a decisão proferida pelo relator, no prazo de **15 dias** (e não mais 5!), e nos parece que, de fato, nesse ponto, é a regra a ser adotada, afastando-se aquela prevista na legislação específica e no regimento interno (cf. arts. 1.021 e 1.070, CPC/2015). Naturalmente, em se tratando de decisão do **Pleno** que não conhece de ação direta de inconstitucionalidade, **não será cabível o agravo**, já que só admissível contra decisão do **relator** que liminarmente indefere a petição inicial (ADI 2.073-AgR-QO, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.10.2000, *DJ* de 24.11.2000);

■ **não rescindibilidade da decisão proferida**, tudo em razão da **natureza objetiva** do processo de ADI;

■ **não vinculação à tese jurídica (causa de pedir “aberta”)**: o STF, ao julgar a ADI, não está condicionado à *causa petendi*, não estando vinculado, portanto, a *qualquer* tese jurídica apresentada. Devem os Ministros apreciar o pedido de suposta inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, podendo, por conseguinte, decretar a inconstitucionalidade da norma por fundamentos diversos (STF, *RTJ* 46/352). Conforme vimos, ainda é possível, mesmo não havendo pedido expresso, a Corte nulificar outra lei ou ato normativo por arrastamento ou reverberação (cf. *item 6.7.1.5*).

Nesses casos, contudo, sustentamos que a regra contida no **art. 10 do CPC/2015** deveria ser observada. Conforme expresse, **o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar**, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Essa observância do contraditório, mesmo em processo objetivo, parece bastante salutar, sempre na busca da melhor interpretação a ser dada pela Corte.

Contudo, essa nossa proposta de aplicação do art. 10 do CPC/2015 parece não vir a ser reconhecida pela Corte. De fato, muito embora o art. 3.º, I, da Lei n. 9.868/99 exija a indicação dos **“fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”**, o STF tem afirmado, conforme vimos, que essa fundamentação não vincula a Corte (*causa petendi* aberta), que poderá, inclusive, “examinar a questão por fundamento diverso daquele alegado pelo requerente” (nesse sentido, ADI 1.749, Rel. p/ o ac. Min. Nelson Jobim, j. 25.11.1999, Pleno; ADI 2.728; ADI 2.213 e, já na vigência do CPC/2015, **ADI 3.796**, j. 08.03.2017, *DJE* de 1.º.08.2017).

E um alerta deve ser feito: a perspectiva de julgamento além do pedido deve ocorrer somente se admitida a técnica de julgamento da nulificação por arrastamento, havendo conexão com o objeto da ação. Isso porque, “embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, **o pedido da inicial deve ser certo e determinado**. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício” (**ADPF 347 TPI-Ref**, j. 18.03.2020).

■ **inexistência de impedimento ou suspeição**: “não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, **exceto** se o próprio Ministro firmar, por razões de **foro íntimo**, a sua não participação” (tese fixada no julgamento da **ADI 6.362**, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.09.2020, ratificando o posicionamento firmado em questão de ordem quando da apreciação da **ADI 2.238**, j. 24.06.2020. Precedente: **ADI 3.345**).

Conforme destacou o Min. Celso de Mello, “a diretriz jurisprudencial ora referida encontra fundamento na circunstância de que os institutos do impedimento e da suspeição **restringem-se ao plano dos processos subjetivos**, em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos, **não se estendendo nem incidindo, ordinariamente, no processo de fiscalização abstrata**, que se define como típico processo de **caráter objetivo** destinado a viabilizar ‘o julgamento não de uma relação jurídica concreta, mas de validade de lei em tese (...)’ (RTJ 95/999, Rel. Min. Moreira Alves)” (ADI 2.238, fls. 19). (Esse entendimento, em *obiter dictum*, já que esse não era o objeto específico da ação, foi reafirmado no julgamento da **ADI 5.953**, na qual a Corte, por 7 x 4, declarou inconstitucional o art. 144, VIII, CPC/2015, j. 22.08.2023, *DJE* de 18.10.2023. Destacamos, ainda, a específica confirmação da inexistência de impedimento ou suspeição nas ações de controle concentrado no julgamento da **ADI 2.231**, que tinha por objeto a própria lei da ADPF. Apesar de o Min. Gilmar Mendes ter declarado o seu impedimento em 07.06.2004, em razão de ter atuado no processo como AGU, valendo-se dos precedentes citados, manifestou-se pela inexistência de impedimento e votou acompanhando o relator no sentido da constitucionalidade da Lei n. 9.882/99 — Pleno, j. 22.05.2023, *DJE* de 15.06.2023.)

■ 6.7.1.16. **“Amicus curiae” (ADI e demais ações) e audiências públicas (“sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” — Peter Häberle)**

Peter Häberle, em conhecido estudo, propõe a ideia de que a interpretação não pode ficar restrita aos órgãos estatais, mas que deve ser **aberta** para todos os que “vivem” a norma (a Constituição), sendo, assim, esses destinatários, legítimos intérpretes, em um interessante **processo de revisão** da metodologia jurídica tradicional de interpretação.¹⁷⁷

Dentro dessa perspectiva de pluralização do debate, sem dúvida, os institutos do *amicus curiae* e das audiências públicas assumem um papel extremamente relevante.

■ 6.7.1.16.1. “*Amicus curiae*” — regras gerais

Conforme esclareceu o Min. Celso de Mello, “o pedido de intervenção assistencial, ordinariamente, não tem cabimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõem, em nosso sistema de direito positivo, de legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato (RDA 155/155, 157/266 — ADI 575-PI (AgRg), Rel. Min. Celso de Mello, v.g.)”. Isso porque, continua, “... o processo de fiscalização normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo (RTJ 113/22, 131/1001, 136/467 e 164/506-507)” (ADI 2.130-MC/SC, DJ de 02.02.2001, p. 145).

Essa regra está expressa no art. 7.º, *caput*, da Lei n. 9.868/99, que veda a “intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”.

No entanto, o art. 7.º, § 2.º, da referida lei estabelece que “o relator, considerando a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes**, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

O Min. Fachin descreveu com precisão a importância do *amicus curiae*, ou “amigo da Corte”: “como é sabido, a **interação dialogal** entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, **tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos que, não raro, excedem os limites estritos da controvérsia entre as partes em sentido formal**. Possibilita-se, assim, a produção de decisões **mais adequadas e legítimas** do ponto de vista do Estado Democrático de Direito” (ADI 6.500, j. 24.05.2021).

Passamos, então, a analisar a literalidade do dispositivo normativo acima citado (art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99):

■ **relator:** a admissão ou não do *amicus curiae* será decidida pelo relator, que verificará o preenchimento dos requisitos e a conveniência e oportunidade da manifestação. Destacamos que, mesmo admitido (pelo relator), o Tribunal poderá deixar de referendá-lo, afastando a sua intervenção (nesse sentido, cf. ADI 2.238, *DJ* de 09.05.2002);

■ **a decisão será mesmo irrecurável? SIM!** Conforme visto, a lei estabelece que o relator poderá, **por despacho irrecurável** (na verdade é uma decisão), **admitir** a manifestação de outros órgãos ou entidades (sobre o tema e evolução da jurisprudência, cf. *item* 6.7.1.16.9);

■ **requisitos:** relevância da matéria e representatividade dos postulantes. Na medida em que o *amicus curiae* deve ser reconhecido como um *colaborador da Justiça*, **não se pode admitir o deferimento do seu ingresso como um direito subjetivo processual do interessado**, mesmo que relevante a matéria e possuidor de representatividade adequada. Isso porque, além desses dois requisitos normativos, a jurisprudência do STF vem ainda exigindo (cf. ADI 3.460-ED): a) a oportunidade (ADI 4.071 AgR) e b) a utilidade das informações prestadas (ADI 2.321 MC);

■ **prazo para admissão:** vinha fixado no § 1.º do art. 7.º da Lei n. 9.868/99 (*prazo das informações*), que, no entanto, foi **vetado**. Nas razões do veto, o Presidente da República observa que “... eventual dúvida poderá ser superada com a utilização do prazo das informações previsto no parágrafo único do art. 6.º” (Mensagem n. 1.674/99). Trata-se do prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido de informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado (nesse sentido, cf. ADI 1.104). **Entendemos, contudo, que, dada a natureza e finalidade do *amicus curiae*, esse prazo poderá ser flexibilizado pelo relator, que terá discricionariedade para aceitar ou não a sua presença no processo**

objetivo, ainda que após o decurso do aludido prazo, ou, até mesmo, somente para a apresentação de sustentação oral, como se verificou na ADPF 46/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 20.06.2005). O objetivo do instituto do *amicus curiae* é auxiliar a instrução processual. Assim, em um primeiro momento, o STF entendeu como possível a sua admissão no processo até o início do julgamento. Uma vez em curso e já iniciado o julgamento, a presença do *amicus curiae* deverá ser rejeitada para evitar tumulto processual (nesse sentido, cf. ADI 2.238, Inf. 267/STF). Avançando, o STF **mudou o entendimento** e restringiu um pouco mais o momento. A partir do julgamento da **ADI 4.071** AgR/DF (Rel. Min. Menezes Direito, **22.04.2009**, DJE de 16.10.2009 e Inf. 543/STF), **o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta.**¹⁷⁸ Apesar desse entendimento (inclusive cobrado nos concursos públicos), destacamos algumas poucas decisões que permitiram o ingresso do *amicus curiae* em momento seguinte, diante de situações excepcionalíssimas, por exemplo, para garantir a paridade de armas em razão da sensibilidade da matéria (cf. RE 841.526, Rel. Min. Fux, j. 28.03.2016) e o primeiro precedente flexibilizando o entendimento: RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.08.2015. Há, ainda, alguns precedentes que superaram o marco estabelecido tendo em vista a **relevância da questão discutida** e a **representatividade da entidade postulante** (RE 597.064/RJ. No mesmo sentido, a questão preliminar debatida no julgamento do RE 760.931/DF, Tribunal Pleno. Nas hipóteses de indeferimento, há decisões admitindo a apresentação de memoriais pelos interessados — RE 597.064). E outros que superaram o marco temporal têm em vista a **“utilidade das informações trazidas em prol de uma compreensão mais adequada do tema”** (cf. ADPF 334, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2022, em razão de pedido formulado pelo Conselho Federal da OAB. No mesmo sentido, cf. ADI 4.395 e ADI 2.548).

A jurisprudência do STF vem estabelecendo que, uma vez admitido o *amicus curiae*, ele passa a ter direito de:

■ **apresentar sustentação oral I:** “... assinalo, por necessário, que, em face da decisão plenária proferida em questão de ordem suscitada na **ADI 2.777/SP**, Rel. Min. Cezar Peluso (*DJU* de 15.12.2003, p. 5), o ‘amicus curiae’, uma vez formalmente admitido no processo de fiscalização normativa abstrata, tem o direito de proceder à sustentação oral de suas razões, observado, no que couber, o § 3.º do art. 131 do *RISTF*, na redação conferida pela Emenda Regimental 15/2004” (ADI 3.345/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 29.08.2005. Nesse sentido, cf. ADI 3.540, *DJ* de 25.08.2005; ADI 3.498, *DJ* de 09.08.2005; ADPF 73, *DJ* de 08.08.2005; ADPF 46/DF, *DJ* de 20.06.2005; ADI 3.056, *DJ* de 06.06.2005);

■ **apresentar sustentação oral II:** nesse julgamento da ADI 2.777 o Min. Sepúlveda Pertence, “... considerando que a Lei 9.868/99 não regulou a questão relativa à sustentação oral pelo *amicus curiae*, entendeu que compete ao Tribunal decidir a respeito, através de norma regimental, razão por que, excepcionalmente e apenas no caso concreto, admitiu a sustentação oral. Vencidos os Ministros *Carlos Velloso* e *Ellen Gracie*, que, salientando que a admissão da sustentação oral nessas hipóteses poderia implicar a **inviabilidade de funcionamento da Corte**, pelo eventual excesso de intervenções, entendiam possível apenas a manifestação escrita” (ADI 2.777, *Inf.* 331/STF);

■ **apresentar sustentação oral III:** a tese vencedora que **admite a sustentação oral pelo *amicus curiae*** está consagrada, como visto, no **art. 131, § 3.º, do Regimento Interno do STF**, nos termos da Emenda Regimental n. 15, de 30.03.2004, com a seguinte redação: “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2.º do artigo 132 deste Regimento”. O *caput* do art. 132 estabelece que cada uma das partes

falará pelo tempo máximo de 15 minutos. Já o seu § 2.º determina que, se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles não se convencionar;

■ **limites de atuação:** porém, conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, é preciso deixar enfatizado que o *amicus curiae*, uma vez admitido seu ingresso no processo objetivo, tem direito a ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal, inclusive com direito a sustentação oral (Emenda Regimental n. 15/2004, *RISTF*), **mas não tem direito a formular pedido ou de aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação** (AC 1.362, j. 05.09.2006). Nesse sentido, “o *amicus curiae* **não** tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADPF 347 TPI-Ref, j. 18.03.2020).

Continuando, lembramos que o instituto do *amicus curiae* se consolidou no julgamento da ADI 2.130-MC/SC, no voto do Min. Celso de Mello (*DJ* de 02.02.2001, p. 145), pedindo vênica para destacar as suas principais passagens:

■ “a admissão de terceiro, na condição de *amicus curiae*, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como **fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte**, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma **perspectiva eminentemente pluralística**, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os **interesses gerais da coletividade** ou que expressem os **valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais**. Em suma: a regra inscrita no art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/99 — que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do *amicus curiae* —

tem por precípua finalidade **pluralizar o debate constitucional**” (grifamos);

■ “... a regra inovadora constante do art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/99, que, em caráter excepcional, **abrandou o sentido absoluto da vedação pertinente à intervenção assistencial**, passando, agora, a permitir o ingresso de entidade dotada de **representatividade adequada** no processo de controle abstrato de constitucionalidade” (grifamos);

■ “... entendo que a atuação processual do *amicus curiae* não deve limitar-se à mera apresentação de memoriais ou à prestação eventual de informações que lhe venham a ser solicitadas. Cumpre permitir-lhe, em extensão maior, o exercício de determinados poderes processuais, como aquele consistente no direito de proceder à **sustentação oral** das razões que justificaram a sua admissão formal na causa. Reconheço, no entanto, que, a propósito dessa questão, existe decisão monocrática, em sentido contrário, proferida pelo eminente Presidente desta Corte, na Sessão de julgamento da ADI 2.321-DF (medida cautelar)”;

■ assim, continua o ilustre Ministro, o STF, ao admitir a figura do *amicus curiae*, nas hipóteses previstas na lei e de acordo com a jurisprudência que se vem firmando, “... não só garantirá **maior efetividade** e atribuirá **maior legitimidade às suas decisões**, mas, sobretudo, **valorizará**, sob uma perspectiva eminentemente **pluralística**, o sentido **essencialmente democrático dessa participação processual**, enriquecida pelos elementos de informação e pelo acervo de experiências que o *amicus curiae* poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um processo — como o de controle abstrato de constitucionalidade — cujas **implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância e de inquestionável significação**”.

■ 6.7.1.16.2. É possível a admissão do “*amicus curiae*” na ADC?

SIM.

Essa questão parece bastante pertinente, especialmente diante do veto do § 2.º do art. 18 da Lei n. 9.868/99.

De fato, na mesma linha do art. 7.º, *caput*, o art. 18, *caput*, que também não foi vetado, veda a intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade.

O § 2.º do art. 18 tinha a mesma redação dada ao § 2.º do art. 7.º, o qual, por sua vez, não foi vetado, nos seguintes termos:

“§ 2.º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

Então, temos a seguinte situação: o dispositivo legal que admitia a figura do *amicus curiae* foi vetado para a ADC (ação declaratória de constitucionalidade), não o sendo para a ADI (ação direta de inconstitucionalidade).

Como poderemos demonstrar melhor no *item 6.7.1.17* (Efeitos da decisão), ADI e ADC são **ações dúplices** ou **ambivalentes**, ou seja, são ações “com sinais trocados”, já que a procedência de uma implica a improcedência da outra.

Essa tendência vinha sendo percebida na jurisprudência do STF (Rcl AgR-QO 1.880 — *Inf. 289/STF*), estando praticamente consolidada na **Reforma do Judiciário**, EC n. 45/2004. Isso porque os legitimados para as ações e os efeitos da decisão passaram a ser os mesmos. A única diferença ainda existente está no objeto da ADC, que continua sendo exclusivamente a **lei federal** (diferentemente da ADI, que tem por objeto tanto a lei federal como a estadual e a distrital de natureza estadual). Cabe alertar, contudo, que, na **PEC Paralela do Judiciário** (PEC n. 29-A/2000-SF e 358/2005-CD), o objeto da ADC passa a ser, também, além da lei federal, a estadual e a distrital de natureza estadual, fechando, em definitivo, essa situação de ambivalência. Resta aguardar a sua aprovação!

Diante do exposto, entendemos possível a aplicação, por analogia, da regra que admite o *amicus curiae* na ADI (art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99) para a ADC. Portanto, admissível, com as ressalvas já apresentadas, a figura do *amicus curiae* na **ação declaratória de constitucionalidade**.

Nesse sentido, o próprio Presidente da República já havia se posicionado nas razões do veto do art. 18, § 2.º (Mensagem n. 1.674/99): “o veto ao § 2.º constitui consequência do veto ao § 1.º. **Resta assegurada, todavia, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação sistemática, admitir no processo da ação declaratória a abertura processual prevista para a ação direta no § 2.º do art. 7.º**”.

■ 6.7.1.16.3. Cabe “*amicus curiae*” na ADPF?

SIM.

O art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99 tem a seguinte redação: “poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por **requerimento dos interessados no processo**”.

Dessa forma, observa-se que não há, no caso, dispositivo explícito tratando da figura do *amicus curiae*. Apesar dessa omissão normativa, o STF vem admitindo a sua presença, aplicando, por analogia, o art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, desde que se demonstrem a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes**.

Na **ADPF 46/DF**, o Min. Marco Aurélio posicionou-se pela sua admissibilidade, porém, como exceção à regra geral: “... é possível a aplicação, por analogia, ao processo revelador de arguição de descumprimento de preceito fundamental, da Lei n. 9.868/99, no que disciplina a intervenção de terceiro. Observe-se, no entanto, que a participação encerra exceção...” (DJ de 20.06.2005, p. 7).

Na **ADPF 73/DF**, o Min. Relator, Eros Grau, aceitou a figura do *amicus curiae* nos seguintes termos:

■ “DECISÃO: (Pet SR-STF n. 87.857/2005). Junte-se. 2. A Conectas Direitos Humanos requer sua admissão na presente ADPF, na condição de *amicus curiae* (§ 2.º do artigo 6.º da Lei n. 9.882/99). 3. Em face da relevância da questão, e com o objetivo de pluralizar o debate constitucional, aplico analogicamente a norma inscrita no § 2.º do artigo 7.º da Lei n. 9.868/99, admitindo o ingresso da peticionária, na qualidade de *amicus curiae*, observando-se, quanto à sustentação oral, o disposto no art. 131, § 3.º, do *RISTF*, na redação dada pela Emenda Regimental n. 15, de 30.03.2004. Determino à Secretaria que proceda às anotações. Publique-se. Brasília, 1.º de agosto de 2005” (*DJ* de 08.08.2005, p. 27).

Portanto, também com as ressalvas já expostas, concordamos que, excepcionalmente e desde que configuradas as hipóteses de cabimento, admitida será a presença do *amicus curiae* na ADPF (nesse sentido, confira: **ADPF 205**, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 16.02.2011, *DJE* de 24.02.2011; **ADPF 132**, Rel. Min. Carlos Britto, decisão monocrática, j. 29.04.2009, *DJE* de 07.05.2009, e, ainda, **ADPFs 33 e 183**).

■ 6.7.1.16.4. Cabe “*amicus curiae*” na ADO?

SIM.

O art. 12-E da Lei n. 9.868/99, incluído pela Lei n. 12.063/2009, determina sejam aplicadas, ao procedimento da **ação direta de inconstitucionalidade por omissão**, no que couber, “as disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei”.

Assim, uma vez que a previsão do *amicus curiae* para a ADI consta da referida Seção (art. 7.º, § 2.º) e sendo compatível com a ação em análise, entendemos **perfeitamente possível a admissão de *amicus curiae* na ADO**, buscando a pluralização do debate.

Ainda, o art. 12-E, § 1.º, da referida lei estabelece que os demais titulares da ADO poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no

prazo das informações, bem como apresentar memoriais, o que, em nosso entender, na medida em que, na hipótese, não propuseram a ação, serão considerados *amicus curiae*.

■ 6.7.1.16.5. Cabe “*amicus curiae*” na IF (representação interventiva)?

SIM.

O art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011 permite sejam autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de **interessados no processo**, utilizando a mesma nomenclatura (“interessados no processo”) do art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99, que fundamenta a possibilidade do *amicus curiae* na ADPF.

Assim, de acordo com os precedentes utilizados para a ADPF, parece razoável aceitar, excepcionalmente, e nos termos do art. 7.º, § 2.º (ADI), aqui aplicado por analogia, o ***amicus curiae* na representação interventiva** (art. 36, III).

■ 6.7.1.16.6. Outras hipóteses de cabimento do “*amicus curiae*”

Em interessante trabalho,¹⁷⁹ Gustavo Santana Nogueira, além das situações já analisadas, identifica outras hipóteses de cabimento do *amicus curiae*, não desenvolvidas neste estudo em razão de nosso objetivo, mas que devem ser observadas especialmente para as provas de direito processual civil:

- art. 31 da Lei n. 6.385/76 — processos de interesse da CVM;
- art. 118 da Lei n. 12.529/2011 — nos processos judiciais em que se discuta a aplicação da referida Lei n. 12.529/2011, que, dentre outras providências, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente;

- art. 950, § 3.º, CPC/2015 (art. 483, § 3.º, CPC/73) — controle difuso de constitucionalidade;
- art. 14, § 7.º, da Lei n. 10.259/2001 — no âmbito dos Juizados Especiais Federais.¹⁸⁰

Podemos lembrar, ainda, duas importantes hipóteses de *amicus curiae* que são brevemente retomadas no estudo da “repercussão geral” (item 11.8.1.3) e da súmula vinculante (item 11.14):

- art. 3.º, § 2.º, da Lei n. 11.417/2006 — procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF;
- art. 543-A, § 6.º, CPC/73, introduzido pela Lei n. 11.418/2006 — análise da repercussão geral pelo STF no julgamento do recurso extraordinário (cf. arts. 1.035, § 4.º, e 1.038, I, CPC/2015).

Finalmente, destacamos uma previsão bastante ampliada do instituto do *amicus curiae* nos termos do art. 138, CPC/2015, que o admite para as causas em geral, desde que se demonstre a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Além disso, conforme estudaremos no item seguinte, a previsão explícita e geral é de que o *amicus curiae* poderá ser **pessoa natural**.

■ 6.7.1.16.7. ***Parlamentar pode ser admitido no processo como “amicus curiae”? (Novidade mais ampla introduzida pelo CPC/2015 — Lei n. 13.105/2015)***

Depois de muito pensar, concordamos com importante e arrojada decisão de **Edson Alfredo Smaniotto**, à época Desembargador do **TJDF** e relator nos autos da ADI 2004.00.2.008459-7 (decisão em 30.09.2005).

Em suas palavras, avançando “numa análise mais aproximada, tem-se que o postulante, parlamentar, foi designado por via eleitoral para desempenhar função política na democracia representativa sobre a qual se funda o regime democrático instituído no país (CF, art. 1.º), e nesta condição,

desenvolve e materializa a cidadania e o direito de representatividade do povo, verdadeiro titular do poder. Sua postulação no processo se dará *erga omnes*”.

Assim, em nosso entender, desde que fique demonstrado que o parlamentar atua como “representante ideológico” de uma coletividade **(representatividade adequada)**, e não em busca de interesse individual egoístico, perfeitamente possível a sua admissão como *amicus curiae* (o tema precisa ser mais bem explicitado pelo STF, apesar de alguns poucos precedentes admitindo a figura de parlamentar como *amicus curiae* — *pendente*).¹⁸¹

Para se ter um exemplo de precedente da Suprema Corte, destacamos a decisão monocrática proferida pelo Min. Barroso, nos seguintes termos: “o Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Junior requer o ingresso no feito, a título de *amicus curiae* (Petição 12.658/2019). Dada a **relevância da matéria** e a **possibilidade de contribuir para a apresentação de pontos de vista diversos** daqueles apontados pelo requerente e pela maioria dos *amici curiae* e, portanto, de modo a assegurar a **pluralidade de opiniões, excepcionalmente**, defiro seu ingresso no feito, tal como requerido (art. 7.º, § 2.º, Lei n. 9.868/1999)” (ADPF 527-MC, j. 25.08.2021).

CUIDADO: cabe alertar que o STF, de modo genérico, **não vem admitindo** o ingresso de **pessoa física** como *amicus curiae*, destacando-se, nesse sentido, o voto do Min. Cezar Peluso na **ADI 4.178/GO**:

“... 4. Não assiste razão ao pleito de (...), que requerem admissão na condição de *amici curiae*. É que os requerentes são **pessoas físicas**, terceiros concretamente interessados no feito, **carecendo do requisito de representatividade** inerente à intervenção prevista pelo art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, o qual, aliás, é explícito ao admitir somente a manifestação de outros ‘órgãos ou entidades’ como medida excepcional”.

Entendemos que essa visão mais restrita da Suprema Corte viola o *Novo Código de Processo Civil*, que, de maneira genérica, admite a **pessoa física** como *amicus curiae*, nos seguintes termos:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de **pessoa natural** ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação.

§ 1.º A intervenção de que trata o *caput* não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3.º.

§ 2.º Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3.º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Para o STF, contudo, em regra, a **pessoa física** não possui representatividade para intervir em ações de controle concentrado como *amicus curiae*, com exceção dos exemplos trazidos e em situações excepcionais, de requerimento feito por Parlamentar no sentido de “representante ideológico” de uma coletividade.

■ 6.7.1.16.8. *Natureza jurídica do “amicus curiae”*

Do ponto de vista burocrático, o STF, ao fazer a anotação no processo e indicar o andamento na Internet, aponta o *amicus curiae* como “**parte interessada**”.

O Min. Maurício Corrêa, no julgamento da ADI 2.581 AgR/SP, chegou a afirmar que o *amicus curiae* atua como “colaborador informal da Corte”, não configurando, “... tecnicamente, hipótese de intervenção *ad*

coadjuvandum (AGRADI 748-RS, Celso de Mello, DJ de 18.11.1994). Assim, como **mero colaborador informal**, o *amicus curiae* não está legitimado para recorrer das decisões proferidas em ação direta” (DJ de 18.04.2002).

No julgamento do RE 602.584 (17.10.2018), o Colegiado reafirmou não ser parte o *amicus curiae*, mas um **agente colaborador**. “Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito. O privilégio acaba quando a sugestão é feita” (Inf. 920/STF).

O Min. Celso de Mello, conforme destacamos no julgamento da ADI 2.130, referiu-se a uma **“intervenção processual”**.

O art. 131, § 3.º, do Regimento Interno do STF, nos termos da Emenda Regimental n. 15, de 30.03.2004, passou a admitir uma declarada hipótese de **intervenção de terceiros**.

É claro que a sua natureza jurídica é **distinta** das modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC, até em razão da natureza do processo objetivo e abstrato do controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, por todo o exposto, parece razoável falarmos em uma **modalidade sui generis de intervenção de terceiros**, inerente ao processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, com características próprias e muito bem definidas.

Por esse motivo, a previsão no CPC/2015 deve ser interpretada nos termos acima apresentados, “temperando” a posição topológica do instituto: Capítulo V (“Do *amicus curiae*”); Título III (**“Da intervenção de terceiros”**); Livro III (“Dos sujeitos do processo”).

■ 6.7.1.16.9. “*Amicus curiae*” pode interpor recurso?

NÃO.

A atual jurisprudência do STF, aplicando a literalidade normativa, entende que tanto a decisão do relator que **indefer** o pedido de ingresso do *amicus curiae* como a que **defer** o ingresso são **irrecorríveis**.

O *amicus curiae*, ainda, por se tratar de **terceiro estranho à relação processual**, não pode interpor recurso, impugnando o acórdão proferido nas ações de controle concentrado, para discutir a **matéria** em análise no processo objetivo perante o STF.

De acordo com a regra geral, a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é **irrecorrível**, ressalvada a interposição de **um único recurso**, qual seja, os **embargos declaratórios** (art. 26, Lei n. 9.868/99).

No caso, contudo, entende o STF que “o *amicus curiae* não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, **sendo inaplicável o art. 138, § 1.º, do CPC**, às ações de controle concentrado de constitucionalidade” (ADIs 3.356, 3.357, 3.937, 3.406 e 3.470 e ADPF 109, j. 23.02.2023, **vencidos os Mins. Fux e Fachin**, que propõem a revisitação desse entendimento jurisprudencial. Cf., também, no sentido do não cabimento de embargos declaratórios, ADI 4.389-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14.08.2019, *DJE* de 18.09.2019, e ADI 6.533-ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, *DJE* de 1.º.09.2021).

Voltemos ao primeiro item da nossa análise. Conforme visto, a lei (art. 7.º, § 2.º, Lei n. 9.868/99 e art. 138, CPC/2015) estabelece que o relator poderá, **por despacho irrecurável** (na verdade é uma **decisão**), **admitir** a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Apesar da regra, em um primeiro momento, vários precedentes no STF admitiam a interposição do recurso de **agravo interno** (art. 1.021 do CPC/2015) na hipótese de indeferimento do ingresso (cf.: ADI 3.105 ED, ADI 3.934 ED-AgR, ADI 3.615 ED, ADI 2.591 ED, ADI 5.022 AgR).

A matéria começou a ser **revista** no julgamento da ADI 3.396-ED, e, tendo em vista o empate em 5 x 5, em 25.05.2016, o processo foi suspenso. Enquanto se aguardava o voto de desempate pela Min. Cármen Lúcia, em 17.10.2018, verificou-se verdadeira **viragem jurisprudencial**, passando a Corte a **não mais admitir a interposição de recurso tanto no caso de admissão como no de indeferimento (RE 602.584 AgR)**.

Dentre os argumentos a justificar o novo posicionamento podemos destacar a própria essência de **colaborador da Corte**, assim como a dita vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. Conforme vimos, o art. 138 do CPC/2015 “é explícito no sentido de conferir ao juiz competência discricionária para admitir ou não a participação, no processo, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, e de não admitir recurso contra essa decisão” (*Inf. 920/STF*).

Outro ponto a justificar a nova orientação seriam os “possíveis prejuízos ao andamento dos trabalhos da Corte decorrentes da admissibilidade do recurso, sobretudo em processos em que há um grande número de requerimentos de participação como *amicus curiae*”.

Em 06.08.2020, o STF mudou, novamente, o seu entendimento, havendo o julgamento final da **ADI 3.396-ED**, que estava pendente. Por 6 x 5, a Corte, resgatando o primeiro entendimento, passou a admitir a interposição de recurso contra a decisão que **nega ingresso** de *amicus curiae* em ação direta de inconstitucionalidade.

Alertamos que desse julgamento não participaram alguns Ministros da atual composição. O Min. Alexandre de Moraes não se pronunciou, pois já havia voto proferido pelo Min. Peluso, o seu antecessor. No mesmo sentido, não tivemos o voto do Min. Kássio Nunes, que tomou posse em 05.11.2020, tendo em vista o voto do seu antecessor, o Min. Celso de Mello, que votou admitindo o agravo. O Min. André Mendonça, que tomou posse em 16.12.2021, também não votou, em razão de já haver voto proferido pelo Min. Marco Aurélio admitindo o recurso contra o indeferimento. Não tivemos, também, o voto do Min. Cristiano Zanin, que tomou posse em 03.08.2023 (cf., também, ADPF 747 AgR).

CUIDADO: conforme alertamos acima, **a atual composição do STF**, aplicando a literalidade normativa, resgatou o entendimento firmado no precedente da primeira viragem jurisprudencial (**RE 602.584 AgR**), estabelecendo o seguinte entendimento: tanto a decisão do relator que **indefere** o pedido de ingresso do *amicus curiae* como a que **defere** o ingresso são **irrecorríveis** (nesse sentido, cf.: **ADI 5.728 AgR**, Pleno, 10 x 0,

j. 29.11.2021, *DJE* de 15.02.2022, e **RE 607.109 AgR-segundo**, Pleno, 10 x 0, j. 20.09.2021, *DJE* de 27.09.2021. Cf., ainda, ADI 6.415 AgR, ADI 4.711 AgR, ADI 2.675, RE 602.584 AgR, ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, ADI 3.608 AgR e ADO 70 AgR, j. 04.07.2022).

■ 6.7.1.16.10. *Audiências públicas*

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, **poderá o relator** requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em **audiência pública**, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria (arts. 9.º, § 1.º, e 20, § 1.º, da Lei n. 9.868/99 e art. 6.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99).

Além da atribuição fixada ao **relator** (art. 21, XVII, *RISTF*), nos termos do art. 13, XVII, *RISTF*, compete ao **Presidente do STF** convocar **audiência pública** para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal, o que nos permite afirmar que a previsão não se resume aos processos de ADI, ADC e ADPF.

Nesse particular, interessante destacar a **primeira audiência pública** realizada no Brasil, em processo jurisdicional de controle concentrado de constitucionalidade, na data de **20.04.2007**, em cumprimento ao preceituado no art. 9.º, § 1.º, da Lei n. 9.868/99 (portanto, quase 8 anos após a sua previsão na referida lei).

Tratava-se da **ADI 3.510**, proposta pelo PGR, contra a utilização de células-tronco de embriões humanos em pesquisas e terapias. Conforme aprofundamos no *item 14.10.1.2*, o STF entendeu, por 6 x 5, que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida, nem mesmo a dignidade da pessoa humana, julgando, assim, improcedente o pedido formulado na ação.¹⁸²

■ 6.7.1.17. *Efeitos da decisão (ADI genérica)*

A ação em comento tem caráter **dúplice** ou **ambivalente**, pois, conforme estabelece o art. 24 da Lei n. 9.868/99, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e, no mesmo passo, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Em outras palavras: a procedência de uma implica a improcedência da outra (ações com “sinais trocados” — cf. a perspectiva gráfica dessa ambivalência no *item* 6.7.2.5).

De modo geral, a decisão no controle concentrado produzirá efeitos contra todos, ou seja, **erga omnes**, e também terá efeito retroativo, **ex tunc**, retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição. Trata-se, portanto, de **ato nulo**.

No entanto, acompanhando o direito alemão e o português, entre outros, a Lei n. 9.868/99, em seu art. 27, introduziu a técnica da **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade**. Nesse sentido, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria qualificada de **2/3** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, diante de tais requisitos, o STF poderá dar **efeito ex nunc**.¹⁸³

Além da eficácia contra todos (*erga omnes*), já comentada, o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99 dispõe que a decisão também terá **efeito vinculante**.

Em um primeiro momento, antes da posição firmada na jurisprudência do STF e das novidades trazidas pela **EC n. 45/2004**, tínhamos o entendimento de que esse dispositivo deveria ser interpretado acompanhando o posicionamento do Min. Sepúlveda Pertence, que dizia ser tal vinculação possível somente nos casos em que, em tese, seria cabível a ADC, devendo o STF assim se pronunciar, sob pena de se dizer mais do que a Constituição estabeleceu.¹⁸⁴

Em relação ao tema, **contudo**, concluindo o julgamento de questão de ordem em agravo regimental interposto contra decisão do Min. Maurício Corrêa, relator — que não conheceu de reclamação ajuizada pelo Município de Turmalina-SP em que se pretendia ver respeitada a decisão proferida pelo STF na ADI 1.662-SP por falta de legitimidade ativa *ad causam* do reclamante —, o STF, por maioria (8 x 3, vencidos os Mins. Moreira Alves, Ilmar Galvão e Marco Aurélio), **declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99**, considerando que a **ação declaratória de constitucionalidade (ADC)** consubstancia uma **ação direta de inconstitucionalidade (ADI)** com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice, sendo os seus efeitos, portanto, semelhantes.¹⁸⁵ Essa interpretação, como veremos a seguir, foi expressamente consagrada com a **Reforma do Judiciário**, EC n. 45/2004, ao dar nova redação ao art. 102, § 2.º, CF/88.

Logo, para as provas de concurso, adotar o entendimento de que a **declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado**, em **abstrato**, em **tese**, marcada pela **generalidade, impessoalidade e abstração**, faz instaurar um **processo objetivo**, sem partes, no qual inexistente litígio referente a situações concretas ou individuais (RTJ 147/31, Rel. Min. Celso de Mello), tornando os atos inconstitucionais **nulos** e, por consequência, **destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica**, com alcance, de modo vinculado e para todos, sobre os **atos pretéritos**, fazendo com que, para se ter uma ideia da amplitude desses efeitos, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo que tenha “revogado” outro ato normativo (nossa análise neste ponto refere-se à ADI perante o STF, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou distrital, desde que no exercício da competência estadual) provoque o **restabelecimento do ato normativo anterior**. Os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, por meio de ADI, podem ser assim resumidos:

■ **erga omnes**;

■ **ex tunc**;

■ **vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.**

Excepcionalmente, porém, como exceção à regra geral do princípio da nulidade, tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria qualificada de **2/3 de seus Ministros**,¹⁸⁶ restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Excepcionalmente, então, os Ministros do STF poderão restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que, na hipótese específica e desde que preencha os requisitos formal (*quorum* **qualificado de 2/3**) e material (**razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**), serão:

■ ***erga omnes***;

■ ***ex nunc***; ou **outro momento a ser fixado pelos Ministros do STF, podendo a modulação ser em algum momento do passado, no momento do julgamento, ou para o futuro (efeito prospectivo)**;

■ **vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.**

Alertamos que não há necessidade de suspensão da execução da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, por decisão definitiva do STF, por meio de resolução do Senado Federal no controle concentrado. Isso porque o **art. 52, X, só se aplica ao controle difuso!**¹⁸⁷ (**CUIDADO:** essa perspectiva deve ser reanalisada à luz da **nova realidade**, qual seja, o reconhecimento pelo STF da **mutação constitucional do art. 52, X**, conforme explicamos no *item 6.6.5.5*, no julgamento das ADIs 3.406 e 3.470, no sentido de que, tanto no controle difuso como no controle concentrado, o papel do Senado Federal seria para dar mera publicidade à decisão, sendo que o efeito *erga omnes* e vinculante decorreria da própria decisão do STF).

No tocante ao controle concentrado, para sedimentar, transcrevemos a regra trazida no § 2.º do art. 102, constitucionalizando, de uma vez por todas, o caráter dúplice ou ambivalente da ADI e da ADC: “§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Conforme vimos no *item 6.7.1.8*, o efeito vinculante atinge somente o **Judiciário** e o **Executivo**,¹⁸⁸ não se estendendo para o Legislativo no exercício de sua função típica de legislar (nem atingindo, conforme sugerimos, as funções atípicas normativas tanto do Judiciário como do Executivo, quando, por exemplo, o Presidente da República edita uma medida provisória). O Legislativo poderá, inclusive, editar nova lei em sentido contrário à decisão do STF em controle de constitucionalidade concentrado ou edição de súmula vinculante. Entendimento diverso significaria o **“inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição”** (cf. **Rcl 2.617**, *Inf. 386/STF*).

Nesse sentido, no tocante à não vinculação ao legislador ao editar uma lei com conteúdo idêntico àquela objeto da ADI, contra esse novo ato normativo **não caberá reclamação constitucional** sob o argumento de violação à tese jurídica firmada na ação de controle concentrado (mesmo que admitida a tese da transcendência dos motivos determinantes), devendo, no caso, ser proposta uma **nova ADI**, em razão do **novo objeto**.

■ 6.7.1.17.1. *Princípio da parcelaridade*

O **princípio da parcelaridade** aplica-se ao controle concentrado. Isso significa que o STF pode julgar parcialmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, expurgando do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferentemente do que ocorre com o veto presidencial, como veremos ao estudar o processo legislativo (art. 66, § 2.º).

Isso porque, e já adiantando a matéria, o Presidente da República, ao vetar determinado projeto de lei (controle de constitucionalidade prévio ou preventivo, realizado pelo Executivo), poderá fazê-lo **integralmente** (veto de todo o projeto de lei) ou **parcialmente**; nesta última hipótese, porém, o veto só poderá ser de **texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea (art. 66, § 2.º, CF).

Por outro lado, o Judiciário, ao realizar o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade, poderá expungir do texto normativo uma expressão, uma só palavra, uma frase, não havendo necessidade de declarar inconstitucional um texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, como acontece com o controle realizado pelo Chefe do Executivo.

Trata-se de interpretação conforme **com redução de texto**, verificada, por exemplo, na ADI 1.227-8, suspendendo a eficácia da expressão “desacato” do art. 7.º, § 2.º, Estatuto dos Advogados.

■ 6.7.1.17.2. ***Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto***

Muitas vezes, o STF pode declarar que a mácula da inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a **interpretação conforme**, pela qual não se configura a inconstitucionalidade.

Importante notar que em hipótese alguma poderá o STF funcionar como *legislador positivo*. A interpretação conforme só será admitida quando existir um **espaço para a decisão** do Judiciário, deixado pelo Legislativo. A interpretação não cabe quando o sentido da norma é **unívoco**, mas somente quando o legislador deixou um campo com diversas interpretações, cabendo ao Judiciário dizer qual delas se coaduna com o sentido da Constituição. O Judiciário, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei, deve sempre atuar como **legislador negativo**, sendo-lhe vedado, portanto, instituir norma jurídica diversa da produzida pelo Legislativo.

■ 6.7.1.17.3. ***Efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Necessidade de impugnação de todo o “complexo normativo”***

O controle concentrado por meio da ADI é marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração e faz instaurar um **processo objetivo**, sem partes, no qual inexistente litígio referente a situações concretas ou individuais (RTJ 147/31, Rel. Min. Celso de Mello).

Nesse sentido, a declaração de inconstitucionalidade reconhece a **nulidade** dos atos inconstitucionais e, por consequência, a inexistência de qualquer carga de eficácia jurídica. Assim, dentre tantos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo que tenha “revogado” outro ato normativo (*nossa análise neste ponto refere-se à ADI perante o STF, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou distrital, desde que no exercício da competência estadual*) provoca o restabelecimento do ato normativo anterior, quando a decisão tiver efeito retroativo.

O STF vem utilizando a expressão **“efeito repristinatório”** (cf. ADI 2.215-PE, medida cautelar, Rel. Min. Celso de Mello, *Inf.* 224/STF) da declaração de inconstitucionalidade. Isso porque, se a lei é nula, ela nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou nenhuma norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido supostamente “revogada” continua tendo eficácia. Eis o efeito repristinatório da decisão.

Não se pode confundir (embora o STF utilize sem muito critério as expressões) **“efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade”** com **“repristinação da norma”**. No primeiro caso temos o restabelecimento da lei anterior porque, se a lei objeto do controle é inconstitucional e, assim, nula, ela nunca teve eficácia, portanto, nunca revogou nenhum outro ato normativo. No segundo, qual seja, na repristinação, nos termos do art. 2.º, § 3.º, da **LINDB** (*Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro* — Decreto-Lei n. 4.657/42),¹⁸⁹ salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, ou seja, precisa de pedido expresse desta terceira lei (que revoga a lei revogadora da lei inicial).

Avançando essa regra geral do efeito repristinatório, contudo, podemos estar diante de situação de revogação da norma anterior mesmo que o STF reconheça a inconstitucionalidade de determinada norma posterior.

Para recordar, os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, por meio de ADI, são: *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, podendo ser dado efeito *ex nunc*, ou a partir de outro momento que venha a ser fixado (exceção à regra geral do princípio da nulidade), desde que a votação tenha sido por 2/3 dos Ministros, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Ocorrendo a **modulação dos efeitos da decisão**, nesse caso, parece-nos que a lei (objeto do controle) vai sim ter a eficácia de revogar a lei anterior. Isso porque, se a decisão reconhece efeitos da referida norma, temos de aceitar a sua existência, validade e, durante o período que o STF determinar, a sua **eficácia**, gerando, dentre tantos efeitos, a natural revogação de lei em sentido contrário ou se expressamente assim estabelecer.

Por fim, destacamos um aspecto formal importante. Se o legitimado ativo da ADI objetivar que a Suprema Corte analise a inconstitucionalidade da lei que vai voltar a produzir efeitos (em razão do efeito repristinatório da decisão), terá de, expressamente, fazer o pedido de apreciação da referida lei, sob pena de o STF não poder, de ofício, apreciá-la e, para piorar, **não conhecer** da ação direta ajuizada. Nesse sentido:

■ “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: **efeito repristinatório**: norma anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a **repristinação** de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, **e não impugnada a norma anterior, não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade**” (ADI 2.574, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 02.10.2002, DJ de 29.08.2003. No mesmo sentido, cf. ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2006, DJ de 28.09.2007).

Por todo o exposto, fica claro que, em eventual controle normativo abstrato a ser instaurado, deverá haver a impugnação de todo o “**complexo normativo**”, de toda a “**cadeia normativa**”, tanto as normas revogadoras como as revogadas.

E qual o limite temporal de impugnação da cadeia normativa?

De acordo com o voto do Min. Gilmar Mendes na **ADI 3.660**, a necessidade de indicação dos atos que compõem a “cadeia normativa” se limita até o **advento da nova Constituição**. Pedimos vênica para transcrever a importante passagem de seu voto:

“... é preciso levar em conta que o processo do controle abstrato de normas destina-se, fundamentalmente, à aferição da constitucionalidade de normas pós-constitucionais (ADI n. 2, Rel. Paulo Brossard, *DJ* 2.2.92). Dessa forma, eventual colisão entre o direito pré-constitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida segundo princípios de direito intertemporal (*Lex posterior derogat priori*). Assim, conjugando ambos os entendimentos professados pela jurisprudência do Tribunal, a conclusão não pode ser outra senão a de que a **impugnação** deve **abranger apenas a cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988**” (voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 3.660, j. 13.03.2008, Plenário, *DJE* de 09.05.2008).

■ **6.7.1.17.4. Efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade¹⁹⁰**

■ **6.7.1.17.4.1. Coisa julgada “inconstitucional”. S. 343/STF. Rescisória (art. 966, V, CPC/2015)**

COLISÃO		
■ Segurança jurídica	X	■ Força normativa da Constituição
■ Autoridade do Poder Judiciário		■ Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais

■ Estabilidade das relações sociais	■ Isonomia: a aplicação assimétrica viola um referencial normativo que dá sustentação a todo o sistema
-------------------------------------	--

De modo geral, vimos, a declaração de inconstitucionalidade no **controle concentrado** tem efeitos retroativos (*ex tunc*), declarando-se a **nulidade** da lei.

Pode ser afirmado, então, por regra, que a lei inconstitucional nunca produziu efeitos, até porque a sentença declaratória restitui os fatos ao *statu quo ante*. Esse reconhecimento gera diversas consequências.

Uma **primeira** seria o “**efeito repristinatório**”, já estudado.

Outra consequência seria a conveniência, aprimorada pelo STF, de se aplicar a técnica da **modulação dos efeitos da decisão** diante de situações particulares, especialmente se reconhecidas por decisões judiciais transitadas em julgado.

Nesse contexto, há necessidade de se respeitar a **coisa julgada**, exceto na hipótese de **matéria penal** (art. 5.º, XL, CF/88), que, a qualquer tempo, permite a revisão criminal (veja que neste caso já houve pelo constituinte originário uma “**ponderação de interesses**”).

Assim, expressamente, o texto não faz outra ressalva, tendo erigido a coisa julgada como valor fundamental.

Processualmente, a sua **desconstituição** deve seguir a **regra processual**, qual seja, pela utilização da **ação rescisória** dentro do prazo decadencial de 2 anos, sendo que, findo tal prazo, fala-se em **coisa soberanamente julgada**, não mais podendo a matéria ser revista.

Podem ser lembradas, contudo, técnicas de “relativização” ou, utilizando uma terminologia mais adequada, de “**desconstituição**” da coisa julgada. Vejamos:

- a decisão transitada em julgado se funda em lei que vem a ser, em momento posterior, declarada inconstitucional;
- a decisão transitada em julgado afronta outros valores da Constituição (cf. *item 6.7.1.17.4.4*).

No primeiro caso, estamos diante da denominada “**sentença inconstitucional**”,¹⁹¹ qual seja, aquela que considera *lei* válida e que, por decisão futura do STF, em **controle concentrado**, vem a ser declarada *inconstitucional*, ou o contrário.

Nessas hipóteses, parece razoável que se aceite o ajuizamento de **ação rescisória**, nos termos do art. 966, V,¹⁹² CPC/2015, lembrando, do ponto de vista formal, o entendimento do STF que exige a juntada de (novo) instrumento de mandato específico, mesmo que conste esse poder no mandato originário, já que estaremos diante de **ação autônoma e com caráter excepcional** (nesse sentido, cf.: AR 2.236-ED, AR 2.239-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.06.2010, Plenário, *DJE* de 03.09.2010; e AR 2.156, AR 2.183 e AR 2.202, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.2010).

Para este estudo, sustentamos que o cabimento da rescisória dar-se-á tanto no caso de declaração de **constitucionalidade** como no de **inconstitucionalidade** em controle concentrado, com efeito *erga omnes* e *ex tunc*, em razão do efeito dúplice ou ambivalente das ações. A inconstitucionalidade da sentença está na desconformidade de interpretação dada à lei.¹⁹³

Contudo, **deverá ser respeitado o prazo decadencial de 2 anos para o seu ajuizamento** e, ainda, a controvérsia sobre a matéria deverá ser necessariamente **constitucional** e não meramente infraconstitucional, para, desta feita, afastar a incidência da S. 343/STF.¹⁹⁴

Transcorrido *in albis* o prazo decadencial de 2 anos sem o ajuizamento da ação rescisória, não mais se poderá falar em desconstituição da coisa julgada individual pela técnica da ação rescisória, mesmo que em controle concentrado venha a ser declarada a inconstitucionalidade de lei com efeitos *ex tunc*.

Segundo Gilmar Mendes, trata-se de “... proteção ao ato singular, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no **plano normativo** (*Normebene*) e no **plano do ato singular** (*Einzelaktebene*) mediante a utilização das *fórmulas de preclusão*”. E completa, com bastante propriedade: “... somente serão

afetados pela declaração de inconstitucionalidade com eficácia geral os atos ainda suscetíveis de revisão ou impugnação”.¹⁹⁵

Esse tema já foi discutido pelo STF no **AI 460.439 AgR/DF** (Inf. 397 e 436/STF, DJ de 09.03.2007, Ata n. 6/2007) e na **Rcl 2.600** (Inf. 440/STF, DJ de 03.08.2007), sendo acatada a tese de **afastamento da S. 343/STF** sem, todavia, ser resolvida a questão da contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória.

A discussão sobre essa problemática foi iniciada no julgamento da Rcl 2.600, em *obiter dictum*, porém o STF, naquele momento, não chegou a enfrentar o prazo para o ajuizamento da rescisória.

Para este estudo, entendemos, **do ponto de vista doutrinário** (posicionamento assumido em nossa tese de doutorado, USP), que o prazo decadencial tem de ser contado do **trânsito em julgado da decisão individual** e foi adotado pela jurisprudência do STF, como se observa abaixo, em julgamento posterior ao da Rcl 2.600 (mas antes da vigência do Novo CPC/2015).¹⁹⁶

Adotar o cabimento da rescisória a partir da nova posição do STF transitada em julgado, em nosso entender, por se tratar de decisão futura e incerta e que poderia ocorrer após vários anos do trânsito em julgado da decisão individual, caracterizaria uma indesejável **perpetuação da “espada de Dâmocles”**¹⁹⁷ e violação aos princípios constitucionais da **segurança jurídica** e **autoridade das decisões do Poder Judiciário**.

Isso posto, a única maneira de se desconstituir a coisa julgada **após o prazo decadencial** da ação rescisória será por outra técnica, qual seja, a da **desconsideração à luz do princípio da proporcionalidade** e limitada às sentenças que **ferirem outros valores constitucionais de igual hierarquia** ao da **segurança jurídica e estabilidade das decisões** e ficar reconhecido, nessa **ponderação de interesses**, que devam ser afastados. O cabimento de rescisória, enfatize-se, deve respeitar, necessariamente, o prazo decadencial de 2 anos.

Esse nosso entendimento fica fortalecido com a decisão proferida no **RE 328.812-ED** (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2008, *DJE* de 02.05.2008 e *Inf.* 497/STF). Segundo o voto do Min. Gilmar Mendes, relator, a **controvérsia de interpretação de lei** é muito diferente da **controvérsia de interpretação constitucional**, tendo em vista que nas decisões proferidas pelo STF se verifica uma particular forma de **concretização constitucional**.

Assim, diante da colisão verificada (*vide* quadro no início deste item), deve-se optar, nessa ponderação de valores, pela preservação da **força normativa da Constituição**, do **princípio da máxima efetividade das normas** e da ideia de **isonomia**, já que a aplicação assimétrica de decisões da corte significaria uma insuportável instabilidade (mais grave que a instabilidade gerada pela ação rescisória) e, conseqüentemente, um fortalecimento das decisões dos tribunais inferiores em relação ao STF, que é o intérprete máximo da Constituição e que, por último, fixa a sua força normativa.

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes deixa muito claro que o **prazo decadencial de 2 anos deverá ser respeitado**, fortalecendo, assim, a nossa posição teórica, defendida anteriormente.¹⁹⁸

■ **6.7.1.17.4.2. *Explicitação da amplitude da S. 343/STF. “Leading case”: RE 590.809 (j. 22.10.2014). Revogado CPC/73 e Novo CPC/2015***

O tema em análise, especialmente a **amplitude da S. 343/STF**, veio a ser rediscutido pelo STF no julgamento do **RE 590.809** (22.10.2014).

No caso concreto, analisava-se a possibilidade de ação rescisória em razão de mudança de entendimento pela Corte sobre matéria constitucional. O acórdão que estava em discussão consolidou, em 02.03.2004, o entendimento de que o contribuinte tem o direito aos créditos presumidos de IPI quando da aquisição de insumos e matérias-primas isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero.

Essa tese firmada, **favorável ao contribuinte, vigorou até 2007**, destacando-se o seguinte precedente: **RE 212.484**, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 05.03.98, Plenário, *DJ* de 27.11.98 (cf., também: RE 350.446/PR; RE 353.668/PR e RE 357.277/RS).

Em **25.06.2007**, contudo, o STF **alterou diametralmente** o seu posicionamento e passou a decidir no sentido de não mais se reconhecer o direito ao referido crédito. Essa mudança de interpretação, naturalmente, beneficiou a Fazenda Pública, contrariando os interesses dos contribuintes.¹⁹⁹

A partir dessa nova posição, a Fazenda Pública iniciou um trabalho judicial objetivando a cobrança de valores não recolhidos, muitos amparados por sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante o ajuizamento de **ação rescisória**, com base no art. 485, V, CPC/73 (isso porque estamos nos referindo a ações propostas antes do advento do CPC/2015), sustentando o afastamento da S. 343/STF, conforme vimos no item anterior.

O STF, por maioria, contudo, no tocante ao entendimento que até então vigorava no sentido de não aplicar a referida súmula, firmou um **novo direcionamento**, resgatando a aplicação da S. 343/STF e, assim, não mais admitindo, pura e simplesmente, a rescisória pelo fato de ter havido mudança em sua jurisprudência.

Basicamente, procurou-se **não banalizar o direito fundamental da coisa julgada**,²⁰⁰ destacando-se os **princípios da segurança jurídica** e da **estabilidade das relações sociais** e, assim, nos termos das situações fáticas do caso concreto, a **manutenção da S. 343/STF** e, portanto, o afastamento da rescisória, preservando-se o acórdão rescindendo **mesmo diante da alteração do entendimento da Corte**. Vejamos parte do voto do Relator e a ementa do acórdão:

“A rescisória deve ser reservada a **situações excepcionalíssimas**, ante a **natureza de cláusula pétrea** conferida pelo constituinte ao **instituto da coisa julgada**. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil (1973), incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante

da razão de ser do verbete, **não se trata de defender o afastamento da medida instrumental — a rescisória — presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada**” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014, Plenário, DJE de 24.11.2014, fls. 10).

“(…) O Verbetes n. 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, **inexistente controle concentrado de constitucionalidade**, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014, Plenário, DJE de 24.11.2014).

Estamos diante de preocupação muito evidente no **Novo Código de Processo Civil**, que teve o cuidado de encontrar instrumentos para uma maior **valorização dos precedentes**, propugnando não somente pela **estabilidade da jurisprudência**, mas, especialmente, por sua **integridade e coerência**, verdadeiros **vetores principiológicos** a partir de uma concepção de **dignidade da pessoa humana**, considerando os princípios da **segurança jurídica**, da **proteção da confiança** e da **isonomia** (cf. arts. 926, *caput*,²⁰¹ e 927, §§ 3.º e 4.º,²⁰² e aprofundamento no item 6.6.5.6).

Tem-se, por conseguinte, uma inegável **valorização do entendimento firmado na S. 343/STF** que afasta o uso irracional da rescisão de decisões transitadas em julgado.

Além da argumentação de que o entendimento foi estabelecido na linha da jurisprudência da Corte que prevalecia quando de sua prolação e de não servir a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação da Constituição, lendo o acórdão em análise, inclusive a sua ementa, parece que o STF também adota a perspectiva por nós sugerida no âmbito

acadêmico (nossa tese de doutorado — USP) no sentido de só se permitir a rescisória da decisão concreta anterior se o novo posicionamento tiver sido firmado em **ação de controle concentrado** com efeito *erga omnes* e vinculante e dentro do prazo decadencial de 2 anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão individual (o que também pode ser observado em razão de edição de **súmula vinculante** a reconhecer a nulidade do ato normativo que fundamentou a decisão de mérito transitada em julgado).

Esse entendimento, naturalmente, não poderá ser o mesmo nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, mesmo quando houver edição de resolução pelo Senado Federal, que produziria, na visão clássica, efeitos *ex nunc* e, em razão da suspensão *erga omnes*, atingiria apenas as decisões sem trânsito em julgado.

No controle concentrado, por outro lado, ou mesmo em razão de edição de súmula vinculante, reconhecendo-se a nulidade do ato normativo, os efeitos serão para todos e, por regra, com efeito retroativo.

Neste caso, diferentemente do controle difuso, conforme sustentamos, não se trata de eficácia natural da sentença *erga omnes*, que, em tese, poderia ser afastada pela demonstração de prejuízo jurídico individual. No fundo, trata-se de **extensão erga omnes da coisa julgada, pro et contra**, e mesmo sem a participação de terceiros, até porque forte é a ideia de substituição processual da coletividade pelos legitimados do art. 103, CF/88.

Essa perspectiva parece ter sido superada em razão do reconhecimento pelo STF da mutação constitucional do art. 52, X, no julgamento das ADIs 3.406 e 3.470 (cf. *item 6.6.5.5*).

Avançando, o STF entende que “os efeitos temporais da coisa julgada nas **relações jurídicas tributárias de trato sucessivo** são imediatamente cessados quando o STF se manifestar em sentido oposto em julgamento de controle **concentrado** de constitucionalidade ou de **recurso extraordinário com repercussão geral**”. Veja que o entendimento da Corte se refere, logicamente, ao controle concentrado, mas, também, ao controle difuso, desde que se trate do instituto da repercussão geral (REs 955.227 e 949.297, j. 08.02.2023).

E o Min. Barroso faz importante distinção: “as decisões em controle incidental de constitucionalidade, **anteriormente à instituição do regime de repercussão geral**, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante”.

■ **6.7.1.17.4.3. Arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, do revogado CPC/73: “embargos rescisórios”. Como ficou no CPC/2015 (arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º)?**

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CPC/73	DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CPC/2015
Art. 475-L: “A impugnação somente poderá versar sobre: II — inexigibilidade do título. § 1.º Para efeito do disposto no inciso II do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em <i>lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal</i>, ou fundado em <i>aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal</i>”.	Art. 525, § 1.º: “Na impugnação, o executado poderá alegar: III — inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1.º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em <i>lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal</i>, ou fundado em <i>aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal</i>, em <i>controle de constitucionalidade concentrado ou difuso</i>. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser <i>anterior</i> ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CPC/73	DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA CPC/2015
Art. 741. “Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: II — inexigibilidade do título. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em <i>lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal</i>”.	Art. 535. “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III — inexecutibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. § 5.º Para efeito do disposto no inciso III do <i>caput</i> deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em <i>lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso</i>. § 6.º No caso do § 5.º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7.º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5.º deve ter sido proferida <i>antes do trânsito em julgado da decisão exequenda</i>. § 8.º Se a decisão referida no § 5.º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

Agora, podemos analisar a regra contida nos arts. 741, parágrafo único (redação dada pela Lei n. 11.232/2005, assim como a redação que lhe conferia a MP n. 2.180-35), e 475-L, § 1.º, ambos do revogado CPC/73, para,

em seguida, analisar o Novo CPC/2015.

Por um lado, poder-se-ia dizer que a novidade é **inconstitucional**, por violação ao princípio da **segurança jurídica** e ao da **autoridade do Poder Judiciário**. Mas essa argumentação parece enfraquecer-se diante da solução conferida pelo STF em relação à colisão apontada.

Por outro lado, podemos afirmar ser a **ação rescisória** a única técnica processual estabelecida no sistema brasileiro para, de maneira legítima, desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, previsão em vários dispositivos da CF/88 (cf. arts. 102, I, “j”; 105, I, “e”; 108, I, “b”, e art. 27, § 10, ADCT).

Em nosso entender, referidos dispositivos **legais** (os arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único, CPC/73) não tratam de “relativização” imoderada ou da hipótese de “desconstituição pelo princípio da proporcionalidade”, mas de uma nova técnica (**“embargos rescisórios”**) a afrontar a **regra constitucional da ação rescisória**. Nesse sentido, inconstitucional.²⁰³

Apesar desse nosso entendimento, o Pleno do STF, no julgamento da **ADI 2.418**, por 10 x 1, vencido o Min. Marco Aurélio, julgou improcedentes os pedidos nela formulados e, assim, declarou a **constitucionalidade** do parágrafo único do art. 741 e do § 1.º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1.º, III e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5.º. No mesmo sentido, manifestou-se a Corte em plenário virtual, por 9 x 2, no julgamento da **ADI 3.740** (j. 20.09.2019 a 26.09.2019).

A previsão estabelecida nos arts. 525, § 12, e 535, § 5.º (CPC/2015), no tocante à inexigibilidade da obrigação será verificada se o título estiver fundado em lei que o STF já tenha, **anteriormente ao seu trânsito em julgado**, declarado inconstitucional (arts. 525, § 14, e 535, § 7.º).

Nesse sentido, conforme estabeleceu a Corte, referidos dispositivos, “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que

(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional — seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado **em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda**” (RE 611.503, j. 20.09.2018).

O dispositivo em análise estabelece que esse reconhecimento da inconstitucionalidade tenha sido em **controle concentrado** ou em **controle difuso**.

Aliás, conforme já falamos anteriormente, para o Min. Relator Teori Zavascki, a **distinção entre controle difuso ou concentrado é irrelevante**, independentemente da edição de resolução pelo Senado Federal.

E enfatiza: “A distinção restritiva, entre precedentes em controle incidental e em controle concentrado, não é compatível com a evidente intenção do legislador, já referida, de valorizar a autoridade dos precedentes emanados do órgão judiciário guardião da Constituição, que não pode ser hierarquizada simplesmente em função do procedimento em que a decisão foi tomada. Sob esse enfoque, **há idêntica força de autoridade nas decisões do STF tanto em ação direta quanto nas proferidas em via recursal**, estas também com natural vocação expansiva, conforme reconheceu o STF no julgamento da Reclamação 4.335, Min. Gilmar Mendes, DJE 22.10.14, a evidenciar que está ganhando autoridade a recomendação da doutrina clássica de que a eficácia *erga omnes* das decisões que reconhecem a inconstitucionalidade, **ainda que incidentalmente**, deveria ser considerada ‘efeito natural da sentença’ (BITTENCOURT, Lúcio, op. cit., p. 143; CASTRO NUNES, José. *Teoria e prática do Poder Judiciário*. Rio de Janeiro: Forense, 1943. p. 592)” (fls. 32 e 33 do acórdão — ADI 2.418, j. 04.05.2016, DJE de 17.11.2016).

Neste ponto, a análise do Novo CPC merece um destaque: a **redação original** do projeto de lei encaminhado para o Senado Federal (**PL n. 166/2010**) deixava claro que o cabimento dessa tese de impugnação seria possível nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade no **controle concentrado** ou, se no controle **difuso, somente se houvesse suspensão da execução da norma por resolução do Senado Federal** (anteriores ao trânsito em julgado da decisão exequenda).

A redação encaminhada para sanção presidencial decorreu de aprovação de **substitutivo da Câmara dos Deputados**, votado como destaque em separado na **sessão extraordinária do dia 17.12.2014**, em razão dos requerimentos feitos pelos Senadores Eduardo Braga e Humberto Costa (cf. votação no *DSF* de 18.12.2014, p. 523).

Outro ponto nos chama a atenção: no **parecer final da Câmara dos Deputados** (PL n. 6.065/2005 — que produziu o denominado “substitutivo da CD”), que **definiu essa redação final**, os Relatores (tanto o Deputado Paulo Teixeira como o Deputado Sérgio Barradas Carneiro), ao analisarem o **PL n. 2.066/2007** (que pretendia **revogar** esse dispositivo, que estabelece a inexigibilidade de título fundado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal), deixavam claro que, no tocante ao controle difuso, o efeito pretendido **dependeria de edição da resolução pelo Senado Federal**.

A redação final aprovada, contudo, não fez distinção entre controle concentrado ou difuso.

Nesse sentido, como se viu acima, o STF entendeu como irrelevante a decisão proferida em controle concentrado ou difuso com repercussão geral (EC n. 45/2004), declarando a constitucionalidade do art. 525, § 12. Essa, aliás, a atual posição do STF no sentido da mutação constitucional do art. 52, X (cf. *item 6.6.5.5*, ADIs 3.406 e 3.470 e *item 6.6.5.7*, REs 955.227 e 949.297).

Finalmente, a outra hipótese de defesa (**também introduzida pelo substitutivo da CD, não estando prevista no projeto original do SF**) poderá ser apresentada se a decisão que funda a execução tiver sido proferida

antes da nova interpretação a ser dada pelo STF. Tanto o **art. 525, § 15**, como o **art. 535, § 8.º**, admitem o cabimento de **ação rescisória**, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.

Neste ponto, remetemos o leitor para discussão que trouxemos no *item* 6.7.1.17.4.2, devendo deixar bem claro que, segundo sustentamos, referida ação rescisória (e melhorou ao não mais se falar em “embargos rescisórios”) deverá observar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da decisão individual (e que funda a execução) e somente se o reconhecimento da inconstitucionalidade **posterior** pelo STF se der em **controle concentrado**, tendo em vista o seu efeito *erga omnes* e *ex tunc* — retroativo, a reconhecer a nulidade *ab origine* do ato normativo que funda a execução (**não se admitindo a hipótese de controle difuso, nem mesmo**, para essa situação, **a edição de resolução do Senado Federal**, que teria efeito *ex nunc* e, portanto, não retroativo, não atingindo a decisão anterior e que está servindo de fundamento para a execução impugnada).

Esse tema específico não foi apreciado pelo STF no julgamento da citada ADI 2.418, mas, em *obiter dictum*, alguns Ministros sinalizaram certa preocupação em se contar o prazo decadencial da rescisória quando da futura e incerta decisão a ser proferida pelo STF. A lei criou um **termo inicial** de decadência da ação rescisória **móvel** e **diferido no tempo**.

Em relação a essa novidade, disse o Min. Barroso: “... esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático” (ADI 2.418, fls. 47 do acórdão).

A discussão sobre **termo inicial** para a contagem do prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória foi novamente levantada no debate sobre a chamada “uberização” das atividades.

O STF, em 2018, por 6 x 4, reputou inconstitucional o entendimento firmado na S. 331/TST, por violação aos princípios da **livre-iniciativa** (arts. 1.º, IV, e 170, CF/88) e da **liberdade contratual** (art. 5.º, II, CF/88), firmando a seguinte **tese** de julgamento: “1. É **lícita** a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego

entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei n. 8.212/1993” (**ADPF 324**, j. 30.08.2018).

Nesse sentido, na mesma data, no julgamento do **RE 958.252**, o STF entendeu ser “**lícita** a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (cf., também, ADC 48, ADI 5.835 MC e RE 688.223).

Surgia, então, a questão: essa mudança de entendimento permitiria a destituição da coisa julgada em caso concreto no qual se reconheceu o “vínculo trabalhista”? Se sim, **qual o termo inicial** para o ajuizamento da ação rescisória?

Havia manifestação do Min. Fux propondo a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da decisão individual e, assim, declarando a inconstitucionalidade do § 15 do art. 525 e a do § 8.º do art. 535, CPC (j. 18.09.2023). Contudo, diante da modulação dos efeitos da decisão firmada pela Corte no julgamento de embargos de declaração em momento anterior (j. 08.07.2022), essa análise específica ficou afastada, não tendo sido analisada formalmente pelo tribunal.

Aliás, vale a pena assistir ao vídeo da sessão de julgamento na qual, logo no início de sua fala, o Min. Fux deixa claro que não irão analisar a constitucionalidade dos referidos dispositivos do § 15, CPC.²⁰⁴

E por que fazemos esse destaque nessa nossa análise?

O nosso objetivo é deixar claro que o STF, no fechamento desta edição, ainda não havia formalmente discutido a questão, apesar de ter sido estabelecido no texto escrito do julgamento que o prazo contaria da decisão do STF na ADPF 324 e não do trânsito em julgado das ações individuais (**RE 958.252 ED**, j. 29.11.2023).

Deixamos claro, contudo, que, muito embora essa divulgação do resultado acima, ao analisarmos o vídeo da sessão de julgamento, observamos que a Corte ainda não enfrentou o tema de modo específico (pendente no fechamento desta edição).

Em julgamento anterior, a matéria chegou a ser ventilada, tendo os Mins. Fux e Gilmar Mendes sinalizado no sentido da inconstitucionalidade de se contar o prazo (termo *a quo*) a partir da decisão futura do STF, e não do trânsito em julgado do processo individual. O Min. Barroso, Presidente, contudo, determinou que essa análise deveria se dar em outro momento ([RE 586.068](#), j. 09.11.2023, data da fixação da tese).²⁰⁵

■ **6.7.1.17.4.4. Aspectos conclusivos: efeito da decisão no plano normativo (“Normebene”) e no plano do ato singular (“Einzelaktebene”) mediante a utilização das chamadas fórmulas de preclusão (interessante tendência apontada pelo Min. Gilmar Mendes). Perspectiva introduzida pelo CPC/2015**

O efeito vinculante, seja decorrente do controle concentrado (ADI ou ADC), seja, ainda, em razão da edição de súmula vinculante, seja em razão de aprovação de resolução por parte do Senado Federal, seja em razão da nova perspectiva de se aproximar os efeitos do controle difuso na hipótese de recurso extraordinário com **repercussão geral** aos do controle concentrado (cf. ADI 2.418, discutida acima, bem como o entendimento no sentido da mutação constitucional do art. 52, X, REs 955.227 e 949.297), produzirá impacto sobre as situações individuais (no caso da resolução do SF, com efeitos, por regra, não retroativos e, então, somente em relação aos processos que não tenham transitado em julgado).

Estando em curso ação individual e sobrevindo decisão em controle concentrado ou edição de súmula vinculante, ou resolução do SF, ou mesmo a decisão pela Suprema Corte nessa nova perspectiva de valorização dos precedentes (abstrativização do controle difuso e supervalorização dos precedentes nos exatos termos do CPC/2015 — cf. [ADI 2.418](#)), o juiz do

processo individual, ainda não findo, ficará vinculado, devendo decidir a questão prejudicial de inconstitucionalidade nos exatos termos do estabelecido no processo coletivo.

Sobrevindo decisão do processo individual em desrespeito a entendimento prévio já fixado em controle concentrado de constitucionalidade, com efeito *ex tunc*, vinculante e *erga omnes*, ou em desrespeito a súmula vinculante ou a anterior resolução do Senado Federal, ou em razão de decisão mesmo que em controle difuso diante da nova perspectiva apontada pelo STF no sentido de mutação constitucional do art. 52, X, nas hipóteses de repercussão geral, parece razoável sustentarmos a desconstituição da coisa julgada individual (posterior) por ação rescisória e **desde que dentro do prazo decadencial de 2 anos**, com fundamento no art. 966, IV, CPC/2015, por ofensa a coisa julgada anterior (do processo coletivo).

Por outro lado, modificando o STF o entendimento da tese jurídica em controle concentrado ou vindo a editar súmula vinculante, eventual sentença individual transitada em julgado (lembrando que, se estiver pendente de recurso, o tribunal estaria também vinculado ao novo posicionamento) caracterizar-se-á como **sentença individual inconstitucional**. Nesse caso, só se poderia pensar em desconstituição da coisa julgada individual anterior por meio de **ação rescisória**, tendo por fundamento o art. 966, V, CPC/2015, e se afastando a regra fixada na S. 343/STF somente se a controvérsia for de **natureza constitucional**, à luz do princípio da força normativa da Constituição e do STF, na condição de seu intérprete final.

Para essa hipótese, contudo, a rescisória deve, necessariamente, respeitar o prazo decadencial de 2 anos, a ser **contado do trânsito em julgado da sentença individual**, e não a partir da nova posição do STF, sob pena de se caracterizar uma indesejável perpetuação da **“Espada de Dâmocles”** e violação aos princípios constitucionais da **segurança jurídica** e da **autoridade das decisões do Poder Judiciário** (o tema precisa ser analisado pelo STF à luz do CPC/2015, conforme destacado nos itens anteriores — pendente).

Em outro sentido, havendo *ato singular individual* anterior, além do prazo decadencial de 2 anos, com a ressalva da matéria penal (**revisão criminal**), a coisa julgada individual deverá ser respeitada e o sistema terá de conviver com as sentenças contraditórias.

Em interessante voto, o Min. Gilmar Mendes observou que, embora não vigore no direito brasileiro algo semelhante à regra do § 79 da Lei do *Bundesverfassungsgericht*, “que prescreve a **intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação, não se deve supor que a declaração de nulidade afete, entre nós, todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional**”. Deve haver, segundo afirmou, proteção ao ato singular, em homenagem ao **princípio da segurança jurídica**, procedendo-se à diferenciação entre o **efeito da decisão no plano normativo (Normebene)** e **no plano do ato singular (Einzelaktebene)** mediante a **utilização das chamadas fórmulas de preclusão** (cf. Ipsen, Jörn, *Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden-Baden, 1980, p. 266 e s. Ver, também, Mendes, Gilmar, *Jurisdição constitucional*, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 334)” (RE 217.141-AgR, voto do Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2006, DJ de 04.08.2006).

O entendimento segundo o qual a decisão do STF em controle concentrado futuro não produz a automática reforma de sentenças que tenham estabelecido interpretação diversa em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei foi **reafirmado** pelo STF no julgamento do **RE 730.462**, j. 28.05.2015 (**ressalvando-se, quanto à indispensabilidade da rescisória, “a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”**).

Em 2023, ao julgar a questão específica da cobrança da CSLL, aplicando-se a **lógica da cláusula rebus sic stantibus**, reforçou o STF: “o tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. **Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente**

permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014)” (RE 955.227, j. 08.02.2023). Vejamos a tese de julgamento:

■ “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, **anteriores à instituição do regime de repercussão geral**, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em **ação direta** ou **em sede de repercussão geral** interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.

Fora dessa hipótese, a desconstituição da coisa julgada só poderá ter por fundamento a **colisão com outros valores constitucionais**, situação essa verificada à luz dos princípios da **razoabilidade** e da **proporcionalidade** e se o magistrado entender que o princípio da segurança jurídica deva ser afastado, e em situações excepcionalíssimas.

CUIDADO: em decisão extremamente relevante, o STF aplicou a técnica da ponderação mesmo depois de findo o prazo da ação rescisória.

Tratava-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TJDF que acolheu preliminar de coisa julgada e determinou a **extinção de nova** ação de investigação de paternidade proposta em razão da agora viabilidade de realização do exame de DNA, tendo em vista que a questão já estava decidida havia **mais de 10 anos!**

À época, o recorrente, representado por sua genitora, ingressou com ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, que foi julgada improcedente, **por insuficiência de provas**. Sustentaram que o recorrente, no primeiro julgamento, não tinha condições financeiras de custear o exame de DNA. Com a promulgação da Lei Distrital n. 1.097/96, o Poder Público passou a custear o referido exame.

No caso concreto, em **situação excepcionalíssima**, o STF afastou a alegação de segurança jurídica para fazer valer o *direito fundamental que toda pessoa tem de conhecer as suas origens* (**“princípio” da busca da identidade genética**), especialmente se, à época da decisão que se procura rescindir, não se pôde fazer o exame de DNA.

A decisão foi tomada, em **02.06.2011**, por **7 x 2**, no julgamento do **RE 363.889**, concedendo ao recorrente o direito de voltar a pleitear, perante o suposto pai, a realização do **exame de DNA**, tendo em vista que, na primeira decisão, embora beneficiária da assistência judiciária, a recorrente não podia arcar com as custas para a sua realização:

“EMENTA: (...). **Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo.** 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da **identidade genética**, como natural **emanação do direito de personalidade** de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o **direito à igualdade entre os filhos**, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da **paternidade responsável**” (RE 363.889, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.06.2011, DJE de 16.12.2011).

A **3.^a Turma do STJ**, por sua vez, em momento seguinte e por unanimidade, concluiu que esse entendimento fixado pelo STF não deveria ser seguido se a não realização do exame de DNA decorresse de **recusa** do investigado ou seus herdeiros para o comparecimento ao laboratório para a coleta do material biológico. Isso porque, no precedente firmado pelo STF, a impossibilidade de realização do exame se verificou em razão de um peculiar contexto, qual seja, a ausência de condições da parte e a negativa do Estado em implementá-la, caracterizando, então, **circunstâncias alheias à vontade das partes**.

Vejamos parte da ementa do julgado, pedindo vênia para sua transcrição, em razão de sua importância: “(...). Configura **conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva**, a ser observada também em sede processual, a **reiterada negativa**, por parte da recorrente, de produzir a **prova que traria certeza à controvérsia estabelecida** nos autos da anterior ação de investigação de paternidade para, transitada em julgado a decisão que lhe é desfavorável, ajuizar ação negatória de paternidade agora visando à realização do exame de DNA que se negara a realizar anteriormente. 4. Intolerável o comportamento contraditório da parte, beirando os limites da litigância de má-fé” (STJ, 3.^a T., REsp 1.562.239/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.05.2017, DJE de 16.05.2017).

Esse tema poderá vir a ser reapreciado pelo STF, em sua atual composição, e, certamente, ensejará amplo debate (*pendente*).

Finalmente, devemos destacar uma **novidade introduzida pelo CPC/2015**.

De acordo com o **art. 966, VII**, como nova previsão explícita de cabimento de ação rescisória, a decisão de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, **prova nova** cuja **existência ignorava** ou de que **não pôde fazer uso**, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Nesse caso, contudo, conforme art. 975, § 2.º, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da **prova nova**, observado o prazo máximo de **5 anos**, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

■ 6.7.1.17.5. *Pedido de cautelar (ADI genérica)*

O art. 102, I, “p”, CF/88, estabelece que cabe ao STF processar e julgar, originariamente, o pedido de cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade.

De acordo com o *caput* do art. 10 da Lei n. 9.868/99, salvo no período de recesso,²⁰⁶ a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da **maioria absoluta (6 Ministros)** dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22 (**quorum de instalação da sessão de julgamento** com pelo menos **8 Ministros** dos 11), após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, dispensada essa audiência em caso de **excepcional urgência**, hipótese em que o Tribunal poderá deferir a medida cautelar (art. 10, § 3.º).

Julgando indispensável, o relator ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias, sendo facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma do Regimento do Tribunal (art. 10, §§ 1.º e 2.º).

Desde que presentes os requisitos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*, poderá ser concedida a liminar, suspendendo a eficácia do ato normativo.

E quais seriam os efeitos da concessão da medida cautelar? De acordo com os §§ 1.º e 2.º do art. 11 da Lei n. 9.868/99, em total consonância com o posicionamento do STF, a concessão da medida cautelar terá eficácia contra todos (***erga omnes***) e efeito ***ex nunc***, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa (***ex tunc***). No julgamento de questão de ordem em agravo regimental interposto na **Rcl 1.880**, o STF, por maioria, reservou-se para examinar, quando necessário para o julgamento da causa, a questão sobre a extensão do **efeito vinculante** às medidas liminares em ação direta de inconstitucionalidade (cf. **Inf. 289/STF**, de 04 a 08.11.2002). A **concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário**.

Ainda, de acordo com o art. 12 da Lei, havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da **relevância da matéria** e de seu **especial significado para a ordem social e a segurança jurídica**, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do

Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, **submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.**

E quais seriam os efeitos do indeferimento da medida cautelar? O STF, revendo posição anterior, definiu que o indeferimento da cautelar **não** significa a confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante.

Portanto, na medida em que não se poderá sustentar o efeito vinculante da decisão de indeferimento, conforme anotou o STF, “não se admite reclamação contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, indefere, sob qualquer que seja o fundamento, pedido de liminar” (Rcl 3.458 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.10.2007, *DJE* de 23.11.2007). Nesse sentido, se algum juiz em sede de controle difuso afastar a aplicação da lei, declarando-a inconstitucional de modo incidental, contra essa decisão não caberá reclamação.

■ 6.7.1.18. ***Reclamação para a garantia da autoridade da decisão do STF: paradigma de ordem objetiva (ADI genérica e súmula vinculante)***

■ 6.7.1.18.1. ***Regras gerais***

A fim de garantir a **autoridade da decisão proferida pelo STF**, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a Excelsa Corte reconhece o ajuizamento de **reclamação**, nos termos do art. 102, I, “I” (competência originária do STF), desde que o ato judicial que se alega tenha desrespeitado sua decisão **não** tenha transitado em julgado (**S. 734/STF, 26.11.2003**).

Ainda, a partir da EC n. 45/2004 (*Reforma do Poder Judiciário*), admite-se o instituto da reclamação para resguardar a correta aplicação das **súmulas vinculantes** (art. 103-A, § 3.º, CF/88).

Na vigência do CPC/73, conforme afirmou o Min. Dias Toffoli, refletindo o entendimento da Corte sobre o instituto da reclamação constitucional, “para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema

Corte, cuja autoridade venha a estar comprometida, deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia *erga omnes*”, não se admitindo paradigma de ordem subjetiva (Min. Dias Toffoli, Rcl 14.810-AgR, j. 23.05.2013 — cf., também, Rcl 4.381-AgR).

Conforme sustentamos, a previsão de efeito vinculante a abrir o caminho diretamente ao STF tem de estar **explícita na Constituição Federal**, seja em sua redação originária (decisões em controle concentrado), seja em razão de emenda à Constituição (súmulas vinculantes), não podendo haver ampliação por lei infraconstitucional.

Por isso, algumas novidades introduzidas pelo **CPC/2015** são, em nosso entender, **inconstitucionais**. Conforme dissemos, muito embora se reconheça a eficácia expansiva das decisões mesmo quando tomadas em controvérsias concretas e individuais, há que se dar uma **interpretação estrita para o cabimento da reclamação constitucional**, sob pena de transformar o STF em Corte de revisão, em órgão recursal, tendo em vista a criação de um inadmissível (porque **inconstitucional**) atalho processual ou, ainda, um acesso *per saltum* à Suprema Corte, em combatida supressão de instância.

CUIDADO: essa nossa perspectiva, apesar de encontrar vozes na doutrina, parece não se sustentar perante a jurisprudência do STF a ser firmada já na vigência do CPC/2015. Assim, orientamos a leitura do *item* 6.6.5.6 e, enquanto não afastada, para realização das provas de concurso público, a aplicação da lei (art. 988, CPC/2015).

E quais os **legitimados** para a sua propositura?

Até o julgamento de questão de ordem na Reclamação n. 1.880, em 07.11.2002, a jurisprudência do STF, mesmo após o advento da Lei n. 9.868/99, **em um primeiro momento**, não considerava parte interessada para a propositura da referida ação terceiros que tivessem, subjetivamente, interesse jurídico ou econômico na observância da decisão, já que o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, como justificavam, fazia instaurar um processo objetivo, sem partes, no qual inexistia litígio referente a situações concretas ou individuais. Assim, nessa primeira fase, só seria conhecida a reclamação se

proposta por um dos legitimados do art. 103, CF/88 (art. 2.º da Lei n. 9.868/99), e com idêntico objeto, mesmo que o referido autor não tivesse sido parte na ação direta de inconstitucionalidade cuja decisão fundava o pedido reclamatório (legitimação concorrente — cf. Rcl 354, Rel. Min. Celso de Mello).²⁰⁷

Declarando **novo posicionamento (07.11.2002)**, coincidente com o que expusemos nas edições anteriores deste trabalho, o STF, por maioria de votos, após o julgamento de questão de ordem em agravo regimental, declarou **constitucional o parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99**, passando a considerar parte legítima para a propositura de reclamação **todos aqueles que forem atingidos por decisões contrárias ao entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento de mérito proferido em ação direta de inconstitucionalidade**, havendo, assim, uma **ampliação do conceito de parte interessada** (art. 13 da Lei n. 8.038/90).²⁰⁸

Esse novo entendimento é reforçado com a redação conferida ao art. 102, § 2.º, CF/88, pela EC n. 45/2004 (*Reforma do Poder Judiciário*), no seguinte sentido: “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Para se ter um exemplo da amplitude da perspectiva do instituto da reclamação, havendo efeito vinculante até mesmo perante a Administração Pública, temos sustentado a possibilidade de ajuizamento de reclamação em face de ato de Prefeito que contraria decisão proferida pelo STF com caráter vinculante.

Do ponto de vista do procedimento, conforme anotou o STF, “... para o conhecimento da reclamação não se exige a juntada de cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal que teria sido desrespeitado. Dispensabilidade da peça em virtude de o acórdão ter sido proferido pela própria Suprema Corte”

(Rcl 6.167-AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes Direito, j. 18.09.2008, *DJE* de 14.11.2008).

Finalmente, em interessante decisão, o STF admitiu, no julgamento de reclamação, a mudança na interpretação dada a determinado ato normativo (e que serviu de paradigma), declarando, inclusive, a sua inconstitucionalidade incidental.²⁰⁹

■ 6.7.1.18.2. *Natureza jurídica do instituto da reclamação*

A **natureza jurídica** da reclamação foi bem desenvolvida pelo Min. Marco Aurélio, e pedimos vênia para transcrevê-la abaixo de maneira esquematizada e acrescentando outras perspectivas:²¹⁰

■ **ação** — Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, Forense, t. V, p. 384;

■ **recurso ou sucedâneo recursal** — Moacyr Amaral Santos, *RTJ* 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, *O Poder Judiciário e a nova Constituição*, Aide, 1989, p. 80;

■ **remédio incomum** — Orozimbo Nonato, apud Cordeiro de Mello, *O processo no Supremo Tribunal Federal*, v. 1, p. 280;

■ **incidente processual** — Moniz de Aragão, *A correição parcial*, 1969, p. 110;

■ **medida de direito processual constitucional** — José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, 9. ed., Saraiva, 1987, v. 3, 2.^a parte, p. 199, item n. 653;

■ **medida processual de caráter excepcional** — Min. Djaci Falcão, *RTJ* 112/518-522;

■ **instrumento de extração constitucional** — “inobstante a origem pretoriana de sua criação (*RTJ* 112/504), destinada a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘I’) e do Superior Tribunal de

Justiça (CF, art. 105, I, 'f') — Ementa da Rcl 336, Rel. Min. Marco Aurélio;

■ **simples postulação perante o próprio órgão que proferiu uma decisão para o seu exato e integral cumprimento** — Grinover (Da reclamação, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 38/80);

■ **provimento mandamental de natureza constitucional** — Pedro Lenza, para este trabalho.

É de realçar o pensamento de Grinover ao analisar a natureza jurídica do **instituto da reclamação**: “... não se trata de ação, uma vez que não se vai rediscutir a causa com um terceiro; não se trata de recurso, pois a relação processual já está encerrada, nem se pretende reformar a decisão, mas antes garanti-la; não se trata de incidente processual, porquanto o processo já se encerrou. Cuida-se simplesmente de postular perante o próprio órgão que proferiu uma decisão o seu exato e integral cumprimento”.²¹¹

Já sustentamos, em outro estudo,²¹² a conclusão trazida por Grinover, qual seja, tratar-se a **reclamação** de verdadeiro **exercício constitucional de direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder** (art. 5.º, XXXIV, “a”, CF).²¹³

Esse entendimento parece agora estar consagrado no STF, o que se observa pela ementa da **ADI 2.480**, j. 02.04.2007, *DJ* de 15.06.2006, na qual se aceitou a previsão da reclamação também para o controle de constitucionalidade estadual e com previsão na CE.²¹⁴

Poderíamos dizer, então, que a **reclamação** nada mais é que um **instrumento de caráter mandamental e natureza constitucional**.

■ 6.7.2. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

■ 6.7.2.1. Conceito (ADC)

A **ação declaratória de constitucionalidade** foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993 (*DOU* de 18.03.1993), com a alteração da redação do art. 102, I,

“a”, e acréscimo do § 2.º ao art. 102, bem como do § 4.º ao art. 103, tendo sido regulamentado o seu processo e julgamento pela Lei n. 9.868/99.

Busca-se por meio dessa ação declarar a **constitucionalidade de lei ou ato normativo federal**. Indaga-se: mas toda lei não se presume constitucional? Sim, no entanto, o que existe é uma presunção relativa (*juris tantum*) de toda lei ser constitucional. Em se tratando de presunção relativa, admite-se prova em contrário, declarando-se, quando necessário, através dos mecanismos da ADI genérica ou do controle difuso, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.

Pois bem, qual seria, então, a utilidade dessa ação? O objetivo da ADC é transformar uma presunção **relativa** de constitucionalidade em **absoluta** (*jure et de jure*), não mais se admitindo prova em contrário. Ou seja, julgada procedente a ADC, tal decisão vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, que não mais poderão declarar a inconstitucionalidade da aludida lei, ou agir em desconformidade com a decisão do STF. Não estaremos mais, repita-se, diante de uma presunção relativa de constitucionalidade da lei, mas **absoluta**.

Deve-se deixar claro que ao se falar em “presunção absoluta” no modelo do **processo objetivo** não significa a impossibilidade eterna de rever o entendimento. Como sabemos, o STF poderá mudar de posição, alterando a interpretação dada ao ato normativo federal e, no caso, sem dúvida, declarar, em decisão futura, a sua inconstitucionalidade. Em outras palavras, o efeito vinculante não “vincula” o STF (Pleno) que poderá alterar o seu posicionamento. Mas, naturalmente, enquanto não observada essa “viragem jurisprudencial” pela mais alta Corte do país, os juízes e tribunais, em razão do efeito vinculante da decisão, deverão a ela se curvar.

Em síntese, a ADC busca afastar o nefasto quadro de insegurança jurídica ou incerteza sobre a validade ou aplicação de lei ou ato normativo federal, preservando a ordem jurídica constitucional.

■ 6.7.2.2. **Objeto (ADC)**

O objeto da referida ação é **lei ou ato normativo federal**. Frise-se: somente lei ou ato normativo federal, diferentemente do que ocorre com a ADI genérica, cujo objeto engloba, também, a lei ou ato normativo estadual (cf. art. 102, § 2.º).

■ 6.7.2.3. *Competência (ADC)*

O órgão competente para apreciar a ADC é o **STF**, conforme estabelece o art. 102, I, “a”, CF/88, de forma originária.

■ 6.7.2.4. *Legitimidade (ADC)*

Antes da **EC n. 45/2004**, os legitimados para a propositura da referida ação eram apenas quatro, de acordo com o art. 103, § 4.º, CF/88, quais sejam: a) Presidente da República; b) Mesa do Senado Federal; c) Mesa da Câmara dos Deputados; d) Procurador-Geral da República.

Com a revogação do § 4.º e a nova redação do *caput* do art. 103, pela aludida emenda, os legitimados para a propositura da ADC passaram a ser os **mesmos da ADI genérica** (vide item 6.7.1.14).

■ 6.7.2.5. *Procedimento (ADC)*

O procedimento na ADC é praticamente o mesmo seguido na ADI genérica, mas algumas observações devem ser feitas.

Em um primeiro momento, entendeu a doutrina não ser justificável a citação do Advogado-Geral da União na medida em que inexistia ato ou texto impugnado, já que se afirma a constitucionalidade na inicial.

Nesse ponto, contudo, gostaríamos de abrir uma discussão: em sendo ADI e ADC ações dúplices ou ambivalentes, ações com sinais trocados, em caso de improcedência do pedido na ADC, os efeitos, se assim decidido pelo STF, serão os mesmos da hipótese de deferimento da ADI, qual seja, a **inconstitucionalidade da lei**. Por esse motivo, parece razoável afirmar que o

AGU tenha de ser sempre citado na ADC para não se desrespeitar o art. 103, § 3.º (**matéria pendente**). Vejamos, graficamente, a perspectiva dessa ambivalência:

ADI E ADC SÃO AÇÕES DÚPLICES OU AMBIVALENTES, OU SEJA, SÃO “AÇÕES COM SINAIS TROCADOS”. A PROCEDÊNCIA DE UMA IMPLICA A IMPROCEDÊNCIA DA OUTRA		
Ação	 ADI (ação direta de inconstitucionalidade)	 ADC (ação declaratória de constitucionalidade)
Resultado do julgamento	 (+) procedência	 (-) improcedência
Consequência em relação à lei	 inconstitucionalidade	 inconstitucionalidade

O Procurador-Geral da República, por força do art. 103, § 1.º, CF/88, deverá ser previamente ouvido, emitindo o seu parecer.

Um requisito intrínseco à inicial, conforme vem relatando o STF, necessário para o conhecimento e análise do mérito, seria a demonstração da *“controvérsia judicial que põe risco à presunção de constitucionalidade do ato normativo sob exame... permitindo à Corte o conhecimento das alegações em favor da constitucionalidade e contra ela, e do modo como estão sendo decididas num ou noutro sentido”*.²¹⁵

Outro requisito, também exposto pelo Min. Relator Moreira Alves na ADC citada, seria, quando alegado **vício formal de inconstitucionalidade**, a necessária juntada aos autos de cópia dos documentos relativos ao processo legislativo de formação da lei ou ato normativo federal.

Esses dois requisitos que o STF vinha exigindo jurisprudencialmente foram expressamente previstos na Lei n. 9.868/99, que, em seu art. 14, estabelece que a petição inicial indicará: a) o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido; b) o pedido, com suas especificações; c) a existência de **controvérsia judicial relevante** sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Determina

também a referida lei que a petição inicial deverá conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade.

A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão **liminarmente indeferidas** pelo relator, cabendo **agravo** dessa decisão (art. 15 da lei).

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219, Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Após a indispensável manifestação do PGR, o Relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

Convém notar, seguindo a linha procedimental adotada na ADI, que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Pode, ainda, o relator solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição.

De acordo com a lei, as informações, perícias e audiências serão realizadas no prazo de **30 dias**, contado da solicitação do relator.

As regras sobre votação e *quorum* são as mesmas expostas na ADI genérica: desde que presente o *quorum* para instalação da sessão de julgamento de **8 Ministros**, a declaração de constitucionalidade dar-se-á pelo *quorum* da **maioria absoluta dos 11 Ministros do STF, isto é, pelo menos 6 deverão posicionar-se favoráveis à procedência da ação**.

Por fim, é **vedada a intervenção de terceiros** (muito embora, conforme visto no item 6.7.1.16.2, cabível *amicus curiae*) e a **desistência** da ação após a sua propositura. A decisão é **irrecorrível**, ressalvada a interposição de **embargos declaratórios, não podendo ser objeto de ação rescisória**.

■ 6.7.2.6. *Efeitos da decisão (ADC)*

O art. 102, § 2.º, criado pela EC n. 3/93, estabelece que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo **STF**, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo **federal**, produzirão **eficácia contra todos** e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Assim, podemos sistematizar os efeitos como sendo:

- **erga omnes** (eficácia contra todos);

- **ex tunc**;

- **vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital**.

■ 6.7.2.7. *Medida cautelar (ADC)*

Inovação trazida pelo Projeto de Lei n. 2.960/97 (PL n. 10/99, no Senado Federal), que originou a Lei n. 9.868/99, tão comentada nesta parte do trabalho, foi a admissão de medida cautelar nas ações declaratórias de constitucionalidade.

Nesse sentido, o art. 21 prevê que o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais **suspendam** o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

Essa suspensão perdurará apenas por 180 dias contados da publicação da parte dispositiva da decisão no *DOU*, prazo esse definido pela lei para que o tribunal julgue a ação declaratória. Findo tal prazo, sem julgamento, cessará a eficácia da medida cautelar.

Malgrado posicionamento minoritário em contrário,²¹⁶ o STF, por votação majoritária, apreciando preliminar suscitada pelo Min. *Sydney Sanches*, quanto ao cabimento ou não de liminar em ação declaratória, no julgamento da **ADC (MC) 4**, pacificou o entendimento segundo o qual é perfeitamente possível a atribuição de **efeito vinculante** e *erga omnes* em sede de liminar (decisão não definitiva de mérito) na ADC, tendo em vista o **poder geral de cautela** da Corte, podendo suas decisões ser preservadas pelo instrumento da **reclamação** (CF, art. 102, I, “I”).

Finalmente, na hipótese de indeferimento de cautelar, em razão do efeito ambivalente da ação, referida decisão significaria o mesmo que a procedência da ADI (ações dúplices ou ambivalentes). Assim, se no dispositivo da decisão se manifestar a Corte, respeitando os requisitos legais, parece-nos que se poderia estabelecer o efeito vinculante e *erga omnes* em relação a essa decisão que equivaleria à concessão da cautelar em ADI.

■ 6.7.3. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)**

■ 6.7.3.1. **Localização (ADPF)**

O § 1.º do art. 102, CF/88, estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da CF/88, será apreciada pelo STF, **na forma da lei**.

Trata-se de norma constitucional de **eficácia limitada**, ou seja, enquanto não houvesse lei descrevendo a forma da nova ação constitucional, a Suprema Corte não poderia apreciá-la (Pet 1.140 AgR, j. 02.05.1996, *DJ* de 31.05.1996). Veja que a Constituição prescreveu apenas a competência do STF para o julgamento e deixou ampla liberdade para a sua definição pelo legislador ordinário.

Onze anos depois, a **Lei n. 9.882/99**, regulamentando o dispositivo constitucional, definiu as regras procedimentais para a aludida arguição.

Referida lei foi questionada em ADI ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em 27.06.2000. Depois de cerca de 23 anos, já tendo sido ajuizadas quase 1.000 ADPFs, o STF julgou a ação e declarou **constitucional** a referida lei que regulamentou a ADPF (**ADI 2.231**, Pleno, j. 22.05.2023, *DJE* de 15.06.2023).

■ 6.7.3.2. **Objeto — hipóteses de cabimento (ADPF)**

A arguição de descumprimento de preceito fundamental será cabível, **nos termos da lei** em comento, seja na modalidade de **arguição autônoma** (direta), seja na hipótese de **arguição incidental** (ou paralela).

O art. 1.º, *caput*, da Lei n. 9.882/99 disciplinou a hipótese de **arguição autônoma**, tendo por objeto *evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público*.

Percebe-se nítido caráter **preventivo** na primeira situação (**evitar**) e caráter **repressivo** na segunda (**reparar lesão a preceito fundamental**), devendo haver **nexo de causalidade** entre a **lesão ao preceito fundamental** e o **ato do Poder Público**, de que esfera for, não se restringindo a atos normativos, podendo a lesão resultar de **qualquer ato administrativo**, inclusive **decretos regulamentares**.

A segunda hipótese (**arguição incidental**), prevista no parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99, prevê a possibilidade de arguição quando for **relevante** o *fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal (e por consequência o distrital, acrescente-se), incluídos os anteriores à Constituição* (o chamado direito pré-constitucional).

Nessa hipótese, deverá ser demonstrada a **divergência jurisdicional (comprovação da controvérsia judicial) relevante** na aplicação do ato normativo, violador do preceito fundamental.

Observa-se, então, que essa segunda modalidade de **arguição (incidental)**, além de se restringir a **ato normativo**, pressupõe a demonstração de **controvérsia judicial relevante**, o que faz crer a existência de uma **demanda concreta**, tanto é que o art. 6.º, § 2.º, da Lei n. 9.882/99 autoriza ao relator, se entender necessário, **ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição**.

Nesse sentido, disse o Min. Barroso no julgamento da ADI 2.231, que questionava o referido instituto: “a **arguição incidental** pressupõe, assim, a **existência de um litígio**, de uma **demanda concreta** já submetida ao Poder Judiciário, além de outros requisitos para além da subsidiariedade e da ameaça de lesão a preceito fundamental: **(i)** a necessidade de que seja **relevante** o fundamento da controvérsia constitucional e **(ii)** que se dirija contra **lei ou ato normativo** — e não contra qualquer ato do Poder Público. Nos casos da arguição incidental, eventuais processos em tramitação ficarão sujeitos à suspensão liminar de seu andamento ou dos efeitos da decisão acaso já proferida (art. 5.º, § 3.º), bem como à tese jurídica que venha a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento final da ADPF, que terá eficácia *erga omnes* e vinculante (art. 10, § 3.º)”.

E continua: “ao contrário do que sustenta o CFOAB, não existe violação ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal, tratando-se a medida de mecanismo eficaz para decisão de uma mesma questão de direito, de forma isonômica e uniforme, em prol de maior segurança jurídica” (**ADI 2.231**, j. 22.05.2023, fls. 21 do acórdão).

Busca-se, nesse sentido, procedendo a uma *cisão funcional* em relação ao caso concreto, antecipar o entendimento da Suprema Corte sobre a matéria.

Gilmar Mendes, nesse caso, fazendo um contraponto ao art. 97 em relação ao qual se observa uma *cisão funcional horizontal*, no caso da ADPF incidental, vislumbra uma **cisão funcional no plano vertical (de órgãos das instâncias ordinárias para o STF)**.²¹⁷

Ainda, cabe notar, na medida em que a ADPF pode ter por objeto ato editado antes da Constituição, a sua importante utilização como **instrumento de análise em abstrato de recepção** de lei ou ato normativo.

Nessa hipótese, conforme anotou o Min. Gilmar Mendes, a revogação da lei ou do ato normativo editado antes do novo ordenamento jurídico e objeto da demanda “não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não recepção da norma pela ordem constitucional superveniente” (**ADPF 33**, j. 07.12.2005, Plenário).

■ 6.7.3.3. *Preceito fundamental — conceito (ADPF)*

Tanto a Constituição como a lei infraconstitucional deixaram de conceituar **preceito fundamental**, cabendo essa tarefa à doutrina e, em última instância, ao STF.

Até o momento, os Ministros do STF não definiram, com precisão, o que entendem por preceito fundamental. Em algumas hipóteses, disseram **o que não é preceito fundamental**.

Para se ter um exemplo, na apreciação da questão de ordem da **ADPF 1-RJ**, apresentada pelo Min. Relator Néri da Silveira, o Tribunal não conheceu da ADPF ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil — PC do B, contra ato do Prefeito do Município do Rio de Janeiro que, ao vetar parcialmente, de forma imotivada, projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal — que elevava o valor do IPTU para o exercício financeiro de 2000 —, teria violado o princípio constitucional da separação de Poderes (CF, art. 2.º). Considerou-se ser incabível na espécie a ADPF, dado que **o veto constitui ato político do Poder Executivo, insuscetível de ser enquadrado no conceito de ato do Poder Público**, previsto no art. 1.º da Lei n. 9.882/99.

CUIDADO: estabelecida a regra de que o **veto** enquanto **ato político não pode ser objeto de ADPF**, devemos trazer a exceção da **admissibilidade de ADPF contra veto por inconstitucionalidade**.

Explicamos: em um caso específico, durante o prazo constitucional de 15 dias úteis (art. 66, § 1.º, CF/88), o Presidente da República **sancionou** determinados dispositivos de projeto de lei que se materializaram, após a promulgação e publicação, no § 5.º do art. 3.º-B e no art. 3.º-F da Lei n. 13.979/2020 — *lei para o enfrentamento da Covid-19*, na redação conferida pela Lei n. 14.019, de 2 de julho de 2020.

Inusitadamente, após 3 dias, o Presidente da República **republicou o veto** e inseriu os referidos dispositivos **que haviam sido sancionados**, agora como **vetados!** (segundo se justificou, o veto teria saído com “incorreção” na primeira publicação).

A Corte, nesse caso específico, entendeu que **o segundo veto seria inconstitucional** por violar o devido processo legislativo e, portanto, admitiu a ADPF. Conforme se decidiu, “não se admite ‘novo veto’ em **lei já promulgada e publicada**. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo **incabível eventual retratação**” (ADPFs 714, 715 e 716, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.02.2021, DJE de 25.02.2021).

Valemo-nos, então, de algumas sugestões da **doutrina** para conceituar preceito fundamental.

Para o Professor Cássio Juvenal Faria, preceitos fundamentais seriam aquelas “normas qualificadas, que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais, por exemplo, os ‘princípios fundamentais’ do Título I (arts. 1.º ao 4.º); os integrantes da cláusula pétrea (art. 60, § 4.º); os chamados princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII); os que integram a enunciação dos direitos e garantias fundamentais (Título II); os princípios gerais da atividade econômica (art. 170); etc.”.²¹⁸

Para Bulos, “qualificam-se de *fundamentais* os grandes preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelecem comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares da manifestação constituinte originária”. Como exemplos o autor lembra os arts. 1.º, 2.º, 5.º, II, 37, 207 etc.²¹⁹

■ 6.7.3.4. *Competência (ADPF)*

De acordo com o art. 102, § 1.º, CF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental será apreciada pelo **STF** (competência originária), na forma da lei.

■ 6.7.3.5. *Legitimidade (ADPF)*

Os legitimados para a propositura da referida ação são os **mesmos da ADI genérica**, previstos no art. 103, I a IX, CF/88, e no art. 2.º, I a IX, da Lei n. 9.868/99 (cf. o art. 2.º, I, da Lei n. 9.882/99), com as observações sobre a **pertinência temática** expostas quando do comentário sobre a ADI genérica.

O art. 2.º, II, da Lei n. 9.882/99 permitia a legitimação para **qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público**, mas foi **vetado**.

Apesar do **veto**, o art. 2.º, § 1.º, estabelece que, “na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao **Procurador-Geral da República**, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo”.²²⁰

■ 6.7.3.6. *Procedimento (ADPF). Particularidades do princípio da subsidiariedade*

Proposta a ação diretamente no **STF**, por um dos legitimados, deverá o relator sorteado analisar a regularidade formal da petição inicial, que deverá conter, além dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) e observância das regras regimentais: **a)** a indicação do preceito fundamental que se considera violado; **b)** a indicação do ato questionado; **c)** a prova da violação do preceito fundamental; **d)** o pedido, com suas especificações; **e)** se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação (parágrafo único do art. 3.º da lei em análise).

Liminarmente, o relator, não sendo o caso de arguição, faltante um dos requisitos apontados, ou inepta a inicial, indeferirá a petição inicial, sendo cabível o **recurso de agravo**, no prazo de **5 dias**, para atacar tal decisão (art. 4.º § 2.º, da Lei n. 9.882/99).

De acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Fundamental notar que, consoante o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio **eficaz** capaz de sanar a lesividade. Trata-se do **princípio da subsidiariedade** (caráter residual), que, segundo o Min. Celso de Mello, condiciona o ajuizamento da ação à “... ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a lesividade indicada pelo autor” (ADPF-6/RJ, DJ de 19.09.2000. *Vide*, ainda, ADPF 3, questão de ordem, DJ de 26.03.2001). Trata-se, conforme anotou em outro julgado, de “**pressuposto negativo de admissibilidade**”, atuando a “cláusula da subsidiariedade” como “**causa obstativa**” para o ajuizamento da ADPF no STF (**ADPF 314 AgR/DF**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2014, Plenário, DJE de 19.02.2015).

Evoluindo, o STF entendeu que o **princípio da subsidiariedade** deve ser interpretado no contexto da **ordem constitucional global** e em relação aos processos de índole objetiva (ADI, ADC, ADO): “(...) inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem

constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, *a priori*, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação” (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.12.2005, DJ de 27.10.2006. No mesmo sentido: ADPF 47-MC, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.12.2005, DJ de 27.10.2006).

Havendo pedido de liminar e apreciado pelo relator, este solicitará as informações necessárias às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de 10 dias, podendo, ainda, caso entenda necessário, ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição (no caso, a **arguição incidental**), requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou, ainda, fixar data para declarações, em **audiência pública** (cf. ADPF 101 — *importação de pneus usados* — 27.06.2008 e ADPF 54 — *interrupção de gravidez por anencefalia* — 26 e 28 de agosto e 4 e 16 de setembro, todas em 2008), de pessoas com experiência e autoridade na matéria (art. 6.º e § 1.º, da Lei n. 9.882/99).

Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.

Assim, conforme visto no *item 6.7.1.16.3*, o STF vem admitindo *amicus curiae* na ADPF, aplicando, por analogia, o art. 7.º, § 2.º, da Lei n. 9.868/99, desde que se demonstrem a **relevância da matéria** e a **representatividade dos postulantes** (cf. ADPFs 33, 46, 73, 132, 183, 205 etc.).

Ouvido o MP (art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99, acatando o mandamento do art. 103, § 1.º, CF/88), o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, pedindo dia para julgamento.

Da mesma forma que ocorre no julgamento da ADI, a decisão (julgamento) sobre a arguição será proferida pelo *quorum* da **maioria absoluta** (art. 97, CF/88), desde que presente o *quorum de instalação da sessão de julgamento*, previsto no art. 8.º da Lei n. 9.882/99, ou seja, a

exigência de estarem presentes pelo menos **2/3 dos Ministros (8 dos 11 Ministros)**.

Tal como se verifica no processo de ADI, a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é **irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória** (art. 12 da Lei n. 9.882/99).

Apesar do silêncio da lei, bem como da afirmação da irrecorribilidade, entendemos perfeitamente cabíveis os **embargos de declaração**, em razão de sua natureza jurídica de integração e esclarecimento da decisão e, também, com fundamento no art. 26 da Lei n. 9.868/99 (ADI e ADC), aplicado por analogia.²²¹

Finalmente, a lei é explícita ao assegurar o cabimento de **reclamação** contra o descumprimento da decisão proferida pelo STF, na forma do seu Regimento Interno (art. 13 da Lei n. 9.882/99).

■ 6.7.3.7. *Efeitos da decisão (ADPF)*

Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

A decisão é **imediatamente autoaplicável**, na medida em que o presidente do STF determinará o **imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente**.

De acordo com o art. 10, § 2.º, da Lei n. 9.882/99, dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União*.

A decisão terá eficácia contra todos (*erga omnes*) e **efeito vinculante** relativamente aos demais órgãos do Poder Público, além de efeitos retroativos (*ex tunc*).

Da mesma maneira como acontece na ADI, como exceção à regra geral do princípio da nulidade, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista **razões de segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de **2/3** de seus membros, **restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado (*ex nunc*) ou de outro momento que venha a ser fixado.**

■ **6.7.3.8. *O parágrafo único do art. 1.º da Lei n. 9.882/99 é constitucional (arguição incidental)?***

SIM.

A Constituição autorizou a apreciação, pelo STF, da **arguição de preceito fundamental**, na forma da **lei**.

Já havia previsto competência ao STF, em sede de ADI, para apreciação de lei ou ato normativo federal ou estadual, como já visto, **excluídos** os municipais e os anteriores à Constituição.

Para Gilmar Ferreira Mendes, surge instrumento adequado ao combate da chamada “guerra de liminares”, introduzindo profundas alterações no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade:

“Em **primeiro lugar**, porque permite a antecipação de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da ‘interpretação autêntica’ do Supremo Tribunal Federal”.

“Em **segundo lugar**, porque poderá ser utilizado para — de forma definitiva e com eficácia geral — solver controvérsia relevante sobre a legitimidade do **direito ordinário pré-constitucional** em face da nova Constituição que, até o momento, somente poderia ser veiculada mediante a utilização do **recurso extraordinário**.”

“Em **terceiro**, porque as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses processos, haja vista a eficácia *erga omnes* e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas diversas entidades **municipais**. A solução oferecida pela nova lei é superior a uma outra alternativa oferecida, que consistiria no reconhecimento da competência dos Tribunais de Justiça para apreciar, em ação direta de inconstitucionalidade, a legitimidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Além de ensejar múltiplas e variadas interpretações, essa solução acabaria por agravar a crise do Supremo Tribunal Federal, com a multiplicação de recursos extraordinários interpostos contra as decisões proferidas pelas diferentes Cortes estaduais” (Gilmar Ferreira Mendes, *Revista Jurídica Virtual*, n. 7, dez./1999).

Conforme informamos, houve questionamento do referido dispositivo que trata sobre a arguição incidental na ADI 2.213, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB.

Depois de quase 23 anos, o STF declarou **constitucional** a integralidade da Lei n. 9.882/99 (**ADI 2.231**, Pleno, j. 22.05.2023, *DJE* de 15.06.2023).

Conforme ficou expresso na ementa do acórdão ao se referir à **ADPF incidental** ou **paralela**, “o desenho dessa modalidade de arguição pelo legislador infraconstitucional visou justamente a possibilitar a provocação do Supremo Tribunal Federal para **apreciar relevantes controvérsias constitucionais concretamente debatidas em qualquer juízo ou tribunal, quando não houvesse outra forma idônea de tutelar preceitos fundamentais**. A previsão impugnada não viola os princípios do juiz natural ou do devido processo legal, mas veicula mecanismo eficaz de decisão de uma mesma questão de direito, de forma **isonômica** e **uniforme**, contribuindo para **maior segurança jurídica**” (item 3).

■ 6.7.3.9. *Pedido de medida liminar (ADPF)*

O art. 5.º da Lei n. 9.882/99 estabelece que o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros (pelo menos **6 Ministros**), poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Em caso de **extrema urgência ou perigo de lesão grave**, ou, ainda, em **período de recesso**, contudo, poderá o **relator** conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.

O relator poderá, ainda, ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 dias.

A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, **salvo se decorrentes da coisa julgada**.

Depois de toda uma discussão sobre a constitucionalidade do aludido dispositivo, inclusive com liminar do Min. Néri da Silveira na ADI 2.231-MC suspendendo o art. 5.º, § 3.º, da Lei n. 9.882/99 (j. 05.12.2001), na prática, em ações futuras, o STF ignorava a referida decisão e aplicava o dispositivo de maneira integral (cf. ADPFs 77 e 79).

Em **22.05.2023**, a Corte, por unanimidade, declarou constitucional a Lei n. 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (mérito da **ADI 2.231**).

Conforme afirmou o Min. Barroso, “a possibilidade de suspensão nacional de processos ou de efeitos de decisões judiciais tem por objetivo evitar que a tutela de preceitos fundamentais buscada na ADPF se torne ineficaz ou que sejam tomadas decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito, a comprometer a segurança jurídica e a efetividade da prestação judicial” (fls. 23).

■ **6.7.3.10.** ***ADPF pode ser conhecida como ADI? Se sim, o princípio da fungibilidade teria natureza ambivalente? Ou seja, ADI***

poderia ser conhecida como ADPF?

SIM, mas devemos observar os balizamentos estabelecidos pelo STF considerando a noção de **dúvida objetiva** e a proibição da incidência de **erro grosseiro**. Vejamos.

Quanto à primeira indagação, “tendo em conta o **caráter subsidiário** da arguição de descumprimento de preceito fundamental — ADPF, consubstanciado no § 1.º do art. 4.º da Lei 9.882/1999, o Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de conhecer, como ação direta de inconstitucionalidade — ADI, a ADPF ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, em que se impugna a **Portaria 156/2005**, editada pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda do Pará, que estabeleceu, para fins de arrecadação do ICMS, novo boletim de preços mínimos de mercado para os produtos que elenca em seu anexo único. Entendeu-se demonstrada a impossibilidade de se conhecer da ação como ADPF, em razão da **existência de outro meio eficaz para impugnação da norma**, qual seja a ADI, porquanto o objeto do pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade de **preceito autônomo** por ofensa a dispositivos constitucionais, restando observados os demais requisitos necessários à propositura da ação direta” (**ADPF 72 QO/PA**, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º.06.2005 — *Inf. 390/STF*).

Reafirmando esse entendimento, também, no sentido do conhecimento de ADPF como ADI (**princípio da fungibilidade** — art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 — e perfeita satisfação dos requisitos exigidos à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade — legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido), cf. a reautuação da **ADPF 143** como **ADI 4.180-REF-MC** (j. 19.12.2008), bem como a reautuação da **ADPF 178** como **ADI 4.277** (j. 21.07.2009), tendo sido discutido, nesta última, o importante tema da união homoafetiva.

Em relação à segunda questão, o STF também admitiu que pedido formulado em ADI fosse conhecido como ADPF, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Muito embora outras problemáticas foram postas na causa, o dito “ponto jurídico mais nevrálgico e absorvente” consistia na discussão

sobre a alteração de parâmetro de constitucionalidade pela EC n. 45/2004 e, assim, a discussão sobre a revogação ou não de lei anterior pela referida emenda. Assim, concluíram os Ministros do STF: “é lícito conhecer de ADI como ADPF, **quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela**” (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.02.2012, Plenário, DJE de 1.º.03.2013).

O tema da fungibilidade veio a ser novamente discutido pela Corte no ano de 2014. No julgamento monocrático da ADPF 158, o Min. Gilmar Mendes não admitiu a fungibilidade por se tratar de situação clara para o cabimento de ADI; no caso, o objeto da ADPF era uma lei federal editada após a promulgação da CF/88. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário no julgamento do agravo regimental interposto (ADPF 158 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2014, Plenário, DJE de 02.02.2015).

Em outro julgado, o STF reafirmou que **dúvida razoável** sobre o caráter autônomo de atos infralegais, como decretos, resoluções e portarias, assim como **alterações supervenientes de normas constitucionais** poderiam justificar a **fungibilidade**. No caso concreto, porém, por se tratar de *lei ordinária federal editada depois da promulgação da CF/88*, **longe de envolver dúvida objetiva**, não configuraria a fungibilidade por se tratar de **erro grosseiro** na escolha do instrumento, violando, assim, o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99 (ADPF 314 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2014, Plenário, DJE de 19.02.2015).

Estamos diante, portanto, da posição do STF sobre a aplicação do **princípio da fungibilidade** e, como bem colocou o Min. Marco Aurélio, da orientação conciliatória entre “**instrumentalidade** e **celeridades processuais**, de um lado, e **necessidade de não se baratear os institutos**, do outro”. De acordo com os precedentes citados, admite-se a fungibilidade quando se estiver diante de **dúvida razoável** sobre o “caráter autônomo de atos infralegais (...) como decretos, resoluções, portarias” ou em razão da “alteração superveniente da norma constitucional dita violada”. Fora essas hipóteses, caracterizado estará o **erro grosseiro** a afastar a aplicação da

fungibilidade. Nesses termos, damos um claro exemplo de erro grosseiro, como verificado no precedente acima: impugnação de lei federal pós-constitucional por ADPF, quando cabível, no caso, indubitavelmente, a propositura de ADI.

■ 6.7.4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

■ 6.7.4.1. Conceito (ADO)

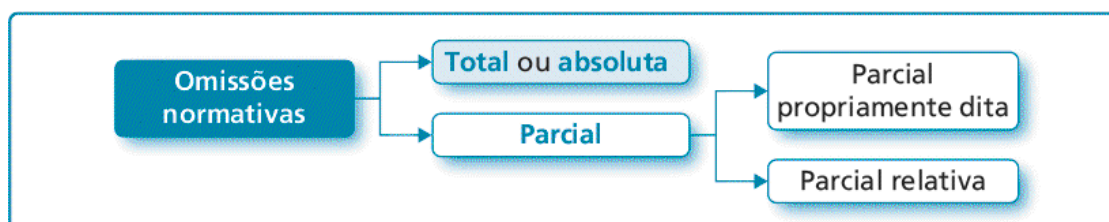
Trata-se de inovação da CF/88, inspirada no art. 283 da Constituição portuguesa. O que se busca com a ADO é combater uma “doença”, chamada pela doutrina de **“síndrome de inefetividade das normas constitucionais”**.

O art. 103, § 2.º, CF/88, determina que, declarada a inconstitucionalidade por omissão **de medida para tornar efetiva norma constitucional**, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. O que se busca é **tornar efetiva norma constitucional** destituída de efetividade, ou seja, somente as normas constitucionais de **eficácia limitada**.²²²

Abrimos um pequeno parêntese, remetendo o leitor para o capítulo que trata dos **remédios constitucionais**, sugerindo o estudo conjunto da **ADO** com o do **mandado de injunção**, que também se caracteriza como um “remédio” cujo objetivo é combater a “síndrome de inefetividade das normas constitucionais”, de eficácia limitada. Na **ADO** temos o controle **concentrado**; através do **mandado de injunção**, o controle **difuso**, pela via de exceção ou defesa e, atualmente, com algumas particularidades previstas na **Lei n. 13.300/2016**, que o regulamentou (cf. *item 14.11.5*).

Cabe mencionar, por último, a **Lei n. 12.063/2009**, que passou a estabelecer a disciplina processual da ADO e será apresentada nos itens seguintes.

■ 6.7.4.2. Espécies de omissão



A omissão poderá ser total (absoluta) ou parcial: **total**, quando não houver o cumprimento do dever de normatizar, editando medida para tornar efetiva a norma constitucional; **parcial**, quando houver a normatização infraconstitucional, porém de forma insuficiente.

Como exemplo de **inconstitucionalidade por omissão total** ou **absoluta**, destacamos o art. 37, VII, que prevê o direito de greve para os servidores públicos, ainda não regulamentado por lei.²²³ Outro exemplo é o revogado art. 192, § 3.º, que dependia de lei (limitação da taxa de juros a 12% ao ano — cf. S. 648/STF e SV 7/2008).

A **inconstitucionalidade por omissão parcial**, por seu turno, divide-se em duas: parcial propriamente dita ou parcial relativa.

Por **omissão parcial propriamente dita**, o ato normativo, apesar de editado, regula de forma deficiente o texto. Como exemplo, temos o art. 7.º, IV, que dispõe sobre o direito ao **salário mínimo**. A lei fixando o seu valor existe, mas o regulamenta de forma deficiente, pois o valor estabelecido é muito inferior ao razoável para cumprir toda a garantia da referida norma.

Já **omissão parcial relativa** surge quando o ato normativo existe e outorga determinado benefício a certa categoria, mas deixa de concedê-lo a outra, que deveria ter sido contemplada. Nesse caso, deve-se lembrar o entendimento materializado na Súmula 339/STF, potencializada com a sua conversão na **SV 37/2014**: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

■ 6.7.4.3. Objeto (ADO)

O art. 103, § 2.º, fala em “omissão de **medida**” para tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos **Poderes** ou de **órgão administrativo**.

Com precisão anota Barroso que a omissão é de cunho **normativo**, que é mais ampla do que a omissão de cunho *legislativo*. Assim, engloba “... atos gerais, abstratos e obrigatórios de outros Poderes e não apenas daquele ao qual cabe, precipuamente, a criação do direito positivo”.

A omissão, então, pode ser do **Poder Legislativo**, do **Poder Executivo** (atos secundários de caráter geral, como regulamentos, instruções, resoluções etc.), ou do próprio **Judiciário** (por exemplo, a omissão em regulamentar algum aspecto processual em seu Regimento Interno).

Portanto, continua Barroso, “... são impugnáveis, no controle abstrato da omissão, a inércia legislativa em editar quaisquer dos atos normativos primários suscetíveis de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade... O objeto aqui, porém, é mais amplo: também caberá a fiscalização da omissão inconstitucional em se tratando de atos normativos secundários, como regulamentos ou instruções, de competência do Executivo, e até mesmo, eventualmente, de atos próprios dos órgãos judiciais”.²²⁴

O STF já decidiu que, pendente julgamento de ADO, se a norma constitucional que não tinha sido regulamentada vier a ser revogada, a ação deverá ser extinta por perda de objeto, julgando-se prejudicada (ADI 1.836, Rel. Min. Moreira Alves, j. 18.06.1998).

A mesma decisão, qual seja, pela perda de objeto, tomou o STF para a hipótese de encaminhamento de projeto de lei sobre a matéria ao Congresso Nacional (cf. ADI 130-2/DF), ou, ainda, pelo não cabimento da ação se, no momento de sua propositura, o processo legislativo já havia sido desencadeado (ADI 2.495, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 02.05.2002, *DJ* de 02.08.2002).

CUIDADO: este último posicionamento, contudo, foi repensado no julgamento da **ADO 3.682**, entendendo o STF não se justificar a demora na apreciação de projetos já propostos (*inertia deliberandi* das Casas Legislativas), passível de se caracterizar uma desautorizada “conduta

manifestamente **negligente** ou **desidiosa** das Casas Legislativas”, colocando em **risco a própria ordem constitucional** (voto do Min. Gilmar Mendes — tema discutido no *item 6.7.4.9*).

Por derradeiro, adotando posicionamento bastante formalista, sobre o qual deixamos a nossa crítica, o STF entendeu inexistente a fungibilidade da ADO com o mandado de injunção, tendo em vista a diversidade de pedidos: “Impossibilidade jurídica do pedido de conversão do mandado de injunção em ação direta de inconstitucionalidade por omissão” (**MI 395-QO**, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 11.09.1992).

■ 6.7.4.4. *Competência (ADO)*

O órgão competente para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o **STF**, de forma originária (art. 103, § 2.º, c/c, analogicamente, o art. 102, I, “a”).

■ 6.7.4.5. *Legitimidade (ADO)*

Os legitimados para a propositura da **ADO** são **os mesmos da ADI genérica**, ou seja, o rol previsto no **art. 103**, com as peculiaridades já apontadas em relação à **pertinência temática**.

A **Lei n. 12.063/2009** ratificou esse posicionamento, não havendo mais qualquer dúvida sobre a questão.

■ 6.7.4.6. *Natureza jurídica dos legitimados (ADO)*

Conforme anota o Min. Gilmar Mendes, assim como acontece na ADI genérica, o processo de controle na **ADO** tem por escopo a “defesa da ordem fundamental contra condutas com ela incompatíveis. Não se destina, pela própria índole, à proteção de situações individuais ou de relações subjetivadas, mas visa precipuamente à defesa da ordem jurídica”. Os legitimados agem como “**advogados do interesse público** ou, para usar a

expressão de *Kelsen*, como **advogados da Constituição**". Utilizando a denominação de *Triepel*, tem-se "típico **processo objetivo**" (voto na ADI 3.682).

■ 6.7.4.7. *Procedimento (ADO)*

O procedimento da **ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO)** é praticamente o mesmo da ADI genérica, com algumas peculiaridades.

Nos termos do art. 12-B da Lei n. 9.868/99, a petição inicial, acompanhada de procuração, **se for o caso**, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão, e indicará:

- a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa;
- o pedido, com suas especificações.

Naturalmente, em razão do **peticionamento eletrônico**, não faz mais sentido a prescrição de apresentação da petição em duas vias, por isso o texto prescreve essa necessidade "se for o caso". Dentro dessa realidade, de modo acertado, o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 13.300/2016 (que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo) estabelece que, "**quando não for transmitida por meio eletrônico**, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados".

A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, cabendo **agravo** da referida decisão.

Lembramos que, de acordo com o CPC/2015, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de

agravo interno para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219 do Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Proposta a ação, não se admitirá desistência, devendo ser, no que couber, aplicadas as disposições constantes da Seção I do Capítulo II da Lei n. 9.868/99.

Os legitimados constantes do art. 103, CF/88, poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais.

Modificando o entendimento do STF,²²⁵ a lei passou a estabelecer que o relator **poderá** solicitar a manifestação do **AGU**, cujo encaminhamento deverá ser feito no prazo de 15 dias.

O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 dias, após o decurso do prazo para informações.

Finalmente, segundo Clèmerson Merlin Clève, “não há prazo para a propositura da ação. É evidente, entretanto, que sem o transcurso de um prazo razoável, aferível caso a caso, não haverá omissão constitucional censurável, mas sim mera lacuna técnica (omissão constitucional e omissão constitucional em trânsito para a inconstitucionalidade)”.²²⁶

■ 6.7.4.8. *Medida cautelar (ADO)*

Nesse ponto, a **Lei n. 12.063/2009** inovou a matéria, passando a admitir expressamente medida cautelar na **ADO**.

Segundo o art. 12-F da Lei n. 9.868/99, em caso de **excepcional urgência e relevância da matéria**, o STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus **membros**, observado o disposto no art. 22 (*quorum* de instalação da sessão de julgamento com no mínimo 8 Ministros), poderá **conceder medida**

cautelar, **após** a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias.²²⁷

A medida cautelar poderá consistir na **suspensão** da **aplicação da lei** ou do **ato normativo questionado**, no caso de **omissão parcial**, bem como **na suspensão de processos judiciais** ou de **procedimentos administrativos**, ou ainda em **outra providência a ser fixada pelo Tribunal**.

O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias.

No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma do previsto no Regimento do Tribunal.

Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar, em seção especial do *Diário Oficial da União* e do *Diário da Justiça da União*, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II da Lei n. 9.868/99.

■ 6.7.4.9. *Efeitos da decisão (ADO)*

■ 6.7.4.9.1. *Regras gerais*

Declarada a inconstitucionalidade em razão de omissão total ou parcial, indagamos se o STF (Poder Judiciário) poderia elaborar a lei, para suprir a omissão.

Em respeito ao princípio da **tripartição dos Poderes**, insculpido no art. 2.º, CF/88, não é permitido ao Judiciário legislar (salvo nas hipóteses constitucionalmente previstas, como a elaboração de seu Regimento Interno).

O art. 103, § 2.º, estabelece efeitos diversos para o **poder competente** e para o **órgão administrativo**:

■ **poder competente:** será dada ciência ao poder competente, não tendo sido fixado qualquer prazo para a adoção das providências necessárias;

■ **órgão administrativo:** deverá suprir a omissão da medida no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, ou, na dicção do art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, em **prazo razoável** a ser estipulado **excepcionalmente** pelo Tribunal, tendo em vista as **circunstâncias específicas** do caso e o **interesse público** envolvido.

Neste ponto, o art. 103, § 2.º, poderia ser interpretado de duas maneiras: **a)** ou o prazo foi estabelecido apenas para o órgão administrativo, não podendo o STF fixar prazo para o Legislativo ou outro Poder omissor; **b)** ou o prazo pode ser fixado pelo Judiciário tanto para o órgão administrativo como para o Legislativo ou outro órgão omissor. Porém, se estabelecido para o órgão administrativo, deverá ser dentro de 30 dias e, agora, nos termos do art. 12-H, § 1.º, da Lei n. 9.868/99, em **prazo razoável** a ser estipulado **excepcionalmente** pelo Tribunal, tendo em vista as **circunstâncias específicas** do caso e o **interesse público** envolvido.

Nesse sentido, o Min. Carlos Britto, no julgamento da **ADO 3.682**, observou, acompanhando o voto do Min. relator: “diferentemente da Constituição portuguesa, a nossa não se limitou a cuidar da ADI por omissão de medida legislativa; foi além. Quando a nossa Constituição falou em dar ciência ao poder competente, claro que mais de um poder, não só ao Poder Legislativo, apenas a Constituição avançou o comando de que, em se tratando de órgão administrativo, esse prazo seria de trinta dias, mas **sem com isso excluir a possibilidade de se fixar um prazo, logicamente, maior para o Poder Legislativo**” (grifamos).

O tema, nessa linha, foi **amplamente revisto pelo STF** no precedente citado (e de *indispensável leitura para as provas e concursos*), no qual se discutiu a inércia do legislador em elaborar a LC federal, prevista nos termos do art. 18, § 4.º, na redação dada pela EC n. 15/96, fixando o procedimento de criação dos novos Municípios (cf. *item 7.6.1*).

Como se sabe, a EC n. 15/96, alterando a redação do art. 18, § 4.º, foi publicada em 13.09.1996. Apesar de fazer quase 30 anos, a lei complementar federal ainda não é uma realidade, mostrando-se, portanto, flagrante a omissão. (Devemos lembrar que o Congresso Nacional já aprovou projeto de lei complementar disciplinando a matéria, porém, este foi vetado pela então Presidente da República Dilma Rousseff mais de uma vez. O último, nos mesmos termos de veto anterior, de acordo com a *mensagem n. 250/2014*, teve por fundamento o dito **interesse público**: “depreende-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja a correspondente geração de novas receitas”).

O Min. Relator, Gilmar Mendes, no julgamento da citada ADO 3.682, à época antes da aprovação dos mencionados projetos de lei (que, aliás, como visto, foram **todos vetados**), estabeleceu: “... apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4.º, da Constituição, é possível constatar a **omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência**. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, **não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas**, conduta esta que pode pôr em **risco a própria ordem constitucional**. A **inertia deliberandi** das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4.º, da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal”.

Dessa forma, “a tramitação de projeto de lei não obsta a caracterização de omissão inconstitucional, especialmente, se inobservado um prazo razoável de deliberação” (*Inf. 1.101/STF* — além do precedente firmado na ADI 3.682, cf., ainda, ADOs 27, 30 e 38).

Pelo que se observa do voto do Min. Gilmar Mendes, no direito alemão, com o objetivo de afastar as omissões legislativas, várias técnicas surgiram, como aquela que declara a **inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade** (*Unvereinbarerklärung*), ou aquela de **apelo ao legislador** (*Appellentscheidung*), esta última “... decisão na qual se afirma que a situação jurídica em apreço ainda se afigura constitucional, devendo o legislador empreender as medidas requeridas para evitar a consolidação de um estado de inconstitucionalidade”, tudo para se evitar uma inconcebível situação de “autêntico caos jurídico”.

E conclui: “o princípio do Estado de Direito (art. 1.º), a cláusula que assegura a imediata aplicação dos direitos fundamentais (art. 5.º, § 1.º) e o disposto no art. 5.º, LXXI, que, ao conceder o mandado de injunção para garantir os direitos e liberdades constitucionais, impõe ao legislador o dever de agir para a concretização desses direitos, exigem ação imediata para eliminar o estado de inconstitucionalidade”.

Assim, a ação foi julgada “... procedente para declarar o **estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional**, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4.º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios” (**ADO 3.682**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.05.2007, *DJ* de 06.09.2007).

Muito embora a *ementa* acima reproduzida não indique o caráter coercitivo da decisão do STF (“*não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável*”), a leitura do acórdão²²⁸ e suas discussões

finalis nos dava a ideia de que, em razão do **caráter mandamental** da decisão, o Congresso Nacional teria de legislar dentro de tal período de 18 meses, prazo, inclusive, fixado no dispositivo do acórdão.

Em não elaborando a lei, dado o caráter mandamental, consequências processuais poderiam decorrer e, ainda, parece-nos que seria possível aplicar, por analogia, o art. 64 e seus parágrafos (CF/88), com a ideia de travamento de pauta, ou, quem sabe, diante da evolução da jurisprudência do STF no controle das omissões legislativas (**MI 712** — cf. *item 14.11.5.7*) e das novidades introduzidas pela Lei n. 13.300/2016, o suprimento da omissão pelo próprio STF.

Questionando os efeitos práticos da **ADO 3.682**, em 11.09.2008, o Presidente da Câmara dos Deputados encaminhou o *Ofício n. 1073/2008/SGM/P*, de 02.09.2008, ao Presidente do STF, dizendo não ter tomado conhecimento de decisão que “obrigasse” o Parlamento a elaborar a LC, assim como alertando sobre o risco de a decisão do STF violar o **princípio da separação de Poderes** (art. 2.º, CF/88), caso fosse realmente impositiva a decisão proferida.

Contudo, restringindo nossa opinião, o então **Presidente do STF, Min. Gilmar Mendes**, determinou, em **12.09.2008**, por meio do *Ofício n. 346/GP*, fosse comunicado ao Presidente da Câmara dos Deputados o inteiro teor do acórdão de fls. 132-187, e esclareceu: **“não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI ns. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios”**.

Deixou claro, no entanto, que findo o prazo de 24 meses e não resolvida a situação dos Municípios criados violando a regra contida no art. 18, § 4.º, eles desapareceriam, restabelecendo a situação anterior.

Para tentar resolver esse impasse, o CN promulgou a **EC n. 57/2008**, que acrescentou o art. 96 ao ADCT: “ficam **convalidados** os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, **atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação**”.

Percebe-se que referida EC convalidou, de acordo com os limites temporais indicados, o vício formal de todas as leis estaduais que criaram Municípios sem a observância do art. 18, § 4.º, “constitucionalizando”, de maneira **ilegítima**, leis que nasceram inconstitucionais.

Parece-nos bem complicado aceitar que Municípios que foram criados, alguns até, por exemplo, sem o plebiscito adequado, sem um rigoroso estudo de viabilidade, sejam convalidados por emenda constitucional em um “gritante” e imoral mecanismo de **constitucionalidade superveniente**.

Em nosso entender, a EC foi contra a decisão do STF que fazia um “apelo” para se elaborar a lei complementar e, uma vez elaborada, a decisão do STF era no sentido de se corrigir o vício apontado, dando oportunidade para que os Municípios criados preenchessem todos os requisitos constantes do art. 18, § 4.º.

Foi por esse motivo que o STF fixou um prazo distinto na modulação dos efeitos.

Lembrando, o apelo era para o Congresso Nacional fazer a lei em 18 meses e, em relação aos Municípios, foi fixado o prazo de 24 meses de sobrevida. Essa diferença de 6 meses seria para que o Município corrigisse o vício formal de inconstitucionalidade, e, se nada fizesse, findo o prazo maior de 24 meses, implacavelmente, o Município desapareceria. Sem dúvida, novamente, insistimos, a EC mostra-se ilegítima e inconstitucional.

E qual a posição do STF sobre a matéria?

Temos observado que os municípios que foram **criados a partir de 31.12.2006**, data estabelecida pela emenda, não estão sendo preservados pelo STF, já que referida emenda convalidou expressamente apenas aqueles que foram efetivamente criados até aquela data, conforme se observa pelo

comando contido no art. 96, ADCT (cf. [ADI 4.992](#), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.09.2014, Plenário, *DJE* de 13.11.2014).

Por sua vez, em relação aos Municípios que foram **criados até 31.12.2006**, o STF vem determinando não apenas que a referida **data** seja observada, como também a **necessidade de realização de plebiscito**, pois, ao se determinar a observância dos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação (art. 96, ADCT), pressupõe-se que “as legislações estaduais para serem constitucionalmente válidas deveriam conter a previsão do plebiscito já estabelecida pela Constituição desde a redação originária do art. 18, § 4.º ” (cf. [RE 1.171.699](#), Pleno, j. 29.11.2019 — cf. [ADI 2.921](#)).

Nesse sentido, destacamos a tese para o *tema 559* da repercussão geral: “**a EC n. 57/2008 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária** e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados” ([RE 614.384](#), Pleno, j. 02.05.2022, *DJE* de 16.05.2022).

■ 6.7.4.9.2. *Novas perspectivas: ADOs 20, 24, 25, 26, 27 e 38 — um passo adiante nas decisões meramente recomendatórias*

Passamos a estudar importantes precedentes que sinalizam essa aplaudida perspectiva de superação do tímido entendimento que se firmou na jurisprudência do STF no sentido de somente constituir o Poder competente em mora.

O primeiro deles foi a decisão tomada pelo Min. Dias Toffoli, no **julgamento monocrático** do pedido de medida cautelar na **ADO 24** (j. 1.º.07.2013). Apesar de se tratar de julgamento monocrático e não pelo Plenário (como aquele proferido na ADO 25, a seguir analisado), a sua importância se mostra extremamente relevante, e, por isso, o seu destaque.

O art. 27, EC n. 19/98, estabeleceu o prazo de **120 dias** para que o Congresso Nacional **elaborasse a lei de defesa do usuário de serviços públicos**, aliás, um assunto extremamente importante quando se pensa nos serviços de saúde, educação, transporte, assistência social etc.

Nesse sentido, o **art. 37, § 3.º, I, CF/88**, estabelece que a lei disciplinará as formas de participação do **usuário** na administração pública direta e indireta, regulando especialmente e dentre outras questões as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. O **art. 175, I, CF/88**, por sua vez, ao disciplinar a prestação de serviços públicos, assevera, dentre outras questões, que a lei disporá sobre os **direitos dos usuários** e a **obrigação de manter o serviço adequado**.

No momento do julgamento do pedido de liminar (j. 1.º.07.2013), haviam-se passado **quase 20 anos**, e a lei, que deveria ter sido editada em 120 dias, a contar da data da EC n. 19/98, ainda não tinha sido elaborada, apesar da existência de projetos de lei tramitando (PLC n. 6.953/2002, substitutivo do PL n. 674/99).

Tratava-se de mais um complicado exemplo de **inatividade legislativa** e, no caso, por existirem os projetos de lei, de *inertia deliberandi* (discussão e votação).

Em sua decisão, de maneira acertada, o Ministro entendeu que a **inércia** na apreciação dos projetos de lei se mostrava **inaceitável**, já que **manifesta a omissão** a caracterizar afronta à Constituição (e, por que não dizer, nas palavras do Min. Gilmar Mendes, no julgamento da ADO 3.682, **omissão negligente e desidiosa a colocar em risco a própria ordem constitucional**).

Dessa forma, acolhendo o pedido formulado pela OAB, fixou o prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional elaborasse a lei.

Muito embora tenha sido fixado o prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional elaborasse a lei, de maneira extremamente complicada, pois não se respeitou a ordem judicial que fixava o prazo mais do que

razoável, somente em **26.06.2017** foi editada a **Lei n. 13.460**, estabelecendo as normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

A lei é bastante avançada e traz importantes conquistas. Contudo, algo nos chamou muito a atenção: o art. 25 do dispositivo legal estabelece os seguintes prazos, a contarem da publicação, para sua vigência (*vacatio legis*):

■ **360 dias** para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de quinhentos mil habitantes;

■ **540 dias** para os Municípios entre cem mil e quinhentos mil habitantes; e

■ **720 dias** para os Municípios com menos de cem mil habitantes.

Realmente, lamentável essa previsão de *vacatio legis* extremamente desarrazoada! A EC n. 19/98, há 19 anos, fixou um prazo de 120 dias para que a lei fosse elaborada. Passados não 120 dias, mas **19 anos**, ou seja, quase 7.000 dias (e não 120, insista-se), a lei foi publicada. Curiosamente, os Parlamentares fixaram novos prazos para sua vigência, totalmente inaceitáveis. Em nosso entender, o art. 25 da lei, que estabelece referidos prazos, tendo como parâmetro o de 120 dias a contar da promulgação da EC n. 19/98, ou seja, a contar de 04.06.1998, é flagrantemente inconstitucional.

Essa questão, pensamos, poderia ter sido discutida na referida ADO em análise, sob a perspectiva de que o desproporcional prazo de *vacatio legis* significou afronta ao prazo de 120 dias fixado na liminar, que foi proferida no ano de 2013. Em 20.12.2017, contudo, o processo foi extinto em razão do advento da lei e, assim, eventual discussão somente poderá ser travada em ação individual ou mediante a propositura de eventual ADI.

Agora passamos a analisar o **segundo precedente**, qual seja, o julgamento da **ADO 25**, que se deu pelo Plenário do STF e, assim, sem dúvida, trouxe novas e avançadas perspectivas.

Conforme expresso na E.M.I. n. 84/MF/C.Civil, de 30.04.2003, que encaminhou a PEC 41/2003, aprovada como **EC n. 42/2003** (“Reforma Tributária”), objetivava-se, com as alterações propostas, “mantendo a arrecadação nas três esferas de governo e fortalecendo a Federação”, “**estimular a atividade econômica e a competitividade do País**, através da racionalização e simplificação dos tributos”.

Assim, dentre as várias modificações introduzidas pela reforma, destacamos a constitucionalização da **desoneração do ICMS** prevista na *Lei Kandir* (LC n. 87/96 e suas alterações). Essa medida, contudo, gerou expressivo impacto nas finanças estaduais e prejuízos, já que, ao se prescrever a imunidade constitucional (art. 155, § 2.º, X, “a”), acabou com a referida receita pública.

Para compensar essa **perda de arrecadação**, o art. 91, ADCT, introduzido pela EC n. 42/2003, estabeleceu uma fórmula de transferência constitucional obrigatória da União para os Estados e o DF, consagrando um inegável exemplo de **federalismo cooperativo**, com o objetivo de **atenuar** os impactos financeiros decorrentes dos incentivos tributários.

Todo esse mecanismo compensatório, contudo, de acordo com a regra constitucional introduzida, depende de **lei complementar nacional**, que definirá o montante de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as **exportações** para o exterior de **produtos primários e semielaborados**, a **relação entre as exportações e as importações**, os **créditos** decorrentes de **aquisições destinadas ao ativo permanente** e a **efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2.º, X, “a”**.

Muito embora tenham sido fixados critérios provisórios de repasse nos termos do art. 91, § 3.º, ADCT, que remete às regras da *Lei Kandir*, essa previsão se mostra tímida e não reflete a realidade, estando muitos Estados com vultosos prejuízos. Há, portanto, uma inegável mora legislativa do Congresso Nacional desde 2003.

Diante desse quadro, em 30.11.2016, o STF julgou a **ADO 25** e, por maioria, **fixou prazo de 12 meses** para o Congresso Nacional sanar a omissão. Findo esse prazo e não sendo elaborada a lei complementar, caberá ao **Tribunal de Contas da União** (justificando essa incumbência ao TCU em razão do prescrito no art. 161, parágrafo único, CF/88) **a)** fixar o valor do montante total a ser transferido aos Estados-Membros e ao DF, considerando os critérios do art. 91, ADCT; **b)** calcular o valor das quotas a que cada um deles fará jus, considerando os entendimentos entre os Estados-Membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária — CONFAZ. Quando vier a ser elaborada a necessária lei complementar pelo Congresso Nacional, naturalmente, cessará de imediato a competência do TCU, conferida de forma **precária** e **excepcional** pela decisão judicial da Corte.

Estamos diante, neste caso da ADO 25, de precedente extremamente significativo e emblemático, que consagra a posição **concretista intermediária** que é a regra estabelecida pela lei que regulamentou o mandado de injunção (cf. art. 8.º da Lei n. 13.300/2016 e discussão no *item 14.11.5.7* deste nosso estudo). Como disse a Min. Cármen Lúcia, “a fixação de um prazo para que o parlamento supra a omissão é um **passo adiante na natureza recomendatória** que se tinha no julgamento das ADOs” (*Notícias STF*, 30.11.2016).

Destacamos que houve pedido de prorrogação do prazo por mais 12 meses e, depois, por mais 90 dias, tendo sido referendada a decisão do Relator pela maioria dos Ministros. Em seguida, foi homologado acordo firmado entre a União e todos os Entes Estaduais para encaminhamento ao Congresso Nacional para as providências cabíveis, nos termos do voto do Relator.

Trata-se, sem dúvida, de situação inédita no âmbito federativo. “A Corte registrou a inauguração, nesta ADO, do **pensamento do possível no Federalismo cooperativo**, uma das facetas mais formidáveis da interpretação constitucional. Todos os atores do pacto federativo foram chamados para tentarem solucionar o impasse entre as esferas federal, estadual e distrital,

que se prolongava desde a instituição da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996), com algumas atuações pontuais produzidas pelas Leis Complementares 102/2000 e 115/2002 e com a EC 42/2003. As unidades federativas foram conclamadas para que, na linha do pensamento do possível, se dissipassem de suas certezas absolutas, interesses estratificados e compreendessem a oportunidade sob o olhar do federalismo cooperativo, no afã de diminuir as tensões/diferenças e aproximar as convergências”.

No referido acordo, “chegou-se a um consenso mínimo quanto a valores e forma de pagamento, deu-se quitação de eventuais dívidas pretéritas e futuras. Previu-se que a parcela constitucionalmente devida aos municípios (25%) está reservada e que não serão devidos honorários advocatícios nas ações judiciais extintas em decorrência dele. Nele, há cláusula resolutória e eleição de foro para dirimir eventuais entraves que surjam em sua interpretação” (*Inf. 978/STF*).

O Congresso Nacional, em criticável demora, somente em 29 de dezembro de 2020, editou a **LC n. 176** para dispor sobre a compensação das perdas na arrecadação, conforme acima estudado, sendo que a **EC n. 109/2021** revogou o art. 91, ADCT.

Destacamos, agora, o julgamento da **ADO 26** (em conjunto com o **MI 4.733**), na qual, de maneira inovadora, o STF adotou a posição **concretista direta, geral e com efeito vinculante**.

O Tribunal, por maioria, reconheceu o “**estado de mora constitucional** do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5.º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT”.

Assim, diante da existência de **omissão normativa constitucional do Poder Legislativo da União**, a Corte **cientificou o Congresso Nacional**, constituindo-o em mora formal.

Contudo, sem dar qualquer prazo ou obrigar o Congresso Nacional a legislar (o que poderia significar afronta à separação de poderes), o STF deu “interpretação conforme à Constituição, em face dos **mandados**

constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5.º da Carta Política, para **enquadrar a homofobia e a transfobia**, qualquer que seja a forma de sua manifestação, **nos diversos tipos penais definidos na Lei n. 7.716/89**, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que as **práticas homotransfóbicas** qualificam-se como espécies do gênero **racismo**, na dimensão de **racismo social** consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais **comportamentos de homotransfobia** ajustam-se ao conceito de **atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão**” (ADO 26, j. 13.06.2019, DJE de 06.10.2020).

Os Mins. Lewandowski e Toffoli questionaram se seria possível o Poder Judiciário estabelecer a criminalização de determinada conduta, especialmente diante da regra contida no **art. 5.º, XXXIX**, CF/88, que consagra o **princípio da estrita reserva legal** (cf. *item 14.10.28.2*). Em outras palavras e abrindo o questionamento: poderia o Poder Judiciário ter criminalizado uma determinada conduta, invadindo a atribuição específica do Poder Legislativo?

Em um primeiro momento, entendemos que não, mesmo que se esteja diante de interpretação conforme à Constituição. Pensamos que o Supremo “legislou”, e, nesse sentido, por mais que tenhamos a expectativa de um STF mais ativo no controle das omissões normativas, essa atuação positiva em matéria penal, definindo condutas criminosas, mostra-se muito delicada. (Estamos avaliando, contudo, diante do importante comando constitucional estabelecido nos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5.º, até que ponto se poderia tolerar a inércia parlamentar. Qual seria o limite dessa omissão inconstitucional?)

Analisamos, agora, o julgamento da **ADO 27**.

O art. 3.º, EC n. 45/2004 (Reforma do Judiciário), tem a seguinte redação: “a **lei** criará o **Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas (FUNGET)**, integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas”.

Até o fechamento desta edição, referida lei ainda não havia sido aprovada, mesmo depois de quase 20 anos da reforma constitucional, existindo projetos de lei encaminhados, porém sem movimentação desde 2010 (*inertia deliberandi*).

Nesse sentido, o STF adotou a posição **concretista intermediária**, fixando um prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional edite a norma. Ao que parece, o provimento tem caráter mandamental (ADO 27, j. 30.06.2023, *DJE* de 28.02.2023).

Passamos a analisar **ADO 38**.

Esse precedente diz respeito à fixação do número de deputados por lei complementar federal, observado o limite de no mínimo 8 e no máximo 70 Deputados Federais por Estado (art. 45, § 2.º, CF/88).

A LC n. 78/93, ao disciplinar o assunto, fixou o número de deputados em 513, mas, em seu art. 1.º, parágrafo único, **delegou** a segunda obrigação (fixação da representação por Estado e pelo DF) ao **TSE**.

O STF entendeu essa delegação como **inconstitucional**. Trata-se de critério envolvendo **juízo de valor** a ser determinado **necessariamente** pelo **Parlamento**, não se admitindo a transferência dessa atribuição para o TSE ou para qualquer outro órgão. Na mesma assentada, por conseguinte, os Ministros declararam a inconstitucionalidade da **Res. n. 23.389/2013 do TSE**, que disciplinava o tamanho das bancadas para cada Estado e para o DF (ADIs 4.947, 4.963, 4.965, 5.020, 5.028 e 5.130, Rel. p/ o ac. Min. Rosa Weber, j. 1.º.07.2014, Plenário, *DJE* de 30.10.2014).

Em momento seguinte, o STF reconheceu a “mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do § 1.º do art. 45 da CF (*revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado/população*), **fixando prazo até 30.06.2025 para que seja sanada**

a omissão, pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes, e entendeu que, após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao TSE determinar, até 1.º.10.2025, o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais (CF, arts. 27, *caput*, e 32, § 3.º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição e o número total de parlamentares previsto na LC n. 78/1993, valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022 e da metodologia utilizada por ocasião da edição da Resolução-TSE 23.389/2013” (**ADO 38**, j. 28.08.2023, *DJE* de 09.10.2023).

Finalmente, trazemos o estudo da **ADO 20**, na qual o STF discutiu uma alegada existência de omissão inconstitucional na regulamentação da **licença-paternidade** (art. 7.º, XIX, CF/88), entendendo ser o art. 10, § 1.º, ADCT, que prescreve o prazo de 5 dias, “regra transitória, prevista há mais de três décadas, que se revela **manifestamente insuficiente** para suprir a omissão na regulamentação do direito constitucional à licença-paternidade” (Min. Barroso, em seu voto, fls. 1).

Buscando implementar a igualdade de gênero (art. 5.º, I, CF/88) e cumprir os deveres constitucionais de proteção familiar e à infância, a Corte aprovou a seguinte tese de julgamento: “1. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no art. 7.º, XIX, da Constituição. 2. Fica estabelecido o **prazo de 18 meses** para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, **caberá a este Tribunal fixar o período da licença-paternidade**” (j. 14.12.2023).

Analisando a evolução das decisões tomadas pelo STF nas ADOs 20, 24, 25, 26, 27 e 38, confirmamos que essas novas perspectivas consagram um novo sentido para a ADO que não seja o da ineficiente “mera ciência”.

■ **6.7.4.10. A atual jurisprudência do STF admite a fungibilidade entre ADI e ADO?**

SIM.

Pedimos vênia para transcrever a ementa do precedente, recomendando a leitura do voto do Min. Gilmar Mendes, bem como a análise da discussão que expusemos no *item 6.7.3.10* deste estudo, tendo o STF estabelecido alguns parâmetros:

“EMENTA: Senhores Ministros, Senhoras Ministras. Estamos diante de um caso deveras interessante. Temos quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI n. 1.987/DF, ADI n. 875/DF, ADI n. 2.727/DF e ADI n. 3.243/DF) imbricadas por uma evidente relação de conexão, fenômeno que determina o seu **julgamento conjunto**, conforme a jurisprudência desta Corte (**ADI-MC n. 150**, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* 9.3.1990). Por outro lado, é possível observar a intenção dos requerentes de estabelecer uma nítida **distinção de pedidos**: uns pela declaração da inconstitucionalidade por omissão e outros pela declaração da inconstitucionalidade (por ação). (...) O quadro aqui revelado, portanto, está a demonstrar uma **clara imbricação de pedidos e causas de pedir** e, dessa forma, a **evidenciar a patente fungibilidade que pode existir entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão**. (...) A Lei n. 9.868/99 possui capítulos específicos para a ação direta de inconstitucionalidade (Capítulo II) e para a ação declaratória de constitucionalidade (Capítulo III). Com a nova Lei n. 12.063, de 22 de outubro de 2009, a Lei n. 9.868/99 passa a contar com o capítulo II-A, que estabelece rito procedimental e medidas cautelares específicas para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A Lei n. 9.882/99, por seu turno, trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental. No Supremo Tribunal Federal, atualmente, todas as ações possuem uma classe específica de autuação: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI); Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); Ação Direta de

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). **Portanto, ante a aparente confusão inicialmente verificada nos diversos pedidos, como demonstrado, e tendo em vista a patente defasagem da jurisprudência até então adotada pelo Tribunal, temos aqui uma valiosa oportunidade para superarmos o antigo entendimento e reconhecemos o caráter fungível entre as ações**” (ADI 875; ADI 1.987; ADI 2.727, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2010, Plenário, DJE de 30.04.2010).

■ 6.7.5. Representação Interventiva (IF)

■ 6.7.5.1. Conceito (IF)

O art. 18, *caput*, CF/88, estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**. Vale dizer, como regra geral, nenhum ente federativo deverá intervir em qualquer outro.

Excepcionalmente, no entanto, a CF prevê situações (de anormalidade) em que poderá haver a intervenção:

- **União** → nos **Estados, Distrito Federal** (hipóteses do art. 34) e nos **Municípios localizados em Território Federal**²²⁹ (hipótese do art. 35);
- **Estados** → em seus **Municípios** (art. 35).

A **representação interventiva**, que surgiu, conforme visto, com a Constituição de 1934, apresenta-se como um dos pressupostos para a decretação da intervenção federal, ou estadual, pelos Chefes do Executivo, nas hipóteses contempladas na CF/88.²³⁰ Assim, reforce-se, nessa modalidade de procedimento, quem decreta a intervenção não é o Judiciário, mas o Chefe do Poder Executivo.

Clèmerson Clève, ao analisar o instituto, conclui tratar-se de “... procedimento fincado a meio caminho entre a fiscalização da lei *in thesi* e aquela realizada *in casu*. Trata-se, pois, de uma variante da fiscalização concreta realizada por meio de ação direta”.²³¹

O Judiciário exerce, assim, um controle da **ordem constitucional** tendo em vista o **caso concreto** que lhe é submetido à análise.

Nesse sentido, Barroso observa que “... embora seja formulado um juízo de certa forma abstrato acerca da constitucionalidade do ato normativo — nas hipóteses em que o ato impugnado tenha essa natureza (e, acrescente-se, veremos que o objeto não se resume a ato normativo) — não se trata de processo objetivo, sem partes ou sem um caso concreto subjacente. Cuida-se, sim, de um **litúgio constitucional**, de uma **relação processual contraditória**, contrapondo União e Estado-membro, cujo desfecho pode resultar em intervenção federal”.²³²

O Judiciário não nulifica o ato, mas apenas verifica se estão presentes os pressupostos para a futura decretação da intervenção pelo Chefe do Executivo.

Poderíamos pensar, então, em 3 fases do procedimento, estudadas a seguir:

FASE 1	FASE 2	FASE 3
■ fase jurisdicional: o STF ou TJ analisam apenas os pressupostos para a intervenção, não nulificando o ato que a ensejou. Julgando procedente o pedido, requisitam a intervenção para o Chefe do Executivo	■ intervenção branda: o Chefe do Executivo, por meio de decreto, limita-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade ■ controle político? NÃO. Nesta <i>fase 2</i>, está dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa	■ intervenção efetiva: se a medida tomada durante a <i>fase 2</i> não foi suficiente, o Chefe do Executivo decretará a efetiva intervenção, devendo especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor ■ controle político? SIM. Nesta <i>fase 3</i>, deverá o decreto do Chefe do Executivo ser submetido à apreciação do

		Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas, sendo que, estando em recesso, será feita a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas
--	--	--

■ 6.7.5.2. ***Representação interventiva federal (ADI interventiva federal)***

O art. 36, III, CF/88, primeira parte, estabelece que a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo **STF**, de representação do **Procurador-Geral da República**, na hipótese do **art. 34, VII**, quais sejam, os **princípios sensíveis da Constituição**.

Durante a vigência do texto de 1988, jamais se passou da *fase 1* (judicial) para a *fase 2* (decretação pelo Chefe do Poder Executivo), muito embora alguns poucos pedidos de intervenção, com base no art. 36, III, destacando-se:

■ **IF 114** (07.02.1991): pedido de intervenção em razão de omissão do Poder Público no controle de **linchamento de presos** no Estado de Mato Grosso. No mérito, o STF entendeu que não era caso de intervenção, indeferindo, portanto, o pedido;

■ **IF 4.822** (08.04.2005): pedido de intervenção no *Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje)*, com base em deliberação do *Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)*, que condenou a sua estrutura física e gerencial. A Min. Cármen Lúcia, “considerando o decurso do tempo, os termos em que apresentado o pedido de intervenção federal e a notícia, de domínio público, sobre a desativação e demolição do antigo Centro de Atendimento Juvenil Especializado do Distrito Federal”, em 02.05.2018, julgou prejudicado o pedido de intervenção federal por perda superveniente de objeto;

■ **IF 5.129 (05.10.2008)**: pedido de intervenção formulado pelo PGR contra o estado de Rondônia, por suposta violação a direitos humanos no **presídio Urso Branco**, em Porto Velho, que se encontra em situação de “calamidade”. Segundo o então PGR, Antonio Fernando Souza, “... nos últimos oito anos contabilizaram-se mais de cem mortes e dezenas de lesões corporais [contra presos], fruto de motins, rebeliões entre presos e torturas eventualmente perpetradas por agentes penitenciários” (*Notícias STF*, 08.10.2008). O pleito interventivo foi julgado prejudicado em razão da “substancial alteração do quadro fático-normativo”, conforme manifestação da PGR (j. 27.09.2023);

■ **IF 5.179 (11.02.2010)**: pedido de intervenção por suposto esquema de corrupção no DF. Conforme relatado a seguir, no mérito, o pedido foi julgado improcedente.

■ 6.7.5.2.1. *Objeto (IF)*

Apesar de, em um primeiro momento, o STF, mesmo diante de doutrina em sentido contrário (Alfredo Buzaid²³³), ter limitado o objeto da ação somente a atos normativos (**Rp 94/DF**, Rel. Min. Castro Nunes, j. 17.07.1946), o entendimento atual é o **mais amplo possível**, podendo ser objeto da ação:

■ **lei ou ato normativo que viole princípios sensíveis;**

■ **omissão ou incapacidade** das autoridades locais para assegurar o cumprimento e preservação dos princípios sensíveis, por exemplo, os direitos da pessoa humana;

■ **ato governamental estadual** que desrespeite os princípios sensíveis;

■ **ato administrativo que afronte os princípios sensíveis;**

■ **ato concreto que viole os princípios sensíveis.**

A **fase judicial** da intervenção não se confunde com a fase judicial das demais ações de inconstitucionalidade, pois, como visto, na ADI Interventiva (ou, por alguns, denominada **representação interventiva**), o Tribunal **não**

nulificará, na **hipótese de lei**, o ato normativo.

Em relação à **omissão**, trata-se de importante avanço, já sugerido pela doutrina e, posteriormente, sedimentado na jurisprudência do STF, bem como na **Lei n. 12.562/2011**.

Como exemplo, citamos situação em que presos no Estado do Mato Grosso, por omissão estatal e negligência, estavam sendo **linchados** pela população local, revoltada com a gravidade dos crimes praticados.

Naturalmente, o STF entendeu que a omissão e a incapacidade do governo local em garantir o direito de presos (**direitos da pessoa humana**) já seriam suficientes para o cabimento da ação. Nesse sentido:

“Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos ‘direitos da pessoa humana’, em face de **fato criminoso praticado com extrema crueldade** a indicar a inexistência de ‘condição mínima’, no Estado, ‘para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida’. (...) Hipótese em que estão em causa ‘direitos da pessoa humana’, em sua compreensão mais ampla, revelando-se **impotentes as autoridades policiais locais** para manter a **segurança** de três presos que acabaram subtraídos de sua proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. Intervenção federal e restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade da medida interventiva.” No tocante ao mérito do STF, contudo, embora a gravidade dos fatos, negou provimento ao pedido já que o Estado de Mato Grosso estaria procedendo a apuração do crime (**IF 114**, Rel. Min. Presidente Néri da Silveira, j. 13.03.1991).

O pedido de intervenção, conforme já referimos, também poderá envolver o DF, em razão de lei ou ato normativo, omissão ou ato governamental **distrital**.

Nessa linha, destacamos, para exemplificar, pedido de intervenção em razão de **ato governamental** a sugerir suposto “esquema de corrupção”, preservado, segundo o pedido formulado, por omissão das autoridades locais.²³⁴

Estamos nos referindo à IF 5.179, tendo sido o pedido formulado pelo PGR com base no art. 34, VII, “a”, por suposta violação aos **princípios republicano e democrático**, bem como ao **sistema representativo** (art. 34, VII, “a”, CF).

O pedido de intervenção federal fundou-se na “... **alegação** da existência de **esquema de corrupção** que envolveria o ex-Governador do DF, alguns Deputados Distritais e suplentes, investigados pelo STJ, e cujo concerto estaria promovendo a desmoralização das instituições públicas e comprometendo a higidez do Estado Federal. Tais fatos revelariam conspícua **crise institucional** hábil a colocar em risco as atribuições político-constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e provocar instabilidade da ordem constitucional brasileira. (...) **No mérito**, entendeu-se que o perfil do momento político-administrativo do Distrito Federal já **não autorizaria a decretação de intervenção federal**, a qual se revelaria, agora, **inadmissível** perante a **dissolução do quadro que se preordenaria a remediar...**”, tendo ficado vencido o Min. Ayres Britto (IF 5.179, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2010, Plenário, DJE de 08.10.2010 e Inf. 593/STF).

Em face da gravidade dos fatos expostos na inicial, muito embora o **indeferimento** do pedido de intervenção acima relatado, vale a pena reproduzir passagens do voto **vencido** do Min. Ayres Britto (que pode ser lido na íntegra, uma vez que já publicado o referido acórdão):

“O Distrito Federal padece de **leucemia ética, democrática e cívica**, pelas suas cúpulas no âmbito do Legislativo e do Executivo. O caso é de **hecatombe institucional**. E aí, serve como luva encomendada essa **ferramenta** chamada de **intervenção**”, disse Ayres Britto.

Gurgel pediu a intervenção após ser deflagrada uma crise política na capital federal a partir de operação da Polícia Federal que investigou denúncias de corrupção, formação de quadrilha, desvio de verbas

públicas e fraude em licitações no governo do DF.

Ayres Britto afirmou que a máquina administrativa distrital ainda padece de **deficiências graves**, mesmo após a eleição indireta do governador Rogério Rosso (PMDB) e que o Poder Legislativo ainda se encontra em estado de **letargia**, de não funcionamento. ‘A mentalidade dos governantes nos dois Poderes, Executivo e Legislativo, não mudou, permanece’, ponderou. ‘O caso é de cultura antirrepublicana de governo. Daí a necessidade da intervenção federal’.

Ele acrescentou ainda que há ‘provas robustas’, com fitas e depoimentos que evidenciam a situação de corrupção na capital federal, mas ressaltou que essa situação é, na verdade, um sintoma. ‘A causa da corrupção, dos desvios administrativos, de tantos conluíus espúrios está em uma **cultura antirrepublicana** que se instalou no Distrito Federal de longa data. Uma cultura antirrepublicana de governo que não é de agora’, afirmou.

Ele destacou a importância do Distrito Federal perante a nação, por ser a capital da República, como mais uma razão para a intervenção, e foi taxativo: ‘O bom exemplo republicano, representativo, democrático, ético tem que partir de Brasília. O bom exemplo vem de cima’.

‘Acho que a oportunidade é excelente para se fazer uma **profilaxia**. Não para cassar o Distrito Federal. Na verdade, se trata de **libertar o Distrito Federal das garras de um perigosíssimo esquema de enquadramento para assaltar o erário**’, concluiu Ayres Britto” (cf. *Notícias STF*, 30.06.2010).

■ 6.7.5.2.2. *Princípios sensíveis*

Cabe o pedido de intervenção, já referimos, quando houver violação aos denominados **princípios sensíveis**, que estão expostos no art. 34, VII, “a”-“e”:

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- direitos da pessoa humana;

- autonomia municipal;
- prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta;
- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde.

■ 6.7.5.2.3. *Competência (IF)*

Na hipótese de **representação interventiva federal**, a competência é **originária** do **STF** (art. 36, III).

■ 6.7.5.2.4. *Legitimidade (IF)*

O **único** e **exclusivo** *legitimado ativo* para a propositura da **representação interventiva federal** é o **Procurador-Geral da República**, que tem total **autonomia** e **discricionariedade** para formar o seu convencimento de ajuizamento.

Já se sustentou atuar ele como representante da União, chegando, outros, a sugerir, no entanto, que essa atribuição fosse transferida, por emenda, para o AGU.

Contudo, não nos parece adequado nem a ideia de representação da União, em virtude da regra constante no art. 129, IX, que veda, expressamente, por parte do Ministério Público, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, nem mesmo a transferência dessa atribuição para o AGU.

O entendimento que deve ser adotado é o de que o **PGR** atua em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sobretudo, no caso, a defesa do **equilíbrio federativo**.

Legitimado passivo deve ser entendido como o **ente federativo** no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CF/88, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos estaduais ou distritais responsáveis, como a Assembleia Legislativa local ou o Governador, neste último caso representado pelo Procurador-Geral do Estado ou do DF (art. 132, CF/88).

Verifica-se, assim, uma **relação processual controvertida** entre a União e os Estados-Membros ou o DF.

■ 6.7.5.2.5. *Procedimento (IF)*

O procedimento da **representação interventiva federal** estava previsto na **Lei n. 4.337, de 1.º.06.1964**, assim como nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.038/90 e nos arts. 350 a 354, *RISTF*.

Contudo, cabe alertar a publicação da **Lei n. 12.562, de 23.12.2011**, regulamentando o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o STF.

Proposta a ação pelo Procurador-Geral da República, no STF, a petição inicial deverá conter:

■ a indicação do **princípio constitucional** sensível (art. 34, VII, CF/88) que se considera violado ou, se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas (esta última hipótese será tratada no capítulo 7, no item sobre *intervenção federal*);

■ a indicação do **ato normativo**, do **ato administrativo**, do **ato concreto** ou da **omissão** questionados;

■ a **prova** da **violação do princípio constitucional** ou da recusa de execução de lei federal;

■ o **pedido**, com suas especificações.

A petição inicial será apresentada em 2 vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado (**estadual** ou **distrital**) e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Incumbe ao relator **indeferir liminarmente** a **petição inicial** quando:

- não for o caso de representação interventiva;
- faltar algum dos requisitos estabelecidos na lei;
- for inepta.

Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá, de acordo com a lei, **agravo**, no prazo de **5 dias**.

Mas cuidado, entendemos que essa regra, prevista no art. 4.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011, foi **revogada** pelo CPC/2015.

De acordo com o Novo Código, com *vacatio legis* de um ano a contar da data de sua publicação oficial (art. 1.045), previsto nos arts. 994, III, e 1.021, contra a decisão monocrática do Relator caberá o recurso de **agravo interno** para o Pleno do STF. A novidade é que, por força da regra explícita do art. 1.070 e da previsão geral fixada no art. 1.003, § 5.º, o prazo para a interposição desse recurso, bem como para responder-lhe (art. 1.021, § 2.º), passa a ser de **15 dias** (e não mais de 5), devendo a contagem, pela regra geral do art. 219, Novo CPC/2015, dar-se em **dias úteis**.

Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir **(administrativamente)** o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do regimento interno.

Não solucionado o problema e não sendo caso de arquivamento, apreciado eventual pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as **informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado**, que as prestarão em até **10 dias**.

Decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o **AGU** e o **PGR**, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de **10 dias**.

O relator, se entender necessário, poderá **requisitar informações adicionais**, **designar perito** ou **comissão de peritos** para que elabore laudo sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em **audiência pública**, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Poderão ser autorizadas, ainda, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo, reconhecendo-se, assim, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, da Lei n. 12.562/2011, a manifestação de **amicus curiae**.

Vencidos os prazos ou, se for o caso, realizadas as diligências, o relator lançará o relatório, com cópia para todos os Ministros e pedirá dia para julgamento.

A **decisão** sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos **8 Ministros** (*quorum* de instalação da sessão de julgamento, como se verifica, também, na ADI), devendo ser proclamada a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 Ministros (**maioria absoluta**).

Estando ausentes Ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será **suspenso**, a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão.

Julgado procedente o pedido, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela **procedência do pedido** formulado na representação interventiva, o Presidente do STF, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do **Presidente da República** para, no **prazo improrrogável de até 15 dias**, dar cumprimento aos §§ 1.º e 3.º do art. 36 da Constituição Federal.

Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do *Diário da Justiça* e do *Diário Oficial da União*.

Por se tratar de **“requisição”**, e não mera solicitação, o Presidente da República não poderá descumprir a **ordem mandamental**, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, devendo, então, decretar a intervenção (por nós denominada, nesta agora *fase 2* — *vide* quadro *supra*, item 6.7.5.1 —, **intervenção branda**).

O Presidente da República, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de **decreto**, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado. Caso essa medida não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o **Presidente da República decretará** a intervenção federal (*fase 3 — intervenção efetiva*).

Nesse último caso, o **decreto de intervenção**, que especificará a **amplitude**, o **prazo** e as **condições de execução** e que, **se couber, nomeará** o **interventor** afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, CF/88), será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas (**controle político**). Se o Congresso Nacional não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas (art. 36, §§ 1.º e 2.º, CF/88).

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo por impedimento legal (art. 36, § 4.º, CF/88).

Cabe alertar que a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é:

- **irrecorrível;**
- **insuscetível de impugnação por ação rescisória.**

■ 6.7.5.2.6. *Medida liminar (IF)*

Barroso chegou a sustentar que “a natureza e a finalidade da ação direta interventiva **não são compatíveis com a possibilidade de concessão de medida liminar**. Não há como antecipar qualquer tipo de efeito, como a eventual suspensão do ato impugnado, uma vez que a própria decisão de mérito tem como consequência apenas a determinação de que o Chefe do Executivo execute a intervenção”.²³⁵

Cumprе lembrar, contudo, que o art. 2.º da Lei n. 5.778/72, que regula o processo da *representação interventiva estadual*, estabelece que o relator da representação poderá, a requerimento do chefe do Ministério Público estadual

e mediante despacho fundamentado, **suspender liminarmente o ato impugnado**.

Anteriormente, o art. 5.º da Lei n. 4.337/64 previa um *procedimento abreviado* para a análise do pedido.

Finalmente, o art. 5.º da Lei n. 12.562/2011 **admitiu expressamente o cabimento de medida liminar na representação interventiva**, mas somente por decisão da **maioria absoluta** dos Ministros.

Parece que a não previsão de concessão de medida liminar pelo Relator ou pelo Ministro Presidente do STF (diferente das outras ações de controle) vai ao encontro da preocupação lançada por Barroso e da gravidade dos efeitos da decisão em relação à Federação.

Para concessão da liminar, o relator **poderá** ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o AGU ou o PGR, no prazo comum de 5 dias.

A liminar poderá consistir na determinação de que se **suspenda o andamento de processo** ou **os efeitos de decisões judiciais** ou **administrativas** ou **de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva**.

■ 6.7.5.2.7. ***Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal***

O art. 36, III, estabelece o cabimento de **representação interventiva** perante o **STF**, a ser ajuizada pelo **PGR**, no caso de **recusa à execução de lei federal** por parte de Estado-Membro ou do Distrito Federal (art. 34, VI, 1.ª parte).

Gilmar Mendes prefere falar em **“recusa à execução do direito federal”**,²³⁶ o que também entendemos mais adequado.

Relembramos que, originalmente, o texto de 1988 falava em competência do STJ, equívoco este corrigido pela *Reforma do Judiciário* (EC n. 45/2004), que, acertadamente, deixou claro ser competência do **STF**, até porque, no fundo, o que se tem é um conflito entre a União e o Estado ou a

União e o DF (que descumprem ou não aplicam o direito federal), incidindo, assim, a regra do **art. 102, I, “f”**, CF/88, e, portanto, a competência do STF.

O procedimento está previsto, igualmente, na **Lei n. 12.562/2011**, e tudo o que se falou acima se aplica à hipótese.

A doutrina tem-se limitado a tratar como ADI Interventiva (admitindo-se essa nomenclatura ainda como adequada) a hipótese do art. 34, VII (violação aos princípios sensíveis), e, assim, remetemos o nosso ilustre leitor para a temática da *intervenção federal estudada no capítulo 7 (item 7.12)*.

■ 6.7.5.3. **Representação interventiva estadual (ADI interventiva estadual)**

O processo da **representação interventiva estadual** está regulamentado na **Lei n. 5.778/72**, que, em seu art. 1.º, *caput*, estabelece que o processo e o julgamento das representações interventivas estaduais em Municípios regulam-se, no que for aplicável, pela **Lei n. 4.337/64**, excetuado o seu art. 6.º (que tinha a seguinte redação: “*só caberão embargos, que se processarão na forma da legislação em vigor, quando, na decisão, forem 3 (três) ou mais os votos divergentes*”).

Alertamos, contudo, que, com o advento da **Lei n. 12.562/2011**, que tratou de toda a matéria, a nosso ver, a Lei n. 4.337/64 foi totalmente revogada e, assim, o procedimento deverá observar, no que couber, as novas regras introduzidas pela referida Lei n. 12.562/2011.

O art. 35, IV, CF/88, por sua vez, dispõe que a intervenção estadual, a ser decretada pelo **Governador de Estado**, dependerá de provimento pelo **TJ local** de representação para assegurar a observância de princípios indicados na CE, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. As regras vêm previstas nas Constituições estaduais e nos regimentos internos dos tribunais locais, devendo, em essência, por **simetria**, seguir o **modelo federal**, de acordo com o seguinte quadro:

ADI INTERVENTIVA FEDERAL

ADI INTERVENTIVA

		ESTADUAL
Fase 1 — “Judicial”		
OBJETO	■ Lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental estaduais ou distritais que desrespeitem os princípios sensíveis previstos no art. 34, VII, “a”-“e”, CF/88	■ Lei ou ato normativo, ou omissão, ou ato governamental municipais que desrespeitem os princípios sensíveis indicados na CE
COMPETÊNCIA	■ STF — originária	■ TJ — originária
LEGITIMADO ATIVO	■ PGR — Chefe do Ministério Público da União (art. 129, IV, CF/88)	■ PGJ — Chefe do Ministério Público Estadual (art. 129, IV, CF/88)
LEGITIMADO PASSIVO	■ Ente federativo (Estado ou DF) no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CF/88, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos estaduais ou distritais responsáveis pela violação aos princípios sensíveis	■ Ente federativo (Município) no qual se verifica a violação ao princípio sensível da CE, devendo ser solicitadas informações às autoridades ou aos órgãos municipais responsáveis pela violação aos princípios sensíveis
PROCEDIMENTO	■ Proposta a ação pelo Procurador-Geral da República, no STF, quando a lei ou o ato normativo de natureza estadual (ou distrital), ou omissão, ou ato governamental contrariarem os princípios sensíveis da CF, buscar-se-á a solução administrativa ■ Não sendo o caso, nem o de arquivamento, serão solicitadas informações às autoridades estaduais ou distritais responsáveis e ouvido o PGR, sendo, então, o pedido relatado e levado a julgamento ■ Julgado procedente o pedido (<i>quorum</i> do art. 97, maioria absoluta), o Presidente do STF imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do Poder Público	■ Proposta a ação pelo Procurador-Geral de Justiça, no TJ, quando a lei ou o ato normativo, ou omissão, ou ato governamental de natureza municipal contrariarem os princípios sensíveis previstos na CE, buscar-se-á a solução administrativa ■ Não sendo o caso, nem o de arquivamento, serão solicitadas informações às autoridades municipais responsáveis e ouvido o PGJ, sendo, então, o pedido relatado e levado a julgamento ■ Julgado procedente o pedido (<i>quorum</i> do art. 97, maioria absoluta), o Presidente do TJ imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do Poder Público

	interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República , que, por se tratar de “requisição”, e não mera solicitação, não poderá descumprir a ordem mandamental, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, inaugurando-se, assim, a <i>fase 2</i> do procedimento	interessados e requisitará a intervenção ao Governador do Estado , que, por se tratar de “requisição”, e não mera solicitação, não poderá descumprir a ordem mandamental, sob pena de cometimento tanto de crime comum como de responsabilidade, inaugurando-se, assim, a <i>fase 2</i> do procedimento
Fase 2 — “Intervenção Branda”		
DECRETO DO EXECUTIVO	■ O Presidente da República, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de decreto, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade ■ Nessa fase, está dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional (controle político)	■ O Governador do Estado, nos termos do art. 36, § 3.º, por meio de decreto, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade ■ Nessa fase, está dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa (controle político)
Fase 3 — “Intervenção Efetiva”		
DECRETO DO EXECUTIVO E CONTROLE POLÍTICO	■ Caso a medida de mera suspensão não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o Presidente da República decretará a efetiva intervenção no Estado ou no DF, executando-a com a nomeação de interventor, se for o caso, e afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, CF/88) ■ Nesse caso de intervenção efetiva, haverá controle político pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas a contar do decreto interventivo. Se o Congresso Nacional não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária	■ Caso a medida de mera suspensão não seja suficiente para o restabelecimento da normalidade, aí, sim, o Governador do Estado decretará a efetiva intervenção no Município, executando-a com a nomeação de interventor, se for o caso, e afastando as autoridades responsáveis de seus cargos (art. 84, X, CF/88) ■ Nesse caso de intervenção efetiva, haverá controle político pela Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas a contar do decreto interventivo. Se a Assembleia Legislativa não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária

	■ Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal	■ Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal
--	--	--

■ 6.8. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS ESTADOS-MEMBROS

■ 6.8.1. Regras gerais

Nos termos do art. 125, § 2.º, CF/88, cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Nesse sentido, o constituinte consagrou, ao menos na literalidade do referido dispositivo, o controle abstrato de constitucionalidade estadual, fixando regras claras:

- somente leis ou atos normativos **estaduais** ou **municipais** poderão ser objeto de controle;
- o parâmetro ou paradigma de confronto deverá ser a **Constituição Estadual** (e esse tema será retomado ao analisarmos a perspectiva das normas de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE — cf. *item 6.8.5*);
- apesar de não fixar explicitamente os legitimados, **vedou** a atribuição da legitimação para agir a um único órgão;
- o órgão competente para o julgamento da ação pela via principal será, exclusivamente, o **TJ local**.

Pelo princípio da simetria, muito embora o art. 125, § 2.º, tenha fixado somente a possibilidade de instituição de **representação de inconstitucionalidade** (que corresponderia à ADI), parece-nos perfeitamente possível que, desde que respeitadas as regras da CF/88, se implementem os demais meios de controle, quais sejam, além do controle difuso, as ações de controle concentrado originariamente no TJ local, destacando-se: a já

mencionada representação de inconstitucionalidade, a ADC, a ADPF, a ADO e a IF — representação interventiva (ADI interventiva estadual).²³⁷

Para este estudo, vamos concentrar a análise na **representação de inconstitucionalidade**, terminologia prescrita pela EC n. 16/65 quando introduziu no direito brasileiro o controle concentrado.

■ 6.8.2. Objeto

A teor do art. 125, § 2.º, CF/88, o controle abstrato estadual terá por objeto **exclusivamente** leis ou atos normativos **estaduais** ou **municipais**.

Pode-se afirmar, assim, que o TJ local nunca julgará, em controle concentrado e abstrato, lei federal. Ou, em outras palavras, as leis federais só poderão ser objeto de controle abstrato perante o STF. Ou, ainda, o STF não julgará em ADI lei municipal perante a CF (só por meio de ADPF, como visto, ou, excepcionalmente, nas hipóteses de RE de normas de reprodução obrigatória, conforme desenvolvido no *item* 6.8.6).

■ 6.8.3. Competência

Somente o **TJ local** será o órgão competente para, exercendo competência originária, julgar o controle de constitucionalidade abstrato estadual (art. 125, § 2.º).

■ 6.8.4. Legitimados

A regra constitucional não especificou os legitimados. Apenas proibiu a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Assim, cabe às Constituições Estaduais a delimitação da regra, destacando-se os legitimados que apresentam simetria com o plano federal:

ART. 103 — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O	ART. 125, § 2.º — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O	ART. 125, § 2.º — CF/88 — LEGITIMADOS PARA O
--	---	---

CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O STF	CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O TJ LOCAL — “PRINCÍPIO DA SIMETRIA”	CONTROLE CONCENTRADO PERANTE O TJ LOCAL — “PRINCÍPIO DA SIMETRIA” — ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO A LEIS OU ATOS MUNICIPAIS
☐ Presidente da República	☐ Governador de Estado	☐ Prefeito
☐ Mesa do Senado Federal ☐ Mesa da Câmara dos Deputados	☐ Mesa de Assembleia Legislativa	☐ Mesa de Câmara Municipal
☐ Procurador-Geral da República	☐ Procurador-Geral de Justiça	
☐ Conselho Federal da OAB	☐ Conselho Seccional da OAB	
☐ Partido político com representação no Congresso Nacional	☐ Partido político com representação na Assembleia Legislativa	☐ Partido político com representação na Câmara do Município
☐ Confederação sindical ☐ Entidade de classe de âmbito nacional	☐ Federação sindical ☐ Entidade de classe de âmbito estadual	

A pergunta que surge é se poderia a Constituição Estadual ampliar para **Deputados Estaduais, Procurador-Geral do Estado** ou do **Município, Defensor Público-Geral do Estado**, ou ainda por **iniciativa popular** (ação popular — *Popularklage*), legitimados que não guardam simetria com o art. 103 (que não fixou legitimação para Deputado Federal ou Senador, ou para o AGU ou Procurador da Fazenda, ou Defensor Público Geral da União etc.).

Entendemos que **SIM**, até porque tal previsão prestigiaria a intenção do constituinte de 1988, que foi no sentido de ampliar o rol de legitimados para a propositura de ADI.

O STF já se manifestou em relação aos Deputados Estaduais: “Legitimação ativa de Deputado Estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2.º, da Constituição Federal. Precedente: **ADI 558-9-MC**, Pertence, j. 16.08.91, *DJ* 26.03.93” (**RE 261.677**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.04.2006, *DJ* de 15.09.2006).

Outrossim, no precedente citado (ADI 558-9-MC), em julgamento de medida cautelar, o STF entendeu como **constitucional** o art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com o seguinte teor: “Art. 162. A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo **Governador do Estado**, pela **Mesa**, por **Comissão Permanente** ou pelos **membros da Assembleia Legislativa**, pelo **Procurador-Geral da Justiça**, pelo **Procurador-Geral do Estado**, pelo **Procurador-Geral da Defensoria Pública**, **Defensor Público Geral do Estado**, por **Prefeito Municipal**, por **Mesa de Câmara de Vereadores**, pelo **Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil**, por **partido político com representação na Assembleia Legislativa** ou em **Câmara de Vereadores**, e por **federação sindical** ou **entidade de classe de âmbito estadual**”.

Esse entendimento foi confirmado no julgamento de mérito que ocorreu depois de quase 30 anos, em 22.04.2021, declarando-se integralmente **constitucional** o referido art. 162 (vencidos, cinco Ministros declaravam inconstitucionais as expressões “por Comissão Permanente ou pelos membros” contidas no citado dispositivo).

Assim, ampliar, em âmbito estadual, os parâmetros estabelecidos pelo art. 103, CF/88, mostra-se perfeitamente possível. E restringir, aquém da simetria, caracterizaria afronta à Constituição?

Cumprindo a literalidade da regra do art. 125, § 2.º, deverá ser observada a proibição de se estabelecer a legitimação para agir a um único órgão. Contudo, entendemos **conveniente** que se faça, ao menos, mas podendo ser ampliada, uma **simetria estrita** com o art. 103, conforme tabela anterior.

■ 6.8.5. Parâmetro de controle (pauta de referência ou paradigma de confronto)

Conforme bem definiu Leoncy, “a expressão **parâmetro de controle** designa o complexo ou conjunto de normas superiores utilizadas como **referência** pelo Tribunal competente para analisar a legitimidade constitucional de leis e atos normativos submetidos a exame” (grifamos).²³⁸

Nesta parte do estudo, vamos descrever a literalidade prevista no art. 125, § 2.º, CF/88, que define o controle concentrado de constitucionalidade estadual para, em seguida, analisar o atual entendimento do STF sobre o parâmetro ou paradigma de confronto nas hipóteses de norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE.

■ 6.8.5.1. *Regras gerais: literalidade do art. 125, § 2.º, CF/88*

CONTROLE CONCENTRADO POR MEIO DE ADI GENÉRICA			
STF (ADI)		TJ (ADI)	
objeto: lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital de natureza estadual		objeto: lei ou ato normativo estadual ou municipal e, no âmbito do DF, lei ou ato normativo distrital de natureza estadual ou municipal	
Lei Municipal ou Lei Distrital de natureza Municipal		Lei Federal	
Regra: o STF não é intérprete originário de lei municipal ou distrital de natureza municipal por meio de ADI		Regra: o TJ não é intérprete originário de lei federal por meio de ADI estadual ou distrital	
parâmetro: CF		parâmetro: CE ou, perante o DF, Lei Orgânica do DF (CUIDADO: analisar jurisprudência do STF para as hipóteses de normas de reprodução obrigatória — cf. item 6.8.5.2)	
CE ou Lei Orgânica do DF		CF	
Regra: a CE ou a Lei Orgânica do DF não podem ser parâmetro de controle para o ajuizamento de ADI originária, já que o STF é o intérprete final da CF		Regra: a CF não pode ser parâmetro de controle para o ajuizamento de ADI originária, já que o TJ é o intérprete final da CE ou, no âmbito distrital, da Lei Orgânica do DF Exceção: cf. item 6.8.5.2, em que se analisa a hipótese de norma de reprodução obrigatória	

Conforme estudado e tendo em vista a literalidade da regra fixada no art. 125, § 2.º, o controle abstrato estadual por meio de ADI só poderá apreciar lei ou ato normativo **estadual** ou **municipal** que forem confrontados perante a **Constituição Estadual**, ou lei ou ato normativo distrital perante a Lei Orgânica do DF.

O **TJ**, assim, só realiza controle abstrato tendo como parâmetro a **CE**, não podendo ter como parâmetro (controle concentrado e abstrato) a CF e, no caso do DF, tendo por parâmetro a Lei Orgânica do DF (**CUIDADO:** essa afirmação deve ser revista nas hipóteses de normas de reprodução obrigatória estudadas no item seguinte).²³⁹

Por sua vez, o **STF** só realiza controle concentrado e abstrato, por meio da ADI genérica, tendo como parâmetro a **CF**, não podendo ter como paradigma de confronto a CE ou a Lei Orgânica do DF, já que o STF é o intérprete final da CF.

Em relação ao objeto (ADI genérica), o **TJ** só apreciará lei **municipal** ou **estadual** (aplicando-se, naturalmente, a regra para o DF, que acumula tanto a competência municipal como a estadual), enquanto o **STF**, apenas lei **federal** ou **estadual** (ou distrital de caráter estadual).

O TJ, então, **não** poderá realizar controle concentrado de lei federal, por meio de ADI genérica, seja em face da CE, seja em face da CF.

Em igual sentido, o STF **não** poderá analisar, originariamente, por meio da ADI genérica, lei municipal em face da CE (ou lei distrital, perante a Lei Orgânica do DF), mas apenas e excepcionalmente a lei municipal (ou distrital de natureza municipal) perante a CF, mas pela via da **ADPF**.

Vejam que estamos nos referindo ao controle concentrado e em abstrato por meio da ADI genérica. Isso porque, em se tratando de controle difuso, seria perfeitamente possível que o TJ (art. 97 — cláusula de reserva de plenário), pelo Pleno ou Órgão Especial, de maneira incidental, apreciasse a constitucionalidade de lei federal perante a CF. Mas, percebam, somente no controle difuso.

■ 6.8.5.2. *Normas de reprodução obrigatória ou compulsória e normas de mera imitação (da CF na CE)*

De acordo com o art. 25, *caput*, CF/88, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, **observados os princípios da Constituição Federal**.

Esse dispositivo consagra a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, que, por sua vez, assegura aos Estados a sua capacidade de auto-organização.

Naturalmente, sabemos que os Estados não poderão extrapolar os limites fixados pela Constituição Federal, até porque se trata de limites colocados pelo próprio poder constituinte originário.

A grande dificuldade, portanto, é saber a amplitude e autonomia para o exercício dessa capacidade de auto-organização e, assim, identificar as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal (e, por isso, nos

exatos parâmetros fixados, sem possibilidade de abertura), distinguindo-as daquelas que se encontram dentro de um campo de liberdade normativa dos Estados-Membros e que, se “copiarem” as disposições da Constituição Federal, o farão por mera liberalidade, pois podem fixar um sentido distinto.

Nesses termos, podemos destacar as denominadas **normas centrais da Constituição Federal**, definidas por Raul Machado Horta como “um conjunto de normas constitucionais vinculadas à organização da forma federal de Estado, com missão de manter e preservar a homogeneidade dentro da pluralidade das pessoas jurídicas, dos entes dotados de soberania na União e de autonomia nos Estados-Membros e nos Municípios, que compõem a figura complexa do Estado Federal. As normas centrais não são normas de centralização, como as do Estado Unitário. São normas constitucionais federais que servem aos fins da participação, da coordenação e da autonomia das partes constitutivas do Estado Federal. Distribuem-se em círculos normativos, configurados na Constituição Federal, para ulterior **projeção** nas Constituições dos Estados. Nem sempre dispõem de aplicação imediata e automática. Identificam o figurino, o modelo federal, para nele introduzir-se, posteriormente, o constituinte estadual, em sua tarefa de organização do Estado Federado. **Não são normas inócuas**. A **infringência** de normas dessa natureza, na Constituição do Estado ou na legislação estadual, gera a sanção da **inconstitucionalidade**”.²⁴⁰

A partir desse conceito, Horta distingue a **Constituição Total** da **Constituição Federal**: aquela é segmento desta última e **aglutina** as **normas centrais** que devem ser observadas pelas Constituições estaduais.

Essas **normas centrais** podem ser definidas como **normas de reprodução (absorção) obrigatória** ou **compulsória** pelos Estados-Membros e foram assim exemplificadas pelo autor:²⁴¹

- normas dos direitos e garantias fundamentais;
- normas de repartição de competência;
- normas dos direitos políticos;
- normas de preordenação dos poderes do Estado-Membro;

normas dos princípios constitucionais enumerados (Pontes de Miranda ■ os denomina “princípios constitucionais sensíveis”), previstos no art. 34, VII, “a-e”;

■ normas da administração pública;

■ normas de garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público;

■ normas estabelecidas como “princípios gerais do direito tributário” e as de “limitação e instituição do poder tributário”;

■ normas contidas no capítulo sobre os “princípios gerais da atividade econômica”;

■ normas da Ordem Social.

Conforme observa o autor, “as **normas centrais** da Constituição Federal, tenham elas natureza de **princípios constitucionais**, de **princípios estabelecidos** e de **normas de preordenação**, afetam a liberdade criadora do poder constituinte estadual e acentuam o caráter derivado desse poder. Como consequência da subordinação à Constituição Federal, que é a matriz do ordenamento jurídico parcial dos Estados-Membros, a atividade do constituinte estadual se exaure, em grande parte, na elaboração de normas de reprodução, mediante as quais faz a **transferência** da Constituição Federal para a Constituição do Estado das normas centrais, especialmente as situadas no campo das normas de preordenação”.²⁴²

Em importante estudo sobre o tema da *autonomia dos Estados-Membros*,²⁴³ Horta já havia constatado a íntima conexão entre as normas de reprodução e a expansividade do modelo federal. Nesses casos de comando da Constituição Federal, o Estado simplesmente realiza um processo de “**transplantação**”.

Assim, o autor distingue as normas de reprodução da CF na CE daquelas de mera imitação:²⁴⁴

■ **normas de reprodução**: “decorrem do caráter **compulsório** da norma constitucional superior”;

■ **normas de imitação:** “exprimem a cópia de técnicas ou de institutos, por **influência** de **sugestão** exercida pelo modelo superior”, traduzindo uma “**adesão voluntária** do constituinte a uma determinada disposição constitucional”.

Feita essa distinção, resta saber se seria possível a realização de controle de constitucionalidade pelo TJ local nas hipóteses de termos como parâmetro de confronto *normas de reprodução obrigatória* da CF na CE ou se a aferição poderia ser realizada apenas nas hipóteses de *normas de imitação* ou naquelas elaboradas dentro de um *campo de liberdade*, sem qualquer influência da CF.

Isso porque — e é nesse ponto que a dúvida reside — em se tratando de norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE o que se tem no fundo é, em essência, uma final violação da Constituição Federal, pois o Estado, ao elaborar a norma, não tem “espaço” para ampliação ou desvirtuamento.

Para responder a essa questão, temos de destacar três momentos distintos da jurisprudência do STF para, então, expor o atual posicionamento da Corte. Vejamos:

PRECEDENTE	NORMAS DE REPRODUÇÃO DA CF NA CE: CABE CONTROLE CONCENTRADO ORIGINARIAMENTE NO TJ LOCAL TENDO COMO PARÂMETRO OU PARADIGMA DE CONFRONTO REFERIDAS NORMAS COMPULSORIAMENTE COPIADAS DA CF NA CE?	NORMAS DE IMITAÇÃO: CABE CONTROLE CONCENTRADO NO TJ LOCAL TENDO COMO PARÂMETRO OU PARADIGMA DE CONFRONTO A NORMA DA CE QUE COPIOU, POR LIBERALIDADE, A NORMA DA CF?
■ Rcl 370 — j. 09.04.1992, Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti	■ NÃO ■ Independentemente de estarem reproduzidas na CE, não caberá o controle estadual, pois a violação da CE será, no	■ SIM ■ No caso, a norma escrita na CE não precisaria ter seguido os parâmetros da CF, já que não se trata de norma de reprodução

	fundo, violação da própria CF e o TJ não é intérprete final desta, havendo, por isso, usurpação da competência do STF ²⁴⁵	compulsória, mas de mera imitação por “adesão voluntária”, ou seja, poderia ser diferente da CF dentro do campo de autonomia federativa do Estado-Membro
■ Rcl 383 — j. 11.06.1999, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves	■ SIM ■ Para tanto, a norma da CF deverá estar reproduzida expressa e fisicamente na CE. Nesse caso, a ADI será julgada pelo TJ local e, em seguida, havendo interposição de recurso extraordinário em face do acórdão do TJ, pelo STF. Qual o motivo de caber o RE? Como se trata de norma de reprodução obrigatória da CF, deixar a ação terminar no TJ significaria tornar esse tribunal intérprete final da CF, o que caracterizaria afronta à competência do STF	■ SIM ■ No caso, a norma escrita na CE não precisaria ter seguido os parâmetros da CF, já que não se trata de norma de reprodução compulsória, mas de mera imitação por “adesão voluntária”, ou seja, poderia ser diferente da CF dentro do campo de autonomia federativa do Estado-Membro
■ RE 650.898 — RG, j. 1.º.02.2017, Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, tendo sido o entendimento reafirmado na ADI 5.646 (j. 07.02.2019)	■ SIM ■ Neste último precedente, caberá ADI Estadual estando ou não reproduzida a norma da CF na CE. Vejamos a tese firmada: “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”	■ SIM ■ No caso, a norma escrita na CE não precisaria ter seguido os parâmetros da CF, já que não se trata de norma de reprodução compulsória, mas de mera imitação por “adesão voluntária”, ou seja, poderia ser diferente da CF dentro do campo de autonomia federativa do Estado-Membro

Analisando os precedentes mencionados, observa-se que a atual jurisprudência do STF (**RE 650.898**) sinaliza uma mistura das outras duas antagônicas posições que se firmaram.

Dessa forma, será possível a propositura de ADI no TJ local, tendo por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal, confrontados em face de três hipóteses de parâmetros:

- norma de reprodução obrigatória da CF expressamente copiada na CE, cabendo RE para o STF;
- norma de reprodução obrigatória da CF mesmo que não tenha sido expressamente reproduzida na CE. Nesse caso, segundo a atual jurisprudência do STF (**RE 650.898**, j. 1.º.02.2017, *DJE* de 24.08.2017), os TJs poderão exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou mesmo municipais utilizando como parâmetro as referidas normas da CF de reprodução obrigatória pelos Estados, estando ou não textualmente escritas na CE. Contra o acórdão do TJ também caberá a interposição de RE para o STF. Esse entendimento foi reafirmado na **ADI 5.646** (j. 07.02.2019);
- normas de imitação, hipótese em que não caberá RE para o STF, devendo a decisão ficar “confinada” no TJ local.

Conforme já havia sustentado o Min. Barroso em voto proferido na 1.^a Turma do STF — antecedendo o atual posicionamento firmado no Pleno e acima exposto (RE 650.898) —, as **normas constitucionais federais de reprodução obrigatória** pelos Estados-Membros podem ser caracterizadas como “disposições da Carta da República que, por preordenarem diretamente a organização dos Estados-Membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam **automaticamente** nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela **repetição textual** do texto federal, seja pelo **silêncio** dos constituintes locais — afinal, **se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local**” (**Rcl 17.954 AgR**, j. 21.10.2016, *DJE* de 10.11.2016).

Todo esse entendimento foi confirmado pelo STF em momento seguinte: “a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o **parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória** ou exista, **no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal**” (ADI 5.647, Pleno, j. 04.11.2021, DJE de 17.11.2021).

■ 6.8.5.3. *A utilização do recurso extraordinário no controle concentrado e em abstrato estadual*

De modo geral, da decisão do TJ local em controle abstrato (ADI) de lei **estadual** ou **municipal** diante da CE **não** cabe recurso para o STF, já que este é o intérprete máximo de lei (federal, estadual ou distrital de natureza estadual) perante a CF, e não perante a CE.

Excepcionalmente, contudo, conforme visto, pode surgir situação em que o parâmetro da CE nada mais seja que uma **norma de observância obrigatória** ou **compulsória pelos Estados-Membros** (norma de **reprodução obrigatória**), ou, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do **RE 650.898**, a possibilidade de se admitir, no âmbito do TJ local, o exercício do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais (ou estaduais, acrescente-se) utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que de **reprodução obrigatória** pelos Estados (j. 1.º.02.2017, cf. *item* 6.8.5.2).

Nesse caso, se a lei **estadual**, ou mesmo a **municipal**, viola a CE ou as normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória de acordo com o precedente acima citado, no fundo, o que se terá, em essência, será a violação da Constituição Federal. Como o TJ não tem essa atribuição de análise, objetivando evitar a situação de o TJ usurpar a competência do STF (o intérprete máximo da Constituição), abre-se a possibilidade de interpor **recurso extraordinário** contra o acórdão do TJ em controle abstrato estadual

para que o STF diga, então, qual a interpretação da lei **estadual** ou **municipal** perante a **CF**.

Trata-se, pois, de utilização de recurso típico do controle difuso (pela via incidental) no controle concentrado estadual em abstrato.

O recurso extraordinário será um simples mecanismo de levar ao STF a análise da matéria. Assim, a decisão do STF nesse específico recurso extraordinário produzirá os mesmos efeitos da ADI, ou seja, por regra, *erga omnes*, *ex tunc* e vinculante, podendo o STF, naturalmente, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, modular os efeitos da decisão. Portanto, não se aplicará a regra do art. 52, X, não tendo o Senado Federal qualquer participação.

Desse modo, **e tomem cuidado com essa constatação**, surgirá a possibilidade de o STF analisar a constitucionalidade de lei municipal perante a CF e com efeitos *erga omnes*, se na análise inicial do controle abstrato estadual a lei municipal foi confrontada em relação à norma da CE de reprodução obrigatória e compulsória da CF, ou, como no precedente firmado no **RE 650.898**, já estudado, quando se tratar de normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados.

Nesse sentido, confirmam os julgados abaixo:

“Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante **Tribunal de Justiça** na qual se impugna **Lei municipal** sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que **reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados**. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-Membros. Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de **recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o**

alcance desta” (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, j. 11.06.1992, *DJ* de 21.05.1993).

“... o Tribunal, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Min. Moreira Alves, entendeu que a decisão tomada em **recurso extraordinário** interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça em representação de inconstitucionalidade de **lei municipal frente à Constituição Estadual** (CF, art. 125, § 2.º) tem eficácia *erga omnes*, por se tratar de controle concentrado **ainda que a via do recurso extraordinário seja própria do controle difuso**, eficácia essa que se estende a todo o território nacional” (**RE 187.142-RJ**, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.08.1998, *Inf. 118/STF*).

Dentre outros exemplos, destacamos, ainda, os seguintes julgados: **RE 199.281**, **RE 599.633 AgR**, **RE 505.476 AgR** e **ADI 1.268**.

■ 6.8.6. “Simultaneus processus”

As leis **estaduais**, em se tratando de controle concentrado pela via em abstrato, sofrem **dupla fiscalização**, tanto por meio de ADI no TJ, e tendo como parâmetro a CE (ou a própria CF, nas hipóteses de norma de reprodução obrigatória, nos termos da tese firmada no julgamento do **RE 650.898** — cf. *item 6.8.5.2*), como perante o STF, tendo como parâmetro a CF.

Isso significa que a mesma lei estadual poderá ser objeto de controle concentrado no TJ e no STF. Se isso acontecer, estaremos diante do fenômeno da **simultaneidade de ações diretas de inconstitucionalidade**, também denominado *simultaneus processus*.

Nessa situação, em sendo o mesmo o objeto (vale dizer, a mesma lei estadual), assim como o parâmetro estadual de confronto, **norma de reprodução obrigatória** prevista na Constituição Federal, o controle estadual deverá ficar **suspenso** (em razão da causa de **suspensão prejudicial**

do referido processo), aguardando o resultado do controle federal, já que o STF é o intérprete máximo da Constituição.

Nesse sentido, explica o Min. Celso de Mello, “a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, perante o Supremo Tribunal Federal, em que se postule a invalidação de legislação editada por Estado-membro, questionada em face da Constituição da República (CF, art. 102, I, *a*), qualifica-se como causa de suspensão prejudicial do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que, promovido perante o Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 2.º), tenha, por objeto de impugnação, os **mesmos atos normativos emanados do Estado-membro**, contestados, porém, em face da Constituição Estadual (...). Tal entendimento, no entanto, há de ser observado sempre que tal impugnação — deduzida perante a Corte Judiciária local — invocar, como **parâmetro de controle, princípios inscritos na Carta Política local impregnados de predominante coeficiente de federalidade, tal como ocorre com os postulados de reprodução necessária constantes da própria Constituição da República** (RTJ 147/404 — RTJ 152/371-373, *v.g.*)” (ADI 4.138, j. 11.12.2009, *cf. Inf. 573/STF*).

Deixando bem claro: essa situação de simultaneidade das ações deverá ser considerada **apenas nas hipóteses das normas de reprodução obrigatória ou compulsória da Constituição Federal pelos Estados-Membros**.

Verificado o fenômeno do *simultaneus processus*, as seguintes hipóteses poderão surgir a partir da decisão a ser proferida pelo STF:

■ **STF declara inconstitucional a lei estadual perante a CF** — a ADI estadual perderá o seu objeto, não mais produzindo a lei efeitos no referido Estado;²⁴⁶

■ **STF declara constitucional a lei estadual perante a CF** — o TJ poderá prosseguir no julgamento da ADI da lei estadual diante da CE, pois, perante a Constituição Estadual, a referida lei poderá ser

incompatível (mas, naturalmente, **desde que seja por fundamento diverso**).

Vamos imaginar agora que a ação seja proposta perante o TJ estadual e que este julgue a ação, que transita em julgado. Poderá, no futuro, a mesma lei ser examinada em controle abstrato perante o STF e tendo como parâmetro a CF? Duas são as hipóteses:

■ **TJ declara previamente a lei estadual constitucional** — naturalmente, para essa hipótese, não se tratará de simultaneidade. Assim, em sendo no futuro ajuizada a ADI perante o STF, tendo por objeto a mesma lei estadual, o STF poderá reconhecê-la como **inconstitucional** diante da CF. Como o STF é o intérprete máximo da constitucionalidade das leis e o responsável por apontar a *força normativa* da Constituição, a nova decisão do STF prevalecerá inclusive sobre a coisa julgada estadual;

■ **TJ declara previamente a lei estadual inconstitucional** — entendemos que não haveria mais sentido em falar em controle perante o STF, já que a lei estadual foi retirada do ordenamento jurídico.

CUIDADO: nesse último caso, contudo, o STF analisou a situação específica de norma de reprodução obrigatória da CF na CE e, então, reconheceu a possibilidade de julgamento pela Corte, mesmo no caso de anterior nulificação por parte da Corte estadual. Segundo assinalou o Min. Barroso, “não podemos permitir que o Tribunal de Justiça estadual dê a última palavra sobre a compatibilidade de uma lei com a Constituição Federal. Essa é prerrogativa do Supremo”.

Assim, “coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o Tribunal de Justiça local e outra perante o STF, o julgamento da primeira — estadual — somente prejudica o da segunda — do STF — se preenchidas duas condições **cumulativas**: **1)** se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e **2)** se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição

do Estado **sem correspondência na Constituição Federal**. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade” (**ADI 3.659**, j. 13.12.2018).

■ 6.9. QUADRO COMPARATIVO DO SISTEMA JURISDICIONAL MISTO DE CONTROLE POSTERIOR OU REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

	OBJETO	COMPETÊNCIA	LEGITIMAÇÃO ATIVA
Controle difuso — atos normativos	■ Qualquer lei ou ato de indiscutível caráter normativo, contrário à Constituição (via de exceção ou defesa — declaração de inconstitucionalidade <i>incidenter tantum</i>)	■ Qualquer juízo ou Tribunal	■ Qualquer pessoa física ou jurídica, no caso concreto
Controle difuso — omissões — mandado de injunção individual ou coletivo (<i>vide</i> capítulo sobre remédios constitucionais)	■ Falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição de eficácia limitada , prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania	■ Arts. 102, I, “q”, 102, II, “a”, 105, I, “h”, 121, § 4.º, V, e 125, § 1.º (qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de organização judiciária)	■ Qualquer pessoa, física ou jurídica, no caso concreto
ADI genérica (controle concentrado no STF)	■ Lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital (natureza estadual), contestados em face da CF/88 (via de ação, controle abstrato, em tese)	■ STF — competência originária	■ Arts. 103, CF/88, e 2.º da Lei n. 9.868/99
ADC	■ Lei ou ato normativo federal	■ STF — competência originária	■ Art. 103, CF/88 (modificado pela EC n. 45/2004)
Arguição de descum-			

primário de preceito fundamental (ADPF)	■ Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público e quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, distrital, incluídos os anteriores à Constituição	■ STF — competência originária	■ Arts. 103, CF/88, e 2.º da Lei n. 9.882/99 (os mesmos da ADI)
ADI por omissão (ADO)	■ Falta de medida regulamentadora de artigo da Constituição de <i>eficácia limitada</i>	■ STF — competência originária	■ Arts. 103, CF/88, e 12-A da Lei n. 9.868/99
Representação Interventiva (ADI Interventiva)	■ Lei ou ato normativo, ato administrativo, ato concreto, ou omissões, estaduais ou distritais, que violam princípios sensíveis da CF/88 ■ A hipótese de recusa, por parte de Estado-Membro ou do DF, à execução de lei federal vai ser estudada no <i>item 7.12.1</i>	■ STF — competência originária	■ Procurador-Geral da República — art. 36, III, CF/88

	CAUTELAR	QUORUM	EFEITOS DA DECISÃO
Controle difuso — atos normativos	■ Possível, seguindo-se as regras processuais	■ Juízo monocrático: o próprio juiz, de modo incidental ■ Juízo colegiado (Tribunal): art. 97, CF, <i>maioria absoluta</i> (dos	■ Para as partes: <i>inter partes</i> e <i>ex tunc</i>, já tendo o STF admitido efeito <i>ex nunc e pro futuro</i> — cf. RE 197.917, <i>Inf. 341/STF</i>

		membros do Tribunal ou Órgão Especial, de acordo com o Regimento Interno)	■ Para terceiros (art. 52, X): suspensão da execução da lei pelo Senado Federal através de <i>resolução: erga omnes</i> e <i>ex nunc</i> ■ Mutaç�o constitucional do art. 52, X: cf. discuss�o no item 6.6.5 da parte te�rica
Controle difuso — omiss�es — mandado de injun��o individual ou coletivo (<i>vide</i> cap�tulo sobre rem�dios constitucionais)	■ Imposs�vel. Contudo, tendo em vista as novas tend�ncias, pode-se pensar na mo-difica��o desse entendimento	■ Ju�zo monocr�tico: o pr�prio juiz, de modo incidental, poder� verificar a inconstitucionalidade por omiss�o ■ Ju�zo colegiado (Tribunal): art. 97, CF, <i>maioria absoluta</i> (dos membros do Tribunal ou �rg�o Especial, de acordo com o Regimen-to Interno), modo incidental, para apreciar a inconstitucionalidade por omiss�o	■ <i>Erga omnes</i>: at� que sobrevenha a medida integrativa, na linha do entendimento fixado pelo STF no MI 712, consagrando a <i>teoria concretista geral</i> (cf. item 14.11.5.7) ■ <i>Inter partes</i>: at� que sobrevenha a medida integrativa, na linha do entendimento fixado pelo STF em v�rios MIs, consagrando, nesses casos, a <i>teoria concretista individual</i> (cf. item 14.11.5.7)
ADI gen�rica (controle concentrado no STF)	■ Poss�vel (art. 102, I, “p”, CF)	■ Cautelar: a) regra geral — <i>maioria absoluta</i> (6); b) no per�odo de recesso — <i>Presidente do Tribunal</i> ■ M�rito: a) regra geral — <i>maioria absoluta</i> (6), presentes 8 Ministros; b) art. 27 da Lei n. 9.868/99 — possibilidade de modula��o dos efeitos da decis�o, desde que haja manifesta��o de	■ Cautelar: <i>erga omnes</i>, <i>ex nunc</i> e <i>vinculante</i> (o art. 11, § 1.�, da Lei n. 9.868/99 permite efic�cia retroativa, <i>ex tunc</i>) ■ M�rito: <i>erga omnes</i>, <i>ex tunc</i> e <i>vinculante</i> (regra geral). Pode haver <i>modula��o</i> dos efeitos da decis�o, ou seja, efeito <i>ex nunc</i>, para o <i>futuro</i>, ou a partir de certo momento (art. 27

		pelo menos 2/3 dos Ministros (8), presentes 8 Ministros	da Lei n. 9.868/99)
ADC	■ Possível (jurisprudência do STF — ADC 4)	■ Cautelar: regra geral — maioria absoluta ■ Mérito: regra geral — maioria absoluta (6), presentes 8 Ministros	■ Cautelar: <i>erga omnes</i> e <i>vinculante</i> (suspensão dos julgamentos) ■ Mérito: <i>erga omnes, ex tunc</i> e <i>vinculante</i>
Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)	■ Possível (art. 5.º da Lei n. 9.882/99)	■ Cautelar: a) regra geral — maioria absoluta (6); b) no período de recesso, extrema urgência, perigo de le-são grave — relator ■ Mérito: a) regra geral — maioria absoluta (6), presentes 8 Ministros; b) art. 11 da Lei n. 9.882/99 — possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, desde que haja manifestação de pelo menos 2/3 dos Ministros (8), presentes 8 Ministros	■ Cautelar: <i>erga omnes, ex tunc</i> e <i>vinculante</i> . A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada ■ Mérito: <i>erga omnes, ex tunc</i> e <i>vinculante</i> (regra geral). Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pode haver modulação dos efeitos da decisão, ou seja, efeito <i>ex nunc</i> , para o futuro, ou a partir de certo momento (art. 11 da Lei n. 9.882/99)
ADI por omissão (ADO)	■ Possível (art. 12-F da Lei n. 9.868/99)	■ Cautelar: maioria absoluta (6), presentes 8 Ministros ■ Mérito: maioria	■ Cautelar: poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de

		absoluta (6), presentes 8 Ministros	omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal ■ Mérito: a) poder com-petente — será dada ciência para a adoção das providências necessárias, constituindo-o em mora; b) órgão administrativo: as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido, sob pena de responsabilidade
Representação Interventiva (ADI Interventiva)	■ Possível (art. 5.º da Lei n. 12.562/2011)	■ Cautelar: decisão da maioria absoluta (6) ■ Mérito: decisão da maioria absoluta (6), presentes pelo menos 8 Ministros	■ Cautelar: a liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva ■ Mérito: decisão da maioria absoluta (6) ■ Julgada a ação, far-

			se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela procedência do pedido formulado, o Presidente do STF, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 dias, dar cumprimento aos §§ 1.º e 3.º do art. 36, CF
--	--	--	--

■ 6.10. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

6

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE



somos.in/CEDC28



DIVISÃO ESPACIAL DO PODER — ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

■ 7.1. NOÇÕES PRELIMINARES

■ 7.1.1. Elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado

A Constituição deve trazer em si os *elementos integrantes* (*componentes* ou *constitutivos*) do Estado, quais sejam:

- soberania;
- finalidade;
- povo;
- território.

Nesses termos, Dalmo de Abreu Dallari define **Estado** como “*a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território*”. Nesse conceito se acham presentes todos **os elementos que compõem o Estado**, e só esses elementos. A noção de **poder** está implícita na de **soberania**, que, no entanto, é referida como característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao **bem comum**, com a vinculação deste a um certo **povo** e, finalmente, a territorialidade, limitadora da ação jurídica e política do Estado, está presente na menção a determinado **território**”.¹

■ 7.1.2. Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado

A organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sob três aspectos: **forma de governo**, **sistema de governo** e **forma de Estado**.

- **forma de governo:** República *ou* Monarquia;
- **sistema de governo:** presidencialismo *ou* parlamentarismo;
- **forma de Estado:** Estado unitário *ou* Federação. Entre um e outro, parte da doutrina (v.g., Juan Fernando Badía) identifica outras formas de Estado, quais sejam, o Estado regional (Itália) e o autonômico (Espanha).

O Brasil adotou a **forma republicana** de governo, o **sistema presidencialista** de governo² e a **forma federativa** de Estado.³

■ 7.2. FORMAS DE ESTADO

Conforme anota José Afonso da Silva, “o modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de *forma de Estado*. Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se *Estado unitário*. Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide, no espaço territorial (divisão espacial de poderes), gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, distribuídas regionalmente, encontramos-nos diante de uma *forma de Estado composto*, denominado *Estado federal* ou *Federação de Estados*”.

E continua: “a repartição regional de poderes autônomos constitui o cerne do conceito de Estado Federal. Nisso é que ele se distingue da *forma de Estado unitário* (França, Chile, Uruguai, Paraguai e outros), que não possui senão um centro de poder que se estende por todo o território e sobre toda a população e controla todas as coletividades regionais e locais. É certo que o *Estado unitário* pode ser descentralizado e, geralmente, o é, mas essa descentralização, por ampla que seja, não é de tipo federativo, como nas federações, mas de tipo autárquico, gerando uma forma de *autarquia territorial* no máximo, e não uma *autonomia político-constitucional*, e nele as coletividades internas ficam na dependência do poder unitário, nacional e central”.⁴

Em relação ao Estado unitário, poderíamos, de acordo com o **grau de descentralização**, identificar: **a) Estado unitário puro**, marcado por uma absoluta centralização do exercício do Poder; **b) Estado unitário descentralizado administrativamente**, apesar de ainda concentrar a tomada de decisões políticas nas mãos do Governo Nacional, avança descentralizando a execução das decisões políticas já tomadas. Criam-se pessoas para, em nome do Governo Nacional, como se fossem uma extensão deste (*longa manus*), executar, administrar, as decisões políticas tomadas; **c) Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente**: além da

autonomia administrativa, haveria certa autonomia política para a implementação do comando central.

Certos autores, ao analisar alguns casos particulares, entendem imprecisa essa alocação dentro dessa categoria de Estado unitário de maior grau de descentralização, preferindo, então, criar **outras**, localizadas **entre o Estado federal e o unitário**, quais sejam, os denominados **Estado regional** (Itália) e **Estado autonômico** (Espanha), que se identificam não apenas pela descentralização administrativa como também — e aí a marca — pela **legislativa**. Haveria um único poder constituinte, mas pluralidade de fontes legislativas/normativas.⁵

Para este trabalho, dado o seu objetivo, focaremos na **forma federativa de Estado**.

■ 7.3. FEDERAÇÃO

■ 7.3.1. Histórico

A **forma federativa de Estado** tem sua origem nos EUA, e data de 1787.

Anteriormente, em 1776, tivemos a **proclamação da independência** das 13 colônias britânicas da América, passando cada qual a se intitular um novo Estado, **soberano**, com plena liberdade e independência.

Os Estados resolveram formar, através de um tratado internacional, intitulado **Artigos de Confederação**, a *Confederação dos Estados Americanos*, um pacto de colaboração a fim de se protegerem das constantes ameaças da antiga metrópole inglesa. No aludido **pacto confederativo**, permitia-se a denúncia do tratado a qualquer tempo, consagrando-se, assim, o **direito de retirada**, de **separação**, de **secessão** do pacto.

A permissão do **direito de secessão** aumentava o problema das constantes ameaças e a fragilidade perante os iminentes ataques britânicos. Nesse sentido, buscando uma solução para aquela situação em que se encontravam, os **Estados Confederados** (ainda era uma Confederação de Estados soberanos) resolveram reunir-se na cidade da Filadélfia (todos, ausentando-se apenas o Estado de Rhode Island), onde, então, estruturaram as bases para a **Federação** norte-americana.⁶ Nessa nova forma de Estado proposta não se permitiria mais o direito de secessão. Cada Estado cedia parcela de sua soberania para um órgão central, responsável pela centralização e unificação, formando os **Estados Unidos da América**, passando, nesse momento, a ser **autônomos entre si**, dentro do pacto federativo.

Daí dizerem os autores que a formação da Federação dos EUA decorreu de um **movimento centrípeto**, de fora para dentro, ou seja, Estados soberanos cedendo parcela de sua soberania, em verdadeiro movimento de **aglutinação**. Veremos que no Brasil a formação, por outro lado, resultou de

um movimento **centrífugo**, de dentro para fora, ou seja, um Estado unitário centralizado descentralizando-se. Em decorrência dessa razão histórica, conseguimos entender por que os Estados norte-americanos têm autonomia muito maior que os Estados-Membros brasileiros.

Apenas alertamos que no **modelo de repartição de competência** (item 7.9), bem como na **tipologia do federalismo** (item 7.3.2), a doutrina vislumbra tanto um federalismo **centrípeto** como um federalismo **centrífugo** ou por **segregação**, em **sentido diverso** do acima apresentado.

Nessa outra concepção (que **não** busca analisar o **movimento** de formação da Federação, mas, acima de tudo, a amplitude da concentração de atribuições, a caracterizar o “tipo” de organização federal), quando se observar uma maior **concentração** de competências no ente **central**, estaremos diante do modelo **centrípeto** (ou *centralizador*); por outro lado, quando se observar uma maior **distribuição** de atribuições para os Estados-Membros, teremos um modelo **centrífugo** (ou *descentralizador*).

Nas palavras de Raul Machado Horta, “se a concepção do constituinte inclinar-se pelo fortalecimento do poder federal, teremos o *federalismo centrípeto*, que *Georges Scelle* chamou de federalismo por *agregação* ou *associação*; se, ao contrário, a concepção fixar-se na preservação do poder estadual emergirá o *federalismo centrífugo* ou por *segregação*, consoante a terminologia do internacionalista francês. Pode ainda o constituinte federal modelar sua concepção federal pelo *equilíbrio* entre as forças contraditórias da unidade e da diversidade, do localismo e do centralismo, concebendo o federalismo de *cooperação*, o federalismo de *equilíbrio* entre a União soberana e os Estados-membros autônomos”.⁷

Feita esta advertência, propomos a *esquematização* das *tipologias do federalismo*.

■ 7.3.2. Tipologias do Federalismo

■ 7.3.2.1. *Federalismo por agregação ou por desagregação (segregação)*

Essa classificação leva em conta a **formação histórica**, a **origem** do federalismo em determinado Estado, podendo ser por **agregação** ou por **desagregação**.

No **federalismo por agregação**, os Estados independentes ou soberanos resolvem abrir mão de parcela de sua soberania para agregar-se entre si e formar um novo Estado, agora, Federativo, passando a ser, entre si, autônomos. O modelo busca uma maior solidez, tendo em vista a *indissolubilidade do vínculo federativo*. Como exemplo, podemos citar a formação dos **Estados Unidos**, da **Alemanha** e da **Suíça**.

Por sua vez, no **federalismo por desagregação** (*segregação*), a Federação surge a partir de determinado Estado unitário que resolve descentralizar-se, “em obediência a imperativos políticos (salvaguarda das liberdades) e de eficiência”.⁸ O **Brasil** é exemplo de federalismo por desagregação, que surgiu a partir da proclamação da República, materializando-se, o novo modelo, na Constituição de 1891.

■ 7.3.2.2. **Federalismo dual ou cooperativo**

Ao analisar o **modo** de **separação de atribuições** (competências) entre os entes federativos, a doutrina identificou tanto o federalismo **dual** como o federalismo **cooperativo**.

No **federalismo dual**, a separação de atribuições entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em cooperação ou interpenetração entre eles. O exemplo seriam os **Estados Unidos** em sua origem.

Flexibilizando a rigidez do modelo dual (clássico), sobrevém o modelo **cooperativo**, especialmente durante o século XX, com o surgimento do *Estado do Bem-Estar Social*, ou *Estado-providência*.

Nesse modelo, as atribuições serão exercidas de modo **comum** ou **concorrente**, estabelecendo-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos, que deverão atuar em **conjunto**. Assim, modernamente, percebe-

se, cada vez mais, uma **gradativa substituição** do federalismo dual pelo cooperativo.

A doutrina adverte o risco de, a pretexto do modelo cooperativo, instituir-se um federalismo de “fachada”, com fortalecimento do órgão central em detrimento dos demais entes federativos e, assim, havendo sobreposição da União, a caracterização de um federalismo de subordinação.

Zimmermann, contudo, salienta que, se por um lado existe esse risco de negação do próprio federalismo, não se pode deixar de admitir o **federalismo cooperativo** verdadeiramente **democrático**, formado “... no consentimento geral da nação, e não através da imposição do poder central”, eliminando-se, dessa forma, o autoritarismo.⁹

O modelo **brasileiro** pode ser classificado como um **federalismo cooperativo**.

■ **7.3.2.3. Federalismo simétrico ou assimétrico** A simetria ou assimetria do federalismo decorre dos mais variados **fatores**, seja em relação à cultura, seja no concernente ao desenvolvimento, à língua etc.

No federalismo **simétrico** verifica-se homogeneidade de cultura e desenvolvimento, assim como de língua, como é o caso dos Estados Unidos.

Por outro lado, o federalismo **assimétrico** pode decorrer da diversidade de língua e cultura, como se verifica, por exemplo, nos quatro diferentes grupos étnicos da Suíça (*cantões*), ou, também, no caso do Canadá, país bilíngue e multicultural.

No **Brasil**, há certo “**erro de simetria**”, pelo fato de o constituinte tratar de modo idêntico os Estados, como se verifica na representação no Parlamento (cada Estado, não importa o seu tamanho, o seu desenvolvimento, elege o número fixo de 3 Senadores, cada qual com dois suplentes — art. 46, §§ 1.º e 3.º).

O constituinte deveria ter considerado a dimensão territorial, o desenvolvimento econômico, a cultura etc., tratando, dessa forma, de modo assimétrico os entes federativos. Essa distinção, naturalmente, não poderia

significar a preferência de um ente federativo em relação a outro, sob pena de se desvirtuar o texto constitucional.

■ **7.3.2.4. *Federalismo orgânico*** No **federalismo orgânico**, o Estado deve ser considerado um “organismo”. Busca-se, dessa forma, sustentar a manutenção do “todo” em detrimento da “parte”.

Os Estados-Membros, por consequência, aparecem como um simples reflexo do “*todo-poderoso* poder central”.

Conforme aponta Zimmermann, “este modelo, o orgânico-federativo, parece haver se estabelecido sob as novas formulações teóricas surgidas ao longo do século XX. Movidas por concepções que visavam muito mais o estabelecimento da homogeneidade e a formulação de concepções centralistas, elas acabaram por atender, direta ou indiretamente, aos objetivos ditatoriais de governos federais socialistas e da América Latina”.¹⁰

■ **7.3.2.5. *Federalismo de integração*** Em nome da **integração nacional**, passa a ser verificada a preponderância do Governo central sobre os demais entes, atenuando, assim, as características do modelo federativo.

Nesse sentido, André Ramos Tavares constata que, “no extremo, o federalismo de integração será um federalismo meramente formal, cuja forte assimetria entre poderes distribuídos entre as entidades componentes da federação o aproxima de um Estado unitário descentralizado, com forte e ampla dependência, por parte das unidades federativas, em relação ao Governo da União federal”.¹¹

■ **7.3.2.6. *Federalismo equilíbrio*** O **federalismo equilíbrio** traduz a ideia de que os entes federativos devem manter-se em harmonia, reforçando-se as instituições.

Segundo André Ramos Tavares, “isso pode ser alcançado pelo estabelecimento de regiões de desenvolvimento (entre os Estados) e de regiões metropolitanas (entre os municípios), concessão de benefícios, além

da redistribuição de rendas”,¹² destacando-se, respectivamente, os arts. 43, 25, § 3.º, 151, I, e 157 a 159.

■ **7.3.2.7. Federalismo de segundo grau** Manoel Gonçalves Ferreira Filho fala em uma *tríplice estrutura do Estado brasileiro*, diferente, por exemplo, do modelo norte-americano que apresenta a União e os Estados-Membros.

De fato, no Brasil, é reconhecida a existência de **3 ordens**, quais sejam, a da União (*ordem central*), a dos Estados (*ordens regionais*) e a dos Municípios (*ordens locais*).

Não se pode esquecer, naturalmente, a posição peculiar do DF em nossa Federação que, a partir do texto de 1988, não tem natureza nem de Estado nem de Município, podendo ser caracterizado como “... uma *unidade federada* com autonomia parcialmente tutelada”.¹³

Em seguida, observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho que o poder de auto-organização dos Municípios deverá observar **dois graus**, quais sejam, a Constituição Federal e a Constituição do respectivo Estado. Assim, conclui, “a Constituição de 1988 consagra um **federalismo de segundo grau**”.¹⁴

■ 7.3.3. Características da Federação

Apesar de cada Estado federativo apresentar características peculiares, inerentes às suas realidades locais, encontramos alguns pontos em comum que podem assim ser sistematizados:

■ **descentralização política:** a própria Constituição prevê núcleos de poder político, concedendo autonomia para os referidos entes;

■ **repartição de competência:** garante a autonomia entre os entes federativos e, assim, o equilíbrio da federação;

■ **Constituição rígida como base jurídica:** fundamental a existência de uma Constituição rígida no sentido de garantir a distribuição de competências entre os entes autônomos, surgindo, então, uma verdadeira

estabilidade institucional;

■ **inexistência do direito de secessão:** não se permite, uma vez criado o pacto federativo, o direito de separação, de retirada. Tanto é que, só a título de exemplo, no Brasil, a CF/88 estabeleceu em seu art. 34, I, que a tentativa de retirada ensejará a decretação da intervenção federal no Estado “rebelante”. Eis o **princípio da indissolubilidade do vínculo federativo**, lembrando, inclusive, que a forma federativa de Estado é um dos limites materiais ao poder de emenda, na medida em que, de acordo com o art. 60, § 4.º, I, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a **forma federativa de Estado**;

■ **soberania do Estado federal:** a partir do momento que os Estados ingressam na federação perdem soberania, passando a ser autônomos. Os entes federativos são, portanto, autônomos entre si, de acordo com as regras constitucionalmente previstas, nos limites de sua competência; a **soberania**, por seu turno, é característica do todo, do “país”, do Estado federal, no caso do Brasil, tanto é que aparece como **fundamento da República Federativa do Brasil** (art. 1.º, I, CF/88). Conforme alertamos no *item 4.7*, dentro do conceito de **supranacionalidade**, hoje se fala em **flexibilização** da ideia clássica de soberania;

■ **intervenção:** diante de situações de crise, o processo interventivo surge como instrumento para assegurar o equilíbrio federativo e, assim, a manutenção da Federação;

■ **auto-organização dos Estados-Membros:** através da elaboração das Constituições Estaduais (*vide* art. 25, CF/88);

■ **órgão representativo dos Estados-Membros:** no Brasil, de acordo com o art. 46, a representação dá-se através do Senado Federal;

■ **guardião da Constituição:** no Brasil, o STF;

■ **repartição de receitas:** assegura o equilíbrio entre os entes federativos (arts. 157 a 159).

■ 7.3.4. Federação brasileira

■ 7.3.4.1. *Breve histórico*

Provisoriamente, a Federação no Brasil surge com o Decreto n. 1, de 15.11.1889, decreto esse instituidor, também, da forma republicana de governo. A consolidação veio com a primeira Constituição Republicana, de 1891, que em seu art. 1.º estabeleceu: “A nação Brasileira adota como forma de governo, sob o regimen representativo, a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitue-se, por união perpetua e indissolúvel das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil”.¹⁵

As Constituições posteriores mantiveram a forma federativa de Estado, porém, “não se pode deixar de registrar o entendimento de alguns, segundo o qual, nas Constituições de 1937 e de 1967, bem como durante a vigência da Emenda n. 1/69, tivemos no Brasil somente uma Federação de fachada”.¹⁶

■ 7.3.4.2. *Federação na CF/88 e princípios fundamentais*¹⁷

■ 7.3.4.2.1. *Composição e sistematização conceitual*

Preceitua o art. 1.º, *caput*, CF/88, que a **República Federativa do Brasil** é formada pela união **indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, sendo que o *caput* de seu art. 18 complementa, estabelecendo que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União**, os **Estados**, o **Distrito Federal** e os **Municípios**, todos **autônomos**, nos termos desta Constituição”.

José Afonso da Silva esclarece o assunto: “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, como se vê do art. 18, a *União*, os *Estados*, o *Distrito Federal* e os *Municípios*. A Constituição aí quis destacar as entidades que integram a estrutura federativa brasileira: os *componentes do nosso Estado Federal*. Merece reparo dizer que é a organização político-administrativa que compreende tais entidades, como se houvesse alguma diferença entre o que aqui se estabelece e o que se declarou no art. 1.º. Dizer que a República Federativa do Brasil é formada

pela *união indissolúvel* dos Estados e Municípios e do Distrito Federal não é diverso de dizer que ela compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, porque a *união indissolúvel* (embora com inicial minúscula) do art. 1.º é a mesma União (com inicial maiúscula) do art. 18. Repetição inútil, mas que não houve jeito de evitar, tal o apego à tradição formal de fazer constar do art. 1.º essa cláusula que vem de constituições anteriores, sem levar em conta que a metodologia da Constituição de 1988 não comporta tal apego destituído de sentido. Enfim, temos aí destacados os componentes da nossa República Federativa: (a) União; (b) Estados; (c) Distrito Federal; e (d) Municípios...”.¹⁸

Então podemos esquematizar:

- **forma de governo:** republicana;
- **forma de Estado:** Federação;
- **característica do Estado brasileiro:** trata-se de Estado de Direito, democratizado, qual seja, Estado Democrático de Direito;
- **entes componentes da Federação:** União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- **sistema de governo:** presidencialista.

■ 7.3.4.2.2. ***Fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.º, CF/88)***

O art. 1.º enumera, como **fundamentos** da República Federativa do Brasil:

- soberania — fundamento da República Federativa do Brasil *e não da União, enquanto ente federativo. A soberania é do conjunto formado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;*
- cidadania;
- dignidade da pessoa humana;
- valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa;
- pluralismo político.

■ 7.3.4.2.3. ***Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3.º, CF/88)***

Os objetivos fundamentais (e em concursos já foi necessário conhecê-los, em contraposição aos fundamentos) vêm relacionados no art. 3.º, CF/88.

Como advertiu Celso Bastos, “a ideia de objetivos não pode ser confundida com a de fundamentos, muito embora, algumas vezes, isto possa ocorrer. Os fundamentos são inerentes ao Estado, fazem parte de sua estrutura. Quanto aos objetivos, estes consistem em algo exterior que deve ser perseguido”.¹⁹ A CF/88 assim os define:

- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- garantir o desenvolvimento nacional;
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

■ 7.3.4.2.4. ***Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais (art. 4.º, CF/88)***

O art. 4.º, CF/88, dispõe que a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- independência nacional;
- prevalência dos direitos humanos;
- autodeterminação dos povos;
- não intervenção;
- igualdade entre os Estados;
- defesa da paz;
- solução pacífica dos conflitos;
- repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

■ concessão de asilo político.

■ 7.3.4.2.5. *Idioma oficial da República Federativa do Brasil (art. 13, “caput”, CF/88)*

O **idioma oficial** da República Federativa do Brasil é a **língua portuguesa**. Daí ser o **ensino fundamental regular** ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, **também**, a possibilidade de utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (art. 13, *caput*, c/c o art. 210, § 2.º).

Um tema que vem sendo discutido e causando controvérsia diz respeito à denominada **“linguagem neutra”** ou **“linguagem não binária”**, que estabelece a substituição dos gêneros nas palavras por opções ditas “neutras”, trocando a utilização dos artigos feminino ou masculino por “e”, “x”, “u”, “@” (para se ter um exemplo, as palavras “todos” ou “todas” na linguagem neutra ficariam “todes”, “todxs”, “todus”, “tod@s”).

Alguns Estados-Membros aprovaram leis **proibindo** a utilização da linguagem neutra nas escolas, vedando o seu uso na grade curricular, no material didático, bem como em editais de concursos públicos.

Para se ter um exemplo, de acordo com a Lei n. 5.123/2021 do Estado de Rondônia, “fica garantido aos estudantes do Estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VolP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa — CPLP”.

O STF estabeleceu que a competência para tratar sobre a matéria é da **União (art. 22, XXIV — diretrizes e bases da educação nacional)**, e, por isso, as leis estaduais (distritais ou municipais, acrescentamos) que tratam do assunto são **inconstitucionais** em razão de **vício formal** (competência federativa para legislar).

Conforme informado, “embora os Estados possuam competência para legislar concorrentemente sobre educação, **devem observar as normas gerais editadas pela União** (CF/88, **art. 24, IX**). Nesse contexto, a União editou, no exercício de sua **competência nacional**, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), cujo sentido engloba as regras que tratam de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Portanto, no âmbito da competência concorrente, a União fixa as regras minimamente homogêneas em todo território nacional” (*Inf. 1.082/STF* e **ADI 7.019**, Pleno, 11 x 0, j. 13.02.2023, *DJE* de 10.04.2023).

Do ponto de vista de regulamentação, portanto, a matéria só poderá ser disciplinada pelo Congresso Nacional (art. 22, XXIV), por **lei nacional** (e não pelo Ministério da Educação), quando, então, a sociedade poderá dialogar melhor sobre o tema.

Para se ter um exemplo de projeto de lei sobre a matéria no Congresso Nacional, destacamos o **PL 6.256/2019-CD**, aprovado na Câmara dos Deputados em 05.12.2023 e, no fechamento desta edição, tramitando no Senado Federal, que, ao instituir a “Política Nacional de **Linguagem Simples** nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta”, explicitou que a Administração Pública deverá obedecer ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) — art. 5.º, *caput* (tema pendente).

Finalmente, de acordo com o art. 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar **formação básica comum** e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

■ 7.3.4.2.6. ***Símbolos da República Federativa do Brasil (art. 13, §§ 1.º e 2.º, CF/88)***

Os **símbolos** da República Federativa do Brasil são: a **bandeira**,²⁰ o **hino**,²¹ as **armas**²² e o **selo nacional**,²³ sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter os seus próprios símbolos (art. 13, §§ 1.º e 2.º).

Dentro da ideia de desenvolvimento de uma **consciência cidadã**, a Lei n. 12.472/2011 introduziu o § 6.º ao art. 32 da Lei n. 9.394/96 (*Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB*), passando a estabelecer que o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.

A preocupação em relação aos símbolos estimulou o legislador, no passado, a **criminalizar** certas condutas, destacando-se o art. 35 da Lei n. 5.700/71 (que ainda qualifica como **contravenção penal** violações às disposições da referida lei, sem, contudo, haver a definição específica do tipo penal, caracterizando norma penal em branco), bem como o art. 44 do Decreto-Lei n. 898, de 29 de setembro de 1969 (que **considerava crime contra a segurança nacional, a ordem política e social**, com detenção de 2 a 4 anos, “destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais, quando expostos em lugar público”). Cabe observar que a Lei n. 6.620/78 manteve a referida criminalização (mas com pena de **reclusão** de 1 a 4 anos), e, posteriormente, a Lei n. 7.170/83 **revogou** o referido dispositivo, **não mais estabelecendo a conduta como crime**.

Devemos lembrar, ainda, a previsão no Código Penal Militar do crime (militar) de **desrespeito a símbolo nacional**: “praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em **ultraje a símbolo nacional**: pena — detenção, de um a dois anos”.

Para ilustrar, apesar de termos encontrado apenas um acórdão no STJ e um outro no STM em relação à referida conduta, transcrevemos a ementa de interessante julgado em que a Justiça Castrense analisou a conduta de militares que postaram na *internet* dança do Hino Nacional em ritmo de *funk*:

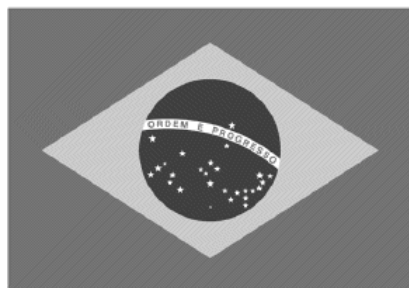
■ “Apelação. **Desrespeito a símbolo nacional** (CPM, art. 161). Recrutas que, no interior da Organização Militar onde serviam, devidamente fardados, entram em formação e passam a dançar uma versão modificada do Hino Nacional em ritmo de ‘funk’. Conduta desrespeitosa filmada, com a anuência de todos os participantes, e divulgada na rede mundial de computadores” (STM, Apelação/RS n. 60-86.2011.7.03.0203, j.

07.05.2013). “A conduta desrespeitosa dos acusados foi imprópria e inadequada, constituindo verdadeiro **ultraje ao Hino Nacional Brasileiro**, amoldando-se, portanto, ao crime de desrespeito a símbolo nacional (art. 161 do CPM). Presentes o dolo de ultrajar e a potencial consciência da ilicitude da conduta, uma vez que os embargantes declararam que receberam instrução sobre como deveriam se comportar quando da execução do Hino Nacional” (STM, *embargos infringentes*, j. 26.11.2013).

Apesar de a Constituição não classificar como símbolo da República Federativa do Brasil as **cores nacionais**, a título de curiosidade, convém lembrar que a Lei n. 5.700/71, em seu art. 28, definiu, como nacionais, o **verde** e o **amarelo**, permitindo que sejam usados sem quaisquer restrições, inclusive associados a azul e branco (art. 29).

Finalmente, apenas para ilustrar, passamos a representar graficamente os símbolos da República Federativa do Brasil:²⁴

■ **Bandeira Nacional**



■ **Hino Nacional**



■ Armas Nacionais (Brasão de Armas)



■ Selo Nacional



■ 7.3.4.2.7. ***Vedações constitucionais impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios***

Existe expressa vedação constitucional, prevista no art. 19, CF/88, impossibilitando aos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios):

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O Brasil, como veremos melhor ao analisar o art. 5.º, VI, no *item 14.10.6*, é um país **leigo, laico, não confessional**, ou seja, desde o advento da República não adota nenhuma religião oficial (cf., também, *item 3.10.1.3*), havendo separação entre Estado e igreja.

Contudo, conforme adverte José Afonso da Silva, esta separação entre Estado e Igreja (Estado laico, 19, I), deve ser vista de **modo atenuado**, já que o constituinte originário prescreveu **pontos de contato**, “tais como a previsão de *ensino religioso* (art. 210, § 1.º), o *casamento religioso com efeitos civis* (art. 226, § 2.º) e a *assistência religiosa* nas entidades oficiais (art. 5.º, VII, acrescente-se). Enfim, fazem-se **algumas concessões** à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que ao largo da história do país o substrato dessa confessionalidade é a cultura haurida na prática do Catolicismo”.²⁵

Em relação aos dispositivos constitucionais, podemos destacar, ainda, além dos citados pelo ilustre professor, os seguintes e que, também, estabelecem os referidos “pontos de contato”, atenuando o sentido de Estado laico: **a)** previsão da expressão “Deus” no preâmbulo; **b)** inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias (art. 5.º, VI); **c)** colaboração de interesse público, na forma deste dispositivo em análise (art. 19, I); **d)** escusa de consciência por motivo de crença religiosa (arts. 5.º, VIII, e 143, § 1.º); **e)** imunidade religiosa (art. 150, VI, “a”); **f)** possibilidade de destinação de recursos públicos para escolas confessionais, na forma do descrito no art. 213; **g)** reconhecimento aos índios, dentre outros, de seus costumes, crenças e tradições (art. 231).

No tocante ao **ensino religioso** nas escolas públicas de ensino fundamental, que constituirá disciplina dos horários normais, o STF, por **6 x 5**, estabeleceu a possibilidade de se ter **natureza confessional**, na medida em

que a sua matrícula é **facultativa**, nos termos do art. 210, § 1.º, CF/88, e, também, diante deste reconhecimento de separação atenuada entre Estado e igreja (**ADI 4.439**, j. 27.09.2017, *DJE* de 21.06.2018 — cf. *item 14.10.6.2*).

- recusar fé aos documentos públicos, ou seja, os documentos públicos presumem-se idôneos;
- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, inegável desdobramento do princípio da isonomia, que será mais bem estudado no *item 14.10.2*.

■ 7.4. UNIÃO FEDERAL

A União Federal mais os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios compõem a República Federativa do Brasil, vale dizer, o Estado federal, o país Brasil.

A União, segundo José Afonso da Silva, “... se constitui pela congregação das comunidades regionais que vêm a ser os Estados-membros. Então quando se fala em Federação se refere à *união* dos Estados. No caso brasileiro, seria a união dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por isso se diz *União Federal*...”.²⁶

Assim, uma coisa é a União — unidade federativa —, ordem central, que se forma pela reunião de partes, através de um pacto federativo. Outra coisa é a República Federativa do Brasil, formada pela reunião da União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos, nos termos da CF. A República Federativa do Brasil, portanto, é soberana no plano internacional (cf. art. 1.º, I), enquanto os entes federativos são autônomos entre si!

A União possui “**dupla personalidade**”, pois assume um papel internamente e outro internacionalmente.

Internamente, é uma pessoa jurídica de direito público interno, componente da Federação brasileira e autônoma na medida em que possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, configurando, assim, autonomia **financeira, administrativa e política (FAP)**.

Internacionalmente, a União representa a República Federativa do Brasil (*vide* art. 21, I a IV). Observe-se que a soberania é da República Federativa do Brasil, representada pela União Federal.

Exemplificando, de maneira interessante, David Araujo e Serrano Nunes observam: “a União age em nome de toda a Federação quando, no plano internacional, representa o País, ou, no plano interno, intervém em um Estado-membro. Outras vezes, porém, a União age por si, como nas situações

em que organiza a Justiça Federal, realiza uma obra pública ou organiza o serviço público federal”.²⁷

■ 7.4.1. Capital Federal

CONSTITUIÇÃO	DISPOSITIVO NORMATIVO	CAPITAL	LOCALIZAÇÃO
■ 1824	■ não há previsão expressa	■ Rio de Janeiro	■ cidade do Rio de Janeiro
■ Ato Adicional n. 16/1834	■ art. 1.º, 2.ª parte	■ Rio de Janeiro — elevado à condição de Município Neutro	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1891	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1934	■ art. 4.º, <i>caput</i> , das Disposições Transitórias	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1937	■ art. 7.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1946 (primeiro momento)	■ art. 1.º, § 2.º	■ Distrito Federal	■ cidade do Rio de Janeiro
■ 1946 (segundo momento — 21.04.1960)	■ art. 4.º, ADCT	■ Distrito Federal (por força do art. 1.º, § 2.º), tendo sido dado o nome de “Brasília” à nova capital inaugurada em 21.04.1960, quando houve a sua transferência para o Planalto Central do Brasil (cf. art. 33 da Lei n. 2.874/56)	■ Planalto Central

■ 1967	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ Planalto Central
■ EC n. 1/1969	■ art. 2.º	■ Distrito Federal	■ Planalto Central
■ 1988	■ art. 18, § 1.º	■ Brasília	■ Planalto Central (no território do Distrito Federal — RA I ²⁸)

Brasília é a Capital Federal (art. 18, § 1.º). Trata-se de inovação em relação à Carta anterior, que estabelecia ser o Distrito Federal a Capital da União (cf. *item 7.7.1*).

Juscelino Kubitschek, cumprindo mandamento constitucional de interiorização do País (art. 3.º, CF/1891;²⁹ art. 4.º, *caput*, das Disposições Transitórias da CF/1934;³⁰ e art. 4.º, ADCT, CF/1946),³¹ inaugurou Brasília em **21.04.1960**.³²

Conforme anotou José Afonso da Silva, de acordo com as regras fixadas na Constituição de 1988, Brasília “assume uma posição jurídica específica no conceito brasileiro de ‘cidade’. Brasília é *civitas civitatum*, na medida em que é cidade-centro, polo irradiante, de onde partem, aos governados, as decisões mais graves e onde acontecem os fatos decisivos para os destinos do país. Mas **não se encaixa no conceito geral de ‘cidade’, porque não é sede de Município**. É *civitas* e *poli*, enquanto modo de habitar e **sede do Governo Federal**”.

Ainda, de acordo com o art. 6.º da Lei Orgânica do DF, Brasília, além de ser a Capital da República Federativa do Brasil (e, como vimos, **sede do Governo Federal**), também é **sede do governo do Distrito Federal**.³³

Finalmente, o **art. 48, VII**, CF/88, estabelece ser atribuição do Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a **transferência temporária da sede do Governo Federal**.

Veja que o texto fala em transferência **temporária** e da **sede do Governo Federal**. Assim, não se admitirá a transferência definitiva (da sede do Governo Federal) e, muito menos, a transferência da Capital Federal. Esta será **sempre** Brasília, e o que eventualmente será transferido, insista-se, será a sede do Governo Federal.

Poderíamos pensar em situações de crise, como guerra, calamidade pública ou situações que impossibilitassem o funcionamento normal do Governo Federal, a justificar a eventual necessidade de sua transferência.

Como exemplo, citamos a **Lei n. 8.675/93**, que dispôs sobre a transferência temporária e simbólica da sede do Governo Federal para a cidade de **Salvador**, capital do Estado da Bahia, nos dias 15 e 16 de julho de 1993, datas da realização das reuniões de cúpula da *III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo*, tendo sido os atos e despachos do Presidente da República e dos Ministros de Estado datados naquela localidade. Tratava-se de homenagem prestada à cidade de Salvador que foi a primeira sede de governo do País.

■ 7.4.2. Bens da União

O art. 20 define os bens da União. Em relação a esse tema, orientamos, para as provas, uma breve leitura do referido art. 20, CF/88.³⁴ Trata-se de questão sempre perguntada, exigindo a pura memorização do candidato.

Tendo em vista a novidade trazida pela **EC n. 46/2005**, resolvemos destacar o art. 20, IV, CF/88. Começemos a análise pelo quadro comparativo da redação do aludido dispositivo:

■ Art. 20, IV — as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, (AC) as áreas referidas no art. 26, II.

■ Art. 20, IV — as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, **as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II (redação dada pela EC n. 46/2005).**

Durante a tramitação da matéria no Senado Federal, a presidência recebeu expediente subscrito por membros da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de lideranças municipais, da sociedade civil organizada e de populares solicitando empenho para a rápida aprovação da matéria, tendo em vista a sua importância para os Municípios localizados na ilha de São Luís.

Ao analisar a antiga redação dada ao art. 20, IV, observaram: “este tratamento distinto na Constituição, dado aos municípios situados em ilhas, particularmente em ilhas costeiras, estabelece uma discriminação brutal em relação aos demais municípios brasileiros. Senão vejamos:

- os moradores destes municípios, exceto aqueles residentes em terras oriundas de sesmarias, não são proprietários da área em que moram, ou têm o domínio útil, ou são posseiros;

- esses mesmos moradores, excetuada a questão das sesmarias, têm que pagar IPTU às prefeituras, o que ocorre em todos os municípios brasileiros, e taxa de foros à União, fato que tecnicamente pode não ser caracterizado como bitributação, mas de fato o é, penalizando sobremaneira uma população que já possui sua capacidade de pagar impostos e taxas exaurida;

- prejudica o setor primário, na medida em que o pequeno produtor, para conseguir crédito junto às agências de crédito, normalmente lhe é exigido o título de propriedade da área, que não possui;

- a indústria e o comércio também são prejudicados, na medida que têm que incluir mais uma taxa em seus insumos, diminuindo sua competitividade;

- o setor imobiliário é prejudicado quando, em qualquer transação de imóveis, além do ITBI, pago às prefeituras, deve ser pago laudêmio à União;

■ conflitos fundiários são constantes devido o entendimento da União que as terras são de sua propriedade e a existência de escrituras lavradas em cartório conferindo a terceiros estas mesmas áreas como próprias”.

No **Parecer n. 462, de 2004, da CCJC**, o relator, Senador Jorge Bornhausen, faz importante observação: “... a proposta claramente cuida apenas de restabelecer a normalidade dos fatos, retirando do patrimônio da União terras que lhe foram indevidamente atribuídas, e restituindo aos municípios tais glebas que, em face do processo de urbanização, passaram a integrar suas respectivas áreas administrativas” (*DSF* de 12.05.2004, p. 13799).

Seguindo esse entendimento, sustentamos que essa importante medida estimularia o desenvolvimento local de diversos Municípios, entes federativos autônomos, podendo-se destacar, dentre tantos, três que são também capitais de Estado: Florianópolis/SC, São Luís/MA e Vitória/ES. Lembramos, ainda, para se ter mais exemplos, a Ilha de Itaparica e os seus Municípios; a mágica “Morro de São Paulo”, no Município de Cairu, todas no Estado da Bahia. No Estado do Piauí, destacamos a Ilha Grande de Santa Isabel. No Estado de Santa Catarina, a Ilha de São Francisco do Sul. No Estado de São Paulo, a Ilha de São Vicente, dentre tantos outros Municípios que seriam beneficiados com a medida.

Em nosso entender, a única ressalva era aquela expressamente prevista na **EC n. 46/2005**, qual seja, as **áreas afetadas ao serviço público** e à **unidade ambiental federal**, que continuavam como bens da **União**.

CUIDADO: esse nosso entendimento, contudo, não prevaleceu no STF. Analisando a situação específica do **Município de Vitória**, o Tribunal entendeu que os **terrenos de marinha e seus acrescidos** estabelecidos na ilha costeira em que situado referido ente federativo deveriam ser considerados como **bens da União**, na forma do **art. 20, VII**, que não foi revogado com o advento da referida reforma constitucional (interpretação sistemática dos incisos IV e VII do art. 20, CF/88).

Nesse sentido, a Corte, por 8 x 1, apreciando o *tema 676* da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a EC n. 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do art. 20, VII, da Constituição da República, sobre os **terrenos de marinha e seus acrescidos** situados em **ilhas costeiras sede de Municípios**” (definidos abaixo), como no caso de Vitória (**RE 636.199**, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.04.2017).

Conforme se destacou, além dos argumentos no sentido da necessidade de harmonização entre os incisos IV e VII do art. 20, CF/88, “os terrenos de marinha e seus acrescidos, **do ponto de vista histórico**, já integravam o rol de bens da União, mesmo antes de as ilhas costeiras passarem a compor o patrimônio federal, a reforçar o rechaço à tese de que teria sido alterado o tratamento jurídico a eles conferido em razão da modificação introduzida pela EC 46/2005 na propriedade das ilhas marítimas. Também destoia do sistema de distribuição de bens entre as entidades da Federação entender que os **Municípios sediados em ilhas** sejam proprietários dos terrenos de marinha, e não o sejam os **Municípios costeiros**. Com a EC 46/2005, portanto, as ilhas costeiras em que situada a sede de Município passaram a receber o mesmo tratamento da porção continental do território brasileiro no tocante ao regime de bens da União (...). A isonomia aspirada pelo constituinte derivado operou-se em prestígio da autonomia municipal preconizada na Carta de 1988 e cuidou de equiparar o regime jurídico-patrimonial das ilhas costeiras em que sediados Municípios àquele incidente sobre suas porções continentais, favorecendo a promoção dos interesses locais e o desenvolvimento da região” (*Inf. 862/STF*).

Como consequência desse entendimento de que os **terrenos de marinha e seus acrescidos** situados em **ilhas costeiras sede de Municípios** são de **propriedade da União**, o uso privativo dos referidos bens imóveis da União está regulamentado em legislação específica, no caso, o Decreto-Lei n. 9.760/46, implementando-se a sua utilização pelo regime do **aforamento** (art. 99 do Decreto-Lei n. 9.760/46).

Conforme observa Di Pietro, quando aplicável a imóveis da União, a **enfiteuse** tem natureza de **direito real de natureza pública**, havendo uma bifurcação da propriedade: **a) domínio direto**: o senhorio e a propriedade do imóvel pertencem à União, que conserva o domínio direto; **b) domínio útil**: pertence ao foreiro ou enfiteuta, que tem poderes de usar, gozar e reivindicar a coisa, bem como alienar os seus direitos a outrem. Entre as suas obrigações está a de pagar anualmente o **foro** (contraprestação em razão do domínio útil), bem como o **laudêmio**, na hipótese de “transferência onerosa, por ato *inter vivos*, do domínio útil ou de direitos sobre as benfeitorias, bem como a cessão de direitos a eles relativos” (art. 3.º do Decreto-Lei n. 2.398/87).³⁵

Teceremos brevíssimos comentários sobre alguns bens da União (apenas a definição da dimensão), cujo questionamento, pela lógica, certamente deverá aparecer em direito administrativo:

■ **terrenos de marinha**: aqueles “em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Para os efeitos dessa definição, a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano” (art. 2.º do Decreto-Lei n. 9.760/46);

■ **terrenos acrescidos de marinha**: “os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha” (art. 3.º do Decreto-Lei n. 9.760/46);

■ **mar territorial**: “... faixa de **12 milhas marítimas** de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil” (art. 1.º da Lei n. 8.617/93);

■ **zona contígua:** “... faixa que se estende das **12 às 24 milhas marítimas**, contadas das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” (art. 4.º da Lei n. 8.617/93);

■ **zona econômica exclusiva:** “... faixa que se estende das **12 às 200 milhas marítimas**, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” (art. 6.º da Lei n. 8.617/93);

■ **plataforma continental:** “... leito ou subsolo das áreas marítimas que se estendem **além do seu mar territorial**, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, **ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base**, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância” (art. 11 da Lei n. 8.617/93);

■ **faixa de fronteira:** faixa de até **150 quilômetros** de largura, ao longo das fronteiras terrestres (art. 20, § 2.º, CF/88).

Dentro deste último conceito, convém destacar as **terras devolutas**, bens públicos *dominicais*, pertencentes à União, por força do art. 20, II, desde que situadas na *faixa de fronteira*. Logo, são bens da União as *terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei*. As demais terras devolutas, em regra, desde que não tenham sido trespassadas aos Municípios, são de propriedade dos Estados.³⁶

Finalmente, estabelece a Constituição, na redação dada pela **EC n. 102/2019**, ser assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a **participação** no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração (art. 20, § 1.º).

■ 7.4.3. Competências da União Federal

■ 7.4.3.1. Competência não legislativa (administrativa ou material)

A competência não legislativa, como o próprio nome ajuda a compreender, determina um campo de atuação político-administrativa, tanto é que são também denominadas competências administrativas ou materiais, pois não se trata de atividade legiferante. Regulamenta o campo do exercício das **funções governamentais**, podendo tanto ser **exclusiva** da União (marcada pela particularidade da **indelegabilidade**) como **comum** (também chamada de **cumulativa, concorrente, administrativa** ou **paralela**) aos entes federativos, assim esquematizadas:

■ **exclusiva**: art. 21, CF/88;

■ **comum (cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela)**: art. 23 — trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em relação à competência *comum* (cumulativa, concorrente administrativa ou paralela), de maneira bastante interessante, o art. 23, parágrafo único, estabelece que **leis complementares** fixarão normas para a **cooperação** entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o **equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional**.

O objetivo é claro: como se trata de competência comum a todos, ou seja, concorrente no sentido de todos os entes federativos poderem atuar, o objetivo de referidas leis complementares é evitar não só conflitos como também a dispersão de recursos, procurando estabelecer mecanismos de otimização dos esforços.

Como exemplo, podemos citar a **LC n. 140/2011**, que, regulamentando os incisos III, VI e VII do art. 23, CF/88, fixou normas para a **cooperação** entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas **ações**

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas:

- à proteção das paisagens naturais notáveis;
- à proteção do meio ambiente;
- ao combate à poluição em qualquer de suas formas;
- à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Infelizmente, o legislador regulamentou apenas os incisos III, VI e VII do art. 23. Diante dessa constatação, surge a questão: e se ocorrer conflito entre os entes federativos durante o exercício das demais competências previstas no art. 23, qual a solução a adotar?

Nesse caso, observam Mendes, Coelho e Branco que, “se o critério da colaboração não vingar, há de se cogitar do **critério da preponderância de interesses**. Mesmo não havendo hierarquia entre os entes que compõem a Federação, pode-se falar em hierarquia de interesses, em que os mais **amplos** (da União) devem preferir aos mais restritos (dos Estados)” (grifamos).³⁷

Contudo, vale a pena destacar voto do Min. Fachin no julgamento de questão envolvendo a **proibição do amianto** (cf. *item 7.11.1*) ao sustentar que o **federalismo cooperativo** “não se satisfaz apenas com o princípio informador da predominância de interesses”, devendo observar os preceitos de **subsidiariedade** e **proporcionalidade**.

Conforme expressa, “de acordo com a primeira (subsidiariedade), o ente político maior deve deixar para o menor tudo aquilo que este puder fazer com **maior economia e eficácia**. Já de acordo com a segunda (proporcionalidade), é preciso sempre respeitar uma rigorosa **adequação entre meios e fins**. A proporcionalidade poderia ser utilizada, portanto, como teste de razoabilidade para soluções de problemas envolvendo competência de nítida orientação constitucional. O teste de razoabilidade, por sua vez, exigiria o exame das razões que levaram o legislador a adotar determinado regulamento. Consistiria, portanto, em avaliar se as razões necessárias para a conclusão a que chegou foram levadas em conta ou se optou por motivos que não poderiam ter sido considerados. Interpretando, pois, os princípios da

subsidiariedade e da proporcionalidade nesses termos, seria possível, então, superar o conteúdo meramente formal do princípio e reconhecer um aspecto material, consubstanciado numa presunção de autonomia em favor dos entes menores (‘presumption against preemption’), para a edição de leis que resguardecem seus interesses” (*Inf. 848/STF*, ADIs 3.356, 3.357, 3.937 e ADPF 109, j. 30.11.2017, *DJE* de 1.º.02.2019).

Mas fica um **ALERTA**: muito embora essa interessante perspectiva, o Pleno, ao apreciar leis estaduais que obrigavam empresas de telefonia a instalar equipamentos para o bloqueio de celulares em presídios, entendeu-as como inconstitucionais, por tratarem de telecomunicações (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, IV). Por mais que o argumento lançado pelo Min. Fachin tivesse o apoio dos Mins. Barroso e Rosa Weber (sustentando haver a matéria conexão com direito penitenciário, consumo e segurança pública — o que permitira a normatização estadual), não adotando meramente o critério da preponderância de interesses, a maioria do STF, contudo, capitulou a matéria como afeta a telecomunicações, atraindo, assim, a competência da União.

Apesar do reconhecimento de pontos de contato entre os temas, a maioria dos Ministros fundamentou com base no **critério da prevalência de interesses** para solucionar o conflito, sustentando a competência da União quando a matéria transcender interesses locais e regionais, devendo, no caso, haver um tratamento nacional uniforme (ADIs 3.835, 5.356, 5.253, 5.327 e 4.861, j. 03.08.2016).

De todo modo, a partir das perspectivas lançadas nas ações que discutiram a proibição do **amianto** (ADIs 4.066, 3.937, 3.406, 3.470, 3.356, 3.357 e ADPF 109), parece que a ideia de **federalismo cooperativo** ganhou força, seja em relação ao **tabaco** (cf. *item 7.11.2*), como, em especial, em vários julgamentos proferidos pela Corte para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da **pandemia da Covid-19** (cf. *item 7.11.3*).

■ 7.4.3.2. *Competência legislativa*

Como a terminologia indica, trata-se de competências, constitucionalmente definidas, para **elaborar leis**. Elas foram assim definidas para a União Federal:

■ **privativa:** art. 22, CF/88. Indaga-se: apesar de ser competência privativa da União, poderiam aquelas matérias ser regulamentadas também por outros entes federativos? Sim, de acordo com a regra do art. 22, parágrafo único, que permite à União, por meio de **lei complementar**, autorizar os **Estados** a legislar sobre questões específicas das matérias previstas no referido art. 22. Entendemos que essa possibilidade estende-se, também, ao **Distrito Federal**, por força do art. 32, § 1.º,³⁸ CF/88. Finalmente, havendo opção política e discricionária, referida delegação não poderá ser direcionada a um único Estado determinado, mas deverá ser para todos os Estados e o DF (no exercício de sua competência estadual);

■ **concorrente:** o art. 24 define as matérias de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Em relação àquelas matérias, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**. Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada pela União sobre norma geral, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, *caput*, c/c o art. 32, § 1.º) poderão suplementar a União e legislar, também, sobre as normas gerais, exercendo a **competência legislativa plena**. Se a União resolver legislar sobre norma geral, a norma geral que o Estado (ou Distrito Federal) havia elaborado terá a sua **eficácia suspensa**, no ponto em que for contrária à nova lei federal sobre norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver, perfeitamente, a norma geral federal e a estadual (ou distrital). Observe-se tratar de **suspensão da eficácia, e não revogação**, pois, caso a norma geral federal que suspendeu a eficácia da norma geral estadual seja revogada por outra norma geral federal, que, por seu turno, não contrarie a norma geral feita pelo Estado, esta última voltará a produzir efeitos (lembre-se que a norma geral estadual apenas teve a sua **eficácia suspensa**);³⁹

competência tributária expressa: art. 153 (estudar especialmente em ■ direito tributário);

■ **competência tributária residual:** art. 154, I (instituição, mediante **lei complementar**, de impostos não previstos no art. 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na CF);

■ **competência tributária extraordinária:** art. 154, II (instituição, na iminência ou no caso de guerra externa, de **impostos extraordinários**, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação).

■ 7.4.3.3. *Competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação — discussão em relação à EC n. 85/2015*

De acordo com o art. 218, *caput*, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação (cf. *item 19.6*).

Nesse sentido, a Constituição prescreve que o *Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação* será organizado em regime de **colaboração** entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

A disciplina desse sistema dar-se-á, de acordo com o art. 219-B, §§ 1.º e 2.º (EC n. 85/2015), da seguinte forma:

■ **União (lei federal):** disporá sobre as *normas gerais* do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

■ **Estados, Distrito Federal e Municípios:** legislarão *concorrentemente* sobre suas peculiaridades.

Essa previsão de **competência concorrente** está também prevista no art. 24, IX (redação dada pela EC n. 85/2015).

Isso posto, indagamos: a introdução da regra contida no art. 219-B, § 2.º, CF/88, pela EC n. 85/2015, cria um novo modelo de competência concorrente na federação brasileira?

Entendemos que **não**!

Isso porque devemos analisar as atribuições destinadas aos entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) sempre à luz do art. 24, §§ 1.º a 4.º, bem como do art. 30, I e II.

Assim, a competência da **União** limitar-se-á a estabelecer **normas gerais** sobre o *Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação*. Por sua vez, a competência dos **Estados** e do **DF**, existindo a norma geral federal, destinar-se-á para complementar referida norma. A competência dos **Municípios**, por outro lado, limitar-se-á a suplementar a legislação federal e a estadual **existentes** no que couber e sempre à luz do interesse local.

E se não existir a norma geral federal?

Nos termos do art. 24, §§ 2.º e 4.º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos **Estados** e do **DF**. Isso porque, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados e o DF exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, lembrando que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual e/ou da lei distrital, no que lhe for contrário.

Estamos propondo que essa atuação normativa **supletiva** (supletiva já que inexistente a lei federal, no caso em análise), estabelecida para os Estados e para o DF, não tenha sido estendida pela EC n. 85/2015 para os Municípios.

Muito embora no art. 219-B, § 2.º, fale-se em “legislação concorrente”, entendemos que os **Municípios** não poderão extrapolar os limites explícitos do art. 30, I e II. Em outras palavras, estão autorizados **apenas** a **suplementar** as **leis federal** ou **estaduais que já existem**, não podendo invadir a competência de um desses entes federativos na hipótese de inexistência das referidas leis (na medida em que a regra da competência

concorrente — art. 24 — não foi introduzida para os Municípios). Havendo inércia, o parâmetro será sempre o interesse local (art. 30, I).

Vamos aguardar, então, as discussões sobre o tema, seja na doutrina, como, também, na jurisprudência do STF (**pendente** de análise futura).

■ **7.4.3.4. *Legislação sobre o meio ambiente e controle da poluição: competência municipal. O caso particular da queima da palha da cana-de-açúcar (RE 586.224) e o da aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitem fumaça acima de padrões considerados aceitáveis (RE 194.704)***

A) RE 586.224: queima da palha da cana-de-açúcar

As perspectivas lançadas no item anterior parecem encontrar alguma relação com precedente analisado pelo STF envolvendo a **proibição de queimada em canaviais**.

A Corte analisou a Lei n. 1.952/95, do Município de Paulínia (SP), que proibiu, **sem qualquer exceção**, a queima da palha da cana-de-açúcar.

Eis a questão: **poderia o município ter legislado sobre meio ambiente ou essa competência foi fixada apenas para a União, os Estados e o DF?**

Conforme vimos, a atribuição de proteção ao meio ambiente está fixada como matéria de competência administrativa (material) comum a todos os entes federativos (art. 23, VI). Trata-se de previsão para a atuação governamental, e não para se legislar.

A definição da competência normativa, no caso, está estabelecida como de **competência concorrente** entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, VI).

Conforme expusemos, não há previsão de aplicação das regras de competência concorrente (art. 24, §§ 1.º a 4.º) para os Municípios cuja competência foi estabelecida apenas para legislar sobre assuntos de **interesse local** (art. 30, I), podendo **suplementar** a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II).

No precedente em análise, contudo, de maneira inovadora, o STF, por unanimidade, “firmou a tese de que **o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)**” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, Plenário, DJE de 08.05.2015).

No caso, como já existe legislação federal prevendo a eliminação planejada e gradual da queima da palha da cana-de-açúcar (art. 40 da Lei n. 12.651/2012 — Código Florestal), não poderia a lei municipal ter fixado a proibição total e imediata, especialmente por não se enquadrar a matéria como de interesse local específico daquele município.

Estamos diante de importante precedente que inova, em nosso entender, a leitura sobre o tema da competência entre os entes federativos, procurando harmonizar as regras de competência concorrente (art. 24) com aquelas de interesse local e suplementar dos Municípios (art. 30, I e II).

B) RE 194.704: aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitem fumaça acima de padrões considerados aceitáveis

Nesse mesmo sentido, a partir do precedente da queima da palha da cana-de-açúcar, o STF analisou lei do Município de Belo Horizonte com base na qual se aplicaram multas por poluição do meio ambiente, decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores no perímetro urbano (*vide Infns. ns. 347, 431, 807 e 870/STF*).

A Corte reafirmou que o município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de assuntos de interesse **estritamente** local e, naturalmente, não violar as legislações federal e estadual, por se tratar de matéria de competência concorrente.

Conforme afirmou o Min. Celso de Mello em seu voto, “o controle da poluição ambiental, especialmente vocacionado a impedir a degradação dos índices de qualidade do ar, assim obstando o agravamento da poluição atmosférica (que constitui fenômeno presente nos grandes centros urbanos e

nas áreas metropolitanas, como sucede com o Município de Belo Horizonte/MG), traduz matéria que se submete à esfera de competência legislativa dos Municípios, observado, para esse efeito, como **limite inultrapassável**, o **interesse local**, e desde que as medidas de regulação normativa **não transgridam nem conflitem com o âmbito de atuação que a Constituição da República atribuiu à União Federal e aos Estados-membros**” (RE 194.704, Plenário, j. 29.06.2017, DJE de 17.11.2017, fls. 110 do acórdão).

■ 7.4.4. Regiões administrativas ou de desenvolvimento

O art. 43, *caput*, CF, estabelece que, para **efeitos administrativos**, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu **desenvolvimento** e à **redução das desigualdades regionais**.

Trata-se, nos dizeres do Professor José Afonso da Silva, de “formas especiais de organização administrativa do território”,⁴⁰ destituídas de competência legislativa, em razão de sua falta de capacidade política no âmbito jurídico-formal.

Lei complementar disporá sobre: **a)** as condições para integração de regiões em desenvolvimento; **b)** a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

Dentre os **incentivos regionais**, podemos destacar, além de outros, na forma da lei: **a)** igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; **b)** juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; **c)** isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Neste caso, sempre que possível, a **concessão dos incentivos regionais** considerará **critérios de sustentabilidade ambiental** e **redução das emissões de carbono** (art. 43, § 4.º, introduzido pela EC n. 132/2023); **d)** prioridade para

o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

Em relação a estas últimas áreas, sujeitas a secas periódicas, o § 3.º do art. 43 dispõe que a União incentivará a recuperação das terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação, sendo que, nos termos do art. 42, ADCT, na redação dada pela **EC n. 89, de 15.09.2015**, durante **40 anos**, a União aplicará, do montante de recursos destinados à irrigação, 20% na Região Centro-Oeste e 50% na Região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Desses percentuais, no mínimo 50% serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem **agricultores familiares** que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. Trata-se, sem dúvida, da consagração do princípio das “discriminações positivas”, ou “ações afirmativas”, que será retomado no *item 14.10.2* ao tratarmos do princípio da igualdade substancial ou material (*vide*, também, arts. 3.º, III, e 187, VII).

Como exemplos de regiões administrativas ou de desenvolvimento podemos lembrar a SUDENE (LC n. 66/91), a SUDAM (LC n. 67/91), a SUFRAMA (LC n. 134/2010), as autorizações para o Poder Executivo criar as Regiões Administrativas Integradas de Desenvolvimento da Grande Teresina (LC n. 112, de 19.09.2001) e do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA (LC n. 113, de 19.09.2001), assim como a instituição da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO —, de natureza autárquica especial, com autonomia administrativa e financeira, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e com área de atuação abrangendo os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal (LC n. 129, de 08.01.2009).

Convém destacar, contudo, a **extinção** da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), por meio, respectivamente, das

MPs ns. 2.156-5 e 2.157-5, de 24.08.2001. Em contrapartida, foram criadas as **Agências de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e da Amazônia (ADA)**, de natureza autárquica, vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de implementar políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia, respectivamente. Cabe alertar sobre a forma de extinção da SUDAM e da SUDENE e sobre a criação da ADENE e da ADA, qual seja, **por meio de medida provisória**, o que poderá ser questionado perante o Judiciário, restando aguardar o pronunciamento do STF (pendente).

Posteriormente, a **LC n. 124/2007** instituiu, novamente, a **SUDAM**, de natureza autárquica especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

A **LC n. 125/2007**, por sua vez, instituiu a **SUDENE**, também de natureza autárquica especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

Finalmente, a **LC n. 129/2009** instituiu a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — **SUDECO**, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal.

■ 7.5. ESTADOS-MEMBROS

Os Estados-Membros são *autônomos* em decorrência da capacidade de **auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação**. Trata-se de **autonomia**, e não de **soberania**, na medida em que a **soberania** é um dos **fundamentos** da República Federativa do Brasil. Internamente, os entes federativos são **autônomos**, nos limites de suas competências, constitucionalmente definidas, delimitadas e asseguradas. Constituem pessoas jurídicas de direito público interno, autônomos, nos seguintes termos:

■ **auto-organização:** art. 25, *caput*, que, como vimos, preceitua que os Estados se **organizam** e serão **regidos** pelas leis e Constituições que adotarem, observando-se, sempre, as regras e preceitos estabelecidos na CF, conforme já expusemos ao tratar do poder constituinte derivado decorrente;

■ **autogoverno:** os arts. 27, 28 e 125 estabelecem regras para a estruturação dos “Poderes”: **Legislativo:** Assembleia Legislativa; **Executivo:** Governador do Estado; e **Judiciário:** Tribunais e Juízes (cada um dos Poderes será estudado nos *capítulos 9-11*);

■ **autoadministração e autolegislação:** arts. 18 e 25 a 28 — regras de competências legislativas e não legislativas, que serão oportunamente estudadas.

■ 7.5.1. Formação dos Estados-Membros

■ 7.5.1.1. Regra geral

O art. 18, § 3.º, CF/88, prevê os requisitos para o processo de criação dos Estados-Membros que deverão ser conjugados com outro requisito, o do art. 48, VI. Vejamos:

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS — ART. 18, § 3.º

"Os Estados podem **incorporar-se entre si**, **subdividir-se** ou **desmembrar-se** para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do **Congresso Nacional**, por **lei complementar**."

Fusão

Cisão

Desmembramento

■ **plebiscito:** por meio de plebiscito, a população interessada deverá aprovar a formação do novo Estado. Não havendo aprovação, nem se passará à próxima fase, na medida em que o plebiscito é **condição prévia, essencial e prejudicial** à fase seguinte;

■ **propositura do projeto de lei complementar:** o art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.709/98 estabelece que, **em sendo favorável** o resultado da consulta prévia ao povo mediante plebiscito, será proposto projeto de lei perante qualquer das Casas do Congresso Nacional;

■ **audiência das Assembleias legislativas:** à Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no item anterior compete proceder a audiência das **respectivas** Assembleias Legislativas (art. 4.º, § 2.º, da Lei n. 9.709/98, regulamentando o art. 48, VI, CF/88). Observe-se que o parecer das Assembleias Legislativas dos Estados **não é vinculativo**, ou seja, mesmo que desfavorável, poderá dar-se continuidade ao processo de formação de novos Estados (ao contrário da consulta plebiscitária, como vimos acima!);

■ **aprovação pelo Congresso Nacional:** após a manifestação das Assembleias legislativas, passa-se à fase de aprovação do projeto de **lei complementar**, proposto no Congresso Nacional, através do *quorum* de aprovação pela **maioria absoluta**, de acordo com o art. 69, CF/88. Cabe alertar que o Congresso Nacional não está obrigado a aprovar o projeto de lei, nem o Presidente da República está obrigado a sancioná-lo. Ou seja, ambos têm discricionariedade, mesmo diante de manifestação

plebiscitária favorável, devendo avaliar a conveniência política para a República Federativa do Brasil.

■ 7.5.1.2. *Aspectos específicos e procedimentais*

O art. 3.º da Lei n. 9.709/98 estatui que nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3.º do art. 18, CF (**criação de Estados-Membros**), o plebiscito e o referendo são convocados mediante **decreto legislativo**, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional.

É de observar que a competência para **autorizar** referendo e **convocar** plebiscito, de acordo com o art. 49, XV, CF/88, é **exclusiva do Congresso Nacional**, materializada por **decreto legislativo**.

Para ilustrar, vamos lembrar o caso concreto da proposta de divisão do **Estado do Pará**, que aconteceu em 2011 e que acabou não sendo aceita pelo povo.

O **Decreto Legislativo n. 136/2011** dispôs sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do **Carajás**,⁴¹ nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, enquanto, por sua vez, o **Decreto Legislativo n. 137/2011** convocou plebiscito sobre a criação do Estado do **Tapajós**.⁴²

Interessante notar que foram os parlamentares os responsáveis pela definição do suposto novo desenho do atual Estado do Pará no caso de aprovação do plebiscito.

Ou seja, essa definição já chega pronta para que a população do Estado responda no momento da consulta.

A) E quais poderiam ser os possíveis resultados do plebiscito?

Conforme sinalizado anteriormente, se o povo responder que não é a favor da separação para formação de novos Estados (**desmembramento formação**), o procedimento não seguirá, ou seja, a **vontade negativa** do povo **vincula**, não podendo, assim, jamais, o Parlamento aprovar eventual

projeto de lei complementar criando os novos Estados contra a vontade negativa manifestada no plebiscito.

Portanto, parece-nos possível concluir que a **democracia direta prevalece sobre a democracia representativa**.

Agora, ao invés, se a **vontade** do povo for no **sentido favorável**, o projeto de lei complementar poderá seguir a sua tramitação e, assim, o parlamento, **com autonomia**, avaliará a conveniência ou não da criação dos novos Estados.

Isso significa que o Congresso Nacional terá total liberdade para não aceitar a criação dos novos Estados, até porque é o órgão político responsável pela avaliação e conveniência do novo desenho do Estado brasileiro.

B) Se a população autorizar o procedimento e o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei complementar, o Presidente da República poderá vetar o projeto de lei?

Sim! O que quer dizer que o Presidente da República terá autonomia para ir contra a vontade do povo. E, novamente, essa situação não tem nenhum empecilho, na medida em que o Chefe do Executivo, mesmo que eleito pelo povo, tem, em igual sentido, liberdade para avaliar a conveniência do novo “desenho”.

Nesse caso, parece-nos que, consagrando o **sistema dos freios e contrapesos** e em respeito à literalidade do **art. 66, § 4.º, CF/88**, necessariamente, o veto presidencial será apreciado pelo Parlamento em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, podendo ser **rejeitado** pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores (lembramos que, para essa hipótese, a **EC n. 76/2013**, no tocante ao modo de votação, aboliu a regra do escrutínio secreto, passando a ser votação ostensiva, ou seja, voto “aberto”).

Avançando, o art. 18, § 3.º, CF/88, estabelece que os Estados podem desmembrar-se para formar novos Estados mediante **aprovação da população diretamente interessada**, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

C) O que deve ser entendido por população diretamente interessada a ser ouvida no plebiscito?

Em **24.08.2011**, o Plenário do STF decidiu, no julgamento da **ADI 2.650**,⁴³ que o plebiscito para o desmembramento de um Estado da Federação deve envolver não somente a população do território a ser desmembrado, mas também a de **todo o Estado-Membro**, no caso do exemplo em análise, a população de todo o Estado do Pará.

E como fica o resto do Brasil? Será que a mudança no desenho da Federação não afetaria o interesse das populações e dos outros Estados?

Essa preocupação foi manifestada pelo Min. Marco Aurélio no julgamento da referida ADI 2.650, que chegou a afirmar a necessidade de se fazer a consulta envolvendo a população de todo o território nacional.

Conforme noticiado, explicou “... que os estados e os municípios de hoje têm participação em receitas federais e estaduais. ‘Ora, se há possibilidade de vir à balha um novo município ou um novo estado haverá prejuízo para as populações dos demais estados e dos demais municípios, e a razão é muito simples: aumentará o divisor do fundo alusivo aos estados e do fundo também referente aos municípios’” (*Notícias STF*, 24.08.2011).

Contudo, como visto, **essa tese não prevaleceu**.

Assim, muito cuidado e retomando: população diretamente interessada deve ser entendida como **a população de todo o Estado-Membro (ou de todo o Município, no caso de seu desmembramento), e não apenas a população da área a ser desmembrada**.

Em relação ao **resto do Brasil**, podemos afirmar que a consulta acabará sendo realizada, segundo anotado no julgamento da ADI 2.650, **indiretamente**, por meio dos seus **representantes eleitos**, na medida em que, relembramos, o Congresso Nacional terá discricionariedade para aprovar ou não o projeto de LC, mesmo diante de plebiscito favorável.

■ 7.5.1.3. E qual deve ser o procedimento no caso de criação de um novo Estado?

Ou, em outras palavras, o que acontecerá se o povo autorizar a criação do novo Estado, o projeto de lei complementar for aprovado pelo Congresso Nacional e o Presidente da República sancioná-lo, promulgando e determinando a publicação da nova lei, que efetivamente tratará do novo desenho do território nacional?

Nesse caso, de acordo com o [art. 235](#), CF/88, nos **10 primeiros anos** da referida criação, serão observadas as seguintes regras básicas:

- a Assembleia Legislativa será composta de 17 Deputados, se a população do Estado for inferior a 600.000 habitantes, e de 24, se igual ou superior a esse número, até 1.500.000;
- o Governo terá no máximo 10 Secretarias;
- o Tribunal de Contas terá 3 membros, nomeados pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;
- o Tribunal de Justiça terá 7 Desembargadores;
- os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos na forma do art. 235, V, “a” e “b”;
- no caso de Estado proveniente de Território Federal, os 5 primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País;
- em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e títulos;
- até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis *ad nutum*;
- se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá de acordo com o art. 235, IX, “a” e “b”;

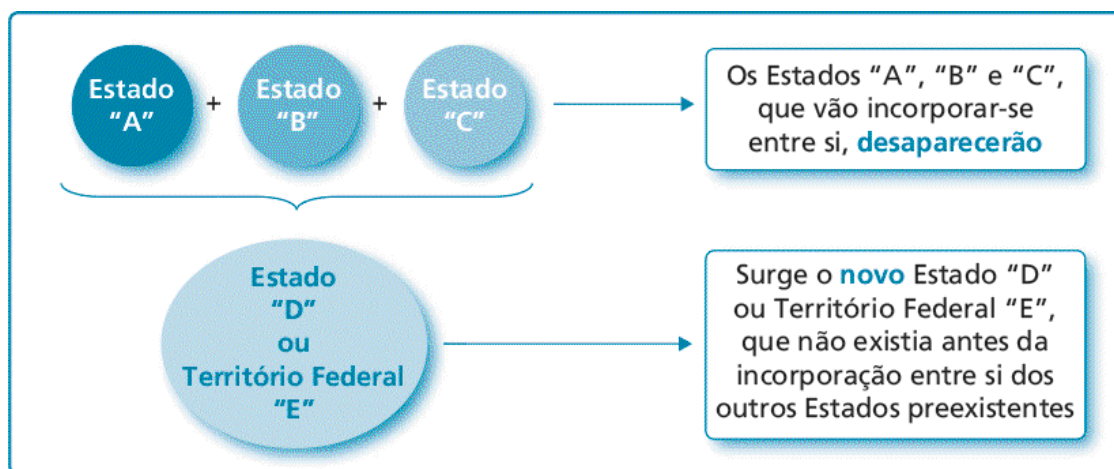
- as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados, serão disciplinadas na Constituição Estadual;
- as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado.

■ 7.5.1.4. *Fusão*

O art. 18, § 3.º, determina que os Estados poderão **incorporar-se entre si**. Trata-se do instituto da **fusão**, na medida em que dois ou mais Estados se unem geograficamente, formando um terceiro e novo **Estado** ou **Território Federal**, distinto dos Estados anteriores, os quais, por sua vez, perderão a personalidade primitiva. Ou seja, os Estados que se incorporarem entre si não mais existirão; o Estado ou Território Federal que será formado considera-se inexistente antes do processo de fusão.

Nesse caso, por população diretamente interessada, a ser consultada mediante plebiscito, deve-se entender a população de cada um dos Estados que desejam fundir-se.

Como exemplo, podemos lembrar o art. 8.º da **LC n. 20/74**, que criou o atual **Estado do Rio de Janeiro** em razão da fusão dos *Estados do Rio de Janeiro* e da *Guanabara* (antigo Município Neutro, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro e que foi a capital do Brasil, transformada em Distrito Federal pela Constituição de 1891, e transformado no Estado da Guanabara em 21.04.1960 quando houve a inauguração de Brasília e a transferência da Capital para o Planalto Central).



■ 7.5.1.5. *Cisão*

A **cisão** ocorre quando um Estado que já existe **subdivide-se**, formando dois ou mais Estados-Membros novos (que não existiam), com personalidades distintas, ou Territórios Federais. O Estado originário que se subdividiu **desaparece**, deixando de existir politicamente.

Como anota José Afonso da Silva, subdivisão "... significa separar um todo em várias partes, formando cada qual uma unidade independente das demais".⁴⁴

Por população diretamente interessada a ser consultada, mediante plebiscito, sobre a subdivisão do Estado deve-se entender a população do referido Estado que vai partir-se.



Imagem sem descrição.

■ 7.5.1.6. *Desmembramento*

Ao estabelecer o art. 18, § 3.º, que os Estados podem **desmembrar-se**, fixou-se a possibilidade de um ou mais Estados cederem parte de seu território geográfico para formar um novo Estado ou Território Federal que não existia ou se anexar (a parte desmembrada) a um outro Estado que já existia.

Como regra, **o Estado originário não desaparece**. Foi o que aconteceu com o Estado de Goiás em relação ao do **Tocantins** (art. 13, ADCT) e com o de Mato Grosso em relação a Mato Grosso do Sul, este criado pela LC n. 31/77.

Assim, surgem duas modalidades de desmembramento:

■ **desmembramento anexação** — a parte desmembrada vai anexar-se a um Estado que já existe, ampliando o seu território geográfico. Não haverá criação de um novo Estado. Tanto o Estado primitivo permanece (só que com área e população menores) como o Estado que receberá a parte desmembrada continua a existir (só que com área e população maiores);



Imagem sem descrição.

■ **desmembramento formação** — a parte desmembrada se transformará em um ou mais de um Estado novo ou Território Federal, que não existia.



Imagem sem descrição.

Reforçando, nos dois casos o Estado originário **não** desaparecerá, não ocorrendo a perda de sua identidade. Apenas perderá parte de seu território e da população.

No tocante ao plebiscito, por população diretamente interessada deve ser entendida tanto a do território que se pretende desmembrar como a que receberá o acréscimo, na hipótese de desmembramento anexação. Na hipótese de desmembramento formação deve ser ouvida a população do Estado que sofrerá o desmembramento.

Em relação ao **Estado do Tocantins**, criado na forma do art. 13, ADCT, acima mencionado (desmembramento formação), cabe lembrar que, depois de 32 anos, a **EC n. 110/2021** introduziu o art. 18-A ao ADCT, nos seguintes termos: “os atos administrativos praticados no Estado do Tocantins, decorrentes de sua instalação, entre 1.º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994, eivados de qualquer vício jurídico e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários ficam convalidados após 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

De fato, a previsão genérica da convalidação de atos administrativos decorrentes da instalação do Estado do Tocantins pode, sem dúvida, violar **a regra do concurso público**, até porque a convalidação, segundo a referida emenda, deve se dar após 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Como a convalidação se refere a atos praticados entre 1.º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994, esta já estaria consolidada desde 31.12.1999.)

A Corte enfrentou o tema no caso específico na ADI 598/91. Vejamos a ementa:

■ “O título ‘Pioneiro do Tocantins’, previsto no *caput* do art. 25 da Lei n. 157/90, atribuído a servidores do Estado, nada tem de inconstitucional. ENTRETANTO, quando utilizado para concurso de provas e títulos, ofende clara e diretamente o preceito constitucional que a todos assegura o acesso aos cargos públicos, pois, o critério consagrado nas normas impugnadas, de maneira oblíqua, mas eficaz, deforma o concurso a ponto

de fraudar o preceito constitucional, art. 37, II, da Constituição. Declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘inclusive para fins de concurso público de títulos e provas’ contida no par. único do art. 25 da Lei n. 157/90, do art. 29 e seu parágrafo único do Decreto n. 1.520, de 08.08.90, e da expressão ‘cabendo ao ‘Pioneiro do Tocantins’, como título, 30 (trinta) pontos, nos termos do art. 25, único, da Lei n. 157, de 27 de julho de 1990 e seu regulamento’, contida no item 4.4 do edital de concurso público de 15.10.90, publicado no *DOE* de 16.10.90” (ADI 598, j. 23.09.1993).

Ainda queremos refletir mais sobre o tema, mas, nesse momento inicial, diferentemente da regra trazida pelo Constituinte Originário nos arts. 19 e 22, ADCT, e da previsão estabelecida no art. 54 da Lei n. 9.784/99, não poderia o constituinte reformador ter passado por cima da regra do concurso público, inclusive na situação de serviços notariais e de registro (art. 236, § 3.º, CF/88).

■ 7.5.2. Bens dos Estados-Membros

De acordo com o art. 26, CF/88, incluem-se entre os bens dos Estados: I — as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; II — as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; III — as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; IV — as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

■ 7.5.3. Competências dos Estados-Membros

■ 7.5.3.1. Competência não legislativa (*administrativa ou material*)

■ **comum (cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela):** trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23, CF/88;

■ **residual (remanescente ou reservada):** são reservadas aos Estados as competências administrativas que não lhes sejam vedadas, ou a competência que sobrar (eventual resíduo), após a enumeração dos outros entes federativos (art. 25, § 1.º), ou seja, as competências que não sejam da União (art. 21), do Distrito Federal (art. 23), dos Municípios (art. 30, III a IX) e comum (art. 23).

■ 7.5.3.2. *Competência legislativa*

Como a terminologia indica, trata-se de competências, constitucionalmente definidas, **para elaborar leis**. Foram assim definidas para os Estados-Membros:

■ **expressa:** art. 25, *caput* → qual seja, como vimos, a capacidade de auto-organização dos Estados-Membros, que se regerão pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da CF/88;

■ **residual (remanescente ou reservada):** art. 25, § 1.º → toda competência que não for vedada está reservada aos Estados-Membros, ou seja, o resíduo que sobrar, o que não for de competência expressa dos outros entes e não houver vedação, caberá aos Estados materializar;

Perguntamos: quem tem competência para explorar e regulamentar a prestação de serviços de **transporte intermunicipal** (o transporte entre municípios **dentro do mesmo Estado**)?

Em primeiro lugar, precisamos descobrir se existem disposições que foram estabelecidas expressamente. De acordo com a regra constitucional, compete à **União** explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de **transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros** (art. 21, XII, “e”). A Constituição também

determina ser competência dos **Municípios** organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os **serviços públicos de interesse local**, incluído o de **transporte coletivo (dentro do mesmo Município)**, que tem **caráter essencial** (art. 30, V).

Dessa forma, fica clara a existência de regra expressa disciplinando o transporte de passageiros entre dois ou mais Estados e entre o Brasil e outros países (União), bem como dentro de um mesmo município (Municípios).

Contudo, **não há previsão de competência para dispor sobre o serviço de transporte entre municípios de um mesmo Estado**. Estamos diante de hipótese que não foi expressamente destinada para os demais entes federativos e que também não foi vedada aos Estados-Membros. Nesse sentido, aplica-se a regra do **art. 25, § 1.º, CF/88**, que reconhece a **competência estadual**, conforme, inclusive, entendeu o STF no julgamento da **ADI 2.349** (Pleno, j. 31.08.2005).

■ **delegada pela União**: art. 22, parágrafo único → como vimos, a União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa prevista no art. 22 e incisos. Tal autorização dar-se-á por meio de **lei complementar**;⁴⁵

■ **concorrente**: art. 24 → a concorrência para legislar dar-se-á entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à **União** legislar sobre normas gerais e aos **Estados**, sobre normas específicas;

■ **suplementar**: art. 24, §§ 1.º a 4.º → no âmbito da legislação concorrente, como vimos, a União limita-se a estabelecer normas gerais e os Estados, normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, os Estados poderão **suplementá-la**, regulamentando as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência de lei federal sobre norma geral, a aludida norma estadual geral (suplementar) terá a sua eficácia suspensa, no que for contrária à lei federal sobre normas gerais editadas posteriormente.⁴⁶

Assim, poderíamos, conforme a doutrina, dividir a competência suplementar em duas, a saber: **a) competência suplementar**

complementar — na hipótese de já existir lei federal sobre a matéria, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal (na competência estadual) simplesmente completá-las; **b) competência suplementar supletiva** — nessa hipótese inexistente a lei federal, passando os Estados e o Distrito Federal (na competência estadual), temporariamente, a ter a competência plena sobre a matéria;

■ **tributária expressa:** art. 155 (estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.5.4. Exploração dos serviços locais de gás canalizado

Os **serviços locais de gás canalizado** serão explorados diretamente pelos Estados, ou mediante concessão, na forma da lei, vedando-se a regulamentação da referida matéria por medida provisória, como expressamente previsto no art. 25, § 2.º (com a redação determinada pela EC n. 5/95), e em decorrência do art. 246, CF/88.

A Lei n. 9.478, de 06.08.1997 (*vide* também a Lei n. 9.847, de 26.10.1999), veio dispor sobre a **política energética nacional** e as **atividades relativas ao monopólio do petróleo**, instituindo o **Conselho Nacional de Política Energética** e a **Agência Nacional do Petróleo**, além de outras providências pertinentes à matéria.

Trata-se, de acordo com o art. 6.º, XXII, da aludida lei, da **distribuição de gás canalizado**, ou seja, serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2.º do art. 25, CF.⁴⁷

■ 7.5.5. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões

■ 7.5.5.1. Aspectos gerais

A política de agrupamento de municípios para a implementação de *serviços públicos comuns*, como, por exemplo, os de saneamento básico, foi **lançada** na Constituição de 1937 (art. 29), que delegava aos Estados a regulamentação das condições, bem como a forma de sua administração.

A Constituição de 1946 permitiu ao Estado apenas a criação de órgão de assistência técnica aos Municípios.

Já a de 1967 (art. 157, § 10) e a EC n. 1/69 (art. 164) trataram de modo explícito da possibilidade de criação de *regiões metropolitanas*, para a realização de *serviços de interesse comum*, mediante lei complementar do Congresso Nacional, ou seja, a competência era da União.

A Constituição de 1988, por sua vez, inovando, passa a atribuir aos **Estados** a competência para instituir não só as **regiões metropolitanas** mas, também, **aglomerações urbanas** e **microrregiões**, nos seguintes termos (art. 25, § 3.º):

■ **legitimados:** Estados-Membros;

■ **requisito formal:** a instituição dar-se-á por **lei complementar** a ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado;

■ **requisito material (elementos de constituição):** agrupamento de municípios limítrofes (dois ou mais);

■ **finalidade:** integrar a organização, o planejamento e a execução de **funções públicas de interesse comum**. Segundo interpretou o STF, “o interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais” (**ADI 1.842**, j. 06.03.2013);

■ **função pública de interesse comum:** “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (art. 2.º, II, da Lei n. 13.089/2015 — “Estatuto da Metrópole”).

■ 7.5.5.2. *Conceito*

De acordo com José Afonso da Silva:⁴⁸

■ **região metropolitana:** “constitui-se de um conjunto de Municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um Município-polo”;

■ **microrregiões:** “formam-se de grupos de Municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas por continuidade urbana”;

■ **aglomerados urbanos:** “carecem de conceituação, mas, de logo, se percebe que se trata de áreas urbanas, sem um polo de atração urbana, quer tais áreas sejam das cidades sedes dos Municípios, como na baixada santista (em São Paulo), ou não”.

Para o ilustre professor, o que dá essência ao conceito de **região metropolitana**, legitimando-a e justificando-a, é o fenômeno da **conurbação**, ou seja, “a existência de núcleos urbanos contíguos, contínuos ou não, subordinados a mais de um Município, sob a **influência de um Município-polo**”.

As *microrregiões* distinguem-se das *regiões metropolitanas* sob esse aspecto fático, caracterizando-se como “regiões espaciais definidas para *fins administrativos*, que também pressupõem a existência de um agrupamento de Municípios limítrofes com interesses comuns”, mas sem o citado aspecto urbanístico (a *conurbação*, “realidade fática, antológica, essência conceitual”).

A **região metropolitana**, diferente da *microrregião* (definida para fins administrativos), apresenta-se, portanto, como **região urbana** (“comunidade integrada em um espaço fortemente urbanizado”), e não puramente territorial. Essa característica marcante também se verifica nos *aglomerados urbanos*, que, contudo, diferente das *regiões metropolitanas*, não possuem um polo de atração urbana.⁴⁹

Partindo dessa perspectiva doutrinária, devemos destacar as definições contidas no *Estatuto da Metrópole* (Lei n. 13.089/2015), a saber:

■ **região metropolitana:** “unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (inicialmente definido na redação original do art. 2.º, VII, da Lei n. 13.089/2015, o instituto veio a ser alterado pela Lei n. 13.683/2018, tendo sido modificado pela MP 862/2018, que teve o seu prazo de vigência encerrado em 14.05.2019, voltando, então, a valer a regra dada pela referida Lei n. 13.683/2018);

■ **aglomeração urbana:** “unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas” (art. 2.º, I).

De maneira bastante interessante, o art. 4.º do *Estatuto da Metrópole* prevê a possibilidade de instituição de **região metropolitana** ou de **aglomeração urbana** que envolva **Municípios pertencentes a mais de um Estado**, hipótese em que será formalizada mediante a aprovação de **leis complementares pelas assembleias legislativas de cada um dos Estados envolvidos**.

Até a aprovação das referidas leis complementares por todos os Estados, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os Municípios dos Estados que já houverem aprovado a respectiva lei.

■ 7.5.5.3. *O que aconteceu com as regiões metropolitanas instituídas antes da nova Constituição de 1988?*

Conforme se observou, a partir de 1988, a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões passou a depender de **lei complementar estadual**.

No ordenamento jurídico anterior, a competência era da União, destacando-se os seguintes exemplos, **recepcionados** e que perduram até que lei complementar estadual disponha de modo diverso:

■ **LC n. 14/73:** regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza;

■ **LC n. 20/74:** região metropolitana do Rio de Janeiro, que veio a ser alterada pela **LC estadual n. 87/97**.

■ 7.5.5.4. ***Caráter compulsório da participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões***

O art. 357, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro exigia a *prévia aprovação pela respectiva câmara municipal* para a participação de qualquer município em região metropolitana.

O STF, interpretando o art. 25, § 3.º, reconheceu o **caráter compulsório da participação**, bastando a existência de **lei complementar estadual** (**ADI 1.841**, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 1.º.08.2002, Plenário, DJ de 20.09.2002).

Em igual sentido já havia decidido a Corte em relação ao art. 216, § 1.º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, declarando **inconstitucional** a *exigência de plebiscito às populações diretamente interessadas* para a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Como se disse, basta a existência de lei complementar aprovada pela Assembleia Legislativa estadual (**ADI 796**, j. 02.02.1998).

O tema voltou a ser reafirmado no julgamento da **ADI 1.842** (j. 06.03.2013), também envolvendo lei complementar específica estadual que criou a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos.

Conforme ficou estabelecido, “a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do **saneamento básico**, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos

municípios menos favorecidos. Repita-se que **este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal**” (item 4 da ementa).

■ 7.5.5.5. ***O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal que deverá ser preservada. Não se admite a simples transferência de competências exclusivamente para o Estado-Membro. A gestão deverá ser compartilhada***

Analisando o caso concreto do Estado do Rio de Janeiro, o STF deixou claro que a **autonomia municipal** deverá ser preservada. Assim, a organização, o planejamento e a execução de *funções públicas de interesse comum*, bem como o seu processo decisório, não poderão ser transferidos com exclusividade para o Estado-Membro, devendo ser assegurada a participação tanto dos municípios compreendidos como do referido ente federativo.

Conforme ficou assentado na *ementa* do julgamento da **ADI 1.842**, “o interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região”.

Dessa forma, “o parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre Municípios e Estado. **É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios**”.

Ao final, a Corte estabeleceu que “a **participação** dos entes nesse colegiado **não necessita de ser paritária**, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, **sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto**”.

■ 7.5.5.6. “Estatuto da Metrópole” — Lei n. 13.089/2015

Em discussão desde o advento do “Estatuto da Cidade” (Lei n. 10.257/2001), em sua complementação, a União elaborou a **Lei n. 13.089, de 12.01.2015**, instituindo o denominado “**Estatuto da Metrópole**”.

Tendo por fundamento os arts. 21, XX; 23, IX; 24, I; 25, § 3.º; e 182, o *Estatuto da Metrópole* estabelece:

- diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em **regiões metropolitanas** e em **aglomerações urbanas** instituídas pelos Estados;
- normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa;
- critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

Além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, as disposições introduzidas na lei aplicam-se, no que couber, às **microrregiões** instituídas pelos Estados com fundamento em **funções públicas de interesse comum com características predominantemente urbanas**.

De modo bastante interessante, o *Estatuto da Metrópole* preserva o entendimento firmado pelo STF no julgamento da **ADI 1.842** (cf. *item 7.5.5.4*), confirmando o caráter compulsório de participação dos Municípios nas regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, com a preservação da autonomia dos entes federativos em relação aos interesses comuns de abrangência metropolitana, como os serviços de transporte público, saneamento básico, meio ambiente, mobilidade urbana, moradia etc.

Lança-se a ideia de uma denominada “**governança interfederativa**”, definida pelo estatuto como o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum” (art. 2.º, IV).

Por sua vez, o art. 6.º da referida Lei n. 13.089/2015 estabelece que a **governança interfederativa** das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, com a previsão expressa de apoio da União, respeitará os seguintes **princípios**:

- prevalência do interesse comum sobre o local;
- compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano integrado (redação dada pela Lei n. 13.683/2018);
- autonomia dos entes da Federação;
- observância das peculiaridades regionais e locais;
- gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei n. 10.257/2001;
- efetividade no uso dos recursos públicos;
- busca do desenvolvimento sustentável.

No fundo, o estatuto confirma uma inegável tendência e realidade dos tempos atuais, marcada por não mais se sustentar a plena e isolada autonomia municipal, nem a crença em uma ultrapassada onipresença do Estado para tratar das questões supramunicipais.

O que se tem é a confirmação da necessidade de participação de todos os entes federativos envolvidos, bem como o necessário e permanente diálogo no tocante à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum.

■ 7.5.5.7. ***Qual a natureza jurídica das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões criadas por lei complementar estadual?***

Apesar da discussão doutrinária sobre o assunto, Michel Temer estabelece que a região metropolitana (e em seguida diz caber tal observação para as aglomerações urbanas e microrregiões) “não é dotada de personalidade. Com este dizer fica afastada a ideia de governo próprio ou,

mesmo, de administração própria. Não é pessoa política nem administrativa. Não é centro personalizado. Não é organismo. É órgão”.⁵⁰

Em outras palavras, instituído o agrupamento de municípios por um dos instrumentos, **não se criará um novo ente federativo**, não se tratará de entidade política autônoma, mas, em essência, será estabelecido um órgão com função meramente administrativa e executória, nos termos da lei complementar estadual.

Alaor Caffé Alves vislumbra no permissivo do art. 25, § 3.º, a possibilidade de se instituir uma “nova forma de administração regional, no âmbito dos Estados, como um corpo-administrativo territorial (**autarquia territorial, intergovernamental e plurifuncional**), sem personalidade política”.⁵¹

Essa *entidade regional* criada para a implementação das *funções públicas de interesse comum*, sempre assegurando a participação dos Municípios e do Estado, não poderá se confundir com as pessoas *políticas* que a instituirão, mas, naturalmente, poderá, diante da transferência de parte específica de competências e atribuições previstas na Constituição, ter personalidade *jurídica* (não política!).

Nesse sentido, interessante anotar o reconhecimento, pelo Min. Gilmar Mendes, de se implementar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum por **agências reguladoras**.

Ao analisar o caso concreto do Estado do Rio de Janeiro (**ADI 1.842**), em seu voto, reconheceu que o **serviço de saneamento básico** “— no âmbito de regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos — constitui interesse coletivo que não pode estar subordinado à direção de único ente, mas deve ser planejado e executado de acordo com decisões colegiadas em que participem tanto os municípios compreendidos como o estado federado”.

“Portanto, nesses casos, o poder concedente do serviço de saneamento básico nem permanece fracionado entre os municípios, nem é transferido para o estado federado, mas deve ser dirigido por **estrutura colegiada** — instituída por meio da lei complementar estadual que cria o agrupamento de comunidades locais — em que a vontade de um único ente não seja imposta a

todos os demais entes políticos participantes. Esta estrutura colegiada deve regular o serviço de saneamento básico de forma a dar viabilidade técnica e econômica ao adequado atendimento do interesse coletivo.”

E concluiu: “... a mencionada estrutura colegiada pode ser implementada tanto por **acordo**, mediante **convênios**, quanto de **forma vinculada**, na instituição dos agrupamentos de municípios. Ademais, a instituição de **agências reguladoras** pode se provar como forma bastante eficiente de estabelecer padrão técnico na prestação e concessão coletivas do serviço de saneamento básico” (grifamos).

■ 7.6. MUNICÍPIOS

O Município pode ser definido como pessoa jurídica de direito público interno e **autônoma** nos termos e de acordo com as regras estabelecidas na CF/88.

Muito se questionou a respeito de serem os Municípios parte integrante ou não de nossa Federação, bem como sobre a sua autonomia. A análise dos arts. 1.º e 18, bem como de todo o capítulo reservado aos Municípios (apesar de vozes em contrário), leva-nos ao único entendimento de que eles são entes federativos, dotados de autonomia própria, materializada por sua capacidade de **auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação**. Ainda mais diante do art. 34, VII, “c”, que prevê a intervenção federal na hipótese de o Estado não respeitar a **autonomia municipal**.

Como já alertamos, trata-se de **autonomia**, e não de **soberania**, uma vez que a **soberania** é um dos **fundamentos** da República Federativa do Brasil. Internamente, os entes federativos são **autônomos**, na medida de sua competência, constitucionalmente definida, delimitada e assegurada. Vejamos:

■ **auto-organização:** art. 29, *caput* — os Municípios organizam-se por meio de **Lei Orgânica**, votada em **dois turnos**, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por **dois terços** dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e o preceituado nos incisos I a XIV do art. 29, CF/88;

■ **autogoverno:** elege, diretamente, o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores (confira incisos do art. 29);

■ **autoadministração e autolegislação:** art. 30 — regras de competência que serão oportunamente estudadas. O STF, ao destacar a essência da autonomia municipal, estabeleceu que a autoadministração

implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica (ADI 1.842, item 3 da ementa).

■ 7.6.1. Formação dos Municípios

O art. 18, § 4.º, CF/88, com a redação dada pela EC n. 15/96, fixa as regras para a **criação, incorporação, fusão e desmembramento** de Municípios, nos seguintes termos e obedecendo às seguintes etapas:

■ **lei complementar federal:** determinará o período para a mencionada criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, bem como o procedimento (cf. ADI 2.702);

■ **estudo de viabilidade municipal:** deverá ser apresentado, publicado e divulgado, na forma da lei, estudo demonstrando a viabilidade da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios;

■ **plebiscito:** desde que positivo o estudo de viabilidade, far-se-á consulta às populações dos Municípios envolvidos (de todos os Municípios envolvidos, e não apenas da área a ser desmembrada, como vimos em relação aos Estados-Membros), para aprovarem ou não a criação, incorporação, fusão ou desmembramento. Referido **plebiscito** será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual (art. 5.º da Lei n. 9.709/98);

■ **lei estadual:** dentro do período que a lei complementar federal definir, desde que já tenha havido um estudo de viabilidade e aprovação plebiscitária, serão criados, incorporados, fundidos ou desmembrados Municípios, através de **lei estadual**.

Portanto, o **plebiscito** é **condição de procedibilidade** para o processo legislativo da lei estadual. Se favorável, o legislador estadual terá discricionariedade para aprovar ou rejeitar o projeto de lei de criação do novo Município. Em igual sentido, mesmo que aprovada a lei pelo legislador estadual, o Governador de Estado poderá vetá-la.

Modificando anterior jurisprudência do TSE (MS 1.511/DF, de 05.06.1992), o art. 7.º da Lei n. 9.709/98 dispõe que a consulta plebiscitária deverá ocorrer perante as **populações diretamente interessadas**, tanto a do território que será desmembrado como a do distrito que pretende desmembrar-se.

Finalmente, destacamos o julgamento da **ADI 2.240**, na qual se discutiram as regras do art. 18, § 4.º, especialmente a **necessidade de LC federal** determinando o período de criação de novos Municípios.

REDAÇÃO ORIGINAL (1988)	REDAÇÃO DADA PELA EC N. 15/96
■ Art. 18, § 4.º: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.	■ Art. 18, § 4.º: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Pelo que se percebe da leitura comparativa do texto do art. 18, § 4.º, a **EC n. 15/96** estabeleceu outros requisitos para a criação de novos Municípios, dificultando-a. Essa, por sinal, era a intenção do constituinte reformador, buscando evitar o surgimento desenfreado de novos Municípios e sob o controle exclusivo (na redação original) da LC *estadual*.

Aliás, como já estudamos no *item 6.7.1.9*, nessa linha, entendeu o STF que o art. 18, § 4.º, na redação trazida pela EC n. 15/96, é **norma de eficácia limitada** e, por isso, toda lei estadual que criar Município sem a existência da lei complementar federal estará eivada de inconstitucionalidade. Trata-se de **vício formal por violação a um dos pressupostos objetivos do ato**.⁵²

Por isso, reconhecendo a *inertia deliberandi* do Congresso Nacional em apreciar os vários projetos de LC que tramitavam (e vejam que, à época do julgamento, já se fazia mais de 15 anos que a regra havia sido estabelecida

pela EC n. 15/96), no julgamento da **ADO 3.682**, o STF, fazendo um **apelo** ao legislador, fixou o prazo de 18 meses para que o art. 18, § 4.º, CF/88, fosse regulamentado (*vide item 6.7.4.9*).

Por consequência, nas várias ADIs julgadas,⁵³ o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que criaram Municípios sem a existência da LC federal, mas não pronunciou a nulidade dos atos, mantendo a vigência por mais 24 meses (**efeito prospectivo** ou para o futuro).

Buscando regularizar a situação de vários Municípios, o Congresso Nacional promulgou a **EC n. 57, de 18.12.2008**, acrescentando o **art. 96 ao ADCT**, com a seguinte redação: “ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação”.

Chegamos a fazer críticas firmes à nova emenda, em nosso entender, não apenas **inconstitucional** como, acima de tudo, **imoral**.

Todavia, em determinado caso concreto, o STF acabou aceitando os seus termos:

“EMENTA: Criação do Município de Pinto Bandeira/RS. **Ação julgada prejudicada pela edição superveniente da EC 57/2008**. Alegação de contrariedade à EC 15/96 (...). Com o advento da EC 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, **atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação**. A Lei 11.375/99 foi publicada nos termos do art. 9.º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela EC 20/97, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada” (**ADI 2.381-AgR**, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2011, Plenário, *DJE* de 11.04.2011. Nesse sentido, cf. **ADPF 819**, j. 09.10.2023, *DJE* de 09.01.2024).

Apesar desse precedente, devemos alertar que não se extinguiu a necessidade da existência de **lei complementar federal** que regularize o processo de formação dos Municípios. A referida emenda apenas “validou” a criação (inconstitucional — e aí a nossa crítica) dos novos Municípios estabelecidos sem a existência da referida LC federal.

Por esse motivo, não há dúvida de que, se eventual Município vier a ser criado após 31.12.2006 e ainda não tiver sido editada a LC federal prevista no art. 18, § 4.º, também estaremos diante de vício formal de inconstitucionalidade (esse, aliás, tem sido o entendimento do STF: cf. **ADI 4.992**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.09.2014, Plenário, *DJE* de 13.11.2014).

Nesse sentido, a Corte fixou a seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4.º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 15/96” (**ADI 4.711**, j. 08.09.2021, *DJE* de 16.09.2021).

Por sua vez, em relação aos Municípios que foram **criados até 31.12.2006**, o STF vem determinando não apenas que a referida **data** seja observada, como também a **necessidade de realização de plebiscito**, pois, ao se determinar a observância dos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação (art. 96, ADCT), pressupõe-se que “as legislações estaduais para serem constitucionalmente válidas deveriam conter a previsão do plebiscito já estabelecida pela Constituição desde a redação originária do art. 18, § 4.º” (cf. **RE 1.171.699**, Pleno, j. 29.11.2019 — cf. ADI 2.921).

Nesse sentido, destacamos a tese para o *tema 559* da repercussão geral: “**a EC n. 57/2008 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária** e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados” (**RE 614.384**, Pleno, j. 02.05.2022, *DJE* de 16.05.2022).

Finalmente, devemos deixar anotado que, apesar de o Congresso Nacional ter aprovado em mais de uma oportunidade projetos de leis complementares disciplinando a matéria, estes foram vetados pela então Presidente da República Dilma Rousseff. O último, nos mesmos termos de veto anterior, de acordo com a Mensagem n. 250/2014, teve por fundamento o dito **interesse público**: “depreende-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja a correspondente geração de novas receitas”.

■ 7.6.2. Competências dos Municípios

■ 7.6.2.1. *Competências não legislativas (administrativas ou materiais)*

■ **comum (cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela)**: trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23, CF/88;

■ **privativa (enumerada)**: art. 30, III a IX — assim definida: “Art. 30. Compete aos Municípios: ... III — instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV — criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI — manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental (redação dada pela EC n. 53/2006); VII — prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII — promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX — promover a proteção do patrimônio

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.

■ 7.6.2.2. *Competências legislativas*

■ **expressa:** art. 29, *caput* — qual seja, como vimos, a capacidade de auto-organização dos Municípios, através de **lei orgânica**;

■ **interesse local:** art. 30, I — o interesse local diz respeito às peculiaridades e necessidades ínsitas à localidade. Michel Temer observa que a expressão “interesse local”, doutrinariamente, assume o mesmo significado da expressão “peculiar interesse”, expressa na Constituição de 1967. E completa: “Peculiar interesse significa interesse predominante”,⁵⁴

■ **suplementar:** art. 30, II — estabelece competir aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. “No que couber” norteia a atuação municipal, balizando-a dentro do **interesse local**. Observar ainda que tal competência se aplica, também, às matérias do art. 24, suplementando as normas gerais e específicas, juntamente com outras que digam respeito ao peculiar interesse daquela localidade;

■ **plano diretor:** art. 182, § 1.º — o plano diretor deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório para cidades com **mais de vinte mil habitantes**. Serve como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana;⁵⁵

■ **competência tributária expressa:** art. 156 (estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.6.2.3. *Competência municipal para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição*

Conforme já estudamos, o STF analisou a competência municipal para legislar sobre a **proibição de queimada em canaviais** (RE 586.224).

No precedente em análise, de maneira inovadora, a Corte, por unanimidade, “firmou a tese de que **o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)**” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, Plenário, *DJE* de 08.05.2015 — cf. *item 7.4.3.4*).

Em igual perspectiva, o STF, em momento seguinte, entendeu a legitimidade e constitucionalidade de legislação municipal com base na qual se aplicam multas por poluição do meio ambiente, decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores no perímetro urbano (RE 194.704, Rel. Orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2017, Plenário, *DJE* de 17.11.2017).

Conforme informado, “no mérito, o Plenário considerou que as expressões ‘interesse local’, do art. 30, I, da Constituição Federal (CF), e ‘peculiar interesse’, das Constituições anteriores, se equivalem e **não significam interesse exclusivo do Município**, mas **preponderante**. Assim, a matéria é de competência concorrente (CF, art. 24, VI), sobre a qual a União expede normas gerais. Os Estados e o Distrito Federal editam normas suplementares e, na ausência de lei federal sobre normas gerais, editam normas para atender a suas peculiaridades. Por sua vez, os Municípios, com base no art. 30, I e II, da CF, legislam naquilo que for de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no que couber” (*Inf. 870/STF* — cf., também, *item 7.4.3.4* deste nosso estudo).

■ 7.7. DISTRITO FEDERAL

■ 7.7.1. Histórico

O **Distrito Federal** surge da transformação do antigo **Município neutro** (sede da Corte e Capital do Império), nos termos do art. 2.º, Constituição de 1891, passando a ser a Capital da União, mantida a sede na cidade do Rio de Janeiro.

Nesse momento de sua instituição não se podia considerá-lo como entidade federada autônoma, mas simples autarquia territorial.

De acordo com o art. 3.º e parágrafo único, Constituição de 1891 (regra essa mantida nos textos seguintes), ficou pertencendo à União, no **Planalto Central** da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que seria oportunamente **demarcada** para nela estabelecer-se a **futura Capital federal**. Efetuada a mudança da Capital, concretizando-se os compromissos de **interiorização do País**, o Distrito Federal, que se localizava na cidade do Rio de Janeiro, passaria a constituir um Estado.

Cumprindo o “Plano de Metas” (“50 anos em 5”), *Juscelino Kubitschek*, além de importantes realizações econômicas, implementou a construção de **Brasília**, inaugurada em **21 de abril de 1960**. Nessa data, conforme mandamento constitucional, o então Distrito Federal foi transformado no **Estado da Guanabara**, com os mesmos limites geográficos da cidade do Rio de Janeiro, a capital e sede do novo Estado (cf. **Lei n. 3.752/60**).

A título de curiosidade, o Estado da Guanabara **não foi dividido em municípios**, decisão essa que encontrou apoio popular no **plebiscito** realizado em 21 de abril de 1963, além de ter **curta duração** (1960-1975). Por força do art. 8.º da **LC n. 20/74**, a partir de 15.03.1975, os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara incorporaram-se entre si (processo de **fusão**), passando a constituir um único Estado, sob a denominação de **Estado do Rio de Janeiro**, sendo a cidade do Rio de Janeiro a Capital.

Com a Constituição de 1988, de acordo com o art. 18, § 1.º, a Capital Federal passa a ser **Brasília**, situada no território do Distrito Federal, que, no novo modelo, ainda localizado no Planalto Central do Brasil, deixa de ser mera autarquia territorial, tornando-se **ente federativo**, com autonomia parcialmente tutelada pela União, conforme estudaremos.

Brasília, por sua vez, nos termos do art. 6.º da Lei Orgânica do DF, além de ser a Capital da República Federativa do Brasil e sede do governo federal, é, também, **sede do governo do Distrito Federal**.

■ 7.7.2. Distrito Federal como unidade federada

O Distrito Federal é, portanto, uma unidade federada **autônoma**, visto que possui capacidade de **auto-organização**, **autogoverno**, **autoadministração** e **autolegislação**:

■ **auto-organização**: art. 32, *caput* — estabelece que o Distrito Federal se regerá por **lei orgânica**, votada em **dois turnos** com interstício mínimo de **dez dias** e aprovada por **dois terços** da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal;

Muito embora a aprovação da Lei Orgânica do DF tenha que observar o *quorum* de 2/3 (em razão de explícita previsão constitucional), a sua alteração (reforma) não poderá se dar por esse *quorum* mais rígido. Tendo em vista o **princípio da simetria**, o *quorum* de reforma deverá ser de **3/5**, conforme previsto para alteração da Constituição Federal — art. 60, § 2.º, CF/88. Ou seja, o “arquétipo federal” deverá ser observado. Isso porque, decidiu o STF, “as normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional são de observância obrigatória pelos estados-membros” e, portanto, em razão da aproximação constitucional, deverão ser observadas também pelo Distrito Federal (**ADI 7.205**, j. 16.12.2022, *DJE* de 20.04.2023).

■ **autogoverno:** art. 32, §§ 2.º e 3.º — eleição de Governador e Vice-Governador e dos Deputados Distritais;

■ **autoadministração e autolegislação:** regras de competências legislativas e não legislativas, que serão abaixo estudadas.

■ 7.7.3. Outras características importantes

Algumas outras regras devem também ser lembradas:

■ **impossibilidade de divisão do Distrito Federal em Municípios:** o art. 32, *caput*, expressamente, veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, ao contrário do que acontece com os Estados e Territórios;

■ **autonomia parcialmente tutelada pela União:**⁵⁶ a) o art. 32, § 4.º, declara inexistirem polícia civil, polícia penal, polícia militar e corpo de bombeiros militar, pertencentes ao Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6.º), são organizadas e mantidas diretamente pela **União** (art. 21, XIV, na redação dada pela **EC n. 104/2019**, que alterou a Constituição Federal para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital), sendo que a referida utilização pelo Distrito Federal será regulada por lei federal (cf. **SV 39/STF** e capítulo sobre *segurança pública*, item 13.7.7); b) também observar que o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios são organizados e mantidos pela União (arts. 21, XIII, e 22, XVII);

■ **EC n. 69/2012:** na mesma linha da *Reforma do Poder Judiciário* (EC n. 45/2004), que assegurou às *Defensorias Públicas Estaduais* autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária (dentro dos limites constitucionais), com atraso de 8 anos, a **EC n. 69/2012 transferiu** da **União** para o **DF** as atribuições de **organizar** e **manter** a **Defensoria Pública do Distrito Federal**, determinando a aplicação dos mesmos princípios e regras que, nos

termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.

A **Lei n. 10.633/2002** instituiu o **Fundo Constitucional do Distrito Federal — FCDF**, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal (**EC n. 104/2019**), da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do DF, bem como a assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, consoante disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal (cf., ainda, art. 25, EC n. 19/98).

Conforme bem entendeu o STF, na medida em que os recursos destinados ao referido FCDF pertencem aos **cofres federais** (Tesouro Nacional), “a competência para fiscalizar a aplicação dos recursos da União repassados ao FCDF é do **Tribunal de Contas da União — TCU**” e não do Tribunal de Contas do Distrito Federal (**MS 28.584 AgR**, 2.^a T., j. 28.10.2019, *DJE* de 18.11.2019). Esse entendimento segue a mesma lógica do estabelecido pelo Plenário em relação aos **recursos financeiros** oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados aos Estados e Municípios, que, por serem **federais**, são também controlados pelo **TCU** (**ADI 1.934**, j. 07.02.2019).

Nessa linha, entendeu o STF, ainda, que, “ao instituir a chamada ‘gratificação por risco de vida’ dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, o **Poder Legislativo distrital usurpou a competência material da União** para ‘organizar e manter a polícia civil, a polícia penal [EC n. 104/2019 — acrescente-se], a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio’ (inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal). Incidência da Súmula 647 do STF” (**ADI 3.791**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16.06.2010, Plenário, *DJE* de 27.08.2010. Observa-se que a S. 647/STF foi convertida na **SV 39/STF**).

■ 7.7.4. Competências do Distrito Federal

■ 7.7.4.1. *Competências não legislativas (administrativas ou materiais)*

■ **comum (cumulativa ou paralela):** trata-se de competência não legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23, CF/88.

■ 7.7.4.2. *Competências legislativas*

O art. 32, § 1.º, prescreve que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. Assim, tudo o que foi dito a respeito dos Estados aplica-se ao Distrito Federal, bem como o que foi dito sobre os Municípios no tocante à competência para legislar também a ele se aplica.

■ **expressa:** art. 32, *caput* — elaboração da própria lei orgânica;

■ **residual:** art. 25, § 1.º — toda competência que não for vedada, ao Distrito Federal estará reservada;

■ **delegada:** art. 22, parágrafo único — como vimos, a União poderá autorizar o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa. Tal autorização dar-se-á mediante **lei complementar**;

■ **concorrente:** art. 24 — em que se estabelece concorrência para legislar entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo à União legislar sobre normas gerais e ao Distrito Federal, sobre normas específicas;

■ **suplementar:** art. 24, §§ 1.º a 4.º — no âmbito da legislação concorrente, como vimos, a União limita-se a fixar normas gerais e o Distrito Federal, normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, o Distrito Federal poderá **suplementá-la** e regulamentar as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência de lei federal sobre norma geral, a aludida norma distrital geral (suplementar) terá a sua eficácia suspensa, no que for contrária à lei federal sobre normas gerais editadas posteriormente;⁵⁷

- **interesse local:** art. 30, I, combinado com o art. 32, § 1.º;
- **competência tributária expressa:** art. 147, parte final, c/c os arts. 156 e 155 (a estudar especialmente em direito tributário).

■ 7.8. TERRITÓRIOS FEDERAIS

■ 7.8.1. Histórico

Apesar de a primeira Constituição a tratar sobre Territórios ter sido a de 1934, foi na vigência da de 1891 que se estabeleceu o primeiro Território Federal no Brasil, qual seja, o do **Acre**,⁵⁸ adquirido pelo Brasil pelo **Tratado de Petrópolis**, assinado em **17.11.1903** com a República da Bolívia e pelo qual se celebrou **permuta de territórios** (destacando que apenas em 08.09.1909 é que se pacificou a controvérsia em relação à fronteira com o Peru — cf. art. VIII do Estatuto).

De acordo com o art. III do referido Tratado, “por não haver equivalência nas áreas dos territórios permutados entre as duas Nações, os Estados Unidos do Brasil **pagarão uma indenização** de 2.000.000 (dois milhões de libras esterlinas), que a República da Bolívia aceita com o propósito de aplicar principalmente na construção de caminhos de ferro ou em outras obras tendentes a melhorar as comunicações e desenvolver o comércio entre os dois países”.

O *Território do Acre* foi organizado pelo **Decreto n. 5.188, de 07.04.1904**, tendo em vista a autorização concedida pelo Decreto Legislativo n. 1.181, de 25 de fevereiro do mesmo ano, e assim permaneceu até a edição da **Lei n. 4.070/62**, sancionada pelo Presidente da República João Goulart, que o **elevou** à categoria de **Estado**.

Posteriormente, sob o fundamento do art. 6.º da Carta de 1937 — “a União poderá criar, no **interesse da defesa nacional**, com partes desmembradas dos Estados, **Territórios Federais**, cuja administração será regulada em lei especial” — e durante a **2.ª Grande Guerra**, Getúlio Vargas, pelos **Decretos-lei ns. 4.102/42** e **5.812/43**, criou, com partes **desmembradas** dos Estados do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina, os seguintes Territórios Federais:

Fernando de Noronha: extinto nos termos do art. 15, ADCT, CF/88, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. Atualmente, conforme estudaremos a seguir, o arquipélago é um distrito estadual;

Amapá: transformado no **Estado do Amapá** pelo art. 14, ADCT, CF/88, mantidos seus limites geográficos;

Rio Branco: a Lei n. 4.182/62 passou a denominá-lo *Território Federal de Roraima*. Foi transformado no **Estado de Roraima** pelo art. 14, ADCT, CF/88, mantidos seus limites geográficos;

Guaporé: a Lei n. 2.731/56, em homenagem ao sertanista *Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon*, mudou a denominação do *Território Federal do Guaporé* para **Território Federal de Rondônia**. A **LC n. 41/81**, por sua vez, criou o **Estado de Rondônia**, mediante a elevação do então Território Federal, mantidos os seus limites e confrontações;

Ponta Porã: o art. 8.º, ADCT, da Constituição de 1946 determinou a sua reincorporação ao então Estado de Mato Grosso. Atualmente, a área encontra-se no *Estado de Mato Grosso do Sul* (criado por desmembramento de Mato Grosso pela LC n. 31/77);

Iguaçu: o art. 8.º, ADCT, da Constituição de 1946 determinou a sua reincorporação aos Estados do Paraná e de Santa Catarina.

■ 7.8.2. Natureza jurídica

Apesar de ter personalidade, o território **não é dotado de autonomia política**. Trata-se de mera **descentralização administrativo-territorial da União**, qual seja, uma **autarquia** que, consoante expressamente previsto no art. 18, § 2.º, **integra a União**.

■ 7.8.3. Ainda existem territórios no Brasil?

NÃO.

Conforme estudamos, até o advento da Constituição de 1988 havia três territórios: **Roraima, Amapá e Fernando de Noronha**:

■ **Roraima:** foi transformado em Estado, de acordo com o art. 14, *caput*, ADCT;

■ **Amapá:** também foi transformado em Estado, de acordo com o art. 14, *caput*, ADCT;

■ **Fernando de Noronha:** foi extinto, sendo a sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco (art. 15, ADCT, CF/88).

■ 7.8.4. Mas, afinal de contas, o que é Fernando de Noronha?

Dizer, nos termos do art. 15, ADCT, que sua área foi reincorporada ao Estado de Pernambuco não é suficiente. Então, expliquemos melhor a matéria.

De acordo com o art. 96, CE/PE, o Arquipélago de Fernando de Noronha constitui *região geoeconômica, social e cultural do Estado de Pernambuco*, sob a forma de *Distrito Estadual, dotado de estatuto próprio, com autonomia administrativa e financeira*.

Já o parágrafo único do art. 1.º da Lei estadual n. 11.304, de 28.12.1995 (do Estado de Pernambuco), caracteriza o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha** como uma *entidade autárquica integrante do Poder Executivo Estadual, exercendo, sobre toda a extensão da área territorial do Arquipélago de Fernando de Noronha, jurisdição plena atribuída às competências estadual e municipal, bem como os poderes administrativos e de polícia próprios de ente público*.

O Distrito Estadual tem por **sede** o Palácio São Miguel, situado na Vila dos Remédios, na Ilha de Fernando de Noronha, e por **foro** a Comarca do Recife, tendo por competência prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar da população insular.

O § 1.º do art. 96, CE/PE, determina que o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha** será dirigido por um **Administrador-Geral, nomeado** pelo Governador do Estado, com **prévia aprovação da Assembleia Legislativa**, e o § 2.º estabelece a **eleição direta**, pelo voto secreto, concomitantemente com a eleição de Governador de Estado, pelos

cidadãos residentes no Arquipélago, de **7 Conselheiros**, com mandato de **4 anos**, para formação do **Conselho Distrital**, órgão que terá funções consultivas e de fiscalização, na forma da lei.

Muito embora Fernando de Noronha atualmente seja um **Distrito Estadual**, o § 3.º do art. 96, CE/PE, prevê a sua transformação em Município quando alcançar os requisitos e as exigências mínimas, previstos em lei complementar estadual.

■ 7.8.5. **Apesar de não existirem, podem vir a ser criados novos territórios?**

SIM.

Como vimos, o Poder Constituinte de 1988 transformou dois territórios em Estados e extinguiu o terceiro, ainda existentes em 1988.

Apesar disso, é **perfeitamente possível a criação de novos territórios federais**, que, com certeza, continuarão a ser mera autarquia, sem qualquer autonomia capaz de lhes atribuir a característica de entes federados. O processo de criação dar-se-á da seguinte forma:

■ **lei complementar:** a criação de novos territórios dar-se-á mediante **lei complementar**, conforme o art. 18, § 2.º;

■ **plebiscito:** deve haver plebiscito aprovando a criação do território;

■ **modo de criação:** o art. 18, § 3.º, dispõe que os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros, ou formar **Territórios Federais**, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por **lei complementar**.

■ 7.8.6. **Outras características importantes sobre Territórios Federais**

Algumas outras regras devem também ser lembradas:

■ **lei federal:** de acordo com o art. 33, *caput*, lei federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios;

■ **divisão em municípios:** ao contrário do que ocorre com o Distrito Federal, o art. 33, § 1.º, prevê a possibilidade de os Territórios, quando criados, serem divididos em Municípios, aos quais serão aplicadas as regras dos arts. 29 a 31, CF/88;

■ **Executivo:** a direção dos Territórios, se criados, dar-se-á por Governador, nomeado pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal (art. 84, XIV);

■ **Legislativo (CN):** nos termos do art. 45, § 2.º, cada Território elegerá o número fixo de **4 deputados federais**, caracterizando-se, assim, exceção ao princípio proporcional para a eleição de deputados federais, ou seja, não existirá variação do número de representantes da população local dos Territórios;

■ **controle das contas:** a fiscalização das contas do governo do Território caberá ao Congresso Nacional, após o parecer prévio do Tribunal de Contas da União (art. 33, § 2.º);

■ **Judiciário, Ministério Público e defensores públicos federais:** nos Territórios Federais com mais de 100 mil habitantes, além do Governador nomeado na forma da Constituição (art. 84, XIV), haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, organizados e mantidos pela União (art. 33, § 3.º, c/c o art. 21, XIII). Ainda, nos termos do parágrafo único do art. 110, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais (Justiça Federal Comum) caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei;

■ **Polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar dos Territórios federais:** muito embora os Territórios sejam uma descentralização administrativa da União, integrando-a, a EC n. 19/98, alterando a redação do art. 21, XIV, CF/88, situação essa inalterada pela EC n. 104/2019 (polícias penais), não mais atribuiu à União a organização e manutenção da polícia civil, militar e do corpo de

bombeiros dos Territórios, endereçando referida regra **exclusivamente** ao Distrito Federal;

■ **Legislativo:** a lei disporá sobre as eleições para a **Câmara Territorial** e sua competência deliberativa (art. 33, § 3.º);

■ **Sistema de ensino:** organizado pela União, nos termos do art. 211, § 1.º.

■ 7.9. MODELOS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Constituição fixa, de maneira clara, a **repartição de competências** entre os entes federativos, que, conforme visto, são autônomos cada qual dentro de sua parcela de atribuições e capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação (com as especificidades já apontadas, sobretudo em relação ao DF, cuja autonomia é parcialmente tutelada pela União).

As **atribuições** estão estabelecidas pelo constituinte originário e, em tese, poderiam ser objeto de modificação (por emenda), desde que a novidade, a ser introduzida, não violasse a forma federativa de Estado, bem como as demais cláusulas pétreas.

Portanto, teoricamente, para se ter um exemplo, seria possível que determinada emenda transferisse a competência para legislar sobre direito penal, que hoje é reservada à União (art. 22, I), para os Estados, apesar de críticas que possam surgir nesse sentido. Parece-nos que, no exemplo citado, haveria, inclusive, fortalecimento da autonomia federativa estadual. A questão fica, então, dentro de um campo de conveniência política.

Pois bem, essa repartição de competências dá-se de acordo com alguns **modelos**, segundo a doutrina.

■ 7.9.1. Modelo clássico e modelo moderno

No **direito comparado** houve a formulação tanto de um modelo **clássico** como de um modelo **moderno**, tendo como parâmetro a enumeração ou não das atribuições. Vamos a eles.

■ 7.9.1.1. *Modelo clássico*

O **modelo clássico** busca a sua fonte na *Constituição norte-americana de 1787*, refletindo aspirações do final do século XVIII.

Conforme esse modelo, compete à **União** exercer os poderes **enumerados** e aos **Estados**, os poderes não especificados, em um campo **residual**.

Como bem anota Paulo Branco,⁵⁹ o rigorismo da enunciação taxativa é flexibilizado pela **doutrina dos poderes implícitos**.

Isso porque, nas palavras de Raul Machado Horta, “o sentido premonitório do Constituinte de Filadélfia resguardou o desenvolvimento dos poderes enumerados quando reconheceu expressamente ao Congresso a competência ‘para elaborar todas as leis necessárias e adequadas ao exercício dos poderes especificados e dos demais poderes conferidos por esta Constituição ao governo dos Estados Unidos ou aos seus departamentos ou funcionários’ (...) a famosa cláusula dos **poderes implícitos**, que na Corte Suprema Norte-Americana converteu no fundamento de dilatadora construção constitucional na via judicial”.⁶⁰

■ 7.9.1.2. **Modelo moderno**

O **modelo moderno**, por sua vez, passou a ser verificado após a Primeira Guerra Mundial, estando descritas nas Constituições não somente as atribuições exclusivas da União, como, também, as hipóteses de competência comum ou concorrente entre a União e os Estados.

Para Paulo Branco, “o chamado *modelo moderno* responde às contingências da crescente complexidade da vida social, exigindo ação **dirigente** e **unificada** do Estado, em especial para enfrentar as crises sociais e guerras”.⁶¹

■ 7.9.2. **Modelo horizontal e modelo vertical**

Outra classificação, segundo a doutrina, leva em conta não a enumeração das atribuições, mas, partindo delas, se haverá ou não condomínio entre os entes federativos para a sua realização e, assim, vislumbrando tanto um modelo *horizontal* como um modelo *vertical*.

■ 7.9.2.1. *Modelo horizontal*

No **modelo horizontal** não se verifica concorrência entre os entes federativos. Cada qual exerce a sua atribuição nos limites fixados pela Constituição e **sem relação de subordinação**, nem mesmo hierárquica.

Ensina Paulo Branco que “esse modelo apresenta três soluções possíveis para o desafio da distribuição de poderes entre órbitas do Estado Federal. **Uma delas** efetua a enumeração exaustiva da competência de cada esfera da Federação; **outra**, discrimina a competência da União deixando aos Estados-membros os poderes reservados (ou não enumerados); a **última** discrimina os poderes dos Estados-membros, deixando o que restar para a União”.⁶²

No **Brasil**, predomina o **modelo horizontal**, nos termos dos arts. 21, 22, 23, 25 e 30.

■ 7.9.2.2. *Modelo vertical*

No **modelo vertical**, por sua vez, a mesma matéria é **partilhada** entre os diferentes entes federativos, havendo, contudo, certa relação de subordinação no que tange à atuação deles.

Em se tratando de competência legislativa, **geralmente** a **União** fica com **normas gerais** e **princípios**, enquanto os **Estados**, completando-as, legislam para atender às suas **peculiaridades**, tratando de matérias de **interesse regional**. Os **Municípios**, por sua vez, legislam sobre **interesse local**.

O modelo vertical pode ser caracterizado, na lição de Paulo Branco, como uma técnica que estabelece “um verdadeiro **condomínio legislativo** entre a União e os Estados-membros”.⁶³

Como exemplo de modelo vertical, no Brasil, podemos citar as matérias de **competência concorrente** entre a União, os Estados e o Distrito Federal, estabelecidas no art. 24, CF/88.

Vimos que, no âmbito da **competência legislativa concorrente**, a União limita-se a estabelecer normas gerais e os Estados, normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, os Estados poderão suplementá-la, regulamentando as regras gerais sobre o assunto. O exemplo do amianto, analisado no *item 7.11.1*, é bastante interessante para a compreensão dessa regra constitucional.

Finalmente, constata-se que no **modelo vertical** há uma maior **aproximação** entre os entes federativos, que deverão atuar em complemento, em **“condomínio legislativo”**. Já no **modelo horizontal**, parece haver um maior afastamento, na medida em que a distribuição de competência se mostra bastante **rígida** e sem interferência de um sobre outro.

■ 7.10. QUADRO ILUSTRATIVO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL — ALGUNS PRECEDENTES DO STF

O objetivo desta parte do estudo é indicar algumas interpretações fixadas pelo STF em relação ao modelo constitucional de repartição de competências.

Não se pode falar em hierarquia de atos normativos. Existem **campos de atribuição**, definidos pelo constituinte originário. Não se pode afirmar, por exemplo, que a lei municipal é hierarquicamente inferior a certa lei federal. No fundo, o que se tem são campos de atuação e, portanto, se, eventualmente, determinado Município legisla sobre assunto de competência da União, o vício não é legislativo (entre as leis), mas, em essência, **constitucional**, ou seja, em relação à competência federativa para legislar sobre aquele assunto.

Por esse motivo é que, de maneira coerente, a EC n. 45/2004 estabeleceu que cabe **recurso extraordinário** para o **STF** quando, nos termos do art. 102, III, “d”, se julgar válida lei local contestada em face de lei federal. O **vício** que eventualmente a lei conterà será **formal orgânico**, ou seja, em relação ao ente federativo que deveria legislar sobre aquela matéria (cf. *item 6.3.2.1*).

Para efeito de estudo e preparação para provas e concursos, na medida em que esse tema tem uma incidência muito grande, pedimos seja feita a leitura atenta das interpretações já realizadas pelo STF em relação à competência federativa para legislar. O PDF, que está na plataforma, deve ser lido com muita atenção e cuidado.

■ 7.11. AMIANTO, TABACO E COVID-19 (PANDEMIA)

Resolvemos destacar esses temas pois apresentam ampla discussão teórica no âmbito do STF, podendo servir para um estudo aprofundado.

■ 7.11.1. Amianto

Na tentativa de **proteção à saúde**, várias leis, sejam estaduais, sejam municipais, **proíbiram** o uso do amianto, que é utilizado em alguns produtos, como nas tubulações, telhas, caixas-d'água, mangueiras, papéis, papelões etc.

O problema é que o art. 2.º da **Lei federal n. 9.055/95** (Dec. n. 2.350/97) **admitia** o seu **uso controlado**, limitando-o à variedade *crisotila* (asbesto branco).

Dessa forma, o que se sustentava é que as leis estaduais e municipais que proibiam o amianto sem qualquer exceção estariam violando a **regra geral** da lei federal que o admitia, por se tratar de matéria de competência concorrente e, assim, a violar o disposto no art. 24, §§ 1.º ao 4.º.

Algumas ações, **inicialmente**, foram julgadas procedentes, declarando a **inconstitucionalidade formal orgânica** das leis estaduais ou municipais, sob o argumento de que referidos entes federativos não poderiam violar a regra geral já estabelecida pela lei federal. Vamos a elas:

■ **ADI 2.396** — 08.05.2003: o STF entendeu que o Estado de Mato Grosso do Sul não poderia proibir o uso do amianto (Lei estadual n. 2.210/2001), já que a competência para legislar sobre o assunto é **concorrente** e existe a lei federal admitindo-o — art. 24, V, VI e XII, CF;

■ **ADI 2.656** — 08.05.2003: no mesmo sentido, a Suprema Corte entendeu que a lei paulista (Lei n. 10.813/2001) não poderia ter disciplinado o assunto, violando tanto os citados incisos do art. 24 como, ainda, os arts. 20, IX, e 22, VIII e XII;

Essas **vinham sendo** as decisões do STF, a maioria no sentido de se tratar de competência concorrente (art. 24, V — produção e consumo; VI — meio ambiente e poluição; XII — proteção e defesa da saúde).

Assim, teoricamente, conforme decidiu a Corte, havendo a lei federal, os Estados só poderiam legislar suplementando-a, porém, nunca contrariando ou negando o dispositivo. Se a lei federal admite de modo restrito o uso do amianto, teoricamente, a lei estadual ou municipal não poderia proibi-lo totalmente.

Algumas decisões lembraram o art. 20, IX (os recursos minerais como bens da União), e a **competência privativa** da União para legislar sobre comércio interestadual (art. 22, VIII) e sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII).

Conforme já estudamos no *capítulo* 6, a declaração de inconstitucionalidade proferida em controle concentrado **não atinge o Poder Legislativo** na sua função típica de legislar (sob pena de “fossilização” da Constituição, cf. *item* 6.7.1.8). Desta forma, este poderá editar uma lei com conteúdo idêntico àquela que já fora objeto de ADI. Diante desse entendimento, **vários Estados e alguns municípios editaram leis proibindo, mais uma vez, o uso do amianto**. Em face dessas leis, novas ações de controle foram ajuizadas. Vejamos:

■ **ADI 3.356** — ajuizada em 30.11.2004, tem por objeto a Lei n. 12.589/2004, do Estado de Pernambuco, que proibiu o amianto;

■ **ADI 3.357** — ajuizada em 30.11.2004, tem por objeto a Lei n. 11.643/2001, do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu o amianto;

■ **ADI 3.406** — ajuizada em 11.02.2005, tem por objeto a Lei n. 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, que proibiu a extração do asbesto/amianto em todo território daquela unidade da federação, estabelecendo, ainda, a progressiva substituição da produção e da comercialização de produtos que contivessem amianto;

■ **ADI 3.470** — ajuizada em 15.04.2005, tendo o mesmo objeto da ADI 3.406 e, por isso, distribuída por prevenção;

ADI 3.937 — ajuizada em 06.08.2007, tem por objeto a Lei n. 12.684/2007, do Estado de São Paulo, que proibiu o amianto;

■ **ADPF 109** — ajuizada em 10.04.2007, tem por objeto a Lei n. 13.113/2001 e o Decreto n. 41.788/2002, ambos do Município de São Paulo, que proibiu a utilização do amianto na construção civil.

O **STF**, novamente provocado para a análise dos atos normativos estaduais, muito embora naquele momento pendente a apreciação da lei federal, já que ainda não havia sido julgada a **ADI 4.066**, sinalizava uma inegável mudança de entendimento em relação ao tema, passando a admitir a sua proibição por leis estaduais e municipais.

No sentido da constitucionalidade das legislações mais protetivas que proíbem o amianto, alguns argumentos eram sustentados:

■ **Convenção 162 da OIT**: assinada pelo Brasil, recomenda a não pulverização do amianto, desestimulando o seu uso. Por ter, segundo interpretou o STF, natureza **supralegal** (destacando-se o *princípio da prevalência dos direitos humanos*, **art. 4.º, II, CF/88** — cf. *item 9.14.5.2.3*), paralisaria a eficácia da lei federal, permitindo, então, que o Estado legislasse de modo pleno (**art. 24, § 3.º, CF/88**);

■ **preceito constitucional do direito à saúde**: alguns Ministros concluíram que a utilização do amianto traz riscos à saúde (sustentando, inclusive, o risco de câncer), e, assim, apesar de haver lei federal admitindo o seu uso controlado, a lei estadual seria mais protetiva e, portanto, em uma ponderação de interesses, prevaleceria a proteção à saúde (**arts. 196 e 6.º, caput, CF/88**). Nesse sentido, o **art. 7.º, XXII, CF/88**, estabelece ser direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

■ **princípios gerais da atividade econômica (consumidor e meio ambiente)**: as legislações estaduais, mais protetivas, dentro da ideia de ponderação, amoldam-se melhor aos *princípios da defesa do consumidor* e do *meio ambiente* (**art. 170, V e VI, CF/88**);

■ **meio ambiente ecologicamente equilibrado:** nos termos do art. 225, *caput*, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cabe lembrar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado integra o **desenvolvimento nacional** (art. 3.º, II). Dessa forma, a legislação que proíbe a utilização de amianto se conforma melhor à Constituição.

O Min. Ayres Britto, em voto proferido sobre o tema, chegou a sustentar essa perspectiva: “lei estadual que, ao proibir a comercialização de produtos à base de amianto, cumpre muito mais a Constituição da República no plano da proteção da saúde (evitar riscos à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente). Quero dizer: **a legislação estadual é que está muito mais próxima do sumo princípio da eficácia máxima da Constituição em tema de direitos fundamentais**. Tão mais próxima da Convenção da OIT, acresça-se, quanto o diploma federal dela se distancia” (voto proferido nas ADIs 3.937 e 3.357, em 31.10.2012).

Em 23.11.2016, em julgamento conjunto de todas as ações citadas (ADIs 3.356, 3.357, 3.937 e ADPF 109), o Min. Fachin entendeu possíveis as restrições implementadas pelas leis estaduais e municipal. Ao analisar o **federalismo cooperativo**, sustentou que não se deve apenas considerar a ideia de predominância de interesses, devendo-se observar a **subsidiariedade** e a **proporcionalidade**.

Conforme expressa, “de acordo com a primeira (subsidiariedade), o ente político maior deve deixar para o menor tudo aquilo que este puder fazer com **maior economia e eficácia**. Já de acordo com a segunda (proporcionalidade), é preciso sempre respeitar uma rigorosa **adequação entre meios e fins**. A proporcionalidade poderia ser utilizada, portanto, como teste de razoabilidade para soluções de problemas envolvendo competência de nítida orientação constitucional. O teste de razoabilidade, por sua vez, exigiria o exame das razões que levaram o legislador a adotar determinado regulamento.

Consistiria, portanto, em avaliar se as razões necessárias para a conclusão a que chegou foram levadas em conta ou se optou por motivos que não poderiam ter sido considerados. Interpretando, pois, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade nesses termos, seria possível, então, superar o conteúdo meramente formal do princípio e reconhecer um aspecto material, consubstanciado numa presunção de autonomia em favor dos entes menores (‘presumption against preemption’), para a edição de leis que resguardecem seus interesses” (*Inf. 848/STF*).

Portanto, a permissão estabelecida pela lei federal não impediria a proibição pelos demais entes federativos, já que mais protetiva em termos de proteção à saúde e ao meio ambiente.

Essa perspectiva lançada pelo Min. Fachin, **contudo**, não ficou totalmente definida pelo STF, pois, como se verá, a solução adotada foi mais simples, aplicando-se o art. 24, § 3.º, CF/88, já que se reconheceu a inconstitucionalidade da lei federal. As perspectivas lançadas devem ser acompanhadas em eventuais novos pronunciamentos da Corte, neste enfrentamento entre o âmbito de atuação da lei federal e o “espaço” de atuação dos demais entes federativos.

■ SOLUÇÃO DA QUESTÃO DADA PELO STF

O STF, em 24.08.2017, julgou a **ADI 4.066**, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), tendo por objeto o art. 2.º da Lei Federal n. 9.055/95, que admitia o uso controlado do amianto (variedade crisotila — asbesto branco).

Dentro das perspectivas anteriores, a Min. Relatora, Rosa Weber, propôs a seguinte **tese**: “a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no art. 2.º da Lei n. 9.055/95, é **incompatível** com os arts. 7.º, XXII, 196 e 225 da Constituição Federal”.

Contudo, na medida em que o Tribunal computou 5 votos pela procedência da ação e 4 pela improcedência, e, assim, não se atingiu o *quorum* exigido pelo art. 97 da Constituição (maioria absoluta, ou seja, no

mínimo 6), **deixou de se pronunciar a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 9.055/95, em julgamento destituído de eficácia vinculante** (não votaram os Mins. Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, que se declararam impedidos).

Na mesma data, qual seja, 24.08.2017, o **STF**, analisando a lei do Estado de São Paulo que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto no território estadual, julgou **improcedente** o pedido formulado na **ADI 3.937**, declarando, **incidentalmente**, a **inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 9.055/95**.

O reconhecimento, mesmo que incidental, da inconstitucionalidade da lei federal permitiu a declaração de validade da lei estadual nos termos do art. 24, § 3.º, CF/88 (competência legislativa plena estadual em razão de inexistência de lei federal, nulificada).

Segundo afirmou a Corte, estamos diante de **inconstitucionalidade material superveniente da lei federal**, em razão de processo de inconstitucionalização que se operou nesses 22 anos de sua vigência, tendo em vista a **mudança do substrato fático da norma**. Veja: “a discussão em torno da eventual necessidade de banimento do amianto é diferente da que havia quando da edição da norma geral. Se, antes, tinha-se notícia de possíveis danos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da substância, hoje há consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma segura. Além disso, atualmente, o amianto pode ser substituído por outros materiais (fibras de PVA e PP), sem propriedade carcinogênica e recomendados pela Anvisa” (*Inf. 874/STF*, cf. *item 6.1.5*).

Assim, inexistindo lei federal sobre normas gerais, já que o STF declarou, mesmo que incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n. 9.055/95, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Na medida em que a lei estadual em análise não incide no mesmo vício que a lei federal nulificada, o STF pronunciou a constitucionalidade da lei estadual e, assim, julgou improcedente a ADI.

Naturalmente, se o Congresso Nacional resolver legislar novamente — e isso seria possível, a eventual superveniência de lei federal sobre a matéria suspenderia, em tese, a eficácia da lei estadual, no que lhe fosse contrário, até eventual nova nulificação pela Corte, o que também seria esperado.

Em momento seguinte, ao analisar a Lei estadual n. 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, o STF não apenas manteve o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da lei federal, como, ampliando, deu **efeito vinculante e erga omnes a essa declaração** e, assim, julgou improcedente o pedido formulado na ADI, reconhecendo a constitucionalidade da lei estadual (**ADIs 3.406 e 3.470**, j. 29.11.2017, *DJE* de 1.º.02.2019, tendo sido mantido o entendimento em relação aos efeitos no julgamento dos embargos de declaração, j. 23.02.2023, *DJE* de 02.05.2023).

Em relação a essa técnica interessante de declaração incidental de inconstitucionalidade em processo objetivo, remetemos para o estudo dos *itens* 6.6.5.4 e 6.6.5.5.

No tocante à matéria de fundo, não havendo mais a abertura expressa que o art. 2.º da lei federal estabelecia para uma modalidade específica de amianto (asbesto branco), possibilitou-se aos Estados avançarem a proteção: “ao impor um nível de proteção mínima a ser observado em todos os Estados da Federação, a Lei n. 9.055/95 **não pode ser interpretada como obstáculo à maximização dessa proteção**, conforme escolha dos Estados, individualmente considerados. A proibição progressiva encartada na legislação estadual em apreço está alinhada à diretriz norteadora e à teleologia do regime previsto na Lei nº 9.055/95” (*Inf. 886/STF*).

Finalmente, em relação ao tema do amianto, em 30.11.2017, o STF julgou outras 3 ações. Partindo da premissa de que o art. 2.º da lei federal, que permitia o uso de uma variedade do amianto, era inconstitucional, preservou e manteve todas as leis (dos Estados de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, além da do Município de São Paulo) que proibiam integralmente o seu uso (**ADI 3.356, ADI 3.357 e ADPF 109**).

■ 7.11.2. Tabaco

Quem já não escutou falar de Paris (ou já teve a feliz oportunidade de lá estar), o seu *glamour*, os seus cafés, a sua arte, a sua cultura, o extraordinário Louvre, os impressionistas do *D’Orsay*, a “monstruosa” igreja de *Notre-Dame*, a grandiosidade e a vista da *Sacr  -Couer*, as pra  as, a *Champs-  lys  es* (e o *Arc de Triomphe*), fazer um *picnic* aos p  s da maravilhosa Torre *Eiffel*, o romantismo, o charme dos caf  s. Poder  amos ficar aqui por horas falando sobre a encantadora Paris...⁶⁴

Pois bem, at   Paris “surpreendeu” o mundo ao apresentar ampla aceita  o da lei que proibiu o tabaco em bares, restaurantes, discotecas e cassinos do pa  s a partir de janeiro de 2008.

Nesse sentido, no Brasil, algumas leis, sejam estaduais, sejam municipais, proibiram o uso do tabaco, contrariando a reda  o original da Lei Federal n. 9.294/96, que admitia a cria  o de fum  dromo (cf. [ADI 4.239](#) — n  o se admitiu a legitima  o ativa da Abrasel Nacional; [ADI 4.249](#) — julgada prejudicada conforme explicamos abaixo; e [ADI 4.306](#) — julgada improcedente).

No caso do julgamento da [ADI 4.249](#), a lei estadual, objeto da a  o, trazia regra mais protetiva em rela  o    lei federal que delimitava o assunto, autorizando o **fum  dromo** “em   rea destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente” (art. 2.   da Lei federal n. 9.294/96). A restri  o/prote  o imposta pela legisla  o estadual, sem d  vida, melhor resguardava o **princ  pio de prote  o    sa  de**.

E o que aconteceu?

O art. 2.   da Lei federal n. 9.294/96 foi modificado, passando a n  o mais se permitir o fum  dromo (Lei n. 12.546/2011).

Diante dessa modifica  o, conforme entendeu o Min. Celso de Mello, muito embora pudesse ter a lei estadual tratado do assunto na vig  ncia da reda  o original da Lei n. 9.294/96, a superveni  ncia da Lei federal n. 12.546/2011 cessou a efic  cia da lei estadual objeto da ADI (a Uni  o tratou de regra geral). Assim, sua Excel  ncia, monocraticamente, julgou prejudicada a referida ADI, por perda superveniente de seu objeto (ADI 4.249, j. 03.12.2019).

No julgamento da **ADI 4.306**, o STF resgatou a noção do **federalismo cooperativo** adotada no precedente do amianto. Segundo ficou estabelecido, o federalismo torna-se “um instrumento de descentralização, não para simplesmente distribuir poder político, mas para realizar direitos fundamentais” (fls. 16). Assim, “apenas quando a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que possuem os entes menores (*clear statement rule*), seria possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, certa matéria deve ser disciplinada pelo ente maior” (fls. 17). “Estados, próximos dos dilemas das realidades regionais, exerçam a competência legislativa concorrente a eles atribuída pela Constituição, ou na perspectiva da saúde, ou na perspectiva do consumo”.

Avançando, sob um outro aspecto, a discussão travada no caso do amianto poderá orientar a solução a ser dada para a proibição do fumo (não estamos sustentando uma proibição ao direito individual e isolado de fumar — esse é um outro problema, um caso de saúde pública —, mas em relação ao fumo em lugares públicos, como é o caso das legislações em análise).

Como se sabe, o Brasil é signatário da **Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco** (Dec. n. 5.658/2006), que desestimula o seu uso, o que poderia levar ao entendimento de que essa prescrição teria paralisado a eficácia da lei federal se menos restritiva, no sentido da sua natureza de **supralegalidade**. Inexistindo lei federal sobre norma geral, já que a questão envolvendo o fumo, assim como a problemática do amianto, é de competência concorrente (art. 24, V, VI e XII), os Estados exerceriam a sua competência legislativa plena (art. 24, § 3.º, CF/88), de maneira muito mais drástica.

Lembramos, ainda, que o **tabagismo** caracteriza-se, na atualidade, como a **principal causa de morte evitável** e, portanto, indiscutível o **dever** de todos os entes federativos de proteger a saúde e, assim, combater o fumo, que, quando consumido, introduz no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, destacando-se a **nicotina** (responsável pela combatida e famigerada dependência química), o **monóxido de carbono** (gás) e o **alcatrão** (que

contém substâncias pré-cancerígenas), sem contar a problemática do **fumante passivo**.

■ 7.11.3. Covid-19 — medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia e as perspectivas trazidas pelas ECs ns. 109/2021 e 119/2022

Conforme pudemos destacar, em vários julgamentos proferidos pela Corte para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da **pandemia da Covid-19**, tivemos o fortalecimento da ideia de **federalismo cooperativo** (cf. **ADI 6.341**).

Diante das regras contidas no art. 23, II e IX; art. 24, XII; 30, II; e 198, CF/88, bem como nos arts. 6.º, I, e 7.º da Lei n. 8.080/90, afirmou o Min. Alexandre de Moraes, “o Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, **mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais** que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei n. 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente” (**ADPF 672**, ref. medida cautelar, j. 13.10.2020).

Destacamos, também, a aprovação da **EC n. 109/2021**, que introduziu ao texto permanente da Constituição Federal a possibilidade de se decretar **estado de calamidade pública de âmbito nacional** para eventuais e futuras novas situações de calamidade pública (de âmbito nacional), como é a **pandemia**.

Trata-se de competência do Presidente da República para **propor** ao Congresso Nacional, que decretará, por **decreto legislativo**, o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Como não se tem previsão especial, o *quorum* é de maioria simples (arts. 49, XVIII, 84, XXVIII, e 167-B a 167-G). Deixando claro, o **estado de calamidade pública de âmbito nacional** será **decretado pelo Congresso Nacional** por iniciativa privativa do Presidente da República.

Por sua vez, a **EC n. 119/2022** alterou o ADCT para determinar a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição Federal, além de dar outras providências.

■ 7.12. INTERVENÇÃO

Como já tivemos oportunidade de alertar, o art. 18, *caput*, CF/88, preceitua que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos da Constituição Federal.

No entanto, excepcionalmente, a CF prevê situações (de anormalidade) em que haverá intervenção, suprimindo-se, temporariamente, a aludida autonomia. As hipóteses, por trazerem regras de anormalidade e exceção, devem ser interpretadas **restritivamente**, consubstanciando-se um rol taxativo, *numerus clausus*.

A regra da intervenção seguirá o seguinte esquema:

■ **Intervenção federal:** União → nos Estados, Distrito Federal (hipóteses do art. 34) e nos Municípios localizados em território federal (hipótese do art. 35);

■ **Intervenção estadual:** Estados → em seus Municípios (art. 35).

Conforme observa Humberto Peña de Moraes, sendo “instituto típico da estrutura do Estado Federal, repousa a intervenção no afastamento temporário da atuação autônoma da entidade federativa sobre a qual a mesma se projeta”.⁶⁵

■ 7.12.1. Intervenção federal

■ 7.12.1.1. *Hipóteses de intervenção federal*

As hipóteses de **intervenção federal** (e quando dizemos intervenção federal significa intervenção realizada pela União)⁶⁶ nos **Estados** e no **Distrito Federal** estão **taxativamente** previstas no art. 34, sendo cabíveis para:

- manter a integridade nacional;
- repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
- garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
- reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada⁶⁷ por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
- prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.⁶⁸

As hipóteses de **intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais** serão estudadas quando tratarmos da *intervenção estadual*, prevista no art. 35.

■ 7.12.1.2. *Espécies de intervenção federal*

- **espontânea:** nesse caso o Presidente da República age de ofício → art. 34, I, II, III e V;
- **provocada por solicitação:** art. 34, IV, combinado com o art. 36, I, primeira parte → quando coação ou impedimento recaírem sobre o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, impedindo o livre exercício dos aludidos Poderes nas unidades da Federação, a decretação da intervenção federal, pelo Presidente da República, dependerá de

solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido;

■ **provocada por requisição**: a) art. 34, IV, combinado com o art. 36, I, segunda parte → se a coação for exercida contra o **poder judiciário**, a decretação da intervenção federal dependerá de **requisição** do Supremo Tribunal Federal; b) art. 34, VI, segunda parte, combinado com o art. 36, II → no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a decretação dependerá de **requisição** do STF, do STJ ou do TSE, de acordo com a matéria;

Exemplo interessante de pedido de intervenção por descumprimento de decisão judicial seria aquele decorrente do **não pagamento de precatórios** e que vem sendo frustrado em razão de jurisprudência estabelecida pelo STF no sentido de haver necessidade de se tratar de descumprimento voluntário e intencional e haver recursos financeiros.

■ **provocada, dependendo de provimento de representação**: a) art. 34, VII, combinado com o art. 36, III, primeira parte → no caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, previstos no art. 34, VII, CF/88, a intervenção federal dependerá de **provimento**, pelo **STF, de representação do Procurador-Geral da República** (representação interventiva, conforme expusemos no capítulo sobre controle, *item* 6.7.5.2); b) art. 34, VI, primeira parte, combinado com o art. 36, III, segunda parte → para prover a execução de lei federal (pressupondo ter havido recusa à execução de lei federal), a intervenção dependerá de **provimento de representação** do procurador-Geral da República pelo **STF (EC n. 45/2004)** (trata-se, também, de representação interventiva, regulamentada pela **Lei n. 12.562/2011** e com as explicitações nos *itens* 6.7.5.2.5 e 6.7.5.2.7 deste trabalho).

Quanto a esta última hipótese, Humberto Peña de Moraes observa: “insista-se, por oportuno, que a *actio* vertente não busca alcançar oportuna declaração de inconstitucionalidade — fim a que se propõe a ação direta de

inconstitucionalidade interventiva — com vista a possível intervenção, mas sim a garantir, ocorrendo recusa por parte de Estado ou do Distrito Federal e julgada procedente a pretensão pela Excelsa Corte, a execução de lei federal, sob pena, é óbvio, da prática interventiva. A intervenção para execução de lei federal só deve ser havida por lícita, insta observar, quando não existir outro tipo de ação aparelhada para a solução da *quaestio juris*”.⁶⁹

Na hipótese de **solicitação** pelo **Executivo** ou **Legislativo**, o Presidente da República não estará obrigado a intervir, possuindo **discricionariedade** para convencer-se da **conveniência** e **oportunidade**. Por outro lado, havendo **requisição** do **Judiciário**, não sendo o caso de suspensão da execução do ato impugnado (art. 36, § 3.º), o Presidente da República estará **vinculado** e deverá decretar a intervenção federal, sob pena de responsabilização.

■ 7.12.1.3. *Decretação e execução da intervenção federal e a oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional*

Compete privativamente ao **Presidente da República** decretar e executar a intervenção federal (art. 84, X) de forma espontânea ou mediante provocação.

Referida intervenção materializa-se por **decreto presidencial de intervenção** que especificará a **amplitude**, o **prazo** e as **condições de execução** e que, se couber, nomeará o **interventor**, devendo ser submetido ao **posterior** controle político do **Congresso Nacional** no prazo de **24 horas**, sendo que, se este não estiver funcionando, será feita **convocação extraordinária**, no mesmo prazo de **24 horas**, pelo **Presidente do Senado Federal** (art. 57, § 6.º, I).

A Constituição ainda prevê a oitiva dos órgãos superiores de consulta do Presidente da República, quais sejam, o **Conselho da República** (art. 90, I) e o **Conselho de Defesa Nacional** (art. 91, § 1.º, II), mediante convocação do Presidente da República, que os presidirá (art. 84, XVIII), sem haver qualquer vinculação do Chefe do Executivo aos aludidos pareceres, que serão meramente **opinativos**.

Conforme se observa, compete ao Conselho da República **pronunciar-se** sobre a intervenção federal (art. 90, I) e ao Conselho de Defesa Nacional **opinar** sobre a sua decretação (art. 91, § 1.º, II). Apesar de não haver prescrição constitucional expressa sobre o momento das consultas, nem mesmo legal (Lei n. 8.041/90 — Conselho da República e Lei n. 8.183/91 — Conselho de Defesa Nacional), a grande maioria da doutrina entende que estas deverão ser **prévias**, pois não haveria sentido ouvir os órgãos de consulta depois de já implementada a medida.⁷⁰

Surge, então, uma questão: poderia haver dispensa da oitiva dos Conselhos? Neste caso de dispensa em razão das circunstâncias específicas do caso, decretada a intervenção, deveria haver necessariamente a posterior consulta aos referidos órgãos superiores?

Conforme vimos, a **regra** é a **oitiva prévia** dos Conselhos. Contudo, em situações excepcionalíssimas, de extrema urgência, diante de justificativas próprias e decorrentes de circunstâncias específicas dos fatos — lembrando que os referidos pareceres são meramente opinativos —, pensamos ser **possível** a decretação da intervenção sem a oitiva dos Conselhos.

Neste caso de urgente decretação, contudo, para se respeitar o comando constitucional que estabelece a **indispensabilidade** da oitiva dos Conselhos, esta, **necessariamente**, deverá ser posterior e no menor prazo possível, até porque os pareceres a serem emitidos poderão **reorientar** o decreto interventivo e, por que não, em momento seguinte, diante de novas situações fáticas que justifiquem, permitir a sustação da medida em nova apreciação política, sustentando-se aqui um contínuo controle político ao se fazer uma leitura ampliada da parte final do art. 49, IV, tendo em vista a excepcionalidade do instituto.

A efetiva dispensa da oitiva dos Conselhos significaria a banalização da disposição constitucional, pois, do contrário, não teria sentido a sua previsão para essa finalidade específica nas situações de grave crise constitucional previstas na Constituição.

Nesse sentido, Paulo Branco sustenta: “não há por que, em caso de evidente urgência, exigir que a consulta seja prévia, já que as opiniões não são vinculantes e não perdem objeto nas intervenções que se prolongam no tempo, podendo mesmo sugerir rumos diversos dos que inicialmente adotados no ato de intervenção”.⁷¹

Como se trata de tema novo, afinal a primeira intervenção federal ocorreu depois de quase 30 anos de vigência da atual Constituição e, no caso específico, com a posterior oitiva dos Conselhos, depois de já publicado o decreto interventivo (cf. *item 7.12.1.6*), devemos acompanhar a posição do STF. No caso do Rio de Janeiro, houve judicialização da matéria, que, contudo, não foi apreciada: **a) MS 35.537** (impetrado em 19.02.2018 por parlamentar, atacava a tramitação do projeto de decreto legislativo tendo em vista o encaminhamento da mensagem do Presidente da República n. 80/2018. Com a sua aprovação, houve a perda superveniente do objeto do mandado de segurança); **b) ADI 5.915** (ajuizada em 14.03.2018, em 28.02.2019, tendo por objeto o decreto interventivo, foi julgada **prejudicada**, por perda superveniente do objeto, já que a intervenção no Estado do Rio de Janeiro atingiu o seu termo em 31.12.2018).

Devemos lembrar, ainda, que a decretação da intervenção federal no Distrito Federal em 2023 (e que estudaremos a seguir) também se implementou sem a prévia oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional (Decreto n. 11.377/2023).

■ 7.12.1.4. *Controle político exercido pelo Congresso Nacional*

Nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 36, conforme visto acima, o **Congresso Nacional (Legislativo)** realizará **controle político** sobre o decreto de intervenção expedido pelo **Executivo** no prazo de 24 horas, devendo ser feita, pelo Presidente do Senado Federal (art. 57, § 6.º, I), a convocação extraordinária, também no prazo de 24 horas, se a Casa Legislativa estiver em recesso parlamentar. Assim, nos termos do art. 49, IV, o **Congresso Nacional** ou **aprovará** a intervenção federal, ou a **rejeitará**,

sempre por meio de **decreto legislativo**, suspendendo a execução do decreto interventivo nesta última hipótese. Parece possível também pensarmos a hipótese de suspensão parcial de alguma medida tomada pelo Presidente da República no decreto interventivo.

Diferente da regra prevista para o controle político a ser exercido pelo Congresso Nacional nas hipóteses de decretação de estado de defesa (art. 136, § 4.º) e de estado de sítio (art. 137, parágrafo único), que estabelecem o *quorum* da maioria absoluta, em relação à **intervenção federal**, como não há disposição específica, deverá prevalecer a regra geral, qual seja, o *quorum* de aprovação do projeto de decreto legislativo será por **maioria simples**, nos termos do art. 47, CF/88.

Em caso de rejeição pelo Congresso Nacional do decreto interventivo, o Presidente da República deverá cessá-lo imediatamente, sob pena de cometer crime de responsabilidade (art. 85, II — atentado contra os Poderes constitucionais do Estado), passando o ato a ser inconstitucional.

Conforme visto no item anterior, dada a aproximação com os institutos do *estado de defesa* e do *estado de sítio*, parece recomendável a aplicação analógica do art. 140 da Constituição Federal, para se estabelecer o **controle político** não apenas imediato — logo após a decretação, como, também, pensamos, **concomitante**, devendo ser designada comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes à intervenção federal.

■ 7.12.1.4.1. *Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado*

Como regra geral, o decreto interventivo deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional (controle político). Excepcionalmente, a CF (art. 36, § 3.º) dispensa a aludida apreciação, sendo que o decreto se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. As hipóteses em que o controle político é dispensado são as seguintes:

- **art. 34, VI** → para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- **art. 34, VII** → quando houver afronta aos princípios sensíveis da CF.

Nesses casos, no entanto, se o decreto que suspendeu a execução do ato impugnado **não foi suficiente para o restabelecimento da normalidade**, o Presidente da República **decretará a intervenção federal**, nomeando, se couber, interventor, devendo submeter o seu ato ao exame do Congresso Nacional (**controle político**), no prazo de 24 horas, nos termos do art. 36, § 1.º, conforme referido.

■ 7.12.1.5. *Afastamento das autoridades envolvidas*

Por meio do **decreto interventivo**, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, o Presidente da República nomeará (quando necessário) interventor, afastando as autoridades envolvidas.

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4.º).

■ 7.12.1.6. *A intervenção federal na vigência da Constituição Federal de 1988: os casos particulares do Distrito Federal e do Espírito Santo e a efetiva decretação da intervenção federal nos Estados do Rio de Janeiro e de Roraima e no Distrito Federal*

Durante a vigência da Constituição Federal de 1988, tivemos três situações de efetiva decretação de intervenção federal, implementadas pelo **Decreto n. 9.288/2018** no Estado do **Rio de Janeiro**, pelo **Decreto n. 9.602/2018** no Estado de **Roraima** e pelo **Decreto n. 11.377/2023** no caso do **Distrito Federal**.

Antes, porém, vale a pena destacar dois outros relevantes episódios, um envolvendo o **Distrito Federal** (e que não se confunde com a efetiva intervenção em 2023) e outro, o Estado do **Espírito Santo**, que passaram

perto da implementação da medida extrema.

A) Distrito Federal

No caso do Distrito Federal, o pedido de intervenção foi formulado pelo PGR com base no art. 34, VII, “a”, sob a “... **alegação** da existência de **esquema de corrupção** que envolveria o ex-Governador do DF, alguns Deputados Distritais e suplentes, investigados pelo STJ, e cujo concerto estaria promovendo a desmoralização das instituições públicas e comprometendo a higidez do Estado Federal. Tais fatos revelariam conspícua **crise institucional** hábil a colocar em risco as atribuições político-constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e provocar instabilidade da ordem constitucional brasileira. (...) **No mérito**, entendeu-se que o perfil do momento político-administrativo do Distrito Federal já **não autorizaria a decretação de intervenção federal**, a qual se revelaria, agora, **inadmissível** perante a **dissolução do quadro que se preordenaria a remediar...**”, tendo ficado vencido o Min. Ayres Britto (**IF 5.179**, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2010, Plenário, *DJE* de 08.10.2010. Sobre o tema, cf. o *item* 6.7.5.2.1).

B) Espírito Santo

Por sua vez, no Estado do Espírito Santo, tivemos o episódio envolvendo o então Ministro da Justiça Miguel Reale Jr., que ficou à frente do cargo por apenas 3 meses quando apresentou o seu pedido de **demissão** por ter se sentido traído.

Conforme ele mesmo relata em entrevista concedida ao *Conjur*,⁷² no ano de 2002, diante de assassinatos de juízes, promotores e advogados pelo crime organizado, houve um pedido formal pela OAB para a intervenção federal no Estado do Espírito Santo. Essa medida poderia se implementar tanto de forma espontânea pelo Presidente da República (art. 34, III) como pela propositura da representação interventiva pelo PGR (ADI interventiva), com a necessária apreciação do STF (art. 34, VII, “b”).

A demanda foi parar no *Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana*, que, nos termos da *Res. CDDPH n. 15, de 04.07.2002*, aprovou, após ter mandado um grupo de investigação ao estado, “por unanimidade e com palmas”, inclusive com a presença do então Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro, o relatório sobre a representação do Conselho Federal da OAB elaborado pelos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Flávia Piovesan e Belisário dos Santos Jr.⁷³

No dia 08.07.2002, contudo, Miguel Reale Jr. estava em São Paulo e, para sua surpresa, tomou conhecimento pela televisão de que não mais iriam decretar a intervenção, pois, conforme fala do PGR em entrevista dada à imprensa de dentro do Planalto, “a intervenção federal no Espírito Santo era uma questão do Ministro da Justiça e não do governo”. Assim, tanto a intervenção espontânea, que se implementaria mediante ato do Presidente da República observadas as formalidades constitucionais, como a propositura da ADI Interventiva, que dependeria do ajuizamento da representação interventiva pelo PGR, estavam sepultadas.

Miguel Reale Jr. se sentiu traído e, por isso, pediu a demissão do cargo de Ministro da Justiça. Conforme explica, “eu me senti absolutamente desprestigiado pelo Presidente, a quem eu tenho uma admiração muito grande como político e como intelectual, e hoje tenho boas relações. Mas naquele instante era impraticável eu permanecer no Ministério. Ou eu tinha honra ou não tinha. Eu renunciei. O Presidente podia ter me ligado, como ligava diversas vezes, tínhamos inclusive relações de proximidade, e falar: ‘Olha, o Procurador da República veio aqui agora etc.’”.⁷⁴

A imprensa noticiou as possíveis razões para o arquivamento, dentre outras, a **proximidade do pleito eleitoral** e o **impacto que a medida traria**, pois o relatório da comissão, conforme visto, recomendava a intervenção tanto no Executivo como na Assembleia Legislativa. Diziam que o momento político não era adequado...!

C) Rio de Janeiro — Decreto n. 9.288, de 16.02.2018 — primeiro caso de efetiva decretação de intervenção federal na vigência da Constituição Federal de 1988 — aprovado pelo Decreto Legislativo n. 10, de 20.02.2018

Devemos destacar o histórico caso envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, o primeiro depois de quase 30 anos de vigência do texto constitucional. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, X, CF/88, decretou a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública (art. 34, III, CF/88 e Decreto n. 9.288/2018).

Cumprindo as formalidades constitucionais prescritas no art. 36, § 1.º, CF/88, o decreto estabeleceu o **prazo** da intervenção até 31.12.2018, limitando-a à **área de segurança pública do Estado**, tendo sido nomeado para o cargo de **interventor** o General do Exército Braga Netto, que, subordinado ao Presidente da República, assumiu o **controle operacional dos órgãos de segurança pública do Estado**.

Vale a pena destacar que o próprio Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, fez o pedido de intervenção ao declarar a total incapacidade de cuidar da segurança pública do Estado, não conseguindo deter, conforme afirmou em seu discurso na data da assinatura do decreto, onde esteve presente, a guerra entre facções e o que considerou mais grave, a problemática das milícias.

Apesar da nomeação de um militar, a decretação deve ser entendida como a intervenção da União (do governo federal) na política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (art. 21, V, CF/88) e não uma intervenção militar das Forças Armadas. Ou seja, a gestão da segurança pública, as estratégias, as medidas a serem implementadas, enfim, toda a área passou para o interventor, afastando-se o secretário de segurança e o próprio Governador dessa pasta.

Nesse sentido, o art. 3.º, § 5.º, do Decreto n. 9.288/2018 estabeleceu que o interventor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exerceria o controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública previstos no

art. 144 da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Na Nota Técnica Conjunta n. 01/2018 do MPF (PGR-00072549/2018), expedida em 20.02.2018 pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e pela Câmara Criminal do MPF (2CCR), estabeleceu-se o mesmo entendimento acima exposto: “o Decreto n. 9.288/2018 determinou intervenção parcial no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, ‘limitada à área da segurança pública’ (art. 1.º, § 1.º). O interventor foi nomeado para assumir parte das competências do governador de Estado (decreto, art. 3.º). **A natureza da função a ser exercida pelo interventor é, portanto, aquela de Governador de Estado, por definição constitucional um cargo de natureza civil.** Nada obsta que um militar seja designado para assumir essa função, tal como previsto na Constituição (art. 142, § 3.º, II e III), porém esse fato **não transmuda a natureza da função**”.

Dois pontos importantes, contudo, devem ser destacados, especialmente por terem sido judicializados.

O **primeiro** está relacionado a uma formalidade constitucional que não foi observada, qual seja, a **prévia** oitiva do **Conselho da República** (art. 90, I) e do **Conselho de Defesa Nacional** (art. 91, § 1.º, II) para decretação da intervenção federal, sobre a qual já tivemos a oportunidade de expor o nosso entendimento.

Conforme vimos no *item 7.12.1.3*, de fato, a melhor interpretação da Constituição é aquela que reconhece a **prévia consulta** desses chamados órgãos superiores de consulta do Presidente da República para emissão de pareceres na hipótese de intervenção federal. Referidos pareceres, segundo entendimento doutrinário, são meramente **opinativos** (cf. *item 10.4.8*). Entendemos que em situações de extrema urgência ou necessidade iminente, diante de circunstâncias específicas e muito particulares, referida oitiva poderá ser posterior, conforme aconteceu no caso do Rio de Janeiro, em que a decretação se deu em uma sexta-feira (16.02.2018) e a oitiva dos Conselhos na segunda-feira (19.02.2018), tendo sido feitas as convocações para as reuniões no domingo (art. 84, XVIII, CF/88).

Depois de ouvidos os Conselhos, no dia seguinte, qual seja, em 20.02.2018, nos termos do **DL n. 10/2018**, o Congresso Nacional, observando o comando constitucional previsto no art. 49, IV, **aprovou**, com folga (lembrando que o *quorum* é por maioria simples), o decreto interventivo presidencial, nos seguintes termos:

■ **Câmara dos Deputados:** 340 votos favoráveis, 72 contrários e 1 abstenção (Projeto de Decreto Legislativo n. 886-A/2018);

■ **Senado Federal:** 55 votos favoráveis, 13 contrários e 1 abstenção (Projeto de Decreto Legislativo n. 4/2018).

O **segundo** ponto decorreu do pronunciamento do então Presidente da República Michel Temer na cerimônia de assinatura do decreto (em 16.02.2018), ao informar que iria **cessar** o decreto para votar a Reforma da Previdência. Vejamos a fala de sua excelência: “eu registro que ajustamos ontem à noite com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira a **continuidade** da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do País. **Quando ela estiver para ser votada**, e naturalmente isto segundo avaliação das Casas Legislativas, **eu farei cessar a intervenção**. No instante que se verifique, segundo os critérios das Casas Legislativas que há condições para votação, reitero, eu farei cessar a intervenção”.

Como se sabe e estudamos no *capítulo 9*, a Constituição estabeleceu **limitações circunstanciais** à reforma constitucional, qual seja, nos termos do art. 60, § 1.º, a proibição de se **emendar** a Constituição na vigência de **intervenção federal**, de estado de defesa ou de estado de sítio.

Com o máximo respeito, não concordamos com a “estratégia” apresentada pelo Presidente da República em seu pronunciamento. Pensamos que o objetivo do constituinte originário ao manter e **ampliar** os limites circunstanciais ao poder de reforma (lembrando que antes da Constituição de 1988, a primeira Constituição a estabelecer regra similar, vedando a alteração apenas na vigência de estado de sítio, foi a de 1934, mantida nas seguintes,

exceto na de 1937) foi evitar a reforma constitucional em situação de legalidade extraordinária e, portanto, de grave instabilidade.

Dessa forma, ou os requisitos para intervenção estão presentes, ou não é hipótese de sua decretação. Cessá-la para uma finalidade diversa, não relacionada aos motivos que ensejaram a intervenção, caracterizaria inequívoco **desvio de finalidade** e, portanto, **fraude constitucional**. Demonstrado que o objetivo da decretação foi outro que não o de se pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, haveria **crime de responsabilidade**. A intervenção federal só deve cessar, dentro do prazo estabelecido, se os motivos que a justificaram deixarem de existir e, jamais, para a finalidade diversa como a de se aprovar uma PEC, por mais importante que seja. Essa medida, sem dúvida, caracterizaria **inaceitável “violência” constitucional**.

Outros temas ainda poderiam ser destacados, como, dentre outros, a amplitude da regra contida no art. 60, § 1.º, qual seja, **a decretação da intervenção federal paralisa toda tramitação de PEC ou apenas a fase de discussão e votação da proposta?**⁷⁵

Entendemos que a **paralisação** deva ser de **toda a tramitação**, ficando impedidas a discussão e a votação da PEC. A instabilidade da medida excepcional traria riscos para isenção dos debates e formulação dos pareceres.

Em sentido contrário, o Min. Dias Toffoli sustentou a suspensão de “todos os atos deliberativos do processo legislativo da emenda constitucional, **mas não a tramitação das propostas de emenda**” (MS 35.535, j. 26.06.2018, fls. 9 da decisão — tendo sido julgado prejudicado o agravo interno em razão do fim da intervenção federal e de não constar nenhuma tramitação da PEC 287/2016 durante o ano legislativo de 2018).⁷⁶

D) Roraima — Decreto n. 9.602, de 08.12.2018 — segundo caso de efetiva decretação de intervenção federal na vigência da Constituição Federal de 1988 — aprovado pelo Decreto Legislativo n. 174, de 12.12.2018

Diante da grave crise na segurança pública e no sistema carcerário, acrescentando-se o enorme risco de rebeliões, além da política de acolhida humanitária a imigrantes venezuelanos, o então Presidente da República, Michel Temer, com a aquiescência da Governadora, decretou a “intervenção federal no Estado de Roraima até 31.12.2018, para, nos termos do art. 34, *caput*, inciso III, da Constituição, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública”.

Conforme declarou, por haver concordância, “fiz com a senhora governadora uma espécie de **intervenção negociada**. Ela aceitou a esta fórmula, concordou com esta fórmula. Acha que, de fato, a situação está se complicando no estado de Roraima e que a melhor solução seria precisamente essa” (*Agência Brasil*, 07.12.2018).

Diferente do Rio de Janeiro (2018) e do Distrito Federal (2023), cujas intervenções se limitaram à área de segurança pública, a intervenção no Estado de Roraima abrangeu todo o Poder Executivo, afastando-se a Governadora e se nomeando, para o cargo de Interventor, Antonio Denarium, o eleito pelo povo para assumir o cargo a partir de 1.º.01.2019.

Dessa forma, enquanto as intervenções no **Rio de Janeiro** e no **Distrito Federal** foram **parciais** (segurança pública), a no Estado de **Roraima** foi **total**, substituindo-se a Governadora pelo interventor, que assumiu todas as suas atribuições.

Nesse segundo caso, a cronologia dos fatos demonstra total observância ao procedimento: **a)** prévia oitiva dos Conselhos, que opinaram, por unanimidade, pela decretação da intervenção (08.12.2018); **b)** oficialização da intervenção, publicando o decreto presidencial no *Diário Oficial da União* (10.12.2018); **c)** controle político pelo Congresso Nacional por decreto legislativo (12.12.2018).

E) Distrito Federal — Decreto n. 11.377, de 08.01.2023 — terceiro caso de efetiva decretação de intervenção federal na vigência da Constituição Federal de 1988 — aprovado pelo Decreto Legislativo n. 1, de 10.01.2023

Todos se recordam dos gravíssimos atos que atentaram contra a democracia e as instituições brasileiras em **08.01.2023**, com a invasão e destruição violenta do **edifício-sede do STF**, do **Congresso Nacional** e do **Palácio do Planalto**, sede dos Três Poderes, bem como do **patrimônio público**, em razão de questionamentos e inconformismo dos manifestantes em relação ao resultado das eleições de 2022.

Os referidos **atos antidemocráticos** de 8 de janeiro sofreram várias medidas de reação e contenção, dentre as quais a decretação da intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023, **limitada à área de segurança pública**, conforme o disposto no art. 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.

O objetivo da intervenção era **pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal**, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos (art. 34, III), tendo sido nomeado para o cargo de Interventor Ricardo Garcia Cappelli, subordinado ao Presidente da República.

As demais áreas que não tinham relação com a segurança pública permaneceram sob a titularidade do Governador do Distrito Federal, que, contudo, veio a ser afastado por 90 dias em razão de decisão do STF (cf. **Inq 4.879, Ref. Lim.** e *item 10.4.13.2*).

O Congresso Nacional, cumprindo o procedimento constitucional, aprovou a referida intervenção na área de segurança pública do Distrito Federal, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.377/2023, constante da Mensagem do Poder Executivo n. 14, de 08.01.2023, com o objetivo de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública (Decreto Legislativo n. 1, de 10.01.2023).

Devemos lembrar que, assim como no caso do Rio de Janeiro, **a decretação da intervenção se deu sem a prévia oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional**.

Conforme já explicamos anteriormente, a regra é a oitiva prévia dos Conselhos. Contudo, em situações **excepcionalíssimas, de extrema urgência, diante de justificativas próprias e decorrentes de**

circunstâncias específicas dos fatos — lembrando que os referidos pareceres são meramente opinativos —, pensamos ser possível a decretação da intervenção sem a oitiva dos Conselhos.

De fato, foi o que aconteceu no caso do Rio de Janeiro (2018) e agora no do DF (2023) em análise.

Nesses casos, contudo, para se respeitar o comando constitucional que estabelece a **indispensabilidade da oitiva dos Conselhos**, esta, necessariamente, deverá ocorrer no menor prazo possível, até porque os pareceres a serem emitidos poderão reorientar o decreto interventivo e, por que não, em momento seguinte, diante de novas situações fáticas que justifiquem, permitir a sustação da medida em eventual nova apreciação, sustentando-se aqui um contínuo controle político ao se fazer uma leitura ampliada da parte final do art. 49, IV, tendo em vista a excepcionalidade do instituto.

A efetiva dispensa da oitiva dos Conselhos significaria a banalização da disposição constitucional, pois, do contrário, não teria sentido a sua previsão para essa finalidade específica nas situações de grave crise constitucional previstas na Constituição.

■ 7.12.1.7. *A intervenção federal: necessidade de preservação dos direitos fundamentais*

Diferente da decretação do estado de defesa e do estado de sítio, que expressamente admitem a possibilidade de imposição de medidas coercitivas, inclusive restrições a direitos e garantias (cf. arts. 136, § 1.º, I e II, e 139, I-VII), **a Constituição não estabelece nenhuma possibilidade de restrição a direitos na hipótese de decretação de intervenção federal.**

Nesse sentido, diante da excepcionalidade da medida, a interpretação deverá ser restritiva e, portanto, não se admitirá, em hipótese alguma, mitigação de direitos fundamentais.

Repudiamos qualquer medida que tenha se imaginado no caso do Rio de Janeiro, conforme noticiado pela imprensa, de se expedirem “mandados coletivos de busca, apreensão e captura”, ou, conforme se expressou em outro momento, “mandados com múltiplos alvos”, destacando-se, nesse sentido, tanto a Nota Técnica Conjunta do MPF — PGR-00072549/20158 (20.02.2018), como a Nota Pública expedida pela Associação Nacional dos Defensores Públicos — ANADEP (21.02.2018), ambas enaltecendo a necessidade de serem observadas as garantias fundamentais da presunção de inocência, do devido processo legal, da inviolabilidade do domicílio e da intimidade, do dever de motivar as decisões judiciais e, naturalmente, a regra legal contida no art. 243, CPP.

■ 7.12.2. Intervenção estadual

■ 7.12.2.1. *Hipóteses de intervenção estadual e intervenção federal nos Municípios localizados em Territórios Federais*

As hipóteses de **intervenção estadual** e **federal** (nos Municípios localizados em Territórios Federais) estão **taxativamente** previstas no art. 35, sendo cabíveis quando:

- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
- não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
- não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;⁷⁷
- o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

A **taxatividade** prevista no art. 35 já foi inúmeras vezes declarada pela Suprema Corte, que, inclusive, **não** admite a alteração de suas **excepcionais hipóteses**, preceitos de observância compulsória por parte dos Estados-Membros, pelo constituinte estadual, seja para ampliá-las ou reduzi-las (ADIs 6.617, 2.917 e 336).

Devemos lembrar que a **EC n. 119/2022** acrescentou o art. 119, ADCT, no seguinte sentido: “Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no *caput* deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021”.

O disposto no referido dispositivo trazido no art. 119, ADCT, **obsta a ocorrência dos efeitos do inciso III do *caput* do art. 35, Constituição Federal**.

■ 7.12.2.2. *Decretação e execução da intervenção estadual*

A decretação e execução da intervenção estadual é de competência privativa do **Governador de Estado**, por meio de **decreto de intervenção**, que especificará a amplitude, o prazo e as condições da execução e, quando couber, nomeará o interventor.

■ 7.12.2.3. *Controle exercido pelo Legislativo*

A Constituição estabeleceu a realização de **controle político** a ser exercido pelo Legislativo, devendo o decreto de intervenção ser submetido à apreciação da **Assembleia Legislativa**, no prazo de 24 horas. Na hipótese de não estar funcionando, haverá convocação extraordinária, também no prazo de 24 horas.

■ 7.12.2.3.1. *Hipóteses em que o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado*

Em regra, o decreto interventivo deverá ser apreciado pela Assembleia Legislativa (intervenção estadual). Excepcionalmente, porém, a CF (art. 36, § 3.º) dispensa a aludida apreciação pelo Congresso Nacional (hipóteses já estudadas quando tratamos da intervenção federal), ou pela Assembleia Legislativa estadual, sendo que o decreto, nesses casos, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. A hipótese em que o controle político é dispensado ocorre quando:

■ **art. 35, IV** → o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

No entanto, se a suspensão da execução do ato impugnado não for suficiente para o restabelecimento da normalidade, o Governador de Estado decretará a intervenção no Município (hipótese de intervenção estadual em Município), submetendo esse ato (decreto interventivo) à Assembleia Legislativa, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente.

■ 7.12.2.4. *Afastamento das autoridades envolvidas*

No decreto interventivo que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, o Governador de Estado nomeará (quando necessário) interventor, afastando as autoridades envolvidas.

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4.º).

■ 7.12.2.5. *Súmula 637 do STF*

Nos termos da S. 637/STF, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município”.

■ 7.13. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

7

DIVISÃO ESPACIAL DO PODER — ORGANIZAÇÃO DO ESTADO



 Imagem sem descrição.

8

separação de “poderes”— teoria geral

8.1. Noções introdutórias

8.1.1. Aristóteles: identificação das funções do Estado

As primeiras bases teóricas para a “tripartição de Poderes” foram lançadas na Antiguidade grega por **Aristóteles**, em sua obra *Política*, em que o pensador vislumbrava a existência de **três funções distintas** exercidas pelo poder **soberano**, quais sejam, a função de editar normas gerais a serem observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto (administrando) e a função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos.

Acontece que **Aristóteles**, em decorrência do momento histórico de sua teorização, descrevia a **concentração** do exercício de tais funções na figura de uma única pessoa, o soberano, que detinha um poder “incontrastável de mando”, uma vez que era ele quem editava o ato geral, aplicava-o ao caso concreto e, unilateralmente, também resolvia os litígios eventualmente decorrentes da aplicação da lei. A célebre frase de *Luís XIV* reflete tal descrição: “*L’État c’est moi*”, ou seja, “o Estado sou eu”, o soberano.

Dessa forma, **Aristóteles** contribuiu no sentido de **identificar o exercício de três funções estatais distintas**, apesar de exercidas por um único órgão.

8.1.2. Montesquieu: correspondência entre a divisão funcional e a divisão orgânica

Muito tempo depois, a teoria de Aristóteles seria “aprimorada” pela visão precursora do Estado liberal burguês desenvolvida por **Montesquieu** em seu *O espírito das leis*.

O grande avanço trazido por Montesquieu não foi a identificação do exercício de três funções estatais. De fato, partindo desse pressuposto aristotélico, o grande pensador francês inovou dizendo que tais funções estariam intimamente conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Cada função corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas do soberano. Essa teoria surge em contraposição ao absolutismo, servindo de base estrutural para o desenvolvimento de diversos movimentos, como as revoluções americana e francesa, caracterizando-se, na *Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão*,¹ em seu art. 16,² como verdadeiro **dogma constitucional**.

De acordo com essa teoria, cada Poder exercia uma função típica, inerente à sua natureza, atuando independente e autonomamente, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e julgar, de modo unilateral, como se percebia no absolutismo.

Cabe alertar, conforme destacou, com acerto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “a divisão funcional do poder — ou, como tradicionalmente se diz, a ‘*separação de poderes*’ — que ainda hoje é a base da organização do governo nas democracias ocidentais, não foi invenção genial de um homem inspirado, mas sim é o resultado empírico da evolução constitucional inglesa, qual a consagrou o *Bill of Rights* de 1689. De fato, a ‘gloriosa revolução’ pôs no mesmo pé a autoridade real e a autoridade do parlamento, forçando um compromisso que foi a divisão do poder, reservando-se ao monarca certas funções, ao parlamento outras e reconhecendo-se a independência dos juízes. Esse compromisso foi **teorizado** por **Locke**, no *Segundo tratado do governo civil*, que o justificou a partir da hipótese do estado de natureza. Ganhou ele, porém, **repercussão estrondosa** com a obra de **Montesquieu**, *O espírito das leis*, que o transformou numa das mais célebres doutrinas políticas de todos os tempos”.³

8.1.3. E qual seria a finalidade da separação dos poderes?

Dimitri, com precisão, observa que “seu objetivo fundamental é preservar a liberdade individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a

tendência ‘absolutista’ de exercício do poder político pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. A distribuição do poder entre órgãos estatais dotados de independência é tida pelos partidários do liberalismo político como garantia de equilíbrio político que evita ou, pelo menos, minimiza os riscos de abuso de poder. O Estado que estabelece a separação dos poderes evita o despotismo e assume feições liberais. Do ponto de vista teórico, isso significa que na base da separação dos poderes encontra-se a tese da existência de nexo causal entre a divisão do poder e a liberdade individual. A separação dos poderes persegue esse objetivo de duas maneiras. Primeiro, impondo a **colaboração** e o **consenso** de várias autoridades estatais na tomada de decisões. Segundo, estabelecendo **mecanismos de fiscalização e responsabilização recíproca dos poderes estatais**, conforme o desenho institucional dos **freios e contrapesos**”.⁴

Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

“EMENTA: (...). A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de **conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado**, representa o **princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição**. Esse princípio, que tem assento no art. 2.º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.

(...).

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a **impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado**, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de

qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.09.1999, Plenário, DJ de 12.05.2000 — grifamos).

Dentre os vários exemplos desse mecanismo de **freios e contrapesos**, em razão da **interpenetração dos “poderes” (interferências ou controles recíprocos)**, com o objetivo de **evitar abusos de poder**, podemos destacar:

- **art. 5.º, XXXV**: o Poder **Judiciário** pode rever atos de determinada CPI (**Legislativo**) que extrapolem o *postulado da reserva constitucional de jurisdição*, quando, por exemplo, o seu presidente expede um mandado de busca e apreensão em total violação ao art. 5.º, XI;
- **art. 52, I**: compete privativamente ao Senado Federal (**Legislativo**) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República (**Executivo**) nos crimes de responsabilidade;
- **art. 53, § 1.º, c/c o art. 102, I, “b”**: eventual condenação pelo STF (**Judiciário**) de parlamentar federal corrupto (**Legislativo**) que se vale de seu cargo para indevidamente enriquecer (cf. julgamento do denominado “mensalão” na AP 470);
- **art. 62**: as medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República (**Executivo**) poderão ser rejeitadas pelo Congresso Nacional (**Legislativo**);
- **art. 66, § 1.º**: o Chefe do Poder **Executivo** pode sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelo Parlamento (**Legislativo**);
- **art. 66, §§ 4.º a 6.º**: o Parlamento (**Legislativo**) poderá “derrubar” o veto lançado pelo Chefe do Poder **Executivo**;
- **art. 66, § 7.º**: se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República (**Executivo**), nos casos dos §§ 3.º e 5.º, o Presidente do Senado (**Legislativo**) a promulgará, e, se este

não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado **(Legislativo)** fazê-lo;

■ **art. 63, I e II:** cabe emenda parlamentar **(Legislativo)** em projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República **(Executivo)**;

■ **art. 64, § 1.º:** o Presidente da República **(Executivo)** poderá solicitar urgência para o Parlamento **(Legislativo)** apreciar os projetos de sua iniciativa;

■ **art. 97:** os juízes **(Judiciário)** poderão declarar a inconstitucionalidade de lei **(Legislativo)** ou ato normativo do Poder Público (inclusive, como exemplo, de decretos autônomos elaborados pelo **Executivo**);

■ **art. 101, parágrafo único (c/c o art. 52, III, “a”, e o art. 84, XIV):** os Ministros do STF **(Judiciário)** serão nomeados pelo Presidente da República **(Executivo)**, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal **(Legislativo)**;

■ **art. 102, I, “a”:** compete ao STF **(Judiciário)** declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual **(Legislativo)**.

8.2. funções típicas e atípicas

A teoria da “tripartição⁵ de Poderes”, exposta por Montesquieu, foi adotada por grande parte dos Estados modernos,⁶ só que de maneira **abrandada**. Isso porque, diante das realidades sociais e históricas, passou-se a permitir uma maior interpenetração entre os Poderes, atenuando a teoria que pregava a separação pura e absoluta deles.⁷

Dessa forma, além do exercício de **funções típicas** (*predominantes*), inerentes e ínsitas à sua natureza, cada órgão exerce, também, outras duas funções atípicas (de natureza típica dos outros dois órgãos). Assim, o Legislativo, por exemplo, além de exercer uma função típica, inerente à sua

natureza, exerce, também, uma **função atípica** de natureza *executiva* e outra **função atípica** de natureza *jurisdicional*.

Importante esclarecer que, mesmo no exercício da função atípica, o órgão exercerá uma função sua, não havendo aí ferimento ao princípio da separação de Poderes, porque tal competência foi constitucionalmente assegurada pelo poder constituinte originário. Vejamos o quadro abaixo, trazendo uma visão panorâmica das **funções típicas** de cada órgão, bem como **exemplos** de algumas **funções atípicas**:

ÓRGÃO	FUNÇÃO TÍPICA	FUNÇÃO ATÍPICA
LEGISLATIVO	■ legislar	■ Natureza executiva: ao dispor sobre sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores etc.
	■ fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo	■ Natureza jurisdicional: o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I)
EXECUTIVO	■ prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração	■ Natureza legislativa: o Presidente da República, por exemplo, adota medida provisória, com força de lei (art. 62)
JUDICIÁRIO	■ julgar (<i>função jurisdicional</i>), dizendo o direito no caso concreto e dirimindo os	■ Natureza jurisdicional: o Executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos ■ Natureza legislativa: regimento interno de seus tribunais (art. 96, I, “a”)

conflitos que lhe são levados, quando da aplicação da lei

■ **Natureza executiva:** administra, v.g., ao conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários (art. 96, I, “f”)

Finalmente, pedimos vênia para ressaltar a caracterização feita por José Afonso da Silva⁸ em relação às três funções (típicas) exercidas pelos Órgãos:

- **função legislativa:** “consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas *leis*”;
- **função executiva:** “resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se limita à simples *execução das leis*, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em *função de governo*, com atribuições políticas, colegislativas e de decisão, e *função administrativa*, com suas três missões básicas: *intervenção*, *fomento* e *serviço público*”;
- **função jurisdicional:** “tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse”.

8.3. Impropriedade da expressão “tripartição de Poderes”

Depois de todo o visto, devemos apenas sistematizar a imprecisão do uso da expressão “tripartição de Poderes”.

Isso porque o poder é **uno, indivisível e indelegável**. O poder não se triparte. O poder é um só, manifestando-se por meio de **órgãos** que

exercem **funções**. Dessa maneira, temos:

a) poder: uno, indivisível e indelegável, um atributo do Estado que emana do povo;

b) função: “a função constitui, pois, um modo particular e caracterizado de o Estado manifestar a sua vontade”;⁹

c) órgão: “os órgãos são, em consequência, os instrumentos de que se vale o Estado para exercitar suas funções, descritas na Constituição, cuja eficácia é assegurada pelo Poder que a embasa”.¹⁰

Assim, todos os atos praticados pelo Estado decorrem de um só Poder, uno, indivisível e indelegável. Esses atos adquirem diversas formas, dependendo das funções exercidas pelos diferentes órgãos. O órgão legislativo, por exemplo, exerce uma função típica, inerente à sua natureza, além de funções atípicas, conforme vimos no quadro anterior, ocorrendo o mesmo com os órgãos executivo e jurisdicional.

A correspondência entre **funções** e **órgãos** é imposta e decorrente da separação orgânica dos poderes e, naturalmente, está explícita no texto de 1988, destacando-se:

■ **art. 44:** o “Poder” **Legislativo** (*função*) é exercido pelo **Congresso Nacional** (*órgão*), que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

■ **art. 76:** o “Poder” **Executivo** (*função*) é exercido pelo **Presidente da República** (*órgão*), auxiliado pelos Ministros de Estado;

■ **art. 92:** são órgãos do “Poder” **Judiciário** (*função*):¹¹ I — o Supremo Tribunal Federal; I-A — o Conselho Nacional de Justiça; II — o Superior Tribunal de Justiça; III — os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV — os Tribunais e Juízes do Trabalho; V — os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI — os

Tribunais e Juízes Militares; VII — os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios (*órgãos*).

Feitas essas observações, devemos lembrar que a expressão “tripartição de Poderes”, normalmente, é utilizada sem muito rigor técnico, inclusive pela própria Constituição, que em seu art. 2.º assevera: “São **Poderes** da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Portanto, por “Poderes” entendam-se *órgãos*, em decorrência do que expusemos acima.

8.4. A independência dos Poderes e a indelegabilidade de atribuições

Ressaltamos serem os “Poderes” (*órgãos*) independentes entre si, cada qual atuando dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida quando da manifestação do *poder constituinte originário*.

Nesse sentido, as atribuições asseguradas não poderão ser delegadas de um Poder (*órgão*) a outro. Trata-se do **princípio da indelegabilidade de atribuições**. Um *órgão* só poderá exercer atribuições de outro, ou da natureza típica de outro, quando houver expressa previsão (e aí surgem as funções atípicas) e, diretamente, quando houver delegação por parte do poder constituinte originário, como ocorre, por exemplo, com as leis delegadas do art. 68, cuja atribuição é delegada pelo Legislativo ao Executivo.

Pelo que se observa no quadro abaixo, as Constituições de 1891, 1934, 1946, 1967 e a EC n. 1/69 não só foram explícitas ao proclamar a cláusula da **indelegabilidade**, como também deixaram clara a possibilidade de **interpenetração** entre os poderes a ser materializada naquilo que se denominou **freios e contrapesos**. Vejamos:

CONSTITUIÇÕES	PARTIÇÃO DE	INDEPENDÊNCIA
	FUNÇÕES	
	(quadripartição e a regra da tripartição)	ORGÂNICA

1824

■ **Art. 10.** Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são **quatro**: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial.

■ *Não há ressalva explícita.*

■ **Art. 9.º** A **divisão e harmonia** dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece.

1891

■ **Art. 15.** São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, **harmônicos e independentes entre si.**

■ **Art. 79.** O cidadão investido em funções de qualquer dos três Poderes federais não poderá exercer as de outro.

1934

■ **Art. 3.º, caput** — São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, **independentes e coordenados entre si.**

■ **Art. 3.º, § 1.º** — É vedado aos Poderes constitucionais delegar suas atribuições.

1937

■ *Não existe um dispositivo explícito, muito embora o texto tenha criado capítulos*

■ **Art. 3.º, § 2.º** — O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.

■ *Não há ressalva explícita.*

*próprios para o
Legislativo e o
Judiciário.*

1946	■ Art. 36. São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.	■ Art. 36, § 1.º — O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. ■ Art. 36, § 2.º — É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. ■ Art. 6.º, parágrafo único — Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
1967		
EC n. 1/69	■ Art. 6.º, caput — São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.	■ Art. 6.º, parágrafo único — Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
1988	■ Art. 2.º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.	■ <i>Não há ressalva explícita.</i>

Embora a regra da **indelegabilidade** e a enunciação da existência de **ressalvas** não estejam individual e expressamente estabelecidas na redação da Constituição de 1988 (em um artigo específico, como se observou nos referidos textos anteriores), não há dúvida de que devam ser reconhecidas no ordenamento atual, seja por se tratar da essência da separação de poderes adotada nos Estados modernos (do contrário, a *separação de poderes* perderia a sua utilidade), seja porque essas exceções (**interferências** ou **controles recíprocos**, em verdadeira **interpenetração de poderes**, materializando os **freios e contrapesos**) podem ser expressamente **identificadas**, o que se viu acima, **ao longo da Constituição**.

Por fim, lembre-se de que a CF/88 erigiu à categoria de **cláusula pétrea a separação de Poderes** (art. 60, § 4.º, III).

8.5. MATERIAL DIGITAL EXCLUSIVO

8

SEPARAÇÃO DE “PODERES” — TEORIA GERAL

 Imagem sem descrição.



PODER LEGISLATIVO

■ 9.1. ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

■ 9.1.1. Estrutura do Poder Legislativo federal

A análise do Poder Legislativo (ou, de modo mais técnico, órgão legislativo) deve ser empreendida levando em conta a forma de Estado introduzida no Brasil, verificando-se de que modo ocorre a sua manifestação em âmbito federal, estadual, distrital e municipal.

Assim, diz-se que no Brasil vigora o **bicameralismo federativo**, no âmbito federal. Ou seja, o Poder Legislativo no Brasil, em âmbito federal, é **bicameral**, isto é, composto por duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a primeira constituída por representantes do **povo** e a segunda, por representantes dos **Estados-Membros** e do **Distrito Federal**, adjetivando, assim, o nosso bicameralismo, que é do tipo federativo, como visto.

Pelo exposto, outra não poderia ser a redação do art. 44, CF/88, que diz: “O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”.

As regras fundamentais sobre o legislativo federal serão estudadas individualmente, destacando-se a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as reuniões dos parlamentares, as comissões e demais regras atinentes aos Deputados e Senadores, como imunidades, incompatibilidades e impedimentos, perda do mandato etc. Neste momento, teceremos alguns comentários a respeito do legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais, para, em um segundo momento, voltarmos ao legislativo federal.

■ 9.1.2. Estrutura do Poder Legislativo estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais

O Poder Legislativo em âmbito estadual, municipal, distrital e dos Territórios Federais (estes últimos, quando criados), ao contrário da estrutura do legislativo federal, é do tipo **unicameral**, pois composto por uma única Casa, conforme se observa pela leitura dos arts. 27, 29, 32 e 33, § 3.º, última parte, todos da CF/88.

■ 9.1.2.1. Estrutura do Poder Legislativo estadual

■ **unicameralismo**: o legislativo estadual é exercido pela **Assembleia Legislativa**, composta pelos **Deputados Estaduais**, também representantes do **povo** do Estado;

■ **número de deputados estaduais**: “o número de Deputados à **Assembleia Legislativa** corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze” (art. 27, *caput*).

Portanto, até o número de 12 Deputados Federais, o número de Deputados Estaduais será obtido pela multiplicação por 3 (o triplo). Acima de 12, segue a seguinte fórmula: $y = (x - 12) + 36 \rightarrow$ em que **y** corresponde ao número de Deputados Estaduais e **x**, ao número de Deputados Federais. A fórmula, para facilitar, pode ser assim resumida: $y = x + 24$, em que **y** corresponde ao número de Deputados Estaduais e **x**, ao número de Deputados Federais (quando forem acima de 12). Veja a tabela abaixo e “viva a matemática”!:

NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS (X)	NÚMERO DE DEPUTADOS ESTADUAIS (Y)	FÓRMULA
8	24 ¹	o triplo

9	27	o triplo
10	30	o triplo
11	33	o triplo
12	36	o triplo
13	37	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
14	38	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
(...)		
68 ²	92	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
69	93	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$
70	94 ³	$y = (x - 12) + 36$ ou $y = x + 24$

- **mandato:** o mandato dos Deputados Estaduais será de **4 anos**;
- **outras regras:** as regras da CF sobre **sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas** serão aplicadas aos parlamentares estaduais (art. 27, § 1.º). Desta feita, o regime reservado aos parlamentares federais será o mesmo a ser observado pelos estaduais;
- **remuneração:** determina o § 2.º do art. 27 que o **subsídio** dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, não podendo ser superior a **75%** daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º, 57, § 7.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I. Trata-se de subteto do

funcionalismo a ser respeitado no âmbito do Poder Legislativo Estadual, segundo a regra trazida pela **Reforma da Previdência** (art. 37, XI — EC n. 41/2003). Entendemos que o subteto do funcionalismo a ser observado no âmbito do Poder Legislativo Estadual continua sendo o subsídio do Deputado Estadual, apesar da novidade trazida no art. 37, § 12, pela **EC n. 47/2005**. Isso porque a parte final é bem clara ao dizer que a flexibilização da “PEC Paralela” não se aplica ao subsídio do Deputado Estadual, que continua sendo o parâmetro e limite, nos termos do art. 37, XI, que não foi modificado.

■ 9.1.2.2. *Estrutura do Poder Legislativo municipal*

■ **unicameralismo:** o legislativo municipal é exercido pela **Câmara Municipal (Câmara dos Vereadores)**, composta pelos **Vereadores**, representantes do **povo** do Município;

■ **número de Vereadores:** será estabelecido de acordo com o número de habitantes de cada Município, até os limites máximos prescritos no art. 29, IV, nos termos da redação dada pela **EC n. 58/2009**.⁴

A fixação em si implementa-se pela **lei orgânica de cada município** e não por resolução de sua Câmara dos Vereadores (art. 29, *caput*). Conforme indicado, a Constituição Federal fixa o **limite máximo** de acordo com as faixas do art. 29, IV. A lei orgânica, por sua vez, define esse número, vinculando o parlamento municipal, que não poderá alterá-lo. Isso porque o Parlamento, ao estabelecê-lo em sua lei orgânica — até o limite constitucional máximo, pode querer limitá-lo de acordo com a receita daquele ente federativo.

A título de curiosidade, cabe lembrar que, antes da EC n. 58/2009, a *Resolução n. 21.702/2004/TSE*, partindo do julgamento do RE 197.917, que definiu a proporcionalidade em relação ao Município de Mira Estrela, produziu efeitos para todo o País.

■ **mandato:** o mandato dos Vereadores será de **4 anos**;

■ **inviolabilidade ou imunidade material:** os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município (art. 29, VIII, estudado mais adiante);

■ **remuneração:** as regras sobre a remuneração dos Vereadores, inicialmente, foram fixadas no art. 29, V, CF/88, cuja redação foi alterada pela EC n. 19/98. A EC n. 1/92 acrescentou o inciso VI ao referido art. 29, que, por sua vez, também foi alterado pela **reforma administrativa** (EC n. 19/98). Tanto na primeira reforma como na segunda, fixou-se que o **valor da remuneração dos Vereadores** corresponderia a, no máximo, 75% do subsídio, em espécie, dos **Deputados Estaduais**, sendo fixado por lei de **iniciativa da Câmara dos Vereadores**. Felizmente, de maneira mais transparente, outra reforma sofreu o texto constitucional, por meio da **EC n. 25, de 14.02.2000**, que alterou o inciso VI do art. 29 e acrescentou o art. 29-A à Constituição Federal, estipulando critérios mais claros e objetivos para o controle dos gastos públicos, no caso em análise, do Poder Legislativo Municipal.

Agora, com as novas regras, a fixação dos percentuais não ficará mais ao puro arbítrio dos Vereadores, através de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, na medida em que os **percentuais máximos** já foram estabelecidos pelo próprio poder constituinte derivado reformador, na EC n. 25/2000. De acordo com as novas regras (art. 29, VI, CF/88), o **limite máximo** dos subsídios dos Vereadores continua a ser **75%** do subsídio dos Deputados Estaduais,⁵ porém variável de acordo com o número de habitantes de cada Município, segundo a tabela abaixo, não podendo o **total da despesa** com a **remuneração dos Vereadores** ultrapassar o montante de **5%** da receita do Município (art. 29, VII):

TAMANHO DO MUNICÍPIO — NÚMERO DE HABITANTES (Y)	SUBSÍDIO MÁXIMO DO VEREADOR — (X)% DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

$y \leq 10.000$	20%
$10.001 \leq y \leq 50.000$	30%
$50.001 \leq y \leq 100.000$	40%
$100.001 \leq y \leq 300.000$	50%
$300.001 \leq y \leq 500.000$	60%
$500.001 \leq y$	75%

Dessa forma, de acordo com as novas regras, o subsídio dos Vereadores será **fixado** pelas respectivas **Câmaras Municipais**, em cada legislatura para a **subsequente**, ou seja, fica vedada tal prática na legislatura vigente. Na verdade, a fixação dos subsídios continuará a ocorrer na legislatura (período de 4 anos = ao mandato) imediatamente anterior à subsequente, porém até os limites máximos já previamente determinados pela EC n. 25/2000, de acordo com o número de habitantes do Município.

Isso porque, conforme já decidiu o STF, a fixação de subsídios na mesma legislatura caracteriza “ato lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à **moralidade administrativa**, patrimônio moral da sociedade” (STF, RE 172.212-6/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2.^a T., DJ 1, de 27.03.1998, p. 19). Ressalte-se que na fixação dos subsídios deverão ser observadas as regras da CF/88, da CE, bem como os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica.

Cabe lembrar, ainda, o subteto determinado pela **Reforma da Previdência** (art. 37, XI, EC n. 41/2003), qual seja, no **Município**, nenhum subsídio poderá ser superior àquele do **Prefeito**. A **Reforma Tributária** (EC 132, de 20.12.2023), contudo, estabeleceu exceção a essa regra ao prescrever que os **servidores de carreira das administrações tributárias** dos Estados, do Distrito Federal e dos **Municípios sujeitam-se ao limite aplicável aos servidores da União**, ou seja, poderão receber acima do referido subteto,

tendo como valor máximo o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF (teto do funcionalismo).

Pois bem, além das regras já mencionadas, a **EC n. 25/2000** trouxe outros limites, estes, todavia, com caráter genérico e que foram reescalados pela **EC n. 58/2009**. De acordo com o art. 29-A, antes de sua alteração pela **EC n. 109/2021**, o **total da despesa** do Poder Legislativo Municipal, **incluídos** os subsídios dos Vereadores e **excluídos** os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais indicados na tabela a seguir, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5.º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

TAMANHO DO MUNICÍPIO — NÚMERO DE HABITANTES (Y)	O TOTAL DA DESPESA NÃO PODE ULTRAPASSAR OS SEGUINTE PERCENTUAIS (SOBRE O SOMATÓRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS NO § 5.º DO ART. 153 E NOS ARTS. 158 E 159, EFETIVAMENTE REALIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR)
$y \leq 100.000$	7%
$100.001 \leq y \leq 300.000$	6%
$300.001 \leq y \leq 500.000$	5%
$500.001 \leq y \leq 3.000.000$	4,5%
$3.000.001 \leq y \leq 8.000.000$	4%
$8.000.001 \leq y$	3,5%

IMPORTANTE: a **EC n. 109/2021**, derivada da apelidada “PEC Emergencial”, mantendo os percentuais indicados acima, foi mais restritiva, já que passou a colocar dentro dos limites **os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas** (que eram excluídos na redação dada pela EC n. 25/2001).

Essa nova limitação prevista no art. 29-A, contudo, entra em vigor a partir do início da primeira legislatura municipal, após a data de publicação da EC (art. 7.º).

Além desses limites, o § 1.º do art. 29-A, também acrescentado, estatui que a Câmara Municipal não gastará mais de **70%** de sua **receita** com a **folha de pagamentos**, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, ou seja, a remuneração de todo o pessoal da Câmara dos Vereadores. O desrespeito a essa regra constitui **crime de responsabilidade** do **Presidente da Câmara Municipal**. Convém lembrar que, dentro dessa filosofia e política de contenção de gastos do Poder Legislativo Municipal, o art. 29, VII, acrescentado pela EC n. 1/92, já estabelecia que o **total da despesa** com a **remuneração dos Vereadores** (parte da **folha de pagamentos**) não poderia ultrapassar o montante de **5%** da receita do Município.

Já o **Prefeito Municipal**, de acordo com as novas regras, além do **crime de responsabilidade** previsto no Decreto-Lei n. 201/67, que será estudado em momento oportuno, praticará **crime de responsabilidade** caso deixe de efetuar o repasse dos valores para o Poder Legislativo, de acordo com as regras do art. 29-A, § 2.º, I, II e III, ou seja: **a)** efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A em análise; **b)** não enviar o referido repasse até o dia **20** de cada mês; **c)** enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária.

Por fim, devemos destacar a *vacatio legis* prevista no art. 3.º, EC n. 25/2000, que, embora tenha sido publicada no *DOU* eletrônico de 15.02.2000, só entrou em vigor em **1.º de janeiro de 2001**, abarcando, portanto, essa nova legislatura que se iniciou na mesma data.

■ 9.1.2.3. *Estrutura do Poder Legislativo distrital*

■ **unicameralismo**: o legislativo distrital é exercido pela **Câmara Legislativa** (art. 32, *caput*), composta pelos Deputados Distritais, que representam o povo do Distrito Federal;

■ **aplicação das características dos Estados:** como determina o art. 32, § 3.º, aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27, ou seja, todas as regras estabelecidas para os Estados valem para o Distrito Federal.

■ 9.1.2.4. *Estrutura do Poder Legislativo dos Territórios Federais*

■ **regra geral:** o art. 33, § 3.º, última parte, determina que a lei disporá sobre as eleições para a **Câmara Territorial** e sua competência deliberativa. Como não existem Territórios Federais (apesar de poderem vir a ser criados), ainda não foi regulamentado esse dispositivo constitucional. Cabe observar que, quando criados, de acordo com o art. 45, § 2.º, cada Território elegerá o número fixo de **4 Deputados Federais**, para compor a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional.

■ 9.2. ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

De acordo com o **art. 48**, CF/88, cabe ao **Congresso Nacional**, com a **sanção do Presidente da República**, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- transferência temporária da sede do Governo Federal;
- concessão de anistia;
- organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios, e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal (*EC n. 69/2012*);
- criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, “b”, já que, quando **vagos** os cargos ou funções públicas, caberá ao Presidente, mediante decreto, dispor sobre a extinção;
- criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública (confira, também, o art. 88, CF/88, alterado pela EC n. 32/2001);
- telecomunicações e radiodifusão;
- matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;

- moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal;
- fixação do subsídio dos Ministros do STF, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I.

Alertamos que, de acordo com o art. 84, VI, “a”, na nova redação dada pela **EC n. 32/2001**, compete privativamente ao **Presidente da República** (cf. parágrafo único do art. 84) dispor, mediante **decreto**, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar o aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos**.

Agora **cuidado**. O **art. 49** trata das matérias de **competência exclusiva** do Congresso Nacional, sendo **dispensada a manifestação do Presidente da República**, através de sanção ou veto (art. 48, *caput*). Como veremos ao comentar as espécies normativas, as atribuições referidas no art. 49 são materializadas por **decreto legislativo**.⁶

Para os concursos públicos, entendemos indispensável o conhecimento das referidas matérias, fazendo-se um contraponto em relação àquelas do art. 48.

Dessa forma, é da **competência exclusiva do Congresso Nacional** (art. 49):

- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar (cf. LC n. 90/97, com as alterações introduzidas pela LC n. 149/2015);
- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
- mudar temporariamente sua sede;
- fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;
- fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I;
- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
- apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
- escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
- aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
- autorizar referendo e convocar plebiscito;
- autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

■ 9.3. CÂMARA DOS DEPUTADOS

■ 9.3.1. Aspectos fundamentais

■ **composição:** a Câmara dos Deputados é composta por **representantes do povo**,⁷ ou seja, por Deputados Federais eleitos que manifestam a vontade popular. Lembramos que todo o poder emana do povo, que o exerce, ou de forma direta (ex.: plebiscito, referendo e iniciativa popular — soberania popular, art. 14, I-III), ou por meio de seus representantes, que em âmbito federal são os Deputados Federais (cabe repetir que, nas outras esferas, o Poder Legislativo é **unicameral**, sendo eleitos, também, pelo povo, para representá-los, os Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores, respectivamente para o legislativo estadual, do Distrito Federal e municipal). Por fim, destacamos que cada Território Federal, quando criado, elegerá o número **fixo** de **4** Deputados Federais, independentemente da população, não havendo representação no Senado Federal, já que não terão autonomia federativa, sendo simples descentralização da União — autarquia federal;

■ **eleição:** os Deputados Federais são eleitos pelo povo segundo o **princípio proporcional**. Ou seja, “o número total de Deputados, bem como a representação por Estados e pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcionalmente à **população**,⁸ procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de **oito** ou mais de **setenta** Deputados” (art. 45, § 1.º);

■ **número de Deputados Federais:** como referido, o número de Deputados Federais será proporcional à população de cada Estado e do Distrito Federal, não podendo cada Estado e o DF ter menos que **8**, nem mais que **70** Deputados Federais. Relembrar que os Territórios Federais, se vierem a ser criados, elegerão um número **fixo** de **4** Deputados — art.

45, § 2.º. O número total de Deputados Federais foi fixado pela LC n. 78/93 em **513**;

A Constituição foi explícita ao determinar que a **lei complementar** deverá estabelecer não apenas o **número total de deputados federais** (no caso, como citado, fixado em 513), como, também, a **representação por Estado e pelo DF**. Ocorre que a LC n. 78/93, ao disciplinar o assunto, em seu art. 1.º, parágrafo único, **delegou** a segunda obrigação (fixação da representação por Estado e pelo DF) ao **TSE**.

O STF entendeu essa delegação como **inconstitucional**. Trata-se de critério envolvendo **juízo de valor** a ser determinado **necessariamente** pelo **Parlamento**, não se admitindo a transferência dessa atribuição para o TSE ou para qualquer outro órgão. Na mesma assentada, por conseguinte, os Ministros declararam a inconstitucionalidade da **Res. n. 23.389/2013 do TSE**, que disciplinava o tamanho das bancadas para cada Estado e para o DF.⁹

Em importante julgado, o STF declarou a “mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do § 1.º do art. 45 da CF (**revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado/população**), fixando prazo até 30.06.2025 para que seja sanada a omissão, pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes, e entendeu que, após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao TSE determinar, até 1.º.10.2025, o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais (CF, arts. 27, *caput*, e 32, § 3.º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição e o número total de parlamentares previsto na LC n. 78/1993, valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022 e da metodologia utilizada por ocasião da edição da Resolução-TSE 23.389/2013” (**ADO 38**, j. 28.08.2023, *DJE* de 09.10.2023).

■ **mandato:** o mandato de cada Deputado é de **4 anos**, período esse correspondente à **legislatura** (art. 44, parágrafo único);

■ **renovação dos Deputados:** a cada **4 anos** serão renovados os Deputados, permitida a reeleição;

■ **remuneração:** de acordo com o **DLG n. 172, de 21.12.2022**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49, CF/88, foi fixado em **R\$ 39.293,32**, a partir de **1.º.01.2023**, igualando-se, à época, ao subsídio mensal dos Ministros do STF (cf. *item 9.6* e a Lei n. 13.752/2018, que fixou o teto do funcionalismo no valor de R\$ 39.293,32).

Referido decreto legislativo prescreveu um aumento progressivo do subsídio mensal ao longo do tempo, nos seguintes termos:

■ **R\$ 39.293,32** — a partir de 1.º.01.2023;

■ **R\$ 41.650,92** — a partir de 1.º.04.2023;

■ **R\$ 44.008,52** — a partir de 1.º.02.2024;

■ **R\$ 46.366,19** — a partir de 1.º.02.2025.

Deve-se observar, então, que, em janeiro de 2023, o valor se igualou ao teto do funcionalismo então vigente à época e que, a partir de 1.º.04.2023, em tese, ficaria acima do limite constitucional, o que, como se sabe, não é permitido.

Apesar de promulgado com essa previsão de aumento acima do teto em 21.12.2022, no mesmo dia, foi aprovado o PL n. 2.438/2022, fixando o subsídio de Ministro do STF em valores sucessivos equivalentes aos indicados acima para os Parlamentares, passando, então, a validar os novos aumentos, tudo conforme a **Lei n. 14.520, de 09.01.2023**, em razão da efetiva sanção ao referido projeto de lei.

■ 9.3.2. **Requisitos para a candidatura dos Deputados Federais**

- **brasileiro nato ou naturalizado** (art. 14, § 3.º, I) → a exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência daquela Casa, consoante estabelece o art. 12, § 3.º, II;
- **maior de 21 anos** (art. 14, § 3.º, VI, “c”);
- **pleno exercício dos direitos políticos** (art. 14, § 3.º, II);
- **alistamento eleitoral** (art. 14, § 3.º, III);
- **domicílio eleitoral na circunscrição** (art. 14, § 3.º, IV);
- **filiação partidária** (art. 14, § 3.º, V).

■ 9.3.3. Competências privativas da Câmara dos Deputados

As matérias de competência privativa¹⁰ dos Deputados Federais estão previstas no art. 51, CF/88, e **não** dependerão de sanção presidencial, nos termos do art. 48, *caput*. Tais atribuições, como veremos ao tratar das espécies normativas, são materializadas por meio de **resoluções**.

Nos termos da Constituição, compete privativamente à **Câmara dos Deputados**:

- autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
- proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
- elaborar seu regimento interno;
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a **iniciativa de lei** para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Em relação ao art. 51, IV, cumpre notar que a Câmara dos Deputados tem competência apenas para a **iniciativa** de projeto de lei que vise à fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços, devendo, necessariamente, depois de aprovada nas duas Casas, a matéria ir à sanção do Presidente da República. Trata-se de **novidade** introduzida pela **EC n. 19/98**, que **retirou** da CD a **competência privativa** para a fixação da referida remuneração.

Devemos alertar que a competência para fixar idêntico **subsídio** para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I, nos termos do **art. 49, VII**, é do **Congresso Nacional**, por **Decreto Legislativo** (cf. *item 9.6*).

■ eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

■ 9.4. SENADO FEDERAL

■ 9.4.1. Aspectos fundamentais

■ **composição:** o Senado Federal é composto por representantes dos **Estados** e do **Distrito Federal**. Quando criados, os Territórios Federais não terão representação no Senado Federal, na medida em que não terão autonomia federativa;

■ **eleição:** os Senadores são eleitos pelo povo segundo o **princípio majoritário**, ou seja, não mais se trata de estabelecer um número proporcional à população, mas, sim, de eleger ao Senado aquele candidato que obtiver nas urnas o maior número de votos;

■ **número de Senadores:** cada Estado e o Distrito Federal **elegerão o número fixo de 3 Senadores**, sendo que cada Senador será eleito com **2 suplentes**;

■ **mandato:** o mandato de cada Senador é de **8 anos**, portanto, duas **legislaturas**;

■ **renovação dos Senadores:** cada Senador eleito cumpre mandato de 8 anos. Cada Estado e o Distrito Federal elegem um número fixo de 3 Senadores, com 2 suplentes cada um. A renovação, porém, dos Senadores eleitos dar-se-á de quatro em quatro anos, na proporção de **1/3** e **2/3**. Vejamos o exemplo: em 1998 foi eleito um Senador que cumprirá mandato de 1999 a 2006. Em 1999, já existiam 2 Senadores eleitos desde 1994 (início do mandato em 1995), ou seja, já tinham cumprido 4 anos do mandato no final de 1998. Como em 1998 foi trocado 1 dos 3, em 2002 eleger-se-ão 2 dos 3 (para começar um novo mandato de 8 anos em 2003). Assim, sempre existirão 3 Senadores, só que a renovação deles se dará a cada 4 anos, por 1 e 2/3;

■ **remuneração:** de acordo com o **DLG n. 172, de 21.12.2022**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49 da Constituição Federal, foi fixado em **R\$**

39.293,32, a partir de **1.º.01.2023**, igualando-se, à época, ao subsídio mensal dos Ministros do STF (cf. *item 9.6*).

Referido decreto legislativo estabeleceu um crescimento escalonado do subsídio dos Parlamentares ao longo do tempo, nos seguintes termos:

- **R\$ 39.293,32** — a partir de 1.º.01.2023;
- **R\$ 41.650,92** — a partir de 1.º.04.2023;
- **R\$ 44.008,52** — a partir de 1.º.02.2024;
- **R\$ 46.366,19** — a partir de 1.º.02.2025.

■ 9.4.2. **Requisitos para a candidatura dos Senadores**

- **brasileiro nato ou naturalizado** (art. 14, § 3.º, I) → a exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência daquela Casa, conforme estabelece o art. 12, § 3.º, III;
- **maior de 35 anos** (art. 14, § 3.º, VI, “a”);
- **pleno exercício dos direitos políticos** (art. 14, § 3.º, II);
- **alistamento eleitoral** (art. 14, § 3.º, III);
- **domicílio eleitoral na circunscrição** (art. 14, § 3.º, IV);
- **filiação partidária** (art. 14, § 3.º, V).

■ 9.4.3. **Competências privativas do Senado Federal**

As matérias de competência privativa¹¹ do Senado Federal estão previstas no art. 52, CF/88, e **não** dependerão de sanção presidencial (art. 48, *caput*) para a sua maturação. Tais atribuições, como veremos ao tratar das espécies normativas, são materializadas através de **resoluções**.

Assim, nos termos da Constituição, compete privativamente ao **Senado Federal**:

■ processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

■ processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (redação dada pela EC n. 45, de 2004)

■ aprovar previamente, por **voto secreto**, após arguição pública, a escolha de: **a)** Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; **b)** Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; **c)** Governador de Território; **d)** Presidente e diretores do Banco Central; **e)** Procurador-Geral da República; **f)** titulares de outros cargos que a lei determinar;

■ aprovar previamente, por **voto secreto**, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

■ autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

■ fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

■ dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

■ dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

■ estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

- suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
- aprovar, por maioria absoluta e por **voto secreto**, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
- elaborar seu regimento interno;
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

Como vimos em relação à Câmara dos Deputados, o Senado Federal, também a partir da **EC n. 19/98**, passou a ter competência **apenas** para a **iniciativa de projeto de lei** para fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços.

Devemos alertar, conforme já visto em relação à Câmara, que a competência para fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I, nos termos do **art. 49, VII**, é do **Congresso Nacional**, por **Decreto Legislativo** (cf. *item 9.6*).

- eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

■ 9.5. QUADRO COMPARATIVO E DELIBERAÇÕES

	SENADO FEDERAL	CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMPOSIÇÃO	■ Representantes dos Estados e do Distrito Federal	■ Representantes do povo
SISTEMA DE ELEIÇÃO	■ Sistema majoritário	■ Sistema proporcional à população de cada Estado e do DF, sendo que os TFs elegerão 4 (art. 45, § 2.º)
NÚMERO DE PARLAMENTARES	■ 3 Senadores por Estado e pelo DF, cada qual com 2 suplentes. Atualmente, 81 Senadores (26 Estados x 3 = 78 + 3 do DF)	■ A LC n. 78/93 fixou em 513 Deputados Federais. Nenhum Estado nem o DF terão menos que 8, nem mais que 70 Deputados. Os Territórios, se criados, elegerão 4 Deputados
MANDATO	■ 8 anos = 2 legislaturas	■ 4 anos = 1 legislatura
RENOVAÇÃO	■ A cada 4 anos, por 1/3 e 2/3, sendo que cada Senador cumpre o mandato de 8 anos	■ A cada 4 anos, sendo que cada Deputado cumpre o mandato de 4 anos
IDADE MÍNIMA (CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE)	■ 35 anos	■ 21 anos

As Casas parlamentares, no exercício de suas atribuições, deliberam por meio de votação, que poderá ser **secreta** ou **ostensiva**, ou seja, pública, por meio do voto “aberto”, prestigiando, neste último caso, a transparência que deve orientar a atuação dos representantes do povo.

O voto secreto é garantia do eleitor. Os parlamentares têm o dever de prestação de contas (**princípio da publicidade**) e, nesse sentido, reforça-se a ideia de votação aberta. Algumas reformas aboliram a votação secreta, mas algumas hipóteses ainda continuam sem a publicidade esperada. Vejamos:

DISPOSITIVO	COMPETÊNCIA / ASSUNTO	VOTAÇÃO
Art. 52, III	■ Senado Federal: aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de: a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; c) Governador de Território; d) Presidente e diretores do Banco Central; e) Procurador-Geral da República; f) titulares de outros cargos que a lei determinar.	SECRETA
Art. 52, IV	■ Senado Federal: aprovar previamente, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.	SECRETA
Art. 52, XI	■ Senado Federal: aprovar, por maioria absoluta, a exoneração, de ofício, do PGR antes do término de seu mandato.	SECRETA
Art. 53, § 2.º (EC n. 35/2001)	■ Casa Legislativa (CD ou SF): resolver sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável de membros do Congresso Nacional.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)
Art. 53, § 3.º (EC n. 35/2001)	■ Casa Legislativa (CD ou SF): sustar o andamento de ação penal contra parlamentar.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)
Art. 55, § 2.º	■ Casa Legislativa (CD ou SF): nos casos dos	OSTENSIVA

(EC n. 76/2013)	incisos I, II e VI, do art. 55, decidir sobre a perda do mandato, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.	(votação pública, ou seja, voto “aberto”)
Art. 66, § 4.º (EC n. 76/2013)	■ Sessão conjunta da CD e do SF: apreciação sobre o veto presidencial apostado a projeto de lei.	OSTENSIVA (votação pública, ou seja, voto “aberto”)

■ 9.6. REMUNERAÇÃO DOS PARLAMENTARES

■ 9.6.1. Subsídio mensal

Vimos que, de acordo com o **DLG n. 172, de 21.12.2022**, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49, CF/88, foi fixado em **R\$ 39.293,32**, a partir de **1.º.01.2023**, igualando-se, assim, à época, ao subsídio de Ministros do STF, estabelecido pela **Lei n. 13.752/2018**, que corresponde ao teto do funcionalismo público.

Referido decreto legislativo estabeleceu um crescimento escalonado do subsídio dos Parlamentares ao longo do tempo, nos seguintes termos:

- **R\$ 39.293,32** — a partir de 1.º.01.2023;
- **R\$ 41.650,92** — a partir de 1.º.04.2023;
- **R\$ 44.008,52** — a partir de 1.º.02.2024;
- **R\$ 46.366,19** — a partir de 1.º.02.2025.

A título de curiosidade, indicamos a evolução do valor estabelecido em 2007, em 2010, depois em 2014 e o atual previsto no decreto legislativo de 2022, com expressivo aumento de 138%, mais do que dobrando o que era pago em 2007. Vejamos:

DLG N. 112/2007 — FIXAVA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.04.2007	DLG N. 805/2010 — FIXAVA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.02.2011	DLG N. 276, DE 18.12.2014 — FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.02.2015	DLG N. 172, DE 21.12.2022 — FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL A PARTIR DE 1.º.01.2023
■ R\$ 16.512,09	■ R\$ 26.723,13	■ R\$ 33.763,00	■ R\$ 39.293,32 (com a previsão de aumento

			conforme indicado acima)
--	--	--	--------------------------

Deve-se deixar claro que a Constituição **não** determina que o subsídio dos Deputados e Senadores seja igual ao dos Ministros do STF. O art. 37, XI, estabelece que o **limite remuneratório** dos parlamentares será igual ao subsídio mensal pago aos Ministros do STF, podendo este ser fixado em valor inferior.

Não somos contra a aproximação ou a equiparação dos subsídios dos ocupantes dos “Poderes”. Apenas achamos que a mesma agilidade deveria ser impressa em relação à aprovação do **salário mínimo**, bem como ao considerável aumento (de 2007 até a última previsão em 2022), buscando-se, ao máximo, atingir, dentro da reserva do possível, os ditames do art. 7.º, IV, CF/88.

Trazemos os valores de outras autoridades para efeitos comparativos, destacando-se que, conforme visto, nos termos da **Lei n. 13.752/2018**, observado o art. 169, CF/88, o teto do funcionalismo (subsídio pago aos Ministros do STF) passou a ser de **R\$ 39.293,22**, sendo que a **Lei n. 14.520, de 09.01.2023**, fixou o subsídio dos Ministros do STF em **R\$ 46.366,19**, implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, da seguinte forma, ou seja, exatamente conforme o aumento previsto para os membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, de acordo com o estabelecido pelo Decreto Legislativo n. 172/2022:

- **R\$ 41.650,92** — a partir de 1.º.04.2023;
- **R\$ 44.008,52** — a partir de 1.º.02.2024;
- **R\$ 46.366,19** — a partir de 1.º.02.2025.

Devemos destacar que o referido DLG n. 172/2022 igualou o subsídio dos membros do Congresso Nacional aos do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, estabelecendo-se um aumento progressivo exatamente conforme os subsídios dos Ministros do STF.

A Constituição não estabelece a igualdade de valores remuneratórios, exceto em relação à fixação dos subsídios para os **Deputados Federais e Senadores**, que deverão ser **idênticos** (art. 49, VII), não havendo essa exigência no que se refere às demais autoridades citadas (art. 49, VIII).

Apesar da regra constitucional, conforme vimos, a partir de **1.º.01.2023**, com os escalonamentos ao longo do tempo, Ministros do STF, Deputados Federais e Senadores da República, Presidente e Vice-Presidente da República, bem como os Ministros de Estado passaram a ter os mesmos valores de subsídios mensais.

A título de curiosidade, vejamos o aumento das remunerações em relação às referidas autoridades, lembrando que o subsídio mensal de Ministro do STF (teto) foi fixado em R\$ 39.293,32 (Lei n. 13.752/2018), sendo que a **Lei n. 14.520, de 09.01.2023**, o fixou em **R\$ 46.366,19**, implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, da forma indicada acima e ao longo do tempo:

AUTORIDADE	ATO NORMA-TIVO ANTERIOR/-VALOR	ATO NORMA-TIVO ANTERIOR/-VALOR	ATO NORMA-TIVO ANTERIOR/-VALOR	ATO NORMA-TIVO EM VIGOR/VALOR
Presidente da República	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 11.420,21	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014 ■ R\$ 30.934,70	■ DLG n. 172/2022 ■ R\$ 39.293,32 — a partir de 1.º.01.2023 ■ R\$ 41.650,92 — a partir de 1.º.04.2023 ■ R\$ 44.008,52 — a partir de 1.º.02.2024 ■ R\$ 46.366,19 — a partir de 1.º.02.2025

Vice-Presidente da República	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 10.748,43	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014 ■ R\$ 30.934,70	■ DLG n. 172/2022 ■ R\$ 39.293,32 — a partir de 1.º.01.2023 ■ R\$ 41.650,92 — a partir de 1.º.04.2023 ■ R\$ 44.008,52 — a partir de 1.º.02.2024 ■ R\$ 46.366,19 — a partir de 1.º.02.2025
Ministros de Estado	■ DLG n. 113/2007 ■ R\$ 10.748,43	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 277/2014 ■ R\$ 30.934,70	■ DLG n. 172/2022 ■ R\$ 39.293,32 — a partir de 1.º.01.2023 ■ R\$ 41.650,92 — a partir de 1.º.04.2023 ■ R\$ 44.008,52 — a partir de 1.º.02.2024 ■ R\$ 46.366,19 — a partir de 1.º.02.2025
Membros do Congresso Nacional	■ DLG n. 112/2007 ■ R\$ 16.512,09	■ DLG n. 805/2010 ■ R\$ 26.723,13	■ DLG n. 276/2014 ■ R\$ 33.763,00	■ DLG n. 172/2022 ■ R\$ 39.293,32 — a partir de 1.º.01.2023 ■ R\$ 41.650,92 — a partir de

				1.º.04.2023
				■ R\$ 44.008,52 — a partir de 1.º.02.2024
				■ R\$ 46.366,19 — a partir de 1.º.02.2025

Finalmente, ressaltamos que os **membros do Congresso Nacional** continuam recebendo, além do subsídio mensal e da ajuda de custo (equivalente ao valor do subsídio) no início e no final do mandato, outros valores, como a cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP), verba de gabinete, auxílio-moradia, fornecimento de jornais, revistas e publicações técnicas, serviços gráficos, passagens aéreas, atendimento médico e odontológico etc.¹²

A **natureza jurídica** dessas verbas deveria ser melhor estudada para verificar se alguma delas tem essência de remuneração, gerando problemas com a regra do teto fixada no art. 37, XI (já que, conforme estudamos, o subsídio mensal dos parlamentares, além dessas outras verbas, deve respeitar o teto do funcionalismo. Para conhecimento, há entendimento de que incide imposto de renda sobre o total da remuneração do deputado, inclusive sobre o auxílio-moradia, quando pago em espécie).

■ 9.6.2. Verba indenizatória: dever de transparência

De acordo com o art. 1.º, *caput*, do *Ato da Comissão Diretora n. 3/2003 do Senado Federal*, a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar destina-se ao pagamento de despesas mensais realizadas pelos Senadores com aluguel — de imóvel, de veículos ou de equipamentos — com material de expediente para escritório, com locomoção e com outras despesas diretas e **exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar**.

O **dever** de apresentar os **documentos comprobatórios** das despesas existe desde a publicação do *Ato da Comissão Diretora n. 3/2009*.

A orientação, sem dúvida, direciona-se para os Deputados Federais, destacando-se o *Ato da Mesa n. 43/2009*, que institucionaliza a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) naquela Casa.

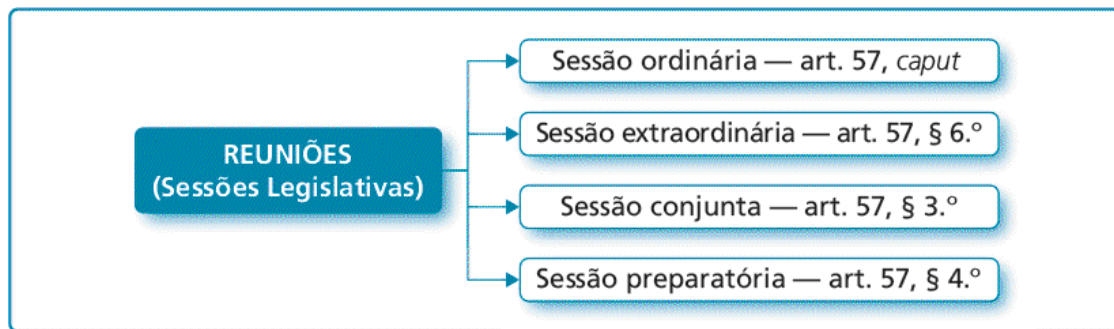
Isso posto, passamos a analisar uma situação concreta envolvendo a negativa de fornecimento dessas verbas pelo Senado Federal para um jornal de grande circulação.

Trata-se do **MS 28.178**, no qual a Empresa *Folha da Manhã S/A* (editora do jornal *Folha de S. Paulo*) solicitou o fornecimento de informações sobre a **verba indenizatória** dos Senadores no período de setembro a dezembro de 2008. O ato coator se caracterizava pela negativa de fornecimento dessas informações sob o argumento de que estão acobertadas pelo sigilo. Apesar da regra atual que consagra o dever de publicidade, na situação concreta dos autos não havia previsão de prestar as informações durante o período em discussão no citado mandado de segurança.

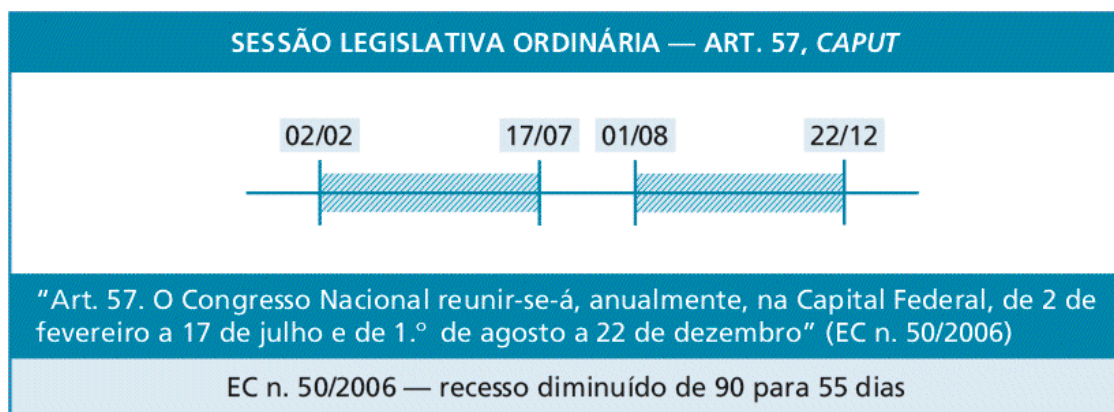
O voto do Min. Roberto Barroso mostrou-se bastante adequado. Conforme divulgado, a **natureza pública** dessa verba “estaria presente tanto na fonte pagadora — o Senado Federal — quanto na finalidade, vinculada ao exercício da representação popular. Nesse contexto, **a regra geral seria a publicidade** e decorreria de um conjunto de normas constitucionais, como o **direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos** (CF, art. 5.º, XXXIII) — especialmente no tocante à documentação governamental (CF, art. 216, § 2.º) —, o **princípio da publicidade** (CF, art. 37, *caput* e § 3.º, II) e o **princípio republicano** (CF, art. 1.º), do qual se originariam os **deveres de transparência e prestação de contas**, bem como a possibilidade de responsabilização ampla por eventuais irregularidades. Recordou que o art. 1.º, parágrafo único, da CF enuncia que ‘todo o poder emana do povo’. Assim, os órgãos estatais teriam o dever de esclarecer ao seu mandante, titular do poder político, como seriam usadas as verbas arrecadadas da sociedade para o exercício de suas atividades. Observou que a Constituição ressaltaria a regra da publicidade apenas em relação às informações cujo

sigilo fosse imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5.º, XXXIII, parte final) e às que fossem protegidas pela inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CF, art. 5.º, X, c/c art. 37, § 3.º, II). Por se tratar de situações excepcionais, **o ônus argumentativo de demonstrar a caracterização de uma dessas circunstâncias incumbiria a quem pretendesse afastar a regra geral da publicidade**” (*Inf. 770/STF*). Nesses termos, em **04.03.2015**, o Plenário do STF concedeu a ordem obrigando a autoridade impetrada a fornecer à impetrante cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória por Senadores da República referentes ao período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2008 (*Inf. 776/STF*).

■ 9.7. DAS REUNIÕES



■ 9.7.1. Sessão legislativa ordinária



O art. 57, *caput*, estabelece, nos termos da redação conferida pela EC n. 50, de 14.02.2006, que o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1.º de agosto a 22 de dezembro**. Nesse período, chamado de **sessão legislativa**, os parlamentares se reúnem **ordinariamente**.

Fora desse período, ou seja, de **18 a 31 de julho** e de **23 de dezembro a 1.º de fevereiro**, temos o **recesso parlamentar**, e, havendo necessidade, os parlamentares serão convocados **extraordinariamente**. Como veremos

abaixo ao tratar das comissões, durante o recesso parlamentar haverá uma **Comissão representativa do Congresso Nacional**, com atribuições definidas no regimento comum (art. 58, § 4.º).

Sem dúvida, essa primeira novidade trazida pela EC n. 50/2006, qual seja, a redução do recesso parlamentar de 90 para 55 dias, objetiva atender aos anseios e insatisfações da sociedade.

Deve-se notar que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2.º).

Por fim, tendo definido o que venha a ser **sessão legislativa ordinária** (reunião anual em Brasília do Congresso Nacional, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro), bem como **legislatura** (período de 4 anos que corresponde ao mandato dos Deputados Federais), conclui-se que cada **legislatura** é composta por 4 **sessões legislativas ordinárias**.

■ 9.7.2. Hipóteses de convocação extraordinária

A convocação extraordinária será feita, de acordo com o **art. 57, § 6.º**:

■ pelo **Presidente do Senado Federal**: nas hipóteses de decretação de estado de defesa; decretação de intervenção federal; pedido de autorização para a decretação de estado de sítio; e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;

■ pelo **Presidente da República**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

■ pelo **Presidente da Câmara dos Deputados**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006);

■ pelo **Presidente do Senado Federal**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n.

50/2006);

■ por **requerimento da maioria dos membros de ambas as casas**: em caso de urgência ou interesse público relevante e sempre com a **aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional (EC n. 50/2006).

Importante observar que, na **sessão legislativa extraordinária**, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8.º do art. 57, sendo **vedado**, ainda, o pagamento de **parcela indenizatória**, em razão da convocação extraordinária (cf. art. 57, § 7.º).

Como se percebe, a **EC n. 50/2006**, também respondendo às críticas da sociedade que condenava, com rigor, o pagamento de parcela indenizatória em valor não superior ao do subsídio mensal, em ato moralizador, **extinguiu o pagamento de qualquer valor extra** em caso de convocação extraordinária.

A vedação contida no art. 57, § 7.º, deve ser entendida como de **reprodução obrigatória** para os parlamentares dos Estados-Membros (art. 27, § 2.º, CF/88¹³) (nesse sentido, cf. **ADPF 836**, j. 03.08.2021) e do DF (art. 32, § 3.º, CF/88¹⁴) e, em nosso entender, também de observância compulsória para os parlamentares municipais, tendo em vista o princípio da **moralidade da legislação** e, acima de tudo, da **simetria**.¹⁵

Nessa linha de moralização, o Congresso Nacional já havia **abolido** o pagamento da **ajuda de custo** durante a convocação extraordinária, mediante alteração do *caput* e revogação do § 1.º do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95 pelo Decreto Legislativo n. 1/2006.

Mas atenção: nos termos do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95, continua devida ao parlamentar, no início e no final previstos para a **sessão legislativa ordinária**, **ajuda de custo** equivalente ao valor da remuneração, ficando vedado o seu pagamento, contudo, na sessão legislativa extraordinária.

A **ajuda de custo** destina-se, a teor do **revogado** § 1.º do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95, à compensação de despesas com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa.

Portanto, com a novidade trazida pelo Decreto Legislativo n. 1/2006 e pela EC n. 50/2006, durante a convocação extraordinária, **não mais cabe o pagamento de ajuda de custo**, nem mesmo **o pagamento de qualquer parcela indenizatória** em razão da convocação. No entanto, em consonância com a nova redação conferida ao *caput* do art. 3.º do Decreto Legislativo n. 7/95 (pelo Decreto Legislativo n. 1/2006), ainda persiste o pagamento de **ajuda de custo** durante a **sessão legislativa ordinária**.

Excepcionando a regra geral do art. 57, § 7.º, que limita o Congresso Nacional, na sessão legislativa extraordinária, a deliberar somente sobre a matéria para a qual foi convocado, a **EC n. 32, de 11.09.2001**, trouxe uma única exceção, qual seja, a possibilidade de apreciação de **medidas provisórias** que estiverem em vigor na data da referida convocação extraordinária.

Assim, de acordo com o art. 57, § 8.º, acrescentado, “havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas **automaticamente incluídas na pauta da convocação**”.

■ 9.7.3. Reunião em sessão conjunta

Em determinadas hipóteses, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em **sessão conjunta**. Isso se dará, entre outros casos previstos na Constituição, para (cf. o art. 57, § 3.º):

- I — inaugurar a sessão legislativa;
- II — elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- III — receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- IV — conhecer do veto e sobre ele deliberar.

■ 9.7.4. Sessão preparatória e Mesas Diretoras

Não obstante já tenhamos observado que a sessão legislativa ordinária só começa em **2 de fevereiro**, cada uma das Casas reunir-se-á em **sessões preparatórias**, a partir de **1.º de fevereiro**, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 anos, **vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente** (nesse caso, o recesso parlamentar será de **54** dias e não **55**, já que o Congresso Nacional reunir-se-á, **ordinariamente**, a partir de 1.º de fevereiro).

Observa-se, portanto, que em uma **legislatura**, qual seja, no período de **4 anos** (art. 44, parágrafo único), haverá uma eleição no primeiro biênio e uma outra no segundo biênio.

Explicitando, **legislatura** é o período de 4 anos que corresponde ao mandato parlamentar e que se inicia com a posse em 1.º de fevereiro do ano seguinte ao das eleições e vai até a posse dos novos parlamentares eleitos nas eleições subsequentes.

O Parlamento, ao analisar a vedação expressa do art. 57, § 4.º, afastou a proibição de recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente quando se tratasse de **legislaturas diferentes**.

Nesse sentido, o art. 5.º, § 1.º, *RICD*, é expresse ao estabelecer **não ser considerada recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas**. No mesmo sentido, o Parecer n. 555, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal.

Para se ter um exemplo, dentre tantos outros, recordamos a recondução do Senador Renan Calheiros, reeleito presidente do Senado Federal para o biênio 2015-2016, após já ter sido Presidente da Casa e, portanto, da Mesa, no biênio anterior.

Essa matéria foi apreciada pelo STF no julgamento da **ADI 6.524**, que, por 6 x 5, manteve o entendimento estabelecido pelas Casas legislativas. Os 5 Ministros vencidos, na linha do voto do Min. Relator Gilmar Mendes,

propunham uma *delicada* mutação constitucional do referido dispositivo para se permitir a reeleição inclusive na mesma legislatura. Essa interpretação não vingou (j. 15.12.2020, *DJE* de 06.04.2021).

As teses propostas pelo Min. Barroso descrevem a posição da Corte:

■ “1. Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, **dentro da mesma legislatura**. Eventual reconhecimento de uma mutação constitucional tem como limite as possibilidades semânticas do texto.”

■ “2. Não viola a Constituição a interpretação que vem sendo dada pelo Congresso Nacional de admitir a recondução em caso de (...) eleição ocorrida em **nova legislatura**.”

Devemos assinalar que o STF, em outros julgamentos, sustentou a não incidência do princípio da simetria para a norma do art. 57, § 4.º, em análise. Apesar disso, admitiu a reeleição para os membros das **Mesas das Assembleias estaduais** uma única vez, estabelecendo-se as seguintes teses:

“(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura;

(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e

(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07.01.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (**ADI 6.674**, j. 19.12.2023 — cf. ADIs 6.684/ES, 6.707/ES, 6.709/TO e 6.710/SE, j. 21.09.2021, *DJE* de 17.12.2021).

A Corte, em julgamentos subsequentes, confirmou a não obrigatoriedade da reprodução da referida regra do art. 57, § 4.º, em âmbito estadual. Contudo, **proibiu a reeleição em número ilimitado** para os mesmos cargos em mandatos consecutivos em âmbito estadual por violar os **princípios republicano e democrático**, os quais “exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato”, devendo ser observada a regra do art. 14, § 5.º, que permite a reeleição por uma única vez (**ADI 6.716**, Rel. Min. Edson Fachin, voto fls. 6-7, j. 10 a 17.12.2021).

Esse entendimento já havia sido estabelecido pelo STF no julgamento das **ADIs 6.720, 6.721 e 6.722**, tendo sido fixada a seguinte tese de julgamento:

■ “1. O art. 57, § 4.º, da CF, **não é norma de reprodução obrigatória** por parte dos Estados-membros”.

■ “2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes **permitida uma única recondução**” (Sessão Virtual de 27.09.2021, *DJE* de 17.12.2021).

As Mesas Diretoras de cada Casa exercem funções administrativas (de polícia, execução e administração), devendo, no tocante à sua constituição, ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa (art. 58, § 1.º).

Em relação ao Poder Legislativo federal, identificamos a Mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e a Mesa do Congresso Nacional, sendo a esta última, de acordo com o art. 57, § 5.º, estabelecidas algumas regras:

■ **presidência da Mesa do Congresso Nacional:** Presidente do Senado Federal;

■ **demais cargos da Mesa do Congresso Nacional:** serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Dessa forma, se a presidência é ocupada por um membro do Senado Federal (no caso o Presidente do Senado Federal, conforme a regra explícita do art. 57, § 5.º), a 1.ª Vice-presidência será ocupada por um membro da Câmara; o 2.º Vice-presidente do Senado; o 1.º Secretário por um membro da Câmara; o 2.º Secretário por um do Senado; o 3.º Secretário da Câmara e o 4.º Secretário do Senado.

■ 9.8. DAS COMISSÕES PARLAMENTARES



Imagem sem descrição.

José Afonso da Silva define as comissões parlamentares como “organismos constituídos em cada Câmara, composto de número geralmente restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres”.¹⁶

De acordo com o art. 58, as comissões podem ser **permanentes** ou **temporárias** e serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno do Congresso Nacional e de cada Casa, já que existirão comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Estabelece o art. 58, § 1.º, que na constituição das Mesas e de cada Comissão é assegurada, tanto quanto possível, a **representação proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

Passemos, então, a examinar cada uma delas.

■ 9.8.1. Comissão temática ou em razão da matéria (permanentes)

As comissões temáticas estabelecem-se em razão da matéria e são **permanentes** (cf. art. 72 do Regimento Interno do Senado Federal e art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados).

De acordo com o art. 58, § 2.º, CF/88, compete-lhes:

- I — discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
- II — realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- III — convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições, sob pena de cometer crime de responsabilidade (art. 50);
- IV — receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- V — solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI — apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

■ 9.8.2. Comissão especial ou temporária

As comissões especiais são criadas para apreciar uma matéria específica, extinguindo-se com o término da legislatura ou cumprida a finalidade para a qual foram criadas.¹⁷

■ 9.8.3. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

■ 9.8.3.1. Regras gerais

As regras sobre as CPIs estão disciplinadas no art. 58, § 3.º, CF/88, na Lei n. 1.579/52 (alterada pelas Leis ns. 10.679/2003 e 13.367/2016), na Lei n. 10.001/2000 (na parte em que o STF não nulificou, quais sejam, os arts. 1.º e 3.º — cf. ADI 5.351, j. 21.06.2021), na LC n. 105/2001 e nos Regimentos Internos das Casas (arts. 145 a 153, *RISF*, e arts. 35 a 37, *RICD*).

De acordo com as definições normativas, pode-se afirmar que as CPIs são **comissões temporárias**, destinadas a **investigar fato certo e determinado**.

Entendemos que esse papel desempenhado de **fiscalização e controle** da Administração é verdadeira **função típica** do **Poder Legislativo**, tanto que o art. 70, *caput*, CF/88, estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante **controle externo**, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

De acordo com o art. 49, X, CF/88, é **competência exclusiva do Congresso Nacional** fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração

indireta.

Ainda, a função fiscalizadora exercida pelo Poder Legislativo consagra a perspectiva dos **freios e contrapesos**, muito bem delimitada na Constituição de 1988.

Nesse sentido, bem observou a Min. Cármen Lúcia: “no desenho constitucional brasileiro, as comissões parlamentares de inquérito são manifestação da função fiscalizatória do Congresso Nacional sobre a administração pública, instrumentalizando, assim, uma das facetas do sistema de freios e contrapesos, essencial à Democracia” (**ADI 5.351**, j. 21.06.2021, fls. 22 e 23 do acórdão).

■ 9.8.3.2. *Criação*

De acordo com o art. 58, § 3.º, CF/88, as CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de **1/3** da totalidade de seus membros.

Vale dizer, as CPIs somente serão criadas por requerimento de, no mínimo, **171** Deputados (1/3 de 513) e de, também, no mínimo, **27** Senadores (1/3 de 81), em conjunto ou separadamente.

Para sua criação, portanto, 3 **requisitos** indispensáveis deverão ser observados:

■ requerimento subscrito por, no mínimo, **1/3** da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Ou seja, se a **CPI for da Câmara dos Deputados**, a Constituição exige o requerimento de ao menos **171 Deputados**; se do **Senado Federal**, **27 Senadores**. Agora, se for uma **CPMI** (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), 171 Deputados e 27 Senadores, no mínimo, deverão subscrever o requerimento (após o requerimento observando os requisitos constitucionais, a CPMI terá o número de membros fixado no ato da sua criação, devendo ser igual a participação

de Deputados e Senadores, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária — art. 21, parágrafo único, do Regimento Comum do Congresso Nacional — RCN n. 7/70);

■ indicação, com precisão, de **fato determinado** a ser apurado na investigação parlamentar;

■ indicação de **prazo certo** (temporariedade) para o desenvolvimento dos trabalhos.

■ 9.8.3.3. *Direito público subjetivo das minorias*

A discussão sobre a temática do **direito público subjetivo das minorias** surgiu no bojo da *CPI do Apagão Aéreo*, instalada para investigar as causas, as consequências e os responsáveis pela crise ocorrida no setor aéreo brasileiro, observados os requisitos do art. 58, § 3.º.

Após ter sido efetivamente instalada, o Plenário da Câmara dos Deputados desconstituiu o ato de criação da CPI. Contra esse ato da Mesa e do presidente da Câmara dos Deputados, foi impetrado mandado de segurança, e o STF, seguindo o voto do Min. Celso de Mello, determinou a instauração da CPI, sob pena de violação do **direito público subjetivo das minorias**, mesmo contra a vontade da maioria da Casa. Verdadeiro **direito de oposição**, reconhecido, inclusive, às minorias (**MS 26.441**, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.04.2007, Plenário, *DJE* de 18.12.2009).

Nesse sentido, conforme estabeleceu o Min. Barroso em liminar referendada pelo Pleno do STF ao analisar a criação da *CPI da Pandemia Covid-19*, “a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos 3 requisitos previstos no art. 58, § 3.º, da Constituição:

- (i) o requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas;
- (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e
- (iii) a definição de prazo certo para sua duração.

Atendidas as exigências constitucionais, **impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito**, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas

legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 1.º.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007” (**MS 37.760 MC-REF**, j. 14.04.2021, *DJE* de 09.08.2021).

■ 9.8.3.4. **Objeto**

A CPI, ao ser instaurada, deve ter por **objeto** a apuração de **fato determinado** (cf. HC 71.039).

Considera-se fato determinado, de acordo com o art. 35, § 1.º, *RICD*, o acontecimento de relevante interesse para a **vida pública** e a **ordem constitucional, legal, econômica e social do País**, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão, **não** podendo, portanto, a CPI ser instaurada para apurar fato **exclusivamente privado** ou **de caráter pessoal**.

Nesse sentido, diante de um **mesmo fato**, pode ser criada CPI na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em conjunto, a CPMI (comissão parlamentar mista de inquérito), ou, ainda, a investigação poderá ser conduzida pelo Judiciário, por outros órgãos ou, até, por CPIs nos outros entes federativos, se houver interesse comum, devendo cada qual atuar nos limites de sua competência.

O art. 146, *RISF*, estabelece, contudo, que não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes:

- à Câmara dos Deputados;
- às atribuições do Poder Judiciário;
- aos Estados.

Observa-se, também, a possibilidade de instauração de **CPIs simultâneas** dentro de uma **mesma Casa**, sendo que o *Regimento Interno da Câmara dos Deputados*, no seu art. 35, § 4.º, determinou o **limite** de 5, restrição essa declarada **constitucional** pelo STF por estar em consonância com os incs. III e IV do art. 51, CF/88, que conferem à Câmara “a

prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua organização. Tais competências são um poder-dever que permite regular o exercício de suas atividades constitucionais” (ADI 1.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 19.10.2000).

■ 9.8.3.5. *Prazo*

A CPI, por ser uma comissão **temporária**, deve ser criada por **prazo certo**.

A teor do art. 35, § 3.º, *RICD*, a CPI na Câmara, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade do prazo, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

Estabelecendo requisito temporal, o art. 76, *RISF*, por sua vez, prescreve que as **comissões temporárias**, e, no caso, a CPI é uma comissão temporária, se extinguem:

- pela conclusão da sua tarefa; ou
- ao término do respectivo prazo; e
- ao término da sessão legislativa ordinária.

Os §§ 1.º e 4.º do art. 76 estabelecem, contudo, ser lícito à comissão que não tenha concluído a sua tarefa requerer a **prorrogação** do respectivo prazo, sendo que, no caso da CPI, essa prorrogação **não** poderá ultrapassar o período da **legislatura** em que for criada.

■ 9.8.3.6. *Poderes*

As CPIs terão poderes de **investigação**, próprios das autoridades **judiciais**, além de outros previstos nos regimentos internos das Casas.¹⁸

A comissão parlamentar de inquérito realiza, assim, verdadeira **investigação**, materializada no **inquérito parlamentar**, que se qualifica como um “... procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria” (MS 23.652, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2000).

Em razão dos **poderes instrutórios** que lhe foram conferidos, à semelhança dos **juízos de instrução**, o art. 2.º da Lei n. 1.579/52, na redação dada pela Lei n. 13.367/2016, estabelece que, no exercício de suas atribuições, poderão as CPIs determinar diligências que repute necessárias e requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença.

Consoante já decidiu o STF, a CPI pode, por **autoridade própria**, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por **decisão fundamentada** e **motivada**, observadas todas as formalidades legais, determinar:

- **quebra do sigilo fiscal;**
- **quebra do sigilo bancário;**
- **quebra do sigilo de dados;** neste último caso, destaque-se o **sigilo dos dados telefônicos**.¹⁹

Explicitando este último ponto, conforme se destaca abaixo, dentro da ideia de **postulado de reserva constitucional de jurisdição**, o que a CPI **não** tem é a competência para **quebra do sigilo da comunicação telefônica** (interceptação telefônica).

No entanto, pode a CPI requerer a quebra de **registros telefônicos pretéritos**, ou seja, os dados de conversas já ocorridas em determinado período.

Convém destacar o § 1.º do art. 4.º da **LC n. 105/2001**,²⁰ ao estabelecer que as **CPIs**, no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, **obterão** as **informações** e os **documentos sigilosos** de que necessitarem **diretamente** das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, devendo referidas solicitações ser previamente aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito.

Dentro do conceito de poder investigatório da CPI, ela ainda tem o direito de:

■ **ouvir testemunhas, sob pena de condução coercitiva:** as testemunhas prestarão compromisso de dizer a verdade, sob pena de **falso testemunho**. A elas é também assegurada a prerrogativa contra a autoincriminação, garantindo-se o **direito ao silêncio**, ou quando deva guardar sigilo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho (arts. 207, CPP, e art. 388, II, CPC/2015 — cf. HC 79.598/STF);

Devemos alertar que o STF, por 6 x 5, julgou procedentes as **ADPFs ns. 395 e 444**, “para pronunciar a não recepção da expressão ‘**para o interrogatório**’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a **incompatibilidade** com a Constituição Federal da **condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Deixando claro o objeto da controvérsia, esclarecemos que referido julgado analisou **apenas** a condução coercitiva de investigados ou réus — perante a autoridade policial ou judicial —, **para o interrogatório** (direito ao silêncio, presunção de não culpabilidade, liberdade de locomoção, dignidade da pessoa humana) e não para outras situações de condução coercitiva, como no caso de testemunhas (inclusive perante a CPI), ou, ainda, de investigados

ou réus para atos diversos do interrogatório, por exemplo, o reconhecimento, que continuam sendo admitidos.

Em momento seguinte, o art. 10 da **Lei n. 13.869/2019** (*Lei de Abuso de Autoridade*) prescreveu o seguinte **crime**: “decretar a **condução coercitiva** de **testemunha** ou **investigado manifestamente descabida** ou **sem prévia intimação de comparecimento ao juízo**”.

■ **ouvir investigados ou indiciados**: a CPI, contudo, deverá respeitar, retome-se, o **direito ao silêncio do investigado ou indiciado**, que poderá deixar de responder às perguntas que possam incriminá-lo (HC 80.584-PA, Rel. Min. Néri da Silveira, 08.03.2001).

Esse limite ganhou relevância em razão das diversas CPIs para a investigação dos supostos escândalos que envolveram o governo Lula, principalmente durante os meses de julho e agosto de 2005, tendo sido expedidos diversos “salvo-condutos” possibilitando ao requerente, no interrogatório da CPI, ser tratado como **investigado**.

Para se ter um exemplo, citamos o voto da Min. Ellen Gracie, que concedeu *habeas corpus* preventivo ao publicitário *Marcos Valério Fernandes de Souza* para depor na *Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios*, na Câmara dos Deputados, na condição de investigado.

Argumenta a Ministra que “... às Comissões Parlamentares de Inquérito poder-se-ão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados da **garantia constitucional da não autoincriminação**, que tem sua manifestação mais eloquente no **direito ao silêncio dos acusados** (HC 79.812, Celso de Mello; HC 79.244, Sepúlveda Pertence; HC 84.335, Ellen Gracie; HC 83.775, Joaquim Barbosa; HC 85.836, Carlos Velloso). Diante do exposto, defiro a liminar para que o paciente seja dispensado de firmar termo d'e compromisso legal de testemunha, ficando-lhe assegurado o direito de se calar sempre que a resposta à pergunta, a critério dele, paciente, ou de seu advogado, possa atingir a garantia constitucional de não autoincriminação. Comunique-se com

urgência. Expeça-se salvo-conduto. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2005” (HC 86.232/DF, *DJ* de 1.º.08.2005, p. 39).

Nesse sentido, destacamos os salvo-condutos expedidos em favor do ex-tesoureiro e do ex-secretário-geral do Partido dos Trabalhadores (PT), Delúbio Soares e Silvio José Pereira, para deporem na *CPI Mista dos Correios*, na condição de investigados (HC 86.319).

Outrossim, muito bem fundamentada a decisão proferida pelo Min. Peluso ao deferir liminar requerida em favor de Waldomiro Diniz, para que, sempre que convocado a depor perante a *Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos*, tenha o “... direito de permanecer em **silêncio** se a resposta à pergunta implicar risco de autoincriminação. Além disso, ele poderá ser **acompanhado de advogado** e terá garantido o **direito de não ser preso ao invocar o direito constitucional de não se autoincriminar**” (*Notícias STF*, 10.08.2005, HC 86.426).

Analisando a doutrina alemã, também assim a decisão do Min. Gilmar Mendes, que, em sede de cautelar, expediu salvo-conduto para o presidente do Grupo Opportunity, Daniel Valente Dantas, permanecer calado durante depoimento à *CPMI dos Correios* sobre os fatos que possam implicar a sua autoincriminação (*Notícias STF*, 20.09.2005, HC 86.724).

■ E como fica a situação de esposa de investigado?

Tivemos um caso concreto analisado pelo STF no **HC 86.355**, impetrado por Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, esposa do publicitário Marcos Valério. Segundo noticiado, o Min. Jobim “... afirmou que Renilda Souza deve atender à convocação da CPMI, nos dias e horas marcados, mas não é obrigada a assinar o compromisso de dizer a verdade. No entanto, ela deverá ‘responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas’. O Ministro observou que, de acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro (artigos 203, 206 e 208 combinados), **a testemunha não pode se eximir da obrigação de depor**, mas, sendo **cônjuge** de um dos **investigados, não é obrigada a firmar o compromisso de dizer a verdade**” (*Notícias STF*, 25.07.2005, em que se pode verificar a íntegra da decisão).

■ E como fica a situação do Presidente da República (e dos Governadores de Estado)?

A Constituição prescreve que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão **convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República** ou o **Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços** para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando **crime de responsabilidade** a ausência sem justificção adequada (art. 50, *caput*, na redação dada pela **EC n. 132/2023** — Reforma Tributária).

Assim, não se estabelece a possibilidade de se convocar o Presidente da República, sendo esse silêncio uma **regra de limitação**. Conforme observou o Min. Gilmar Mendes, essa disposição “procura tornar operacional o exercício do Poder Executivo, que ficaria deveras afetado com seguidas convocações do Presidente da República para prestar esclarecimentos nas várias Comissões existentes na Câmara dos Deputados e Senado Federal” (ADPF 848 MC-REF — fls. 71 do acórdão).

Nesse sentido, conforme estabeleceu o STF, “o Chefe do Poder Executivo da União é titular de prerrogativas institucionais assecuratórias de sua autonomia e independência perante os demais Poderes. Além da imunidade formal (CF, art. 86, § 3.º) e da irresponsabilidade penal temporária (CF, art. 86, § 4.º), a Constituição Federal isenta-o da obrigatoriedade de depor ou prestar esclarecimentos perante as Casas Legislativas da União e suas comissões, como emerge da dicção dos arts. 50, *caput* e § 2.º, e 58, § 2.º, III, da Constituição Federal, **aplicáveis, por extensão, aos Governadores de Estado**” (ADPF 848 MC-REF, Pleno, j. 28.06.2021, DJE de 21.10.2021. Referida ação foi ajuizada por governadores de 18 estados e do Distrito Federal contra atos da **CPI da Pandemia**. Tendo em vista o encerramento dos trabalhos da CPI, referida ação restou prejudicada, tendo sido extinta em razão da perda superveniente de objeto — 04.07.2022).

Lembramos, ainda, o dever de a CPI permitir a presença de **advogados**, exercendo a defesa técnica, com todas as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da Advocacia.

■ **9.8.3.7.** ***O princípio da separação de “poderes” e a impossibilidade de a CPI investigar atos de conteúdo jurisdicional***

Deve-se consignar que o **princípio da separação de poderes** serve de baliza e limitação material para a atuação parlamentar, e, desse modo, a CPI **não** tem poderes para investigar atos de **conteúdo jurisdicional**, não podendo, portanto, rever os fundamentos de uma sentença judicial.

Apesar disso, o Min. Celso de Mello adverte: “... isso não significa, porém, que todos os atos do Poder Judiciário estejam excluídos do âmbito de incidência da investigação parlamentar. Na verdade, entendo que se revela constitucionalmente **lícito**, a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, **investigar atos de caráter não jurisdicional emanados do Poder Judiciário**, de seus **integrantes** ou de seus **servidores**, especialmente se se cuidar de atos, que, por efeito de expressa determinação constitucional, se exponham à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Legislativo (CF, arts. 70 e 71) ou que traduzam comportamentos configuradores de infrações político-administrativas eventualmente praticadas por Juízes do STF (Lei n. 1.079/50, art. 39), que se acham sujeitos, em processo de *impeachment*, à jurisdição política do Senado da República (CF, art. 52, II)” (voto no **HC 79.441**, j. 15.09.2000, fls. 322-323).

■ **9.8.3.8.** ***Postulado de reserva constitucional de jurisdição***

Muito embora o constituinte originário tenha conferido poderes à CPI, restritos à investigação, referidos poderes não são absolutos, devendo sempre ser respeitado o **postulado da reserva constitucional de jurisdição**.

Conforme definiu o Min. Celso de Mello, “o **postulado da reserva constitucional de jurisdição** importa em submeter, à esfera única de **decisão dos magistrados**, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, **somente pode emanar do juiz**, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’” (MS 23.452).

Isso significa que a CPI **não** poderá praticar determinados **atos de jurisdição** atribuídos exclusivamente ao **Poder Judiciário**, vale dizer, atos **propriamente jurisdicionais**. **Veda-se**, portanto, à CPI:

■ **diligência de busca domiciliar**: a busca domiciliar, nos termos do art. 5.º, XI, CF, verificar-se-á com o consentimento do morador, sendo que, na sua falta, ninguém poderá adentrar na casa, asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, durante o dia ou à noite, mas, durante o dia, somente por **determinação judicial**, não podendo a CPI tomar para si essa competência, que é reservada ao Poder Judiciário;²¹

■ **quebra do sigilo das comunicações telefônicas (interceptação telefônica)**: de acordo com o art. 5.º, XII, a quebra do sigilo telefônico somente poderá ser verificada por **ordem judicial** (e não da CPI ou qualquer outro órgão), para fins de **investigação criminal** ou **instrução processual penal**;

■ **ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito, por exemplo, por crime de falso testemunho** (STF, HC 75.287-0, DJ de 30.04.1997, p. 16302): isso porque a regra geral sobre a prisão prevista no art. 5.º, LXI, determina que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de **autoridade judiciária** (e não CPI) competente, ressalvados os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei — prisão disciplinar (*vide RDA 196/195*, Rel. Min. Celso de Mello; *RDA 199/205*, Rel. Min. Paulo Brossard) e a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo

executor da medida durante o **estado de defesa** e não superior a 10 dias, devendo ser imediatamente comunicada ao juiz competente (art. 136, § 3.º, I a IV).

Outra questão, que pode ser indagada nas provas e já resolvida pelo STF, diz respeito às **medidas assecuratórias**, pertinentes à **eficácia de eventual sentença condenatória**.

Em primoroso trabalho sobre as CPIs, Cássio Juvenal Faria assevera que “os provimentos dessa natureza, como o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, previstos nos arts. 125 e ss. do CPP, bem como a decretação da indisponibilidade de bens de uma pessoa, medida que se insere no **poder geral de cautela do juiz**, são atos **tipicamente jurisdicionais**, próprios do exercício da jurisdição cautelar, quando se destinam a assegurar a eficácia de eventual sentença condenatória, apartando-se, assim, por completo, dos poderes da comissão parlamentar de inquérito, que são apenas de ‘investigação’”.²²

■ 9.8.3.9. *Postulado da colegialidade*

De acordo com a doutrina e a jurisprudência do STF, a **eficácia** das deliberações dos parlamentares integrantes da CPI deve observar o **postulado da colegialidade**, devendo as decisões ser tomadas pela maioria dos votos e não isoladamente. Nesse sentido:

■ “O **princípio**²³ **da colegialidade** traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (‘disclosure’) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua

adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se **nula**” (MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.02.2005, Plenário, DJE de 06.11.2009).

■ 9.8.3.10. **Motivação**

Toda **deliberação da CPI** deverá ser **motivada**, sob pena de padecer do **vício de ineficácia** (art. 93, IX, CF).

Para o Min. Celso de Mello, “as deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se *írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal*” (MS 23.452/RJ, DJ de 12.05.2000, p. 20).

■ 9.8.3.11. **Conclusões: encaminhamento para as autoridades responsáveis para que promovam as eventuais responsabilizações dos infratores**

■ **As CPIs aplicam pena?**

NÃO.

As CPIs não podem nunca impor penalidades ou condenações. Os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o **relatório** da CPI respectiva e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público da União ou dos Estados ou, ainda, às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência e, assim, existindo elementos, para que promovam a responsabilização civil, administrativa ou criminal dos infratores.

Dependendo dos limites da atuação ministerial (na medida em que ao Ministério Público está vedada a representação judicial de entidades públicas — art. 129, IX), entendemos que o relatório deva ser encaminhado, também, para a Advocacia-Geral da União e outros órgãos que exercem a representação judicial e consultoria das respectivas unidades federadas, para que promovam eventual responsabilização civil (nesse sentido, cf. a introdução do art. 6.º-A da Lei n. 1.579/52 pela Lei n. 13.367/2016).

Deixando mais claro e disciplinando a matéria, o art. 37, *RICD*, determina, ao término dos trabalhos, o encaminhamento de **relatório circunstanciado**, com as **conclusões**:

■ à **Mesa**, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação, que será incluída na Ordem do Dia dentro de cinco sessões;

■ ao **Ministério Público** ou à **Advocacia-Geral da União**, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

■ ao **Poder Executivo**, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2.º a 6.º, da Constituição Federal e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

■ à **Comissão Permanente** que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;

■ à **Comissão Mista Permanente** de que trata o art. 166, § 1.º, Constituição Federal;

■ ao **Tribunal de Contas da União**, para as providências previstas no art. 71 da mesma Carta.

O art. 1.º da Lei n. 10.001, de 04.09.2000, determinou que os Presidentes da CD, do SF ou do CN encaminharão o **relatório** da CPI respectiva, e a resolução que o aprovar, aos chefes do MP da União ou dos

Estados, ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência, na medida em que a CPI, como vimos, só investiga, não julga nem aplica qualquer tipo de penalidade.

Buscando evitar que todo o trabalho da CPI fosse perdido, a referida lei estabeleceu, ainda, o dever de as autoridades informarem, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou justificativa pela omissão, bem como a prestação de contas semestral do andamento das medidas tomadas, sob pena de aplicação de sanções administrativas, civis e penais.

O STF, contudo, declarou inconstitucionais referidas disposições por ofensa à autonomia e à independência do Ministério Público, asseguradas pelo § 2.º do art. 127 e pelo § 5.º do art. 128 da Constituição da República (**ADI 5.351**, j. 21.06.2021).

A Corte, por outro lado, entendeu **constitucional** a regra do art. 3.º da lei que assegura a **prioridade** do processo ou do procedimento a ser adotado pela autoridade competente sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de *habeas corpus*, *habeas data* e mandado de segurança.

Conforme se justificou, a previsão de **prioridade de tramitação** tem **natureza processual** e, portanto, **competência privativa da União para legislar** (art. 22, I, CF/88), além de ser **proporcional** e **razoável**.

■ As CPIs podem realizar indiciamento?

NÃO.

Conforme tem sido observado, as CPIs costumam tipificar crimes, indicando os responsáveis pela suposta prática de ilícitos criminais e, muitas vezes, usam a expressão **indiciamento**.

Nesse sentido, para se ter um exemplo, o relatório final (com 1.289 fls.) da **CPI da Pandemia** (instituída pelos Requerimentos ns. 1.371 e 1.372, de 2021), aprovado por 6 x 4 em 26.10.2021, não apenas tipificou os crimes supostamente praticados como, também, “**indiciou**” 78 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. O referido relatório tanto sinalizou uma “sugestão” de indiciamento como, em outras passagens, prescreveu o “indiciamento” de

“pessoas, agentes políticos e servidores públicos, que de algum modo tinham o poder de definir ou influenciar a tomada de decisões no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, bem como de particulares que tiveram envolvimento com práticas delituosas”.

Tecnicamente, **contudo**, não nos parece adequado falarmos em indiciamento por parte da CPI que apura fato certo e determinado e encaminha as suas conclusões para que as autoridades responsáveis promovam as eventuais responsabilizações dos infratores.

Pouco importa, portanto, a tipificação dos eventuais crimes praticados. Essa indicação assume muito mais uma **conotação política** do que jurídica, não estando, portanto, o Ministério Público e demais autoridades competentes a ela vinculados, podendo não somente dar uma outra interpretação, como, também, considerar o fato atípico.

No mais, de acordo com o art. 2.º, § 6.º, da Lei n. 12.830/2013, o **indiciamento** é ato **privativo** do **Delegado de Polícia** e se dará por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias, gerando formais consequências desse procedimento e, sem dúvida, constrangimentos para o indiciado (as regras introduzidas pela referida lei estão sendo discutidas pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 5.043, 5.059 e 5.073 — pendentes).

Conforme anotam Cebrian e Gonçalves, “o indiciamento é um **ato formal** eventualmente realizado durante o **inquérito policial** que decorre do fato de a **autoridade policial** se convencer de que determinada pessoa é a autora da infração penal. **Antes do formal indiciamento, a pessoa é tratada apenas como suspeita ou investigada.** (...). De ver-se, todavia, que o indiciamento é uma declaração formal feita por representante do aparato repressivo estatal, no sentido de apontar aquela pessoa como autora do delito e, como consequência, seu nome e demais dados são lançados no sistema de informações da Secretaria de Segurança Pública relacionados àquele delito e passam, por isso, a constar da folha de antecedentes criminais do indivíduo”.²⁴

Assim, concluímos não ser adequado falar em formal indiciamento por parte da CPI, já que, no caso, haverá o encaminhamento das conclusões materializadas em relatório final para que, eventualmente, as **autoridades responsáveis** promovam a responsabilização dos infratores.

■ 9.8.3.12. *Competência originária do STF*

É da **competência originária** do **STF** processar e julgar **MS** e **HC** impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do **Congresso Nacional ou de quaisquer de suas Casas**.

Isso porque, conforme já decidiu a Suprema Corte, “... a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a *longa manus* do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de *habeas corpus*, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’)” (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, p. 20).

■ 9.8.3.13. *A regra da prejudicialidade*

A jurisprudência do STF, **por regra**, determina a **prejudicialidade** das “... ações de mandado de segurança e de *habeas corpus*, sempre que — impetrados tais *writs* constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito — vierem estas a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação, ou não, de seu relatório final” (MS 23.852-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.06.2001, e julgados reafirmando a jurisprudência, como HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 08.04.2010; MS 25.459-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04.02.2010; MS 34.318, j. 07.03.2017; MS 36.518, j. 04.12.2019 etc.).

■ 9.8.3.14. *A questão específica da quebra do sigilo bancário*

■ Precedente envolvendo a Receita Federal

A questão específica sobre a **quebra do sigilo bancário** e a discussão acerca da necessidade ou não de **autorização judicial** foi, **em um primeiro momento**, decidida pelo STF no julgamento do **RE 389.808** (j. **15.12.2010**).

A discussão surgiu em decorrência de comunicado feito pelo *Banco Santander* a determinada empresa, informando que a Delegacia da Receita Federal do Brasil, partindo de *mandado de procedimento fiscal* e com base na LC n. 105/2001, havia requerido àquela instituição financeira a entrega de informações sobre movimentação bancária da empresa durante o período de 1998 a julho de 2001.

Diante dessa notícia, a empresa buscou o Judiciário, e, após várias medidas, a decisão final veio do STF, que, no caso concreto, por **5 x 4**, concluiu pela necessidade de **autorização judicial** para a quebra de sigilo bancário, por se tratar de verdadeira **cláusula de reserva de jurisdição**, não tendo, portanto, o Fisco esse poder (RE 389.808, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.12.2010, Plenário, *DJE* de 10.05.2011).

O Min. Celso de Mello, em seu voto (inclusive, na **AC 33**), sustentou um verdadeiro “**‘estatuto constitucional do contribuinte’** — consubstanciador de direitos e limitações **oponíveis ao poder impositivo** do Estado”, destacando-se, no caso, o **direito à intimidade** e à **privacidade** (art. 5.º, X).

CUIDADO: em **momento seguinte**, o Pleno do STF, por **9 x 2**, **mudou o entendimento** sobre a situação específica envolvendo a Receita Federal: não se trata de situação de quebra de sigilo, mas, no fundo, de **transferência de sigilo** da órbita bancária para a fiscal, com finalidade de natureza eminentemente fiscal, para que a administração tributária possa, então, cumprir o comando previsto no art. 145, § 1.º, CF/88.

Nesse sentido, o STF, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o *tema 225* da repercussão geral, firmou a seguinte **tese**: “o art. 6.º da LC n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a **igualdade** em relação aos cidadãos, por meio do **princípio da capacidade**

contributiva, bem como estabelece **requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal**” (RE 601.314, Pleno, j. 24.02.2016, DJE de 16.09.2016). Nessa linha, na mesma data, o julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 — cf. *item 14.10.8.1*.

■ E como fica a questão específica das CPIs e demais instituições?

A jurisprudência do STF, diante da cláusula constitucional de que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, entende que as CPIs, por ato próprio, podem determinar a quebra do sigilo bancário, mesmo sem a autorização judicial. O fundamento está na própria regra do art. 58, § 3.º (poderes de investigação próprios das autoridades **judiciais**).

O STF tem tido, também, mesmo em relação às CPIs, a preocupação de manutenção do sigilo das informações. Conforme estabeleceu o Min. Celso de Mello, “com a transmissão das informações pertinentes aos dados reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar de Inquérito — enquanto depositária desses elementos informativos —, a nota de confidencialidade relativa aos registros sigilosos” (MS 23.452 — cf., no mesmo sentido, MS 25.686 e MS 25.940).

Nessa linha, em relação ao sigilo bancário e à reserva de jurisdição, destacamos a evolução da jurisprudência da Corte no tocante à possibilidade de **transferência de informações desde que preservado o sigilo**.

Em um primeiro momento, o STF admitiu a relativização da regra da reserva de jurisdição na hipótese de contas públicas, em razão dos princípios da publicidade e da moralidade (art. 37, CF/88), flexibilizando a proteção do direito à intimidade/privacidade. Não se tratava da quebra do sigilo em si, mas da transferência de informações, desde que preservado o sigilo: “o sigilo de informações necessário à preservação da intimidade é relativizado quando há interesse da sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos”. Nesse sentido, o STF admitiu o conhecimento de informações diretamente, tanto por parte do **TCU** (MS 33.340) como pelo **Ministério Público** (RHC 133.118), devendo ser mantido o sigilo.

Em seguida, a Corte evoluiu de modo genérico em relação à possibilidade de transferência do sigilo para os órgãos de persecução penal (**Ministério Público** e **Autoridades Policiais**). Vejamos:

“1. É **constitucional** o compartilhamento dos **relatórios de inteligência financeira da UIF** [Unidade de Inteligência Financeira, acrescente-se] e da íntegra do **procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil**, que define o lançamento do tributo, com os **órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial**, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de **comunicações formais**, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (**RE 1.055.941**, Rel. Min. Dias Toffoli, 04.12.2019 — Tema 990 da repercussão geral).

Assim, podemos esquematizar:

■ **possibilidade de quebra do sigilo bancário**: o Poder Judiciário e as CPIs (federais, estaduais e distritais), que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (não incluindo aqui as CPIs municipais, conforme será explicitado abaixo);

■ **contas públicas — conhecimento do destino de recursos públicos — relativização da regra geral**: “o sigilo de informações necessário à preservação da intimidade é relativizado quando há interesse da sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos”. Nesse sentido, o STF admitiu o conhecimento de informações diretamente, tanto por parte do **TCU** (MS 33.340) como pelo **Ministério Público** (RHC 133.118);

■ **transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal (a Administração Tributária, cumprindo o comando previsto no art. 145, § 1.º, CF/88, tem poderes para requisitar, por ato próprio, o envio de informações bancárias, desde que na forma do art. 6.º da LC n. 105/2001, o que deve ser entendido como translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal):** “o art. 6.º da LC n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (**RE 601.314**, Pleno, j. 24.02.2016, *DJE* de 16.09.2016). Nessa linha, na mesma data, o julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859;

■ **transferência de informações para os órgãos de persecução penal para fins criminais, devendo ser mantido o sigilo:** “1. É **constitucional** o compartilhamento dos **relatórios de inteligência financeira da UIF** [Unidade de Inteligência Financeira, acrescente-se] e da íntegra do **procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil**, que define o lançamento do tributo, com os **órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial**, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de **comunicações formais**, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (**RE 1.055.941**, Rel. Min. Dias Toffoli, 04.12.2019 — tema 990 da repercussão geral — *DJE* de 06.10.2020).

■ 9.8.3.15. *Sigilo bancário e CPIs estaduais*

Sendo o direito de “quebra” do sigilo assegurado às *CPIs federais*, na medida em que elas têm **“poder de investigação próprio das autoridades judiciais”** (art. 58, § 3.º), necessariamente, dentro da ideia de **simetria** e de **autonomia federativa**, esses poderes também devem ser assegurados às **CPIs estaduais**.

Existem precedentes admitindo o poder de quebra do sigilo fiscal pela **CPI estadual**, desde que, naturalmente, **fundamentado** o pedido. Nessa linha:

■ “Ação cível originária. Mandado de segurança. **Quebra de sigilo de dados bancários determinada por CPI de Assembleia Legislativa**. Recusa de seu cumprimento pelo Banco Central do Brasil. LC 105/2001. Potencial conflito federativo (cf. ACO 730-QO). Federação. Inteligência. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, de aspectos fundamentais decorrentes do princípio da separação de poderes previsto na CF de 1988. **Função fiscalizadora exercida pelo Poder Legislativo**. Mecanismo essencial do sistema de *checks-and-counterchecks* adotado pela CF de 1988. Vedação da utilização desse mecanismo de controle pelos órgãos legislativos dos Estados-membros. Impossibilidade. Violação do equilíbrio federativo e da separação de Poderes. **Poderes de CPI estadual: ainda que seja omissa a LC 105/2001, podem essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados bancários, com base no art. 58, § 3.º, da Constituição**” (ACO 730, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 22.09.2004, Plenário, DJ de 11.11.2005).

Em certa passagem de seu voto, o Relator destaca argumentação do Min. Sepúlveda Pertence no julgamento da **ADI 98** (j. 18.12.1997), que sugere “... uma terceira modalidade de limitações à autonomia constitucional dos Estados: além dos grandes princípios e das vedações — esses e aqueles, implícitos ou explícitos — hão de acrescentar-se às **normas constitucionais centrais** que, não tendo o alcance dos princípios, nem o conteúdo negativo das vedações, são, não obstante, de **absorção compulsória — com ou sem reprodução expressa — no ordenamento parcial dos Estados e**

Municípios'. Entendo que a possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito seja uma dessas normas de absorção compulsória nos Estados-Membros, destinada a garantir o potencial do poder legislativo em sua função de fiscal da administração”.

O tema, amplamente discutido na referida **ACO 730**, cujo resultado foi bastante apertado, por **6 x 5** (*lembrando que a composição, à época, era totalmente distinta da atual*), voltou a ser analisado pelo STF, no julgamento da **ACO 1.271** (conhecida como *mandado de segurança*), tendo havido os votos do Min. Joaquim Barbosa (que concedia a ordem) e do Min. Eros Grau (que a denegava), quando, em 11.03.2010, houve pedido de vista pelo Min. Dias Toffoli, devolvido em 09.05.2011 (cf. *Inf. 578/STF* — **matéria pendente de julgamento pelo STF**).

Na referida ação, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro atacava ato do chefe da *Superintendência Regional da Receita Federal*, que, diante de pedido formulado pela “CPI das Milícias”, negou o fornecimento de informações fiscais a respeito dos investigados, com base no **dever de sigilo fiscal**, uma vez que as atribuições conferidas pelo art. 58, § 3.º, às CPIs federais não se estenderiam às CPIs no âmbito estadual.

Em **12.02.2014**, contudo, o Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido formulado na **ACO 1.271**, tendo em vista o encerramento dos trabalhos da CPI, votando, assim, pela **prejudicialidade** da ação por perda superveniente do seu objeto.

O tema, certamente, precisará ser mais bem debatido pela atual composição da Corte. No entanto, entendemos que o voto do Min. Dias Toffoli, apresentado para efeitos meramente históricos (já que se reconheceu a prejudicialidade da ação), poderá servir de segura orientação para decisões futuras.

Entendeu o Ministro que “a quebra de sigilo fiscal pelas comissões parlamentares de inquérito constitui **instrumento inerente ao exercício da função fiscalizadora insita aos órgãos legislativos** e, como tal, dela também podem fazer uso as CPIs instituídas pelas Assembleias Legislativas e pela Câmara Distrital, desde que observados, em resumo, os seguintes requisitos:

- deve dar-se mediante deliberação colegiada devidamente fundamentada;
- deve haver pertinência entre o objeto da investigação e as informações requisitadas, sendo necessário que se indique fato concreto que justifique tal medida excepcional;
- a atuação da comissão parlamentar estadual deve restringir-se à área de competência constitucional do Poder Legislativo do Estado, somente sendo investigáveis por ele os fatos que possam ser objeto de disciplina em lei, de controle ou de fiscalização parlamentar estadual;
- os dados obtidos podem ser usados somente no âmbito da investigação que lhe deu causa, devendo haver, obrigatoriamente, a preservação da confidencialidade dos dados fiscais, bancários e telefônicos repassados ao parlamento estadual”.

Finalmente, destacamos que, em outra decisão, o Min. Joaquim Barbosa concedeu liminar autorizando a **transferência de informações protegidas por sigilo fiscal** para a CPI no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, que investiga supostas irregularidades e fraudes praticadas contra cerca de 3.000 mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de São Paulo — BANCOOP (**MS 29.046**, liminar proferida em 13.08.2010. Referido mandado de segurança, em 04.11.2011, foi julgado prejudicado, haja vista que a CPI encerrou os seus trabalhos).

Essa parece ser a melhor interpretação e na linha do que o STF já vinha decidindo (ACO 730), sob pena de se esvaziar o papel das CPIs estaduais.

■ 9.8.3.16. *Sigilo bancário e as CPIs distritais*

E a discussão em relação às CPIs no âmbito da **Câmara Legislativa do DF?**

Apesar de ter o Distrito Federal a sua autonomia parcialmente tutelada pela União — e já discutimos a sua amplitude enquanto verdadeiro ente federativo —, parece, sim, razoável, que o mesmo entendimento que se dê aos Estados seja estendido para o DF, até porque, muito embora a sua posição

particular na Federação, o DF se aproxima muito mais dos Estados que dos Municípios (por exemplo, cf. art. 32, § 2.º, que faz coincidir as eleições do Executivo Distrital com a dos Estados-Membros, e art. 32, § 3.º, que determina a aplicação do art. 27 — que trata dos Estados —, aos Deputados Distritais).

Além do mais, o DF tem representação na Federação, já que elegerá 3 Senadores da República (art. 46).

■ 9.8.3.17. *Sigilo bancário e as CPIs municipais*

E as CPIs no âmbito da **Câmara dos Vereadores, podem quebrar sigilo bancário?**

Poderíamos considerar outros argumentos, como o *risco de abuso por parte das referidas CPIs*, sustentado por alguns autores. Porém, preferimos ficar com uma argumentação puramente jurídica e técnica.

Aqui — e o tema da *disclosure* ainda precisa ser mais bem debatido pelo STF —, entendemos, contudo, que a Câmara dos Vereadores, apesar de poder instaurar CPI, seguindo o modelo federal, **não terá, por si, o poder de quebra do sigilo bancário.**

Não estamos dizendo que a CPI não poderá investigar, até porque é função do Legislativo a fiscalização e o controle da administração pública.

Estamos sugerindo que, na hipótese de quebra de sigilo bancário no âmbito da CPI municipal, tenha de haver **autorização judicial.**

E não há problema em diferenciar os Legislativos de nossa Federação, já que, no Brasil, vigora aquilo que a doutrina denominou **federalismo assimétrico** (cf. *item 7.3.2.3*), ocupando o Município uma posição bastante particular.

Como se sabe, apesar de ser integrante da Federação, e isso não se discute (arts. 1.º e 18, *caput*), a posição dos Municípios não se confunde com a dos Estados e a do DF.

Os Municípios **não elegem Senador** e, assim, não têm uma representação direta na Federação.

Ainda, o Município, dentro da ideia de autogoverno, **não tem Judiciário** próprio, apesar de existir, naturalmente, a prestação jurisdicional nas comarcas e seções judiciárias.

Por esse motivo, ou seja, por ter uma posição bastante particular na Federação, sustentamos que as Câmaras Legislativas de Municípios, apesar de poderem instaurar CPIs, não poderão, por ato próprio, determinar a quebra de sigilo bancário.

Mas é possível essa distinção?

De acordo com o Min. Joaquim Barbosa, os **poderes instrutórios não são extensíveis às CPIs municipais**. Isso porque se trata, “... no modelo de separação de poderes da Constituição Federal, de uma excepcional derrogação deste poder para dar a uma casa legislativa poderes jurisdicionais, posto que instrutórios. Essa transferência de poderes jurisdicionais não se pode dar no âmbito do município, exatamente porque o município não dispõe de jurisdição nem de poder jurisdicional, a transferir, na área da CPI, do Judiciário ao Legislativo” (voto na ACO 730, p. 82).

Concordamos com a conclusão, mas o nosso fundamento não é, exclusivamente, o fato de inexistir um Judiciário municipal, e sim a situação do Município na Federação, **especialmente por não ter representação no Senado Federal**.

Também não aceitando a quebra do sigilo bancário por CPI municipal, lembramos Eugênio Pacelli: “ao parlamento municipal não se deve mesmo reconhecer o poder de quebra de sigilo, exatamente em razão da posição que referidos entes (Municípios) ocupam na distribuição do Poder Público. Veja-se, por exemplo, a ampla limitação legiferante dos municípios (restrita às questões de interesse local), e, também, a inexistência de foros privativos, na Constituição da República, para os respectivos parlamentares (vereadores). Ora, sendo assim, não faria sentido permitir a eles poderes superiores às próprias prerrogativas”.²⁵

Tudo o que foi dito encontra fundamento na **ACO 730** e em parte do julgamento da **ACO 1.271** que, infelizmente, diante do encerramento da CPI, foi julgada **prejudicada**, sem a oportunidade de um melhor debate sobre a

matéria e perante distinta composição. Para sabermos a posição dos atuais Ministros, teremos que aguardar o julgamento futuro sobre o tema (**matéria pendente**).

Resumindo o atual entendimento: os Municípios podem criar CPIs que, contudo, diferentemente das dos Estados e do DF, não poderão, por si, quebrar sigilo bancário.

■ 9.8.4. Comissão mista

São formadas por Deputados e Senadores para apreciar, dentre outros e em especial, os assuntos que devam ser examinados em **sessão conjunta** pelo Congresso Nacional.

Devemos lembrar importante **comissão mista permanente** que é a **comissão mista do orçamento**, cujas finalidades estão expressas no art. 166, § 1.º, CF/88.

■ 9.8.5. Comissão representativa

A comissão representativa apresenta a peculiaridade de constituir-se somente durante o **recesso parlamentar** (período fora da **sessão legislativa**, prevista no art. 57, *caput*).

A representatividade será do Congresso Nacional, sendo a comissão eleita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal na **última sessão legislativa ordinária do período legislativo**, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição deverá refletir, na medida do possível, a proporcionalidade da representação partidária (art. 58, § 4.º).

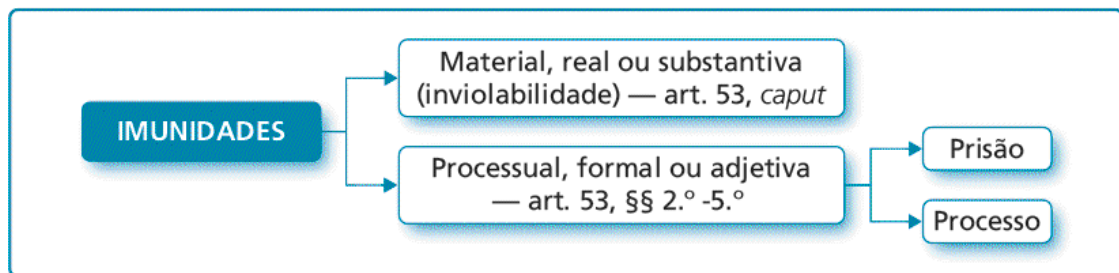
A redação do art. 58, § 4.º, aparece um pouco truncada, devendo ser interpretada da seguinte forma: a **sessão legislativa** é uma só e vai, na redação conferida ao art. 57, *caput*, pela EC n. 50/2006, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1.º de agosto a 22 de dezembro**. Cada sessão legislativa (**anual**) tem **dois períodos legislativos**, ou seja, um no primeiro semestre, quando será eleita a **comissão representativa** para o primeiro recesso do

ano, que acontece de 18 a 31 de julho, e outro no segundo período da sessão legislativa (segundo semestre), momento em que se elegerá nova comissão representativa para o segundo recesso, que irá de 23 de dezembro a 1.º de fevereiro do ano seguinte.

■ 9.9. IMUNIDADES PARLAMENTARES

■ 9.9.1. Aspectos introdutórios

Imunidades parlamentares são **prerrogativas** inerentes à função parlamentar, garantidoras do exercício do mandato, com plena liberdade. Não se trata de direito pessoal ou subjetivo do Parlamentar, na medida em que, como se disse, decorre do efetivo exercício da função parlamentar. Assim, não podemos confundir prerrogativa com privilégio.



Referidas prerrogativas, como veremos, dividem-se em dois tipos: a) **imunidade material, real** ou **substantiva** (também denominada **inviolabilidade**), implicando a exclusão da prática de crime, bem como a inviolabilidade civil, pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares (art. 53, *caput*); b) **imunidade processual, formal** ou **adjetiva**, trazendo regras sobre prisão e processo criminal dos parlamentares (art. 53, §§ 2.º a 5.º, CF/88).

Assim, importante notar que, em sua essência, as aludidas prerrogativas atribuídas aos parlamentares, em virtude da função que exercem, tradicionalmente previstas em nossas Constituições, com algumas exceções nos movimentos autoritários, reforçam a democracia, uma vez que os parlamentares podem livremente expressar suas opiniões, palavras e votos, bem como estar garantidos contra prisões arbitrárias, ou mesmo rivalidades políticas.

As regras sobre imunidades parlamentares sofreram importantes alterações com o advento da **EC n. 35, de 20.12.2001** (SF, PEC n. 2-A/95 e CD PEC n. 610/98, com parecer favorável da CCJ n. 1.461, de 12.12.2001, Rel. Sen. José Fogaça), e passam a ser analisadas notadamente em relação ao processo criminal.²⁶

■ 9.9.2. Imunidade parlamentar federal

Nesse tópico, após a introdução e pequena sistematização do assunto, concentraremos a apresentação em relação às imunidades dos parlamentares federais, quais sejam, dos **Deputados Federais** e dos **Senadores da República**, de acordo com as regras fixadas na **EC n. 35/2001**, que alterou a redação do art. 53, CF/88.

■ 9.9.2.1. *Imunidade material ou inviolabilidade parlamentar (art. 53, “caput”)*

Prevista no art. 53, *caput*, a **imunidade material** garante que os parlamentares federais são invioláveis, **civil** e **penalmente**, por quaisquer de suas **opiniões**, **palavras** e **votos**, desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares, no exercício e relacionados ao mandato (trata-se de manifestações que possuem **nexo de causalidade** com a atividade parlamentar), não se restringindo ao âmbito do Congresso Nacional. Assim, mesmo que um parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo sua função parlamentar federal, em qualquer lugar do território nacional estará resguardado, não praticando qualquer crime por sua opinião, palavra ou voto.²⁷

Segundo o STF, “... a inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista onde se possa identificar um laço de implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente” (RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda

Pertence, j. 12.08.1998, *DJ* de 18.06.2001; AI 493.632-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13.11.2007, *DJE* de 14.03.2008).

Aqui, pedimos vênia para reproduzir interessante compilação doutrinária no que tange à natureza jurídica da inviolabilidade parlamentar. Diz Alexandre de Moraes: “dessa forma Pontes de Miranda (*Comentários à Constituição de 1967*), Nélson Hungria (*Comentários ao Código Penal*) e José Afonso da Silva (*Curso de direito constitucional positivo*) entendem-na como uma *causa excludente de crime*; Basileu Garcia (*Instituições de direito penal*), como *causa que se opõe à formação do crime*; Damásio de Jesus (*Questões criminais*), *causa funcional de isenção de pena*;²⁸ Aníbal Bruno (*Direito penal*), *causa pessoal e funcional de isenção de pena*; Heleno Cláudio Fragoso (*Lições de direito penal*), *causa de irresponsabilidade*; José Frederico Marques (*Tratado de direito penal*), *causa de incapacidade penal por razões políticas*”.²⁹

Não importa, pois, qual a denominação que se dê; o importante é saber que a imunidade material (inviolabilidade) **impede que o parlamentar seja condenado**, já que há ampla descaracterização do tipo penal, **irresponsabilizando-o penal, civil, política e administrativamente (disciplinarmente)**. Trata-se de **irresponsabilidade geral**, desde que, é claro, tenha ocorrido o fato em razão do exercício do mandato e da função parlamentar.³⁰

A **imunidade material**, mantida pela **EC n. 35/2001**, é sinônimo de **democracia**, representando a garantia de o parlamentar não ser perseguido ou prejudicado em razão de sua atividade na tribuna, na medida em que assegura a independência nas manifestações de pensamento e no voto.

E que fique claro: **sustentamos** que a imunidade parlamentar não é absoluta, assim como nenhum direito fundamental é absoluto. Em nosso entender, portanto, em situações excepcionalíssimas, determinadas opiniões, palavras e votos proferidos podem até caracterizar a prática de crime, já que o direito brasileiro não tolera o denominado *hate speech* (cf. item 14.10.5.1).

Mas **cuidado**: essa nossa opinião ainda não foi enfrentada pelo STF, e, assim, atenção para as provas de concursos. Os precedentes do STF no sentido de não se reconhecer a imunidade material são em situações desvinculadas da atividade parlamentar.

Conforme anotou o Min. Celso de Mello, “a cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações — **desde que vinculadas ao desempenho do mandato** — qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes” (**Inq. 2.874** — trecho da ementa).

E um outro ponto: é possível que determinado comportamento esteja acobertado pela imunidade material (criminal) mas que, por outro lado, caracterize-se como **abuso de prerrogativa** e, assim, venha a ensejar, **no âmbito da Casa Legislativa**, a **perda do mandato** por **quebra de decoro parlamentar** (art. 55, II).

Para exemplificar, podemos citar alguns comportamentos de determinados deputados federais durante a votação da autorização para instauração do processo de *impeachment* contra a ex-Presidente Dilma Rousseff (17.04.2016).

Nesse sentido, bem disse o Min. Barroso: “a imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, **quebra de decoro**, a ensejar o **controle político**” (Pet 5.647, j. 22.09.2015, *DJE* de 26.11.2015).

■ 9.9.2.2. *Imunidade formal ou processual*

A imunidade formal ou processual está relacionada à **prisão** dos parlamentares, bem como ao **processo** a ser instaurado contra eles. Devemos, então, saber quando os parlamentares poderão ser presos, bem como se será possível instaurar processo contra eles.

■ 9.9.2.2.1. *Imunidade formal ou processual para a prisão (art. 53, § 2.º). Perspectivas em razão do julgamento da AP 470 — “mensalão”*

Os parlamentares passam a ter imunidade formal para a prisão a partir do momento que são **diplomados** pela Justiça Eleitoral, portanto, antes de tomarem **posse** (que seria o ato público e oficial mediante o qual o Senador ou Deputado se investiria no mandato parlamentar). A **diplomação** nada mais é que um atestado garantindo a regular eleição do candidato. Ocorre antes da posse, configurando o **termo inicial** para a atribuição da **imunidade formal para a prisão**.³¹

Nesse sentido, expresso é o art. 53, § 2.º, CF/88, na redação determinada pela **EC n. 35/2001**: “desde a **expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional não poderão ser **presos**, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”.

Isso posto, passamos a esquematizar melhor as regras sobre a **prisão** dos **parlamentares federais**, que poderá ser **processual** (art. 53, § 2.º), também chamada de **cautelar**, ou somente em razão de **sentença judicial definitiva transitada em julgado**.

Deixando claro, não se caracterizando a hipótese de prisão processual ou cautelar, a **única** forma de prisão do parlamentar será em razão de **sentença penal transitada em julgado e contra a qual não caibam mais recursos**; nesse caso, sob pena de se violar o **princípio da presunção de inocência** (art. 5.º, LVII, CF/88), segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o **trânsito em julgado** de **sentença penal condenatória**”.

Em relação à necessidade do trânsito em julgado, destacamos a ampla discussão do tema pela Corte e, depois de idas e vindas, em votação novamente apertada, a expressa declaração de **constitucionalidade** do **art. 283, CPP**, à luz do **art. 5.º, LVII, CF/88**, no sentido de não se admitir a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (**ADCs 43, 44 e 54**, Pleno, 6 x 5, j. 07.11.2019, *DJE* de 12.11.2020 — pendente o julgamento de embargos declaratórios na ADC 43 — cf. *item 14.10.28.6* deste nosso estudo).

Na linha da **tese vencedora**, o Min. Celso de Mello julgou procedentes os pedidos deduzidos nas referidas ações declaratórias de constitucionalidade, “reafirmando, assim, no que concerne à interpretação do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a tese segundo a qual a execução provisória (ou prematura) da sentença penal condenatória (...) revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o **trânsito em julgado de sua condenação criminal**, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República (CF, art. 5.º, LVII)”.

O **Pacote Anticrime** (Lei n. 13.964/2019), em sua versão final, ratifica e reforça a necessidade do trânsito em julgado ao alterar a redação do art. 283, CPP.

Retomando a análise dos parlamentares federais, conforme vimos, a Constituição admite tanto a prisão cautelar como a em razão do trânsito em julgado. No tocante à primeira, qual seja, a **prisão processual**, haveria violação ao **princípio da presunção de inocência**?

Não. Muito embora se reconheça o caráter excepcional da prisão processual, a Constituição, em seu art. 5.º, LXI, expressamente a admite, ao estabelecer que “ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária** competente, salvo nos casos de *transgressão militar* ou *crime propriamente militar*, definidos em lei”, bem como, ao prescrever, na *vigência do estado de defesa*, a possibilidade de decretação da prisão por crime contra o Estado pelo *executor*

da medida, que deverá comunicá-la imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial (art. 136, § 3.º, I).

A) Prisão processual dos parlamentares federais

De acordo com a doutrina, a **prisão processual** divide-se em três: a) prisão em flagrante; b) prisão preventiva; c) prisão temporária.

Os parlamentares federais só poderão ser **cautelarmente** presos e colocados no cárcere na hipótese de **flagrante de crime inafiançável**.

Estamos diante daquilo que o Min. Celso de Mello denominou “estado de relativa incoercibilidade pessoal dos congressistas (*freedom from arrest*), que só poderão sofrer prisão provisória ou cautelar numa **única e singular hipótese**: situação de flagrância em crime inafiançável” (Inq. 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.02.1991, Plenário).

Nessa hipótese, de acordo com o art. 53, § 2.º, os autos deverão ser remetidos à Casa Parlamentar respectiva no prazo de **24 horas**, para que, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros (*quorum* qualificado, cf. *Inf. STF 28/96*), **resolva sobre a prisão**.

Convém destacar que a votação dos congressistas não mais será secreta, conforme regra anterior à EC n. 35/2001, e sim pelo **voto aberto**, implementando-se, por meio dessa nova sistemática, a transparência que deve sempre imperar nesse tipo de deliberação.

A aprovação pela Casa, dessa forma, é **condição necessária** para a manutenção da prisão em flagrante delito de crime inafiançável (prisão processual ou cautelar) já realizada.

Portanto, se a Casa parlamentar decidir pela não manutenção do cárcere, a prisão deverá ser imediatamente “relaxada” (trata-se de decisão política e discricionária do Parlamento, que poderá assim resolver mesmo na hipótese de não se verificar qualquer ilegalidade, o que nos permite afirmar que a regra do art. 53, § 2.º, deve ser tida como especial em relação à regra geral do art. 5.º, LXV, CF/88, que exige o requisito da ilegalidade para o relaxamento da prisão).³²

Por outro lado, se a Casa mantiver a prisão em flagrante, conforme estabelece o art. 306, § 1.º, CPP, em até 24 horas, os autos deverão ser encaminhados ao **STF** (no caso de parlamentares federais — art. 53, § 1.º, c/c o art. 102, I, “b”, CF/88), para que, então, sejam cumpridas as regras do **art. 310, CPP**, com a importante novidade trazida pelo **Pacote Anticrime** (Lei n. 13.964/2019), que estabeleceu a garantia da **audiência de custódia**. Vejamos: “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover **audiência de custódia** com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

- relaxar a prisão ilegal; ou
- converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (**ADI 5.526**, cf. *itens* 9.9.2.2.3 e 9.11.7); ou
- conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O STF, ao analisar a novidade da obrigatoriedade da audiência de custódia, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao *caput* do art. 310, CPP, alterado pela Lei n. 13.964/2019, “para assentar que o juiz, **em caso de urgência e se o meio se revelar idôneo**, poderá realizar a **audiência de custódia** por **videoconferência**” (**ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305**, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.08.2023, *DJE* de 19.12.2023).

Devemos lembrar que o **Pacote Anticrime** (Lei n. 13.964/2019) trouxe importantes formalidades em relação à **prisão preventiva**, que **não pode mais ser decretada de ofício pelo juiz**, devendo haver **requerimento** do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311, CPP), salvo a exceção trazida no art. 316, CPP.

Apesar de dúvida inicial e divergência entre Turmas criminais do STJ, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça estabeleceu que “a interpretação do art. 310, II, CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2.º e 4.º, e 311,

do mesmo estatuto processual penal, a significar que **se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva**, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal, provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP” (STJ — **RHC 131.263-GO**, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, j. 24.02.2021, *DJE* de 15.04.2021).

Nesse sentido, afirma o Min. Celso de Mello que “a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da **audiência de custódia**, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), **pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente**, pois não se presume — independentemente da gravidade em abstrato do crime — a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser **adequada e motivadamente comprovados** em cada situação ocorrente” (STF — **HC 188.888**, 2.^a T., j. 06.10.2020, *DJE* de 15.12.2020 — até o fechamento desta edição, ainda não tivemos manifestação formal da 1.^a T., nem do Pleno do STF, sobre a matéria — pendente).

B) Prisão de parlamentar em razão de sentença judicial transitada em julgado

Finalmente, temos de tratar da prisão em caso de **sentença judicial transitada em julgado**, tema que ganhou repercussão com o julgamento do “mensalão” (**AP 470**) e que deve ser analisado juntamente com a regra contida no **art. 55, § 2.º**, CF/88, que cuida da perda do mandato.

Em um primeiro momento, em relação à **perda do mandato**,³³ por 5 x 4, no julgamento da **AP 470** (mensalão), em **17.12.2012**, o STF entendeu ser **automática** em razão da condenação criminal transitada em julgado (“... todos os condenados por **mais de 4 anos de reclusão** ou cuja condenação diga respeito a **ato de improbidade administrativa** — o que ocorre nos

crimes contra a administração pública, tais como **peculato** e **corrupção passiva**, deve implicar **automaticamente a perda dos mandatos eletivos**” — *Notícias STF*, 17.12.2012), aplicando-se a regra do art. 15, III, e afastando-se a incidência do art. 55, § 2.º.³⁴

CUIDADO: em **08.08.2013**, mudando esse entendimento, agora por **6 x 4**, no julgamento da **AP 565** (não votou o Min. Fux, impedido, em razão de ter apreciado o caso concreto quando era Min. do STJ), com a participação no julgamento de 2 novos Ministros que não haviam votado no caso do “mensalão” (Min. Barroso e Min. Teori Zavascki), o STF passou a estabelecer que a **perda do mandato de parlamentar condenado não é automática**, devendo ser observada a regra do **art. 55, § 2.º**, CF/88 (cf. *item 9.11.4*).

Por sua vez, no tocante à **prisão em razão da sentença judicial transitada em julgado** (ou seja, quando não mais couberem recursos), o Tribunal entendeu que as penas impostas poderão ser executadas imediatamente.

Em **13.11.2013**, também analisando a AP 470, o STF admitiu a **decretação parcial de trânsito em julgado**, nas partes do acórdão que não mais admitissem recurso, considerando os seus capítulos autonomamente. Dessa forma, resolvendo questão de ordem, a Corte:

■ **decretou**, por unanimidade, “**o trânsito em julgado e determinar a executoriedade imediata dos capítulos autônomos do acórdão condenatório**, não impugnados por embargos infringentes, considerados os estritos limites do recurso”;

■ por maioria, **excluiu** “da execução imediata do acórdão as condenações já impugnadas por meio de embargos infringentes, considerados os estritos limites de cada recurso, por ainda pender o respectivo exame de admissibilidade”;

■ por maioria, **admitiu** “o trânsito em julgado e a execução imediata da pena em relação aos réus cujos segundos embargos declaratórios já teriam sido julgados nesta sessão. No tocante ao trânsito em julgado

parcial do acórdão, à luz dos capítulos autônomos nele existentes, prevaleceu o voto do Ministro Joaquim Barbosa”;

■ por consequência, **certificou** o trânsito em julgado, conforme o caso, independentemente de publicação do acórdão;

■ **determinou** fossem lançados os nomes dos réus no rol dos culpados, bem como “expedidos mandados de prisão, para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime inicial legalmente correspondente ao *quantum* da pena transitada em julgado, nos termos do art. 33, § 2.º, do CP” (*Inf. n. 728/STF*).

Por todo o exposto, as regras sobre a prisão dos parlamentares federais podem ser assim resumidas:

■ **regra geral antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória:** os parlamentares federais **não** poderão ser presos, seja a **prisão penal processual** (também denominada prisão **provisória** ou **cautelar**, englobando aí a prisão temporária, em flagrante delito de crime **afiançável** e a preventiva),³⁵ seja a **prisão civil** (art. 5.º, LXVII);³⁶

■ **única exceção à regra geral:** a única hipótese em que será permitida a prisão do parlamentar federal, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e desde a expedição do diploma, será em caso de **flagrante de crime inafiançável**;³⁷

■ **flagrante de crime inafiançável:** mesmo nessa hipótese, de acordo com o art. 53, § 2.º, os autos deverão ser remetidos à Casa Parlamentar respectiva (por exemplo, sendo Deputado Federal, para a Câmara dos Deputados), no **prazo de 24 horas**, para que, pela **maioria absoluta de seus membros** (*quorum* qualificado, cf. *Inf. STF 28/96*) e pelo **voto aberto, decida sobre a prisão**;

■ **prisão em caso de sentença judicial transitada em julgado (STF):** evoluindo a decisão proferida no julgamento do “mensalão”, **AP 470** (decisões em 17 e 21.12.2012), pela qual se reconhecia a perda automática do mandato (art. 15, III), o STF, em momento seguinte (**08.08.2013**), no julgamento da **AP 565**, passou a estabelecer que a

perda do mandato de parlamentar condenado não é automática, devendo ser observada a regra do **art. 55, § 2.º**, CF/88 (cf. *item 9.11.4*).

■ **9.9.2.2.2. *Prisão preventiva de parlamentar? Precedente da 2.ª Turma do STF. Dúvida manifestada pela 1.ª Turma do STF. Inexistência de apreciação do Pleno. Inafiançabilidade legal em razão de excepcionalidade de caso concreto decorrente de “absoluta anomalia institucional, jurídica e ética”. “Derrotabilidade da regra” contida no art. 53, § 2.º, CF/88. Perspectivas para o julgamento da Pet 9.218 (pendente)***

A 2.ª Turma do STF, ao referendar decisão proferida pelo Min. Teori Zavascki na **AC 4.039**, admitiu a **prisão cautelar** do Senador da República D. do A. G.,³⁸ tendo em vista a presença dos **requisitos de prisão preventiva** (j. 25.11.2015, *DJE* de 13.05.2016. Essa interessante decisão de 39 laudas pode ser encontrada em *Notícias STF*, 25.11.2015. O acórdão, já publicado, não estava disponível porque a ação corre em segredo de justiça — acesso em 16.07.2016).

Conforme noticiado, os autos relatam esquema que supostamente envolveria um Senador da República, o seu assessor parlamentar, um advogado e um banqueiro, “com o objetivo de tentar dissuadir o ex-diretor Internacional da Petrobras N. C. de firmar acordo de colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal nas investigações decorrentes da operação **Lava-Jato**. Tal esquema, segundo relata o MPF, envolveria desde o pagamento de ajuda financeira no valor de R\$ 50 mil mensais à família de N. C. e o pagamento de R\$ 4 milhões em honorários ao advogado (...) por parte do banqueiro (...), até a promessa de suposta influência junto ao Poder Judiciário para a concessão de liberdade a N. C., de forma a facilitar eventual fuga do ex-diretor da Petrobras para a Espanha, país do qual também tem cidadania. Ainda segundo os autos, as reuniões dos investigados para tratar da questão da colaboração premiada de N. C. foram gravadas pelo filho do ex-diretor da Petrobras, e os vídeos, bem como conversas trocadas por *e-mail*

e por aplicativo de celular, foram encaminhados ao MPF” (*Notícias STF*, 25.11.2015).

A situação concreta não se enquadra nas hipóteses de crime definido pela Constituição como inafiançável, mas em **situação de inafiançabilidade decorrente de previsão legal**.

A regra já vista está no art. 53, § 2.º, CF/88, que admite a prisão de parlamentar federal na hipótese de flagrante de crime inafiançável. Ou seja, não é qualquer tipo de prisão, mas apenas a prisão em **flagrante**. E não é qualquer crime, mas apenas os crimes **inafiançáveis**.

A situação concreta não envolvia crime inafiançável, já que a imputação era relacionada a organização criminosa, que, todos sabem, à época dos fatos, não era enquadrada pela Constituição ou pela lei como inafiançável.

Devemos lembrar, a título de atualização, que o **Pacote Anticrime** (Lei n. 13.964/2019) enquadrrou o crime de organização criminosa como hediondo, **quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado** (art. 1.º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/90).

No caso em exame, não se tratava de crime hediondo. Na prática, contudo, o STF entendeu que a inafiançabilidade decorreria da situação concreta e nos termos da lei. Vejamos.

De acordo com o **art. 324, IV, CPP, não será**, igualmente, **concedida fiança** quando presentes os motivos que autorizam a decretação da **prisão preventiva** (art. 312, CPP³⁹), no caso concreto, a sua decretação como garantia da instrução criminal e das investigações.

Assim, se “não será concedida a fiança”, entendeu o STF, estaria configurada a situação de inafiançabilidade (lembrando que o art. 53, § 2.º, CF/88, fala em flagrante de crime inafiançável). Não se trata, na hipótese, de crime inafiançável, mas de situação de inafiançabilidade decorrente da lei.

Dessa forma, tendo a Turma identificado o **estado de flagrância** na prática do crime de organização criminosa, por se tratar de **crime permanente** (art. 2.º, *caput* e § 1.º, da Lei n. 12.850/2013), e a situação de **inafiançabilidade** decorrente de hipóteses de decretação da **prisão preventiva** (art. 324, IV, c/c o art. 312, CPP), a Corte entendeu como

configurada a situação de “flagrante de crime inafiançável” (art. 53, § 2.º, CF/88).

Seja por essa perspectiva, seja por uma outra no sentido de se sustentar a “derrotabilidade da regra” contida no art. 53, § 2.º, CF/88, diante da situação de excepcionalidade e anormalidade, bem como de outros princípios constitucionais, autorizada estaria a prisão preventiva do parlamentar (art. 312, CPP).

Em seu voto, o Min. Zavascki cita o precedente firmado no [HC 89.417](#) (j. 22.08.2006), impetrado em razão da denominada *Operação Dominó* e tendo em vista a prisão preventiva do então Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (deputado estadual que goza das mesmas prerrogativas de imunidade dos parlamentares federais — art. 27, § 1.º, CF/88), em face de reconhecido “estado de flagrância” e “inafiançabilidade” decorrente da excepcionalidade do caso concreto que investigava esquema envolvendo 23 dos 24 parlamentares estaduais da Assembleia Legislativa do Estado.

Diante dessa situação excepcionalíssima e pouco comum, indagou a Min. Cármen Lúcia: “como se cogitar, então, numa situação de **absoluta anomalia institucional, jurídica e ética** que os membros daquela Casa poderiam decidir livremente sobre a prisão de um de seus membros, aplicando a norma constitucional, máximo quando ele é tido como ‘o chefe indiscutível da organização criminosa que coordena as ações do grupo e cobra dos demais integrantes o cumprimento das tarefas que lhes são repassadas?’”.

Na ementa desse precedente, certamente paradigma para decisão proferida no caso específico da AC 4.039, estabelece-se: “os elementos contidos nos autos impõem interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, como previsto no art. 53, § 2.º, da Constituição da República. Há de se buscar interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. **A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro de órgão legislativo não pode ser tomada**

em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Os princípios determinam a interpretação e aplicação corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, composta de 24 deputados, dos quais, 23 estão indiciados em diversos inquéritos, afirma **situação excepcional** e, por isso, **não se há de aplicar a regra constitucional do art. 53, § 2.º, da Constituição da República, de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente**” (HC 89.417).

A Min. Cármen Lúcia, agora nesse outro caso, afirmando que a necessidade de prisão se imporia para resguardar o estado de direito, alertou: o “crime não vencerá a Justiça”. “Um aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e iniquidades: criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade e impunidade e corrupção. Em nenhuma passagem, a Constituição Federal permite a impunidade de quem quer que seja”, apontou (*Notícias STF*, 25.11.2015).

CUIDADO: devemos deixar anotado que, em momento seguinte, a **1.ª Turma** do STF apreciou novo pedido de **prisão preventiva** de parlamentar federal por situações gravíssimas descritas nos autos. Contudo, naquele momento, sinalizou “dúvida razoável, na hipótese, acerca da presença dos requisitos do art. 53, § 2.º da Constituição, para fins de decretação da prisão preventiva” (**Ag. Reg. no 3.º Ag. Reg. na AC 4.327**, j. 26.09.2017).

Apesar de ainda não haver manifestação específica da matéria pelo **Pleno** do STF (pendente — vide discussão abaixo na **Pet 9.218**), entendemos possível a leitura do art. 53, § 2.º, à luz de outros preceitos constitucionais e, assim, diante de situações muito específicas, de **“superlativa excepcionalidade”**, admitir, no extremo, a prisão preventiva de parlamentar, afastando-se, assim, a literalidade do dispositivo em análise, que estabelece apenas a possibilidade de **prisão cautelar em razão de flagrante delito de crime inafiançável**.

Conforme anotou o Min. Teori Zavaski em outro contexto, essa “excepcionalidade da regra geral da custódia cautelar em detrimento de parlamentar já foi objeto de interpretação no STF (HC 89.417), não em

função de sua literalidade ou como regra isolada no sistema constitucional, mas **de acordo com os fins a que ela se destina**, em conformidade com a **aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo**” (HC 138.316, j. 04.11.2016, fls. 4 da decisão monocrática).

Não é possível que a imunidade parlamentar sirva para acobertar a prática de crimes em total desvirtuamento do mandato, conforme se observou nas circunstâncias dos precedentes indicados, tanto do HC 89.417 (1.^a T. — composição diversa da atual —, j. 22.08.2006, 3 x 2) como da AC 4.039 (1.^a T., j. 25.11.2015, 3 x 2).

Devemos destacar a decisão proferida pelo Min. Barroso na **Pet 9.218**, em situação envolvendo parlamentar que **“escondeu maços de dinheiro em suas vestes íntimas”** durante a realização de busca e apreensão, havendo “indícios de participação do Senador, integrante da comissão parlamentar responsável pela execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19, em organização criminosa voltada ao desvio de valores destinados à saúde do Estado de Roraima”.

Não se estava diante de hipótese de prisão em flagrante delito de crime inafiançável, apesar de presentes os requisitos da preventiva.

Contudo, conforme observou Barroso, “persiste fundada dúvida sobre a legitimidade de decretação de **prisão preventiva de parlamentar federal**, já que, no julgamento da ADI 5.526 (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2017), 5 Ministros manifestaram-se de modo expressamente desfavorável a essa possibilidade.⁴⁰ Diante da não configuração de situação de flagrância e da **fundada dúvida sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva**, impõe-se o **afastamento do Senador da função parlamentar**, de modo a impedir que se utilize de seu cargo para dificultar as investigações ou para, ainda mais grave, persistir no cometimento de delitos”, devendo haver controle político dessa decisão pelo voto da maioria absoluta do Senado Federal (aplicação analógica do art. 53, § 2.^o) (**j. 15.10.2020** — pendente a análise da matéria pelo Pleno do STF).⁴¹

Um ponto, contudo, parece certo: conforme se observa no item seguinte, o STF, no julgamento da **ADI 5.526**, estabeleceu a necessidade de se encaminhar à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar a decisão pela qual se aplique **medida cautelar diversa da prisão** do art. 319, CPP, **sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar**, prescrevendo, então, a **aplicação analógica do art. 53, § 2.º, CF**.

Dessa forma, se o STF entendeu a necessidade de controle político posterior para as hipóteses de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no caso de decretação de **prisão preventiva**, que seria mais grave (no caso da construção feita pela 2.^a Turma do STF, lembrando não haver ainda posição do Plenário sobre essa possibilidade), a lógica deveria ser, também, a apreciação pela Casa Legislativa no prazo de 24 horas, por voto aberto e maioria absoluta (apesar de não concordarmos com esse entendimento firmado no referido julgamento).

Esse tema foi judicializado na **ADPF 497** envolvendo parlamentares estaduais, tendo sido a referida arguição rejeitada por não preencher o requisito da subsidiariedade (art. 4.º, § 1.º, da Lei n. 9.882/99), na medida em que a matéria já estava sendo discutida nas **ADIs 5.823, 5.824 e 5.825**, com medidas cautelares decididas e negadas (j. 20.09.2019).

Em referidas ações diretas, o STF, por **6 x 5**, negou medidas cautelares, prevalecendo o entendimento de que as regras da Constituição Federal relativas à imunidade dos deputados federais são **aplicáveis aos deputados estaduais**, e, portanto, poderia o Parlamento estadual sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função parlamentar, aplicando-se o art. 53, § 2.º, CF/88, conforme decidiu o STF no caso dos parlamentares federais no julgamento da ADI 5.526 (j. 08.05.2019, *DJE* de 16.11.2020 — cf. *Inf. 939/STF*).

Em **16.12.2022**, com nova composição, o STF, também por **6 x 5**, julgou o mérito das ADIs 5.824 e 5.825, mantendo o entendimento de ser o art. 27, § 1.º, CF/88, **norma de reprodução obrigatória** no âmbito estadual e no do

DF, declarando ser aplicável aos deputados estaduais (e aos do DF) “todo o estatuto dos congressistas que foi previsto em nível federal para os deputados e senadores” (em 21.11.2023, o Tribunal, por maioria, negou provimento aos embargos de declaração interpostos, *DJE* de 18.12.2023).

■ **9.9.2.2.3. *Outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e a necessidade de controle político (aplicação analógica do art. 53, § 2.º, CF/88) — ADI 5.526***

Conforme vimos, a regra geral do art. 53, § 2.º, tem sido analisada diante de ocorrências muito particulares e, de acordo com os precedentes citados no item anterior, encontramos situações de afastamento de sua literalidade para se admitir, em casos excepcionalíssimos, a prisão preventiva de parlamentar federal.

Agora, surge uma questão: seria possível, também, a aplicação de **outras medidas cautelares diversas da prisão**, descritas no art. 319, CPP?

Conforme estudamos no *item 9.11.7*, em 05.05.2016, o **Pleno**, por unanimidade, referendou decisão do Min. Teori Zavascki que determinou a suspensão do então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do exercício do mandato de deputado federal e, por consequência, da função de Presidente da Câmara dos Deputados. Neste caso, estamos diante de exemplo de provimento cautelar, diverso da prisão, determinando a suspensão do exercício do mandato, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais (art. 282, c/c o art. 319, VI, CPP).

Lembramos que referida decisão foi cumprida normalmente pela Câmara dos Deputados, não havendo nenhum questionamento pelos integrantes da Casa do povo (**AC 4.070 Ref**, Pleno, j. 05.05.2016, *DJE* de 21.10.2016).

Em julgamento seguinte, agora envolvendo Senador da República denunciado pela suposta prática de corrupção passiva e por tentativa de embaraçar investigação a envolver organização criminosa, por 3 x 2, a **1.^a**

Turma do STF restabeleceu as medidas cautelares diversas da prisão que em caso concreto haviam sido determinadas pelo relator originário, Min. Luiz Edson Fachin, e posteriormente revogadas pelo Min. Marco Aurélio, consistentes em: (i) suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública; (ii) proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em tela; e (iii) proibição de se ausentar do País, devendo entregar seus passaportes. Além disso, também por maioria, a Turma acrescentou a medida cautelar diversa de prisão, prevista no art. 319, V, CPP, de recolhimento domiciliar no período noturno (**Ag. Reg. no 3.º Ag. Reg. na AC 4.327**, j. 26.09.2017).

De modo inusitado e totalmente criticável, porém, muito embora se tratasse de decisão judicial explícita, o Senado Federal decidiu descumprir referida medida, sustentando que o acatamento da imposição de medida cautelar diversa da prisão dependeria de deliberação da Casa, tendo em vista a aplicação analógica do art. 53, § 2.º, CF/88.

Assim, instaurou formalmente o procedimento de análise da decisão judicial da 1.ª Turma do STF (**Ofício n. 70/2017-SF**). Depois de muito debate entre os parlamentares, inclusive com argumentos no sentido de não se poder descumprir a decisão judicial, os Senadores da República, apoiados no *Parecer n. 577/2017*, da Advocacia do Senado Federal, entenderam pela aplicação analógica do art. 53, § 2.º, CF/88, e, então, depois de adiamento, marcaram para o dia 17.10.2017 a apreciação da decisão da 1.ª Turma do STF, que aplicou as medidas cautelares diversas da prisão ao Senador A. N.

Diante dessa lamentável decisão do Senado — e dizemos lamentável pois a maneira de se atacar a decisão judicial imposta pela 1.ª Turma do STF seria mediante a interposição de recurso no próprio STF e não o simples e irresponsável descumprimento da decisão, a Min. Presidente do STF, com urgência, diante da crise institucional que se instalava, pautou o julgamento da **ADI 5.526**, que tramitava no STF desde 16.05.2016 e que tinha por objeto justamente essa questão envolvendo a possibilidade ou não de aplicação de medida cautelar diversa da prisão e a necessidade ou não de controle político posterior.

O STF, então, no dia 11.10.2017, portanto, uma semana antes da data que havia sido fixada para a análise pelo Senado Federal da medida tomada pela 1.^a Turma nos autos da AC 4.327, estabeleceu duas importantes teses:

■ **medidas cautelares diversas da prisão (10 x 1):** “o Poder Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal”;

■ **necessidade de controle político (aplicação analógica do art. 53, § 2.º — 6 x 5):** “o Tribunal, também por votação majoritária, deliberou que se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2.º, da Constituição, a decisão pela qual se aplique medida cautelar, **sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar**” (ADI 5.526, Pleno, STF, j. 11.10.2017, DJE de 07.08.2018, pendente o julgamento dos embargos de declaração).

Decidida a questão pelo Pleno do STF — agora no sentido de necessidade de apreciação pela Casa Legislativa federal, mantida a sessão para apreciação do afastamento do Senador da República para o dia 17.10.2017, duas importantes decisões judiciais foram proferidas para definir que a **votação pelo Senado Federal** deveria ser **aberta, ostensiva e nominal**.⁴²

O Senado Federal, por 44 x 26 (lembrando a necessidade de no mínimo 41 votos, qual seja, a maioria absoluta), rejeitou a decisão da 1.^a Turma do STF, permitindo, então, o imediato retorno do Senador para o exercício de suas funções.

A partir do entendimento firmado no julgamento da ADI 5.526, no sentido de que a decisão judicial depende de apreciação pela Casa Legislativa no prazo de 24 horas, por voto aberto e por maioria absoluta, naturalmente, a decisão do Senado Federal no caso em análise deverá ser acatada sem qualquer questionamento jurídico, diferentemente das críticas que lançamos anteriormente no sentido do descumprimento da decisão da 1.^a Turma do STF.

Apesar dessa posição adotada pela maioria do STF, por um placar extremamente apertado, 6 x 5, deixamos o nosso entendimento no sentido de que não nos parece adequada a interpretação dada pela Corte de se aplicar o art. 53, § 2.º, que, conforme vimos, exige o controle político **apenas no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável**.

Esse tema ainda poderá ser rediscutido em relação ao art. 27, § 1.º, CF/88, no sentido de saber se a necessidade de controle político para assegurar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ou não ser estendida aos parlamentares estaduais e do DF e, assim, no fundo, deliberar a Corte sobre a amplitude do referido art. 27, § 1.º.

Conforme já destacamos, o STF, em 08.05.2019, em votação apertada, por **6 x 5**, negou medidas cautelares nas **ADIs 5.823, 5.824 e 5.825**, prevalecendo o entendimento de que as regras da Constituição Federal relativas à imunidade dos deputados federais são aplicáveis aos deputados estaduais, e, portanto, poderia o Parlamento estadual sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função parlamentar, aplicando-se o art. 53, § 2.º, CF/88, conforme decidiu o STF no caso dos parlamentares federais no julgamento da **ADI 5.526** (DJE de 16.11.2020 — cf. *Inf. 939/STF*).

Em **16.12.2022**, com nova composição, o STF, também por **6 x 5**, julgou o mérito das ADIs 5.824 e 5.825, mantendo o entendimento de ser o art. 27, § 1.º, CF/88, **norma de reprodução obrigatória** no âmbito estadual e no do DF, declarando ser aplicável aos deputados estaduais (e aos do DF) “todo o estatuto dos congressistas que foi previsto em nível federal para os deputados e senadores”.

■ 9.9.2.2.4. *Imunidade formal ou processual para o processo (art. 53, §§ 3.º a 5.º)*

As regras sobre a **imunidade formal** para o **processo criminal** dos parlamentares sofreram profundas alterações pela **EC n. 35/2001**, mitigando a amplitude dessa “garantia”.

Antes da aludida reforma, os parlamentares não podiam ser processados sem a prévia licença da Casa, que, em muitos casos, não era deferida, ocasionando situações de verdadeira **impunidade**.

Conforme ponderou o Senador José Fogaça, relator do *Parecer n. 1.461/2001*, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do SF, “a alteração do instituto da imunidade parlamentar é passo imprescindível para a recuperação do prestígio do Poder Legislativo” (*DSF* de 13.12.2001, p. 30789-30790).

De acordo com a nova regra, então, oferecida a denúncia, o Ministro do STF poderá recebê-la **sem a prévia licença da Casa Parlamentar**. Assim, como já era permitido, poderão ser instaurados inquéritos policiais e processos de natureza civil, disciplinar ou administrativa, além do oferecimento da denúncia criminal. A novidade, como visto, reside no fato de que, oferecida a denúncia, poderá ela ser recebida no STF **sem a prévia licença da Casa respectiva**.

Pois bem, após o recebimento da denúncia contra o Senador ou Deputado, **por crime ocorrido após a diplomação**, o STF dará ciência à Casa respectiva, que, por **iniciativa de partido político** nela representado e pelo voto da **maioria absoluta** (*quorum* qualificado) de seus membros, poderá, até a decisão final, **sustar o andamento da ação**.

O **pedido de sustação** será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa Diretora, sendo que a sustação do processo **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato (cf. art. 53, §§ 3.º e 5.º).

Afinal de contas, o pedido de sustação poderá implementar-se até a **decisão final da ação penal movida contra o parlamentar** (art. 53, § 3.º), ou **no prazo improrrogável de 45 dias contados do seu recebimento pela Mesa Diretora** (art. 53, § 4.º)? As duas disposições devem ser harmonizadas, ou seja, a Casa respectiva tem até o final da ação penal para decidir, pelo *quorum* da **maioria absoluta** de seus membros, se suspende ou não a aludida ação penal. O pedido de sustação, pelo partido político, na respectiva Casa representado, poderá implementar-se logo após a ciência dada pelo STF ou

em período subsequente, não havendo prazo certo para tanto, já que, como visto, a **Casa** terá até o trânsito em julgado da sentença final proferida na ação penal para sustá-la. Apesar de não haver prazo certo, contudo, o período durante o qual a ação tramita (até o seu trânsito em julgado) deverá ser respeitado. O único prazo fixado é o de **45 dias** contado do recebimento, pela Mesa Diretora, do pedido de sustação efetuado pelo partido político. Esse prazo, sim, de 45 dias, é **improrrogável**.⁴³

Assim, de acordo com a nova regra trazida pela **EC n. 35/2001**:

■ **não há mais necessidade de prévio pedido de licença para se processar parlamentar federal no STF**, podendo, no máximo, a Casa legislativa, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, **sustar o andamento da ação penal de crime ocorrido após a diplomação**. Isso significa dizer que ainda há imunidade para o processo criminal contra o parlamentar, só que de maneira mitigada, já que, para o seu implemento, ela dependerá de ação da Casa, e não de sua inação, como se verificava antes. Conforme argumentou José Fogaça, “... não se elimina a possibilidade de o parlamento sustar um processo criminal contra um de seus membros quando verificar que esse está carregado de um viés exclusivamente político, mas não se permite a impunidade pelo simples fato de não haver decisão” (*DSF* de 13.12.2001, p. 30789-30790);

■ **não há mais imunidade processual em relação a crimes praticados antes da diplomação**. Diferentemente das regras fixadas para crimes praticados após a diplomação, pela nova sistemática não haverá necessidade de o STF dar ciência à respectiva Casa de ação penal de crime praticado **antes da diplomação**. Nessas hipóteses, por conseguinte, **não poderá**, também, a respectiva Casa, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, **sustar o andamento da aludida ação**.⁴⁴

Essa última situação, que era uma realidade quando da promulgação da EC n. 35/2001, perde sentido com o novo entendimento estabelecido pelo STF em relação à prerrogativa de foro, já que o STF só julgará **crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas** (AP 937 QO, j. 03.05.2018 — cf. *item 9.9.2.3.5*).

Por fim, imagine-se a situação de ter havido sustação do processo em crime praticado **após a diplomação**, em concurso de agentes por parlamentar e outro indivíduo que não goze da referida imunidade. Nesses casos, o **STF**, por motivo de conveniência, decidiu pelo **desmembramento do processo** (art. 80, CPP), em razão da diferença do regime de prescrição, visto estar suspenso somente o prazo prescricional em relação ao parlamentar (cf. STF, Inq. 1.107/MA, Rel. Min. Octavio Gallotti).

■ 9.9.2.3. *Prerrogativa de foro (“foro privilegiado”) (art. 53, § 1.º)*

De acordo com o art. 53, § 1.º, CF/88, “os Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a **julgamento** perante o **Supremo Tribunal Federal**”.

Primeira pergunta: a competência originária do STF para processar e julgar os parlamentares federais se dará em relação às ações de natureza cível e criminal ou apenas criminal?

A resposta está no art. 102, I, “b”, CF/88, que estabelece a competência originária do STF para processar e julgar, “nas **infrações penais comuns**, o Presidente da República, o Vice-Presidente, **os membros do Congresso Nacional**, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”.

Assim, a competência originária do STF se refere apenas ao julgamento das **infrações penais comuns** praticadas pelos Deputados e Senadores da República. Matéria de natureza cível, em tese, será julgada pelo juiz de primeira instância. Eventuais crimes de responsabilidade praticados por parlamentares federais serão apreciados pela respectiva Casa legislativa.

Segunda pergunta: nas hipóteses de infração penal comum, sabendo que a competência originária é do STF, quem deverá julgar: o Plenário ou uma das Turmas (órgão fracionário)?

Inicialmente, a competência para julgar os Deputados e Senadores por infrações penais comuns era do **Plenário** do STF (art. 5.º, I, *RISTF*, em sua redação original).

Com o tempo, contudo, observou-se um aumento muito grande da quantidade de processos e, como consequência, **uma sobrecarga de trabalho do Plenário** para o julgamento dos processos criminais. Isso se deve, certamente, a ações como o denominado “Mensalão” (AP 470), que tomaram a pauta por muitas sessões.⁴⁵

Dentro da ideia de efetividade do processo e racionalização dos julgamentos, observamos alteração regimental e a ampliação da competência das **Turmas**, que passaram a julgar os Deputados e Senadores (*vide*, por exemplo, as Emendas Regimentais n. 45/2011 e 49/2014), exceto os Presidentes das Casas, liberando as pautas do Plenário, cujas sessões são realizadas apenas às quartas e quintas-feiras da semana.

Em **2020**, essa regra foi alterada, resgatando-se a competência do **Plenário** (aprovação da **Emenda Regimental n. 57/2020** em sessão administrativa do Tribunal).

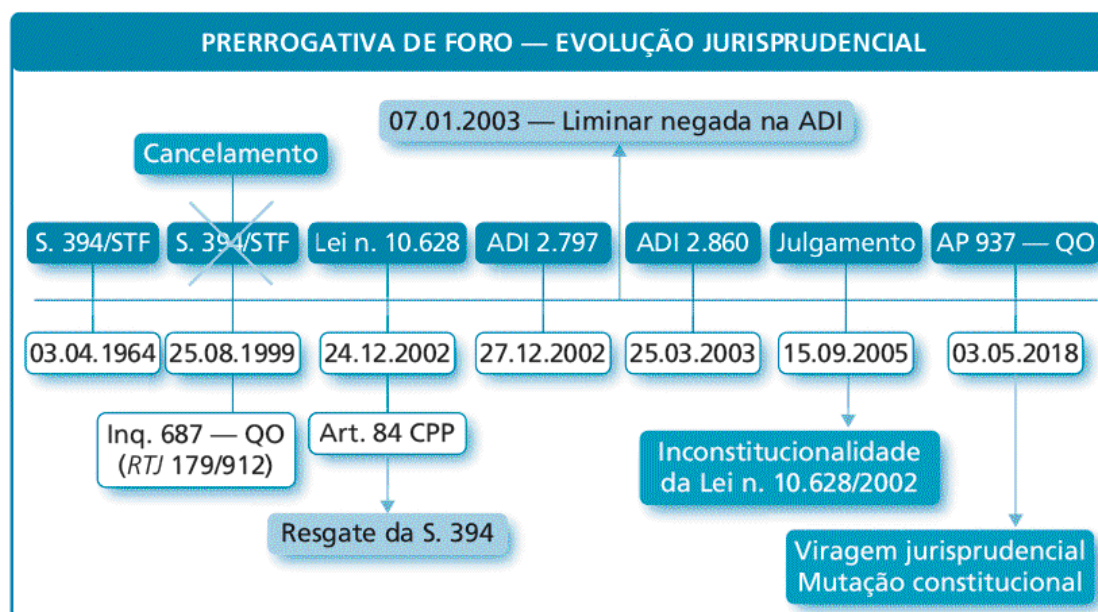
Conforme justificou o Min. Fux, então Presidente da Corte, “a partir do momento em que o Supremo modificou seu entendimento quanto à prerrogativa de foro dos parlamentares federais, **restringindo sua competência apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas**, a quantidade de procedimentos criminais em tramitação foi substancialmente reduzida, com a remessa de ações a outras instâncias. Ele observou que, no último dia 5, tramitavam no Tribunal 166 inquéritos e 29 ações penais, contra 500 inquéritos e 89 ações penais em tramitação em 2018, quando se alterou esse entendimento” (*Notícias STF*, 07.10.2020).

Três anos depois, tudo se modificou novamente. Em **nova alteração regimental**, a competência para o julgamento das infrações penais praticadas por Deputados e Senadores voltou a ser das **Turmas** do STF, tendo em vista um novo acúmulo de ações no Plenário, decorrente, também, dos episódios de 8 de janeiro de 2023, que, segundo afirmou o Min. Barroso, Presidente do STF, “trouxeram de volta ao Tribunal o panorama de excesso de processos e de possível lentidão na sua tramitação e julgamento”. Conforme declarou, “esse cenário recomenda atribuir **parte** da competência penal às Turmas para garantir a eficiência nos casos criminais e sua resolução definitiva, em observância à **garantia constitucional da razoável duração do processo**” (sessão administrativa de 07.12.2023, *Notícias STF*, 08.12.2023). Com a nova alteração regimental, a regra ficou a seguinte:

■ **Turmas:** competência para processar e julgar os Deputados e Senadores nas infrações penais comuns;

■ **Plenário:** competência para processar e julgar, dentre outras autoridades, o **Presidente** do Senado Federal e o **Presidente** da Câmara dos Deputados por crimes comuns praticados.

■ 9.9.2.3.1. *Cancelamento da S. 394/STF*



Na vigência da Constituição de 1946, o STF editou a **S. 394**, com a seguinte redação: “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício” (aprovada em 03.04.1964).

No julgamento da questão de ordem no Inq 687, contudo, o STF determinou o **cancelamento** da referida Súmula. Isso porque, conforme se sustentou, “a tese consubstanciada nessa Súmula não se refletiu na Constituição de 1988, ao menos às expressas, pois, no art. 102, I, ‘b’, estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar ‘os membros do Congresso Nacional’, nos crimes comuns”, não contemplando, portanto, os “ex-membros do Congresso Nacional”.

Ficou claro no julgamento que “a prerrogativa de foro visa a garantir o exercício do cargo ou do mandato, e não a proteger quem o exerce. Menos ainda quem deixa de exercê-lo. Aliás, a prerrogativa de foro perante a Corte Suprema, como expressa na Constituição brasileira, mesmo para os que se encontram no exercício do cargo ou mandato, não é contraditória no Direito

Constitucional Comparado. Menos, ainda, para ex-exercentes de cargos ou mandatos. Ademais, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são, também, os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos” (**Inq. 687 QO**, j. 25.08.1999).

Nesse sentido e pelas razões expostas, preferimos utilizar a expressão “prerrogativa de foro” à expressão “foro privilegiado”, pois, no fundo, não se pode pensar o instituto como um privilégio de determinada pessoa, mas, de maneira precisa, como uma prerrogativa decorrente do (efetivo) exercício da função.

Toda definição de competência para o julgamento dos tribunais está na Constituição, podendo se reconhecer, então, um inegável **postulado de reserva constitucional de competência originária**. Assim, para se ter um exemplo, o STF julga tudo, mas somente aquilo que está expressamente previsto no art. 102, CF/88. O STJ julga o que está no art. 105. A Justiça Federal, no art. 109. A Justiça do Trabalho, no art. 114 etc.

Dessa forma, a ampliação de competência originária dos tribunais não poderá ser implementada por lei, mas, no caso, por reforma constitucional ou eventual processo informal de mudança (mutação constitucional).

Para ilustrar esse entendimento, lembramos a aprovação da **Lei n. 10.628, de 24.12.2002**, que, introduzida no final do mandato de diversos Parlamentares, “ressuscitou” a já banida e execrada regra da *perpetuatio jurisdictionis* após o término do mandato das autoridades. Em nosso entender, a nova regra, retrógrada, ao manter o foro privilegiado para os crimes praticados durante o mandato, é flagrantemente inconstitucional, já que veiculada por lei ordinária e não por emenda constitucional, ferindo, desta feita, o princípio da separação de Poderes.

Tendo por objeto a referida lei, foram propostas a **ADI 2.797**, ajuizada em 27.12.2002 pela *Associação Nacional dos Membros do MP (CONAMP)*, e que teve seu pedido de liminar negado pelo STF (07.01.2003), e a **ADI 2.860**, proposta pela *Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)*,

distribuída por prevenção, em 25.03.2003, àquela primeira ajuizada pela CONAMP.

Por maioria de votos (7 x 3), em 15.09.2005, o Plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade do foro especial para ex-ocupantes de cargos públicos e/ou mandatos eletivos.

Posteriormente, em 17.05.2012, os **embargos declaratórios** opostos pelo Procurador-Geral da República na ADI 2.797 foram **acolhidos**, por maioria, pelo Plenário, para assentar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1.º e 2.º do art. 84, CPP, inseridos pelo art. 1.º da Lei n. 10.628/2002, terão **eficácia a partir de 15.09.2005**. “Na espécie, alegava-se que a norma declarada inconstitucional teria vigido por 3 anos — com alterações nas regras de competência especial por prerrogativa de função quanto às ações de improbidade, inquéritos e ações penais — a exigir fossem **modulados** os efeitos do julgado. Destacou-se a necessidade de se preservar a validade dos atos processuais praticados no curso das mencionadas ações e inquéritos contra ex-ocupantes de cargos públicos e de mandatos eletivos julgados no período de **24.12.2002**, data de vigência da Lei n. 10.628/2002, até a data da declaração de sua inconstitucionalidade, **15.09.2005** (*vide* quadro acima). Pontuou-se que inúmeras ações foram julgadas com fundamento na Lei n. 10.628/2002 e, por segurança jurídica, necessário adotar-se a **modulação**, assegurada a eficácia *ex nunc*, nos termos do **art. 27 da Lei n. 9.868/99**. Asseverou-se que os **processos ainda em tramitação não teriam sua competência deslocada para esta Corte**” (*Inf. 666/STF — grifamos*).

■ 9.9.2.3.2. **Caso “Gulliver”. “Ciranda dos processos”. “Valsa processual”. AP 333 (j. 05.12.2007)**

Neste item, propomos a análise da seguinte questão: o ato de **renúncia** de parlamentar constitui gesto legítimo para afastar a prerrogativa de foro?

Para tanto, lembramos o polêmico caso decorrente da **renúncia** do ex-Deputado Federal R. C. L. (PSDB-PB), que, nos autos da **AP 333**, estava sendo acusado do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra o ex-Governador da Paraíba, Tarcísio Burity, por ter, consoante narra a denúncia, efetuado disparos de arma de fogo em um restaurante de João Pessoa (de nome “Gulliver” e, por isso, ter ficado conhecido o caso por este nome).

De acordo com o relatório da referida ação penal, ao tempo dos fatos, o denunciado (R. C. L.) era Governador do Estado da Paraíba. Por esse motivo, a denúncia foi oferecida perante o STJ (art. 105, I, “a”).

R. C. L., nas eleições de 1994, elege-se Senador da República, e nas duas eleições que se seguiram, Deputado Federal, sendo que o seu último mandato terminaria em 31.12.2010.

Assim, sendo ele **parlamentar federal**, nos termos do art. 53, § 1.º, já estudado, expedido o diploma, a competência para julgar R. C. L. passou a ser do **STF** (muito embora ao tempo dos fatos — 05.11.1993 — fosse Governador da Paraíba).

Durante a ação penal (tendo sido a denúncia recebida em 2002), houve amplo direito de defesa, e se tentou ouvir uma testemunha por mais de 1 ano.

Em 31.10.2007, faltando 5 dias para o início do julgamento, já marcado pelo STF, R. C. L. renunciou ao mandato de Deputado Federal (legislatura 2007-2010).

A polêmica se instaurara. Não sendo mais Deputado Federal, ou seja, passando a ser uma pessoa comum, o STF deixava de ser competente, segundo a orientação firmada a partir do cancelamento da S. 394 e, também, ao se declarar inconstitucional a Lei n. 10.628/2002?

O tema se mostrou bastante complicado, tanto é que a votação estava empatada em 4 x 4. Parte dos Ministros entendia que a renúncia caracterizava “evidente propósito de frustrar o julgamento pelo STF”, verdadeiro **“abuso de direito”**, e outros 4 achavam que a renúncia tinha sido legítima.

Ao final, em 05.12.2007, por 7 x 4, os Ministros entenderam que a competência do Supremo cessava ao ter R. C. L. deixado de ser Deputado Federal, mesmo na hipótese de renúncia. Como afirmou Celso de Mello, invocando o princípio do **juiz natural**, a renúncia é inquestionável. “Foi recebida e gerou efeitos, antes do julgamento final do processo em curso, sendo um desses efeitos a cessação da competência do STF para julgá-lo” (*Notícias STF*, 05.12.2007).

Por esse motivo, passando a ser pessoa comum, sem prerrogativa de foro, os autos foram remetidos para o **Juízo Criminal da Comarca de João Pessoa**.

Dada a importância do tema, pedimos vênia para transcrever a ementa do referido acórdão, que deixa claro, também, o afastamento da competência do júri quando o acusado tem prerrogativa de foro:

■ “EMENTA: Ação penal. Questões de ordem. Crime doloso contra a vida imputado a parlamentar federal. Competência do STF *versus* competência do tribunal do júri. **Norma constitucional especial**. Prevalência. Renúncia ao mandato. Abuso de direito. Não reconhecimento. Extinção da competência do STF para julgamento. Remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. 1. O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal, detém prerrogativa de foro perante o STF, onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra a vida. 2. A norma contida no art. 5.º, XXXVIII, da CR, que garante a instituição do júri, cede diante do disposto no art. 102, I, ‘b’, da Lei Maior, definidor da competência do STF, dada a especialidade deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. 3. **A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do STF para o juízo criminal de primeiro grau**. Ausente o abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato. 4. Autos encaminhados ao juízo atualmente competente” (**AP 333**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 05.12.2007, *DJE* de 11.04.2008).

Como se verifica, os autos iniciaram a sua tramitação no STJ (Governador de Estado), tendo sido remetidos para o STF (SF e CD) e, agora, para a Justiça Comum. Essa situação, bastante criticada, foi denominada pelo Min. Gilmar Mendes “**ciranda dos processos**”, levando-o inclusive a repensar um eventual e futuro resgate da atualmente cancelada S. 394 do STF (cf. *Notícias STF*, 1.º.07.2008 — *íntegra da entrevista coletiva*). Em outra oportunidade, o Min. Joaquim Barbosa denominou esse “vai e volta” de “**valsa processual**”.

■ 9.9.2.3.3. ***Renúncia ao mandato. Manutenção da competência do STF. Abuso de direito. Fraude processual inaceitável: AP 396 (j. 28.10.2010)***

O tema da prerrogativa de foro veio a ser reanalisado pelo STF em outro caso polêmico: a **AP 396**, julgada em **28.10.2010**.

De acordo com as *informações públicas contidas no site do STF*, apurava-se suposto esquema a caracterizar os crimes de **formação de quadrilha** e **peculato**, envolvendo, dentre outros, o ex-Deputado Federal N. D. (PMDB-RO) (*Inf. 606/STF* e *Notícias STF*, 28.10.2010).

No caso em análise, o *MP do Estado de Rondônia* instaurou “... procedimento investigatório a partir de representações em que se questionava a licitude de contrato publicitário firmado entre a Assembleia Legislativa local e determinada empresa. No decorrer das apurações, o *parquet* constataria a existência de suposto esquema criminoso — engendrado para desviar dinheiro daquela Casa Legislativa — no qual o réu, na qualidade de diretor financeiro da Assembleia Legislativa, teria assinado vários cheques e os repassado, por mais de 2 anos, à mencionada empresa de publicidade a pretexto de pagamento pelos serviços, sequer prestados. Em razão disso, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público daquela unidade federativa oferecera denúncia contra o parlamentar e outros 7 corréus por formação de quadrilha e peculato, em concurso material e de pessoas. Após o recebimento da inicial acusatória pela Corte de origem, o réu fora empossado

Deputado Federal e o processo, **desmembrado, remetido ao STF**, que assim o mantivera e afirmara a validade dos atos judiciais praticados anteriormente à diplomação e à posse do parlamentar federal” (*Inf. 606/STF*).

Muito embora a decisão proferida no caso do “mensalão” no sentido de julgamento de todos os corréus em um mesmo processo (**Inq. 2.245**), a regra que o STF vem adotando é, havendo prerrogativa de foro de um dos envolvidos, o **desmembramento** do processo, com base na **conveniência da instrução** e na **racionalização dos trabalhos**.

No caso em referência, a denúncia foi oferecida em **24.06.1999** pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, porque ainda não havia a prerrogativa de foro. Contudo, em **03.01.2005**, N. D. tomou posse como Deputado Federal, para exercício do mandato na *Legislatura 2003-2007*, quando, então, por esse motivo, o juiz da 3.^a Vara Criminal da Comarca de Porto Velho (RO) determinou o **desmembramento** dos autos, com a **remessa** do processo para o **STF**, em razão da prerrogativa de foro.

A ação foi distribuída, no STF, em **16.08.2005** e, às vésperas do julgamento — **27.10.2010** —, o Deputado Federal **renunciou** ao mandato, sendo que o crime prescreveria no dia **04.11.2010**.

Eis o cronograma dos fatos:

- **24.06.1999** — oferecimento de denúncia na comarca de Porto Velho;
- **03.01.2005** — posse como Deputado Federal;
- **16.08.2005** — a ação é distribuída no STF;
- **22.10.2010** — inclusão do feito em pauta é publicada no *DJE*;
- **27.10.2010** — o Deputado Federal renuncia ao mandato;
- **28.10.2010** — o STF resolve questão de ordem e reconhece a subsistência da competência da Corte mesmo diante da hipótese de renúncia ao mandato;
- **04.11.2010** — haveria a prescrição do crime.

Revedo o julgamento proferido no caso do ex-Deputado Federal R. C. L. (AP 333), no qual o STF, por 7 x 4, entendia que a renúncia (no caso, faltando 5 dias para o julgamento) era válida e, assim, cessaria a competência

do STF, por **8 x 1**, modificando o seu entendimento, **decidiu**, em 28.10.2010, **julgar a ação (AP 396)**, mantendo a sua competência, mesmo não sendo mais o réu parlamentar, e condenando-o à pena de reclusão de 13 anos, 4 meses e 10 dias, em regime inicialmente fechado, além de 66 dias-multa, pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288, CP) e peculato (art. 312, CP).

Temos, assim, um **novo entendimento do STF**, que, a nosso ver, mostra-se **muito acertado**.

Dentre os vários argumentos expendidos pelos Ministros para se manter a competência do STF, a renúncia, às vésperas do julgamento, caracterizou-se como **“fraude processual inaceitável”**, frustrando a atuação jurisdicional do Estado e tornando, assim, o STF **refém** da opção do réu. Sustentou-se, ainda, tratar-se a atitude de verdadeiro **abuso de direito**. “A Constituição garante a imunidade, mas não a impunidade.” A fraude à lei mostra-se, ainda, “eticamente pouco sustentável”, não podendo o STF aceitar a “... manipulação de instâncias para efeito de prescrição”, citando-se, por fim, a afirmação de Ulpiano, segundo a qual “não se pode tirar proveito da própria torpeza”.⁴⁶

■ 9.9.2.3.4. ***Nova tentativa de fixação de tese de julgamento sobre a prerrogativa de foro. Inexistência de fraude processual e abuso de direito. Afastamento do risco de prescrição da pena em abstrato: AP 536 (j. 27.03.2014)***

O tema sobre a manutenção da competência do STF em caso de renúncia ao mandato de parlamentar federal foi retomado no julgamento da **AP 536** (27.03.2014, *DJE* de 12.08.2014).

De acordo com os autos, “o ex-parlamentar e outros réus foram denunciados pelo Procurador-Geral da República pela suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, em concurso material e em concurso de pessoas. Houve o desmembramento do processo no Supremo e a AP 536 passou a tramitar apenas contra E. A., por ele ser deputado federal à

época. A denúncia foi recebida pelo Supremo no dia 3 de dezembro de 2009. Posteriormente, o réu foi interrogado e as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. Em 7 de fevereiro de 2014, o Procurador-Geral da República apresentou alegações finais e, reiterando os termos da denúncia, pediu a aplicação de uma pena de 22 anos de prisão. No dia 19 de fevereiro de 2014, o réu comunicou ao Supremo que havia renunciado ao mandato de deputado” (*Notícias do STF* de 27.03.2014).

Nesse caso concreto, o STF entendeu não ter havido fraude processual e abuso de direito e, assim, determinou, depois de mais de 9 anos de tramitação do feito, a sua **remessa** para o juízo de primeiro grau.

Diferentemente do entendimento firmado na AP 396, houve o afastamento do risco de prescrição da pena em abstrato e não se reconheceu, como dissemos, a caracterização de abuso de direito.

Propôs, então, o Min. Roberto Barroso, Relator, a definição de um critério geral mais objetivo para o reconhecimento da fraude em casos futuros, sustentando a aplicação analógica do art. 55, § 4.º, CF/88, e, portanto, o marco temporal do recebimento da denúncia. Muito embora acompanhado por outros 3 Ministros, **infelizmente, no referido julgado, não houve maioria absoluta para a definição do marco temporal, deixando a Corte essa fixação para outro momento.**

■ 9.9.2.3.5. ***Viragem jurisprudencial. Novo entendimento da Corte. Mutação constitucional: AP 937 QO (j. 03.05.2018)***

O tema da **prerrogativa de foro** voltou a ser analisado pelo STF na apreciação da questão de ordem na **AP 937**, suscitada pelo Min. Barroso, Relator, em 15.02.2017 (*DJE* de 20.02.2017). Vejamos a **cronologia dos fatos** para, em seguida, descrever a nova posição da Corte, estabelecendo marcante viragem jurisprudencial (mutação constitucional):

■ **Eleições municipais de 2008:** suposta prática de crime;

■ **Outubro de 2008:** o suposto autor do crime foi reeleito Prefeito de município do Rio de Janeiro;

■ **1.º.01.2009:** assume a Prefeitura;

■ **30.01.2013:** recebimento de denúncia pelo TRE do RJ, pela suposta prática do crime de captação ilícita de sufrágio. Porém, como já havia encerrado o mandato de Prefeito, o TRE anulou o recebimento da denúncia e declinou a competência em favor do Juízo da 256.ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro;

■ **14.04.2014:** Juízo eleitoral de 1.ª instância recebe a denúncia;

■ **Outubro/2014:** o ex-Prefeito é eleito suplente de Deputado Federal pelo Rio de Janeiro;

■ **10.02.2015:** diplomado Deputado Federal, em razão de afastamento de Deputados de seu partido;

■ **14.04.2016:** deixa o cargo de Deputado Federal, em razão do retorno dos Deputados que haviam sido afastados;

■ **19.04.2016:** assume novamente como Deputado Federal, em razão do afastamento do titular;

■ **13.09.2016:** assume **definitivamente** como Deputado Federal, em razão da perda de mandato do titular;

■ **1.º.01.2017:** renúncia ao mandato de Deputado Federal para assumir como Prefeito de município do Rio de Janeiro (terceiro mandato);

■ **15.02.2017:** o Relator da AP 937 **suscita questão de ordem** a ser apreciada pelo Pleno do STF, sustentando, diante da “disfuncionalidade do foro por prerrogativa de função”, a possibilidade de conferir interpretação restritiva às normas constitucionais que disciplinam o assunto;

■ **31.05.2017:** iniciado o julgamento pelo **Pleno do STF**, o Min. Relator lança tese propondo interpretação restritiva às normas constitucionais que tratam sobre a prerrogativa de foro, limitando as competências jurisdicionais aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas por parlamentares federais;

■ **1.º.06.2017 — 29.09.2017 (pedido de vista e devolução dos autos para julgamento):** após o voto do Min. Marco Aurélio, acompanhando em parte o Ministro Relator, e os votos das Mins. Rosa Weber e Cármen Lúcia (Presidente), acompanhando o Ministro Relator, pediu vista dos autos o Min. Alexandre de Moraes (**4 Ministros** — o Relator e mais três Ministros sustentando as teses lançadas);

■ **23.11.2017 — 27.03.2018 (pedido de vista e devolução dos autos):** após o voto-vista do Min. Alexandre de Moraes, acompanhando, em parte, o Relator, nos termos de seu voto, e após os votos dos Mins. Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, acompanhando integralmente o Relator, pediu vista dos autos o Min. Dias Toffoli. Dentre os 8 votos já computados, 6 sustentavam integralmente as teses lançadas (o Relator e outros 5 Ministros);

■ **02.05.2018:** após os votos dos Mins. Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, acompanhando em parte o Relator, nos termos de seus votos, o julgamento foi suspenso;

■ **03.05.2018:** O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, tendo o Min. Dias Toffoli reajustado o seu voto, resolveu questão de ordem no sentido de confirmar as teses lançadas (6 Ministros acompanharam integralmente as duas teses) e, por consequência, determinou o retorno dos autos para o juízo eleitoral da 1.^a instância, aplicando já o novo entendimento.

Observando a cronologia dos fatos acima descritos, o suposto delito teria sido cometido em 2008, quando o réu disputou a Prefeitura de determinado município do Rio de Janeiro, tendo sido a ação penal proposta em razão de indicada, e ainda a ser apurada, prática do crime de captação ilícita de sufrágio — corrupção eleitoral (art. 299, Código Eleitoral). Como foi eleito, o caso começou a ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, descreve o Min. Barroso, de acordo com a denúncia, nas eleições municipais de 2008, o réu teria angariado votos para se eleger Prefeito, por meio da entrega de notas de R\$ 50,00 e da distribuição de carne aos eleitores (fls. 2-A/2-D). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) recebeu a denúncia em 30.01.2013 (fls. 329/331). No entanto, com o encerramento do mandato do réu como Prefeito, o Tribunal Regional Eleitoral declinou de sua competência em favor do Juízo da 256.^a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro (fls. 355). Na sequência, o TRE, em sede de *habeas corpus*, anulou o recebimento da denúncia e os atos posteriores, já que, à época, o acusado “já não ocupava o cargo que lhe deferia foro por prerrogativa de função” (fls. 443/449). O Juízo eleitoral de 1.^a instância proferiu, então, nova decisão de recebimento da denúncia em 14.04.2014 (fls. 452/456) e realizou a instrução processual, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu (*descrição apresentada em decisão proferida pelo Relator na AP 937, afetando a questão ao Pleno do STF, j. 15.02.2017*).

Em momento seguinte, o réu foi diplomado Deputado Federal, em razão de ser 1.^o Suplente e ter ocorrido o afastamento dos Deputados eleitos. Nesse sentido, os autos foram remetidos para o STF. Quase um ano depois, ele teve que se afastar, pois os Deputados eleitos reassumiram os cargos. Em seguida, assumiu em definitivo, pois foi declarada a perda do mandato do titular.

Finalmente, novamente eleito Prefeito de mesma cidade do Rio de Janeiro (3.^o mandato, não consecutivo), renunciou ao mandato de Deputado Federal para assumir a Prefeitura em 1.^o.01.2017.

Na medida em que os autos ainda estavam no STF, o Min. Barroso, Relator, **suscitou a questão de ordem** para enfrentar o tema da **prerrogativa de foro**. Descrevendo uma problemática, qual seja, o que chamou de **“disfuncionalidade prática do regime de foro”**, sustentou a necessidade de se repensar o instituto, seja por alteração constitucional (lembramos que o Senado Federal aprovou a **PEC 10/2013**), seja por drástica mudança de interpretação constitucional (mutação constitucional), a partir de três razões:

■ **razões filosóficas:** “trata-se de uma reminiscência aristocrática, não republicana, que dá privilégio a alguns, sem um fundamento razoável”;

■ **razões estruturais:** “Cortes Constitucionais, como o STF, não foram concebidas para funcionarem como juízos criminais de 1.º grau, nem têm estrutura para isso. O julgamento da Ação Penal 470 (conhecida como Mensalão) ocupou o Tribunal por um ano e meio, em 69 sessões”;

■ **razões de justiça:** “o foro por prerrogativa é causa frequente de impunidade, porque dele resulta maior demora na tramitação dos processos e permite a manipulação da jurisdição do Tribunal”.

No dia 03.05.2018, 6 Ministros aderiram integralmente às seguintes teses, estabelecendo que a nova linha interpretativa (inegável viragem jurisprudencial, a partir de mutação constitucional) deva ser **aplicada imediatamente aos processos em curso**, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). Vejamos:

■ “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”; e

■ “após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.

Cabe lembrar que o Min. Barroso, em 19.12.2017, antes mesmo desse desfecho dado pelo Pleno, tendo em vista o que chamou de “improbabilidade de reversão da orientação” que já havia se firmado e que já contava com o apoio de 8 Ministros (já que o caso específico se enquadrava também na linha do entendimento firmado pelos Mins. Alexandre de Moraes e Marco Aurélio), no julgamento do **Inq. 3.026, monocraticamente, declinou a**

competência remetendo os autos do inquérito para a primeira instância, já que determinado Deputado Federal estava “sendo investigado pela prática, em tese, de crimes contra a Administração Pública cometidos durante o exercício da presidência da Câmara de Vereadores de Natal, entre 2005 e 2006” e, portanto, por supostos crimes sem nenhuma relação com a função parlamentar desempenhada.

Para ele, o caso específico (Inq. 3.026) retratava a mencionada **“disfuncionalidade”** do sistema: “o processo já tramitou em quatro jurisdições: no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Justiça do Estado, na primeira instância da justiça estadual e encontra-se de volta ao STF”.

Conforme observou — e entendemos interessante descrever a problemática da questão e a nova orientação que está sendo sedimentada na Corte, “a restrição do foro aqui proposta — como a restrição do foro em geral — resolve, sobretudo, os problemas que ele acarreta para o Supremo Tribunal Federal. Dentre eles, a **politização indevida da Corte**, a criação de **tensões com o Congresso Nacional** e o **desprestígio junto à sociedade**, por se tratar de uma competência que ele **exerce mal**. Há uma visão atrasada que ainda prevalece em alguns espaços da vida brasileira de que quanto mais competências se têm, maior a quantidade de poder. Nesta visão, o poder não é uma forma de fazer o bem e promover justiça, mas um instrumento para proteger os amigos e perseguir os inimigos. Já é boa hora de se superarem os ciclos do atraso institucional e existencial no Brasil”.

Mas alertou a inegável e problemática **disfunção**: “a restrição do foro **não resolve** o problema da **impunidade** entre nós. Quanto a esta, além de fatores superestruturais, como a cultura da desigualdade, a seletividade do sistema e a crença de que a criminalidade do colarinho branco não tem grande gravidade, é preciso enfrentar um sistema processual penal obsoleto, baseado no oficialismo e na cultura da procrastinação, voltada a prolongar indefinidamente os processos, seja no cível, seja no crime. **O Poder Judiciário, no Brasil, acaba sendo o refúgio dos que não têm razão (...)**” (fls. 5 da decisão).

Conforme vimos, a nova linha interpretativa estabelecida pelo Pleno do STF no julgamento da questão de ordem na AP 937 deve se **aplicar imediatamente aos processos em curso**, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízes com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inq. 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).

Esse entendimento, que sofreu críticas por parte da doutrina em razão de alegada **violação à garantia do juiz natural**, já é realidade incontornável no STF e tem motivado, por parte dos Ministros, a imediata remessa de processos criminais e inquéritos para os juízes de 1.^a instância nos termos da tese fixada, destacando-se, por exemplo: as ações penais n. 607, 907, 928, 945, 956, 970, 991, 1.004 e os inquéritos n. 3.611, 3.850, 4.125, 4.306, 4.510, entre tantos outros.

Destacamos importante crítica feita pelos Mins. Dias Toffoli e Gilmar Mendes no sentido de se estender o novo entendimento para todas as autoridades, pois não faria sentido que a nova interpretação valesse apenas para 513 Deputados e 81 Senadores, quando, em verdade, como se sabe, mais de 50.000 autoridades ostentam a prerrogativa, muitas vezes estabelecida em Constituições estaduais, que têm fixado a prerrogativa para Procuradores de Estado, Secretários, Defensores Públicos etc.

Diante dessa situação, no dia 09.05.2018, o Min. Dias Toffoli encaminhou à Min. Cármen Lúcia, Presidente do STF, o **Ofício n. 10/2018-GMDT**, propondo a edição de duas súmulas vinculantes, com a seguinte redação (**PSV 131/2018**):

■ **“Súmula Vinculante n. (x):** A competência por prerrogativa de foro, prevista na Constituição Federal para agentes públicos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público, compreende exclusivamente os crimes praticados no exercício e em razão do cargo ou da função pública”;

■ **“Súmula Vinculante n. (xx):** São inconstitucionais normas de Constituições Estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria”.

Conforme observou, a prerrogativa de foro constitui exceção ao princípio republicano e, assim, disse o Ministro, deve ser interpretada restritivamente. Nesse sentido, faz total sentido seguir a linha do decidido pela Corte na AP 937 QO e restringir a prerrogativa em relação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados a funções desempenhadas.

Essa observação está perfeita, até porque não se pode pensar a prerrogativa relacionada à pessoa, mas, por outro, à função desempenhada. Por esse motivo, preferimos a expressão “prerrogativa de foro” à “foro privilegiado”, pois, como se disse, não se pode pensar o instituto como um privilégio de alguém, mas, em verdade, como uma prerrogativa que decorra do **efetivo** exercício da função.

A partir do **silêncio eloquente** sobre a prerrogativa de foro no art. 27, § 1.º, CF/88 (que manda aplicar aos parlamentares estaduais as regras sobre imunidades previstas para os parlamentares federais, não falando nada sobre foro), tem razão ao afirmar que a competência para legislar sobre direito processual é da União e não dos Estados e do DF, sustentando, assim, a inconstitucionalidade dessas disposições.

Em nossa opinião, o STF já poderia ter definido o tema no dia da votação do precedente em análise, conforme proposto pelos Mins. Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Infelizmente, contudo, teremos que aguardar a solução a ser dada em processos isolados, bem como no julgamento da referida proposta de súmula vinculante, não se tendo perspectivas de quando serão apreciadas (pendentes).

Finalmente, a decisão do STF orientará a linha restritiva de interpretação dada ao instituto. Pioneiramente, logo após a decisão do STF, 2 dias depois!, o Min. Luis Felipe Salomão do STJ, **monocraticamente**, determinou a baixa dos autos para a 1.^a instância em que figurava como réu o Governador de Estado por suposta prática de crimes de responsabilidade de Prefeito e, portanto, sem relação com o cargo de Governador (**AP 866/STJ**, j. 07.05.2018 — acolhida pelo Órgão Especial em 20.06.2018).

Destacamos, ainda, decisão restritiva proferida pelo STJ, enaltecendo a **contemporaneidade** e a **pertinência temática** para se estabelecer a prerrogativa de foro. Assim, mesmo no caso de reeleição, o STJ entendeu que a competência deveria ser do juízo de 1.^a instância para crime cometido durante o mandato anterior (fazendo valer, inclusive, a regra da **unidade de legislatura**, destacando o **isolamento dos mandatos** para se aplicar a interpretação estabelecida pelo STF (**QO na AP 874-DF**, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, j. 15.05.2019).

No fundo, o STJ não adentrou na discussão da tese 2 fixada pelo STF, que estabeleceu, de modo claro, um verdadeiro “**marco temporal** uniforme e objetivo de *perpetuatio jurisdictionis* que se aplica a todos os casos de investidura ou desinvestidura de cargo com foro privilegiado, independentemente de abuso processual” (voto do Min. Barroso, fls. 826 do acórdão publicado na AP 937 QO).

Resgatemos, novamente, a tese 2 estabelecida pelo STF: “após o **final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais**, a competência para processar e julgar ações penais **não será mais afetada** em razão de o agente público vir a ocupar **outro** cargo ou **deixar o cargo** que ocupava, qualquer que seja o motivo”.

E se for **reeleito** e a apuração do fato criminoso praticado durante o exercício do primeiro mandato e relacionado à função já estiver em fase avançada, ou seja, a ação penal já estiver em fase posterior ao final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para

apresentação de alegações finais, nesse caso, haveria *perpetuatio jurisdictionis*?

Pela tese 2 fixada pelo STF, **apesar de não ter descrito essa situação de reeleição**, parece que sim.

A situação fática da discussão do STJ é muito particular (réu no 4.º mandato de Governador — 2.ª reeleição, sendo discutido fato criminoso supostamente praticado no 2.º mandato — 1.ª reeleição, com intervalo de exercício de cargo de Senador da República).

Em certa medida, parece que o STF, na tese 2 fixada na AP 937 QO, resgata alguma lógica da cancelada **S. 394**, claro que bem diferente, pois o marco temporal é bem mais avançado. Pensamos, contudo, que melhor seria a observância da contemporaneidade e pertinência temática, ou seja, findo o mandato, finda a prerrogativa, salvo em caso de fraude processual — renúncia, quando, então, faria sentido adotar um marco temporal.

Conforme se observa, a proposta de súmula vinculante encaminhada não entra nessa questão de definição de marco temporal em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, ou, ainda, vir a ser reeleito. Certamente, um tema que irá mobilizar novamente a Corte.

E qual o motivo de estarmos nesta nova edição do livro resgatando esse tema da prerrogativa de foro?

Certamente o tema será novamente apreciado pelo STF diante das novidades introduzidas pela **Nova Lei de Abuso de Autoridade** (Lei n. 13.869/2019), que ampliou, significativamente, os tipos penais, explicitando os sujeitos do crime.

Referida lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer **agente público**, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

- servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
- membros do Poder Legislativo;
- membros do Poder Executivo;
- membros do Poder Judiciário;
- membros do Ministério Público;
- membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei n. 13.869/2019, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo *caput* do art. 2.º dessa lei.

Nesse sentido, esperamos que o STF decida com rapidez a **PSV n. 131/2018**, analisando, também, a questão do marco temporal objetivo (que não está na proposta).

Apesar de ainda não termos decisão formal pelo Pleno do STF (pendente no fechamento desta edição), a 1.ª Turma da Suprema Corte ampliou o entendimento nos seguintes termos: a *ratio decidendi* do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937” (**Inq. 4.703-QO**, j. 12.06.2018).

Ainda, a Corte admitiu a (manutenção da) competência do STF na hipótese de parlamentares federais em duas situações, flexibilizando a ideia de necessário nexo de causalidade direto com a função exercida:

- **continuidade do cargo exercido (mesmo cargo)**: a 1.ª Turma do STF flexibilizou a regra estabelecida na AP 937-QO para reconhecer a manutenção da prerrogativa de foro na hipótese de continuidade no

cargo exercido, sendo exercidas as mesmas funções (**REs 1.240.599-AgR** e **1.253.213-AgR**, j. 08.06.2020);

■ **mandatos cruzados:** “o Tribunal, por maioria (8 x 3), deu provimento ao agravo regimental, para assentar a **manutenção da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal** em hipóteses como a dos presentes autos, em que verificada a existência de ‘mandatos cruzados’ **exclusivamente de parlamentar federal**, ou seja, de parlamentar investido, sem solução de continuidade, em mandato em casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da competência originária (art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Rosa Weber (Relatora), Roberto Barroso e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 30.4.2021 a 11.5.2021 (**PET 9.189**, j. 14.05.2021)”.

Apesar desse alargamento, em vários outros precedentes a Corte estabeleceu que “as normas que estabelecem o foro por prerrogativa de função são **excepcionais** e devem ser **interpretadas restritivamente**, não cabendo ao legislador constituinte estadual estabelecer foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas listadas na Constituição Federal, a qual não cita defensores públicos nem procuradores” (**ADI 6.501**, Pleno, j. 23.08.2021, *Inf. 1.026/STF*). Nesse sentido, estabeleceu-se a seguinte tese:

■ “É inconstitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria”.

■ **9.9.2.4. *Foro por prerrogativa de função e jurisdições de categorias diversas — a discussão sobre o desmembramento***

As prerrogativas de foro são definidas pela Constituição em relação às autoridades no exercício efetivo da função. Assim, de acordo com o entendimento fixado pela Corte, por exemplo e conforme visto, um ex-parlamentar não teria mais a referida prerrogativa com o término do seu mandato ou nas citadas hipóteses de fraude.

Contudo, em razão de **circunstâncias especiais** a serem apreciadas, demonstradas e justificadas em cada caso concreto, lembrando que, nos termos do art. 78, III, CPP, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, poder-se-á deliberar no sentido do julgamento conjunto de todos os corréus (cf. *Inf. 673/STF*).

Esse entendimento, negando o desmembramento, foi o que se verificou no julgamento do “mensalão” (**Inq. 2.245** e correspondente **AP 470**), no qual, dos 38 réus, apenas 3 eram parlamentares, e, diante dessa circunstância, decidiu a Corte, em razão da prerrogativa, no sentido da competência do STF para o julgamento de **todos**⁴⁷ os réus. Vejamos:

“Questão de ordem. Inquérito. Desmembramento. Art. 80 do CPP. Critério subjetivo afastado. Critério objetivo. **Inadequação ao caso concreto**. Manutenção integral do inquérito sob julgamento da Corte. Rejeitada a proposta de adoção do critério subjetivo para o desmembramento do inquérito, nos termos do art. 80 do CPP, resta o critério objetivo, que, por sua vez, é **desprovido de utilidade no caso concreto**, em face da **complexidade do feito**. Inquérito não desmembrado. Questão de ordem resolvida no sentido da **permanência**, sob a jurisdição do **STF**, de **todas** as pessoas denunciadas” (**Inq 2.245-QO-QO**, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.12.2006, Plenário, *DJ* de 09.11.2007, e entendimento mantido na solução de questão de ordem que se colocou na correspondente **AP 470**, em 02.08.2012 — cf. outros detalhes do tema no *item 10.4.14.4*).

Devemos deixar claro, contudo, que o **desmembramento** é a **regra**. Somente em situações **excepcionalíssimas** é que deve haver o julgamento conjunto no Tribunal com jurisdição de maior graduação. (Remetemos o

nosso ilustre leitor para o *item 10.4.14.4*, no qual desenvolvemos a matéria e trazemos importante tentativa de *roteirização* proposta pelo Min. Roberto Barroso no julgamento do **Inq 3.515 AgR/SP**, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.02.2014, Plenário, *DJE* de 25.02.2014.)

■ 9.9.2.5. *Outras garantias*

■ **sigilo de fonte:** de acordo com o art. 53, § 6.º, e conforme já estabelecido antes do advento da **EC n. 35/2001**, “os Deputados e Senadores não serão obrigados a **testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações”;

■ **incorporação às forças armadas de Deputados e Senadores:** “a incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, **dependerá de prévia licença da Casa respectiva**” (art. 53, § 7.º, mantida a referida garantia na **EC n. 35/2001**);

■ **imunidades durante a vigência de estado de sítio e de defesa:** como regra geral, durante a vigência desses estados de anormalidade, os parlamentares não perdem as imunidades. Apenas durante o **estado de sítio** as imunidades poderão ser **suspensas**, mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida (art. 53, § 8.º, regra essa mantida pela **EC n. 35/2001**).

■ 9.9.2.6. *As imunidades parlamentares podem ser renunciadas?*

Imaginem vocês, candidatos que se preparam para concursos públicos, que, em determinado momento, o examinador formule as seguintes questões:

■ José da Silva, deputado federal, no exercício do mandato, portanto, após a diplomação, comete um crime. Recebida a denúncia no STF, após ser dada ciência ao Parlamento há **sustação do andamento da ação**. O deputado, inconformado com a acusação, faz questão de ser processado, para provar a sua inocência. Que deverá fazer? Como as imunidades parlamentares dizem respeito ao cargo que ocupa e não à pessoa, a única maneira que o parlamentar encontrará para provar a sua inocência será esperar o término do mandato, ou renunciar de imediato, para que perca, então, a imunidade;

■ José da Silva, deputado federal, na tribuna, em empolgante discurso, declara que o governo federal desviou verba do erário público, de forma irregular. Em meio à empolgação, diz ter dados seguros e, inclusive, diz renunciar às suas imunidades para provar que fala a verdade. Isso é possível? Não, na medida em que as imunidades são irrenunciáveis. Caso fale isso, podemos encarar como mera demagogia política!

Portanto, devemos observar, mais uma vez, que as **imunidades parlamentares são irrenunciáveis** por decorrerem da função exercida, e não da figura do parlamentar.

Assinalou Celso de Mello que “o instituto da imunidade parlamentar atua, no contexto normativo delineado por nossa Constituição, como condição e garantia de **independência do Poder Legislativo**, seu real destinatário, em face dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora **não** constitua uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de **prerrogativa de caráter institucional**, inerente ao Poder Legislativo, que só é conferida ao parlamentar ‘*ratione muneris*’, em função do cargo e do mandato que exerce. É por essa razão que **não se reconhece ao congressista**, em tema de imunidade parlamentar, **a faculdade de a ela renunciar**. Trata-se de garantia institucional deferida ao Congresso Nacional. **O congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre ela, qualquer poder de disposição**” (Inq. 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 1.º.02.1991, Plenário, RTJ 135/509).

■ 9.9.2.7. *As imunidades parlamentares estendem-se aos suplentes?*

As imunidades parlamentares são prerrogativas que decorrem do efetivo exercício da função parlamentar. Não são garantias da pessoa, mas prerrogativas do cargo. Assim, as imunidades, inclusive a prerrogativa de foro, **não** se estendem aos suplentes, a não ser que assumam o cargo ou estejam em seu efetivo exercício (cf. Inqs. 2.453-AgR, 2.421-AgR e 2.800).

■ 9.9.3. **Parlamentares estaduais e do DF**

Aos **Deputados Estaduais** (cf. art. 27, § 1.º) serão aplicadas as **mesmas regras** previstas na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, **imunidades**, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Todo esse entendimento deve ser aplicado em relação aos Deputados Distritais, na medida em que o art. 32, § 3.º, CF/88 determina a aplicação das regras do art. 27.

O STF, por 6 x 5, negou medidas cautelares nas **ADIs 5.823, 5.824 e 5.825**, nas quais se discute a extensão a deputados estaduais das imunidades formais prescritas para os parlamentares federais, tendo prevalecido o entendimento de que as regras da Constituição Federal relativas à imunidade dos deputados federais são aplicáveis aos deputados estaduais (j. 08.05.2019).

Em **16.12.2022**, com nova composição, o STF, também por **6 x 5**, julgou o mérito das ADIs 5.824 e 5.825, mantendo o entendimento de ser o art. 27, § 1.º, CF/88 **norma de reprodução obrigatória** no âmbito estadual e no do DF, declarando ser aplicável aos deputados estaduais (e aos do DF) “todo o estatuto dos congressistas que foi previsto em nível federal para os deputados e senadores”.

■ 9.9.4. **Parlamentares municipais**

De acordo com o art. 29, VIII, como já visto, os Municípios reger-se-ão por lei orgânica, que deverá obedecer, dentre outras regras, à da **inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município**.

Ou seja, o Vereador Municipal somente terá **imunidade material** (excluindo-se a responsabilidade penal e a civil), desde que o ato tenha sido praticado *in officio* ou *propter officium* (devendo haver, assim, **pertinência** com o exercício do mandato) e na **circunscrição municipal**, não lhe tendo sido atribuída a imunidade formal ou processual. Nesse sentido, precisas são as palavras do Min. Celso de Mello:

“EMENTA: 1. A garantia constitucional da **imunidade parlamentar em sentido material** (CF, art. 29, VIII, c/c o art. 53, *caput*) **exclui a responsabilidade penal** (e também **civil**) do membro do Poder Legislativo (Vereadores, Deputados e Senadores), por manifestações, orais ou escritas, desde que **motivadas pelo desempenho do mandato (prática in officio)** ou **externadas em razão deste (prática propter officium)**. Tratando-se de Vereador, a inviolabilidade constitucional que o ampara no exercício da atividade legislativa estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos, **mesmo fora do recinto da própria Câmara Municipal**, desde que **nos estritos limites territoriais do Município a que se acha funcionalmente vinculado**. Precedentes. AI 631.276/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, *v.g.*). 3. Essa prerrogativa político-jurídica — que protege o parlamentar (como os Vereadores, p. ex.) em tema de responsabilidade penal — incide, de maneira ampla, nos casos em que as declarações contumeliosas tenham sido proferidas no recinto da Casa legislativa, notadamente da tribuna parlamentar, hipótese em que será absoluta a inviolabilidade constitucional. Doutrina. Precedentes” (AI 818.693, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 1.º.08.2011, DJE de 03.08.2011. No mesmo sentido, cf. HC 74.201, j. 12.11.1996).

Reafirmando o entendimento, o STF estabeleceu que a locução *no exercício do mandato* “deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como **proteção adicional à liberdade de expressão**, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo” (**RE 600.063**, j. 25.02.2015, *DJE* de 15.05.2015).

Além disso, nos termos do art. 29, IX, a lei orgânica também deverá observar as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto na CF para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa.

■ 9.10. INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DOS PARLAMENTARES FEDERAIS

Em decorrência de sua nobre função, aos parlamentares é vedado o exercício de algumas atividades, bem como determinados comportamentos, desde a **expedição do diploma** e, posteriormente, após tomarem **posse**. Os Deputados e Senadores **não poderão**, enuncia o art. 54, I e II, CF/88:

I — DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA	■ firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; ■ aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.
II — DESDE A POSSE	■ ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; ■ ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, “a”; ■ patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, “a”; ■ ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

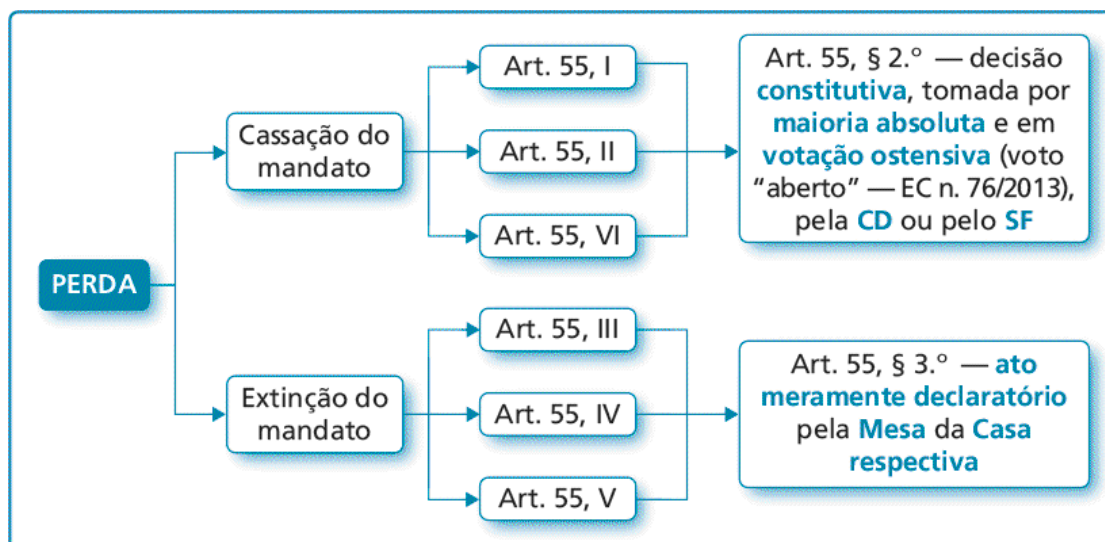
■ 9.11. PERDA DO MANDATO DO DEPUTADO OU SENADOR

■ 9.11.1. Hipóteses de perda do mandato e suas peculiaridades

O art. 55, CF/88, estabelece que perderá o mandato o parlamentar federal:

HIPÓTESES DE PERDA DO MANDATO (ART. 55)	PECULIARIDADES
I — quando o parlamentar infringir qualquer das proibições estabelecidas no art. 54 (quadro anterior);	§ 2.º a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal , por maioria absoluta , mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
II — cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ;	§ 1.º É incompatível com o decoro parlamentar , além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Nesta hipótese, de acordo com o § 2.º do art. 55, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal , por maioria absoluta , mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
III — que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva , de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
IV — que perder ou tiver suspensos os direitos políticos (Obs.: sabemos ser, na vigência da CF/88, vedada a cassação de direitos políticos. Porém, o art. 15, CF/88, estabelece hipóteses de	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva , de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso

perda e suspensão);	Nacional, assegurada ampla defesa.
V — quando o decretar a Justiça Eleitoral , nos casos previstos nesta Constituição;	§ 3.º a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva , de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
VI — que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.	§ 2.º a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal , por maioria absoluta , mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.



■ 9.11.2. Cassação⁴⁸ x extinção do mandato

Pela regra fixada no art. 55, § 2.º, CF/88, na hipótese de **cassação do mandato**, a sua perda será **decidida** pela **Câmara dos Deputados** ou pelo **Senado Federal**, por **maioria absoluta**, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Em se tratando de **extinção**, por outro lado (art. 55, § 3.º), a perda será **declarada** pela **Mesa da Casa respectiva**, de ofício ou mediante

provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Dessa forma, na primeira situação (cassação — **decisão** — pela Casa), o provimento político terá natureza **constitutiva**. Na segunda (extinção — **declaração** — pela Mesa), a natureza será **declaratória**.

Cassação do mandato, ensina José Afonso da Silva,⁴⁹ “é a **decretação** da **perda** do mandato por ter seu titular incorrido em falta funcional definida em lei e punida com esta sanção”. **Extinção do mandato**, por seu turno, define-se como “o **perecimento** do mandato pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente **inexistente a investidura eletiva**, tal como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões expressamente fixado (desinteresse, que a Constituição eleva à condição de renúncia), perda ou suspensão dos direitos políticos”. Nesse caso, trata-se de provimento meramente **declaratório**, pois a Mesa apenas reconhece (por declaração) a ocorrência do fato ou ato do **perecimento do mandato**.⁵⁰

■ 9.11.3. **Votação aberta na hipótese de cassação do mandato: aprovação da “PEC do voto aberto” (EC n. 76/2013). Avanço democrático**

Conforme visto, nas hipóteses de **cassação do mandato** (art. 55, I, II e VI), de acordo com a Constituição, a perda do mandato será **decidida** pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, nos termos do art. 55, § 2.º.

Aperfeiçoando a regra estabelecida pelo constituinte originário, a *EC n. 76/2013* **aboliu a votação secreta** nos casos de perda de mandato de Deputado ou de Senador. Dessa forma, a votação deverá ser **ostensiva**, ou seja, **aberta**, para que o povo saiba como os seus representantes votaram em relação a situações extremamente graves como a condenação criminal de parlamentar.

■ 9.11.4. **A perda do mandato parlamentar em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado e a interpretação**

fixada pelo STF no julgamento da AP 470 (“mensalão”), bem como da AP 565 (art. 15, III, x art. 55, §§ 2.º e 3.º). O caso concreto da AP 396.⁵¹ Proposta de exceção objetiva à regra geral (MS 32.326 e APs 694 e 863)

Conforme já anunciamos anteriormente, em um primeiro momento o STF entendeu que, na hipótese de condenação de **réus parlamentares** pela prática, entre outros, de **crimes contra a Administração Pública**, tendo em vista tratar-se de conduta juridicamente incompatível com os deveres inerentes ao cargo, impunha-se “a perda do mandato como medida adequada, necessária e proporcional” (**AP 470**, j. 17.12.2013).⁵²

Evoluindo, contudo, a Corte mudou o entendimento e passou a reconhecer a especialidade do art. 55, § 2.º, no sentido de a perda do cargo depender de decisão da Casa (**AP 565**, j. 08.08.2013).

A) AP 470 — “mensalão” — j. 17.12.2012 (primeira orientação, superada em momento seguinte)

O tema precisava ser esclarecido pela Suprema Corte, que o fez, em um **primeiro momento**, em julgamento apertado, por **5 x 4**, ao decidir que os três Deputados Federais condenados **na AP 470** (“mensalão”) e que ainda exerciam o mandato, quais sejam, João Paulo Cunha (PT/SP), Pedro Henry (PP/MT) e Valdemar Costa Neto (PR/SP), perderiam, **automaticamente**, os seus mandatos com o **trânsito em julgado** da **sentença penal condenatória**.

A decisão, muito embora tenha sido proferida pela maioria exigida, deu-se sem estar completo o Plenário da Corte.

O Min. Teori Albino Zavascki, apesar de já ter tomado posse em **29.11.2012**, em razão da vaga deixada pelo Min. Cezar Peluso, aposentado em setembro ao completar 70 anos, não participou do referido julgamento.

Ainda, no momento da decisão (17.12.2012), encontrava-se também em aberto a vaga do Min. Ayres Britto, aposentado compulsoriamente desde 17.11.2012, nos termos do Decreto Presidencial de 14.11.2012, e que veio a ser preenchida somente com a indicação e posse do Min. Luís Roberto Barroso em 26.06.2013.

Portanto, 9 Ministros, naquele momento, resolveram a questão. Estando empatado em 4 x 4 (no sentido ou não da perda automática do mandato, em razão da sentença penal condenatória transitada em julgado), o Min. Celso de Mello, em 17.12.2012, proferiu o voto de desempate, determinando a aplicação do art. 55, § 3.º, CF/88, que apenas atribui ao Parlamento o poder de **declarar** a perda do mandato, e não o de **decidir** sobre a sua concretização, afastando-se, assim, a regra contida no art. 55, § 2.º.

De acordo com a sua decisão, “... todos os condenados por **mais de 4 anos de reclusão** ou cuja condenação diga respeito a **ato de improbidade administrativa** — o que ocorre nos crimes contra a administração pública, tais como peculato e corrupção passiva, deve implicar **automaticamente a perda dos mandatos eletivos**. E, neste caso, a perda deve ocorrer, no entender do ministro Celso de Mello, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, como no crime de peculato, punido com penas que vão de 2 a 12 anos de reclusão. Já quanto aos demais casos, isto é, em condenações por tempo inferior e por delitos de menor potencial ofensivo, caberá à Câmara, no entendimento do ministro Celso de Mello, deliberar sobre a perda ou não do mandato, conforme previsto no parágrafo 2.º do artigo 55 da Constituição Federal” (*Notícias STF*, 17.12.2012).

Cabe observar que, além desses argumentos trazidos pelo Min. Celso de Mello, o STF estabeleceu que, uma vez **transitado em julgado o processo** (*Inf. 693/STF*):

- por unanimidade, ficam **suspensos os direitos políticos de todos os réus condenados**, com base no **art. 15, III**, CF;
- por maioria, fica **decretada a perda de mandato eletivo** dos Deputados Federais acusados na ação penal;
- as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos previstas no art. 15, CF, são taxativas;
- o Poder Legislativo pode decretar a perda de mandato de Deputado Federal ou Senador, com fundamento em perda ou suspensão de direitos políticos, bem assim em condenação criminal transitada em julgado (art.

55, IV e VI, CF). Essa previsão constitucional, contudo, **vincula-se aos casos em que a sentença condenatória não decretar a perda de mandato**, em razão de não estarem presentes os requisitos legais (art. 92, I, “a” e “b”, e parágrafo único, CP),⁵³ ou alguma legislação especial, como a Nova Lei de Abuso de Autoridade — art. 4.º, III e parágrafo único⁵⁴), ou por ter sido proferida anteriormente à expedição do diploma, com o trânsito em julgado ocorrente em momento posterior;

■ não se aplica o art. 55, CF (juízo político), uma vez que a **perda de mandato eletivo** caracteriza-se como **efeito irreversível da sentença condenatória**;

■ de acordo com o art. 55, § 3.º, introduzido pela EC n. 35/2001, estabeleceu-se a possibilidade de **suspensão do processo**, com o objetivo de se evitar que o parlamentar seja submetido a perseguição política. Na medida em que essa situação não se verificou, o feito poderia seguir o seu trâmite regular;

■ os réus cometeram **crimes contra a Administração Pública** quando no exercício do cargo, a revelar conduta **incompatível** com o exercício de mandato eletivo.

Ressalte-se que esse **primeiro entendimento** sobre a perda automática do mandato não refletia a jurisprudência do STF que, de modo instável (lembrando que o placar foi fixado por **5 x 4**), modificou-se sem a composição completa da Corte.

Isso porque, conforme se observa pelos precedentes indicados abaixo, o STF **entendia** ser a regra do **art. 55, § 2.º**, CF/88, **especial** sobre a regra geral do art. 15, III (nesse sentido, preciso o voto do Min. Dias Toffoli, apesar de vencido, nesse primeiro momento, proferido no julgamento do “mensalão”):

■ **MS 21.443/DF** (j. 22.04.1992): não obstante a decisão tenha analisado uma situação concreta de falta de decoro parlamentar (art. 55, II), assim definiu o Min. Paulo Brossard: “observadas as formalidades constitucionalmente enunciadas, a decisão, da Câmara ou do Senado,

poderá ser discutível, poderá ser injusta, poderá ser desacertada, mas será definitiva e irrecorrível; será insuscetível de revisão judicial. Porque a Constituição deu à Câmara e só à Câmara, ao Senado e só ao Senado, a competência para decidir algo que à Câmara e ao Senado diz respeito”.

■ **RE 179.502** (j. 31.05.1995): apesar de ser a questão diferente, na linha do voto do Min. Relator Moreira Alves, pelo princípio da especialidade, a regra do art. 55, VI e § 2.º, deveria prevalecer sobre a regra geral do art. 15, III (*lex speciali derogat lex generali*). Nesse sentido, bastante elucidativo o voto do Min. Celso de Mello.

Esse entendimento, que então **prevalecia** no STF, superado naquele primeiro momento da análise da AP 470, parecia seguir a *ratio* da regra prevista pela *Assembleia Nacional Constituinte* que acolheu, por 407 votos (16 contrários e 6 abstenções, de um total de 429), a **Emenda n. 1.895 — Modificativa** do texto do “Centrão” (de autoria do Constituinte **Antero de Barros**, destacada pelo Constituinte Fernando Lyra), para fixar, com precisão, a regra especial do art. 55, §§ 2.º e 3.º, sendo que, no caso, como explicou o Constituinte Nelson Jobim, teria o objetivo de, em relação à condenação criminal (embora estivessem preocupados, na discussão, com os **crimes de menor potencial ofensivo**, reconheça-se), entregar a decisão, que seria política, ao Plenário das Casas respectivas, não sendo a perda do mandato automática.⁵⁵

O STF, contudo, de modo explícito, definiu **posicionamento**, estabelecendo interpretação harmonizadora dos dispositivos em antinomia (arts. 15, III, e 55, VI, § 2.º) a partir do substrato axiológico de normas constitucionais (**ética e moralidade na administração pública, isonomia e princípio republicano**).

B) AP 565 — MUDANÇA DE ENTENDIMENTO — aplicação da regra especial do art. 55, § 2.º — a perda do mandato depende de deliberação da Casa — j. 08.08.2013

CUIDADO: em momento seguinte, como se apontou, no julgamento da **AP 565**, em **08.08.2013**, agora com os votos do Min. Teori Zavascki e do Min. Luís Roberto Barroso, por 6 x 4 (o Min. Fux não votou porque se declarou impedido, pois já havia julgado o caso concreto quando era Ministro do STJ), o STF decidiu **que a perda do mandato parlamentar não é automática e depende de manifestação da Casa**, declarando a regra do art. 55, § 2.º, **especial** em relação à geral contida no art. 15, III.

Ainda, ficou estabelecido que a perda do mandato a ser **decidida** pela Casa não impediria o réu parlamentar de cumprir a pena imposta. Assim, a Corte, reconhecendo o não cabimento de qualquer outro recurso, certificou o trânsito em julgado, determinou fosse lançado o nome dos réus no rol dos culpados e expediu os competentes mandados de prisão.

C) AP 396 e a EC n. 76/2013 (fruto da aprovação da “PEC do voto aberto”) — histórica primeira votação aberta

Pois bem, diante desse novo posicionamento, qual seja, o de que a perda do mandato não é automática, em outro caso, envolvendo a condenação de Deputado Federal à pena de mais de 13 anos de reclusão, em regime fechado, por formação de quadrilha e peculato (**AP 396**, N. D.), diante da *Representação n. 20/2013*, levou-se à Câmara dos Deputados a discussão sobre a perda do mandato parlamentar.

Em **28.08.2013**, a Casa **manteve** o mandato do deputado federal que cumpria pena. Isso mesmo, estávamos diante da estranha situação de se ter um deputado federal mantido no cargo e cumprindo pena em regime fechado.⁵⁶

Essa situação gerou a revolta da sociedade e, sem dúvida, serviu para a mobilização do Congresso Nacional.

Procurando “escutar a voz das ruas”, o Parlamento passou a analisar duas propostas de emenda: **a)** “PEC do voto aberto” (pois, naquele momento, a votação ainda era secreta); **b)** PEC que estabelece a perda imediata do mandato de parlamentar condenado por crimes contra a Administração Pública.

A primeira foi aprovada e promulgada como **EC n. 76/2013**. A segunda, até o fechamento desta edição, ainda estava sendo discutida no Parlamento (*matéria pendente*), apesar dos avanços trazidos pela **Nova Lei de Abuso de Autoridade** (Lei n. 13.869/2019).

Em se tratando de aplicação da Nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019), apenas para destacar, o art. 4.º, III, define serem **efeitos da condenação** a **perda** do **cargo**, do **mandato** ou da **função pública**. Esses efeitos, contudo, são **condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade**, não sendo automáticos, **devendo ser declarados motivadamente na sentença** (art. 4.º, parágrafo único, da Lei n. 13.869/2019).

Voltando aos efeitos práticos da aprovação da “PEC do voto aberto”, em 12.02.2014, em nova votação e à luz da regra introduzida pela EC n. 76/2013, a Câmara dos Deputados **cassou**, por 467 votos favoráveis e 1 abstenção, o mandato do Deputado Federal N. D., assumindo, assim, de modo definitivo o seu suplente.

A sociedade presenciou a **histórica primeira votação aberta** na Câmara dos Deputados, “corrigindo” o dito “erro político” cometido na primeira votação (pelo voto fechado) que o manteve no cargo (*Agência Câmara Notícias*).

Esse novo julgamento teve por objeto a **Rep. 22/2013**, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e que apontou dois motivos para a **quebra do decoro** (art. 55, II — portanto, outro fundamento): a) ter o deputado votado no processo de perda do seu próprio mandato, violando o regimento interno (art. 180, § 6.º); b) ter saído, nas dependências externas da Câmara, “algemado e transportado de camburão do serviço penitenciário para o Presídio da Papuda, em Brasília”, o que afetaria a imagem da Casa.

D) MS 32.326 e APs 694 e 863 — proposta de exceção objetiva à regra geral — j. 02.09.2013, 02.05.2017 e 23.05.2017

Conforme se observou, a regra geral é a contida no art. 55, VI e § 2.º, que estabelece a necessidade de **decisão** da Casa Legislativa, **por voto aberto**, para deliberação sobre a perda do mandato em razão de condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Estabelecida a regra, vamos imaginar uma situação específica para, então, enunciar a exceção objetiva, constitucionalmente descrita: suponha que a condenação criminal tenha fixado pena privativa de liberdade, em **regime inicial fechado**, por período de tempo que seja superior ao restante do mandato, ou que, por estar encarcerado, o parlamentar deixe de comparecer, por impossibilidade física já que está preso!, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, ou, ainda, por essas razões, que o seu afastamento ultrapasse 120 dias o período da sessão legislativa.

Nesses casos, parece ter razão a proposta sugerida pelo **Min. Barroso** em decisão monocrática proferida no **MS 32.326** (j. 02.09.2013), que serviu de paradigma para novos pronunciamentos da 1.ª Turma do STF no julgamento da **AP 694** (Rel. Min. Rosa Weber, j. 02.05.2017) e da **AP 863** (Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2017), que estabeleceu a perda automática do mandato como resultado direto e inexorável da condenação.

Apesar de se tratar de decisão monocrática, seguida de decisão de uma das Turmas do STF **e não do Plenário**, sem dúvida, estamos diante de exceção objetiva bastante convincente.

Conforme estabeleceu o Min. Barroso, “a Constituição prevê, como regra geral, que cabe a cada uma das Casas do Congresso Nacional, respectivamente, a **decisão** sobre a perda do mandato de Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Esta regra geral, no entanto, não se aplica em caso de condenação em **regime inicial fechado, por tempo superior ao prazo remanescente do mandato parlamentar**. Em tal situação, a perda do mandato se dá **automaticamente**, por força da **impossibilidade jurídica e física de seu exercício**. Como consequência, quando se tratar de Deputado cujo prazo de prisão em regime fechado exceda o período que falta para a conclusão de seu mandato, **a perda se dá como resultado direto e inexorável da condenação**, sendo a decisão

da Câmara dos Deputados **vinculada** e **declaratória**” (MS 32.326, decisão monocrática proferida em 02.09.2013, fls. 17 da decisão).

E, ainda, “de acordo com a legislação em vigor e a interpretação judicial que lhe tem sido dada, o preso em **regime aberto** e **semiaberto** pode ser **autorizado à prestação de trabalho externo**, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Este tem sido o entendimento pacífico do STJ, podendo-se citar, exemplificativamente, os acórdãos proferidos no HC 251.107 e no HC 255.781 (...). Por outro lado, no tocante ao preso em **regime fechado**, a Lei de Execuções Penais (arts. 36 e 37) não apenas **restringe** o trabalho externo como exige o cumprimento mínimo de **1/6 da pena**. Reiterando: o preso em regime fechado tem **restrições severas ao trabalho externo**, além de não poder prestá-lo antes do cumprimento do sexto inicial da pena. Disso resulta que o condenado em regime inicial fechado, cujo período remanescente de mandato seja inferior a 1/6 (um sexto) da pena a que foi condenado — isto é, ao tempo mínimo que terá de permanecer necessariamente na penitenciária (LEP, art. 87) —, não pode conservar o mandato. É que, nessa situação, verifica-se uma **impossibilidade jurídica e física** para o exercício do mandato. Jurídica, porque uma das condições mínimas exigidas pela Constituição para o exercício do mandato é o comparecimento às sessões da Casa (CF, arts. 55, III, e 56, II). E física, porque ele simplesmente não tem como estar presente ao local onde se realizam os trabalhos e, sobretudo, as sessões deliberativas da Casa Legislativa” (fls. 15 e 16).

Essa orientação, conforme já mencionamos, foi adotada em momento seguinte pela 1.^a Turma do STF, que reconheceu hipóteses de afastamento por mais de 120 dias da sessão legislativa. Vejamos os julgados:

■ **AP 694:** “desmembramento da operação Sanguessuga, da Polícia Federal, na qual foi revelado um esquema criminoso, atuando em diversos estados, para o desvio de recursos públicos por meio da aquisição superfaturada, por prefeituras, de veículos — especialmente ambulâncias — e equipamentos médicos, com licitações direcionadas

para favorecer” determinado o grupo. “Segundo a acusação, caberia ao deputado federal apresentar emendas ao orçamento geral da União, destinadas a municípios das regiões norte e nordeste do Estado do Rio de Janeiro, para beneficiar as empresas do grupo.” Referido deputado foi condenado a 12 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 374 dias-multa pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (*Notícias STF*, 02.05.2017).

■ **AP 863:** de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o deputado federal P. M. “atuou na lavagem de dinheiro desviado de obras públicas e fez remessas ilegais ao exterior, por meio de doleiros. O deputado, conforme a acusação, participou de esquema de cobrança de propinas na Prefeitura de São Paulo, em 1997 e 1998, que continuou a contar com seu envolvimento direto nos anos seguintes”. A 1.^a Turma do STF condenou o deputado, pelo crime de lavagem de dinheiro, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 248 dias-multa (*Notícias STF*, 23.05.2017).

Em ambos os casos, a Corte entendeu a aplicação do art. 55, § 3.º. Assim, a perda do mandato deverá ser **declarada** pela **Mesa da Casa** e não decidida pelo plenário. Trata-se de provimento meramente declaratório sem a possibilidade de contestação da decisão judicial.

Apesar da autonomia do Parlamento para levar a questão à Mesa, em razão do seu próprio direito de agenda e da separação de poderes, sustentamos que, em caso de demora desarrazoada, o STF poderá fixar prazo para a implementação da decisão judicial com as consequências de seu eventual e criticável descumprimento.

Por todo o exposto, podemos esquematizar as seguintes situações nas quais a condenação criminal, como exceção à regra geral, ensejará a perda automática do mandato, havendo a necessidade de mera **declaração da Mesa** para a concretização da medida: